

Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR)

Band 135

Luzerner Dissertation bei Prof. Dr. Jürg-Beat Ackermann

Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR)

Herausgegeben von Jörg Schmid im Auftrag der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern

Band 135

Thierry Urwyler

**Das Teilnahmerecht der Verteidigung
am Explorationsgespräch des
psychiatrischen Sachverständigen
mit der beschuldigten Person im
Lichte der EMRK**

**Mit Fokus auf das Gutachten zur Schuldfähigkeit
und Massnahmenindikation**



Nomos

Schulthess § 2019

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, vorbehalten. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2019

ISBN 978-3-7255-8041-5 Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf

ISBN 978-3-8487-6251-4 NOMOS Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden

www.schulthess.com

www.nomos.de

Vorwort

«La procédure pénale est une des manifestations les plus révélatrices de la culture. En effet, elle codifie la manière dont on traite les comportements qui menacent la société; elle traduit la manière dont la société perçoit le rapport entre l'individu et la collectivité...»

Ständerat Pierre Bonhôte, Amtl. Bull. SR 2006, S. 985

Das Strafprozessrecht hat – treffender als Bonhôte kann man es kaum ausdrücken – kulturenthüllenden Charakter. Es kodifiziert die Art und Weise, wie mit gesellschaftsgefährdendem Verhalten umgegangen werden soll, und bringt die Beziehung zwischen Individuum und Kollektiv zum Ausdruck. Es ist das zum Gesetz erhobene Ergebnis einer hochkomplexen und facettenreichen Interessenabwägung. Steigt man eine Abstraktionsstufe hinab, zerfällt das Strafprozessrecht in fassbare, kontrovers diskutierte Einzelfragen. Eine davon lautet, ob die Verteidigung der beschuldigten Person berechtigt sei, am Explorationsgespräch ihrer Mandantin mit dem psychiatrischen Sachverständigen teilzunehmen. Die vorliegende Arbeit bejaht dies. Die zu diesem Ergebnis führenden Erwägungen mögen eines Tages – so die Hoffnung und Ambition des Verfassers – einen Teil des Fundaments für eine Änderung der Gerichtspraxis oder des Gesetzes bilden.

Die Dissertation trägt zwar lediglich meinen Namen. Die etwas über 250 Seiten sind aber nicht alleine das Resultat unzählbarer Stunden an individueller Kopf- und Schreibtischarbeit. Viele Pfeiler stützen dieses Gebäude. Prof. Dr. Jürg-Beat Ackermann, mein Doktorvater, gab mir alle Mittel in die Hand, das vorliegende Werk an seinem Lehrstuhl zu entwickeln und zu finalisieren. Sodann erstellte er in kürzester Frist ein tiefeschürfendes und anregendes Erstgutachten. Dafür gebührt Dir, Jürg, ein herzliches «Merci beaucoup!». Schön, dürfen wir die Zusammenarbeit in anderen Projekten weiterführen. Ebenso möchte ich Prof. Dr. Wolfgang Wohlers für sein zügig erstelltes und wertvolles Zweitgutachten danken. Sodann sei den bereits genannten Professoren und Prof. Dr. Andreas Eicker für ein anregendes Kolloquium gedankt. Last but (definitely) not least haben meine Familie, meine Partnerin, zahlreiche Freunde und Arbeitskollegen (sowohl an der Universität Luzern als auch im Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich) direkt oder indirekt zum Gelingen dieses Projekts beigetragen: Sei es durch fachliche Diskussionen über meinen Untersuchungsgegenstand, durch Förderbeiträge in zeitlicher oder sachlicher Hinsicht oder auch durch die emotionale Unterstützung während des Schreibprozesses. Auch dank Euch allen kann ich heute auf die Dissertationszeit zurückblicken und sagen: «What a ride!». Herzlichen Dank!

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Literaturverzeichnis	XIX
Materialienverzeichnis	XLIX
Abkürzungsverzeichnis	LI
1. Teil: Einleitung	1
§ 1 Themenaufriß	1
§ 2 Forschungsrahmen und -vorgehen	20
2. Teil: Verfassungsrechtliche und gesetzliche Ausgangslage	27
§ 3 Rahmenmodell des Verfassungsrechts	27
§ 4 Rahmenmodell der Strafprozessordnung	39
3. Teil: Das Teilnahmepostulat im Lichte des Rechts auf Stellungnahme zum Gutachten	55
§ 5 Prüfungsmodell des EGMR	55
§ 6 Position und Rolle des PSY-Sachverständigen	65
§ 7 Konventionswidrige Unüberprüfbarkeit der Explorationsinhalte	100
§ 8 Ermittlung konventionskompatibler Lösungsmodelle	132
4. Teil: Das Teilnahmepostulat im Lichte des Rechts auf Beizug der Verteidigung	165
§ 9 Prüfungsmodell des EGMR	165
§ 10 Konventionswidriger Ausschluss der Verteidigung	176
§ 11 Ermittlung konventionskompatibler Lösungsmodelle	226
Schlussbilanz	247
Sachregister	255

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Literaturverzeichnis.....	XIX
Materialienverzeichnis.....	XLIX
Abkürzungsverzeichnis.....	LI
1. Teil: Einleitung	1
§ 1 Themenaufriß	1
I. Leitstern: materielle Wahrheit.....	2
II. Herausforderung: Beweisführung zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation.....	2
1. Beweisfragen um die Schuldfähigkeit	3
2. Beweisfragen um die Massnahmenindikation	3
III. Lösung: Beizug von psychiatrischen Sachverständigen.....	4
IV. Mittel: Erhebungen des PSY-Sachverständigen.....	5
V. Schlüsselement: Explorationsgespräch.....	6
1. Relevanz des Untersuchungsmittels.....	6
2. Methodischer Rahmen der Exploration	7
A) Kernelemente der Erhebung	7
a) Anamnese.....	7
b) Psychischer Befund & Persönlichkeitsdiagnostik.....	8
c) Tatsachverhalt	8
d) Zukunft.....	10
B) Strukturierung des Explorationsablaufs.....	10
C) Gesprächsführungsmethodik	11
D) Prinzip des Drittpersonenausschlusses	12
VI. Resultat: Wahrheitsannäherung durch den Sachverständigenbeweis	13
VII. Preis: partieller Kontrollverlust über Sachverhaltserhebung und - würdigung.....	14
VIII. Konfliktzone: Kontrollmöglichkeiten der Verteidigung über das Explorationsgespräch	15
1. Postulat: Teilnahmerecht der Verteidigung an der Exploration.....	15
A) Begründungsstrang I: Überprüfbarkeit des Gutachtens.....	17
B) Begründungsstrang II: Wahrung der Verteidigungsrechte während des Explorationsgesprächs.....	18
2. Gegenmeinung: Exploration ≠ Einvernahme.....	18

3.	Spannungsfeld: Psychiatrische Methodik v. Verteidigungsrechte	19
§ 2	Forschungsrahmen und -vorgehen.....	20
I.	Untersuchungsgegenstand auf einen Blick	20
II.	Legitimation der Schwerpunktsetzung	21
1.	Fokus auf das Gutachten zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation.....	21
2.	Fokus auf die EMRK.....	22
III.	Untersuchungsetappen.....	25
2. Teil: Verfassungsrechtliche und gesetzliche Ausgangslage	27	
§ 3	Rahmenmodell des Verfassungsrechts	27
I.	Kernargumente der Teilnahmerechtsimmunisierung.....	27
1.	Genügen des Rechts auf Stellungnahme	28
A)	Ausserstrafprozessuale Leitlinien	28
B)	Strafprozessualer Gleichlauf.....	29
2.	Sonderrechtsprechung bei medizinisch-psychiatrischen Untersuchungen.....	30
A)	Schutz der Methodenfreiheit.....	30
a)	Methodenbedingter Ausschluss von Drittpersonen	30
b)	Methodenbedingte Anwesenheit von Drittpersonen	32
B)	Befürchtete Reflexwirkungen eines Teilnahmerechts	33
II.	Scheinargumente der Teilnahmerechtsimmunisierung	34
1.	Fehlender Beweiserhebungscharakter von sachverständigen Erhebungen	35
2.	Befürchteter Mangel an Sachverständigen.....	35
3.	Negation der Subjektstellung des Exploranden.....	36
4.	Mangelnder Beitrag des passiv anwesenden Rechtsbeistands an die Rechtspflege	37
III.	Fazit	37
§ 4	Rahmenmodell der Strafprozessordnung.....	39
I.	Motto: «Bewährtes beibehalten – Weiterentwicklungen wo notwendig»	40
1.	Orientierungspunkt I: Höherrangiges Recht.....	40
2.	Orientierungspunkt II: Bestand an kantonalen Regelungsansätzen	40
A)	Kantonalrechtliche Regelungen.....	41
B)	Teilnahmeimmunisierung des Explorationsgesprächs.....	42
3.	Zwischenfazit	43
II.	Gesetzgebungsverfahren: Bekenntnis zum Bewährten.....	44
1.	Vorparlamentarische Phase	44

2.	Parlamentarische Phase.....	45
A)	Ständerat.....	45
B)	Nationalrat.....	46
3.	Zwischenfazit.....	46
III.	Auslegungstreit um Art. 147 StPO.....	47
1.	Teilnahmerechtsfeindliche Auslegung.....	47
2.	Teilnahmerechtsfreundliche Auslegung.....	49
A)	Zweifel an der Klarheit des gesetzgeberischen Willens.....	49
B)	Analogie zur strafbehördlichen Beweiserhebung.....	49
C)	Verfassungs- und völkerrechtskonforme Auslegung.....	50
IV.	Stellungnahme.....	50
1.	Klarer Wille des Gesetzgebers.....	51
2.	Misslingen der StPO-Analogie zur Einvernahmnormierung.....	52
3.	Unzulässigkeit völker-/verfassungskonformen «Begradigung».....	52
4.	Fazit.....	53

3. Teil: Das Teilnahmepostulat im Lichte des Rechts auf Stellungnahme zum Gutachten..... 55

§ 5	Prüfungsmodell des EGMR.....	55
I.	Verortung des Prüfungsmodells in Art. 6 EMRK.....	55
II.	Fairnessprüfungssequenzen des EGMR.....	56
1.	Position und Rolle des Sachverständigen.....	57
A)	Relevanzkriterium.....	57
B)	Neutralitätskriterium.....	58
2.	Verteidigungsinstrumentarium.....	58
3.	Gesamtwürdigungsansatz.....	60
A)	Manifestation des Gesamtwürdigungsansatzes im Neutralitätskontext.....	61
B)	Manifestation des Gesamtwürdigungsansatzes im Kontext der Verteidigungsrechte.....	62
4.	Fazit.....	64
§ 6	Position und Rolle des PSY-Sachverständigen.....	65
I.	Relevanz des Sachverständigenbeweises.....	65
1.	Dimension der Sachverhaltsermittlung.....	66
A)	Leitbild: Ermittlungsverbot.....	66
B)	Fakt: Teildelegation der Ermittlung.....	66
2.	Dimension der Beweiswürdigung.....	68
A)	Leitbild: Gehilfe des Gerichts.....	68
B)	Fakt: Teildelegation der Beweiswürdigung.....	69
a)	Beweiswürdigung als rationalitätsgebundener Vorgang.....	70
b)	Sachverständigenbeweis als verkörperte Rationalität.....	71

c)	Grundsätzliche Bindung des Gerichts durch den Sachverständigenbeweis in Fachfragen.....	71
3.	Dimension der Rechtsanwendung	74
A)	Leitbild: iura novit curia	75
B)	Fakt: Teileinfluss des PSY-Gutachtens	75
a)	Schuldfähigkeitsgutachten.....	76
b)	Massnahmengutachten	79
c)	Normative Abstinenz als unzulängliches Remedium	85
II.	Neutralität des Sachverständigen.....	87
1.	Leitbild: Unabhängigkeit und Unparteilichkeit.....	87
2.	Fakt: systembedingte Neutralitätszweifel.....	89
A)	Vermengung von faktischer Ermittler- und Richterfunktion	89
B)	Beauftragung durch die Strafverfolgungsbehörde	91
C)	Politisch-medialer Druck	93
3.	Objektivität der sachverständigen Beurteilung	94
A)	Leitbild: Objektivität.....	95
B)	Fakt: Ermessensspielräume bei der PSY-Begutachtung	95
III.	Fazit	98
1.	Leitbild	98
2.	Faktenlage	99
3.	Fairnessimplikationen	99
§ 7	Konventionswidrige Unüberprüfbarkeit der Explorationsinhalte.....	100
I.	Ausgangsvariablen der Untersuchung	100
1.	Explorationsbezogene Überprüfungsbedürfnisse	100
A)	Kongruenz zwischen historischem Explorationsgeschehen und Gutachtenssachverhalt	101
B)	Konformität mit dem psychiatrischen Methodenstandard	101
C)	Konformität mit juristischen Beweiserhebungsregeln	102
a)	Verbotene Beweiserhebungsmethoden (Art. 140 StPO)	102
b)	Verbot von Suggestivfragen.....	103
c)	Manifestation von Ausstandsgründen	104
2.	Grundannahmen bezüglich des Verteidigungsdispositivs	105
II.	Sachverständiger als imperfekte Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt.....	107
1.	Informationsbrücken	108
A)	Akteneinsicht	108
a)	Allgemeine Dokumentationspflicht.....	108
b)	Konkretisierung für das Explorationsgespräch.....	109
aa)	Angaben des Exploranden	110
bb)	Fremdbeurteilungsebenen	111
B)	Befragung des PSY-Sachverständigen.....	112

2.	Imperfektion der Informationsbrücken.....	112
A)	Verzerrungseffekte	113
a)	Zerrspiegel der Persönlichkeit.....	114
b)	Selbstreflexion als imperfektes Korrektiv.....	115
B)	Informationsfilterung und -selektion	117
a)	Informationsverlust durch unbewusste Filterung	117
b)	Informationsverlust durch bewusste Selektion	118
C)	Dokumentationsfokus auf den Exploranden.....	118
D)	Vergessenskurve.....	119
3.	Zwischenfazit.....	119
III.	Beschuldigter als imperfekte Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt	120
1.	Analoge Herausforderungen wie beim Sachverständigen	121
2.	Katalysatoren für eine mangelhafte Explorationsrekonstruktion....	121
A)	Mangelnde Beobachterstellung	121
B)	Besondere Verletzlichkeit der Exploranden	122
C)	Fehlendes psychiatrisches und juristisches Fachwissen	123
3.	Zwischenfazit.....	123
IV.	Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten der Sachverständigenschilderung	124
V.	Kompensationsmechanismen: mangelnde Effektivität.....	127
1.	Beizug von Privatsachverständigen	127
A)	Mangelnde Kompensationseignung von Privatgutachten.....	127
a)	Methodenkritisches Privatgutachten	128
b)	«Vollbegutachtung» durch den Privatsachverständigen	128
B)	Beweiswert des Privatgutachtens	129
2.	Strafbehördliche Massnahmen.....	129
VI.	Fazit: Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 i.V.m. Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK..	130
§ 8	Ermittlung konventionskompatibler Lösungsmodelle.....	132
I.	Optimierung der Position und Rolle des Sachverständigen	133
1.	Neutralitätssicherung bei der Auftragsvergabe.....	133
A)	Fragmentarische Sicherung der Neutralität	134
B)	Anhaltende Intransparenz der Exploration	134
2.	Doppelbegutachtung	135
A)	Neutralitätszweifel am Sachverständigen der Verteidigung.....	136
B)	Anhaltende Intransparenz der Exploration	136
II.	Teilnahmerecht der Verteidigung.....	136
1.	Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten des Sachverständigen.....	137
A)	Systematische Position der Verteidigung	138
B)	Fehlendes Fachwissen der Verteidigung	138
2.	Reflexwirkungen eines Teilnahmerechts	139
3.	Inkompatibilität mit psychiatrischer Methodik	141

III.	Aufwertung des Dokumentationsstandards	142
1.	Beweisrechtliche Bestandteile der Exploration	142
A)	Einvernahmekomponente	142
B)	Augenscheinkomponente	144
2.	Implikation auf Wahl des Dokumentationsansatzes	145
A)	Ausscheiden ungeeigneter Dokumentationsansätze	145
a)	Defizite einer Protokollierungspflicht	145
aa)	Inadäquate Dokumentation der Exploration	146
bb)	Kapazitätsgrenzen der beschuldigten Person	146
cc)	Störung der Exploration	148
dd)	Würdigung	148
b)	Defizite einer Tonband-Dokumentation	150
B)	Audiovisuelle Aufzeichnung als sinnvoller Dokumentationsstandard	150
a)	Vorteile der audiovisuellen Aufzeichnung	151
aa)	Transparenz der Exploration	151
bb)	Methodenkompatibilität	152
cc)	Leistungsmöglichkeiten des Sachverständigen	153
dd)	Ausbildungseffekte	153
ee)	Verhinderung der Teilnahmerekumulation	154
ff)	De-facto-Durchsetzbarkeit durch Exploranden	154
gg)	Wegfallen unnötiger Rechtsmittelverfahren	154
b)	(Befürchtete) Nachteile der audiovisuellen Aufzeichnung	155
aa)	Aufzeichnung als Störfaktor	155
bb)	Interpretationsspielräume trotz Aufzeichnung	157
cc)	Sichtung der Aufzeichnungen	158
dd)	Persönlichkeitsschutz des Exploranden	159
ee)	Logistisch-kostentechnische Herausforderungen	160
ff)	Verbreitung der Aufzeichnungen	161
IV.	Fazit	161

4. Teil: Das Teilnahmepostulat im Lichte des Rechts auf Beizug der Verteidigung..... 165

§ 9	Prüfungsmodell des EGMR	165
I.	Verortung des Prüfungsmodells in Art. 6 EMRK	165
II.	Fairnessprüfungssequenzen des EGMR	166
1.	Aktivierung und Inhalt des Beizugsrechts	166
A)	Der «Anwalt der ersten Stunde»	166
B)	Ratio der Schutzausweitung ins Vorverfahren	167
C)	Manifestationsformen des Verteidigerhandelns	168
a)	Freier Verkehr mit der Verteidigung	168

b) Teilnahmerecht der Verteidigung	169
2. Nexus zu nemo tenetur.....	169
3. Belehrungspflicht und Verzicht auf Verteidigungsrechte	171
4. Zwingende Gründe für den Ausschluss der Verteidigung	172
5. Gesamtwürdigungsansatz	173
A) Beweislastverteilung im Rahmen der Gesamtwürdigung.....	173
B) Kriterien der Gesamtwürdigung	174
§ 10 Konventionswidriger Ausschluss der Verteidigung	176
I. Leitbild: Exploration ≠ Einvernahme	176
II. Fakt: materielle Kongruenz zwischen Einvernahme und Exploration ..	177
1. Tangenten der psychiatrischen Exploration mit nemo tenetur	178
A) Sachlicher Schutzbereich von nemo tenetur	179
a) Willensabhängigkeit des Beweismittels.....	179
b) Geschützte Explorationsinhalte.....	180
B) Gesetzliche Adressierung im Explorationskontext (Art. 185 Abs. 5 StPO)	181
C) Verwertbarkeit der Explorationsinhalte.....	182
a) Leitlinien der kantonalen Rechtsprechung und h.L.	182
b) Ambivalente Bundesgerichtspraxis.....	184
c) Würdigung	184
D) Selbstbelastungsgefahren im Explorationskontext	187
a) Retrospektive Selbstbelastungsgefahr.....	188
aa) Direkte Selbstbelastung	188
bb) Indirekte Selbstbelastung.....	189
b) Prospektive Selbstbelastungsgefahr	190
E) Psychischer Druck auf den «freien» Kooperationsentscheid der beschuldigten Person	191
a) Druckfaktoren auf den Kooperationsentscheid	192
aa) Informationsinteresse und Gesprächsführungs- technik des Sachverständigen.....	192
bb) Katalysatoren für allgemeinen Kooperationsdruck ...	194
b) Verletzlichkeit des Exploranden	195
aa) Allgemeine Verletzlichkeit.....	195
bb) Besondere Verletzlichkeit	196
F) Potenzielle Verkennung der Sachverständigenrolle durch die beschuldigte Person (Täuschungselement).....	197
2. Schutz vor ungesetzlichem Verhalten des Sachverständigen	199
3. Determinierende Relevanz der gutachterlichen Erhebungen für das gerichtliche Verfahren	199
4. Zwischenfazit.....	200
III. PSY-Methodenstandard als (potenzieller) Einschränkungsgrund	201
1. Methodenstandard: Drittpersonenausschluss	202

2.	Legitimation des Einschränkungsgrunds.....	203
A)	(In)stabilität der Prämisse: «Verteidigung als Störfaktor».....	203
a)	Störwirkung bei passiver Präsenz der Verteidigung.....	204
b)	Störwirkung bei aktiver Intervention der Verteidigung.....	206
B)	Inkompatibilität des Ausschlusses der Verteidigung im Lichte der EMRK-Praxis zu den «zwingenden Gründen».....	208
3.	Zwischenfazit	209
IV.	Fairnessverletzung qua Gesamtwürdigung	210
1.	Indikatoren für die Annahme eines <u>un</u> fairen Verfahrens	211
A)	Nationalrechtliche Ausgestaltung des Beweisverfahrens	211
B)	Signifikanz des Beweismaterials für Urteilsbasis	212
C)	Qualität der Beweise	214
D)	Besondere Verletzlichkeit der beschuldigten Person als Explorandin.....	215
E)	Fehlen eines Verzichts auf Verteidigerbeizug	218
2.	Indikatoren für die Annahme eines fairen Verfahrens	218
A)	Belehrung über das Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht	218
B)	Freier Verkehr mit der Verteidigung	220
C)	Öffentliches Interesse an Untersuchung/Bestrafung.....	222
D)	Einwendungen gegen Beweismaterial & Aussagerückzug oder -modifikation	222
E)	Würdigung durch professionelles Gericht	224
3.	Fazit: Verletzung von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK	224
§ 11	Ermittlung konventionskompatibler Lösungsmodelle	226
I.	Teilnahmerechtslose Lösungsansätze	226
1.	Verbot der Befragung zum Tatsachverhalt.....	226
A)	Fragmentarischer Schutzgehalt.....	226
B)	Einschnitt in Sachverständigenmethodik.....	227
C)	Probleme der praktischen Umsetzung.....	228
2.	Audiovisuelle Aufzeichnung.....	228
A)	Optimierung der Transparenz	228
B)	Fragmentarischer Schutzgehalt	229
3.	Tatinterlokut.....	229
A)	Kein Tatnachweis qua Gutachten	230
B)	Fragmentarischer Schutzgehalt.....	230
C)	Potenzielle Verfahrensverlängerung.....	231
4.	Fiktion des fehlenden Beweiswerts von Explorationsangaben ausserhalb des Gutachtens.....	231
A)	Fragmentarischer Schutzgehalt.....	231
B)	Instabilität der Beweiswertfiktion.....	232
5.	Verwertungsverbote	232

A)	Verwertungsverbot ausserhalb des Gutachtens (Variante I).....	233
a)	Fragmentarischer Schutzgehalt	233
b)	Systemwidrigkeit von Divergenzen zwischen Urteils- und Gutachtenssachverhalt.....	234
B)	Verwertungsverbot für von nemo tenetur geschützte Beweissubstrate (Variante II)	235
a)	Schutz von nemo tenetur.....	235
b)	Fragmentarischer Schutzgehalt	235
aa)	Schutzdefizit während der Exploration	236
bb)	Explorationsangaben als Ermittlungsansatz	236
cc)	Faktische Beeinflussung der Beweiswürdigung durch unverwertbare Angaben	237
c)	Methodeneingriff & Prozessökonomie	238
C)	Exkurs: Untauglichkeit eines gerichtsbezogenen Verwertungsverbots.....	238
II.	Teilnahmerecht der Verteidigung.....	240
1.	Globaler Schutz der Verteidigungsrechte	240
2.	Überwindbare Herausforderungen.....	241
A)	Modifikation der Explorationsmodalitäten.....	241
B)	Reflexwirkungen auf Teilnehmerzahl	242
C)	Unzulässiges Verteidigerverhalten.....	243
D)	Kosten der Verteidigerteilnahme.....	244
III.	Fazit.....	245
	Schlussbilanz.....	247
	Sachregister	255

Literaturverzeichnis

- AAPL TASK FORCE, Video recording of forensic psychiatric evaluations, Approved by the AAPL Executive Council May 31, 199, Revised May 2013 (zit. AAPL TASK FORCE).
- ACKERMANN JÜRG-BEAT/VETTERLI LUZIA, Brisante Aspekte der neuen Anklageschrift – nach EMRK, BV und Schweizerischer Strafprozessordnung, ZStrR 2008, S. 193 ff.
- AEBI MARCEL ET AL., Jugendstrafrechtliche Gutachten in der Schweiz, AJP 2018, S. 1461 ff.
- AESCHLIMANN JÜRG, Einführung in das Strafprozessrecht, Die neuen bernischen Gesetze, Bern/Stuttgart/Wien 1997.
- AHRENS BERND/LINDEN MICHAEL, Videofeedback zur Schulung der ärztlichen Gesprächsführung in der psychiatrischen Weiterbildung, in: Kügelgen Bernhard (Hrsg.), Video in Psychiatrie und Psychotherapie, Berlin 1989, S. 144 ff.
- ALBRECHT PETER, Die Funktion und Rechtsstellung des Verteidigers im Strafverfahren, in: Niggli Alexander Marcel/Münch Peter (Hrsg.), Handbücher für die Anwaltspraxis, Strafverteidigung, Basel/Genf/München 2002, S. 7 ff. (zit. ALBRECHT, Funktion).
- ALBRECHT PETER-ALEXIS, Überzeugungsbildung und Sachverständigenbeweis in der neueren strafrechtlichen Judikatur zur freien Beweiswürdigung (§ 261 StPO), NSTz 1983, S. 486 ff. (zit ALBRECHT, NSTz 1983).
- ALIOTTA MASSIMO, Begutachtungen im Bundessozialversicherungsrecht – eine kritische Würdigung ausgewählter verfahrensrechtlicher Aspekte, in: Murer Erwin (Hrsg.), Möglichkeiten und Grenzen der medizinischen Begutachtung, Medizin zwischen dem Hammer der Anwaltschaft und dem Amboss der Versicherer, Bern 2010, S. 63 ff. (zit. ALIOTTA, Begutachtungen).
- ALIOTTA MASSIMO, Begutachtungen im Bundessozialversicherungsrecht, Gehörs- und Partizipationsrechte der versicherten Personen bei Begutachtungen im nichtstreitigen Verwaltungsverfahren gemäss ATSG, Diss. Zürich 2017 (zit. ALIOTTA, Diss).
- AMMANN MATHIAS, Videoprotokollierung von Einvernahmen, Kriminalistik 2011, S. 570 ff.
- ANTOGNINI CATERINA, L'appréciation des expertises scientifiques, Jusletter 6. Juni 2011.

- APPAZOV ARTUR, Expert Evidence and International Criminal Justice, Cham 2016.
- ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR METHODIK UND DOKUMENTATION IN DER PSYCHIATRIE (AMDP), Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde, 10. A., Göttingen 2018.
- ARENS PETER, Gutachter im Prozeß, in: Reh binder Manfred (Hrsg.), Recht im sozialen Rechtsstaat, Opladen 1973, S. 261 ff.
- ARONSON H. ROBERT, Should the Privilege against Self-Incrimination Apply to Compelled Psychiatric Examinations?, Stanford Law Review 1973, S. 55 ff.
- ASHWORTH ANDREW, Self-Incrimination in European Human Rights Law - A Pregnant Pragmatism?, Cardozo Law Review 2008, S. 751 ff.
- AXMANN STEFAN ET AL., Physik vor Gericht, Die forensische Physik am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, Kriminalistik 2016, S. 477 ff.
- AZIBERT GILBERT, Code de procédure pénale 2018, 30. A., Paris 2017.
- BACA-GARCIA ENRIQUE ET AL., Diagnostic stability of psychiatric disorders in clinical practice, British Journal of Psychiatry 2007, S. 210 ff.
- BÄNZIGER FELIX/STOLZ W. AUGUST/KOBLER WALTER, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Appenzell A.Rh., 2.A., Speicher 1992.
- BARBIER DE LA SERRE ERIC/SIBONY ANNE-LISE, Expert Evidence before the EC Courts, Common Market Law Review 2008, S. 941 ff.
- BARTON STEFAN, Der psychowissenschaftliche Sachverständige im Strafverfahren, Heidelberg 1983 (zit. BARTON, Sachverständige).
- BARTON STEPHAN, Sachverständiger und Verteidiger, StV 1983, S. 73 ff. (zit. Barton, StV 1983).
- BARTON STEPHAN, Verfahrensrecht, StPO §§ 78, 137, Anwesenheit des Verteidigers bei Exploration durch Sachverständigen, Anmerkung, StV 2003, S. 537 ff. (zit. BARTON, StV 2003).
- BAUER ALAIN/CORNU PIERRE, Code de procédure pénale Neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003.
- BAUMER SONJA/LUDEWIG REVITAL/TAVOR DAPHNA, Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, AJP 2011, S. 1415 ff.
- BECKERT SANDRA MARIA, Sachverständigengutachten im Strafverfahren zur Glaubwürdigkeit und zur Schuldfähigkeit im Falle der Untersuchungsverweigerung des zu Begutachtenden, Diss. Passau, Frankfurt a.M. 2014.

- BERGER MARK, Europeanizing self-incrimination: The Right to Remain Silent in the European Court of Human Rights, *Columbia Journal of European Law* 2006, S. 339 ff.
- BERLINGER ADRIAN, Glaubhaftigkeitsbegutachtung im Strafprozess, Beweis-seignung und Beweiswert, Diss. Luzern, Zürich 2014.
- BERNASCONI PAOLO ET AL. (Hrsg.), *Commentario, Codice Svizzero di Procedure Penale (CPP)*, Zürich/St.Gallen 2010 (zit. CPP-Bernasconi et al.-BEARBEITER).
- BERNHARD STEPHAN, (Keine) Kontrolle psychiatrischer Explorationsgespräche durch die Verteidigung, *iusNet* 27. November 2018; online (zit. BERNHARD, *iusNet* 27. November 2018).
- BERNHARD STEPHAN, Nach dem Fall Rupperswil, *Anwaltsrevue* 2019, S. 163 ff. (zit. BERNHARD, *Anwaltsrevue* 2019).
- BERNHARD STEPHAN, Freiheitsentziehendes Massnahmenrecht oder freiheits-entziehende Massnahmen jenseits des Rechts?, Die Bedeutung der psychiatrischen Gutachten in der Strafjustiz aus der Perspektive eines Strafverteidigers, in: Kuhn André/Schwarzenegger Christian/Vuille Joëlle (Hrsg.), *Strafverfolgung – Individuum – Öffentlichkeit im Spannungsfeld der Wahrnehmungen*, Bern 2017, S. 139 ff. (zit. BERNHARD, *Massnahmenrecht*).
- BERNHARD STEPHAN, Nr. 33 Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil vom 20. Dezember 2017 i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich – 6B_989/2017, *fp* 2018, S. 470 ff. (zit. BERNHARD, *fp* 2018).
- BERNHARD STEPHAN, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Ein Essay für die Strafverteidigung zur Beratung der beschuldigten Person, *fp* S0/2014 (Sonderheft), S. 2 ff. (zit. BERNHARD, *fp* S0/2014).
- BERNHARD STEPHAN, Sicherheitsgesellschaft und psychiatrische Begutachtungspraxis in Strafverfahren, *Jusletter* 13. Februar 2012 (zit. BERNHARD, *Jusletter* 13. Februar 2012).
- BERNHARD STEPHAN/BINDER MARTINA ANJA, Neue StPO: Nach wie vor keine Kontrolle der sogenannten Erhebung bei (psychiatrischen) Begutachtungen?, *Anwaltsrevue* 2011, S. 9 ff.
- BERNHARD STEPHAN/STUDER RAFAEL, Prekäre Unschuld bei Begutachtungen ohne Tat- oder Schuldinterlokut, in: Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernhard Stephan (Hrsg.), *Forum Justiz und Psychiatrie, Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung*, Bern 2016, S. 1 ff. (zit. BERNHARD/STUDER, *Schuldinterlokut*).

- BERNHARD STEPHAN/STUDER RAFAEL, Psychiatrische Gutachter ohne strafprozessuale Kontrolle?, ZStrR 2015, S. 76 ff. (zit. BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015).
- BERNHEIM EMMANUELLE, Le psychiatre devant le juge: entre pragmatisme et captivité, une communication aléatoire, Canadian Journal of Law and Society 2008, S. 39 ff.
- BEYDOUN KHALIL, Beweisverwertungsverbote, Ein Vergleich zwischen der schweizerischen und der US-amerikanischen Handhabung der Beweisverwertungsverbote, Diss. Freiburg, Zürich 2017.
- BILLING FENELLA, The Right to Silence in Transnational Criminal Proceedings Comparative Law Perspectives, Cham 2016.
- BINDER ANJA MARTINA, Expertenwissen und Verfahrensgarantien, Dargestellt an den verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf Bundesebene, Diss. Zürich 2016.
- BLIESENER THOMAS/LÖSEL FRIEDRICH/KÖHNKEN GÜNTER, Lehrbuch Rechtspsychologie, Bern 2014 (zit. Bliesener/Lösel/Köhnken-BEARBEITER).
- BMJV, Bericht der Expertenkommission zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens, Berlin 2015.
- BÖHME ANNA, Der medizinische Sachverständigenbeweis in der obligatorischen Unfallversicherung, Fairness durch das Verfahren, den Sachverständigen und das Sachverständigengutachten, Diss. Luzern, Zürich 2018.
- BOEHME-NESSLER VOLKER, Prekäre Balance: Überlegungen zum heiklen Verhältnis von Richtern und Gutachtern, Rechtswissenschaft 2014, S. 189 ff.
- BOMMER FELIX, Parteirechte der beschuldigten Person bei Beweiserhebungen in der Untersuchung, recht 2010, S. 196 ff. (zit. BOMMER, recht 2010).
- BOMMER FELIX, Über notwendige Verteidigung, in: Bommer Felix/Berti V. Stephen (Hrsg.), Verfahrensrecht am Beginn einer neuen Epoche, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2011 – 150 Jahre Schweizerischer Juristenverein, Zürich 2011, S. 93 ff. (zit. BOMMER, FG Juristentag).
- BOMMER FELIX/KAUFMANN ARIANE, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2009, ZBJV 2014, S. 1007 ff.
- BOVAY BENOÎT ET AL., Procédure pénale vaudoise, Lavi, Concordat sur l'entraide judiciaire, Execution des peines, Code annoté, 3. A., Basel 2008.
- BOVEY GRÉGORY, Le juge face à l'expert, in: Chappuis Christine/Winiger Bénédict (Hrsg.), La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Zürich 2011, S. 95 ff.

- BRANDA MARIO, La perizia psichiatrica secondo l'art. 20 CP: annotazioni su criteri e prassi nella determinazione dell'imputabilit  dell'accusato, in: Borghi Marco (Hrsg.), *Le perizie giudiziarie*, Basel 2008, S. 125 ff.
- BRODBECK HANSJ RG, L gen verboten -  berlegungen zum T uschungsverbot nach Art. 140 StPO, fp 2010, S. 300 ff.
- BROWN LISA V., Help or Hindrance? The Support Person in the Psychiatric Medico-legal Examination, *Psychiatry, Psychology and Law* 2018, S. 86 ff.
- BRUNNER FRANZISKA ET AL., Evaluation von operationalisierten Kriterien zur Schuldf higkeitsbeurteilung bei paraphiler St rung, *Recht & Psychiatrie* 2016, S. 228 ff.
- BRUNNER Matthias, Die Verl sslichkeit von psychiatrischen Gutachten, Aspekte der Verteidigung, in: Capus Nadja/Bacher Jean-Luc (Hrsg.), *Strafjustiz zwischen Anspruch und Wirklichkeit*, Bern 2010, S. 303 ff. (zit. BRUNNER, Verl sslichkeit).
- BRUNNER MATTHIAS, Psychiatrische Begutachtung – Aspekte der Verteidigung, in: Heer Marianne/Sch bi Christian (Hrsg.), *Gericht und Expertise*, Bern 2005, S. 185 ff. (zit. BRUNNER, Aspekte, S.).
- BRUNNER MATTHIAS, Psychiatrische Gutachter agieren im rechtsfreien Raum, pl doyer 3/2005, S. 36 ff. (zit. BRUNNER, pl doyer 3/2005).
- BRUNNER MATTHIAS, Verteidigung/Beratung des Klienten bei der psychiatrischen Begutachtung, in: Forum Strafverteidigung CH et al. (Hrsg.), *Strafverteidigung und Sicherheitswahn*, 3. L nderforum Strafverteidigung, Z rich 14./15. Juni 2013, Z rich 2014, S. 137 ff. (zit. BRUNNER, Beratung).
- B HLER ALFRED, Erwartungen des Richters an den Sachverst ndigen, *AJP* 1999, S. 567 ff.
- BURIC ZORAN, Re-Assessing the Jurisprudence of the European Court of Human Rights on Police Interrogation - Case of Ibrahim and others v. the United Kingdom, in: Dui  Dunja/Petra ev  Tunjica (Hrsg.), *EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement*, Osijek 2018, S. 338 ff.
- CAIANIELLO MICHELE, Editorial, You Can't Always Counterbalance What You Want, *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 2017, S. 283 ff.
- CAPUS NADJA, «Ich erm rdere Dich. Es gibt keine Gesetze f r Vito. Vitogesetze.», Theorie und Empirie zur Herstellung von Schriftprotokollen in Strafverfahren, «Justice - Justiz - Giustizia» 2014/3. (zit. CAPUS, «Justice - Justiz - Giustizia» 2014/3).

- CAPUS NADJA, Schriftprotokolle im Strafverfahren: «der todte Buchstabe ist noch immer nicht das lebendige Wort selbst», BJM 2012, S. 173 ff. (zit. CAPUS, BJM 2012).
- CAPUS NADJA/STOLL MIRJAM, Lesen und Unterzeichnen von Einvernahmeprotokollen im Vor- und im Hauptverfahren, Anmerkungen zur Revision der Schweizerischen Strafprozessordnung aus Sicht der rechtswissenschaftlichen und kriminologischen Protokollforschung, ZStrR 2013, S. 195 ff.
- CAPUS NADJA/STOLL MIRJAM/STUDER RAFAEL, Die Belehrung über das Schweigerecht, MschrKrim 2016, S. 42 ff.
- CAVEGN CLAUDINE, Das Recht der beschuldigten Person auf Ladung und Befragung von Entlastungszeugen im ordentlichen Strafverfahren, Diss. Zürich 2010.
- CECI J. STEPHEN/BRUCK MAGGIE, Why Judges Must Insist on Electronically Preserved Recordings of Child Interviews, Court Review 2000, S. 10 ff.
- CELIKSOY ERGUL, Ibrahim and Others v. UK: Watering down the Salduz principles?, New Journal of European Criminal Law 2018, S. 1 ff.
- CHAMPOD CHRISTOPHE/VUILLE JOELLE, Scientific Evidence in Europe – Admissibility, Evaluation and Equality of Arms, International Commentary on Evidence 2011, S. 1 ff.
- CHRISTEN STEFAN, Zum Anwesenheitsrecht der Privatklägerschaft im schweizerischen Strafprozessrecht, ZStrR 2011, S. 463 ff.
- CLAAS INGRID, «Beistände» bei Begutachtungen – aus anwaltlicher Sicht, Med-Sach 2007, S. 24 ff.
- COLLINS ROGER/LINCOLN ROBYN/FRANK MARK, The Effect of Rapport in Forensic Interviewing, Psychiatry, Psychology and Law 2002, S. 69 ff.
- CONSTANTINOU MARIOS/ASHENDORF LEE/MCCAFFREY ROBERT J., Effects of a Third Party Observer During Neuropsychological Assessment: When the Observer Is a Video Camera, Journal of Forensic Neuropsychology 2005, S. 39 ff.
- CONSTANTINOU MARIOS/ASHENDORF LEE/MCCAFFREY ROBERT J., When the Third Party Observer of a Neuropsychological Evaluation is an Audio Recorder, The Clinical Neuropsychologist 2002, S. 407 ff.
- CRAMER J. ROBERT/BRODSKY L. STANLEY, Undue Influence or Ensuring Rights?, Attorney Presence During Forensic Psychology Evaluations, Ethics & Behavior 2007, S. 51 ff.
- DAHLE KLAUS-PETER/LEHMANN ROBERT J.B., Zum prognostischen Mehrwert einer integrativen nomothetisch-idiografischen kriminalpsychologischen

- Prognosebeurteilung – Eine empirische Untersuchung an männlichen Gewalt- und Sexualstraftätern, FPPK 2018, S. 37 ff.
- DAHS HANS, Handbuch des Strafverteidigers, 8. A., Köln 2015.
- DECAIGNY TOM, Inquisitorial and adversarial expert examinations in the case law of the European Court of Human Rights, New Journal of European Criminal Law 2014, S. 149 ff.
- DECKERS RÜDIGER, Verteidigung und Psychosachverständige, in: Dudeck Manuela/Kaspar Johannes/Lindemann Michael (Hrsg.), Verantwortung und Zurechnung im Spiegel von Strafrecht und Psychiatrie, Baden-Baden 2014, S. 205 ff.
- DEITMARING HILDEGARD, Begleitpersonen bei der ärztlichen Begutachtung im Sozialverwaltungsverfahren – Bestandsaufnahme und Diskussion, Med-Sach 2009, S. 107 ff.
- DELACRAUSAZ PHILIPPE/MOULIN VALÉRIE, Réflexions sur le travail collégial en expertise psychiatrique, Jusletter 25. April 2015.
- DETTNER KLAUS, Der Sachverständige im Strafverfahren – eine Bestandsaufnahme, NSTZ 1998, S. 57 ff.
- DIPPEL KARLHANS, Ausgewählte Themen des Beweises durch Sachverständige im Strafverfahren, in: Jung Heike/Luenburger Bernd/Wahle Eberhard (Hrsg.), Festschrift für Egon Müller, Baden-Baden 2008, S. 125 ff. (zit. DIPPEL, FS Müller).
- DIPPEL KARLHANS, Die Stellung des Sachverständigen im Strafprozess, Eine Studie unter besonderer Berücksichtigung der Zulässigkeit und der Folgen eigener Ermittlungen des Sachverständigen nach geltendem und künftigem Recht, Diss. Heidelberg 1986 (zit. DIPPEL, Diss).
- DONATSCH ANDREAS, Der amtliche Sachverständige und der Privatgutachter im Zürcher Strafprozess, in: Donatsch Andreas et al. (Hrsg.), 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich: Festschrift, Zürich 2000, S. 363 ff. (zit. DONATSCH, 125 Jahre Kassationsgericht).
- DONATSCH ANDREAS, Der Sachverständige im Strafverfahrensrecht, unter besonderer Berücksichtigung seiner Unabhängigkeit sowie des Privatgutachters, Jusletter 14. Mai 2007 (zit. DONATSCH, Jusletter 14. Mai 2007).
- DONATSCH ANDREAS, Erste Erfahrungen mit dem Beweisrecht, fp 2012, S. 235 ff. (zit. Donatsch, fp 2012).
- DONATSCH ANDREAS, Rechtsmediziner als Gutachter bei Delikten gegen Leib und Leben, Kriminalistik 1995, S. 513 ff. (zit. Donatsch, Kriminalistik 1995).

- DONATSCH ANDREAS, Zur Unabhängigkeit und Unbefangenheit des Sachverständigen, in: Lieber Viktor et al. (Hrsg.), Rechtsschutz, Festschrift zum 70. Geburtstag von Guido von Castelberg, Zürich 1997, S. 37 ff. (zit. DONATSCH, FS Castelberg).
- DONATSCH ANDREAS, Das Sachverständigengutachten im Strafprozess, fp 2019, S. 135 ff. (zit. DONATSCH, fp 2019).
- DONATSCH ANDREAS/CAVEGN CLAUDINE, Ausgewählte Fragen zum Beweisrecht nach der schweizerischen Strafprozessordnung, ZStrR 2008, S. 158 ff. (zit. DONATSCH/CAVEGN, ZStrR 2008).
- DONATSCH ANDREAS/CAVEGN CLAUDINE, Der Anspruch auf einen Anwalt zu Beginn der Strafuntersuchung, fp 2009, S. 104 ff. (zit. DONATSCH/CAVEGN, fp 2009).
- DONATSCH ANDREAS/HANSJAKOB THOMAS/LIEBER VIKTOR (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2.A., Zürich 2014 (zit. ZK StPO-BEARBEITER).
- DONATSCH ANDREAS/SCHMID NIKLAUS, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich: vom 4. Mai 1919, Lieferung 5., Zürich 1996-2007 (Donatsch/Schmid-BEARBEITER)
- DONATSCH ANDREAS/SCHWARZENEGGER CHRISTIAN/WOHLERS WOLFGANG, Strafprozessrecht, 2.A., Zürich 2014.
- DONATSCH ANDREAS/ZUBERBÜHLER SIMONE, Die Nutzung von Expertenwissen im Strafverfahren – am Beispiel des Strafprozessrechts des Kantons Zürich sowie des Entwurfs für eine eidgenössische Strafprozessordnung, in: Niggli Marcel Alexander/Hurtado Pozo José/Queloz Nicolas (Hrsg.), Festschrift für Franz Riklin: zur Emeritierung und zugleich dem 67. Geburtstag, Zürich 2007, S. 337 ff.
- DROR ITIEL E./MURRIE DANIEL C., A Hierarchy of Expert Performance Applied to Forensic Psychological Assessments, Psychology Public Policy and Law, 9/2017, 1 ff.
- DRUSCHKE BETTINA, Das Anwesenheitsrecht der Verfahrensbeteiligten bei den tatsächlichen Ermittlungen des Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren, Diss. Münster 1989.
- DUBS HANS, Zur Stellung und Aufgabe des Psychiaters im Strafverfahren, ZStrR 1989, S. 337 ff.
- EBNER GERHARD ET AL., Qualitätsleitlinien für versicherungspsychiatrische Gutachten – Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie SGPP, SZS 2016, S. 435 ff.

- EDITORS, Right to Counsel at the Pretrial Mental Examination of an Accused, University of Pennsylvania Law Review 1970, S. 448 ff.
- EGE GIAN, Der Affekt im schweizerischen Strafrecht, Die Berücksichtigung von heftigen Gemütsbewegungen im Allgemeinen und Besonderen Teil des schweizerischen Strafgesetzbuches, Diss. Zürich 2017.
- EGG RUDOLF, Die unheimlichen Richter, Wie Gutachter die Strafjustiz beeinflussen, München 2015.
- EGLIN DIETER, Die Einvernahme des Beschuldigten im Strafverfahren aus der Sicht des Praktikers, BJM 2017, S. 75 ff.
- EHRENZELLER BERNHARD ET AL. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Band I, Art. 1-80, 3. A., Zürich/St.Gallen 2014 (BV-Ehrenzeller et al.-I-BEARBEITER).
- EHRENZELLER BERNHARD ET AL. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Band II, Art. 81-197, 3. A., Zürich/St.Gallen 2014 (BV-Ehrenzeller et al.-II-BEARBEITER).
- EICKER ANDREAS, Die Prinzipien der «materiellen Wahrheit» und der «freien Beweiswürdigung» im Strafprozeß, Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Sachverständigenbeweises und der Sachgebundenheit richterlicher Überzeugungsbildung bei der Schuldfähigkeitsfeststellung und der Feststellung subjektiver Deliktsmerkmale, Herbolzheim 2001.
- EISENBERG ULRICH, Anmerkungen zu dem Beitrag «Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten», NStZ 2005, S. 304 ff.
- ELLGRING HEINER, Der Wert des Videos in der Psychotherapie, in: Kugelgen Bernhard (Hrsg.), Video in Psychiatrie und Psychotherapie, Berlin 1989, S. 11 ff.
- ENGELHARDT KARIN, Schuldfähigkeitsbegutachtung und Strafurteil, Eine Untersuchung über die Auswirkungen von Sachverständigengutachten auf die Entscheidung über die Schuldfähigkeit in Strafverfahren wegen Gewaltdelikten vor bayerischen Strafrichtern, Diss. Erlangen-Nürnberg 1994.
- ERB VOLKER ET AL. (Hrsg.), Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Grosskommentar, 26. A., Elfter Band, EMRK/IPBRP, Berlin/Boston 2012 (zit. Erb et al.-BEARBEITER).
- ERB VOLKER, Die Abhängigkeit des Richters vom Sachverständigen, ZStW 2009, S. 882 ff.

- ESSER ROBERT, Auf dem Weg zu einem europäischen Strafverfahrensrecht, Die Grundlagen im Spiegel der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg, Berlin 2002.
- EYTAN ARIEL, Das psychiatrische Gutachten: ein Instrument zuhanden der Strafjustiz, #prison-info 1/2017, S. 18 ff.
- FÄHNDRICH ERDMANN/STIEGLITZ ROLF-DIETER, Leitfaden zur Erfassung des psychopathologischen Befundes, Halbstrukturiertes Interview anhand des AMDP-Systems, 5. A., Göttingen 2018.
- FASTENMEIER WOLFGANG, Ist die MPU reformbedürftig?, Blutalkohol 2014, S. 81 ff.
- FEGERT JÖRG MICHAEL ET AL., Psychiatrische Begutachtung in Sexualstrafverfahren, Eine empirische Untersuchung von Gutachten zur Schuldfähigkeit bei jugendlichen, heranwachsenden und erwachsenen Beschuldigten in Mecklenburg-Vorpommern, Herbolzheim 2006.
- FELTHOUS ALAN R./SASS HENNING, Diagnostischer Prozess und Voreingenommenheit in der forensischen Psychiatrie, FPPK 2011, S. 136 ff.
- FERRAND FRÉDÉRIQUE, Le principe contradictoire et l'expertise en droit comparé européen, Revue internationale de droit comparé 2000, S. 345 ff.
- FILLI ALEXANDER, Die Auskunftserteilung des Arztes an Behörden unter dem Aspekt des Berufsgeheimnisses gemäss Art. 321 StGB, BJM 1987, S. 57 ff.
- FINCKE MARTIN, Die Pflicht des Sachverständigen zur Belehrung des Beschuldigten, ZStW 1973, S. 656 ff.
- FINGERHUTH THOMAS, 4. Teil Strafrecht, Rechtsprechung im Überblick, 2009 - 2011 (5. 2009 - 4. 2011): Straf- und Strafprozessrecht, in: Furrer Andreas (Hrsg.), Aktuelle Anwaltspraxis, Bern 2011, S. 1221 ff. (zit. FINGERHUTH, Anwaltspraxis).
- FINGERHUTH THOMAS, BGE-Praxis II/2018, fp 2018, S. 545 ff. (zit. FINGERHUTH, fp 2018).
- FINZEN ASMUS, Normalität, Die ungezähmte Kategorie in Psychiatrie und Gesellschaft, Köln 2018.
- FOERSTER KLAUS/FOERSTER MAX, Belehrung durch den psychiatrischen Sachverständigen?, in: Dölling Dieter et al. (Hrsg.), Verbrechen – Strafe – Resozialisierung: Festschrift für Heinz Schöch zum 70. Geburtstag am 20. August 2010, Berlin 2010, S. 1007 ff.
- FONJALLAZ JEAN/GASSER JEAN, Le juge et le psychiatre, Une tension nécessaire, Bern 2017.

- FRANCKE JOACHIM, Anwesenheit Dritter und Fremdanamnese – Möglichkeiten und Grenzen, Forum Medizinische Begutachtung 1/2014, S. 20 ff.
- FREI ANDREAS/GRAF MARC/DITTMANN VOLKER, Die Akzeptanz forensisch-psychiatrischer Gutachten vor Gericht, Eine Studie über 81 Fälle angeklagter Tötungsdelikte zwischen 1989 und 1998 in Basel, in: Jehle Jörg-Martin/Dittmann Volker (Hrsg.), Kriminologie zwischen Grundlagenwissenschaften und Praxis, Mönchengladbach 2003, S. 127 ff.
- FURGER RONALD, Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen der Psychiatrie im Strafverfahren, AJP 1992, S. 1120 ff. (zit. FURGER, AJP 1992).
- FURGER RONALD, Hinweise zum kritischen Umgang mit psychiatrischen Gutachten, ZStrR 1988, S. 385 ff. (zit. FURGER, ZStrR 1988).
- GAEDE KARSTEN, Fairness als Teilhabe – Das Recht auf konkrete und wirksame Teilhabe durch Verteidigung gemäss Art. 6 EMRK, Diss. Zürich, Berlin 2007.
- GEIGER HARALD, Die medizinisch-psychologische Untersuchung, Bestandesaufnahme – Reformüberlegungen, in: Schaffhauser René (Hrsg.), Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2011, S. 41 ff.
- GERSTENFELD CHRISTINE, Der Psychiater als Inquisitor, Die Bedeutung des Geständnisses für das Begutachtungsergebnis, MschrKrim 2000, S. 280 ff.
- GINTER JAAN/ SOO ANNELIN, The Right of the Suspect to Counsel in Pre-trial Criminal Proceedings, Its Content, and the Extent of Application, Juridica International 2012, S. 170 ff.
- GLESS SABINE, Nr. 42 Obergericht Zürich, III. Strafkammer, Beschluss vom 24. April 2013 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl – UH120368, fp 2013, S. 343 ff.
- GMÜR MARIO, «Das Verschuldensprinzip wird ausgehebelt.», plädoyer 4/2017, S. 28 ff.
- GOCKER C. JAMES, Comments, Defective Delinquent Commitment Proceedings and the Constitution: The Privilege Against Self-Incrimination and the Right to Counsel at the Examination Stage, The American University Law Review 1973, S. 619 ff.
- GOLDSCHMID PETER/MAURER THOMAS/SOLLBERGER JÜRIG, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) vom 5. Oktober 2007, Bern 2008.

- GOLDSTEIN LLOYD ROBERT, Consequences of Surveillance of the Forensic Psychiatric Examination: An Overview, *American Journal of Psychiatry* 1988, S. 1243 ff. (zit. GOLDSTEIN, *American Journal of Psychiatry* 1988).
- GOLDSTEIN LLOYD ROBERT, Spying on Psychiatrists: Surreptitious Surveillance of the Forensic Psychiatric Examination by the Patient Himself, *The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law* 1989, S. 367 ff. (zit. GOLDSTEIN, *The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law* 1989).
- GOLLWITZER WALTER, *Menschenrechte im Strafverfahren, MRK und IPBPR, Kommentar*, Berlin 2005.
- GOWENSMITH NEIL W. ET AL., Diagnostic Field Reliability in Forensic Mental Health Evaluations, *Psychological Assessment* 2017, S. 692 ff.
- GOWENSMITH NEIL W./MURRIE DANIEL/BOCCACCINI MARCUS T., Forensic Mental Health Evaluations: Reliability, Validity, Quality, and Other Minor Details, *Jury Expert* 2013, S. 40 ff.
- GRABENWARTER CHRISTOPH, *European Convention on Human Rights, Commentary*, München 2014.
- GRABENWARTER CHRISTOPH/PABEL KATHARINA, *Europäische Menschenrechtskonvention, Ein Studienbuch*, 6. A., München/Basel/Wien 2016.
- GRAF MARC, Fremdanamnese: Die Sicht des forensisch-psychiatrischen Sachverständigen, in: Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernhard Stephan (Hrsg.), *Forum Justiz und Psychiatrie, Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung*, Bern 2016, S. 57 ff. (zit. GRAF, *Fremdanamnese*).
- GRAF MARC, Missbrauch des psychiatrischen Gutachters bei der Rechtsfindung, in: Brägger Benjamin (Hrsg.), *Bedrohte Sicherheit oder bedrohende Sicherheit*, Bern 2012, S. 141 ff. (zit. GRAF, *Missbrauch*).
- GRAF MARC, Qualitätskriterien forensischer Gutachten, in: Kuhn André/Schwarzenegger Christian/Vuille Joëlle, Bern 2017, S. 91 ff. (zit. GRAF, *Qualitätskriterien*).
- GRAF MARC, Richter in Weiss, «Justice - Justiz - Giustizia» 4/2015 (zit. GRAF, «Justice - Justiz - Giustizia» 4/2015).
- GRONER ROGER, *Beweisrecht: Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht*, Bern 2011.
- GUIDON PATRICK, Wechselwirkungen zwischen Medien und Gerichten, *Anwaltsrevue* 2019, S. 271 ff.

- GUTHEIL THOMAS G., Avoiding Bias in Expert Testimony, *Psychiatric Annals* 2004, S. 260 ff.
- GUYAZ ALEXANDRE, Le rôle de l'expert médical du point de vue de l'avocat, in: Chappuis Christine/Winiger Bénédict (Hrsg.), *La preuve en droit de la responsabilité civile*, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève 2011, S. 117 ff.
- HAAG CHRISTIAN, Tonaufnahmen erlaubt, plädoyer 1/2018, S. 14 f.
- HAAS HENRIETTE/ILL CHRISTOPH, Gesprächsführungstechniken in der Einvernahme, *fp S0/2013* S. 2 ff.
- HABERMEYER ELMAR ET AL., Psychologen als Gutachter in Strafverfahren, *AJP* 2016, S. 127 ff.
- HABERMEYER ELMAR, Parteigutachten: Die Sicht des forensisch-psychiatrischen Sachverständigen, in: Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernhard Stephan (Hrsg.), *Forum Justiz und Psychiatrie, Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung*, Bern 2016, S. 67 ff. (zit. HABERMEYER, Parteigutachten).
- HABERMEYER ELMAR, Verwahrte – wer trägt das Risiko?, in: Brägger Benjamin (Hrsg.), *Bedrohte Sicherheit oder bedrohende Sicherheit*, Bern 2012, S. 191 ff. (zit. HABERMEYER, Verwahrte).
- HABERMEYER ELMAR/SACHS JOSEF, Aufgaben und Rolle der forensischen Psychiatrie, *Jusletter* 27. April 2015.
- HABERMEYER ELMAR/SASS HENNING, Die Mindeststandards der Schuldfähigkeitsbegutachtung aus psychiatrischer Sicht, *FPPK* 2007, S. 10 ff.
- HADDENBROCK SIEGFRIED, Das Sachverständigendilemma im deutschen Strafprozeß ohne Tat- oder Schuldinterlokut, *NJW* 1981, S. 1302 ff.
- HAEFELIN WALTER, *Die amtliche Verteidigung im schweizerischen Strafprozess*, Diss. Zürich, Zürich/St. Gallen 2010.
- HANSJAKOB THOMAS, Geheime Erhebung von Beweisen nach StPO, *fp* 2011 S. 299 ff.
- HÄSSLER FRANK/KINZE WOLFRAM/NEDOPIL NORBERT (Hrsg.), *Praxishandbuch forensische Psychiatrie, Grundlagen, Begutachtung, Interventionen im Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kindesalter*, 2. A., Berlin 2015. (zit. Hässler/Kinze/Nedophil-BEARBEITER).
- HAUG ACHIM, *Psychiatrische Untersuchung, Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologen in Praxis und Klinik*, 8. A., Bern 2017.

- HAUG ACHIM/TRABERT WOLFGANG/SCHAUB RAINER, Der psychopathologische Befund als Kernstück der psychiatrischen Diagnostik, Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie 2012, S. 257 ff.
- HAUSER ROBERT/SCHWERI ERHARD/HARTMANN KARL, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. A., Basel/Genf/München 2005.
- HAUSOTTER WOLFGANG, «Beistände» bei Begutachtungen – aus Sicht des medizinischen Sachverständigen, MedSach 2007, S. 27 ff.
- HAYS R. JAY, A Response to Shealy, Cramer, and Pirelli's «Third Party Presence During Criminal Forensic Evaluations: Psychologists' Opinions, Attitudes, and Practices», Professional Psychology: Research and Practice 2008, S. 570 ff.
- HEER MARIANNE, Beendigung therapeutischer Massnahmen: Zuständigkeiten und Verfahren, Versuch eines Konzepts in einer wenig überschaubaren Gesetzgebung und Rechtsprechung, AJP 2017, S. 592 ff. (zit. HEER, AJP 2017).
- HEER MARIANNE, Die psychiatrische Begutachtung unter dem Einfluss des Strafprozessrechts, in: Heer Marianne et al. (Hrsg.), «Toujours agité – jamais abattu», Festschrift für Hans Wiprächtiger, Basel 2011, S. 177 ff. (HEER, FS Wiprächtiger).
- HEER MARIANNE, Immer strengere Anforderungen an psychiatrische Gutachten, einige Überlegungen aus richterlicher Sicht, in: Kuhn André/ Schwarzenegger Christian/Vuille Joëlle (Hrsg.), Bern 2017, S. 106 ff. (zit. HEER, Anforderungen).
- HEER MARIANNE, Psychiatrische Gutachten als Grundlage für verantwortbare gerichtliche Entscheidungen, Eindrücke aus der ermittlungsrichterlichen und richterlichen Praxis in der Schweiz, in: Hässler Frank et al. (Hrsg.), Forensische Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie, Aspekte der forensischen Begutachtung, Stuttgart 2003, S. 199 ff. (zit. HEER, Grundlage).
- HEER MARIANNE, Psychiatrische Gutachten im Strafverfahren – Eine Herausforderung für Juristen, in: Riedo Christof/Fiolka Gerhard/Gfeller R. Diego (Hrsg.), Liber amicorum für Marcel Alexander Niggli, Von Lemuren, Igeln und anderen strafrechtlichen Themen, Basel 2010, S. 101 ff. (zit. HEER, LA Niggli).
- HEER MARIANNE, Psychiatrische Gutachten: wertvolle Entscheidungsgrundlagen oder Feigenblatt?, in: Riklin Franz (Hrsg.), Kapitulierte die Strafjustiz vor der Psychiatrie? Verschuldensstrafrecht auf dem Prüfstand, Bern 2016, S. 11 ff. (zit. HEER, Feigenblatt).

- HEER MARIANNE, Sanktionenrecht unter dem Druck der Öffentlichkeit, in: Marcel Niggli/Manon Jendly (Hrsg.), Strafsystem und Öffentlichkeit: Zwischen Kuscheljustiz und Scharfrichter, Bern 2012, S. 141 ff. (zit. HEER, Öffentlichkeit).
- HEER MARIANNE, Zum Problem des unvollständigen Sachverhalts im Zusammenhang mit aussagepsychologischen Gutachten, in: Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernhard Stephan (Hrsg.), Forum Justiz und Psychiatrie, Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung, Bern 2016, S. 101 ff. (zit. HEER, Gutachten).
- HEER MARIANNE/COVACI JACQUELINE, Teilnahmerecht der Verteidigung bei psychiatrischen Explorationsgesprächen, AJP 2019, S. 438 ff.
- HELFENSTEIN MARC, Der Sachverständigenbeweis im schweizerischen Strafprozess, Diss. Zürich 1978.
- HOFF PAUL, Psychopathologie und operationalisierte Diagnostik in der forensischen Psychiatrie, FPPK 2015, S. 258 ff. (zit. HOFF, FPPK 2015).
- HOFF PAUL, Was darf die Psychiatrie, Oberhofen 2014 (zit. HOFF, Psychiatrie).
- HOHL-CHIRAZI CATHERINE, De Salduz à Ibrahim: vers un ramollissement diffus de l'Etat de droit?, in: Garibian Sevan/Jeanerret Yvan (Hrsg.), Dodécaphonie pénale, Liber discipulorum en l'honneur du Professeur Robert Roth, Genf/Zürich/Basel 2016, S. 97 ff. (zit. HOHL-CHIRAZI, LD Roth).
- HOHL-CHIRAZI CATHERINE, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, Diss. Genf 2016 (zit. HOHL-CHIRAZI, Diss.).
- HÖRNER WALTER/LIEBAU KARIN/FOERSTER KLAUS, Die Berücksichtigung des forensisch-psychiatrischen Gutachtens im Strafverfahren und im rechtskräftigen Urteil, MschrKrim 1988, S. 395 ff.
- HORWITZ E. JULIE/MCCAFFREY J. ROBERT, Effects of a third party observer and anxiety on tests of executive function, Archives of Clinical Neuropsychology 2008, S. 409 ff.
- HOWE SHAW LEE LAURA/MCCAFFREY J. ROBERT, Third party observation during neuropsychological evaluation: An update on the literature, practical advice for practitioners, and future directions, The Clinical Neuropsychologist 2010, S. 518 ff.
- HUBER ANDREAS, Experten und Expertenkommissionen im Strafprozess und im Straf- und Massnahmenvollzug: Eine kritische Analyse der Mitwirkung von Sachverständigen, Fachrichtern und Fachkommissionen unter Berücksichtigung verwaltungs- und staatsrechtlicher Aspekte, Diss. Basel, Zürich 2019.

- HUNKELER GILBERT, Mittendrin statt nur dabei – Reflexion über die Rolle des Rechtsanwenders, gestützt auf ein systemtheoretisch geprägtes Modell interkultureller Kommunikation, Jusletter 15. Juni 2009.
- IGNOR ALEXANDER, Ist der schweigende Angeklagte der Goldstandard der Verteidigung?, FPPK 2015, S. 92 ff.
- ISENRING BERNHARD/MÜLLER RAHEL, Kommunikation zwischen Verteidigung und Gutachter im Strafprozess, AJP 2016, S. 1334 ff.
- JACKSON JOHN, Re-conceptualizing the Right of Silence as an Effective Fair Trial Standard, International and Comparative Law Quarterly 2009, S. 835 ff.
- JACOBS ANN, L'arrêt Cottin c. Belgique ou l'irrésistible marche vers l'expertise contradictoire en matière pénale, Note sous l'arrêt Cottin c. Belgique du 2 juin 2005, de la Cour européenne des droits de l'homme (1re section), Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme 2007, S. 215 ff.
- JACOBS ANN/GUERRA VINCENT, L'expertise pénale à la croisée des chemins, Biquet-Mathieu Christine et al. (Hrsg.), Liber Amicorum Paul Delnoy, Brüssel 2005, S. 949 ff.
- JANSEN GABRIELE, Zeuge und Aussagenpsychologie, 2. A., Heidelberg 2012.
- JEANNERET YVAN/KUHN ANDRÉ, Précis de procédure pénale, 2. A, Bern 2018.
- JEGER JÖRG, Die Mitwirkung Dritter bei der Begutachtung aus der Sicht des medizinischen Gutachters, Jusletter 3. September 2007.
- KALMBACH C. KAREN/LYONS M. PHILLIP, Unique Nature of Forensic Mental Health Practice, Applied Psychology in Criminal Justice 2006, S. 261 ff.
- KAMMEIER HEINZ/POLLÄHNE HELMUTH (Hrsg.), Massregelvollzugsrecht, Kommentar, 4. A., Berlin/Boston 2018 (zit. Kammeier/Pollähne-BEARBEITER).
- KARPENSTEIN ULRICH/MAYER C. FRANZ, (Hrsg.), EMRK, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Kommentar, 2. A., München 2015 (zit. Karpenstein/Mayer-BEARBEITER).
- KAUFMANN ARIANE, Das Unmittelbarkeitsprinzip und die Folgen seiner Einschränkung in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Diss. Luzern, Zürich 2013.
- KELLER KARIN, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, unter besonderer Berücksichtigung der Regelung im Kanton Zürich, Diss. Zürich 1993.

- KEPPLINGER HANS MATHIAS/JOST PABLO/WOHLRABE MARTIN, Strafprozesse unter dem Einfluss von Online- und Offlinemedien aus Sicht von Richtern und Staatsanwälten, Mainz 2018.
- KIEGELAND PETER, Praxishandbuch der Exploration, Arbeitstechniken für die medizinisch-psychologische Begutachtung, Berlin 2011.
- KIESEWETTER MARTIN, Anforderungen an das psychiatrische Gutachten, Kriminalistik 1995, S. 601 ff. (zit. KIESEWETTER, Kriminalistik 1995).
- KIESEWETTER MARTIN, Schuld, Delinquenz und forensische Psychiatrie, ZStrR 2010, S. 318 ff. (zit. KIESEWETTER, ZStrR 2010).
- KONRAD NORBERT, Begrüßung und Einführung in das Tagungsthema, in: Pol-lähne Helmut/Lange-Joest Christa (Hrsg.), Achtung: Begutachtung!, Sachverständige in Justiz und Gesellschaft: Erwartungen und Verantwortung, Berlin 2017, S. 9 ff. (zit. KONRAD, Tagungsthema).
- KONRAD NORBERT, Schlechtachten trotz Einhaltung der »Mindestanforderungen an Prognosegutachten«, R & P 2010, S. 30 ff. (zit. Konrad, R & P 2010).
- KONRAD NORBERT/HUCHZERMEIER CHRISTIAN, ICD-11: Ändert sich die forensisch-psychiatrische Begutachtung im Strafrecht?, R & P 2019, S. 84 ff. (zit. KONRAD/HUCHZERMEIER, R & P 2019).
- KONRAD NORBERT/RASCH WILFRIED, Forensische Psychiatrie, Rechtsgrundlagen, Begutachtung und Praxis, 4. A., Stuttgart 2014.
- KRAMMER SANDY/WEBER JONAS/LIEBRENZ MICHAEL, Frauen mit einer Massnahme nach Artikel 59, 60, 61 oder 63 StGB, SZK 2/2018, S. 33 ff.
- KRAUSS DETLEF, Richter und Sachverständiger im Strafverfahren, ZStW 1973, S. 320 ff. (zit. KRAUSS, ZStW 1973).
- KRAUSS DETLEF, Schweigepflicht und Schweigerecht des ärztlichen Sachverständigen im Strafprozeß, ZStW 1985, S. 81 ff. (zit. KRAUSS, ZStW 1985).
- KRÖBER HANS-LUDWIG ET AL. (Hrsg.), Handbuch der Forensischen Psychiatrie, Band 1, Strafrechtliche Grundlagen der Forensischen Psychiatrie, Darmstadt 2007 (zit. Kröber et al.-I-BEARBEITER).
- KRÖBER HANS-LUDWIG ET AL. (Hrsg.), Handbuch der Forensischen Psychiatrie, Band 2, Psychopathologische Grundlagen und Praxis der Forensischen Psychiatrie im Strafrecht, Berlin Heidelberg 2010 (zit. Kröber et al.-II-BEARBEITER).
- KRÖBER HANS-LUDWIG ET AL. (Hrsg.), Handbuch der Forensischen Psychiatrie, Band 3, Psychiatrische Kriminalprognose und Kriminaltherapie, Berlin Heidelberg 2006 (zit. Kröber et al.-III-BEARBEITER).

- KRÖBER HANS-LUDWIG, Aktengutachten, FPPK 2013, S. 302 f. (zit. KRÖBER, FPPK 2013).
- KRÖBER HANS-LUDWIG, Aufzeichnung der psychiatrischen Untersuchung, FPPK 2015, S. 98 ff. (zit. KRÖBER, FPPK 2015-A).
- KRÖBER HANS-LUDWIG, Der psychiatrische Gutachter und der schweigende Angeklagte, in: Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernhard Stephan (Hrsg.), Forum Justiz und Psychiatrie, Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung, Bern 2016, S. 31 ff. (zit. KRÖBER, Angeklagte, S).
- KRÖBER HANS-LUDWIG, Die Auseinandersetzung mit der Tat, FPPK 2007, S. 162 ff. (zit. KRÖBER, FPPK 2007).
- KRÖBER HANS-LUDWIG, Die Wahrheit der Person und die Wahrheit der Tat, Der schweigende Angeklagte aus der Sicht des Psychiaters, FPPK 2015, S. 192 f. (zit. KRÖBER, FPPK 2015-B).
- KRÖBER HANS-LUDWIG, Forensisch-psychiatrische Tatanalyse, FPPK 2010, S. 143 ff. (zit. KRÖBER, FPPK 2010).
- KRÖBER HANS-LUDWIG/FALLER UTE/WULF JÖRN, Nutzen und Grenzen standardisierter Schuldfähigkeitsbegutachtung, Eine Überprüfung des Forensisch-Psychiatrischen Dokumentationssystems, MschrKrim 1994, S. 339 ff.
- KSBS/SGFP, Fragenkatalog für Forensisch-Psychiatrische Gutachten, Oktober 2006 (zit. KSBS/SGFP-Fragenkatalog).
- KUHN ANDRÉ/JEANNERET YVAN (Hrsg.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basel 2011 (zit. CR CPP-BEARBEITER).
- KUHN ERICH/BERNHARD STEPHAN, Gutachten entstehen in einer Blackbox, plädoyer 3/2011, S. 6 ff.
- KÜNG MANFRED/HAURI CLAUDE/BRUNNER THOMAS, Handkommentar zur Zürcher Strafprozessordnung, Bern 2005.
- LADEWIG MEYER/NETTESHEIM MARTIN/VON RAUMER STEFAN (Hrsg.), EMRK, Europäische Menschenrechtskonvention, 4. A., Baden-Baden 2017 (zit. LNR-BEARBEITER).
- LAEMMEL KLAUS, Der psychiatrische Gutacher im Spannungsfeld zwischen Richter, Anklage und Verteidigung, SJZ 1994, S. 245 ff.
- LAMBERIGTS STIJN, The privilege against self-incrimination, A Chameleon of Criminal Procedure, New Journal of European Criminal Law 2016, S. 418 ff.

- LANDE GREGORY R., Videotaping, informed consent and forensic psychiatry, *The Journal of Psychiatry & Law* 2001, S. 53 ff.
- LEHNER CHRIS, Nachträgliche Anordnung stationärer therapeutischer Massnahmen, Eine Auseinandersetzung mit Art. 65 Abs. 1 StGB, Diss. Luzern, Zürich 2015.
- LEYGRAF NORBERT, Probleme der psychiatrischen Begutachtung bei nichtgeständigen Beschuldigten, in: Leygraf et al. (Hrsg.), *Die Sprache des Verbrechens – Wege zu einer klinischen Kriminologie*, Festschrift für Willfried Rasch, Stuttgart/Berlin/Köln 1993, S. 78 ff.
- LIEBER VIKTOR, Ungenügende Verteidigung und die Folgen – Streiflichter zur neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, *fp* 2013, S. 51 ff.
- LITTMANN ECKHARD, Die forensische Begutachtungsuntersuchung im Erleben der Betroffenen, in: Leygraf et al. (Hrsg.), *Die Sprache des Verbrechens – Wege zu einer klinischen Kriminologie*, Festschrift für Willfried Rasch, Stuttgart/Berlin/Köln 1993, S. 85 ff.
- LOOSER E. MARTIN/HERZOG MANUELA, «9/11»-Erlasse und deren Massgeblichkeit trotz Grundrechtsverletzungen, in: Juchli Philipp/Würmli Marcel (Hrsg.), *Auswirkungen des Terrorismus auf Recht, Wirtschaft und Gesellschaft*, Schriften der Assistierenden der Universität St. Gallen (HSG), Bern 2006, S. 17 ff.
- LUPU ANCA, Questions pratiques sur le secret médical, *FZR* 2015 S. 121 ff.
- MAIER PHILIPP/MÖLLER ARNULF, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss Art. 13 StGB, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelung ausgewählter Kantone, Zürich 1999.
- MARELLI RENATO, Das psychiatrische Gutachten, Einflüsse und Grenzen, in: Riemer-Kafka Gabriela (Hrsg.), *Psyche und Sozialversicherung*, Luzern 2014, S. 75 ff.
- MARNEROS ANDREAS, Zum Geständnis «verholfen»? , Der psychiatrische Sachverständige als Ermittler?, *MschrKrim* 1999, S. 359 ff.
- MARQUES LOPES CAROLINA ISABEL, La participation de la défense aux expertises pénales, *Jusletter* 6. Januar 2014.
- MARTINEZ RICHARD/GRAY THOMAS B., Ethics and the mandated video recording of forensic evaluations, in: Griffith Ezra (Hrsg.), *Ethics Challenges in Forensic Psychiatry and Psychology Practices*, New York 2018, S. 176 ff.
- MAURER THOMAS, *Das bernische Strafverfahren*, 2.A., Bern 2003.
- MAZOU MIRIAM, Avocat de la première heure: Quo vadis?, *Jusletter* 13. Februar 2012.

- MEIER MARKUS J./BIGLER ADRIAN, Gedanken zur Gutachtenspraxis im Strafverfahren, *ContraLegem* 2019/1, 60 ff.
- MEISTER E. KENNETH, Miranda on the Couch: An Approach to Problems of Self-Incrimination, Right to Counsel, and Miranda Warnings in Pre-Trial Psychiatric Examinations of Criminal Defendants, *Columbia Journal of Law and Social Problems* 1975, S. 403 ff.
- MELTON BENTLEY GARY ET AL., Psychological evaluations for the courts: a handbook for mental health professionals and lawyers, 4. A., New York 2018.
- MELUNOVIC KENAD, Das Erfordernis von audiovisuellen Aufzeichnungen im Strafverfahren als Ausfluss des Gebots des bestmöglichen Beweismittels, *AJP* 2016, S. 569 ff.
- MOKROS ANDREAS ET AL., PCL-R, Hare Psychopathy Checklist – Revised, Deutsche Version der Hare Psychopathy Checklist - Revised (PCL-R) von R.D. Hare, Göttingen 2017.
- MOKROS ANDREAS, Möglichkeiten und Grenzen standardisierter Untersuchungsinstrumente, *FPPK* 2016, S. 284 ff.
- MOKROS ANDREAS/HABERMEYER ELMAR/KÜCHENHOFF HELMUT, The Uncertainty of Psychological and Psychiatric Diagnoses, *Psychological Assessment* 2018, S. 556 ff.
- MOREILLON LAURENT/PAREIN-REYMOND AUDE, Petit Commentaire, CPP, Code de procédure pénale, 2. A., Basel 2016.
- MOREL R. KENNETH, Test Security in Medicolegal Cases: Proposed Guidelines for Attorneys Utilizing Neuropsychology Practice, *Archives of Clinical Neuropsychology* 2009, S. 635 ff.
- MÜLLER LEO JÜRGEN/NEDOPIL NORBERT, Forensische Psychiatrie, Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht, 5. A., Stuttgart 2017.
- MURRIE DANIEL C./BOCCACCINI MARCUS T., Adversarial Allegiance among Expert Witnesses, *Annual Review of Law and Social Science* 2015, S. 37 ff.
- NÄPFLI PHILIPP, Das Protokoll im Strafprozess, Unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs zur Schweizerischen Strafprozessordnung und der Zürcher Strafprozessordnung, Diss. Zürich, Visp 2007.
- NÄPFLI PHILIPP/RUCKSTUHL NIKLAUS, Protokolle nur nach dem Vieraugenprinzip, *plädoyer* 2/2017, S. 6 ff.

- NEAL TESS M.S., Discerning bias in forensic psychological reports in insanity cases, *Behavioral Sciences & the Law* 2018, S. 325 ff.
- NEAL TESS M.S./BRODSKY STANLEY L., *Forensic Psychologists' Perceptions of Bias and Potential Correction Strategies in Forensic Mental Health Evaluations*, *Psychology, Public Policy, and Law* 2016, S. 58 ff.
- NEDOPIL NORBERT, *Standardisierte Dokumentation als Methode der Qualitätssicherung*, FPPK 2012, S. 221 ff. (zit. NEDOPIL, FPPK 2012).
- NEDOPIL NORBERT, Verständnisschwierigkeiten zwischen dem Juristen und dem psychiatrischen Sachverständigen, *NStZ* 1999, S. 433 ff. (zit. NEDOPIL, *NStZ* 1999).
- NEDOPIL NORBERT/GRASSL PAUL, *Das Forensisch-Psychiatrische Dokumentationssystem (FPDS)*, *Forensia* 1988, S. 139 ff.
- NEDOPIL NORBERT/KRUPINSKI MARTIN, *Beispiel-Gutachten aus der Forensischen Psychiatrie*, Stuttgart 2001.
- NIGGLI ALEXANDER MARCEL, Materielle Wahrheit, *ContraLegem* 2018/2, S. 83 ff.
- NIGGLI ALEXANDER MARCEL/HEER MARIANNE/WIPRÄCHTIGER HANS (Hrsg.), *Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung*, Band I, Art. 1-195 StPO, 2. A., Basel 2014 (zit. BSK StPO-I-BEARBEITER).
- NIGGLI ALEXANDER MARCEL/HEER MARIANNE/WIPRÄCHTIGER HANS (Hrsg.), *Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung*, Band II, Art. 196-437 StPO, Art. 1-54 JStPO, 2. A., Basel 2014 (zit. BSK StPO-II-BEARBEITER).
- NIGGLI ALEXANDER MARCEL/WIPRÄCHTIGER HANS (Hrsg.), *Basler Kommentar, Strafrecht I*, Art. 1-136 StGB, 4. A., Basel 2018 (BSK StGB-BEARBEITER).
- NOLL THOMAS, Die Schuldfähigkeit aus psychiatrisch-psychologischer Sicht, *ZStrR* 2017, S. 61 ff.
- NOLL THOMAS/BERNHARD STEPHAN, Die Ausnahme ist zur Regel geworden, *plädoyer* 5/2017, S. 6 ff.
- NOWROUSIAN BIJAN, *Verteidiger*, *Kriminalistik* 2018, S. 104 ff.
- OBERGERICHT ZÜRICH, *Fachkommission psychiatrische und psychologische Gutachten, Leitfaden zur Gutachtenerstellung vom 17. Juni 2014* (zit. OGER-ZH-FAKO, Leitfaden).

- OBERHOLZER NIKLAUS, Die aktuelle Praxis des Bundesgerichts zu psychiatrischen Gutachten, in: Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernhard Stephan (Hrsg.), Forum Justiz und Psychiatrie, Erkenntnisse von Fachkommissionen Chance einer umfassenden Überprüfung oder Instrument der Repression?, Psychiatrische Gutachten im Fokus des Bundesgerichts, Gerechtfertigte Strenge oder zu hohe Anforderungen?, Bern 2017, S. 51 ff. (zit. OBERHOLZER, Praxis).
- OBERHOLZER NIKLAUS, Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung aus der Perspektive der Justiz, in: Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernhard Stephan (Hrsg.), Forum Justiz und Psychiatrie, Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung, Bern 2016, S. 43 ff. (zit. OBERHOLZER, Begutachtung).
- OBERHOLZER NIKLAUS, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. A., Bern 2012 (zit. OBERHOLZER, Grundzüge 2012).
- OBERHOLZER NIKLAUS, Grundzüge des Strafprozessrechts, Dargestellt am Beispiel des Kantons St. Gallen, 2. A., Bern 2005 (zit. OBERHOLZER, Grundzüge 2005).
- OBERHOLZER NIKLAUS, Renaissance des Strafrechts? – Oder die neue Lust am Strafen, ZStr 2018, S. 85 ff. (zit. OBERHOLZER, ZStrR 2018, S.).
- OERTLE MARKUS/HOLENSTEIN PETER, Der Zwillingsmord von Horgen, Hintergründe und Aufklärung einer unfassbaren Tat, Kriminalistik 2016, S. 129 ff.
- OTT DOMINIQUE, Der Grundsatz «nemo tenetur se ipsum accusare» unter besonderer Berücksichtigung der strassenverkehrsrechtlichen Pflichten, Diss. Zürich 2012.
- OTTO K. RANDY/KRAUSS A. DANIEL, Contemplating the Presence of Third Party Observers and Facilitators in Psychological Evaluations, Assessment 2009, S. 362 ff.
- PALARIC RONAN/MOULIN VALÉRIE, Critères intervenant dans le choix de l'expert judiciaire, psychiatre ou psychologue en France, Annales Médico-Psychologiques 2014, S. 489 ff.
- PAREIN LOIC, La présomption de non-dangerosité en procédure pénale suisse: une consécration nécessaire, ZSR 2018, S. 367 ff.
- PAREIN LOIC/BURGENER FABIO, Affaire Beuze c. Belgique, La présence et le rôle de l'avocat au début de la procédure pénale, AJP 2019, S. 538 ff.
- PETERMANN FRANK, Auskunftsperson oder Beschuldigter?, AJP 2012, S. 1053 ff.

- PICHINI D. ROBERTA, The Right to Counsel during Court-Ordered Psychiatric Examinations of Criminal Defendants, *Villanova Law Review* 1980, S. 135 ff.
- PIES RONALD, How Objective Are Psychiatric Diagnoses?, (Guess Again), *Psychiatry* 2007, S. 18 ff.
- PIETH MARC, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 3. A., Basel 2016.
- PIQUEREZ GÉRARD, *Procédure pénale jurassienne*, Fontanais 2002 (zit. aCPP-JU-PIQUEREZ).
- PIQUEREZ GÉRARD, *Procédure Pénale Suisse, Traité Théorique et Pratique*, 2. A., Zürich 2006 (zit. PIQUEREZ, Traité).
- PIQUEREZ GÉRARD/MACALUSO ALAIN, *Procédure pénale suisse*, 3. A., Zürich 2011.
- PITCHER KELLY, *Judicial Responses to Pre-Trial Procedural Violations in International Criminal Proceedings*, Diss. Amsterdam, Den Haag 2018.
- PITTELOUD JO, *Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire a l'usage des praticiens*, Zürich 2012.
- PIVATY ANNA, The Right to Custodial Legal Assistance in Europe: In Search for the Rationales, *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 2018, S. 62 ff.
- POLLÄHNE HELMUT, Begutachtung!, Nach bestem Wissen und Gewissen?, in: Pollähne Helmut/Lange-Joest Christa (Hrsg.), *Achtung: Begutachtung!, Sachverständige in Justiz und Gesellschaft: Erwartungen und Verantwortung*, Berlin 2017, S. 23 ff. (zit. POLLÄHNE, Begutachtung).
- POLLÄHNE HELMUT, Kriminalprognostik zwischen richtigen Basisraten und falschen Positiven: Theoretische, methodologische und juristische Aspekte, in: Stephan Barton (Hrsg.), «... weil er für die Allgemeinheit gefährlich ist!», *Prognosegutachten, Neurobiologie, Sicherungsverwahrung*, Baden-Baden 2006, S. 221 ff. (zit. POLLÄHNE, Basisraten).
- POLLÄHNE HELMUT, Pollähne Helmut, Prognostik, Strafrecht und Risiko, in: Rode Irmgard/Kammeier Heinz/Leipert Matthias (Hrsg.), *Prognosen im Strafverfahren und bei der Vollstreckung*, Münster 2004, S. 11 ff. (zit. POLLÄHNE, Risiko).
- PRONIN EMILY/KUGLER MATTHEW B., Valuing thoughts, ignoring behavior: The introspection illusion as a source of the bias blind spot, *Journal of Experimental Social Psychology* 2007, S. 565 ff.
- PRUETER-SCHWARTE CHRISTIAN/KUNERT JÜRGEN HANNS, Die Qualität von Schuldfähigkeitsgutachten bei im Maßregelvollzug untergebrachten Pati-

- enten – Ergebnisse einer empirischen Studie, in: Saimeh Nahlah (Hrsg.), *Respekt – Kritik – Entwicklung*, Bonn 2012, S. 127 ff.
- PRÜFER HANS, *Der Delinquent in der Sprache des Gutachters*, in: Leygraf et al. (Hrsg.), *Die Sprache des Verbrechens – Wege zu einer klinischen Kriminologie*, Festschrift für Willfried Rasch, Stuttgart/Berlin/Köln 1993, S. 99 ff.
- RACHLIN STEPHEN/SCHWARTZ HAROLD L., *The Presence of Counsel at Forensic Psychiatric Examinations*, *Journal of Forensic Sciences*, 1988, S. 1008 ff.
- RAMOS VÂNIA COSTA, *The rights of the defence according to the ECtHR, An Illustration in the Light of A.T. v. Luxembourg and the Right to Legal Assistance*, *New Journal of European Criminal Law* 2016, S. 397 ff.
- REDMAYNE MIKE, *Rethinking the Privilege Against Self-Incrimination*, *Oxford Journal of Legal Studies* 2007, S. 209 ff.
- RETTENBERGER MARTIN/VON FRANQUÉ FRITJOF (Hrsg.), *Handbuch kriminalprognostischer Verfahren*, Göttingen 2013 (zit. Rettenberger/von Franqué-BEARBEITER).
- REY GRÉGOIRE, *Procédure Pénale Genevoise et Règles Fédérales applicables*, *Annotations et Commentaires*, Basel 2005.
- RICHNER LORENZ, *Die Psychiatrie und das Strafrecht*, *NZZ* 2. Mai 2013, S. 22.
- RIEDO CHRISTOF/FIOLKA GERHARD/NIGGLI ALEXANDER MARCEL, *Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen*, Basel 2011.
- RIEMER-KAFKA GABRIELA, *Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung*, in: Gabriela Riemer-Kafka, Marc Hürzeler (Hrsg.), *Das indikatorenenorientierte Abklärungsverfahren*, Zürich 2018, S. 149 ff.
- RIKLIN FRANZ, *Das Unmittelbarkeitsprinzip im schweizerischen Strafverfahrensrecht*, *ZStW* 2014, S. 173 ff. (zit. RIKLIN, *ZStW* 2014).
- RIKLIN FRANZ, *StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen*, 2. A., Zürich 2014. (zit. RIKLIN, Art. N).
- ROTH SIMON, *Das Verhältnis zwischen verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflichten und dem Grundsatz «nemo tenetur se ipsum accusare»*, *ZStrR* 2011, S. 296 ff. (zit. ROTH, *ZStrR* 2011).
- ROTH ANDREAS, *Rechtsprechung unter der Lupe, Strassenverkehr* 2019, S. 47 (zit. ROTH, *Strassenverkehr* 2019).
- RUCKSTUHL NIKLAUS, *Die Strafverteidigung als Institut*, *Anwaltsrevue* 2019, S. 256 ff.

- RUCKSTUHL NIKLAUS/DITTMANN VOLKER/ARNOLD JÖRG, Strafprozessrecht, unter Einschluss der forensischen Psychiatrie und Rechtsmedizin sowie des kriminaltechnischen und naturwissenschaftlichen Gutachtens, Zürich 2011.
- SACHS JOSEF/HABERMEYER ELMAR, Qualifizierung und Qualitätskontrolle in der forensischen Psychiatrie, Die gegenwärtigen Standards in der Schweiz, FPPK 2012, S. 258 ff.
- SAIMEH NALAH, Anmerkungen zur Veränderung der Gutachter-Landschaft, Zertifizierungen, Gutachterstatus, Rollenkonflikte, in: Pollähne Helmut/Lange-Joest Christa (Hrsg.), Achtung: Begutachtung!, Sachverständige in Justiz und Gesellschaft: Erwartungen und Verantwortung, Berlin 2017, S. 53 ff.
- SAMUELSSON EVALOTTA, Sind die Parteirechte bei Begutachtungen gewahrt?, plädoyer 5/2006, S. 25.
- SANER ALAIN, Das Teilnahmerecht der Verteidigung bei der psychiatrischen Exploration der beschuldigten Person, ZStrR 2014, S. 121 ff.
- SASS HENNING/HABERMEYER ELMAR, Die Begutachtung von Persönlichkeitsstörungen aus psychopathologischer Sicht, FPPK 2007, S. 156 ff.
- SCHLEGEL STEPHAN, Die Verwirklichung des Rechts auf Wahlverteidigung, Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum schweizerischen und deutschen Recht, Diss. Zürich 2010.
- SCHLEGEL STEPHAN/WOHLERS WOLFGANG, Der »Anwalt der ersten Stunde« in der Schweiz, Zugleich ein Beitrag zu den menschenrechtlichen Mindeststandards der Strafverteidigung, StV 2012, S. 307 ff.
- SCHLOTHAUER REINHOLD, Reform des Ermittlungsverfahrens, in: Strafverteidigervereinigungen, Organisationsbüro (Hrsg.), Bild und Selbstbild der Strafverteidigung, Texte und Ergebnisse des 40. Strafverteidigertags, Frankfurt am Main, 4. - 6. März 2016; Schriftenreihe der Strafverteidigervereinigungen, Bd. 40, Berlin 2016, S. 59 ff.
- SCHMID CARSTEN OLIVIER/SCHOLZ BERNDT O., Schuldfähigkeitsbegutachtung bei Tötungsdelikten, Neue Befunde zur Begutachtungspraxis sowie zu Divergenzen zwischen Gutachtern und Gerichten, MschrKrim 2000, S. 414 ff.
- SCHMID DANIEL, Krank oder böse? Die Schuldfähigkeit und die Sanktionenindikation dissozial persönlichkeitsgestörter Straftäter und delinquenter Psychopaths sowie die Zusammenarbeit von Jurisprudenz und Psychiatrie bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit, Diss. Basel 2009 (zit. SCHMID, Diss.).

- SCHMID GIAN ANDREA, Gutachten: Kritik an der Dunkelkammer, plädoyer 6/2017, S. 22 f. (zit. SCHMID, plädoyer 6/2017).
- SCHMID NIKLAUS, «Anwalt der ersten Stunde» – Zu den Lösungsvorschlägen des Vorentwurfs für eine Schweizerische Strafprozessordnung vom Juni 2001, in: Donatsch Andreas/Forster Marc/Schwarzenegger Christian (Hrsg.), Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte Festschrift für Stefan Trechsel zum 65. Geburtstag, Zürich 2002, S. 745 ff. (zit. SCHMID, FS Trechsel).
- SCHMID NIKLAUS, Einige Aspekte der naturwissenschaftlichen Gutachten aus der Sicht der Schweizerischen Strafprozessordnung, AJP 2010, S. 819 ff. (zit. SCHMID, AJP 2010).
- SCHMID NIKLAUS, Strafprozessrecht, Eine Einführung auf der Grundlage des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, 4. A., Zürich/Basel/Genf 2004 (zit. SCHMID, Strafprozessrecht).
- SCHMID NIKLAUS/JOSITSCH DANIEL, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. A., Zürich/St. Gallen 2017 (zit. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch).
- SCHMID NIKLAUS/JOSITSCH DANIEL, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 3. A., Zürich/St. Gallen 2017 (zit. SCHMID/JOSITSCH, PraKomm).
- SCHNEIDER FRANK/FRISTER HELMUT/OLZEN DIRK, Begutachtung psychischer Störungen, 3. A., Berlin 2015.
- SCHNOOR KATHLEEN, Beurteilung der Schuldfähigkeit, Eine empirische Untersuchung zum Umgang der Justiz mit Sachverständigen, Diss. Giessen, Bonn 2009.
- SCHÖTTLE ALISSA, Die Schuldfähigkeitsbegutachtung in Jugendstrafverfahren – Eine Bestands- und Qualitätsanalyse, Diss. Bonn, Berlin 2013.
- SCHREIBER HANS-LUDWIG, Zur Rolle des psychiatrisch-psychologischen Sachverständigen im Strafverfahren, in: Broda Christian et al. (Hrsg.), Festschrift für Rudolf Wassermann zum sechzigsten Geburtstag, Darmstadt 1985, S. 1007 ff.
- SCHÜLER-SPRINGORUM HORST, «Benzin nach Metern»? , Schuldminde rung, Schulausschluss und das Problem der Quantifizierung, in: Pohlmeier Hermann/Deutsch Erwin/Schreiber Hans-Ludwig (Hrsg.), Psychiatrie heute, Ulrich Venzlaff zum 65. Geburtstag, Heidelberg 1986, S. 52 ff.
- SETTEM OLA JOHAN, Applications of the «Fair Hearing» Norm in ECHR Article 6(1) to Civil Proceedings With Special Emphasis on the Balance Between Procedural Safeguards and Efficiency, Cham 2015.

- SHEALY CLAYTON/PIRELLI GIANNI/CRAMER J. ROBERT, Third Party Presence During Criminal Forensic Evaluations: Psychologists' Opinions, Attitudes, and Practices, *Professional Psychology: Research and Practice* 2008, S. 561 ff.
- SIEGEL DAVID M./KINSCHERFF ROBERT, Recording routine forensic mental health evaluations should be a standard of practice in the 21st century, *Behavioral Sciences & the Law* 2018, S. 373 ff.
- SIMON ROBERT, «Three's a crowd»: the presence of third parties during the forensic psychiatric examination, *The Journal of Psychiatry & Law* 1996, S. 3 ff.
- SIMON ROBERT/WETTSTEIN ROBERT, Toward the Development of Guidelines for the Conduct of Forensic Psychiatric Examinations, *Journal of the Academy of Psychiatry and the Law* 1997, S. 17 ff.
- SMITH C. MAXWELL, Quiet Eyes: The Need For Defense Counsel's Presence at Court-Ordered Psychiatric Evaluations, *Capital Defense Journal* 2004, S. 421 ff.
- SOO ANNELI, Divergence of European Union and Strasbourg Standards on Defence Rights in Criminal Proceedings? Ibrahim and the others v. the UK (13th of September 2016), *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 2017, S. 327 ff.
- STIELS-GLEN MICHAEL, N = 1 oder: «Nach bestem Gewissen»? Gutachten in Strafverfahren, *Psychologie und Gesellschaftskritik* 2015, S. 127 ff.
- STRIDBECK ULF ET al., Expert for Whom?, Court-Appointed Versus Party-Appointed Experts, *Psychiatry, Psychology and Law* 2016, S. 246 ff.
- TANNER BETTINA ALEXANDRA, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und seine Grenzen, Diss. Luzern, Zürich 2018.
- THOMMEN MARC, Darf der Beschuldigte im Strafverfahren lügen?, *sui-generis* 2018, S. 313 ff. (zit. THOMMEN, *sui-generis* 2018)
- THOMMEN MARC, Gerechtigkeit und Wahrheit im modernen Strafprozess, *recht* 2014, S. 264 ff. (THOMMEN, *recht* 2014).
- THOMMEN MARC/SAMADI MOJAN, The Bigger the Crime, the Smaller the Chance of a Fair Trial?, Evidence Exclusion in Serious Crime Cases Under Swiss, Dutch and European Human Rights Law, *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 2016, S. 65 ff.
- THOMMEN MARC/SEELMANN MARTIN, Nr. 32 Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, Urteil vom 3. Dezember 2015 i.S. Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich sowie A. gegen B. – SB150061, *fp* 2016, S. 258 ff.

- TOEPEL FRIEDRICH, Grundstrukturen des Sachverständigenbeweises im Strafprozessrecht, Diss. Tübingen 2002.
- TONDORF GÜNTHER/TONDORF BABETTE, Psychologische und psychiatrische Sachverständige im Strafverfahren: Verteidigung bei Schuldfähigkeits- und Prognosebegutachtung, 3. A., Heidelberg 2011.
- TRECHSEL STEFAN, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford 2005.
- TRECHSEL STEFAN/PIETH MARC (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. A., Zürich/St.Gallen 2018 (zit. PK StGB-BEARBEITER).
- URBANIOK FRANK, FOTRES, Diagnostik, Risikobeurteilung und Risikomanagement bei Straftätern, 3. A., Berlin 2016.
- VAN KAMPEN PETRA, Confronting Expert Evidence under the European Convention, in: Nijboer Fredrikus Johannes/Sprangers Wim J.J.M. (Hrsg.), Harmonisation in Forensic Expertise, An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards, Amsterdam 2000, S. 183 ff.
- VENZLAFF ULRICH ET AL. (Hrsg.), Psychiatrische Begutachtung, Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen, 6. A., München 2015 (zit. Venzlaff et al.-BEARBEITER).
- VERHOEVEN WILLEM-JAN, Perspectives on Changes in the Right to Legal Assistance Prior to and During Police Interrogation, Erasmus Law Review 2014, S. 171 ff.
- VERREL TORSTEN, Die Verwertung von Schuldfähigkeitsgutachten im Strafurteil, Ausgewählte Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über die Bedeutung psychowissenschaftlicher Erkenntnisse für die richterliche Entscheidung über Schuld und Sanktion bei Tötungsdelikten, ZStW 1994, S. 332 ff.
- VETTERLI LUZIA, Kein Teilnahmerecht der Verteidigung bei Begutachtung, ius.focus 9/2018, S. 29.
- VOLCKART BERND, Editorial, R & P 2001.
- VUILLE JOËLLE, Pour une redéfinition du principe de libre appréciation des preuves dans le cas des expertises scientifiques, «Justice - Justiz - Giustizia» 2013/3.
- WAGNER THOMAS/KRANICH UDO, Die verkehrspsychologische Exploration als diagnostische Methode in der Fahreignungsbegutachtung, Blutalkohol 2011, S. 1 ff.
- WAHL THOMAS, Die EU-Richtlinien zur Stärkung der Strafverfahrensrechte im Spiegel der EMRK, ERA Forum 2017, S. 311 ff.

- WEBER JONAS ET AL., Anordnung und Vollzug stationärer therapeutischer Massnahmen gemäss Art. 59 StGB mit Fokus auf geschlossene Strafanstalten bzw. geschlossene Massnahmeneinrichtungen, Studie zuhanden der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF), Bern 2015.
- WEDER ULRICH, Die audiovisuelle Aufzeichnung von Einvernahmen und andern Verfahrenshandlungen, in: Cavallo Angela et al. (Hrsg.), *Liber Amicorum für Andreas Donatsch, Im Einsatz für Wissenschaft, Lehre und Praxis*, Zürich 2012, S. 531 ff.
- WELTE ELIANE, Strafjustiz vs. Medien und Öffentlichkeit – zwei Akteure mit gegensätzlichen Interessen, in: *sui-generis* 2017, S. 201 ff.
- WESTHOFF KARL/KLUCK MARIE-LUISE, *Psychologische Gutachten schreiben und beurteilen*, 6. A., Berlin 2014.
- WHITE WELSH S., The Psychiatric Examination and the Fifth Amendment Privilege in Capital Cases, *Journal of Criminal Law and Criminology* 1983, S. 943 ff.
- WIPRÄCHTIGER HANS, *Aussagepsychologische Begutachtung im Strafrecht*, fp 2010 S. 40 ff.
- WOHLERS WOLFGANG, Das Instrument der Fremdanamnese aus der Sicht des Strafprozessrechts, in: Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernhard Stephan (Hrsg.), *Forum Justiz und Psychiatrie, Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung*, Bern 2016, S. 77 ff. (WOHLERS, Fremdanamnese).
- WOHLERS WOLFGANG, Die Fragestellung bei aussagepsychologischen Gutachten als Instrument zur Abgrenzung der Aufgabenbereiche von Strafjustiz und Sachverständigen, in: Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernhard Stephan (Hrsg.), *Forum Justiz und Psychiatrie, Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung*, Bern 2016, S. 109 ff. (zit. WOHLERS, Fragestellung, S.).
- WOHLERS WOLFGANG, Die Pflicht der Verteidigung zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person, *ZStrR* 2012, S. 55 ff. (zit. WOHLERS, *ZStrR* 2012).
- WOHLERS WOLFGANG, Nemo tenetur se ipsum accusare - «an obstruction to the administration of justice?», in: Hettinger et al (Hrsg.), *Festschrift für Wilfried Küper zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2007, S. 691 ff. (zit. WOHLERS, *FS Küper*).
- WOHLERS WOLFGANG, Strafjustiz und Sachverständige, Plädoyer für ein «realistisches» Verständnis des Sachverständigenbeweises, *ZStrR* 2018, S. 431 ff. (zit. WOHLERS, *ZStrR* 2018).

- WOHLERS WOLFGANG, Fair Trial – Grundpfeiler oder Feigenblatt?, fp 2019, S. 207 ff. (zit. WOHLERS, fp 2019).
- WOHLERS WOLFGANG/BLÄSI LINDA, Dogmatik und praktische Relevanz der Beweisverwertungsverbote im Strafprozessrecht der Schweiz, recht 2015, S. 158 ff.
- WU WEI, Interrogational fairness under the European convention on human rights, International Journal of Law, Crime and Justice 2011, S. 37 ff.
- ZAPALLA MARISSA ET AL., Anything You Can Do, I Can Do Better: Bias Awareness in Forensic Evaluators, Journal of Forensic Psychology Research and Practice 2018, S. 45 ff.
- ZAPF PATRICIA ET AL., Cognitive Bias in Forensic Mental Health Assessment: Evaluator Beliefs About Its Nature and Scope, Psychology, Public Policy, and Law 2018, S. 1 ff.
- ZAPF PATRICIA/DROR ITIEL E., Understanding and Mitigating Bias in Forensic Evaluation: Lessons from Forensic Science, International Journal of Forensic Mental Health 2017 (online), S. 1 ff.
- ZÖHNER MALGORZATA ET AL., Muss die Dokumentation des Explorationsgespräches in der Fahreignungsbegutachtung reformiert werden?, Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2013, S. 224 ff.
- ZWEIDLER THOMAS, Die Praxis zur thurgauischen Strafprozessordnung, Bern 2005.
- ZWIEHOFF GABRIELE, Das Recht auf den Sachverständigen, Diss. Hagen, Baden-Baden 2000.

Materialienverzeichnis

- Amtliches Bulletin des Nationalrates, Frühjahrssession 2015, 13.2046, Petition Verein Reform 91, Peter Zimmermann, Schlatt, Artikel 184 StPO, Mehr Rechte für den Verteidiger bei der Erstellung von psychiatrischen Gutachten, S. 565 (zit. Amt. Bull. NR 2015).
- Amtliches Bulletin des Nationalrates, Sommersession 2007, 05.092, Strafprozessrecht, Vereinheitlichung, S. 966 (zit. Amt. Bull. NR 2007).
- Amtliches Bulletin des Ständerates, Frühjahrssession 2015, 13.2046, Petition Verein Reform 91, Peter Zimmermann, Schlatt, Artikel 184 StPO, Mehr Rechte für den Verteidiger bei der Erstellung von psychiatrischen Gutachten, S. 298 (zit. Amt. Bull. SR 2015).
- Amtliches Bulletin des Ständerates, Wintersession 2006, 05.092, Strafprozessrecht, Vereinheitlichung, S. 1024 (zit. Amt. Bull. SR 2006).
- Begleitbericht zum Vorwurf für eine Schweizerische Strafprozessordnung, Bundesamt für Justiz, Bern 2001 (zit. Begleitbericht VE StPO).
- Bericht der Expertenkommission «Vereinheitlichung des Strafprozessrechts», Aus 29 mach 1, Konzept einer eidgenössischen Strafprozessordnung, EJPD, Bern 1997 (zit. Bericht, Aus 29 mach 1).
- Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats vom 19. Februar 2015, 13.2046, Petition Reform 91, Peter Zimmermann, Artikel 184 StPO. Mehr Rechte für den Verteidiger bei der Erstellung von psychiatrischen Gutachten. (zit. Bericht RK NR, Petition Reform 91).
- Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerats vom 10. Februar 2015, 13.2046, Petition Reform 91, Peter Zimmermann, Artikel 184 StPO. Mehr Rechte für den Verteidiger bei der Erstellung von psychiatrischen Gutachten. (zit. Bericht RK SR, Petition Reform 91).
- Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085 (zit. Botschaft StPO).
- Protokoll der Rechtskommission des Nationalrates vom 22. Februar 2007 (zit. Protokoll RK-NR 22. Feb. 2007).
- Protokoll der Rechtskommission des Ständerates vom 21. August 2006 (zit. Protokoll RK-SR 21. Aug. 2006).
- Rapport d'activité intermédiaire à Monsieur le Conseiller fédéral Koller, Commission d'experts «Unification de la procédure pénale», Bern 1995 (zit. Rapport d'activité intermédiaire).

Abkürzungsverzeichnis

A.	Auflage
a.M.	anderer Meinung
AAPL	American Academy of Psychiatry and the Law
Abs.	Absatz
aBV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874
aCPP-JU	Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura du 13 décembre 1990
AJP	Zeitschrift für die Allgemeine Juristische Praxis (Lachen)
AMDP	Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie
Amt. Bull.	Amtliches Bulletin
Art.	Artikel
aStPO-ZH	Strafprozessordnung (StPO) des Kantons Zürich vom 4. Mai 1919
aStPO-VD	Code de procédure pénale (CPP) de Canton de Vaud 12 septembre 1967
aStPO-TI	Codice di procedura penale della Repubblica e Cantone Ticino dicembre 1994
ATSG	Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 (SR 830.1)
BGE	Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Lausanne)
BGer	Bundesgericht
BGFA	Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) vom 23. Juni 2000 (SR 935.61)
BGH	Bundesgerichtshof (Deutschland)
BJM	Basler Juristische Mitteilungen (Reinach)
BMJV	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Deutschland)

BSK	Basler Kommentar
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101)
bzw.	beziehungsweise
CdJ-GE	Cour de Justice de Genève
CH	Schweiz
CP	Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (SR 311.0)
CPP	Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007 (SR 312.0)
CR	Commentaire Romand
CSdCass	Corte Suprema di Cassazione (Italien)
d.h.	das heisst
Diss.	Dissertation
E.	Erwägung
ECHR	European Convention on Human Rights (EMRK)
ECtHR	European Court of Human Rights (EGMR)
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EMRK	Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (SR 0.101)
ERA Forum	ERA Forum, Journal of the Academy of European Law (Berlin)
et al.	et alli (und andere)
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EVGer	Eidgenössisches Versicherungsgericht
f.	folgende
ff	fortfolgende
FG	Festgabe
Fn.	Fussnote
fp	forumpoenale (Bern)

FPDS	Forensisch-psychiatrisches Dokumentationssystem
FPPK	Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie (Heidelberg)
FS	Festschrift
FZR	Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung (Freiburg)
Hrsg.	Herausgeber
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
inkl.	inklusive
insb.	insbesondere
IPBPR	Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (SR 0.103.2)
JStPO	Schweizerische Jugendstraßprozessordnung Jugendstraßprozessordnung, JStPO (SR 312.1)
KassGer-ZH	Kassationsgericht des Kantons Zürich
KGer-LU	Kantonsgericht des Kantons Luzern
KGer-GR	Kantonsgericht des Kantons Graubünden
KSBS	Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (neu: Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz, SSK)
lit.	litera
MedSach	Der medizinische Sachverständige (Stuttgart)
MschrKrim	Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform (Köln)
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
N	Note
no.	Number
NStZ	Neue Zeitschrift für Strafrecht (München)
NZZ	Neue Zürcher Zeitung
OGer-BE	Obergericht des Kantons Bern
OGer-BL	Obergericht des Kantons Basel-Land
OGer-ZH	Obergericht des Kantons Zürich

OGER-ZH-FAKO	Obergericht des Kantons Zürich, Fachkommission psychiatrische und psychologische Gutachten
PraKomm	Praxiskommentar
R & P	Recht & Psychiatrie (Köln)
RK-SR	Rechtskommission des Ständerates
RK-NR	Rechtskommission des Nationalrates
S.	Seite
SGFP	Schweizerischen Gesellschaft für Forensische Psychiatrie
SGPP	Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie
SJZ	Schweizerische Juristenzeitung (Zürich)
sog.	sogenannt
StBOG	Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) vom 19. März 2010 (SR 173.71)
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
StPO	Schweizerische Strafprozessordnung, (Strafprozessordnung, StPO) vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0)
StV	Strafverteidiger (Köln)
SZK	Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie (Bern)
SZS	Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (Bern)
TriApp-TI	La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
u.a.	unter anderem
usw.	und so weiter
v.	versus
VE StPO	Vorentwurf zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung (Bern 2001)
VGer-BL	Verfahrensgericht des Kantons Basel-Land
vgl.	vergleiche

Vol.	Volume
z.B.	zum Beispiel
ZSR	Zeitschrift für schweizerisches Recht (ZSR)
Ziff.	Ziffer
zit.	zitiert
ZK	Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung
ZStrR	Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (Bern)
ZStW	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen- schaft (Berlin)

1. Teil: Einleitung

§ 1 Themenaufriß

«Der Sachverständige hat sich in unserem Strafverfahren neben Polizei und Staatsanwaltschaft einerseits und Gericht andererseits weitgehend als eine den Tathergang ermittelnde und die Entscheidung vorprogrammierende Institution etabliert.» Die Worte von Detlef Krauss aus dem Jahr 1973 haben in keiner Weise an Geltungskraft eingebüßt.¹ Angesichts der prominenten Bedeutung des Sachverständigen überrascht es nicht, dass seine Normierung eine umstrittene Materie des Strafprozessrechts darstellt. Dies gilt für die Tätigkeit von psychiatrischen Sachverständigen (PSY-Sachverständige) in besonderem Masse. Seit jeher bestehen Bestrebungen, die «Staatsanwälte und Richter in Weiss»² mit dem Mittel des Verfahrensrechts unter Kontrolle zu bringen. Dabei ringen Juristen und PSY-Sachverständige kraft ihrer divergierenden Ausbildungen und Denkmuster um die Deutungshoheit im Verfahren.³ 1

Für ein Dauerbrennerthema im interdisziplinären Diskurs sorgen die selbständigen Erhebungen des PSY-Sachverständigen.⁴ Diese stehen im Verdacht, die Verfahrensrechte der Parteien auszuhöhlen.⁵ Für ein bestimmtes Untersuchungsmittel besteht diesbezüglich gar eine dringende Verdachtslage: das Explorationsgespräch des PSY-Sachverständigen mit der beschuldigten Person. Durch diesen Untersuchungsschritt sollen die Verteidigungsrechte der beschuldigten Person in besonderer Weise exponiert sein. Diesem Umstand möchte ein Teil der Lehre damit begegnen, dass der Verteidigung der beschuldigten Person ein Teilnahmerecht am Explorationsgespräch zwischen dem PSY-Sachverständigen und der beschuldigten Person eingeräumt wird.⁶ Eine Forderung, die sich bald harmonisch, bald dissonant in die Ziele eines Strafverfahrens einfügt, wie die nachfolgenden Ausführungen dieses Themenaufrißes illustrieren. 2

¹ KRAUSS, ZStW 1973, S. 320.

² BRUNNER, Aspekte, S. 186 ff.

³ BERNHEIM, S. 59; DIPPEL, Diss., S. 47 ff.; FONJALLAZ/GASSER, S. 161 ff.; MAIER/MÖLLER, S. 39 ff.; OBERHOLZER, Praxis, S. 55 ff.; SCHMID, Diss., S. 439.

⁴ HEER, FS Wiprächtiger, 185 f.; HEER, Feigenblatt, 24 ff.

⁵ HELFENSTEIN, S. 184 ff.; KRAUSS, ZStW 1973, S. 327 ff.

⁶ Stellvertretend: SANER, S. 121 ff.

I. Leitstern: materielle Wahrheit

- 3 Ein elementares Ziel des Strafverfahrens besteht darin, die materielle Wahrheit ans Licht zu bringen, wobei aufgrund der systemimmanenten Grenzen der Beweiserhebung und -würdigung unbestritten ist, dass es sich immer nur um die bestmögliche Annäherung an die objektive Wahrheit handeln kann (sog. prozessuale Wahrheit).⁷ Der Untersuchungsgrundsatz (Art. 6 Abs. 1 StPO) und das Prinzip der freien Beweiswürdigung (Art. 10 Abs. 2 StPO) sind auf höchster Abstraktionsstufe zentrale Garanten für die Erreichung dieses ambitionierten Wahrheitsstrebens. Der Untersuchungsgrundsatz verpflichtet die Strafbehörden, alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären.⁸ Das Prinzip der freien Beweiswürdigung sichert als Komplementär- und Folgestück des Untersuchungsgrundsatzes die möglichst präzise Wahrheitsrekonstruktion ab.⁹ Die urteilende Instanz soll nicht durch starre Beweisregeln, sondern mittels rationaler Erkenntnis zur persönlichen Überzeugung jenseits des vernünftigen Zweifels («in dubio pro reo») gelangen, dass sich ein Geschehen auf eine bestimmte Weise zugetragen hat, und soll diese innere Überzeugung intersubjektiv nachvollziehbar im Urteil darlegen.¹⁰

II. Herausforderung: Beweisführung zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation

- 4 So klar die Maxime der materiellen Wahrheit auf abstrakter Ebene erscheint, so herausfordernd kann sich die Wahrheitssuche in der Praxis gestalten. Dies zeigt sich bei der Feststellung des Tatsachenfundaments für die Fragen der Schuldfähigkeit (Art. 19 f. StGB) und Massnahmenindikation (Art. 56 ff. StGB) geradezu idealtypisch. Hier sieht sich die Verfahrensleitung mit äusserst komplexen Beweisthemen konfrontiert.

⁷ ALBRECHT, Funktion, N 2.6; ALBRECHT, NSTZ 1983, S. 487; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, N 166; THOMMEN, recht 2014, S. 267; zur Tatsache, dass es die objektiv überprüfbare materielle Wahrheit nicht gibt sodann NIGGLI, S. 83 ff.

⁸ Art. 6 Abs. 1 StPO.

⁹ Botschaft StPO, S. 1133.

¹⁰ BSK StPO-I-HOFER, Art. 10 N 61.

1. Beweisfragen um die Schuldfähigkeit

Kommen Fragen zur Schuldfähigkeit (Art. 19 f. StGB) auf, ist auf der Sachverhaltsebene zu prüfen, in welchem psychischen Zustand sich der Täter zum Tatzeitpunkt befand.¹¹ Dabei findet ein komplexes zweistufiges Verfahren – psychiatrisch-normative Methode (auch: biologisch-psychologische Methode) genannt – Anwendung. In einem ersten Schritt ist festzustellen, ob die beschuldigte Person im Tatzeitpunkt an einer psychischen Störung litt.¹² In einem zweiten Schritt ist zu beurteilen, ob und wie stark diese psychische Störung die Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit der beschuldigten Person beeinträchtigte.¹³ Wenn dabei ein psychischer Zustand erkennbar gemacht werden kann, welcher nach «nach Art und Grad stark vom Durchschnitt nicht bloss der Rechts-, sondern auch der Verbrechensgenossen»¹⁴ abweicht und kraft dem die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit im Tatzeitpunkt in qualifizierter Weise beeinträchtigt war, liegt eine verminderte (Art. 19 Abs. 2 StGB) oder bei noch erheblicheren Beeinträchtigungen gar eine aufgehobene Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs.1 StGB) vor.¹⁵

2. Beweisfragen um die Massnahmenindikation

Nicht minder komplex gestaltet sich die Beweisführung für die Massnahmenindikation. Hier ist zu beurteilen, ob zur Verhinderung eines Rückfalls eine stationäre oder ambulante therapeutische Massnahme (Art. 59-61 und 63 StGB) oder die Verwahrung (Art. 64 StGB) anzuordnen ist. Dabei muss «über sämtliche tatsächlichen Voraussetzungen der Massnahmen»¹⁶ Beweis geführt werden. Das so definierte Tatsachenfundament setzt sich aus diversen Teilfragen zusammen.¹⁷ Es ist – komprimiert ausgedrückt – zu klären, ob ein Sonderzustand¹⁸ des

¹¹ BGE 107 IV 3 E. 1a; BGer, 26. November 2009, 6B_725/2009, E. 2; BGE 141 IV 34, nicht publizierte E. 2.2.

¹² BSK StGB-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 14; SCHMID, Diss., S. 436; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S.7 f.

¹³ BSK StGB-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 14; BOETTICHER ET AL., NStZ 2005, S. 58 f.; KIESEWETTER, ZStrR 2010, S. 327 f.; SCHMID, Diss., S. 436; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 8 f.

¹⁴ BGE 116 IV 273, E. 6; BGE 133 IV 145, E. 3.3.

¹⁵ Eingehend dazu BSK StGB-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 30 ff.; PK StGB-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 7 ff.

¹⁶ BGE 144 IV 302, nicht publizierte E. 2.1; BGer, 23. Januar 2018, 6B_28/2017, E. 3.4; BGer, 17. November 2011, 6B_232/2011, E. 3.1.3; vgl. das Fragespektrum im KSBS/SGFP-Fragenkatalog, S. 1 f.

¹⁷ Vgl. die Fragen im KSBS/SGFP-Fragenkatalog, S. 1 f.

¹⁸ Dieser Sonderzustand kann in einer schweren psychischen Störung (Art. 59 und 63 StGB), einer Abhängigkeit von Suchtstoffen oder anderer Abhängigkeit (Art. 60

Täters für die begangene Straftat (mit)verantwortlich war, ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit wegen diesem Sonderzustand des Täters weitere Straftaten zu erwarten sind (Risikobeurteilung), ob der risikorelevante Sonderzustand mit einem Behandlungsbedürfnis des Straftäters korrespondiert, und, sofern dies der Fall ist, ob dieses Behandlungsbedürfnis und das sich daraus ergebende Rückfallrisiko mit einer therapeutischen Massnahme (ambulant oder stationär) in einem bestimmten Zeitrahmen reduziert werden kann oder sich eine Sicherung des Täters aufdrängt (Behandlungsprognose) und welche Möglichkeiten für den Vollzug der geeigneten Massnahme bestehen.¹⁹

III. Lösung: Beizug von psychiatrischen Sachverständigen

- 7 Möchte man die Strafbehörden angesichts dieser Vielzahl an fachspezifischen Fragestellungen im Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationskontext auf sich alleine gestellt lassen, wäre das Verfahrensziel der materiellen Wahrheit gefährdet. Bald stellt sich die Erkenntnis ein: Die Beweisführung im Rahmen von Art. 19 StGB sowie Art. 56 ff. StGB verlangt nach einschlägigem Fachwissen. Der Gesetzgeber hat diese Gefahr erkannt. Sowohl für die Schuldfähigkeit (Art. 20 StGB) als auch für die Anordnung einer Massnahme (Art. 56 Abs. 3 StGB) ist das Einholen eines Sachverständigenbeweises bei entsprechender Begutachtungsindikation unabdingbar.²⁰ Die Verantwortung für die Erstellung des Gutachtens ist dabei in aller Regel in die Hände eines psychiatrischen Sach-

StGB), einer erheblichen Störung der Persönlichkeitsentwicklung bei im Tatzeitpunkt 18 bis 25 Jahre alten Tätern (Art. 61 StGB), einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere (Art. 64 Abs. 1 Ziff. 1 StGB) oder den Persönlichkeitsmerkmalen des Täters, den Tatumständen und in seinen gesamten Lebensumständen (Art. 64 Abs. 1 Ziff. 2 StGB) bestehen.

¹⁹ Art. 56 Abs. 3 StGB; vgl. auch die konstante Formulierung des Bundesgerichts in BGE 134 IV 315, E. 4.3.1; BGer, 12. Dezember 2018, 6B_257/2018 und 6B_270/2018, E. 7.4.2, BGer, 23. Januar 2018, 6B_28/2017, E. 3.3.3; BGer, 6. Mai 2014, 6B_829/2013, E. 4.1, wonach Fragen zur «Notwendigkeit und den Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters, zur Art und Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten und zu den Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme» zu beantworten sind; eingehend zu den Massnahmenvoraussetzungen die Ausführungen bei BSK StGB-HEER, Art. 56 ff. StGB; LEHNER, S. 7 ff.

²⁰ HEER, Feigenblatt, S. 11; Leitlinien zur Begutachtungsindikation: BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 7 ff.; PK StGB-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 10 ff. (Schuldfähigkeit) sowie BSK StGB-HEER, Art. 56 N 41; PK StGB-TRECHSEL/PAUEN BORER, Art. 56 N 10 (Massnahmenindikation).

verständigen zu legen.²¹ Ihm kommt die komplexe Aufgabe zu, das Tatsachengrundament für die Schuld- und/oder Massnahmenfrage zu erschliessen.

IV. Mittel: Erhebungen des PSY-Sachverständigen

Das vom Beizug eines PSY-Sachverständigen erhoffte Wahrheitsplus kann jedoch nur dann ins Verfahren einfliessen, wenn die ihm zur Beurteilung vorgelegten Beweisthemen bestmöglich ausgeleuchtet werden. Einen ersten und wichtigen Baustein dafür bilden die strafbehördlichen Beweiserhebungen. Die Strafbehörde hat der sachverständigen Person die Anknüpfungstatsachen bekanntzugeben, was im Regelfall durch die Übergabe der Akten erfolgt (Art. 184 Abs. 4 StPO).²² Ist der Sachverhalt noch unklar oder wird er von der beschuldigten Person bestritten, muss dem Sachverständigen vorgegeben werden, von welchem Sachverhalt er vorläufig (d.h. unter Vorbehalt der Beweiswürdigung durch das Gericht) auszugehen hat.²³ Die strafbehördlichen Akten sind eine elementare Informationsquelle und erlauben es dem Sachverständigen, erste Hypothesen zu den ihm unterbreiteten Fragestellungen zu bilden.²⁴ Isoliert lassen sie aber nur in beschränktem Masse fachkundige Stellungnahmen zu.²⁵ In der Regel ist es unumgänglich, dass vom PSY-Sachverständigen eigene fachspezifische Erhebungen von sog. Befundtatsachen vorgenommen werden.²⁶ Dieser Umstand wurde vom Gesetzgeber berücksichtigt. Gerade das bei psychiatrischen Gutachten bestehende Bedürfnis, die zu begutachtende Person nach eigenen Fachregeln befragen zu können, stellte ein leitendes Motiv dar, der sachverständigen Person eine Ausnahmekompetenz zur Vornahme von fachspezifischen gutachtenrelevanten Erhebungen einzuräumen (Art. 185 Abs. 4 StPO; sog. «einfache Erhebungen»).²⁷

²¹ BGE 144 IV 176, E. 4.2.1; BGE 140 IV 49, E. 2.

²² BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 29; ZK StPO-DONATSCH, Art. 184 N 43; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, S. 165; BSK StPO-I-HEER, Art. 184 N 5; HELFENSTEIN, S. 173 ff.; MAIER/MÖLLER, S. 128.

²³ BGer, 20. Dezember 2017, 6B_989/2017, E. 3.3.9; KassGer-ZH, 18. September 2006, AC050083, E. III.7.10.d; AEBI ET AL., S. 1464; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, S. 165 f.; ZK StPO-Donatsch, Art. 184 N 42; BSK StPO-I-HEER, Art. 184 N 31.

²⁴ BOETTCHER ET AL., NStZ 2006, S. 541; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 4; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17; FONJALLAZ/GASSER, S. 125; KIEGELAND, S. 47; KRÖBER, FPPK 2013, S. 303; KONRAD/RASCH, S. 200 und 311; WAGNER/KRANICH, S. 3.

²⁵ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 25; MAIER/MÖLLER, S. 138 f.

²⁶ HELFENSTEIN, S. 191 ff.; Kröber et al.-I-RÖSSNER, S. 410.

²⁷ Botschaft StPO, S. 1212; BGer, 2. August 2018, 6B_56/2018, E. 3.4.2.

V. Schlüsselement: Explorationsgespräch

- 9 Mit der gesetzlichen Grundlage (Art. 185 Abs. 4 StPO) eröffnet sich das Untersuchungsinstrumentarium des PSY-Sachverständigen. Für seine Arbeit können Fremdanamnesen (Befragungen von Angehörigen, Arbeitgeber, behandelnden Ärzten oder Therapeuten des Begutachteten), körperliche Untersuchungen, apparative und labortechnische Analysen sowie testpsychologische Untersuchungen wertvolle Aufschlüsse über die strafbehördliche Fragestellung verschaffen.²⁸ Ihr Einsatz ist jedoch indikationsabhängig und steht im Ermessen des PSY-Sachverständigen.²⁹ Genau umgekehrt liegen die Voraussetzungen für den Fokus des vorliegenden Werkes: das Explorationsgespräch mit der beschuldigten Person.

1. Relevanz des Untersuchungsmittels

- 10 Das Explorationsgespräch (bzw. die Explorationsgespräche³⁰) stellt das zentrale Untersuchungsmittel des psychiatrischen Sachverständigen dar.³¹ Diese Tatsache wird in der Rechtsprechung reflektiert. Das Bundesgericht hält in Rezeption des psychiatrischen Methodenstandards fest, dass ein psychiatrisches Gutachten grundsätzlich nur bei Vornahme einer persönlichen Untersuchung (d.h. Explorationsgespräch) fachgerecht erstellt werden kann; reine Aktengutachten stellen eine Ausnahme dar, deren Zulässigkeit im Einzelfall vom Sachverständigen zu begründen ist.³² Im Strafprozess bedeutet dies: Die beschuldigte Person wird im Rahmen der Begutachtung der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation regelmässig durch den PSY-Sachverständigen exploriert.

²⁸ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 19 ff.; FURGER, AJP 1992, S. 1125; GRAF, Fremdanamnese, S. 59; HAUSOTTER, S. 27; MÜLLER/NEDOPIL, S. 365.

²⁹ Für die Fremdanamnese: BGer, 14. September 2001, 6P.40_2001, E. 4d/bb; BGer, 19. Juli 2017, 6B_70/2017, E. 2.2; BGer, 1. Februar 2008, 6B_547/2007, E. 2.7; für testpsychologische Untersuchungen: BGer, 14. September 2001, 6P.40_2001, E. 4d/cc; BGer, 30. März 2010, 6B_92/2010, E. 3.3; BGer, 25. November 2010, 6B_710/2010, E. 1; für die körperliche Untersuchung: BGer, 14. September 2001, 6P.40_2001, E. 4d/aa; BGer, 30. März 2010, 6B_92/2010, E. 3.3.

³⁰ Bei komplexen Fragestellungen finden regelmässig mehrere Termine statt: BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 542; Kröber et al.-III-KRÖBER, S. 96.

³¹ ARENS, S. 268; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 16.; FURGER, ZStrR 1988, S. 388; FURGER, AJP 1992, S. 1124; HAUSOTTER, S. 27; Bliesener/Lösel/Köhnken-HÄNERT, S. 279; SCHNEIDER/FRISTER/OLZEN, S. 65; WAGNER/KRANICH, S. 11.

³² BGE 127 I 54, E. 2f.; BGer, 20. September 2002, 6P.91/2002, E. 2.1.2; BGer, 16. Februar 2009, 6B_937/2008, E. 2.2; BGer, 16. Mai 2011, 6B_1039/2010, E. 4.4; BGer, 19. Mai 2015, 6B_93/2015, E. 5.2; BGer, 30. Januar 2017, 6B_1046/2016, E. 3.3.

2. Methodischer Rahmen der Exploration

Bei der Ausgestaltung der Exploration ist zu betonen, dass die sachverständige Person nach konstanter Rechtsprechung Methodenfreiheit genießt, d.h. sie darf die Untersuchung nach eigenem fachlichem Ermessen ausgestalten, solange sie sich dabei im Rahmen des wissenschaftlichen Standards bewegt und solange ihre «Schlussfolgerungen transparent sowie für die Verfahrensbeteiligten nachvollziehbar» sind.³³ Der maßgebliche wissenschaftliche Standard zeichnet dabei Leitlinien für die zu erhebenden Informationen (A.), den Ablauf des Gesprächs (B.), die Gesprächsführungstechnik (C.) sowie den Teilnehmerkreis der Exploration (D.) vor. 11

A) Kernelemente der Erhebung

Die höchstrichterlich anerkannte Bedeutung des Explorationsgesprächs erklärt sich schnell, wenn man sich der zahlreichen Informationsebenen bewusst wird, die während diesem Untersuchungsvorgang vom Sachverständigen erschlossen werden. Der Fokus liegt nicht nur auf der vollständigen Erhebung der Anamnese (a), des psychischen Befunds sowie der Persönlichkeit des Exploranden (b). Vielmehr wird der Sachverständige im Rahmen des Explorationsgesprächs auch den konkreten Tatvorwurf mit der beschuldigten Person (c) sowie Zukunftsszenarien besprechen (d). 12

a) Anamnese

Eine unverzichtbare Basis für jegliche psychiatrische Stellungnahme stellt die Erhebung der Anamnese dar. Dabei handelt es sich um die systematische Erfragung begutachtungsrelevanter biographischer Kerndaten des Exploranden durch den Sachverständigen, wozu beispielsweise die somatische und psychische Gesundheit, die Familie, die (vor)schulischen Entwicklung, die Pubertät, berufliche Entwicklung, Sexualität, der Substanzkonsum, sozioökonomische Verhältnisse, die Delinquenzhistorie (Legalanamnese, d.h. Vorstrafen), der Tagesablauf sowie die Freizeitgestaltung gehören, wobei je nach Anlass der Begutachtung bereichsspezifisch vertiefte Befragungen notwendig sind.³⁴ 13

³³ BGE 128 I 81, E. 2; BGer, 17. November 2011, 6B_232/2011, E. 2.3; BGer, 14. Dezember 2015, 6B_304/2015, E. 2.4; BGer, 25. Februar 2016, 6B_1237/2015, E. 1.1.3; BGer, 19. Juni 2018, 6B_582/2017, E. 2.2.3; BGer, 24. Oktober 2018, 6B_1006/2017, E. 2.3.3; zur Orientierung am aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand im Rahmen der Schuldfähigkeitsbegutachtung und Risikobeurteilung auch BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 539; BOETTICHER ET AL., NStZ 2005, S. 58.

³⁴ BOETTICHER ET AL., NStZ 2005, S. 59 f.; BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 530 ff.; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 4 f.; DELACRAUSAZ/MOULIN, N 13; EYTAN, S. 18; FONJALLAZ/GASSER, S. 131; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; Bliese-

b) *Psychischer Befund & Persönlichkeitsdiagnostik*

- 14 Die unmittelbare Interaktion zwischen dem PSY-Sachverständigen und der beschuldigten Person in der Exploration ermöglicht sodann die Erhebung des psychischen Befunds, dem Querschnittsbild der psychischen Verfassung des Exploranden zum Untersuchungszeitpunkt³⁵, sowie das Erfassen der Persönlichkeit des Exploranden³⁶. Zu diesem Zweck wird der Sachverständige das Verhalten sowie die subjektive Erlebnisschilderung des Exploranden beobachten, seine Aufmerksamkeit auf zahlreiche Aspekte richten (Konzentration, Gedächtnis, Affekt, Verbalisierungskompetenzen, Kohärenz des Gedankengangs, beobachtbare Persönlichkeitszüge, kognitive Einstellungen, Selbstreflexion usw.) und diese Merkmale des Exploranden beschreiben.³⁷

c) *Tatsachverhalt*

- 15 Die gutachterliche Beurteilung der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation setzt sodann Kenntnisse über das Tatgeschehen voraus.³⁸ Nur mit ausreichendem Wissen über dieses Thema kann die Deliktdynamik (auch: der Deliktsmechanismus) als zentraler Bestandteil des Gutachtens und Grundlage der Schuldfähigkeits- und Risikobeurteilung erarbeitet werden.³⁹ Zwar wird die sachver-

ner/Lösel/Köhnken-HÄNERT, S. 281; KONRAD/RASCH, S. 321 ff; HAUSOTTER, S. 27.

³⁵ BOETTICHER ET AL., NSTZ 2006, S. 542; EYTAN, S. 18; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; KONRAD/RASCH, S. 334.

³⁶ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 6 f.; BOETTICHER ET AL., NSTZ 2006, S. 541: «Ohne die Rekonstruktion der Persönlichkeitsproblematik...fehlt einer in die Zukunft gerichteten Risikoeinschätzung das entscheidende Fundament.»

³⁷ BOETTICHER ET AL., NSTZ 2006, S. 542; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 6 f.; DELACRAUSAZ/MOULIN, N 13; FONJALLAZ/GASSER, S. 131 ff.; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 20; FURGER, AJP 1992, S. 1124; FURGER, ZStrR 1988, S. 388; FINZEN, S. 66; HABERMAYER/SACHS, N 7; HAUG/TRABERT/SCHAUB, S. 257; HAUSOTTER, S. 27; KONRAD/RASCH, S. 334; Kröber et al.-III-KRÖBER, S. 98 ff.; SIMON/WETTSTEIN, S. 24.

³⁸ Für die Schuldfähigkeit geht dies bereits definitorisch aus dem Tatzeitpunktbezug hervor. Für die Massnahmenindikation vgl. BGer, 12. Dezember 2018, 6B_257/2018, 6B_270/2018, E. 7.6.1, in dem das Bundesgericht in Rezeption des psychiatrischen Methodenstandards «die mangelnde Beachtung der Anlasstat...als wesentliche Fehlerquelle bei der Kriminalprognose» bezeichnet und weiter betont: «Für die prognostische Beurteilung können die konstellativen Bedingungen der Tat und die Mittäterschaft von entscheidender Bedeutung sein».

³⁹ Eingehend URBANIOK, S. 22 ff.; zur Relevanz der Deliktdynamik für die Beurteilung der Schuldfähigkeit sowie der Massnahmenindikation auch AEBI ET AL., S. 1473 f.; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 8 ff.; vgl. auch BOETTICHER ET AL., NSTZ 2006, S. 543: «Auf diese Weise soll eine ganz individuelle Theorie generiert wer-

ständige Person einen Teil des dafür notwendigen Tatwissens bereits durch die strafbehördlichen Beweiserhebungen erlangen (Art. 184 Abs. 4 StPO). Diese Informationsbasis wird jedoch im Explorationsgespräch ergänzt. Entsprechend wird die beschuldigte Person im Rahmen der Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbegutachtung seitens des Sachverständigen auch zum Tatsachverhalt befragt.⁴⁰ Dieser Explorationsabschnitt wird in Teilen des forensisch-psychiatrischen Schrifttums sogar als «Schlüsselmoment»⁴¹ oder «Kernbereich der gutachterlichen Untersuchung»⁴² bezeichnet, was die Relevanz des Tatsachverhalts für die Begutachtung belegt. Dabei wird der PSY-Sachverständige sein Augenmerk auf die äusseren Handlungsabläufe des konkret vorgeworfenen Delikts, das Tatvorfeld, das Nachtatverhalten, aber insbesondere auch auf das subjektive Erleben des Exploranden im Tatzeitpunkt richten, um die für seine Beurteilung relevanten Informationen zu ermitteln.⁴³ Gerade für die Risikobeurteilung wird die sachverständige Person überdies Aspekte wie die «Delikteinsicht, Opferempathie, Veränderungsprozesse seit letztem Delikt, Einschätzung von zukünftigen Risiken und deren Management» vertieft explorieren.⁴⁴

den, aus welchen Gründen gerade diese Person bislang straffällig geworden ist, was ggf. ihre Straffälligkeit aufrechterhalten und ausgeweitet hat» (diese Quelle arbeitet zwar nicht wörtlich mit den Begriffen Deliktdynamik/Deliktmehanismus, aber mit der «individuellen Theorie» ist dasselbe gemeint); Venzlaff et al.-LEYGRAF, S. 420; Kröber et al.-III-KRÖBER, S. 90.

⁴⁰ BOETTICHER ET AL., NSTZ 2005, S. 59 f. «Vollständigkeit der Exploration, insbesondere zu den delikt- und diagnosenspezifischen Bereichen (...detaillierte Darlegung der Tatbegehung)»; BOETTICHER ET AL., NSTZ 2006, S. 542 ff.; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 5: «Zu erfassen ist das aktuelle Delikt in den genauen Handlungsabläufen mit den dazugehörigen affektiven und kognitiven Erlebensaspekten. Auch äussere Umstände, Tatmerkmale, Tatanlaufzeit und Nachtatverhalten sind zu beachten.»; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; EYTAN, S. 18; FINCKE, S. 657; HELFENSTEIN, S. 96; KIEGELAND, S. 236; KONRAD/RASCH, S. 202 und S. 329; Kröber et al.-III-KRÖBER, S. 97 ff.; KRÖBER, FPPK 2007, S. 162 f.; KRÖBER, FPPK 2010, S. 35 ff.; KRÖBER, FPPK 2015-B, S. 102 f.; EGG, S. 116 (zur Tatanalyse im Kontext der Risikobeurteilung); MÜLLER/NEDOPIL, S. 412 ff.; MAIER/MÖLLER, S. 155 und S. 167; vgl. sodann als Beispiel die Kriterien 1 (Analyse der Anlasstat(en)) und 7 (Auseinandersetzung mit der Tat) der sog. Dittmann-Liste (neu Basler-Kriterienkatalog genannt), verfügbar auf https://www.upk.ch/fileadmin/user_upload/Zuweisende_Forensik_Basler_Kriterienkatalog_zur_Beurteilung_der_Legalprognose/Basler_Kriterienkatalog_Version_2.pdf (besucht am: 6. Mai 2019).

⁴¹ EYTAN, S. 18.

⁴² Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18.

⁴³ OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 5 f.; MÜLLER/NEDOPIL, S. 414; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; KONRAD/RASCH, S. 329; implizit auch HABERMAYER/SACHS, N 6 zur Wichtigkeit der Tatschilderung (Motivlage, Tatablauf, Psychodynamik der Tat).

⁴⁴ BOETTICHER ET AL., NSTZ 2006, S. 542.

d) Zukunft

- 16 Bei der Beurteilung der Massnahmenindikation besteht ein wesentlicher Teil der gutachterlichen Tätigkeit darin, das Rückfallrisiko zu quantifizieren und zu prüfen, ob sich dieses mit einer therapeutischen Massnahme reduzieren lässt (Behandelbarkeit).⁴⁵ Für diese Beurteilung sind nicht nur die historischen Fakten von Bedeutung, sondern auch das noch Kommende. Entsprechend wird die sachverständige Person sowohl die subjektive Zukunftsperspektive der beschuldigten Person (individuelle Wünsche des Exploranden bzgl. Zukunft), die objektiven Perspektiven (den sog. «sozialen Empfangsraum»; Wohnung, Arbeit, soziale Beziehungen, gesundheitliche Betreuung, usw.) als auch Informationen zur grundsätzlichen Behandlungsbereitschaft, -fähigkeit und -motivierbarkeit zu erheben versuchen.⁴⁶

B) Strukturierung des Explorationsablaufs

- 17 Zwar fällt es schwer, allgemeingültige Aussagen zur Strukturierung einer Exploration zu machen. Der konkrete Ablauf des Explorationsgesprächs bestimmt sich nach den Besonderheiten des Einzelfalls und bietet dem Sachverständigen eine Vielzahl möglicher Vorgehensweisen.⁴⁷ Grosso modo dürften sich jedoch folgende idealtypische Begutachtungssequenzen einstellen: In einer Aufwärmphase (auch: «offene Einleitung»⁴⁸, «Warm-up»⁴⁹ oder «Warming-up Rapport»⁵⁰ genannt) wird dem Exploranden der Anlass der Untersuchung erklärt, auf die feh-

⁴⁵ Art. 56 Abs. 3 lit. a und b StGB.

⁴⁶ BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 544; EGG, S. 120; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 9 ff; Venzlaff et al.-LEYGRAF, S. 423; vgl. sodann als Beispiel die Kriterien 5 (Einsicht des zu Beurteilenden in seine Persönlichkeit oder vorhandene psychische Störung), 10 (Therapiebereitschaft) und 11 (sozialer Empfangsraum im Hinblick auf Prognose) der sog. Dittmann-Liste (neu: Basler-Kriterienkatalog genannt) verfügbar auf https://www.upk.ch/fileadmin/user_upload/Zuweisende/Forensik__Basler_Kriterienkatalog_zur_Beurteilung_der_Legalprognose/Basler_Kriterienkatalog_Version_2.pdf; besucht am: 6. Mai 2019).

⁴⁷ KIEGELAND, S. 97 und S. 118 f.; WAGNER/KRANICH, S. 11: «Exploration hat sich flexibel dem jeweiligen Einzelfall anzupassen.»; in der Praxis variiert die Ausgestaltung des Gesprächs, seiner Inhalte sowie seiner Strukturierung je nach Symptombild sowie der individuellen Explorationspräferenz des konkreten Sachverständigen. So kann die Exploration frei durchgeführt werden (Ablauf vom PSY-Sachverständigen autonom festgelegt) oder es können (zusätzlich zur freien Exploration) Checklisten, sowie halbstrukturierte und strukturierte Interviews durchgeführt werden (vgl. dazu HAUG, S. 19 ff.; MÜLLER/ NEDOPIL, Psychiatrie, S. 412; KONRAD/RASCH, S. 315; FÄHNDRICH/STIEGLITZ, S. 17 f. und 49 ff.).

⁴⁸ EBNER ET AL., S. 452.

⁴⁹ KIEGELAND, S. 96.

⁵⁰ FÄHNDRICH/STIEGLITZ, S. 49; JANSEN, N 330; WAGNER/KRANICH, S. 8.

lende Schweigepflicht hingewiesen, eine Belehrung über sein Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht vorgenommen (Art. 185 Abs. 5 StPO; nemo tenetur), und schliesslich versucht, mit einer freien Gesprächsführung über die aktuelle Befindlichkeit des Exploranden sowie seine derzeitige Lebenssituation eine entspannte Gesprächsatmosphäre zu kreieren.⁵¹ Danach folgt die indikationsabhängige vertiefte Exploration, in welcher der Sachverständige danach strebt, die für das Gutachten wesentlichen Informationen zu vervollständigen.⁵² Zum Schluss wird der Explorand gefragt, ob alles Wichtige angesprochen wurde oder ob sich noch weitere Erörterungen aufdrängen.⁵³ Ist dies nicht der Fall, endet die Exploration.

C) Gesprächsführungsmethodik

Die Exploration ist in Übereinstimmung mit der psychiatrischen Gesprächsführungsmethodik abzuhandeln. Dazu gehören namentlich die folgenden Gesichtspunkte: Die sachverständige Person hat unter Beibehaltung ihrer sachlichen Neutralität dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Exploration eine entspannte und angstfreie Atmosphäre entsteht (Vertrauensbasis bzw. Aufbau einer tragfähigen Beziehung).⁵⁴ Dem Exploranden ist empathisch zuzuhören.⁵⁵ Unnötige Störungen wie beispielsweise Telefonate gilt es zu vermeiden.⁵⁶ Das Gespräch soll in einer für den Exploranden verständlichen Alltagssprache geführt werden (insb. keine Fachsprache), wobei in der Regel mit offenen Fragen zu arbeiten

18

⁵¹ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17 f.; EBNER ET AL., S. 452; FÄHNDRICH/STIEGLITZ, S. 31; KIEGELAND, S. 95 f.; KONRAD/RASCH, S. 316; MÜLLER/NEDOPIL, S. 413; WAGNER/KRANICH, S. 8; WESTHOFF/KLUCK, S. 67.

⁵² MÜLLER/NEDOPIL, S. 412 f. unterteilen auf einer ersten Stufe die allgemeine biographische Befragung und auf einer zweiten die hypothesengeleitete vertiefte Exploration; ähnlich differenzieren Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17 f. zwischen freiem Bericht und vertiefter Exploration; EBNER ET AL., S. 452; FÄHNDRICH/STIEGLITZ, S. 33 ff.; KIEGELAND, S. 118 ff.; WAGNER/KRANICH, S. 9.

⁵³ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18.

⁵⁴ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17; COLLINS/LINCOLN/FRANK, S. 71; EGG, S. 55; FÄHNDRICH/STIEGLITZ, S. 14; HAUG, S. 15; HAUSOTTER, S. 29; HOFF, Psychiatrie, S. 160; Hässler/Kinze/Nedopil-KINZE, S. 42; KIESEWETTER, Kriminalistik 1995, S. 602; KONRAD/RASCH, S. 315; MÜLLER/NEDOPIL, S. 411; NEDOPIL, NSTZ 1999, S. 435; WAGNER/KRANICH, S. 8.

⁵⁵ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17; HAUG, S. 15; EBNER ET AL., S. 451; MÜLLER/NEDOPIL, S. 411; WAGNER/KRANICH, S. 8.

⁵⁶ BOETTICHER ET AL., NSTZ 2006, S. 542; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 16; MÜLLER/NEDOPIL, S. 411; WESTHOFF/KLUCK, S. 102.

ist.⁵⁷ Suggestivfragen gilt es weitgehend zu vermeiden.⁵⁸ Mit diesen Vorgaben soll eine möglichst optimale Wahrheitsrekonstruktion gewährleistet werden.

D) Prinzip des Drittpersonenausschlusses

- 19 Die methodische Zielvorgabe (Optimierung der Wahrheitssuche) hat auch Implikationen auf den Teilnehmerkreis der Exploration. Das Explorationsgespräch ist als ungestörtes Gespräch unter vier Augen konzipiert.⁵⁹ Die Anwesenheit von Drittpersonen wird als grundsätzlich kontraproduktiv gewertet.⁶⁰ Nicht nur soll durch anwesende Dritte die Neutralität des Sachverständigen gefährdet sein.⁶¹ Zentral ist vielmehr die Annahme, dass durch die Präsenz von Dritten der untersuchungsnotwendige Beziehungsaufbau zwischen Explorand und Sachverständigem (Vertrauensbeziehung) gestört und dem Explorationsgespräch den unerwünschten Charakter einer Einvernahme gegeben wird.⁶² Bereits die «Argusaugen eines Zeugen», der schweigend im Raum sitzt, sollen den ungehemmten Gesprächsverlauf behindern.⁶³ Erst recht als Störung gilt, wenn die anwesende Drittperson im Explorationsgespräch das Wort an sich reisst.⁶⁴ Schlimmstenfalls sei bei der Anwesenheit von Dritten die Beweiseignung der Exploration in Frage gestellt.⁶⁵

⁵⁷ EBNER ET AL., S. 451; FÄHNDRICH/STIEGLITZ, S. 28 f.; KIEGELAND, S. 118; MÜLLER/NEDOPIL, S. 411.

⁵⁸ WESTHOFF/KLUCK, S. 96 f.; EGG, S. 243; differenzierend HAUG, S. 18; FÄHNDRICH/STIEGLITZ, S. 30, welche Suggestivfragen als zu vermeidende Grösse bezeichnen und zur Minimierung aufrufen, gleichzeitig aber einräumen, dass sich nicht jegliche Suggestivfrage vermeiden lässt.

⁵⁹ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17; DEITMARING, S. 107 ff.; HAUSOTTER, S. 27; Hässler/Kinze/Nedopil-KINZE, S. 42; MÜLLER/NEDOPIL, S. 411; SIMON, S. 22.

⁶⁰ DEITMARING, S. 107 ff.; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17; EYTAN, S. 20; HABERMAYER/SACHS, N 7; HAUSOTTER, S. 27; SCHNEIDER/FRISTER/OLZEN, S. 5; SIMON, S. 22; SHEALY/PIRELLI/CRAMER, S. 563 ff., in welcher ein Grossteil der befragten Psychologen (84.4%) angaben, die Präsenz des Rechtsbeistands während der Exploration wäre ein Störfaktor.

⁶¹ ESSER, S. 704 f.; CHAMPOD/VUILLE, S. 28.

⁶² Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17; HABERMAYER/SACHS, N 7; DEITMARING, S. 107 ff.; EYTAN, S. 20; KONRAD/RASCH, S. 201; MAIER/MÖLLER, S. 193; RICHNER, S. 22; SIMON/WETTSTEIN, S. 27.

⁶³ HAUSOTTER, S. 27.

⁶⁴ CRAMER/BRODSKY, S. 55; DEITMARING, S. 107 berichtet von entsprechenden Erfahrungen mit Familienangehörigen; HAUSOTTER, S. 28.

⁶⁵ CRAMER/BRODSKY, S. 58 «An intrusive attorney presence may render an evaluation less valid, perhaps resulting in unsound evidence.»; DEITMARING, S. 112.

Der Grundsatz des Vier-Augen-Gesprächs ist nicht ohne Ausnahmen. Es ist 20 nach psychiatrischen Massstäben unbestritten, dass bei der Exploration fremdsprachiger Menschen ein Übersetzer einzubinden ist, wenn der Sachverständige der Sprache des Exploranden nicht mächtig ist.⁶⁶ Bei sonstigen Drittpersonen, deren Anwesenheit vom Exploranden erwünscht ist, kann die sachverständige Person versuchen, durch eine ausführliche Information des Exploranden über den Ablauf der Untersuchung den Wunsch nach der Anwesenheit der betreffenden Drittpersonen abzubauen.⁶⁷ Alternativ besteht die Möglichkeit, dass die sachverständige Person einen Dritten im Rahmen der Exploration nach eigenem fachkundigem Ermessen zulässt, wenn sie sich davon eine Förderung der Exploration erhofft.⁶⁸ In diesem Fall gilt aber, dass die anwesende Drittperson im Rahmen der Begutachtung zu schweigen hat; sie darf auf keinem Fall ins Gutachtensgeschehen intervenieren.⁶⁹ Schliesslich steht es dem Sachverständigen ebenso frei, die Teilnahme des Dritten abzulehnen.⁷⁰ Und gerade dies dürfte mit Blick auf das methodische Primat des Vier-Augen-Gesprächs der forensische Regelfall sein.

VI. Resultat: Wahrheitsannäherung durch den Sachverständigenbeweis

Hat die sachverständige Person die notwendigen Erhebungen vorgenommen und 21 sind von Seiten der Strafbehörde keine weiteren Ergänzungen bezüglich der relevanten Anknüpfungstatsachen eingetroffen, wird sie zur Verfassung des Gutachtens schreiten. Dabei gilt es das Tatsachenfundament des Gutachtens (Akten, Exploration, Fremdanamnesen, körperliche Untersuchung usw.) zu bezeichnen, dieses zu würdigen, allfällige Diagnosen und mögliche Differentialdi-

⁶⁶ Venzlaff et al.-FOERSTER/DRESSING, S. 19 f.; EBNER ET AL., S. 453 f.; HAUSOTTER, S. 29; KIEGELAND, S. 143 f.; Kröber et al.-II-KRÖBER, S. 179; SCHNEIDER/FRISTER/OLZEN, S. 5.

⁶⁷ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17; HAUSOTTER, S. 29; MAIER/MÖLLER, S. 193; SCHNEIDER/FRISTER/OLZEN, S. 5; ähnlich DEITMARING, S. 112, welche ein zweiphasiges Vorgehen aus Dreiergespräch und nachfolgender bzw. vorausgehender 4-Augen-Exploration vorschlägt.

⁶⁸ KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 193; KONRAD/RASCH, S. 201; MÜLLER/NEDOPIL, S. 411 raten, die Drittpersonenteilnahme auf bestimmte Explorationsabschnitte zu begrenzen.

⁶⁹ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 193; SIMON, S. 11.

⁷⁰ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17; HAUSOTTER, S. 29 empfiehlt in Fällen die Ablehnung des Gutachterauftrags; MAIER/MÖLLER, S. 193; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 193.

agnosen bezüglich des Exploranden zu stellen, diese in Bezug zur Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit (Schuldfähigkeit) sowie der Massnahmenindikation zu setzen und schliesslich die gestellten Fragen zu beantworten.⁷¹ Sämtliche dieser Elemente – das gutachtensrelevante strafbehördliche Tatsachenfundament, die Dokumentation der eigenen Erhebungen sowie die voranstehend erwähnte Beurteilung der Schuldfähigkeit sowie Massnahmenindikation – wird die sachverständige Person in das schriftliche⁷² Gutachten einfließen lassen (Art. 187 Abs. 1 StPO)⁷³ und dieses gegebenenfalls mündlich vor Gericht erläutern (Art. 187 Abs. 2 StPO). Damit endet die prozessuale Tätigkeit des PSY-Sachverständigen. Mit seiner Einbindung ist ein wesentlicher Schritt dafür getan, dass dem Untersuchungsgrundsatz nachgelebt wird und die bestmögliche Annäherung an die materielle Wahrheit erfolgen kann.⁷⁴

VII. Preis: partieller Kontrollverlust über Sachverhaltserhebung und -würdigung

- 22 Das durch den Sachverständigenbeweis erlangte Wahrheitsplus wird zu einem hohen Preis erkaufte. Partiiell gibt die Verfahrensleitung die Sachverhaltsermittlung durch die Exploration des Sachverständigen aus der Hand. So kann es vorkommen, dass die beschuldigte Person in der Exploration Hinweise zur Tat, deren Qualifikation sowie der Strafzumessung liefert, womit quasi als Reflexwirkung der gutachterlichen Tätigkeit die strafbehördliche Sachverhaltserhebung ergänzt wird (Sachverständiger als «Staatsanwalt in Weiss»).⁷⁵ Hinzu kommt die Schwierigkeit, an den im Gutachten mitgeteilten Erkenntnissen zu rütteln: Den fachfremden Verfahrensbeteiligten – somit auch der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung – bleibt inhaltlich nur eine Plausibilitätskontrolle des Gutachtens übrig.⁷⁶ Der Sachverständigenbeweis perpetuiert die Sachver-

⁷¹ BOETTICHER ET AL., NStZ 2005, S. 59 ff.; BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 541 ff.; Venzlaff et al.-FOERSTER/DRESSING, S. 62; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 7 ff.; EYTAN, S. 189; illustrativ sodann die Beispielgutachten bei NEDOPIL/KRUPINSKI, S. 1 ff.

⁷² Das schriftliche Gutachten ist der strafprozessuale Regelfall (Art. 187 Abs. 1 StPO); dies gilt gerade auch im Kontext komplexer psychiatrischer Fragestellungen, wie BSK StPO-I-HEER, Art. 187 N 1 zurecht betont. Dazu auch KassGer-ZH, 2. September 2002, E. 1.3.2.2, in: ZR 102/2003 Nr. 4 S. 18 ff.

⁷³ Venzlaff et al.-FOERSTER/DRESSING, S. 62 ff.; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 2 ff.

⁷⁴ ZK StPO-DONATSCH, Art. 182 N 1; DONATSCH, Jusletter 14. Mai 2007, N 5 ff.; BSK StPO-I-HEER, Art. 182 N 7; CR CPP-VUILLE, Art. 182 N 5.

⁷⁵ BRUNNER, Aspekte, S. 189; HUBER, S. 378; dazu auch KRAUSS, ZStW 1985, S. 82.

⁷⁶ BSK StPO-I-HEER, Art. 189 N 3; treffend OBERHOLZER, Begutachtung, S. 44: «Und die Gerichte, die zwar einiges vom Recht, aber wenig von der Sache verste-

haltsfeststellung und begründet eine faktische Monopolstellung im Kreis der Beweismittel (Sachverständiger als «Richter in Weiss»⁷⁷).⁷⁸

VIII. Konfliktzone: Kontrollmöglichkeiten der Verteidigung über das Explorationsgespräch

Aus den voranstehenden Ausführungen beginnt sich die strafprozessuale Konfliktzone abzuzeichnen. Mit der Schuldfähigkeit und der Massnahmenindikation werden wichtige Weichen im strafrechtlichen System gestellt. Es geht um nicht weniger als einen Freispruch bei Schuldunfähigkeit (Art. 19 Abs. 1 StGB) oder eine Strafmilderung bei einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB). Im Massnahmenrecht (Art. 56 ff. StGB) drohen dem Betroffenen Sanktionen, welche im Vergleich zur Strafe schuldüberschreitende Einschränkungen seiner Freiheitsrechte mit sich bringen können.⁷⁹ Bei der Beurteilung dieser Fragen ist das psychiatrische Gutachten das entscheidende Beweismittel und für dieses Gutachten ist wiederum das Explorationsgespräch eine zentrale Informationsquelle. Bei dieser Ausgangslage kommt es nicht überraschend, dass sich die Aufmerksamkeit der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung den Kontrollmöglichkeiten über das Explorationsgespräch zugewandt hat.

23

1. Postulat: Teilnahmerecht der Verteidigung an der Exploration

Auf der Suche nach juristischen Kontrollmechanismen ist jedoch bald zu konstatieren: Die StPO lässt die sachverständigen Erhebungen von direkten Kontrollmechanismen unberührt und beschränkt die Intervention der Parteien auf den Zeitraum vor (Art. 184 Abs. 3 StPO) und nach Erstellung des Gutachtens (Art. 188 f. StPO). Diese gesetzgeberische Abstinenz bezüglich der sachverständigen Erhebungen hat seine Kritiker: Zentrales werde dem Wildwuchs der Praxis über-

24

hen, versuchen, daraus [dem Gutachten] das Beste zu machen. Sie machen die ihnen fremden Erkenntnisse zu ihren eigenen. Viel mehr bleibt ihnen aber auch nicht übrig; denn: wenn sie von der Sache etwas verstehen würden, hätten sie ja keinen Gutachter beziehen müssen.»; eingehend zu den Überprüfungsmöglichkeiten und -grenzen des Gerichts sodann die Ausführungen in N 118 ff.

⁷⁷ BRUNNER, Aspekte, S. 186; HUBER, S. 378; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 435.

⁷⁸ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 78; ISENING/MÜLLER, S. 1339; Kröber et al.-I-RÖSSNER, S. 413.

⁷⁹ BGE 142 IV 105, E. 5.4; BGer, 29. Dezember 2015, 6B_1001/2015 und 6B_1147/2015, E. 3.2; BSK StGB-HEER, Art. 56 N 30; PK StGB-TRECHSEL/PAUENBORER, Art. 56 N 6.

lassen.⁸⁰ Zu diesen zentralen Aspekten gehört nach einem Teil des Schrifttums auch die Position der Verteidigung: Nach diesen Meinungen ist die Teilnahme der Verteidigung am Explorationsgespräch ihrer Mandantin zur Gewährleistung der Verfahrensfairness unabdingbar.⁸¹

- 25 Diese Forderung steht nicht im luftleeren Raum, wenn man sich der Funktion der Verteidigung bewusst wird. Die beschuldigte Person gilt in einem fairen Strafverfahren als Prozesssubjekt, das seine Verteidigungsrechte autonom ausübt und auf diesem Weg direkt und indirekt an der prozessualen Wahrheitsrekonstruktion teilnimmt.⁸² Diese Konzeption ist die Konsequenz aus der Erkenntnis, dass die kontradiktorische Wahrheitssuche gegenüber der einseitigen Sachverhaltsrekonstruktion durch eine in der Belastungshypothese verhaftete Strafverfolgungsbehörde bessere Resultate liefert.⁸³ Erst durch das Aufeinanderprallen von These und Antithese kann die bestmögliche Annäherung an das Ideal der materiellen Wahrheit erzielt werden.⁸⁴ So klar diese Erkenntnis ist, so schwierig gestaltet es sich, das Ideal eines kontradiktorischen Verfahrens in der Rechtsrealität zu realisieren. Sei es die Komplexität des Strafverfahrens⁸⁵, der auf der beschuldigten Person lastende psychologische Druck und der damit einhergehende Sachlichkeitsverlust⁸⁶ oder die im Vergleich zur Strafverfolgungsbehörde regelmässig geringeren Ressourcen⁸⁷: All diese Aspekte versetzen die beschuldigte Person in eine systematisch schwächere Position als diejenige, welche die Strafbehörde innehat. Das Strafverfahren ist ab initio durch eine Kräfteasymmetrie geprägt.⁸⁸
- 26 Das Recht der beschuldigten Person auf Beizug einer Verteidigung bildet in diesem Zusammenhang ein Gegengewicht zur Übermacht der staatlichen Strafverfolgung und gilt daher zurecht als fundamentaler Baustein eines fairen Verfahrens.⁸⁹ Indem die Verteidigung mit allen rechtmässigen Mitteln auf einen Freispruch oder bei entsprechender Beweislage auf ein möglichst mildes Urteil

⁸⁰ OBERHOLZER, Sachverhalt, S. 53; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 79: «Zentrales wird dem Wildwuchs der Praxis überlassen»; HEER, LA Niggli, S. 114; BERNHARD, Massnahmenrecht, S. 146.

⁸¹ Stellvertretend: SANER, S. 140 ff.; eingehend N 86 ff.

⁸² ALBRECHT, Funktion, N 2.4 f.; SCHLEGEL, S. 34.

⁸³ ALBRECHT, Funktion, N 2.6; GAEDE, S. 339 ff.; HAEFELIN, S. 31.

⁸⁴ DAHS, S. 6; HAEFELIN, S. 31.

⁸⁵ EGMR, S.C. v. the United Kingdom, no. 60958/00, § 29, ECHR 2004-IV; SCHLEGEL, S. 34 f.; TRECHSEL, S. 245; WOHLERS, ZStrR 2012, S. 56.

⁸⁶ BOMMER, FG Juristentag, S. 95; SCHLEGEL, S. 35.

⁸⁷ BOMMER, FG Juristentag, S. 94; SCHLEGEL, S. 34.

⁸⁸ BOMMER, FG Juristentag, S. 94.

⁸⁹ Stellvertretend: EGMR, Simeonovi v. Bulgaria [GC], no. 21980/04, § 112, ECHR 2017; ALBRECHT, Funktion, N 2.9; weiterführend sodann N 283 ff.

hinwirkt⁹⁰ und dabei der beschuldigten Person bei der effektiven Ausübung ihrer Verteidigungsrechte hilft⁹¹, schafft sie das erwünschte Gegengewicht zur Strafverfolgungstätigkeit, ermöglicht ein kontradiktorisches Verfahren und fördert in Konsequenz die strafprozessuale Wahrheitssuche.⁹² Die Verteidigung bildet m.a.W. ein elementares Mittel dafür, dass die beschuldigte Person ihre Rolle als autonomes Prozesssubjekt überhaupt wahrnehmen kann (Verteidigung als Prozesssubjektsgehilfe).⁹³ Dieser Aufgabe als waffengleichheitsförderndes Gegengewicht möchte die Verteidigung verständlicherweise auch im Explorationsgespräch nachkommen. Dies kann nach den Vertretern des Teilnahmerecht-Postulats aber nur dann gelingen, wenn die Verteidigung am Explorationsgespräch anwesend ist. Zur Begründung dieser These werden zwei unterschiedliche Begründungsstränge vorgebracht: die Überprüfbarkeit des Gutachtens (A.) und die Wahrung der Verteidigungsrechte während der Exploration (B.).

A) Begründungsstrang I: Überprüfbarkeit des Gutachtens

Die Verteidigung muss – will sie der beschuldigten Person eine effektive Ausübung ihres Rechts auf Stellungnahme zum Sachverständigenbeweis ermöglichen – umfassende Kenntnisse des Explorationssachverhalts erlangen.⁹⁴ An dieser Transparenz fehlt es nach den Vertretern des Teilnahmepostulats jedoch, da die Verteidigung am Explorationsgespräch abwesend ist und der Untersuchungsvorgang nach ihrer Sicht nicht adäquat dokumentiert wird. Für die Verteidigung finde bei diesen Bedingungen das Explorationsgespräch in einer Blackbox statt.⁹⁵ Diesem Missstand – so das Argument – lasse sich begegnen, indem der Verteidigung ein Teilnahmerecht am Explorationsgespräch eingeräumt werde.⁹⁶

27

⁹⁰ BGE 106 Ia 100, E. 6b; BGE 141 IV 344, E. 4.2; BGE 138 IV 161, E. 2.5.4.

⁹¹ DAHS, N 9; GAEDE, S. 494 f.; SCHLEGEL, S. 36; TRECHSEL, S. 245.

⁹² DAHS, N 11: «Seine strenge Einseitigkeit ist ein hervorragendes Mittel zur Wahrheitserforschung. Sie verbürgt die vollständige Erfassung aller für die Entscheidung des Ermittlungsverfahrens und das Urteil wesentlichen Entlastungstatsachen. Sie ist das von Rechts wegen kalkulierte Gegengewicht gegen das auf die Verfolgung ausgerichtete Wirken der Anklagebehörde.»; ALBRECHT, Funktion, N 2.09; BOMMER, FG Juristentag, S. 94; GAEDE, S. 502; HAEFELIN, S. 37; RUCKSTUHL, S. 259; TRECHSEL, S. 247; WOHLERS, ZStrR 2012, S. 56; BGE 106 Ia 100, E. 6b.

⁹³ WOHLERS, ZStrR 2012, S. 56 f.; WOHLERS, fp 2019, 208.

⁹⁴ SANER, S. 133 f.

⁹⁵ BERNHARD/BINDER, S. 13; BERNHARD, fp 2018, 474; HEER, Anforderungen, 125 f.; KUHN/BERNHARD, S. 7; HEER/COVACI, S. 443; vgl. auch die Rüge des Beschwerdeführers in BGer, 9. März 2017, 6B_100/2017, E. 3.1.

⁹⁶ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 97; SANER, S. 133; BGer, 9. März 2017, 6B_100/2017, E. 3.1.

B) Begründungsstrang II: Wahrung der Verteidigungsrechte während des Explorationsgesprächs

- 28 Die Verteidigung möchte jedoch nicht nur aus Gründen der nachträglichen Kontrolle des Gutachtens am Explorationsgeschehen anwesend sein. Die beschuldigte Person hat bereits während der Begutachtung schützenswerte Verteidigungsinteressen. So besteht etwa ein Bedürfnis, vor unzulässigen Untersuchungstechniken (Suggestivbefragung, Art. 140 StPO etc.) seitens des Sachverständigen unmittelbar geschützt zu werden. Weiter ist zu bedenken, dass die beschuldigte Person auch im Explorationsgespräch die Freiheit hat, zu entscheiden, ob sie mitwirken will oder nicht (*nemo tenetur*, Art. 185 Abs. 5 StPO). Dieses Recht kann aber nur dann effektiv genutzt werden, wenn die Verteidigung die beschuldigte Person während der Exploration über die Aussagestrategie beraten und ihr psychischen Beistand leisten kann. Auf all diese Aspekte zielt der zweite Begründungsstrang für ein Teilnahmerecht ab. Nur wenn die Verteidigung am Explorationsgespräch anwesend sei, könne sie ihrer allgemeinen Beistands-, Kontroll- und Fürsorgefunktion nachkommen; namentlich unzulässige Fragemethoden zu verhindern, das Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht (*nemo tenetur*) abzusichern sowie der beschuldigten Person eine psychologische Stütze zu sein.⁹⁷

2. Gegenmeinung: Exploration ≠ Einvernahme

- 29 Die Forderung nach einem Teilnahmerecht der Verteidigung stösst in forensisch-psychiatrischen Kreisen auf Ablehnung. Die Exploration sei keine Einvernahme, bei der es um das exakt gesprochene Wort gehe, sondern es gehe bei dieser Untersuchung immer auch um die Interaktion zwischen dem Sachverständigen und dem Exploranden sowie um das gutachterliche Erleben dieser Interaktion.⁹⁸ Die Intention des PSY-Sachverständigen sei nicht die Ermittlung des Sachverhalts, sondern die Erfassung der psychischen bzw. womöglich psychopathologischen Symptomatik des Exploranden.⁹⁹ Die Vornahme der Exploration müsse sich nach den Regeln des Fachs (der Psychiatrie) richten; dazu gehöre auch die methodische Freiheit des Sachverständigen, zu entscheiden, ob eine Drittperson zur Exploration zugelassen wird.¹⁰⁰ Eine Position, die im Status quo den Schutz des Gesetzes sowie der Rechtsprechung genießt.¹⁰¹

⁹⁷ BRUNNER, Aspekte, S. 197; SANER, S. 134.

⁹⁸ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; HABERMAYER/SACHS, N 7; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 192 f.

⁹⁹ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18.

¹⁰⁰ HABERMAYER/SACHS, N 7; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 192 f.

¹⁰¹ Dazu eingehend N 43 ff.

3. Spannungsfeld: Psychiatrische Methodik v. Verteidigungsrechte

Die Brisanz des Verteidigerteilnahmepostulats ist nach den voranstehenden Ausführungen evident: Der durch das geltende Recht geschützte Methodenstandard der Psychiatrie und die Forderung eines Teilnahmerechts der Verteidigung beim Explorationsgespräch sind nicht miteinander vereinbar. Ein Spannungsfeld tut sich auf. Auf der einen Seite besteht das durchaus verständliche¹⁰² Bestreben des Sachverständigen, optimale Rahmenbedingungen für seine Wahrheitssuche zu schaffen. Aus seiner Perspektive betrachtet ist es widersprüchlich, ihn wegen seines besonderen Fachwissens zur Optimierung der Wahrheitssuche beizuziehen und ihm sogleich Untersuchungsbedingungen vorschreiben zu wollen (Teilnahmerecht der Verteidigung), welche seiner Methodik (die ja gerade der Wahrheitssuche dienen!) zuwiderlaufen.

Auf der anderen Seite ist ebenso unbestritten, dass die beschuldigte Person in der Exploration nicht nur ein Beweisobjekt, sondern auch ein Verfahrenssubjekt ist, und in dieser Stellung das verfassungs- und völkerrechtlich verbürgte Recht auf eine effektive Verteidigung hat; auch und gerade durch eine formelle Verteidigung.¹⁰³ An dieser verfassungs- und völkerrechtlich verbürgten Effektivität der Verteidigung wecken nun die referierten Begründungsstränge für ein Teilnahmerecht der Verteidigung durchaus Zweifel. Während eine beschuldigte Person bei strafbehördlichen Einvernahmen durchwegs von ihrer Verteidigung begleitet werden kann, gilt selbiges beim Explorationsgespräch nicht. Damit, so die Sicht der Befürworter eines Teilnahmerechts, gebe es in gewisser Weise zwei Strafverfahren: ein normales, in dem die beschuldigte Person auf den Beistand ihrer Verteidigung bauen darf (strafbehördliche Einvernahmen), und ein Sonderverfahren (Exploration), bei welchem selbiges nicht gelten soll, was einer ungerechtfertigten prozessualen Schlechterstellung der begutachteten beschuldigten Person gleichkomme.¹⁰⁴

Vor dem Hintergrund dieser zwei Pole ist die Ausgangslage dieser Arbeit umrissen: Es kollidieren die Methodik des psychiatrischen Sachverständigen und eine bestimmte Auslegung der Verteidigungsrechte. Dabei kann weder die Legitimität der einen noch der anderen Position mittels summarischer Prüfung in Abrede gestellt werden. Ideale Voraussetzungen für eine eingehende Untersuchung, die nachfolgend ihren Platz finden soll.

¹⁰² BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64c; SANER, S. 133.

¹⁰³ Zu diesem Effektivitätsgebot stellvertretend: EGMR, Simeonovi v. Bulgaria [GC], no. 21980/04, § 112, ECHR 2017; BGE 141 I 124, E. 4.2; BV-Ehrenzeller et al.-I-VEST, Art. 32 N 26; RUCKSTUHL, S. 259.

¹⁰⁴ BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 39; SANER, S. 135.

§ 2 Forschungsrahmen und -vorgehen

I. Untersuchungsgegenstand auf einen Blick

- 33 Als Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit gilt es, den Untersuchungsgegenstand in einem Satz zu definieren: Es soll die Frage beantwortet werden, ob sich aus der EMRK ein Teilnahmerecht¹⁰⁵ der Verteidigung¹⁰⁶ am Explorationsgespräch¹⁰⁷ des psychiatrischen¹⁰⁸ Sachverständigen¹⁰⁹ mit der beschuldigten Person¹¹⁰ ergibt, wobei der Fokus auf die Gutachten zur Schuldfähigkeit (Art. 20 StGB) und Massnahmenindikation (Art. 56 Abs. 3 StGB) gelegt wird.

¹⁰⁵ Teilnahmerecht (der Verteidigung) = Recht auf Anwesenheit. Es bleibt zu präzisieren, dass mit der Wendung «Teilnahmerecht der Verteidigung» eine Verkürzung einhergeht. Bei formell-dogmatischer Betrachtung handelt es sich um ein Recht der beschuldigten Person auf Teilnahme ihrer Verteidigung und nicht ein Teilnahmerecht der Verteidigung (vgl. BSK StPO-I-RUCKSTUHL, Art. 159 N 1 und 38). Ist man sich dessen bewusst, schadet es aber nicht, anstelle der umständlichen Wendung «Recht der beschuldigten Person auf Teilnahme ihrer Verteidigung» schlicht vom «Teilnahmerecht der Verteidigung» zu sprechen.

¹⁰⁶ Mit der «Verteidigung» ist der zwingend angeordnete (Art. 130 StPO) oder freiwillig gewählte (Art. 129 StPO) Rechtsbeistand der beschuldigten Person gemeint, der unter Vorbehalt des Übertretungsstrafverfahrens ein Anwalt im Sinne des BGFA ist (Art. 127 Abs. 5 StPO).

¹⁰⁷ Dazu die Ausführungen im Themenaufriss: N 10 ff.

¹⁰⁸ Bei Art. 56 ff. StGB sowie Art. 20 StGB hat die Begutachtung in aller Regel durch einen psychiatrischen Sachverständigen stattzufinden: BGE 144 IV 176, E. 4.2.1; BGE 140 IV 49, E. 2; der damit begründete Ausschluss von Psychologen ist auf Kritik gestossen (stellvertretend: HABERMEYER ET AL., S. 128 ff.). Diese Diskussion soll nicht weiter vertieft werden. Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf den psychiatrischen Sachverständigen. Allerdings gelten die in dieser Arbeit herausdestillierten Rechtsmassstäbe auch für Psychologen, wenn diese dereinst als Sachverständige nach Art. 182 ff. StPO im Rahmen von Art. 20 StGB sowie Art. 56 Abs. 3 StGB zugelassen werden.

¹⁰⁹ Damit sind nur jene PSY-Sachverständigen gemeint, welche ihre Arbeit im Rahmen der Art. 182 ff. StPO verrichten. Ebenfalls erfasst sind fachlich qualifizierte Hilfspersonen (z.B. Assistenzärzte usw.), welche für die sachverständige Person Teile der Exploration durchführen (zu den Limitationen: BGE 144 IV 176).

¹¹⁰ Dabei handelt es sich nach Art. 111 StPO um jene Person, «die in einer Strafanzeige, einem Strafantrag oder von einer Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird.»

II. Legitimation der Schwerpunktsetzung

Die voranstehende Definition des Untersuchungsgegenstands geht mit Eingrenzungen einher, deren Legitimation sich nicht ohne Weiteres ergibt. Diese Lücke ist zu schliessen. Es muss begründet werden, warum sich die vorliegende Arbeit auf die Gutachten zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation beschränkt und aus welchen Gründen der Fokus auf die EMRK gelegt wird. 34

1. Fokus auf das Gutachten zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation

Die Ratio für den Fokus auf die Gutachten zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation ergibt sich aus dem juristischen Status quo: In § 4 wird sich zeigen, dass die StPO keine Ansätze für ein Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch des PSY-Sachverständigen bietet. Damit erweist sich das höherrangige Recht als massgebliche Grösse. Unter dessen Geltung variiert die Antwort auf die Frage, in welchem Rahmen Teilnahmerechte zur Wahrung der Verfahrensfairness notwendig sind, je nach Art der sachverständigen Erhebung und nach Art der prozessualen Rahmenbedingungen; es hat eine Gesamtwürdigung stattzufinden, welche sämtlichen Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung trägt.¹¹¹ 35

Besteht jedoch von Verfassungs und Völkerrechts wegen ein Einzelfallfokus, gilt es, einen möglichst homogenen Untersuchungsgegenstand zu formen. Gerade dies wird mit dem Fokus auf die Gutachten zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation erreicht. Diese Fragestellungen werden dem psychiatrischen Sachverständigen regelmässig im identischen Verfahrensstadium (Vorverfahren)¹¹² parallel¹¹³ zur Begutachtung vorgelegt. Dabei unterstehen beide Gutachten demselben (d.h. dem psychiatrischen) Methodenstandard, welcher im Explo- 36

¹¹¹ Zur Gesamtwürdigungstechnik des EGMR bei der Auslegung von Art. 6 EMRK eingehend die Ausführungen in § 5 und § 9. Treffend sodann folgender Passus des Bundesgerichts in BGE 119 Ia 260, E. 6c: «...inwieweit zur wirksamen Interessenwahrung der Partei bzw. ihrem Rechtsvertreter eine Teilnahme an Beweiserhebungen zugestanden werden muss, beantwortet sich, ausgehend vom zugrundeliegenden Verfahren, je nach Beweismittel unterschiedlich.»

¹¹² BGE 144 I 253, nicht publizierte E. 1.2: «Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das Gesetz besonderes Gewicht darauf legt, dass schon im Vorverfahren für ein grundsätzlich gültiges (und gerichtlich verwertbares) psychiatrisches Gutachten zu sorgen ist.»

¹¹³ Das AppGer-BS, 30. März 2015, BES.2015.32 (AG.2015.227), E. 2.3 weist in diesem Zusammenhang zurecht darauf hin, dass die zwei Begutachtungsindikationen zwar formell unabhängig sind, aber in der Praxis regelmässig beide Fragen zur Begutachtung vorgelegt werden.

rationskontext den Ausschluss von Drittpersonen vorsieht, was in einem Zielkonflikt mit dem Teilnahmepostulat steht.¹¹⁴

- 37 Neben dem Vorteil der Homogenität profitiert der so definierte Untersuchungsgegenstand davon, dass die im Strafverfahren angestossenen Gutachten zur Schuldfähigkeit und zur Massnahmenindikation ohne Zweifel dem strafrechtlichen Anwendungsbereich von Art. 6 EMRK unterstehen, womit sich diesbezügliche langwierige Ausführungen erübrigen und der Fokus alleine auf den materiellen Schutzstandard gelegt werden kann.¹¹⁵ Es ist vor diesem Hintergrund gerechtfertigt, dass sich die vorliegende Arbeit auf die Gutachten zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation fokussiert. Dabei ist sich der Autor sehr wohl bewusst, dass die Untersuchungsergebnisse der vorliegenden Arbeit geeignet sind, über diesen Rahmen hinaus Bedeutung zu erlangen (z.B. im Kontext des Straf- und Massnahmenvollzugs oder im ausserstrafrechtlichen Kontext). Diese Übertragungsarbeit darf jedoch in die Hände anderer Autoren gelegt werden.

2. Fokus auf die EMRK

- 38 Es bleibt zu erklären, wieso sich die vorliegende Arbeit auf den Schutzstandard der EMRK fokussiert und andere einschlägige Rechtsquellen des höherrangigen Rechts wie den IPBPR und die Bundesverfassung unbeachtet lässt. Ein erster Teil der Antwort besteht in der Beobachtung, dass der inhaltliche Schutzstandard dieser Instrumente überwiegend kongruent ausfällt.¹¹⁶ Das Prinzip des fairen Verfahrens und die Verteidigungsrechte der beschuldigten Person sind in der BV, EMRK und im IPBPR gleichermassen abgesichert.¹¹⁷ Als Folge dieser Tatsache werden die Verfahrensgarantien des IPBPR und der EMRK oft gemeinsam kommentiert und es wird bei der Auslegung wechselseitig Bezug genommen.¹¹⁸ Ebenso betont das Bundesgericht regelmässig, dass das Völkerrecht

¹¹⁴ Zur Fokussierung auf den psychiatrischen Sachverständigen im Rahmen der Art. 20 und 56 ff. StGB: N 108; zum psychiatrischen Methodenstandard: N 11 f.

¹¹⁵ LNR-MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KÖNIG, Art. 6 N 32; Erb et al.-ESSER, Art. 6 N 79; für die Begutachtung im Rahmen des Massnahmenvollzugs ist die Anwendbarkeit des strafrechtlichen Anwendungsbereichs von Art. 6 EMRK noch nicht hinreichend gesichert, vgl. dazu BERNHARD/STUDER, Nachverfahren, S. 91 ff.; nach geltender Rechtsprechung dürfte in diesen Konstellationen eher der zivilrechtliche Schutzbereich von Art. 6 EMRK eröffnet sein: LNR-MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KÖNIG, Art. 6 N 32; ähnlich Erb et al.-ESSER, Art. 6 N 79 sowie jüngst EGMR, *Hodžić v. Croatia*, no. 28932/14, § 48 ff., 4 April 2019.

¹¹⁶ BINDER, S. 26.

¹¹⁷ Fair trial: Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 14 Ziff. 1 IPBPR; spezifisch die Verteidigungsrechte: Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 EMRK, Art. 14 Ziff. 3 IPBPR.

¹¹⁸ So etwa in den prominenten Werken von GOLLWITZER sowie Erb et al.-ESSER; auch SCHMID, FS Trechsel, 752 betont die weitgehende Kongruenz.

keine weiterreichenden Garantien als die BV enthält.¹¹⁹ Dieser Umstand manifestiert sich auch beim Untersuchungsgegenstand: Hier prüfte das Bundesgericht die behauptete Verletzung von verfassungs- (Art. 29 ff. BV) bzw. völkerrechtlich garantierten (Art. 6 EMRK) Verfahrensrechten mangels Existenz eines Teilnahmerechts der Verteidigung gleichzeitig in einer Erwägung¹²⁰, woraus sich der Schluss ziehen lässt, dass es den inhaltlichen Schutzstandard dieser Rechtsquellen als identisch betrachtet. Eine nach EMRK, IPBPR und BV separierte Betrachtung würde vor diesem Hintergrund die materielle Erkenntnis nicht fördern, sondern Redundanzen mit sich bringen, da bei jeder Rechtsquelle dieselben inhaltlichen Gesichtspunkte aufzuwerfen wären. Dies gilt es zu vermeiden. Es rechtfertigt sich, den Fokus auf eine dieser Rechtsquellen zu legen.

Damit gelangt man zur Frage, welche dieser Rechtsquellen genauer beleuchtet werden soll. Die Wahl der EMRK drängt sich dabei aus unterschiedlichen Gründen auf. In der schweizerischen Rechtspraxis wird die EMRK extensiv zur Rechtsfindung beigezogen, während der IPBPR kaum Beachtung findet.¹²¹ Angesichts dieser Tatsache rechtfertigt es sich, die vertrautere völkerrechtliche Rechtsquelle (EMRK) zu wählen. Im Verhältnis zwischen der EMRK und der Bundesverfassung spricht sodann Art. 190 BV für den Fokus auf die EMRK. Nach dieser Norm gilt: «Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend». Daraus fliesst, dass das Bundesgericht die Verfassungsmässigkeit eines Bundesgesetzes zwar vorfrageweise überprüfen darf (kein Prüfungsverbot), aber ein als verfassungswidrig erachtetes Bundesgesetz dennoch anwenden muss (sog. Anwen-

¹¹⁹ BGer, 20. Juni 2018, 6B_252/2017, E. 1.3.3: «...dass der Schutz gemäss Art. 32 Abs. 1 BV nicht über denjenigen nach Art. 6 EMRK hinaus geht.»; BGer, 22. Juli 2003, 1P.230/2003, E. 2.1; BGer, 20. Februar 2004, 6P.118/2003, E. 2: «Die EMRK verschafft jedoch hinsichtlich des Gehörsanspruchs keine weitergehenden Rechte als Art. 29 Abs. 2 BV, weshalb sich eine gesonderte Überprüfung des angefochtenen Entscheids auf seine Vereinbarung mit Art. 6 EMRK erübrigt.»; BGer, 17. Juni 2008, 6B_62/2008, E. 3.2; BGer, 23. April 2008, 6B_708/2007, E. 4.1.1; BV-Ehrenzeller et al.-I-SCHWEIZER, Vorbemerkungen zu Art. 7-36 BV N 25.

¹²⁰ BGE 144 I 253, E. 3.8: «Zu prüfen ist weiter, ob sich ein Rechtsanspruch der beschuldigten Person auf Mitwirkung und Anwesenheit ihres Verteidigers bei der Sachverhaltsermittlung eines forensischen Gutachters (wozu bei psychiatrischen Begutachtungen auch das Explorationsgespräch gehört) aus den vom Beschwerdeführer angerufenen Individualrechten und prozessualen Mindestgarantien der Bundesverfassung (Art. 29 Abs. 1-2 und Art. 32 Abs. 2 BV) oder der EMRK (Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 EMRK) ableiten lässt.»

¹²¹ Dies kann durch die Tatsache illustriert werden, dass eine Suche nach dem Begriff «EMRK» in der Kategorie «BGE ab 1954 (publizierte Leitentscheide)» auf <https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de> (besucht am 6. Mai 2019) 1106 exakte Treffer ergibt, während für den Suchbegriff «IPBPR» gerade einmal sieben exakte Treffer zu Buche stehen (Stand: 31. Dezember 2018).

dungsgebot).¹²² Zwar sind die verfassungsmässig geschützten Individualrechte nicht bedeutungslos. Bei mehreren vertretbaren Auslegungsmöglichkeiten ist diejenige zu wählen, welche der Verfassung am besten entspricht (verfassungskonforme Auslegung).¹²³ Dieses Auslegungsmittel findet aber seine absoluten Schranken im klaren Wortlaut und dem Sinn einer Gesetzesbestimmung.¹²⁴

- 40 Gerade eine solche Schranke für die verfassungskonforme Auslegung liegt beim Untersuchungsgegenstand vor: Die Ausführungen in § 4 werden zeigen, dass der Gesetzgeber bewusst auf die Implementierung eines Teilnahmerechts der Verteidigung bei sachverständigen Erhebungen bzw. der psychiatrischen Exploration verzichtete. Würde die verfassungsrechtliche Analyse zum Ergebnis gelangen, dass das Explorationsgespräch zwischen PSY-Sachverständigem und beschuldigter Person nur mit einem Teilnahmerecht der Verteidigung dem Grundsatz des fairen Verfahrens i.S.v. Art. 29 ff. BV genügt, wäre dies nur von theoretischem Interesse. Das Bundesgericht könnte in diesem Fall nur die Verfassungswidrigkeit der StPO feststellen, müsste aber – wie voranstehend geschildert – kraft Art. 190 BV das verfassungswidrige Gesetz anwenden (sog. Anwendungsgebot).
- 41 Für die EMRK gelten diese Limitationen nicht. Zwar darf auch hier ein sich im Wortlaut spiegelnder klarer Wille des Gesetzgebers nicht mit einer völkerrechtskonformen Auslegung zurechtgebogen werden.¹²⁵ Bei einem Normkonflikt gehen aber völkerrechtswidrige Bundesgesetze nach der sog. «Schubert-Praxis» dem Völkerrecht nur dann vor, wenn der «Gesetzgeber bewusst die völkerrechtliche Verpflichtung missachten und insofern auch die politische Verantwortung dafür bewusst tragen wollte».¹²⁶ Von einer solchen Absicht des Gesetzgebers kann keine Rede sein: Ein Ziel der StPO bestand darin, die Vorgaben des höherrangigen Rechts umzusetzen.¹²⁷ Doch selbst wenn dem nicht so wäre, würde die EMRK der StPO vorgehen. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass die Schubert-Praxis bei völkerrechtlichen Normen, die dem Schutz der Menschenrechte dienen, nicht zur Anwendung gelangt. Hier gilt der Vorrang des Völkerrechts sogar bei einem bewussten Verstoß des Gesetzgebers.¹²⁸ Vor die-

¹²² BGE 144 I 126, E. 3.4; BGE 140 I 305, E. 5; BGE 138 I 61, E. 4.7; BGE 136 I 49, E. 3.1; BGE 131 II 710, E. 5.4.

¹²³ BGE 143 III 600, E. 2.7; BGE 138 V 17, E. 4.2; BGE 137 III 217, E. 2.4.1; BGE 131 II 697, E. 4.1; BGE 130 II 65 E. 4.2.

¹²⁴ BGE 143 III 600, E. 2.7; BGE 138 V 17, E. 4.2; BGE 138 I 61, E. 4.3; BGE 137 III 217, E. 2.4.1; BGE 131 II 697, E. 4.1; BGE 129 II 249 E. 5.4; BGE 128 V 20 E. 3a; BGE 123 II 9, E. 2; vgl. auch BV-Ehrenzeller et al.-II-HANGARTNER/LOOSER, Art. 190 N 11.

¹²⁵ BGE 140 I 305, E. 7.4.

¹²⁶ BGE 142 II 35, E. 3.2.

¹²⁷ Vgl. N 68 f.

¹²⁸ BGE 144 I 126, E. 3; BGE 142 II 35, E. 3.2.

sem normhierarchischen Hintergrund ist es gerechtfertigt, den Fokus auf die EMRK und nicht auf die Bundesverfassung zu legen.

III. Untersuchungsetappen

Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit wird in drei Schritten analysiert. Zu Beginn und als Fundament aller weiteren Ausführungen gilt es im 2. Teil, die verfassungs- und gesetzliche Ausgangslage zum Untersuchungsgegenstand darzulegen. Dabei wird sich zeigen, dass weder aus der Verfassungspraxis des Bundesgerichts noch aus der StPO ein Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch des Sachverständigen mit der beschuldigten Person hervorgeht.¹²⁹ Auf Basis dieser Erkenntnis wird der Fokus in den nachfolgenden Teilen auf den materiellen Schutzgehalt von Art. 6 EMRK mit seinem strafrechtlichen Anwendungsbereich gerichtet, wobei sich die Analysesequenzen anhand der im Themenaufriss erwähnten Begründungsstränge für die Herleitung eines Teilnahmerechts der Verteidigung im Explorationsgespräch orientieren. Im 3. Teil wird untersucht, ob das aus dem Gehörsanspruch fließende Recht auf Stellungnahme zum Gutachten es erfordert, dass die Verteidigung am Explorationsgespräch teilnehmen darf (Begründungsstrang I).¹³⁰ Danach wird im 4. Teil geprüft, ob sich ein Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch zur effektiven Wahrung der Verteidigungsrechte während der Exploration aufdrängt (Begründungsstrang II).¹³¹ Die Kernerkenntnisse sämtlicher Teile fließen sodann in die Schlussbilanz ein, welche diese Arbeit zu ihrem Ende führt.¹³²

¹²⁹ Vgl. N 43 ff.

¹³⁰ Vgl. N 96 ff.

¹³¹ Vgl. N 283 ff.

¹³² Vgl. N 424 ff.

2. Teil: Verfassungsrechtliche und gesetzliche Ausgangslage

§ 3 Rahmenmodell des Verfassungsrechts

Für die Aufarbeitung des verfassungsrechtlichen Schutzstandards zum Untersuchungsgegenstand kann der Fokus nicht auf das Strafprozessrecht beschränkt werden. Die massgebliche Verfassungspraxis hat sich rechtsgebietsübergreifend zu Art. 4 aBV bzw. Art. 29 ff. BV entwickelt. Bei der Aufarbeitung dieser Leitlinien wird sich zeigen, dass das Bundesgericht sachverständige Erhebungen seit jeher von Teilnahmebegehren der Parteien und/oder ihrer Rechtsbeistände immunisierte. Nachfolgend soll aber nicht eine rein historische Aufarbeitung dieser Praxis stattfinden. Vielmehr gilt es, das bundesgerichtliche Begründungsgeflecht in thematische Zusammenhänge zu setzen. Bei näherem Hinsehen kann der Ausschluss von Teilnahmerechten bei sachverständigen Erhebungen in Kern- sowie Scheinargumente unterteilt werden. Erstere werden im 3. und 4. Teil einer kritischen Betrachtung zugeführt, während die Scheinargumente bereits in diesem Paragraphen aufgrund ihrer offensichtlich mangelnden Legitimation zu verwerfen sind.

43

I. Kernargumente der Teilnahmerechtsimmunisierung

Die Begründungssenz für die Immunisierung der sachverständigen Erhebungen vor Teilnahmerechten ruht auf mehreren Pfeilern. Ausgangspunkt bildet die bei sämtlichen sachverständigen Erhebungen geltende Annahme, dass die den Parteien und ihren Rechtsbeiständen eingeräumte Möglichkeit, nach Einreichung des Gutachtens Einsicht in dieses und dazu Stellung zu nehmen, die Gehörsrechte ausreichend wahrt (1.). Für die medizinisch-psychiatrische Begutachtung hat sich darüber hinaus ein Begründungsstrang etabliert, nach welchem der Ausschluss von nicht untersuchungsnotwendigen Drittpersonen zusätzlich auf die Methodenfreiheit der sachverständigen Person sowie die befürchteten Reflexwirkungen von Teilnahmerechten gestützt wird (2.).

44

1. Genügen des Rechts auf Stellungnahme

- 45 Im Kontext des Sachverständigenbeweises bildet das Recht der Partei, Einsicht in das Gutachten zu nehmen, dazu Stellung zu beziehen sowie Ergänzungsfragen stellen zu können den eigentlichen Uranspruch des rechtlichen Gehörs.¹³³ Seine Gewährleistung wird im Rahmen des Sachverständigenbeweises seit jeher als ausreichend und Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen spiegelbildlich als verzichtbar angesehen.

A) Ausserstraßprozessuale Leitlinien

- 46 Der Ursprung der hier referierten Praxis reicht ins Jahr 1973 zurück. In BGE 99 Ia 42 stellte sich das Bundesgericht in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren auf den Standpunkt, mehr als das Recht der Partei, das Gutachten zugestellt zu erhalten und dazu Stellung nehmen zu können, lasse sich aus Art. 4 aBV nicht ableiten. Mit dieser Erwägung verwarf es gleichzeitig ein Teilnahmerecht der Beschwerdeführerin am umstrittenen sachverständigen Augenschein an einer Örtlichkeit.¹³⁴ Diese Betrachtung wurde in BGE 119 Ia 260 auf die fachrichterliche Einvernahme (psychiatrisches Explorationsgespräch) ausgedehnt. Streitpunkt des erwachsenenschutzrechtlichen Verfahrens bildete die Frage, ob der Rechtsbeistand der zu begutachtenden Person an der fachrichterlichen psychiatrischen Begutachtung teilnehmen dürfen. Das Bundesgericht lehnte dies ab. Dem Rechtsbeistand sei das Gutachten zugestellt worden. Dieser habe die Gelegenheit gehabt, zu den gutachterlichen Ausführungen Stellung zu nehmen. Mehr lasse sich aus dem Gehörsanspruch nicht herleiten. Im konkreten Verfahren sei der freie Verkehr der betroffenen Person mit ihrem Rechtsbeistand gewährleistet gewesen. Die Anwesenheit des Rechtsbeistands bei der fachrichterlichen Einvernahme sei nicht notwendig gewesen, zumal weder eine besondere Hilflosigkeit des Exploranden geltend gemacht werde noch eine besondere Schwierigkeit des Sachverhalts vorliege, welche das Beisein des Rechtsbeistands erfordere. Zudem sei es nicht notwendig gewesen, bereits im Zeitpunkt der Untersuchung Ergänzungsfragen an den Sachverständigen zu stellen.¹³⁵ Die so fundierte Gehörspraxis und der damit einhergehende Ausschluss von Teilnahmerechten der Parteien und/oder ihrer Rechtsbeistände wurde nachfolgend in

¹³³ Zu den Anfängen dieses Gehörsanspruchs in der bundesgerichtlichen Praxis, vgl. BGE 29 I 461, E. 1; BGE 34 I 10, 14; BGE 92 I 185, 187; BGE 99 Ia 42, E. 3b; aus der neueren Praxis sodann BGer, 23. März 2015, 6B_549/2014, E. 3; BGer, 9. März 2017, 6B_100/2017, E. 3.6; BGer, 20. Februar 2018, 6B_918/2017, E. 2.2.

¹³⁴ BGE 119 Ia 260, E. 6d; bestätigt in BGer, 27. Januar 2003, 5P.11/2003, E. 3.

¹³⁵ BGE 119 Ia 260, E. 3d.

verschiedenen Urteilen bestätigt und auf sachverständige Befragungen von Drittpersonen (Fremdanamnesen) ausgeweitet.¹³⁶

B) Strafprozessualer Gleichlauf

Die vorerwähnten Leitlinien beanspruchen auch im Strafprozess Geltung. Den Grundstein legte ein Verfahren im Jahr 1999. Die beschuldigte Person hatte gerügt, dass weder sie noch ihre Verteidigung an der Abnahme einer Schriftprobe einer Zeugin teilnehmen konnte.¹³⁷ Das Bundesgericht verwies auf den zuvor referierten BGE 119 Ia 260 und hielt in Analogie zum Sachverständigenbeweis fest, dass sich weder aus dem Gesetz noch aus dem höherrangigen Recht ein Teilnahmerecht der Partei sowie der Verteidigung an diesem Erhebungsvorgang ergebe. Es habe die Möglichkeit bestanden, im Hauptverfahren Einwendungen gegen die Schriftprobe zu erheben und Ergänzungsfragen zu stellen. Die mangelnde Teilnahme an der Abnahme der Schriftprobe habe keine Auswirkungen auf die Verteidigungsrechte der beschuldigten Person gehabt.¹³⁸ Diese Leitlinien wurden für das Explorationsgespräch des Sachverständigen mit der beschuldigten Person bestätigt. Nachdem das Bundesgericht zweimal in eher kursorischer Weise Teilnahmebegehren von Rechtsbeiständen an der psychiatrischen Exploration verworfen hatte,¹³⁹ nahm es die Thematik in BGE 144 I 253 eingehend auf. Dabei anerkannte es zwar, dass die Teilnahme der Verteidigung in Ausnahmekonstellationen angezeigt sein kann.¹⁴⁰ An der Feststellung, dass das nachträgliche Recht auf Stellungnahme genügt, änderte diese Erwägung im konkreten Verfahren jedoch nichts. Das Bundesgericht würdigte die Gerichtspraxis und stellte fest, dass der Beschwerdeführer keine hinreichenden Gründe darlege, wieso die Kontrolle des Gutachtens mit den bestehenden Mitteln nicht möglich sei, und verwarf das Argument des Beschwerdeführers, in Anwendung von Art. 29 Abs. 1 und 32 Abs. 2 BV oder Art. 6 EMRK ein Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch anzunehmen.¹⁴¹

¹³⁶ BGE 122 II 464, E. 4b; BGer, 16. Juli 2001, 5P.164/2001, E. 4.

¹³⁷ BGer, 14. September 1999, 1P.405/1999, E. 3a.

¹³⁸ BGer, 14. September 1999, 1P.405/1999, E. 3b-d.

¹³⁹ BGer, 9. März 2017, 6B_100/2017, E. 3.1-3.6; in BGer, 13. November 2017, 1B_443/2017, E. 3.2 führte das Bundesgericht aus, es sei nicht aufgezeigt worden, «weshalb bei seiner Exploration durch den psychiatrischen Gutachter sein Verteidiger hätte anwesend sein müssen bzw. inwiefern die Begutachtung sonstwie Bundesrecht verletzen würde oder im Haftprüfungsverfahren unverwertbar wäre.»

¹⁴⁰ BGE 144 I 253, E. 3.8; zu dieser Fallgruppe auch OBERHOLZER, Grundzüge 2012, N 823; BERNHARD, iusNet 27. November 2018; BSK StPO-I-HEER, Art. 185 N 36.

¹⁴¹ BGE 144 I 253, E. 3.4-3.8; bestätigt in BGer, 24. September 2018, 6B_276/2018, E. 1.4.2; kritisch zu dieser Praxis BERNHARD, iusNet 27. November 2018.

2. Sonderrechtsprechung bei medizinisch-psychiatrischen Untersuchungen

- 48 Die erste Kernerwägung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht nach dem Gesagten darin, dass die Einräumung von Teilnahmerechten an sachverständigen Erhebungen für die Gewährleistung des rechtlichen Gehörs angesichts des Rechts auf Einsicht ins und Stellungnahme zum Gutachten nicht notwendig ist. Für das vorliegend besonders zu interessierende Explorationsgespräch des psychiatrischen Sachverständigen hat sich darüber hinaus eine eigentliche Sonderrechtsprechung gebildet, welche für die Ablehnung von Teilnahmerechten angerufen wird. Diese beruht auf zwei Pfeilern: dem Schutz der Methodenfreiheit (A.) sowie den befürchteten Reflexwirkungen eines Teilnahmerechts (B.).

A) Schutz der Methodenfreiheit

- 49 Bereits im Themenaufriß dieser Abhandlung wurden das Prinzip der Methodenfreiheit des Sachverständigen und die damit einhergehende Autonomie, die Art und Weise der Untersuchung im Rahmen des wissenschaftlichen Standards nach fachkundigem Ermessen festzulegen, erwähnt.¹⁴² Diese Freiheit wird vom Bundesgericht in konstanter Praxis geschützt und enthält im vorliegend zu interessierenden Kontext die Autonomie des Sachverständigen, den Teilnehmerkreis während der Exploration nach eigenem fachkundigem Ermessen festzulegen.

a) Methodenbedingter Ausschluss von Drittpersonen

- 50 Den Grundstein für den bis heute ungebrochenen Schutz des methodenbedingten Ausschlusses von Drittpersonen bei psychiatrischen Explorationsgesprächen legte das Bundesgericht in BGE 119 Ia 260. Die zu begutachtende Partei hatte die Teilnahme ihres Rechtsbeistands im Rahmen einer fachrichterlichen Einvernahme (konkret: eines psychiatrischen Explorationsgesprächs) begehrt. Letzteres sollte die Grundlage für einen erwachsenenschutzrechtlichen Entscheid über eine fürsorgerische Unterbringung bilden. Das Bundesgericht führte zur Ablehnung dieses Begehrens aus, dass es in «ausgesprochen persönlichkeitsrelevanten Angelegenheiten» erforderlich sein könne, dass eine Person ohne ihren Rechtsbeistand angehört werde, um ein möglichst unverfälschtes Bild der Persönlichkeit zu erhalten.¹⁴³ Von diesem Standpunkt ausgehend griff das Bundesgericht die in der Literatur vertretene Meinung auf, wonach bei psychiatrischen Explorationsgesprächen und bei (ärztlichen) körperlichen Untersuchungen keine Drittpersonen zuzulassen sind.¹⁴⁴ Zur Erfüllung seines Auftrags sei es unum-

¹⁴² Vgl. N 11 ff.

¹⁴³ BGE 119 Ia 260, E. 6b.

¹⁴⁴ BGE 119 Ia 260, E. 6c.

gänglich, dass sich der Fachrichter einen zuverlässigen persönlichen Eindruck vom psychischen Zustand des Betroffenen verschaffen könne. Entsprechend müsse er Art und Weise der Begutachtung im Rahmen des Untersuchungszwecks autonom festlegen können, was auch die Bestimmung des Teilnehmerkreises einschliesse.¹⁴⁵

Die unter BGE 119 Ia 260 aufgebauten Leitlinien wurden durch BGE 132 V 443 51 vom fachrichterlichen Kontext auf den Sachverständigenbeweis übertragen. Der Rechtsbeistand der zu begutachtenden Person wollte seine Klientin zur polydisziplinären Begutachtung begleiten, was durch alle Instanzen abgelehnt wurde.¹⁴⁶ Das Bundesgericht folgte den Vorinstanzen und hielt fest, der sachverständigen Person sei für die Erfüllung ihres Auftrags zu einer möglichst objektiven Beurteilung zu verhelfen. Dafür müsse eine Interaktion zwischen ihr und dem Exploranden stattfinden können. Äussere Einflussnahmen seien zu vermeiden.¹⁴⁷ Die Anwesenheit des Rechtsbeistands sei diesem Zweck nicht dienlich, da der Rechtsbeistand als Interessenwahrer des Klienten einseitig im Begutachtungsverfahren intervenieren könnte. Dies verträge sich nicht mit einer wissenschaftlichen Begutachtung, bei der es – ähnlich einer Zeugeneinvernahme, bei der sich der Zeuge auch nicht verbeistanden lassen kann – darum gehe, dem Sachverständigen ein möglichst unverfälschtes und objektives Bild zu verschaffen.¹⁴⁸

Die in BGE 132 V 443 enthaltenen Erwägungen wurden in zahlreichen nachfolgenden Bundesgerichtsurteilen bestätigt¹⁴⁹ und schliesslich mit BGE 144 I 253 52 auch für den strafprozessualen Kontext übernommen.¹⁵⁰ In diesen Urteilen wurden analoge Erwägungen für sämtliche Beistandsformen und -varianten formuliert, wobei die Begründungsmuster je nach Person des Beistands sowie der Form der beantragten Teilnahme geringfügig variierten. Auf das Begehren der Beschwerdeführerin, ihren Lebenspartner als Beistand an der Untersuchung teilnehmen zu lassen, entgegnete das EVGer, dass die nach BGE 119 Ia 260 und BGE 132 V 443 begründete Praxis für die Anwesenheit jeder Drittperson Geltung beanspruche. Im Rahmen der körperlichen oder psychiatrischen Untersuchung sei die Anwesenheit Dritter weder notwendig, noch sei ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten. Sofern notwendig könne beim Lebenspartner

¹⁴⁵ BGE 119 Ia 260, E. 6c.

¹⁴⁶ BGE 132 V 443, A-C.

¹⁴⁷ BGE 132 V 443, E. 3.5.

¹⁴⁸ BGE 132 V 443, E. 3.5.

¹⁴⁹ BGE 137 V 210, E. 3.1.3.3; EVGer, 8. August 2007, I 874/06, E. 4 und E. 4.1.2; EVGer, 14. November 2007, I 1094/06, E. 3.1.2; BGer, 25. August 2011, 8C.245/2011, E. 6; BGer, 29. September 2011, 8C.426/2011, E. 7.4; BGer, 23. Dezember 2011, 8C_587/2011, E. 6.1; BGer, 23. Dezember 2011, 8C.589/2011, E. 8; BGer, 18. Februar 2013, 8C.595/2012, E. 4.2; BGer, 12. Januar 2016, 9C.881/2015, E. 2.1.

¹⁵⁰ BGer, 9. März 2017, 6B_100/2017, E. 3; BGE 144 I 253, E. 3.8.

eine Fremdanamnese eingeholt werden. Die Gegenwart Dritter könne kontraproduktiv sein und die Tatsachenfeststellung erschweren. Sowohl bei der somatischen als auch bei der psychiatrischen Begutachtung bestehe die Gefahr, dass die Drittperson das Wort ergreife und die Gesprächsführung für die begutachtete Person übernehme oder dass sich letztere nicht traue, unbefangene Aussagen zu machen. Es gelte zu vermeiden, dass die Begutachtung zum Anlass genommen werde, den Gutachter in ein Streitgespräch zu verwickeln. Eine kritische Auseinandersetzung habe vielmehr gestützt auf das schriftliche Gutachten zu erfolgen.¹⁵¹

- 53 Mit denselben Argumenten lehnte das Bundesgericht nur wenig später ab, dass sich eine Beschwerdeführerin von einem Arzt zur medizinischen Begutachtung begleiten liess. Die Anwesenheit eines medizinisch ausgebildeten Beistands sei mit dem Vertrauensverhältnis unvereinbar, das eine erspriessliche medizinische Begutachtung voraussetze.¹⁵² Diese Erwägungen vermögen nach Ansicht des Bundesgerichts den Ausschluss des Beistands selbst dann zu begründen, wenn dieser nur unter der Auflage, während der Begutachtung zu schweigen, zugelassen wird. Bereits die blossе Anwesenheit des Dritten sei geeignet, den Verlauf und das Ergebnis der Begutachtung zu beeinflussen, was insbesondere mit der psychiatrischen Exploration unvereinbar sei.¹⁵³

b) Methodenbedingte Anwesenheit von Drittpersonen

- 54 Der bundesgerichtliche Schutz der Methodenfreiheit des Sachverständigen darf indes nicht als Gebot missverstanden werden, Drittpersonen von der Begutachtung auszuschliessen. Vielmehr handelt es sich um die Freiheit des Sachverständigen, den Teilnehmerkreis der Exploration nach fachlichem Ermessen selbst zu bestimmen. Es ist der sachverständigen Person m.a.W. erlaubt, Drittpersonen an der Untersuchung teilnehmen zu lassen.¹⁵⁴ Wenn sie zu diesem Schritt greift, muss sie immerhin offenlegen, welche Angaben vom Exploranden und welche vom Dritten stammen und welchen Einfluss der erweiterte Anwesendenkreis auf

¹⁵¹ EVGer, 26. Juni 2007, I.42/06, E. 4.5.

¹⁵² EVGer, 7. August 2007, I 991/06, E. 3.1 f.

¹⁵³ EVGer, 7. August 2007, I 991/06, E. 3.2.

¹⁵⁴ BGE 119 Ia 260, E. 6c; EVGer, 26. Juni 2007, I.42/06, E. 4.5; BGer, 18. Februar 2013, 8C.595/2012, E. 4.2; BGE 140 V 260, E. 2.3.2 sowie E. 3.3.1, BGer, 29. September 2014, 8C.504/2014, E. 5.2.2; BGer, 12. Januar 2016, 9C.881/2015, E. 2.1 mit der konzisen Ausführung: «Richtig ist vielmehr, dass der Versicherte keinen Rechtsanspruch auf Anwesenheit Dritter während der Untersuchung hat ...Das schliesst selbstverständlich die konsensuale Anwesenheit von Personen des Vertrauens bei der Untersuchung der versicherten Person nicht aus, sofern der jeweilige medizinische Sachverständige damit einverstanden ist. Von einer «Unzulässigkeit» kann keine Rede sein.»

die Beurteilung des Sachverhalts hat.¹⁵⁵ Darüber hinaus hat die sachverständige Person dafür zu sorgen, dass die anwesende Drittperson keinen unerwünschten Einfluss auf die Begutachtung nimmt.¹⁵⁶

In zwei Konstellationen drängt sich die Teilnahme von Drittpersonen sogar methodisch auf, was vom Bundesgericht in seiner Praxis berücksichtigt wird. So können – wie bereits im Themenaufriß dargestellt¹⁵⁷ – bei fremdsprachigen Exploranden Sprachbarrieren bestehen, welche den Beizug eines Übersetzers unausweichlich machen.¹⁵⁸ In diesen Fällen obliegt es der sachverständigen Person, im Rahmen ihres fachkundigen Ermessens zu entscheiden, ob sich der Beizug eines Übersetzers aufdrängt.¹⁵⁹ Weiter kann der prekäre Gesundheitszustand der zu begutachtenden Person das Beisein einer medizinischen Betreuung notwendig machen, wobei auch hier die sachverständige Person im Rahmen ihres fachkundigen Ermessens zu beurteilen hat, ob der Beizug einer Drittperson im Einzelfall angezeigt ist.¹⁶⁰

B) Befürchtete Reflexwirkungen eines Teilnahmerechts

Über den Schutz der Methodenfreiheit hinaus manifestiert sich in der bundesgerichtlichen Praxis die Befürchtung unerwünschter Reflexwirkungen von Teilnahmerechten. So gab das Bundesgericht in BGE 132 V 443 zu bedenken, dass ein Teilnahmerecht des Rechtsbeistands des Versicherten an der Exploration über das Scharnier der Waffengleichheit Teilnahmerechte für weitere Parteien

¹⁵⁵ BGE 140 V 260, E. 3.2.3.

¹⁵⁶ BGer, 18. Februar 2013, 8C.595/2012, E. 4.2.

¹⁵⁷ Vgl. N 20.

¹⁵⁸ EVGer, 12. November 2003, I 642/01, E. 3.1; EVGer, 30. Dezember 2003, I 245/00, E. 4.1.1; EVGer, 3. März 2004, I 748/03, E. 2.1; BGE 140 V 260, E. 3.2.1; BGer, 17. Oktober 2014, 8C.578/2014, E. 4.2.5; BGer, 8. Januar 2016, 9C.262/2015, E. 5.1; BGer, 11. März 2016, 9C.875/2015, E. 5.2; bei somatischen Begutachtungen gilt ein weniger strenger Standard: EVGer, 3. März 2004, I 748/03, E. 2.1 f. (in casu eine rheumatologische Abklärung); ähnlich auch in einer neurologischen Begutachtung: BGer, 17. Oktober 2014, 8C.578/2014, E. 4.2.6; im Gegensatz dazu betrachtete es Verständnisschwierigkeiten bei einer psychiatrischen Begutachtung ohne Übersetzer als unzulässig, da sonst die Anamneseerhebung verfälscht werden kann, vgl. BGer, 8. Januar 2016, 9C.262/2015, E. 6.2.

¹⁵⁹ EVGer, I 245/00, 30. Dezember 2003, E. 4.2.1; EVGer, 3. März 2004, I 748/03, E. 2.1; BGer, 17. Oktober 2014, 8C.578/2014, E. 4.2.5; BGer, 8. Januar 2016, 9C.262/2015, E. 5.1; BGer, 11. März 2016, 9C.875/2015, E. 5.2.

¹⁶⁰ EVGer, 26. Juni 2007, I.42/2006, E. 4.6; BGer, 29. September 2014, 8C.504/2014, E. 5.2.2: «...dass die Anwesenheit einer von der versicherten Person frei gewählten Drittperson bei einer ärztlichen Untersuchung im Regelfall nicht zulässig ist, ausser die Gutachterperson erachtet dies im Einzelfall aus medizinischen oder anderen Gründen als notwendig.»; vgl. auch GUYAZ, S. 140 zum Ausnahmecharakter dieser Anwesenheitsfallgruppe.

(Versicherer, Pensionskasse) nach sich ziehen würde. Dies würde wiederum die Implementierung einer begutachtungsleitenden Behörde voraussetzen, die über die Anträge der Parteien entscheidet. Dadurch würde die Begutachtung den unerwünschten Charakter einer kontradiktorischen Parteiverhandlung erhalten. Weiter würde die Anwesenheit einer Verfahrensleitung im Rechtsmittelverfahren die Anwesenheit des gesamten mehrköpfigen Spruchkörpers nach sich ziehen, was mit den Persönlichkeitsrechten bzw. der Menschenwürde des Exploranden in Konflikt träte. Das Resultat der Begutachtung wäre im Übrigen unter solchen Bedingungen fragwürdig.¹⁶¹ Mit BGE 144 I 253 hat das Bundesgericht diese Bedenken auf den strafprozessualen Kontext übertragen.¹⁶²

- 57 Auch alternativen Lösungsmodellen steht das Bundesgericht kritisch gegenüber. So erwog es in einem Verfahren, dass man bei einem Teilnahmerecht des Rechtsbeistands des Exploranden der sachverständigen Person aus Gründen der Waffengleichheit ebenfalls das Recht einräumen müsse, eine medizinische Fachperson als Beobachter herbeizuziehen, was das Verfahren verkomplizieren würde.¹⁶³ Die ebenso diskutierte Option, die sachverständige Person zu berechtigen, den anwesenden Beistand im Störungsfall des Raumes zu verweisen, fand keinen Anklang, da bei dieser Lösung befürchtet wurde, dass die sachverständige Person bei einem entsprechenden Vorgehen mit Verdächtigungen konfrontiert würde (d.h. ihre Neutralität in Frage stünde).¹⁶⁴

II. Scheinargumente der Teilnahmereichsimmunisierung

- 58 Der Ausschluss von Teilnahmerechten im Rahmen der sachverständigen Erhebungen stützt sich neben den voranstehend erwähnten Kern- auch auf Scheinargumente. Letztere werden der Vollständigkeit halber zwar aufgeführt, aber aufgrund ihrer Haltlosigkeit sogleich mit summarischer Begründung verworfen und in den Kernteilen der vorliegenden Arbeit – d.h. im 3. und 4. Teil – nicht erneut aufgegriffen.

¹⁶¹ Für den gesamten Abschnitt: BGE 132 V 443, E. 3.6; so auch GUYAZ, S. 141.

¹⁶² BGE 144 I 253, E. 3.8.

¹⁶³ EVGer, 26. Juni 2007, I.42/06, E. 4.5.

¹⁶⁴ EVGer, 8. August 2007, I 874/06, E. 4.1.2.

1. Fehlender Beweiserhebungscharakter von sachverständigen Erhebungen

Das erste Scheinargument knüpft an den für das rechtliche Gehör massgeblichen Beweiserhebungsbegriff an. In BGE 99 Ia 42 hielt das Bundesgericht fest, dass die Parteien kraft des Gehörsanspruchs das Recht haben, an förmlichen Beweisabnahmen teilzunehmen. Der sachverständige Augenschein habe jedoch nicht die Vornahme verbindlicher tatsächlicher Feststellungen bezweckt. Die sachverständige Erhebung wurde damit formell nicht als Beweiserhebung erachtet, die nur unter Teilnahme der Parteien erfolgen durfte.¹⁶⁵ Dieselbe Ratio übertrug das Bundesgericht in BGE 119 Ia 260 im erwachsenenschutzrechtlichen Kontext (fürsorgerische Unterbringung) auf die Frage, ob der Rechtsbeistand seinen Mandanten im Rahmen der fachrichterlichen Einvernahme (psychiatrisches Explorationsgespräch) begleiten kann. Dabei führte es aus, dass die Bedeutung der fachrichterlichen Einvernahme einzig darin liege, Grundlage für die Erstellung eines Gutachtens zu sein. Einen eigentlichen Augenschein und damit einen Akt der Beweiserhebung stelle sie nicht dar.¹⁶⁶ Diese Begründung ist formalistisch und kann den Ausschluss von Teilnahmerechten nicht begründen.¹⁶⁷ Tätigt die von der Verfahrensleitung beauftragte sachverständige Person Erhebungen und fliessen diese durch den Sachverständigenbeweis in das Tatsachenfundament des Urteils ein, kann nicht bezweifelt werden, dass es sich materiell um Beweiserhebungen handelt.¹⁶⁸ 59

2. Befürchteter Mangel an Sachverständigen

Das zweite Scheinargument zur Ablehnung von Teilnahmerechten erwähnte das Bundesgericht erstmals in BGE 132 V 443. In diesem Urteil führte es aus, dass bei einem Teilnahmerecht des Rechtsbeistands im Rahmen des psychiatrischen Explorationsgesprächs weder die Verwaltungs- noch die Rechtsmittelbehörden Sachverständige in ausreichender Zahl finden könnten, «die ihre – unter Wahrheitspflicht nach bestem Wissen und Gewissen – auszuführende Tätigkeit unter diesen Voraussetzungen noch verrichten würden» (d.h. mit einem Teilnahmerecht des Rechtsbeistands). Dabei fügte es zur Untermauerung seiner These die sachverständige Person im konkreten Verfahren an, welche sich nur unter der Voraussetzung zur Annahme des Gutachtenauftrags bereit erklärt hatte, dass die 60

¹⁶⁵ BGE 99 Ia 42, E. 3b.

¹⁶⁶ BGE 119 Ia 260, E. 6c.

¹⁶⁷ Vgl. zur analogen Argumentation im Kontext der StPO: HEER, Anforderungen, S. 125 f.

¹⁶⁸ Zur Erhebungstätigkeit des Sachverständigen: N 113 ff.; zur Verwertbarkeit seiner Erhebungen: N 310 ff.

zu begutachtende Person ohne Begleitung ihres Rechtsbeistands erscheine.¹⁶⁹ In einem späteren Verfahren sah das Bundesgericht seine Befürchtung bestätigt, da auch hier die sachverständige Person die Erfüllung ihres Auftrags bei der Gewährung von Teilnahmerechten verweigert hätte.¹⁷⁰

- 61 Der befürchtete Mangel an Sachverständigen vermag den Ausschluss von Teilnahmerechten nicht zu stützen. Bereits die Antwort auf die Frage, ob sich bei der Gewährung von Teilnahmerechten noch Sachverständige finden lassen würden, ist in höchstem Masse unsicher und lässt sich kaum anhand von Einzelverfahren valide erschliessen.¹⁷¹ Ruft man sich die Tatsache vor Augen, dass die sachverständige Person für ihre Tätigkeit das Recht auf eine angemessene Entschädigung hat (vgl. Art. 190 StPO) und vor ihrer forensischen Tätigkeit eine langjährige kostenintensive Ausbildung durchlaufen hat, scheint die Annahme naheliegender, dass sich auch bei modifizierten Begutachtungsbedingungen noch ausreichend Sachverständige finden lassen würden. Wichtiger ist aber, dass der befürchtete Mangel an Sachverständigen bereits im Kern kein taugliches Begründungsmittel zur Ablehnung von Teilnahmerechten darstellt. Wenn sich herausstellen würde, dass die Teilnahme des Rechtsbeistands im Explorationsgespräch eine notwendige Bedingung des fairen Verfahrens ist, könnten Teilnahmerechte nicht mit dem Argument der zu befürchtenden Sachverständigenknappheit verdrängt werden. Ein Unterschreiten des fairnessrechtlichen Minimalstandards wäre unzulässig. Damit erweist sich das Argument der Sachverständigenknappheit auf Tatsachenebene als zweifelhaft und – wichtiger – auf rechtsstaatlicher Ebene als unhaltbar.¹⁷²

3. Negation der Subjektstellung des Exploranden

- 62 Ein drittes Scheinargument besteht in der Negation der Subjektstellung der zu begutachtenden Person. So lehnte das Bundesgericht ein Teilnahmerecht des Rechtsbeistands im Rahmen der psychiatrischen Begutachtung mit den Worten ab, die Partei sei im Rahmen der Untersuchung durch den Sachverständigen nicht als Verfahrenspartei beteiligt, sondern sie werde selber begutachtet.¹⁷³ Allerdings ist klar, dass die Partei eines Verfahrens ihre aus der Menschenwürde fliessende Subjektstellung in keinem Zeitpunkt des Verfahrens verliert. In der Exploration stellt sich lediglich die besondere Situation ein, dass die beschuldig-

¹⁶⁹ BGE 132 V 443, E. 3.7.

¹⁷⁰ EVGer, 7. August 2007, I 991/06, E. 3.2.

¹⁷¹ HEER, Feigenblatt, S. 29 spricht in diesem Zusammenhang zu Recht davon, dass ein solcher Mangel ein Armutszeugnis darstellen würde und zu hoffen ist, dass er einer tatsächlichen Grundlage entbehrt; HUBER, S. 269 Fn. 1237.

¹⁷² BERNHARD/BINDER, S. 11; SANER, S. 132.

¹⁷³ BGE 132 V 443, E. 3.5.

te Person zugleich Beweisobjekt und ein mit Rechten ausgestattetes Verfahrenssubjekt ist. Aus dieser Doppelrolle dürfen der begutachteten Person indes keine verfahrensrechtlichen Nachteile erwachsen.¹⁷⁴ Die Negation ihrer Subjektstellung ist in keinem Zeitpunkt ein stichhaltiges Argument, um Teilnahmerechte ihres Rechtsbestands abzulehnen.¹⁷⁵

4. Mangelnder Beitrag des passiv anwesenden Rechtsbestands an die Rechtspflege

Die Teilnahmerechtsimmunisierung der Exploration wird schliesslich mit einer Überlegung zur Funktion des Rechtsbestands legitimiert. So führte das Bundesgericht aus, dass der Rechtsbestand, welcher bloss als stiller Beobachter an der Exploration teilnehme, keinen Beitrag an die Rechtspflege leiste.¹⁷⁶ Auch dieser These stehen offenkundige Argumente entgegen. So besteht eine Grundlage des Rechts auf Verteidigung anlässlich der Einvernahme im Vorverfahren gerade in der Prämisse, dass mit der Anwesenheit der Verteidigung unzulässigen Verhaltensweisen der Strafbehörden vorgebeugt werden kann (Präventiveffekt).¹⁷⁷ Diese Erwägungen gelten für die Exploration des Sachverständigen in keinem geringeren Masse, womit auch das Argument des mangelnden «Rechtspflegebeitrags» als Scheinargument zurückzuweisen ist.

III. Fazit

Das Bundesgericht schliesst zwar die ausnahmsweise Zulassung des Rechtsbestands im Rahmen der Exploration nicht strikte aus. In seiner Praxis ist jedoch noch nie ein Fall eingetreten, in welchem ein Teilnahmerecht eingeräumt wurde. Vielmehr immunisiert das Bundesgericht sachverständige Erhebungen seit jeher und über sämtliche Rechtsgebiete hinweg (Straf-, Verwaltungs-, Zivilverfahren) von Teilnahmebegehren der Parteien und ihrer Rechtsbestände. Sieht man von den offensichtlich untauglichen und daher summarisch verworfenen Scheinargumenten ab, beruht diese Rechtsprechung hauptsächlich auf der Annahme, dass Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen zur Wahrung des rechtlichen

¹⁷⁴ HEER, FS Wiprächtiger, S. 200.

¹⁷⁵ Ebenso HUBER, S. 269.

¹⁷⁶ EVGer, 8. August 2007, I 874/06, E. 4.1.2. Zusätzlich rezipierte das Gericht mit dieser Erwägung implizit den psychiatrischen Methodenstandard, wonach selbst bei Anwesenheit einer Drittperson dafür zu sorgen ist, dass diese nicht ins Begutachtungsgeschehen interveniert, vgl. N 19 f.

¹⁷⁷ Dazu näher N 287 ff.

Gehörs im Rahmen des Sachverständigenbeweises nicht notwendig sind.¹⁷⁸ Darüber hinaus kommt gerade bei psychiatrischen Explorationsgesprächen dem Schutz der Methodenfreiheit grosse Bedeutung zu.¹⁷⁹ Das Bundesgericht ist in diesem Rahmen bestrebt, optimale Bedingungen für die Wahrheitssuche des Sachverständigen zu schaffen. Letzterer ist befugt, nach eigenem fachkundigem Ermessen über den Kreis der an einer Exploration teilnehmenden Personen zu bestimmen. Dabei führen die methodischen Vorgaben des Sachverständigen – den Sonderfall des Übersetzers und einer medizinischen Betreuung ausgenommen – regelmässig zum Ausschluss von Drittpersonen, damit die erforderliche Vertrauensbasis für die Begutachtung geschaffen und Störungen vermieden werden können. In dieser der Methodenfreiheit verpflichteten Rechtsprechungskonzeption haben Teilnahmerechte von Rechtsbeiständen oder sonstigen Dritten im Rahmen der Exploration keinen Platz.¹⁸⁰

- 65 Seine teilnahmerechtsfeindliche Praxis stützt das Bundesgericht weiter auf die Befürchtung ab, dass bei der grundsätzlichen Gewährung von Teilnahmerechten unerwünschte Reflexwirkungen entstehen. Konkret wird befürchtet, dass ein Teilnahmerecht des Rechtsbeistands der zu begutachtenden Person über das Prinzip der Waffengleichheit Teilnahmerechte der anderen Parteien aktivieren würde. Die Exploration verkäme in einer solchen Konstellation zu einer kontradiktorischen Parteiverhandlung, was nicht nur den Erkenntniswert der Begutachtung schmälern würde, sondern auch mit dem Persönlichkeitsschutz der begutachteten Person (Menschenwürde) nur schwer vereinbar wäre. Auch bei anderen Lösungsmodellen bestehen Bedenken, dass man der sachverständigen Person bei einem Teilnahmerecht des Rechtsbeistands aus Waffengleichheitsgründen ebenfalls das Recht auf einen neutralen medizinischen Beobachter einräumen müsste. Schliesslich wird die Neutralität des Sachverständigen als gefährdet angesehen, wenn er den anwesenden Rechtsbeistand im Störungsfall des Raumes verweist.¹⁸¹
- 66 Summa summarum lässt sich konstatieren: Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen bilden keine bekannte Grösse des Verfassungsrechts; auch und gerade beim psychiatrischen Explorationsgespräch nicht.

¹⁷⁸ Vgl. N 45 ff.

¹⁷⁹ Zu diesem Prinzip: N 11 ff.

¹⁸⁰ Vgl. N 49 ff.

¹⁸¹ Vgl. 56 ff.

§ 4 Rahmenmodell der Strafprozessordnung

Mit Kenntnis des verfassungsrechtlichen Rahmenmodells ist die Basis für eine Analyse der Strafprozessordnung gelegt. Der Legislative stünde es frei, sachverständige Erhebungen unbeschadet der Minimalgarantien des höherrangigen Rechts den Teilnahmeinteressen der Parteien und ihren Rechtsbeiständen zu öffnen. Ein Blick in die StPO bleibt aber vorerst ohne Erkenntnisse. Die Vorschriften zum Sachverständigenbeweis (Art. 182 ff. StPO) enthalten keine Sondernorm zur Frage der Teilnahmerechte der Parteien und/oder deren Rechtsbeistände. Als Fundament eines solchen Anspruchs könnte einzig das allgemeine Teilnahmerecht nach Art. 147 StPO in Frage kommen. Nach Abs. 1 dieser Norm haben Parteien und ihre Rechtsbeistände¹⁸² das Recht, «...bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen».¹⁸³ Allerdings bezieht sich diese Vorschrift nach ihrem Wortlaut einzig auf Beweiserhebungen der Staatsanwaltschaft und der Gerichte und nicht jene der sachverständigen Person. Die nachfolgende Analyse wird zeigen, dass die Absenz einer einschlägigen Regelung in den Art. 182 ff. StPO sowie die ausbleibende Nennung der sachverständigen Erhebungen im Rahmen von Art. 147 StPO nicht das Resultat eines Zufalls, sondern einer überlegten gesetzgeberischen Entscheidung darstellen.

67

¹⁸² Obwohl nicht explizit genannt, ergibt sich aus der Historie und Gesetzessystematik (Art. 147 Abs. 3 StPO) eindeutig, dass neben den Parteien auch allfällig mandatierete Rechtsbeistände zur Teilnahme an den Beweiserhebungen i.S.v. Art. 147 Abs. 1 StPO berechtigt sind. Vgl. die präzisierenden Ausführungen der Botschaft StPO, S. 1187: «Dass neben der Partei auch ihr Rechtsbeistand an einer Beweisabnahme teilnehmen kann, ergibt sich an sich bereits aus Artikel 125 Absatz 1 [Anmerkung des Autors: entspricht dem geltenden Art. 127 Abs. 1 StPO]. Streng gesehen lässt sich daraus jedoch kein Recht des Rechtsbeistandes auf Teilnahme an einer Einvernahme der eigenen Klientschaft ableiten. Die ausdrückliche Statuierung des Teilnahmerechts auch für Rechtsbeistände in Absatz 1 beseitigt mögliche Zweifel.»

¹⁸³ Die französische und italienische Fassung decken sich mit der deutschen Fassung von Art. 147 Abs. 1 StPO, wenn sie von «Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants» bzw. «Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati» sprechen.

I. Motto: «Bewährtes beibehalten – Weiterentwicklungen wo notwendig»

- 68 Der Gesetzgebungsprozess für die Eidgenössische Strafprozessordnung stand unter dem Leitspruch, Bewährtes beizubehalten und Bestehendes wo notwendig weiterzuentwickeln. Letzteres (Weiterentwicklung) sollte vor allem mit Blick auf die Vorgaben des übergeordneten Rechts erfolgen.¹⁸⁴ Vor dem Hintergrund dieses Mottos lassen sich durch die Eruierung des «bewährten» altrechtlichen Bestands kantonaler Regelungen sowie der Vorgaben des höherrangigen Rechts erste Indizien erkennbar machen, ob der Gesetzgeber ein Teilnahmerecht an sachverständigen Erhebungen in die Strafprozessordnung zu legen gedachte.

1. Orientierungspunkt I: Höherrangiges Recht

- 69 Es wurde bereits in § 3 ausführlich dargelegt, dass das Verfassungsrecht zu keinem Zeitpunkt Leitlinien enthielt, aus denen sich für die hier zu interessierende Frage klarer Weiterentwicklungsbedarf für die zu schaffende Strafprozessordnung ergeben hätte. Sachverständige Erhebungen wurden im Gegensatz geradezu teilnahmerechtsimmunisiert. Auch das Völkerrecht beinhaltete – wie im 3. und 4. Teil dieser Arbeit noch näher zu erläutern sein wird¹⁸⁵ – keinen Standard, welcher eine Öffnung der sachverständigen Erhebungen für Teilnahmerechte in klarer Weise indiziert hätte. Kurz: Zum Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens existierte kein Orientierungspunkt des höherrangigen Rechts, welcher den Gesetzgeber zur Implementierung von gesetzlichen Teilnahmerechten bei sachverständigen Erhebungen gedrängt hätte, was sich auch in den diesbezüglich inhaltslosen Materialien spiegelt.

2. Orientierungspunkt II: Bestand an kantonalen Regelungsansätzen

- 70 Ungeachtet des Verfassungs- und Völkerrechtsstandards könnten Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen Teil eines bewährten altrechtlichen Standards gebildet haben, den es in die StPO zu übertragen galt. Doch auch hier indiziert eine nähere Betrachtung Gegenteiliges.

¹⁸⁴ Botschaft StPO, S. 1086 f. («Ohne dass eine einzelne Prozessordnung als Vorlage gedient hätte, knüpfen sie [die Entwürfe] vielmehr an bestehende Verfahrensformen und -institute an, soweit sich diese bewährt haben. Wo notwendig und sinnvoll, wird Bestehendes weiterentwickelt.») und S. 1101.

¹⁸⁵ Vgl. N 96 ff. und N 283 ff.

A) Kantonalrechtliche Regelungen

Die kantonalen Strafprozessordnungen enthielten ganz überwiegend (23 Kantone) keine Normen, welche Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen zum Inhalt hatten. Sofern in einzelnen Verfahren versucht wurde, den Anwendungsbereich von gesetzlich geregelten Teilnahmerechten der Verteidigung bei strafbehördlichen Beweiserhebungen auf sachverständige Erhebungen auszuweiten, war dies nicht von Erfolg gekrönt. Das VGer-BL wies die vom Beschwerdeführer behauptete Existenz eines Teilnahmerechts der Verteidigung am Explorationsgespräch des PSY-Sachverständigen mit der beschuldigten Person mit der Begründung zurück, es existiere keine Gesetzesgrundlage für ein solches Recht.¹⁸⁶ Zu demselben Schluss gelangte das KassGer-ZH: Es hielt fest, dass das allgemeine Teilnahmerecht der Verteidigung bei strafbehördlichen Einvernahmen der beschuldigten Person nach § 17 Abs. 2 Satz 1 aStPO-ZH¹⁸⁷ nicht auf das Explorationsgespräch des PSY-Sachverständigen mit der beschuldigten Person anwendbar sei und dass sich eine analoge Anwendung aufgrund der Unterschiede zwischen Einvernahme und Exploration verbiete.¹⁸⁸

Immerhin drei Kantone (Waadt, Neuchâtel und Tessin) enthielten spezifische Gesetzesbestimmungen. Art. 242 Abs. 1 aStPO-VD stipulierte, dass die Parteien dem Gericht die Teilnahme an den gutachterlichen Erhebungen beantragen können, wobei das Gericht über den Antrag nach Rücksprache mit der sachverständigen Person entscheidet.¹⁸⁹ Ähnlich lautete die Regelung des Kantons Neuenburg, die den Parteien in Art. 160 aStPO-NE das Recht einräumte, dem Gericht einen Antrag auf Teilnahme bei der Gutachtenserstellung zu stellen.¹⁹⁰ Bei diesen Normen handelte es sich jedoch bei näherer Betrachtung nur um die Möglichkeit, einen Antrag auf Teilnahme bei den Erhebungen des Sachverständigen zu stellen, und nicht um ein Teilnahmerecht, da das Gericht den Antrag ohne Weiteres zurückweisen konnte.¹⁹¹ Damit divergierte die Rechtslage in den Kantonen Waadt und Neuenburg sachlich nicht von der zuvor erwähnten kantonalen Mehrheit, denn auch in den Kantonen ohne explizite Regelung konnte ohne

¹⁸⁶ VGer-BL, 26. März 2007, 410 0 32, E. 28.

¹⁸⁷ § 17 Abs. 2 Satz 1 aStPO-ZH: «Der Untersuchungsbeamte hat dem Verteidiger Gelegenheit zu geben, an den Einvernahmen des Angeschuldigten teilzunehmen, wenn dieser es verlangt und der Zweck der Untersuchung dadurch nicht gefährdet wird.»

¹⁸⁸ KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/dd.

¹⁸⁹ Art. 242 aStPO-VD: «Si une partie désire assister à l'une des opérations de l'expertise, elle en fait la demande au juge qui, après avoir consulté l'expert, admet ou rejette la requête.»

¹⁹⁰ Art. 160 aStPO-NE: «Si l'une des parties désire assister à l'expertise, elle en fait la demande au juge.»

¹⁹¹ Für den Kanton Neuchâtel explizit: BAUER/CORNU, Art. 160 N 2; allgemein: HELFENSTEIN, S. 188.

Weiteres ein Antrag auf Teilnahme an den sachverständigen Erhebungen (ohne einhergehenden Rechtsanspruch darauf) gestellt werden.

- 73 Der Kanton Tessin bildete schweizweit die grosse Ausnahme. Nach Art. 142 Abs. 4 aStPO-TI hatten die Parteien das Recht, dass die von ihnen mandatierten Privatsachverständigen an den Erhebungen der amtlich beauftragten sachverständigen Person teilnehmen durften. Einem entsprechenden Antrag musste Folge geleistet werden, sofern durch die Teilnahme des Privatsachverständigen keine Verzögerung oder eine Störung des Begutachtungsprozesses zu befürchten war.¹⁹² Diese Norm statuierte als einzige kantonale Norm ein eigentliches gesetzliches Teilnahmerecht (wenn auch nur des Privatsachverständigen) an Erhebungen der sachverständigen Person, das nur bei Vorliegen sachlicher Gründe eingeschränkt werden konnte.

B) Teilnahmeimmunisierung des Explorationsgesprächs

- 74 Für das Explorationsgespräch des PSY-Sachverständigen mit der beschuldigten Person entwickelte sich unter dem Geltungsbereich der kantonalen Strafprozessordnungen eine Rechtsprechungslinie, welche ein Teilnahmerecht der Verteidigung am PSY-Explorationsgespräch konstant verneinte. Das VGer-BL begründete diesen Standpunkt unter anderem mit dem Verweis auf die Verfassungsrechtsprechung des Bundesgerichts, wonach im Rahmen der Begutachtung diejenigen Bedingungen zu schaffen seien, die aus wissenschaftlicher Sicht am ehesten geeignet sind, eine objektive Beurteilung zu ermöglichen. Die Anwesenheit der Verteidigung sei diesem Zweck nicht dienlich. Die Möglichkeit der nachträglichen Stellungnahme genüge den Anforderungen des rechtlichen Gehörs.¹⁹³ Das KGer-GR gelangte unter Rekurs auf die bundesgerichtlichen Leitlinien zum selben Schluss (kein Teilnahmerecht).¹⁹⁴ Die Harmonie der kantonalen Judikatur wurde auch durch das KassGer-ZH nicht gebrochen. Zwar sei die Teilnahme der Verteidigung am Explorationsgespräch nicht per se unzulässig und in denjenigen Fällen denkbar, in denen sich die misstrauische Haltung eines Exploranden nicht anders bereinigen lasse. Ein Recht der Verteidigung auf Teilnahme am Explorationsgespräch bestehe aber nicht. Die Anwesenheit des Anwalts sei erfahrungsgemäss eher hinderlich, die notwendige Vertrauensbasis

¹⁹² Art. 142 Abs. 4 aStPO-TI: «Le parti possono far assistere alle operazioni peritali periti propri; la domanda dev'essere accolta, sempre che non comporti ritardi od ostacoli all'opera dei periti giudiziali.»

¹⁹³ VGer-BL, 26. März 2007, 410 0 32, E. 28 mit Verweis auf BGE 119 Ia 260, BGer, 14. August 2006, I.650/2005 (= BGE 132 V 443) sowie BGer, 27. Januar 2003, 5P.11/2003.

¹⁹⁴ KGer-GR, 4. Dezember 2007, SF 07 10, E. 5a und b mit Verweis auf BGE 119 Ia 260.

zwischen sachverständiger Person und Explorand zu kreieren.¹⁹⁵ Die Gefahr, dass sich die beschuldigte Person in der Begutachtung selbst belaste, lasse sich mit einer Belehrung über das Aussageverweigerungsrecht bereinigen.¹⁹⁶ Sieht man vom Sonderfall Tessin ab,¹⁹⁷ spiegelte sich in der kantonalen Praxis die bundesgerichtliche Verfassungsrechtsprechung, welche auch vom Schrifttum¹⁹⁸ überwiegend rezipiert wurde, sofern es sich überhaupt zur Thematik äusserte¹⁹⁹. Plädoyers für einen Paradigmenwechsel hin zu einem Teilnahmerecht der Verteidigung beim Explorationsgespräch des Sachverständigen mit der beschuldigten Person blieben die grosse Ausnahme.²⁰⁰

3. Zwischenfazit

Nach der Bestimmung der Orientierungspunkte ist klar: Weder existierte ein klarer Weiterentwicklungsbedarf seitens des höherrangigen Rechts, noch bilde- 75
ten Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen Teil eines bewährten Bestandes. Die kantonalrechtliche Ausgangslage gestaltete sich vielmehr als Spiegel der Verfassungsrechtsprechung und lehnte Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen ab. Für das Explorationsgespräch wurde dies mit der bereits aus der Verfassungspraxis bekannten Begründung untermauert, dass die Anwesenheit der Verteidigung Störungen des Begutachtungsprozesses mit sich bringen würde.²⁰¹

¹⁹⁵ KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/dd.

¹⁹⁶ KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/dd.

¹⁹⁷ BRANDA, S. 147 f. und die von ihm referierte Praxis, wonach die Teilnahme des Privatsachverständigen als Beobachter zulässig war.

¹⁹⁸ BÄNZIGER/STOLZ/KOBLER, Art. 89 N 5; BAUER/CORNU, Art. 160 N 1 f. mit dem Hinweis darauf, dass es bei allen medizinischen (insb. psychiatrischen) Befragungen die Teilnahme von Dritten ausgeschlossen sei; DONATSCH/SCHMID-DONATSCH, § 115 N 35; HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, § 55 N 6 f.; HELFENSTEIN, S. 195 inkl. Fn. 130; OBERHOLZER, Grundzüge 2005, N 935 und 1244 mit Verweis auf BGE 119 Ia 269; SCHMID, Strafprozessrecht, Fn. 241; PIQUEREZ, Traité, N 807 der in Fn 2118 auf BGE 99 Ia 42 hinweist; ZWEIDLER, § 108 N 5 und § 101 N 5.

¹⁹⁹ Diverse Werke enthielten keine Bemerkungen zur Frage der Teilnahmerechte bei sachverständigen Erhebungen: AESCHLIMANN, N 916 ff.; BOVAY ET AL., Art. 233 ff.; KÜNG/HAURI/BRUNNER, § 109 ff.; MAURER, S. 229 ff.; aCPP-JU-PIQUEREZ, S. 278 ff.; REY, Art. 65 ff.

²⁰⁰ BRUNNER, Aspekte, S. 195 ff.; BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 42.

²⁰¹ Für den gesamten Absatz N 70 ff.

II. Gesetzgebungsverfahren: Bekenntnis zum Bewährten

- 76 Angesichts der geschilderten Ausgangslage wäre mit Blick auf das Gesetzgebungsmotto²⁰² zu erwarten, dass der Gesetzgeber das bewährte Prinzip der teilnahmerechtslosen sachverständigen Erhebungen auf die zu schaffende StPO übertrug. Diese Erwartung bestätigte sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens.

1. Vorparlamentarische Phase

- 77 Der Sachverständigenbeweis vermochte im Frühstadium der Rechtsvereinheitlichung wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Weder im Zwischenbericht der Expertenkommission²⁰³ noch im folgenden Bericht der Expertenkommission «Aus 29 mach 1»²⁰⁴ fanden sich einschlägige Äusserungen zur hier zu interessierenden Fragestellung. Erst der Begleitbericht bot erste Aufschlüsse, wobei die massgeblichen Ausführungen nicht im Kontext von Art. 158 ff. VE-StPO (des heutigen Art. 147 StPO²⁰⁵), sondern in den Normen des Sachverständigenbeweises ihren Platz fanden. Der Begleitbericht betonte, dass sich die Regulierung des Sachverständigenbeweises an das Altbekannte anlehne.²⁰⁶ Ebenso wurde die Kompetenz der sachverständigen Person zur Vornahme eigener Erhebungen sowie die damit mögliche Befragungen von Dritten aufgegriffen und dazu ausgeführt, dass letztere mit Blick auf die Aussageverweigerungsrechte der Drittpersonen und allfällige Teilnahmerechte problematisch seien.²⁰⁷ Diese Bedenken vermochten aber die gesetzliche Kompetenz der sachverständigen Person, einfache Erhebungen selbst vorzunehmen, nicht zu verdrängen.²⁰⁸ Das daraus hervorgehende Spannungsverhältnis mit den Teilnahmerechten wurde mit Verweis auf BGE 119 Ia 260 (darin lehnte das Bundesgericht das Teilnahmerecht eines Rechtsbeistands am Explorationsgespräch seines Mandanten ab) implizit zulasten der Verfahrensrechte aufgelöst.²⁰⁹

²⁰² Vgl. N 68.

²⁰³ Rapport d'activité intermédiaire, S. 1 ff.

²⁰⁴ Bericht, Aus 29 mach 1, weder S. 86, noch S. 94, noch S. 104 enthalten eine Äusserung zur Thematik.

²⁰⁵ Begleitbericht VE StPO, S. 113 f.

²⁰⁶ Begleitbericht VE StPO, S. 141.

²⁰⁷ Begleitbericht VE StPO, S. 143 Fn. 155.

²⁰⁸ Begleitbericht VE StPO, S. 142 f.

²⁰⁹ Begleitbericht VE StPO, S. 143 Fn. 155.

Die bundesrätliche Botschaft blieb erkenntnisarm, liess aber keine Abkehr von den im Begleitbericht begründeten Prinzipien erkennen. Wiederum wurden die sachverständigen Erhebungen im Kontext von Art. 144 E-StPO (heute Art. 147 StPO) mit keinem Wort angesprochen. Die dort angebrachten Ausführungen bezogen sich ausschliesslich auf strafbehördliche Beweiserhebungen.²¹⁰ Die Erläuterungen zum Sachverständigenrecht nach Art. 179 ff. E-StPO (Art. 182 ff. StPO) fokussierten sich auf die einfachen Erhebungen der sachverständigen Person nach Art. 182 E-StPO (Art. 185 StPO) und betonten deren sachliche und prozessökonomische Notwendigkeit (insb. bei psychiatrischen Gutachten). Die Thematik der Teilnahmerechte wurde in der Botschaft hingegen nicht mehr aufgegriffen.²¹¹ 78

2. Parlamentarische Phase

Die vorparlamentarische Phase liess Anhaltspunkte vermissen, wonach der Gesetzgeber sachverständige Erhebungen neuen Lösungen zuführen wollte. Die spärlichen Anhaltspunkte indizierten vielmehr ein Bekenntnis zum bewährten teilnahmerechtslosen Status der altrechtlichen kantonalen Verfahrensordnungen. Dieses Bekenntnis verfestigte sich in der parlamentarischen Phase. 79

A) Ständerat

In den Sitzungen der ständerätlichen Kommission beantragte ein Mitglied, dass die beschuldigte Person, wenn sie durch die sachverständige Person befragt wird oder sonst durch den Sachverständigen Beweise erhoben werden, dieselben Rechte wie bei Beweiserhebungen durch Strafbehörden besitzt (Art. 183 Abs. 1 E-StPO).²¹² Diesem Antrag wurde seitens der Verwaltung ein Gegenvorschlag gegenübergestellt, der auf zwei Pfeilern beruhte. Erstens sollten bei Befragungen durch die sachverständige Person Aussage- und Zeugnisverweigerungsrechte Anwendung finden. Zweitens sollte die sachverständige Person verpflichtet werden, die von ihr befragten Personen über diese Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechte zu belehren.²¹³ Vor der Annahme des eingangs erwähnten Antrags riet die Verwaltung ab, da die Verteidigung damit u.a. ein Teilnahmerecht an sachverständigen Befragungen der beschuldigten Person erlangen würde.²¹⁴ Das Kommissionsmitglied, das die eingangs erwähnte Variante formuliert hatte, zog daraufhin seinen Antrag zurück und die ständerätliche Kommission stimmte dem auf Aussage- und Zeugnisverweigerungsrechten und Belehrungs- 80

²¹⁰ Botschaft StPO, S. 1187 ff.

²¹¹ Botschaft StPO, S. 1212 f.

²¹² Protokoll RK-SR 21. Aug. 2006, Antrag Nr. 43 vom 4. Juli 2006.

²¹³ Protokoll RK-SR 21. Aug. 2006, S. 11.

²¹⁴ Protokoll RK-SR 21. Aug. 2006, S. 11.

pflichten beschränkten Gegenvorschlag der Verwaltung zu.²¹⁵ Diese Fassung wurde nachfolgend im Ständerat angenommen.²¹⁶

B) Nationalrat

- 81 In der nationalrätlichen Kommission wiederholte sich grosso modo die Prozedur des Ständerats. Nach dem Antrag eines Mitglieds sollte Art. 182 Abs. 4 E-StPO ein Passus angefügt werden, wonach die Mitwirkungsrechte der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung im Rahmen der Begutachtung gewahrt bleiben müssen.²¹⁷ Abermals wurde seitens der Verwaltung angemahnt, dass dieser Vorschlag unter anderem Teilnahmerechte der Verteidigung bei den entsprechenden sachverständigen Erhebungen aktivieren würde. Nach einer kurzen Diskussion über die Nachteile eines solchen Vorgehens (insb. die Kostenfolgen) wurde der entsprechende Antrag seitens des antragstellenden Kommissionsmitglieds zurückgezogen. Zustimmung fand der Vorschlag des Ständerates.²¹⁸ Diese Fassung wurde anschliessend vom Nationalrat angenommen²¹⁹ und ist in Art. 185 Abs. 5 StPO geltendes Recht geworden.

3. Zwischenfazit

- 82 Bereits die Randbemerkungen des Begleitberichts indizierten ein Bekenntnis zum altrechtlichen Prinzip der teilnahmerechtslosen sachverständigen Erhebungen. Diese Tendenz bestätigte sich in der parlamentarischen Phase. Hier wurde ein Teilnahmerecht der Verteidigung im Rahmen der sachverständigen Erhebungen in den Kommissionen beider Räte diskutiert und die Option zugunsten der Belehrungspflichten der sachverständigen Person (Art. 185 Abs. 5 StPO) verworfen. Die vorparlamentarische und parlamentarische Phase lebten damit dem Grundmotto nach und übertrugen das kantonale Bewährte in die StPO. Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Absicht des Gesetzgebers, Art. 147 StPO über strafbehördliche Beweiserhebungen hinaus auf Art. 185 Abs. 4 StPO zur Anwendung zu bringen.

²¹⁵ Protokoll RK-SR 21. Aug. 2006, S. 11.

²¹⁶ Amt. Bull., SR 2006, S. 1024.

²¹⁷ Protokoll RK-NR 22. Feb. 2007, Antrag Nr. 62 vom 20. Februar 2007.

²¹⁸ Protokoll RK-NR 22. Feb. 2007, S. 60 ff.

²¹⁹ Amt. Bull., NR 2007, S. 966.

III. Auslegungstreit um Art. 147 StPO

Trotz der vorangehend geschilderten Entwicklungen hat die Frage der Anwendung von Art. 147 StPO auf die sachverständigen Erhebungen nach Art. 185 Abs. 4 StPO einige Kontroversen mit sich gebracht und das Schrifttum in zwei Lager geteilt. Die dabei aufgestellten Thesen gilt es in Kürze zu skizzieren (1. und 2.), bevor Stellung dazu bezogen wird (3.).

1. Teilnahmerechtsfeindliche Auslegung

Ein Grossteil der Lehre erachtet Art. 147 StPO nicht als Basis eines Teilnahmerechts bei sachverständigen Erhebungen nach Art. 185 Abs. 4 StPO. Dabei stützen sich diese Stimmen einerseits auf den Wortlaut von Art. 147 Abs. 1 StPO, der die Erhebungen der sachverständigen Person nicht nennt («bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte»), sowie auf die voranstehend referierten Entwicklungen in den parlamentarischen Kommissionssitzungen.²²⁰ Diese auf den Wortlaut und die Entstehungsgeschichte gestützte Auslegung von Art. 147 StPO sieht sich durch die bundesgerichtliche²²¹ und kantonale Rechtsprechung²²² ausnahmslos bestätigt.

²²⁰ ANTOGNINI, N 9; BOMMER, recht 2010, S. 197 f.; CHRISTEN, S. 468; ZK StPO-DONATSCH, Art. 185 N 41; CPP-Bernasconi et al.-GALLANI/MARCELLINI, Art. 185 N 5; FONJALLAZ/ GASSER, S. 124; GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, S. 135; HAEFELIN, S. 213 und insb. Fn. 190; BSK StPO-II-HÄNNI, Art. 251/252 N 28; BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64a; ISENRING/ MÜLLER, AJP 2016, S. 1338; OBERHOLZER, Grundzüge 2012, N 823; HANSJAKOB, S. 303 f.; RIKLIN, Art. 147 N 2 sowie Art. 185 N 6; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1331; SCHMID/JOSITSCH, PraKomm, Art. 147 N 2 sowie Art. 185 N 10; SCHMID/ JOSITSCH, Handbuch, Fn. 397; CR CPP-THORMANN, Art. 147 N 8; CR CPP-VUILLE, Art. 185 N 15 ff.; ZK StPO-WOHLERS, Art. 147 N 1 (wobei dieser Autor seine Position in WOHLERS, Fremdanamnese, S. 84 f. wohl geändert hat); differenzierend DONATSCH, fp 2012, S. 237; PIQUEREZ/ MACALUSO, N 1121 (Grundsatz: keine Teilnahmerechte, aber Ausnahme denkbar).

²²¹ BGE 144 I 253, E. 3.3 ff.; BGer, 14. November 2014, 6B_20/2014, E. 5.2; BGE 142 IV 372, E. 3.3; BGer, 9. März 2017, 6B_100/2017, E. 3.1; BGer, 13. November 2017, 1B_443/2017, E. 3.2.

²²² OGer-BE, 30. März 2011, SK-Nr. 10 387, E. 3 f. (Explorationsgespräch); OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II.3 (Explorationsgespräch); KGer-BL, 16. Juli 2013, 460 13 87, E. 1.3.2; KGer-GR, 11. Februar 2015, SK2 14 39, E. 3d (sachverständige Befragung von Drittpersonen); CdJ-GE, 16. April 2013, ACPR/144/2013, E. 6.5 (sachverständige Kernbohrungen auf Grundstück); TriApp-TI 60.2013.151 vom 3. Juli 2013, E. 3.2.3 (Explorationsgespräch); OGer-AG, 16. Januar 2014, SBK.2013.373, E. 2.3.2.2 (Explorationsgespräch); KGer-LU, 12. August 2014, 2N 14 83, E. 4.1 (Explorationsgespräch)

85 Gerade in den Urteilsbegründungen – sofern sie das grammatikalische und historische Auslegungselement überschreiten – lassen sich altbekannte Erwägungen erkennen. Zentral ist die Annahme, dass die vor und nach der Begutachtung bestehenden Mitwirkungsrechte dem Gehörsanspruch genügen und Teilnahmerechte nicht notwendig sind.²²³ Ebenso findet sich das Argument, dass die Anwesenheit des Rechtsbeistands im Rahmen des Explorationsgesprächs nicht kompatibel mit den optimalen Untersuchungsbedingungen ist, d.h. potentiell störend wirken und den Erkenntniswert der Begutachtung schmälern könnte.²²⁴ Wie auch unter verfassungsrechtlichen Massstäben ist mit dieser Leitlinie nur ein Teilnahmerecht der Verteidigung ausgeschlossen, d.h. es steht der sachverständigen Person offen, nach eigenem fachlichem Ermessen Dritte im Rahmen der Begutachtung zuzulassen.²²⁵ Schliesslich findet sich auch das Argument, dass die Gewährleistung eines Teilnahmerechts der Verteidigung weitere Teilnahmerechte anderer Parteien bewirken könnte, was in Konflikt mit den Persönlichkeitsrechten sowie der Menschenwürde der beschuldigten Person treten könnte.²²⁶ Sodann sind auch die verfassungsrechtlichen Scheinargumente vertreten: Die Anwesenheit der Verteidigung wird als unnütz angesehen: Das Recht, Ergänzungsfragen zu stellen, könne mangels Fachwissen des anwesenden Rechtsbeistands gar nicht ausgeschöpft werden.²²⁷ Sachverständige Erhebungen nach Art. 185 Abs. 4 StPO seien keine Sachverhaltsabklärungen im Sinne von Untersuchungshandlungen und das Teilnahmerecht nach Art. 147 StPO knüpfe erst an die formelle Beweiserhebung durch die Strafbehörde (Erhebung des Gutachtens durch Behörde) und nicht schon dessen Vorbereitung (sachverständige Erhebung) an.²²⁸ Gesamthaft betrachtet erweisen sich die Leitlinien der Rechtsprechung somit weitgehend als Spiegel der bereits referierten Praxis zu den altrechtlichen kantonalen Regelungen bzw. zur bundesgerichtlichen Judikatur zum Untersuchungsgegenstand.

²²³ BGE 144 I 253, E. 3.8; BGE 142 IV 372, E. 3.3; implizit wohl auch BGer, 13. November 2017, 1B_443/2017, E. 3.2; CdJ-GE, 16. April 2013, ACPR/144/2013, E. 6.5; KGer-LU, 12. August 2014, 2N 14 83, E. 4.1.

²²⁴ BGE 144 I 253, E. 3.8; OGer-BE, 30. März 2011, SK-Nr. 10 387, E. 3 f.; OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II.3 und 4.1; OGer-AG, 16. Januar 2014, SBK.2013.373, E. 2.3.2.2; KGer-LU, 12. August 2014, 2N 14 83, E. 4.2 f.; implizit BGer, 9. März 2017, 6B_100/2017, E. 3.1.

²²⁵ OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II.3.

²²⁶ BGE 144 I 253, E. 3.8.

²²⁷ OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II. 4.1; OGer-AG, 16. Januar 2014, SBK.2013.373, E. 2.3.2.3.

²²⁸ OGer-BE, 30. März 2011, SK-Nr. 10 387, E. 3 f.; OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II.3; ähnlich auch KGer-LU, 12. August 2014, 2N 14 83, E. 4.1.

2. Teilnahmerechtsfreundliche Auslegung

Ein Teil des Schrifttums stellt sich gegen die zuvor aufgestellten Auslegungsergebnisse und erachtet Art. 147 StPO als taugliche Grundlage eines Teilnahmerechts bei sachverständigen Erhebungen. Die dafür vorgebrachten Argumente sind historischer (A.), systematisch-teleologischer (B.) sowie verfassungs- und völkerrechtlicher Natur (C.). 86

A) Zweifel an der Klarheit des gesetzgeberischen Willens

Hinterfragt wird zum einen die Klarheit des historischen Auslegungselements. Zwar ignorieren die betreffenden Autoren die Entwicklung in den parlamentarischen Kommissionen (Rückzug der Anträge zur Schaffung eines Teilnahmerechts) nicht. Nach ihrer Meinung dürfe aber aus dem Rückzug eines Antrags durch ein Mitglied in der Kommission nicht der Schluss gezogen werden, dass der Gesetzgeber ein Teilnahmerecht an sachverständigen Erhebungen nicht in die StPO zu legen gedachte. Vielmehr sei in den parlamentarischen Kommissionen unklar geblieben, ob die Verteidigungsrechte nicht ohnehin immer gelten, womit eine ausdrückliche Erwähnung eines Teilnahmerechts im Sachverständigenrecht redundant gewesen wäre.²²⁹ Mit dieser Argumentation – so die implizite Absicht der Autoren – soll der Boden für die nachfolgend zu erläuternden teleologischen und völker- bzw. verfassungsrechtlichen Argumente gelegt werden. 87

B) Analogie zur strafbehördlichen Beweiserhebung

Ein Kernargument für das Teilnahmerecht an sachverständigen Erhebungen ist systematisch-teleologischer Natur. Ausschlaggebend ist die Prämisse der Identität zwischen sachverständiger und strafbehördlicher Erhebung. Es sei nicht zu begründen, dass die Parteien und/oder ihre Rechtsbeistände bei strafbehördlichen Beweiserhebungen mit Teilnahmerechten ausgestattet sind, bei beweisbildenden sachverständigen Erhebungen aber nicht. Folglich seien dieselben Rechte wie bei Erhebungen durch die Verfahrensleitung einzuhalten, wobei ein Teil der Literatur Art. 312 Abs. 2 StPO analog anwenden will.²³⁰ 88

²²⁹ BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 15; BERNHARD/BINDER, S. 13; vgl. auch HUBER, S. 271.

²³⁰ BERNHARD/BINDER, S. 14; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 93; HEER, FS Wiprächtiger, S. 202 f.; HEER, Feigenblatt, S. 28; JEANNERET/KUHN, N 13011; MARQUES LOPES, N 27 ff.; SANER, S. 141 f.; in der Sache nach auch WOHLERS, Fremdanamnese, S. 84 f.; differenzierend MAZOU, N 25 f.; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Art. 185 N 22, welche ein Teilnahmerecht qua Analogie zu Art. 312 StPO dann befürworten, wenn die sachverständige Erhebung Einvernahmecharakter hat, aber bei technischen Erhebungen («opérations techniques») ein Teilnahmerecht

C) Verfassungs- und völkerrechtskonforme Auslegung

- 89 Häufig findet sich schliesslich die Auffassung, dass ein Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch aus einer völker- und verfassungskonformen Auslegung von Art. 147 StPO fliesse. Nur mit einem Teilnahmerecht lasse sich das Gutachten in seiner Gesamtheit nachträglich überprüfen (effektives Recht auf Stellungnahme), und nur so könne die Verteidigung im Rahmen des Explorationsgesprächs ihrer Kontroll-, Beistands- und Fürsorgefunktion nachkommen. Art. 147 StPO müsse daher verfassungs- und völkerrechtskonform ausgelegt werden und auch auf das Explorationsgespräch als Erhebung i.S.v. Art. 185 Abs. 4 StPO Anwendung finden.²³¹

IV. Stellungnahme

- 90 Vor dem Hintergrund des Geschilderten kann Stellung zur Stichhaltigkeit der jeweiligen Argumente bezogen werden. Als Ausgangspunkt gilt es in Erinnerung zu rufen, dass bei der Eruierung der ratio legis einer Norm anhand eines pragmatischen Methodenpluralismus vorzugehen ist.²³² Dabei darf der massgebliche Norminhalt nicht anhand der subjektiven Wertvorstellungen des Rechtsanwenders ermittelt werden; vielmehr hat die Konkretisierung der ratio legis aus Gründen der Gewaltenteilung nach den Vorgaben des Gesetzgebers zu erfolgen.²³³ Gerade bei jüngeren Gesetzen gilt die Leitlinie, dass ein eindeutiger und im Wortlaut reflektierter Wille des Gesetzgebers nicht einfach übergangen werden darf.²³⁴ Diese bindende Kongruenz von Wortlaut (Art. 147 StPO nennt nur strafbehördliche, keine sachverständigen Erhebungen) und gesetzgeberischem Willen bei einem jungen Erlass (dazu sogleich) liegt der hier vertretenen Meinung nach vor, sodass sich unter auslegungsmethodischen Gesichtspunkten nur die teilnahmerechtsfeindliche Auslegung vertreten lässt.²³⁵

in Abrede stellen; interessant sodann HUBER, S. 267 ff., der ein grundsätzliches Teilnahmerecht der Verteidigung jedoch nicht aus Art. 147 StPO, sondern Art. 127 ff. StPO ableitet.

²³¹ Für den ganzen Abschnitt: BERNHARD/BINDER, S. 14; BERNHARD, NZZ 25. April 2014, S. 23; BERNHARD, Jusletter 13. Februar 2012, N 39; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 92 f.; BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 13 ff.; HEER, FS Wiprächtiger, S. 203; MARQUES LOPES, N 25; SANER, S. 140 ff.

²³² BGE 142 IV 333, E. 3.2; BGE 142 IV 1 E. 2.4.1; BGE 141 II 436 E. 4.1; BGE 140 IV 28 E. 4.3.1; BGE 140 V 15 E. 5.3.2.

²³³ Stellvertretend: BGE 140 I 305, E. 6.2.

²³⁴ BGE 139 III 368, E. 3.2; BGE 142 IV 1, E. 2.4.3.

²³⁵ A.M. wohl HEER/COVACI, S. 440, welche dafür halten, dass das Gesetz einem Teilnahmerecht der Verteidigung nicht entgegenstehe.

1. Klarer Wille des Gesetzgebers

Wie bereits dargelegt wurde, werden in der Literatur vereinzelt Zweifel an der Klarheit des gesetzgeberischen Willens angebracht.²³⁶ Dieser Position muss widersprochen werden. Eine Gesamtbetrachtung der Entwicklung der Strafprozessordnung zeigt vielmehr einen klaren Willen des Gesetzgebers, der sich im Wortlaut und der Systematik des Gesetzes spiegelt. Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen waren mit Ausnahme des Kantons Tessin weder den kantonalen Strafprozessordnungen noch der kantonalen und bundesgerichtlichen Gerichtspraxis bekannt. Vielmehr wurden die sachverständigen Erhebungen im Allgemeinen und das psychiatrische Explorationsgespräch im Besonderen konstant «teilnahmerechtsimmunisiert». Im Vereinheitlichungsprozess entschied sich der Gesetzgeber für das Beibehalten des Bewährten. Dies deutete er bereits in der vorparlamentarischen Phase an.²³⁷ Diese Indizien verdichteten sich sodann in der parlamentarischen Phase: Wie geschildert, wurde in den Kommissionssitzungen die Implementierung eines Teilnahmerechts der Verteidigung im Kontext der Sachverständigennormen diskutiert, diese Lösung aber zugunsten von Art. 185 Abs. 5 StPO verworfen.²³⁸ Vor diesem Hintergrund ergibt sich der gesetzgeberische Wille klar: Art. 147 StPO hatte seitens des Gesetzgebers nie zum Ziel, Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen nach Art. 185 Abs. 4 StPO zu begründen. Das Fehlen einer expliziten Regelung zu den Teilnahmerechten im Rahmen von Art. 182 ff. StPO ist keine Gesetzeslücke, sondern ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers.

Diese Feststellung sieht sich auch durch eine dem Erlass der StPO nachfolgende Entwicklung bestätigt. Mittels einer Petition wurde die Integration eines gesetzlichen Teilnahmerechts der Verteidigung im Rahmen der psychiatrischen Begutachtung angestrebt. Sowohl die Kommission des National- als auch jene des Ständerats stellten den Antrag, dem Ansinnen des Petitionärs keine Folge zu leisten.²³⁹ Beide Kommissionen führten zur Begründung wortgleich aus, dass die existierenden Rechte vor und nach der Begutachtung ein Teilnahmerecht der Verteidigung entbehrlich machten.²⁴⁰ Sowohl der Stände- als auch der Nationalrat folgten den Empfehlungen der vorberatenden Kommissionen und gaben der Petition keine Folge.²⁴¹ Damit wurde implizit erkennbar, dass die geltende StPO nach der Vorstellung des Gesetzgebers keine Teilnahmerechte beinhaltet. Zwar darf dieser zeitlich nach Erlass der StPO erfolgende Gesichtspunkt auslegungsmethodisch nur insofern berücksichtigt werden, als dass er Aufschluss über den

²³⁶ Vgl. N 87.

²³⁷ Vgl. N 77 f.

²³⁸ Vgl. N 79 ff.

²³⁹ Bericht RK SR, Petition Reform 91, S. 1; Bericht RK NR, Petition Reform 91, S. 1.

²⁴⁰ Bericht RK SR, Petition Reform 91, S. 2; Bericht RK NR, Petition Reform 91, S. 2.

²⁴¹ Amt. Bull. NR 2015, S. 565; Amt. Bull. SR 2015, S. 298.

bereits im Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens bestehenden Willen des Gesetzgebers gibt. Gerade dieses Erfordernis ist in casu erfüllt und belegt, dass Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen vom Gesetzgeber nie vorgesehen waren.

2. Misslingen der StPO-Analogie zur Einvernahmenormierung

- 93 Das zweite Kernargument der teilnahmerechtsfreundlichen Auslegung fusst auf der Identität zwischen strafbehördlicher Einvernahme und sachverständiger Exploration und will Art. 312 Abs. 2 StPO analog angewendet sehen. Allerdings verbietet sich ein Analogieschluss vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte des Gesetzes, welche sich in Wortlaut und Systematik der StPO spiegelt. Während für polizeiliche Einvernahmen ein Teilnahmerecht der Verteidigung nach Art. 147 StPO aus einem expliziten gesetzlichen Verweis (Art. 312 Abs. 2 StPO) hervorgeht, fehlt es für die sachverständigen Erhebungen gerade an einer solchen Norm. Zur selben Feststellung führt die Betrachtung des Teilnahmerechts der Verteidigung an polizeilichen Einvernahmen im Vorverfahren (Art. 159 Abs. 1 StPO). Eine solche Spezialnorm wurde für die sachverständigen Erhebungen nicht geschaffen. Der Gesetzgeber kreierte absichtlich eine von den strafbehördlichen (auch den polizeilichen!) Einvernahmen abweichende Regelung, die sich in der Gesetzessystematik (weder Verweissnorm noch separate Teilnahmerechtsnorm) und im Wortlaut von Art. 147 StPO spiegelt.

3. Unzulässigkeit der völker-/verfassungskonformen «Begradigung»

- 94 Ein letztes Argument der teilnahmerechtsfreundlichen Auslegung fusst auf verfassungs- und völkerrechtlichem Fundament. Das Teilnahmerecht der Verteidigung fliesse aus dem höherrangigen Recht. Art. 147 StPO sei darum verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen. Ohne an dieser Stelle auf den Schutzstandard des höherrangigen Rechts einzugehen (dies wird Aufgabe des 3. und 4. Teils sein), verbietet sich diese Argumentation aus auslegungsmethodischer Sicht. Die Instrumente der verfassungs- und völkerrechtskonformen Auslegung finden ihren Anwendungsbereich nur so weit, wie im Rahmen der Gesetzesauslegung mehrere Auslegungsergebnisse vertretbar sind. Eine Auslegung entgegen dem klaren Wortlaut und dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers sprengt jedoch den Rahmen der zulässigen verfassungs- und völkerrechtskonformen Auslegung.²⁴² Nun wurde bereits ausführlich begründet, dass genau diese Kongruenz zwischen gesetzgeberischem Willen, Wortlaut (und Gesetzes-

²⁴² Vgl. N 39 und die dort zitierte Rechtsprechung.

systematik) vorliegt. Entsprechend kann Art. 147 StPO nicht durch das höherrangige Recht zurechtgebogen werden.

4. Fazit

Nach dem Gesagten ist der teilnahmerechtsfeindlichen Auslegung von Art. 147 StPO beizupflichten. Die StPO bietet keine Basis für ein Teilnahmerecht der Parteien und/oder ihrer Rechtsbeistände an sachverständigen Erhebungen, wie sich eindeutig aus Wortlaut, Entstehungsgeschichte und Systematik des Gesetzes ergibt. Die StPO führt damit weiter, was bereits zuvor Bestand hatte: das Primat der teilnahmerechtslosen sachverständigen Erhebungen. Dies hat – so viel sei an dieser Stelle bereits erwähnt – nicht die Wertlosigkeit sämtlicher Sachargumente zur Folge, welche Vertreter eines Teilnahmerechts der Verteidigung vorbringen. Der Schutzstandard des höherrangigen Rechts (in dieser Arbeit: der EMRK, die im Kollisionsfall der StPO vorgeht) wird im 3. und 4. Teil dieser Arbeit noch näher zu beleuchten sein. Will man aber die Integrität der Auslegungsmethodik wahren, dürfen Erkenntnisse des höherrangigen Rechts nicht schon bei der Auslegung von Art. 147 StPO einfließen: Eine verfassungs- und völkerrechtskonforme «Begradigung» dieser Norm verbietet sich aufgrund der eindeutigen gesetzgeberischen Vorgaben. 95

3. Teil: Das Teilnahmepostulat im Lichte des Rechts auf Stellungnahme zum Gutachten

§ 5 Prüfungsmodell des EGMR

Wie im Themenaufriß ausgeführt wurde, wird das Postulat des Teilnahmerechts der Verteidigung unter anderem auf die Argumentation gestützt, dass die beschuldigte Person und ihre Verteidigung ohne dieses Mittel nicht in der Lage seien, effektiv für die beschuldigte Person Stellung zum Gutachten bzw. zur Person des Sachverständigen zu beziehen.²⁴³ Dies kontrastiert mit der geltenden Rechtslage. Die Durchführung einer fachgerechten Exploration ist nach bundesgerichtlicher Praxis Sache der sachverständigen Person. Die Verteidigung habe weder den fachlich korrekten Ablauf unmittelbar zu kontrollieren noch die Exploration mit eigenen Fragen zu ergänzen. Sie könne ihre Kritik nach Erstellung des Gutachtens anbringen und es sei nicht ersichtlich, weshalb «eine effiziente methodische und inhaltliche Kontrolle des psychiatrischen Gutachtens durch die Verteidigung auf diesem gesetzlich vorgesehenen Weg von vornherein nicht möglich» sei.²⁴⁴ Im nun folgenden 3. Teil wird die Stabilität dieser einander widersprechenden Thesen zu prüfen sein. Davor gilt es, im vorliegenden Paragraphen das Prüfungsmodell des EGMR zu erläutern, das als dogmatisches Fundament der nachfolgenden Paragraphen dient. 96

I. Verortung des Prüfungsmodells in Art. 6 EMRK

Das relevante Prüfungsmodell des EGMR wurde ursprünglich unter Art. 6 Ziff. 1 EMRK entwickelt. Grund für diese dogmatische Einordnung bildete die Annahme, dass der Sachverständige kein Belastungszeuge i.S.v. Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK darstellt.²⁴⁵ In jüngeren Verfahren ist der EGMR von dieser Positi- 97

²⁴³ Vgl. N 27.

²⁴⁴ BGE 144 I 253, E. 3.8.

²⁴⁵ EGMR, *Bönisch v. Austria*, 6 May 1985, § 29, Series A no. 92; EGMR, *Brandstetter v. Austria*, 28 August 1991, § 42, Series A no. 211, wobei bereits hier der Bezug zu Art. 6 Ziff. 3 EMRK betont wird («The Court considers it appropriate to examine the applicant's complaint under the general rule of paragraph 1 of Article 6 (art. 6-1) of the Convention, whilst having due regard to the guarantees of paragraph 3»); dazu auch DONATSCH, 125 Jahre, S. 365 ff.

on abgerückt und prüft Rügen zum Sachverständigenbeweis im strafprozessualen Kontext unter dem allgemeinen Fairnessgebot nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK in Verbindung mit Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK.²⁴⁶

- 98 Die Frage der Einordnung des Prüfungsmodells in Art. 6 EMRK (konkret: Art. 6 Ziff. 1 isoliert oder in Verbindung mit Art. 6 Ziff. 3 lit. d) spielt aber für die nachfolgende Untersuchung keine Rolle. Massgeblich ist bei beiden Varianten die Maxime, ein waffengleiches Verfahren bzw. eine effektive Überprüfbarkeit des Sachverständigenbeweises sicherzustellen.²⁴⁷ Mit Blick auf diese uniforme Zielvorgabe kommt der rechtsdogmatischen Einordnung des Prüfungsmodells in das Konzept von Art. 6 EMRK nur theoretischer Erkenntniswert zu; sie ist folglich nicht weiter zu vertiefen.²⁴⁸ Das Interesse gilt nachfolgend einzig der Frage, nach welchen materiellen Kriterien der EGMR das Prinzip des fairen Verfahrens im Rahmen der Überprüfbarkeit des Sachverständigenbeweises auslegt.

II. Fairnessprüfungssequenzen des EGMR

- 99 Das Prüfungsmodell des EGMR besteht auf abstrakter Ebene aus zwei Teilen. Es trägt sowohl der Position und Rolle des Sachverständigen (1.) als auch der in einem konkreten Verfahren eingeräumten Verteidigungsrechte (2.) Rechnung. Dabei stehen die beiden Elemente in einer fairnessrechtlichen Austauschbeziehung.

²⁴⁶ EGMR, *Mirilashvili v. Russia*, no. 6293/04, § 158 ff., 11 December 2008; EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 168, 27 March 2014; EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 115, 1 June 2017; EGMR, *C.B. v. Austria*, no. 30465/06, § 38, 4 April 2013; EGMR, *Avagyan v. Armenia*, /no. 1837/10, § 40, 22 November 2018 (wobei die Garantie nach Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK aufgrund der verbleibenden Unterschiede zwischen einem «klassischen» Belastungszeugen und einem Sachverständigen bloss mutatis mutandis angewandt werden soll); TRECHSEL, S. 303 weist darauf hin, dass der Gerichtshof bei der dogmatischen Einordnung zu Art. 6 Ziff. 1 oder Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK keinen klaren Standpunkt einnimmt; a.M. GRABENWARTER, Art. 6 N 87.

²⁴⁷ EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 168, 27 March 2014; EGMR, *Shulepova v. Russia*, no. 34449/03, § 62, 11 December 2008; EGMR, *C.B. v. Austria*, no. 30465/06, § 40, 4 April 2013; EGMR, *Mantovanelli v. France*, 18 March 1997, § 33, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; EGMR, *Cottin v. Belgium*, no. 48386/99, § 29, 2 June 2005; EGMR, *Mirilashvili v. Russia*, no. 6293/04, § 156, 11 December 2008.

²⁴⁸ GRABENWARTER, Art. 6 N 87; GRABENWARTER/PABEL, § 24 N 75; zur Irrelevanz der dogmatischen Einordnung auch TRECHSEL, S. 303.

1. Position und Rolle des Sachverständigen

Ausgangspunkt der EMRK-Fairnessbeurteilung bildet die Analyse der prozessualen Position und Rolle des Sachverständigen im konkreten Verfahren.²⁴⁹ Diese beurteilt sich danach, wie stark die gerichtliche Entscheidung von der Stellungnahme des Sachverständigen abhängt (A.) und ob der Sachverständige im Verfahren mit der notwendigen Neutralität ausgestattet ist (B.). 100

A) Relevanzkriterium

Als Ausgangspunkt der Fairnessanalyse muss aufgezeigt werden, in welchem Mass der Sachverständigenbeweis die richterliche Entscheidungsfindung beeinflusst. Die Kernfrage lautet, ob das Gericht in der Lage ist, die durch den Sachverständigenbeweis eingebrachten Tatsachen selbständig zu würdigen, oder ob der Sachverständigenbeweis die richterliche Beweiswürdigung über weite Strecken ersetzt.²⁵⁰ Letzteres ist umso eher anzunehmen, als sich die vom Gericht und dem Sachverständigen zu beantwortenden Fragen überschneiden.²⁵¹ Weiter verstärkt wird die richterliche Abhängigkeit vom Gutachten, wenn der Sachverständige seine Stellungnahme zu Themen formuliert, die nicht zur Wissenssphäre des Gerichts gehören, was – wie vom EGMR betont – gerade bei medizinischen Fragestellungen regelmässig der Fall ist.²⁵² Liegen in dieser Konstellation nicht weitere Sachverständigenbeweise vor und stützt sich das Gericht für das vom Sachverständigen bearbeitete Beweisthema nicht auf weitere Beweisgrund- 101

²⁴⁹ EGMR, *Sara Lind Eggertsdóttir v. Iceland*, no. 31930/04, § 47, 5 July 2007; EGMR, *Bönisch v. Austria*, 6 May 1985, § 30 f., Series A no. 92; EGMR, *Sara Lind Eggertsdóttir v. Iceland*, no. 31930/04, § 47, 5 July 2007; EGMR, *Shulepova v. Russia*, no. 34449/03, § 62, 11 December 2008; EGMR, *Mirilashvili v. Russia*, no. 6293/04, § 178, 11 December 2008; EGMR, *Letinčić v. Croatia*, no. 7183/11, § 51, 3 May 2016; EGMR, *Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 26711/07 and 2 others, § 94, 12 May 2016; GRABENWARTER, Art. 6 N 65; GRABENWARTER/PABEL, § 24 N 50.

²⁵⁰ EGMR, *Eskelinen and Others v. Finland*, no. 43803/98, § 26, 8 August 2006.

²⁵¹ EGMR, *Oral v. Turkey* (no. 2), no. 18384/04, § 31, 25 November 2008; EGMR, *Cottin v. Belgium*, no. 48386/99, § 31, 2 June 2005; EGMR, *Mantovanelli v. France*, 18 March 1997, § 36, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; EGMR, *Letinčić v. Croatia*, no. 7183/11, § 65, 3 May 2016; kritisch zum Nutzen dieses Kriteriums JACOBS, S. 224.

²⁵² EGMR, *Mantovanelli v. France*, 18 March 1997, § 36, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; EGMR, *Cottin v. Belgium*, no. 48386/99, § 31, 2 June 2005; EGMR, *Shulepova v. Russia*, no. 34449/03, § 66, 11 December 2008; EGMR, *Korošec v. Slovenia*, no. 77212/12, § 47, 8 October 2015; EGMR, *Letinčić v. Croatia*, no. 7183/11, § 64, 3 May 2016; EGMR, *Krunoslava Zovko v. Croatia*, no. 56935/13, § 43, 23 May 2017; EGMR, *Devinar v. Slovenia*, no. 28621/15, § 50, 22 May 2018; kritisch zu diesem Kriterium: DECAIGNY, S. 161.

lagen, wird der zu beurteilende Sachverständigenbeweis zum entscheidenden Beweismittel.²⁵³

B) Neutralitätskriterium

102 Die Neutralität des Sachverständigen bildet das zweite Kriterium, welches für die Analyse der prozessualen Position und Rolle des Sachverständigen zu konsultieren ist. Gerade beim gerichtlich bestellten Sachverständigen besteht die Vermutung, dass seiner Stellungnahme grosses Gewicht bei der richterlichen Entscheidungsfindung zukommt. Entsprechend wichtig ist es für die Annahme eines fairen Verfahrens, dass er seine Arbeit möglichst neutral verrichtet.²⁵⁴ Zweifel an der Neutralität des Sachverständigen können nicht nur durch sein konkretes Verhalten, sondern auch durch seine Nähe zur prozessualen Gegenpartei aufkommen. Zu dieser Fallgruppe gehören beispielsweise die Beauftragung des Sachverständigen durch eine Partei im Verfahren (z.B. die Staatsanwaltschaft)²⁵⁵, die Beauftragung einer vom Staat aufgestellten und finanziell alimentierten medizinischen Begutachtungsinstitution²⁵⁶ oder das Vorliegen eines Anstellungsverhältnisses zwischen der Gegenpartei und dem Sachverständigen²⁵⁷.

2. Verteidigungsinstrumentarium

103 Neben der prozessualen Position und Rolle des Sachverständigen sind die Verteidigungsrechte zu betrachten, welche der beschuldigten Person in einem konkreten Verfahren eingeräumt werden. Dabei gilt die Leitvorgabe, dass die Verteidigungsmittel eine Möglichkeit eröffnen müssen, den Sachverständigenbe-

²⁵³ EGMR, *Devinar v. Sloveenia*, no. 28621/15, § 50, 22 May 2018; EGMR, *Eskelinen and Others v. Finland*, no. 43803/98, § 33, 8 August 2006.

²⁵⁴ EGMR, *Sara Lind Eggertsdóttir v. Iceland*, no. 31930/04, § 47, 5 July 2007; EGMR, *Bönisch v. Austria*, 6 May 1985, § 33, Series A no. 92; EGMR, *Letinčić v. Croatia*, no. 7183/11, § 51, 3 May 2016; EGMR, *Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 26711/07 and 2 others, § 94, 12 May 2016; DECAIGNY, S. 160; DONATSCH/ ZUBERBÜHLER, FS Riklin, S. 344 f.; BGE 137 V 210, E. 2.1.3.

²⁵⁵ EGMR, *Krunoslava Zovko v. Croatia*, no. 56935/13, § 45, 23 May 2017; EGMR, *Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 26711/07 and 2 others, § 94, 12 May 2016; EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 122 f., 1 June 2017; EGMR, *Duško Ivanovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 10718/05, § 57, 24 April 2014.

²⁵⁶ EGMR, *Krunoslava Zovko v. Croatia*, no. 56935/13, § 44, 23 May 2017.

²⁵⁷ EGMR, *Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 26711/07 and 2 others, § 94, 12 May 2016.

weis effektiv auf die Probe zu stellen.²⁵⁸ Rechtsrelevanter Massstab zu Beantwortung dieser Frage bildet das Prinzip der Waffengleichheit.²⁵⁹

Konzeptionell erachtet der EGMR diverse Instrumente als geeignet, die Fairness des Verfahrens beim Sachverständigenbeweis mit zu gewährleisten. Generell müssen der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung die Möglichkeiten offen stehen, Beweisanträge zu stellen, von Beweisen der Gegenpartei Kenntnis zu erhalten sowie zu allen Beweisen/Eingaben der Gegenpartei Stellung beziehen zu können.²⁶⁰ Die damit verbundenen Verteidigungsrechte können konzeptionell vor, während oder nach dem Gutachtenserstellungsprozess Anwendung finden.²⁶¹ Vor der Erstellung des Gutachtens kommt der Möglichkeit, zur Person des Sachverständigen und den Gutachtensfragen Stellung beziehen zu können, fairnessrelevante Bedeutung zu.²⁶² Während der Begutachtung können Teilnahmerechte an den sachverständigen Erhebungen eine Rolle spielen.²⁶³ Sodann wird darauf geachtet, dass die Parteien durch eigene Eingaben und die ihr zur Verfügung stehende Dokumentation auf den Beurteilungsprozess des Sachverständigen einwirken können.²⁶⁴ Nach der Begutachtung wird analysiert, in welchem Ausmass eine Partei Kenntnis von der Beweisgrundlagen hat, auf die der Sachverständige seine Begutachtung stützt (Aspekt der Akteneinsicht).²⁶⁵ Zentral ist sodann die Möglichkeit, das Gutachten studieren zu können, es mit Fragen auf die Probe zu stellen sowie die Möglichkeit, die sachverständige Person unmittelbar vor Gericht ins Kreuzverhör zu nehmen (Aspekt der Stellungnah-

²⁵⁸ EGMR, *Letinčić v. Croatia*, no. 7183/11, § 50, 3 May 2016.

²⁵⁹ EGMR, *Mirilashvili v. Russia*, no. 6293/04, § 156, 11 December 2008 EGMR, *Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia*, nos. 11082/06 and 13772/05, § 728, 25 July 2013; EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 116, 1 June 2017; EGMR, *C.B. v. Austria*, no. 30465/06, § 37, 4 April 2013; EGMR, *G.B. v. France*, no. 44069/98, § 58, ECHR 2001-X; EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 119, 1 June 2017.

²⁶⁰ EGMR, *Mantovanelli v. France*, 18 March 1997, § 33, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; EGMR, *Cottin v. Belgium*, no. 48386/99, § 29, 2 June 2005; EGMR, *Mirilashvili v. Russia*, no. 6293/04, § 156, 11 December 2008; EGMR, *Oral v. Turkey* (no. 2), no. 18384/04, § 30, 25 November 2008.

²⁶¹ EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 173 ff., 27 March 2014; EGMR, *Krunoslava Zovko v. Croatia*, no. 56935/13, § 47, 23 May 2017; dazu auch DECAIGNY, S. 160.

²⁶² EGMR, *Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia*, nos. 11082/06 and 13772/05, § 729, 25 July 2013; EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 184, 27 March 2014.

²⁶³ EGMR, *Mantovanelli v. France*, 18 March 1997, § 36, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; EGMR, *Cottin v. Belgium*, no. 48386/99, § 32 f., 2 June 2005.

²⁶⁴ EGMR, *Krunoslava Zovko v. Croatia*, no. 56935/13, § 46, 23 May 2017.

²⁶⁵ EGMR, *Krunoslava Zovko v. Croatia*, no. 56935/13, § 53, 23 May 2017.

me).²⁶⁶ Als Surrogat zur Direktbefragung des Sachverständigen wird dabei die Anordnung eines Zweitgutachtens anerkannt.²⁶⁷ Für die Effektivität der Stellungnahme hat sodann die Möglichkeit grosse Bedeutung, Privatsachverständige in das Verfahren einzubringen; sei es durch deren Schriftsatz oder die mündliche Aussage des Privatsachverständigen vor Gericht.²⁶⁸ Dabei wird berücksichtigt, ob Stellungnahmen von allfälligen Privatsachverständigen in der richterlichen Beweiswürdigung dasselbe Gewicht erfahren und ob der Privatsachverständige bei seiner Tätigkeit im Vergleich zum amtlichen Sachverständigen benachteiligt wurde.²⁶⁹

3. Gesamtwürdigungsansatz

105 Sind Position und Rolle des Sachverständigen sowie die in einem konkreten Verfahren gewährten Verteidigungsrechte eruiert, nimmt der EGMR in einem weiteren Schritt eine Gesamtwürdigung der Verfahrensfairness vor, deren Massstab immer die effektive Überprüfbarkeit des Sachverständigenbeweises ist.²⁷⁰ Im Rahmen der Gesamtwürdigung ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen: Bei hoher Relevanz des Sachverständigenbeweises und/oder allfälligen Neutralitätsdefiziten des Sachverständigen sind strengere Anforderungen an die Ausgestaltung der Verteidigungsrechte zu stellen.²⁷¹ Umgekehrt

²⁶⁶ EGMR, *Constantinides v. Greece*, no. 76438/12, § 38, 6 October 2016; EGMR, *Devinar v. Slovenia*, no. 28621/15, § 56, 22 May 2018; EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 176 ff., 27 March 2014; EGMR, *Mirilashvili v. Russia*, no. 6293/04, § 190, 11 December 2008; EGMR, *C.B. v. Austria*, no. 30465/06, § 40 ff., 4 April 2013; EGMR, *Duško Ivanovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 10718/05, § 57, 24 April 2014; EGMR, *Avagyan v. Armenia*, /no. 1837/10, § 43, 22 November 2018.

²⁶⁷ EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 182, 27 March 2014.

²⁶⁸ EGMR, *Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia*, nos. 11082/06 and 13772/05, § 731, 25 July 2013; EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 193 ff., 27 March 2014; EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 128, 1 June 2017; EGMR, *C.B. v. Austria*, no. 30465/06, § 44, 4 April 2013; EGMR, *Duško Ivanovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 10718/05, § 57, 24 April 2014.

²⁶⁹ EGMR, *Sara Lind Eggertsdóttir v. Iceland*, no. 31930/04, § 49, 5 July 2007; EGMR, *Shulepova v. Russia*, no. 34449/03, § 68, 11 December 2008; EGMR, *Bönisch v. Austria*, 6 May 1985, § 33 ff., Series A no. 92; EGMR, *Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia*, nos. 11082/06 and 13772/05, § 735, 25 July 2013.

²⁷⁰ CHAMPOD/VUILLE, S. 23; DECAIGNY, S. 157; SETTEM, S. 128; VAN KAMPEN, S. 186.

²⁷¹ EGMR, *Constantinides v. Greece*, no. 76438/12, § 39, 6 October 2016; EGMR, illustrativ auch: EGMR, *Avagyan v. Armenia*, /no. 1837/10, § 40, 22 November 2018 (Sachverständigenbeweis als entscheidendes Beweismittel, darum war Möglichkeit der Befragung vor Gericht obligatorisch).

dürfen gemässigte Massstäbe ihren Platz finden, wenn die sachverständige Stellungnahme keine dominante Rolle im Verfahren beanspruchte, etwa weil er einer von vielen im Verfahren tätigen Sachverständigen war oder das gerichtliche Urteil auch auf andere Beweise gestützt wurde.²⁷² Weiter ist dem Parteiverhalten Rechnung zu tragen. Für die Analyse der Verfahrensfairness ist von Bedeutung, ob sich eine Partei tatsächlich der ihr zustehenden Verteidigungsmöglichkeiten bedient hat.²⁷³ Dieser Gesichtspunkt rechtfertigt sich dadurch, dass es einem Staat kaum als Verletzung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen vorgeworfen werden kann, wenn das mit Rechten ausgestattete Individuum die ihm zur Verfügung stehenden Verteidigungsmittel in selbstverschuldeter Weise nicht ausschöpft. Im Rahmen der Gesamtwürdigung ist zu bedenken, dass aus einzelnen prozessualen Defiziten nie automatisch die Annahme folgt, die Verfahrensfairness sei verletzt worden. Vielmehr erweist sich die Gesamtwürdigung als dynamisches Kompensationsmodell, in welchem zu prüfen ist, ob allfällige Defizite durch andere Faktoren ausgeglichen werden, wie nachfolgend illustriert wird.

A) Manifestation des Gesamtwürdigungsansatzes im Neutralitätskontext

Blosse Zweifel an der Neutralität des Sachverständigen sind für sich genommen noch nicht geeignet, eine Konventionsverletzung zu begründen. Entscheidend sind einzig objektiv gerechtfertigte Neutralitätszweifel.²⁷⁴ Ob solche vorliegen, beurteilt sich in einer Gesamtwürdigung. In dieser wird beispielsweise berücksichtigt, ob der Sachverständige im Auftrag der Strafbehörden oder auf eigene Initiative Ermittlungshandlungen vornimmt, ob vom Sachverständigen ein Eid abgelegt wird, ob die Parteien eine allfällige Befangenheit des Sachverständigen

²⁷² EGMR, *Mirilashvili v. Russia*, no. 6293/04, § 179, 11 December 2008; EGMR, *Eskelinen and Others v. Finland*, no. 43803/98, § 34, 8 August 2006; EGMR, *Laryagin and Aristov v. Russia*, nos. 38697/02 and 14711/03, § 43, 8 January 2009.

²⁷³ Damit eine Verletzung der Verfahrensfairness angenommen werden kann, muss die berechnigte Partei von den ihr zur Verfügung stehenden Verteidigungsmitteln Gebrauch gemacht haben: vgl. EGMR, *Laryagin and Aristov v. Russia*, nos. 38697/02 and 14711/03, § 43 f., 8 January 2009; EGMR, *Klimentyev v. Russia*, no. 46503/99, § 97, 16 November 2006; EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 124, 1 June 2017.

²⁷⁴ EGMR, *Bönisch v. Austria*, 6 May 1985, § 33, Series A no. 92; EGMR, *Brandstetter v. Austria*, 28 August 1991, § 44 f., Series A no. 211; EGMR, *Sara Lind Eggeertsdóttir v. Iceland*, no. 31930/04, § 47 ff., 5 July 2007; EGMR, *Shulepova v. Russia*, no. 34449/03, § 65 ff., 11 December 2008; EGMR, *Krunoslava Zovko v. Croatia*, no. 56935/13, § 44, 23 May 2017; EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 119, 1 June 2017; EGMR, *Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 26711/07 and 2 others, § 98, 12 May 2016.

mit einem Befangenheitsantrag «angreifen» können, ob durch Weisungen des Auftraggebers auf die Sachverständigentätigkeit eingewirkt wird, ob Loyalitätskonflikte des Sachverständigen zum Auftraggeber oder zur zu beurteilenden Person bestehen (z.B. Arbeitgeber, Vorgesetzter, Arbeitskollegen), ob aus der Dokumentation Anhaltspunkte für einen Mangel an Objektivität seitens des Sachverständigen hervorgeht oder ob ökonomische Abhängigkeiten zur beauftragenden Behörde bestehen.²⁷⁵ Dabei ist es z.B. möglich, dass ein durch die staatsanwaltschaftliche Beauftragung erwachsender Neutralitätszweifel durch die sonstigen Rahmenbedingungen des Verfahrens (u.a. wirtschaftliche Unabhängigkeit des Sachverständigen von der Staatsanwaltschaft, Möglichkeit der Partei, den Ausstand des Sachverständigen zu verlangen, Beweisanspruchsrechte im Verfahren, Einsatz des Privatsachverständigen etc.) kompensiert wird.²⁷⁶

B) Manifestation des Gesamtwürdigungsansatzes im Kontext der Verteidigungsrechte

107 Auch auf der Ebene der Verteidigungsrechte ergeben sich durch die Gesamtwürdigungsmethode des EGMR keine generell-abstrakten Vorgaben für nationale Verfahrenssysteme. So gilt zwar das Einbringen von Privatgutachten als wichtige Schutzmassnahme; ein absolutes Recht darauf lässt sich der EMRK aber nicht entnehmen.²⁷⁷ Ebenso steht es über weite Strecken im Ermessen des nationalen Gerichts, ob es dem Antrag auf eine Zweitbegutachtung Folge leistet oder diesen mangels Notwendigkeit abweist.²⁷⁸ Sodann spielt der Gesichtspunkt der Akteneinsicht zwar eine grosse Rolle für eine effektive Verteidigung. Aus der EMRK fliesst aber kein generell-abstraktes Recht auf Akteneinsicht in sämtliche Beweise, welche die sachverständige Person in Erwägung gezogen hat; massgeblich ist die Effektivität der Beteiligung vor Gericht.²⁷⁹ Weiter begründet

²⁷⁵ EGMR, *Devinar v. Sloveenia*, no. 28621/15, § 51, 22 May 2018; EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 121 ff., 1 June 2017; EGMR, *Sara Lind Eggertsdóttir v. Iceland*, no. 31930/04, § 51 f., 5 July 2007; EGMR, *C.B. v. Austria*, no. 30465/06, § 42, 4 April 2013.

²⁷⁶ EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 122 ff.; EGMR, *Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 26711/07 and 2 others, § 94, 12 May 2016; DECAIGNY, S. 159; VAN KAMPEN, S. 200.

²⁷⁷ EGMR, *Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia*, nos. 11082/06 and 13772/05, § 731 f., 25 July 2013.

²⁷⁸ EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 183, 27 March 2014 wo ausgeführt wird, dass die Ablehnung eines solchen Begehrens nur in extremen und offensichtlichen Fällen zur Feststellung eines unfairen Verfahrens führt; EGMR, *Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 26711/07 and 2 others, § 95, 12 May 2016.

²⁷⁹ EGMR, *Cottin v. Belgium*, no. 48386/99, § 30, 2 June 2005; EGMR, *Mantovanelli v. France*, 18 March 1997, § 33, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; un-

eine Ungleichbehandlung zwischen dem gerichtlichen Sachverständigen und dem Privatsachverständigen (z.B. wird letzter nicht zur Aussage vor Gericht zugelassen) isoliert noch keine Verletzung der Verfahrensfairness, wenn ansonsten effektiv zum Sachverständigenbeweis Stellung genommen werden konnte.²⁸⁰ Gleichfalls stellt das persönliche Erscheinen des Sachverständigen vor Gericht zwecks Befragung ein wichtiges Fairnessinstrument dar, das aber durch andere Faktoren (mangelnde Notwendigkeit der Befragung) oder Verteidigungsrechte kompensiert werden kann.²⁸¹ Ferner gilt die Möglichkeit der Mitwirkung im Gutachtenserstellungsprozess zwar als wichtiger Schutzfaktor; die Nichtgewährleistung ist aber noch nicht mit einer Fairnessverletzung gleichbedeutend, solange das Gutachten nachträglich effektiv vor Gericht in Frage gestellt werden kann.²⁸²

Nach dem Gesagten wird es kaum überraschen, dass auch Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen keine unumstösslichen Bestandteile eines fairen Verfahrens im Kontext des Sachverständigenbeweises bilden. Zwar finden sich in der Praxis des EGMR Einzelfälle, in welchen ein Teilnahmerecht an sachverständigen Befragungen/Untersuchungen als Fairnessinstrument berücksichtigt wurde.²⁸³ Diese Urteile sind aber kaum verallgemeinerungsfähig, denn in ihnen betonte der EGMR, dass sich Art. 6 Ziff. 1 EMRK kein generell-abstraktes Prinzip entnehmen lässt, wonach die Parteien und/oder ihre Rechtsbeistände bei einem gerichtlichen Sachverständigen immer die Möglichkeit haben müssen, an

glücklich der Zitierfehler in EGMR, *Letinčić v. Croatia*, no. 7183/11, § 50, 3 May 2016, welcher in EGMR, *Devinar v. Sloveenia*, no. 28621/15, § 51, 22 May 2018 weiter portiert wurde. Dabei rekurriert der EGMR zwar noch immer auf *Mantovaneli*, kehrt aber die dort enthaltene Aussage mangels korrekter Zitierung um 180 Grad. Vgl. auch ESSER, S. 703.

²⁸⁰ EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 193, 27 March 2014; EGMR, *C.B. v. Austria*, no. 30465/06, § 44 ff, 4 April 2013 (der EGMR verneinte hier eine Verletzung, da der amtliche Sachverständige zur Kritik des Privatsachverständigen Stellung bezog und sowohl der Beschwerdeführer als auch sein Anwalt Fragen an den amtlichen Sachverständigen richten konnten).

²⁸¹ EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 168, 27 March 2014 «In analysing whether the personal appearance of an expert at the trial was necessary, the Court will therefore be primarily guided by the principles enshrined in the concept of a «fair trial» under Article 6 § 1 of the Convention, and in particular by the guarantees of adversarial proceedings and equality of arms»; EGMR, *Mirilashvili v. Russia*, no. 6293/04, § 190, 11 December 2008; EGMR, *Borodin v. Russia*, no. 41867/04, § 160 f., 6 November 2012 (Konventionsverletzung verneint, da der Beschwerdeführer Fragen an den Sachverständigen richten und Anträge auf weitere Abklärungen stellen konnte und das Gericht das Gutachten anschliessend streng prüfte); EGMR, *Constantinides v. Greece*, no. 76438/12, § 39, 6 October 2016 (Kompensation primär über Möglichkeit des Privatgutachtens).

²⁸² EGMR, *Matytsina v. Russia*, no. 58428/10, § 175, 27 March 2014.

²⁸³ Vgl. N 104.

den von ihm durchgeführten Befragungen teilzunehmen; ausschlaggebend ist einzig, dass die Parteien vor Gericht effektiv partizipieren können.²⁸⁴ Ob und unter welchen Bedingungen Teilnahmerechte der Parteien und ihrer Rechtsbeistände an sachverständigen Erhebungen aus der EMRK fließen, ist daher auch im einschlägigen Schrifttum umstritten.²⁸⁵

4. Fazit

- 109 Ruft man sich die Gesamtwürdigungsmechanik vor Augen, ist es nicht sinnvoll, aus einzelnen Urteilen generell-abstrakte Prinzipien ableiten zu wollen. Aufgrund des konventionsrechtlichen Ziels, im Einzelfall einen effektiven Menschenrechtsschutz zu gewährleisten, ist einzig von Interesse, ob in einem konkreten Verfahren ein den Umständen angepasstes Mass an Verteidigungsrechten eingeräumt wurde.²⁸⁶ Was dabei fairnessrechtlich als angemessene Verteidigungsmöglichkeit bezeichnet werden kann, muss für jede Rechtsordnung gesondert und anhand der Prinzipien der Waffengleichheit und der Verhältnismässigkeit ermittelt werden.²⁸⁷ Je stärker die prozessuale Position und Rolle des Sachverständigen ist, desto besser wird das verfahrensrechtliche Schutzniveau bezüglich der Verteidigungsrechte der Parteien ausfallen müssen. Es wird Aufgabe der nachfolgenden Paragraphen sein, diese aus der EMRK fliessenden Fairnessparameter auf den schweizerischen Rechtskontext zu münzen und in Bezug zum Untersuchungsgegenstand zu setzen.

²⁸⁴ EGMR, Mantovanelli v. France, 18 March 1997, § 33, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; EGMR, Cottin v. Belgium, no. 48386/99, § 31, 2 June 2005; JACOBS, S. 217 f.; EMRK-Meyer-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER, Art. 6 N 154 f.; VAN KAMPEN, S. 198 und 200; BARBIER DE LA SERRE/SIBONY, S. 946 f.; SETTEM, S. 391; zu direkt daher MARQUES LOPES, N 25, welche mit Blick auf Mantovanelli v. France und Cottin v. Belgium davon ausgeht, dass die beschuldigte Person und ihre Verteidigung ein Teilnahmerecht bei sachverständigen Befragungen von Dritten haben.

²⁸⁵ JACOBS, S. 217 f.; EMRK-MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER, Art. 6 N 154 f.; PIQUEREZ/ MACALUSO, Procédure, N 1121 (Grundsatz: keine Teilnahmerechte; Ausnahme: Teilnahmerechte); a.M. wohl ESSER, S. 704 f. sowie Erb et al.-ESSER, Art. 6 EMRK N 824, der in der Praxis des EGMR keine Ansätze für ein Teilnahmerecht erkennen will; auch DECAIGNY, S. 162 betont, dass aus der EGMR-Praxis kein generelles Teilnahmerecht folge; FERRAND, S. 368.

²⁸⁶ LNR-MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KÖNIG, Art. 6 N 87.

²⁸⁷ Sehr treffend VAN KAMPEN, S. 186: «what is right and what is wrong in criminal proceedings cannot be judged in abstracto, but only within the context of the criminal proceedings at hand. Different circumstances, after all, may dictate different actions.»

§ 6 Position und Rolle des PSY-Sachverständigen

Gemäss den in § 5 erläuterten Prüfungssequenzen des EGMR ist in einem ersten Schritt zu prüfen, welche Position und Rolle dem PSY-Sachverständigen im schweizerischen Strafprozess bei der Schuldfähigkeits- sowie der Massnahmenbegutachtung zukommt. Dieser Analyseschritt wird das Fundament bilden, um in § 7 das bestehende Modell der im schweizerischen Strafverfahren bestehenden Verteidigungsrechte auf die konventionsrechtlich geforderte Effektivität hin zu überprüfen. 110

I. Relevanz des Sachverständigenbeweises

Normalerweise liegt für die Begutachtung der Schuldfähigkeit und oder die Begutachtung der Massnahmenindikation ein einziges Gutachten vor.²⁸⁸ Daraus ergibt sich ein erstes Indiz für die Relevanz des Sachverständigenbeweises. Wichtiger als die quantitative Betrachtung ist jedoch die materielle Relevanzprüfung: Es wäre denkbar, dass die Strafbehörden den rechtsrelevanten Sachverhalt im Rahmen des Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachten weitgehend selbständig abklären und würdigen. In diesem Fall wäre die Relevanz des Sachverständigenbeweises klein. Die Ausgangsbedingungen liegen jedoch umgekehrt. Die nachfolgende Analyse wird zeigen, dass das schweizerische Strafprozessrecht im Rahmen des Sachverständigenbeweises von zahlreichen Kontrasten zwischen normativen Leitbildern und Faktenlage charakterisiert ist.²⁸⁹ Diese ziehen sich wie ein roter Faden durch sämtliche strafprozessualen Austauschbeziehungen zwischen Strafbehörden und Sachverständigem (Beweiserhebung, Beweiswürdigung und sogar Rechtsanwendung). Resultat ist eine substantielle Verantwortungsverschiebung von den Strafbehörden auf den PSY-Sachverständigen. 111

²⁸⁸ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2014, S. 77; BERNHARD, Jusletter 13. Februar 2012, N 4.

²⁸⁹ Dazu auch WOHLERS, ZStrR 2018, S. 434 mit der treffenden Formulierung «...dass die prozessuale Realität des Sachverständigenbeweises (das Law in Action) und der dogmatische Überbau (das Law in the Books) nichts miteinander zu tun haben».

1. Dimension der Sachverhaltsermittlung

A) Leitbild: Ermittlungsverbot

- 112 Wie bereits im Themenaufriß geschildert wurde, bildet der Untersuchungsgrundsatz mit der korrespondierenden Maxime der materiellen Wahrheit einen ersten Baustein der strafbehördlichen Wahrheitsrekonstruktion.²⁹⁰ Art. 6 Abs. 1 StPO lautet: «Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab». Aus dieser gesetzlichen Zuständigkeitsordnung folgt, dass die sachverständige Person grundsätzlich keine eigenen Ermittlungen durchführen bzw. keine eigenen Beweiserhebungen tätigen darf: Es gilt für den Sachverständigen der Grundsatz des Ermittlungsverbots.²⁹¹ Die Aufgabe der Sachverhaltsermittlung kommt in erster Linie den Strafbehörden zu. Folglich ist es Aufgabe der Verfahrensleitung, der sachverständigen Person die notwendige Tatsachenbasis (Anknüpfungstatsachen) vorzugeben.²⁹² Das normative Konzept lautet: Der Sachverständige hat den Sachverhalt so zu beurteilen, wie er von den Strafbehörden vorgegeben wird.²⁹³

B) Fakt: Teildelegation der Ermittlung

- 113 Der Grundsatz des Ermittlungsverbots wird im Rahmen der psychiatrischen Begutachtung stark relativiert. Zwar bleibt die Primär-Ermittlungszuständigkeit unbestritten bei den Strafbehörden. Sie tätigen Ermittlungen zur Tat und Person und übergeben diese in Form der Akten an die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 4 StPO). Diese Akten bilden elementare Bestandteile des gutachterlichen Beurteilungsfundaments. Für die Beurteilung der an den Sachverständigen gestellten Fragen zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation reichen sie aber nur im Ausnahmefall aus.

²⁹⁰ Vgl. N 3.

²⁹¹ Botschaft StPO, S. 1212; ZK StPO-DONATSCH, Art. 185 N 11; BSK StPO-I-HEER, Art. 185 N 19; HEER, Gutachten, S. 103; HEER, FS Wiprächtiger, S. 186; JEANNERET/KUHN, N 13011; CR CPP-VUILLE, Art. 185 N 4; TONDORF/TONDORF, N 282; illustrativ: BGer, 28. Januar 2015, 6B_648/2014, E. 5.2 «Zudem ist daran zu erinnern, dass dem Gutachter nicht die Ermittlung des Sachverhalts...oblag»; SCHMID, AJP 2010 S. 827 f.

²⁹² BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 29; ZK StPO-DONATSCH, Art. 184 N 43; DONATSCH/SCHWARZEN-EGGER/WOHLERS, S. 165; BSK StPO-I-HEER, Art. 184 N 5; HEER, Gutachten, S. 103; HELFENSTEIN, S. 173 ff.; MAIER/MÖLLER, S. 128; WOHLERS, Fremdanamnese, S. 78.

²⁹³ BSK StPO-I-HEER, Art. 185 N 19; RIKLIN, Art. 185 N 3; SCHMID/JOSITSCH, PraxKomm, Art. 182 N 1; BGer, 17. April 2019, 6B_1186/2018, E. 3.2.

Im Regelfall werden fachspezifische Erhebungen des PSY-Sachverständigen notwendig.²⁹⁴ Gerade auch wegen dieses bei psychiatrischen Begutachtungen spezifischen Bedürfnisses hat der Gesetzgeber das Prinzip des Ermittlungsverbots durchbrochen.²⁹⁵ Resultat ist die Erhebungskompetenz der sachverständigen Person nach Art. 185 Abs. 4 StPO, welche auch das psychiatrische Explorationsgespräch erfasst.²⁹⁶ Darin erhebt die sachverständige Person für die Beurteilung der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation das Vorleben des Exploranden (Anamnese), seinen psychischen Ist-Zustand (psychischer Befund), seine Persönlichkeit, Aspekte des Tatsachverhalts sowie die Perspektiven des Exploranden (Zukunft).²⁹⁷ Zwar wird von verschiedenen Autoren darauf hingewiesen, dass Art. 185 Abs. 4 StPO nicht die umfassende Abklärung des Sachverhalts, sondern nur sog. einfache (fachspezifische) Erhebungen erlaube, welche für die Erfüllung des Gutachtensauftrags notwendig sind.²⁹⁸ Ähnlich lauten die Leitlinien der Gerichtspraxis.²⁹⁹ Diese «Limitation» entfaltet indes bei der Begutachtung der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation kaum eine Wirkung, da für den psychiatrischen Sachverständigen wie soeben geschildert sowohl das Vorleben des Exploranden, sein Explorationsverhalten, seine Zukunft als auch seine aktuelle Tat im konkreten Strafverfahren für die Begutachtung von potentieller Relevanz sind.³⁰⁰

²⁹⁴ Vgl. N 8 ff.

²⁹⁵ Botschaft StPO, S. 1212; JEANNERET/KUHN, N 13011; RIKLIN, Art. 185 N 3 f.; treffend auch RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1327, welche in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die absolute Formulierung bezüglich des Ermittlungsverbots in direktem Widerspruch zu Art. 182 StPO stehe (Mangelnde Sachkunde der Verfahrensleitung bzgl. Sachverhaltserhebung und -beurteilung); SCHMID, AJP 2010, S. 828; CR CPP-VUILLE, Art. 185 N 4.

²⁹⁶ Botschaft StPO, S. 1212; DONATSCH, fp 2019, S. 137; JEANNERET/KUHN, N 13001.

²⁹⁷ Vgl. N 12 ff.

²⁹⁸ GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, S. 178; ähnlich SCHMID, AJP 2010, S. 828.

²⁹⁹ BGE 144 I 253, E. 3.7 «Die sachverständige Person nimmt ausschliesslich fachspezifische Erhebungen vor, «die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen» (Art. 185 Abs. 4 StPO). Eine eigene Befragung des Beschuldigten durch die sachverständige Person ist somit eng gutachtensorientiert.»; BGer, 18. Februar 2019, 1B_409/2018, E. 4.3: «Die sachverständige Person nimmt ausschliesslich fachspezifische (einfache) Erhebungen vor, die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen (Art. 185 Abs. 4 StPO). Über die Abklärung solcher fachspezifischer Fragen hinaus bleibt die Sachverhaltsermittlung Aufgabe der untersuchungsleitenden Staatsanwaltschaft».

³⁰⁰ Vgl. N 12 ff.; BRUNNER, Beratung, S. 138; HEER/COVACI, S. 445 f.; HELFENSTEIN, S. 96; MAIER/MÖLLER, S. 166; für die ähnliche Problematik im Kontext ausgaspsychologischer Begutachtungen HEER, Gutachten, S. 105 «Ob allerdings eine solche Trennung zwischen der Erhebung eigener Befunde und unzulässiger Ermittlung des Sachverhaltes in der Praxis regelmässig klar vorgenommen wird oder durchführbar ist, erscheint fraglich»; kaum hilfreich daher der Hinweis von

115 Ist aber ein solcher Gutachtenszusammenhang vorhanden, ist der Sachverständige unter Art. 185 Abs. 4 StPO nicht nur legitimiert, nach diesen Gesichtspunkten für sein Gutachten zu fragen, sondern er muss (Art. 307 StGB) diese Inhalte in Erfahrung bringen und der Verfahrensleitung mitteilen. Die Verfahrensleitung darf diese Ermittlungen im Anschluss beweisrechtlich verwerten.³⁰¹ Daraus folgt: Im Explorationsgespräch findet eine vom Sachverständigen gesteuerte, strafbehördenvertretende (bzw. von dieser delegierte) Sachverhaltsermittlung statt.³⁰² Anstelle vom Ermittlungsverbot des Sachverständigen wäre es treffender, von einer zweigeteilten und einander ergänzenden Ermittlungstätigkeit von Strafbehörde und Sachverständigem zu sprechen. Eine Seite des Gutachtensachverhalts erhebt die Staatsanwaltschaft und übermittelt sie an die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 4 StPO; allenfalls auf Antrag der sachverständigen Person nach Art. 185 Abs. 3 StPO). Die andere Seite des Sachverhalts beschafft sich der psychiatrische Sachverständige im Rahmen von Art. 185 Abs. 4 StPO selbständig. Es ist vor diesem Hintergrund nicht falsch, den PSY-Sachverständigen als (partiellen) «Staatsanwalt in Weiss» zu bezeichnen.³⁰³

2. Dimension der Beweiswürdigung

A) Leitbild: Gehilfe des Gerichts

116 Nach den voranstehenden Ausführungen ist die Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsfrage durch die Arbeit des Sachverständigen mitgeprägt. Dies wäre nicht weiter problematisch, wenn das Gericht in der Lage wäre, das durch den Sachverständigen erhobene Tatsachenfundament selbständig zu würdigen. In diesem Fall wäre die Relevanz des Sachverständigenbeweises limitiert. Allerdings besteht auch auf der Ebene der Beweiswürdigung ein Spannungsverhältnis zwischen normativem Anspruch und der Faktenlage.

117 Nach gängiger Definition ist der Sachverständige Gehilfe bzw. Entscheidungsgehilfe des Gerichts, «dessen Wissen und Erfahrungen er durch besondere Kenntnisse auf seinem Sachgebiet ergänzt».³⁰⁴ Es besteht juristisch eine klare

SCHMID, AJP 2010, S. 828 f., der bei Befragungen zum Tatsachverhalt zu grösster Zurückhaltung mahnt.

³⁰¹ Dazu ausführlich: N 310 ff.

³⁰² BRUNNER, Aspekte, S. 188; BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 37; HEER, LA Niggli, S. 114; HUBER, S. 68; OBERHOLZER, Begutachtung, S. 52.

³⁰³ BRUNNER, Aspekte, S. 190; BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 37; HUBER, S. 378; ähnlich OBERHOLZER, Begutachtung, S. 52, welcher den Sachverständigen in dieser Tätigkeit als Kriminalisten bezeichnet.

³⁰⁴ BGE 141 IV 369, E. 6.2; BGE 127 I 73 E. 3f/bb; BGE 118 Ia 144 E. 1c; BÜHLER, S. 567; DETTER, S. 57, wobei dieser Autor auf zahlreiche ähnlich gelager-

Rollenzuteilung: Die Beweiswürdigung ist Sache des Gerichts und darf nicht auf den Sachverständigen übertragen werden.³⁰⁵ Der Sachverständigenbeweis ist entsprechend wie jedes andere Beweismittel frei zu würdigen.³⁰⁶ Dabei hat das Gericht «das Gutachten nach fachwissenschaftlichen Kriterien zu verstehen und zu prüfen».³⁰⁷ In diesem Rahmen ist das Gutachten auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit, Schlüssigkeit sowie die Einhaltung der wissenschaftlich anerkannten Standards zu überprüfen.³⁰⁸ Mit dieser Dogmatik zur Würdigung eines Gutachtens wird der Konzeption des Sachverständigen als *iudex facti* (Richter des Faktums) auf normativer Ebene eine Absage erteilt.³⁰⁹ Dieses Leitbild ist vor dem verfassungsrechtlichen Hintergrund unumgänglich: Wenn der sachverständigen Person ohne gesetzliche Richterstellung die Rolle als *iudex facti* zugewiesen und seine Feststellungen als das Gericht vorbehaltlos bindend bezeichnet würden, wäre dies mit dem Anspruch auf den gesetzlichen Richter nach Art. 6 EMRK (vgl. auch 30 Abs. 1 Satz 2 BV) nicht zu vereinbaren.³¹⁰

B) Fakt: Teildelegation der Beweiswürdigung

Das Leitbild der freien richterlichen Beweiswürdigung beim Sachverständigenbeweis mag angesichts des Anspruchs auf den gesetzlichen Richter sowie vor dem historischen Hintergrund³¹¹ erklärbar sein. Formal bleibt unbestritten das Gericht Entscheidungsträger.³¹² Der psychiatrische Sachverständige verlagert aber faktisch die Beweiswürdigung für die ihm unterbreiteten Gutachtensfragen über weite Strecken in seinen Wirkungsbereich.³¹³ Das Gericht weist nur be-

118

te Definitionen (z.B. «selbständiger Helfer bei der Wahrheitsfindung» oder «Bera-ter des Gerichts») hinweist; DONATSCH, Jusletter 14.Mai 2007, N 8; HABERMEYER/SACHS, N 22; PITTELOU, N 414; SCHMID, Diss., S. 438; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 438.

³⁰⁵ BGer, 20. September 2012, 6B_294/2012, E. 2.1.2; BGer, 24. September 2018, 6B_276/2018, E. 1.1.4 «Ce n'est...pas le rôle de l'expert, mais bien celui du juge d'établir les faits.»; DETTER, S. 59 f.; HABERMEYER/SACHS, N 2.

³⁰⁶ BGE 142 IV 49, E. 2.1.3; BOVEY, S. 96; DONATSCH, Jusletter 14.Mai 2007, N 9; TOEPEL, S. 213; VUILLE, N 29.

³⁰⁷ BGer, 4. Dezember 2015, 6B_424/2015, E. 2.3; BGer, 12. Dezember 2018, 6B_257/2018, 6B_270/2018, E. 7.4.2.

³⁰⁸ Eingehend WOHLERS, ZStrR 2018, S. 445 f. und die von ihm zitierte Rechtsprechung; sodann ANTOGNINI, N 10; BINDER, S. 191 ff.; DONATSCH, Jusletter 14. Mai 2007, N 44 ff.; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 343 f.

³⁰⁹ ERB, S. 885 ff.; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 439 ff.

³¹⁰ Zu den analog gefassten Verfassungsgarantien: ARENS, S. 274 f.; BERNHEIM, S. 52; BOEHME-NESSLER, S. 193 ff.; DIPPEL, Diss., S. 30; SCHNOOR, S. 65; SCHREIBER, S. 1008; TOEPEL, S. 262; implizit auch KRAUSS, ZStW 1973, S. 335.

³¹¹ Eingehend zur historischen Entwicklung: WOHLERS, ZStrR 2018, S. 439 ff.

³¹² BERNHARD, Massnahmenrecht, S. 144.

³¹³ KRAUSS, ZStW 1973, S. 332; BERNHARD, Massnahmenrecht, 144.

dingt psychiatrische Kenntnisse auf, was die Relevanz des Sachverständigenbeweises erhöht.³¹⁴

a) *Beweiswürdigung als rationalitätsgebundener Vorgang*

- 119 Das Prinzip der freien Beweiswürdigung und die damit verbundene Abkehr von formalen Beweisregeln haben zum Ziel, der materiellen Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen.³¹⁵ Dabei ist die Wahrheitssuche von zwei Komponenten getragen: der subjektiven Überzeugung des urteilenden Gerichts, dass eine Tatsache vorliegt, und der intersubjektiv nachvollziehbaren Begründung dieser inneren Überzeugung.³¹⁶ Beim ersten (subjektiven) Element handelt es sich um den personalen/autoritativen Bestandteil der Beweiswürdigung, während die intersubjektiv nachvollziehbare Darlegung nur unter Bezugnahme auf objektive Wissenssätze erfolgen kann.³¹⁷ Gerade mit Blick auf die objektive Komponente der Beweiswürdigung zeigt sich, dass die «freie» Beweiswürdigung keineswegs eine willkürliche oder auf unsachliche Glaubenssätze gestützte Tatsachenfeststellung gestattet.³¹⁸ Vielmehr ist das Gericht an «Denk-, Natur- und Erfahrungssätze sowie wissenschaftliche Erkenntnisse gebunden».³¹⁹ Die auf Eruiierung der materiellen Wahrheit ausgerichtete «freie» Beweiswürdigung ist daher nicht frei im engeren Sinne, sondern ein rationalitätsgebundener Vorgang, der sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse auszurichten hat.³²⁰

³¹⁴ Zu diesem Aspekt des EGMR-Prüfungsmodells: N 101.

³¹⁵ CHAMPOD/VUILLE, S. 46; BSK StPO-I-TOPHINKE/HOFER, Art. 10 N 42 und N 54 ff.

³¹⁶ BSK StPO-I-TOPHINKE/HOFER, Art. 10 N 54 ff.

³¹⁷ ALBRECHT, NStZ 1983, S. 488; ANTOGNINI, N 31 ff.

³¹⁸ ALBRECHT, NStZ 1983, S. 488.

³¹⁹ BGE 144 IV 345, E. 2.2.3.1.

³²⁰ WOHLERS, ZStr 2018, S. 442 f., der in diesem Zusammenhang zurecht betont, dass die Beweiswürdigung nicht so frei ist, wie man zunächst denken könnte; EICKER, S. 42 ff. merkt in diesem Kontext zurecht an, dass die Denk- und Erfahrungssätze der Wissenschaft keine Eingrenzung der freien Beweiswürdigung, sondern deren notwendige Voraussetzung darstellen; BSK StPO-I-TOPHINKE/HOFER, Art. 10 N 61; TOEPEL, S. 139 ff.; VUILLE, N 5; ungenau hier CHAMPOD/VUILLE, S. 46: «...courts are therefore free to make their own decisions, which means that they can base them on any relevant evidence and are not bound by the requirement of rationality...»; dabei soll nicht abgestritten werden, dass im Rahmen der Beweiswürdigung faktisch auch irrationale Aspekte auf die richterliche Überzeugungsbildung einwirken (dazu MELUNOVIC, S. 598 m.w.N.). Dogmatisch hat sich die Beweiswürdigung und die damit verbundene Überzeugungsbildung des Gerichts aber auf Rationalität auszurichten.

b) Sachverständigenbeweis als verkörperte Rationalität

Wird man sich der Rationalitätsbindung der richterlichen Beweiswürdigung bewusst und ruft man sich die Natur des Sachverständigenbeweises – Einbringen von Fachwissen zwecks Sachaufklärung – ins Bewusstsein, ergibt sich die folgende Erkenntnis: Der Sachverständigenbeweis stellt im Rahmen des ihm vorgegebenen Beweisthemas (in casu: Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation) eine der richterlichen Beweiswürdigung vorgeschaltete Beweiswürdigung dar.³²¹ Diese ist ebenfalls von der subjektiven Überzeugung des Sachverständigen getragen, durch die Bezüge zu den objektiven Erfahrungssätzen der Psychiatrie, Psychologie und Kriminologie rationalitätsorientiert und damit intersubjektiv nachvollziehbar gemacht. Dabei ist die sachverständige Würdigung gegenüber der richterlichen überlegen; sie verkörpert höherrangige Rationalität. Diese Tatsache muss Auswirkungen auf die richterliche Beweiswürdigung zeitigen.

c) Grundsätzliche Bindung des Gerichts durch den Sachverständigenbeweis in Fachfragen

Die Rationalitätsüberlegenheit des Sachverständigen führt zum Grundsatz, dass das Gericht bei Fachfragen durch den (mangelfreien) Sachverständigenbeweis gebunden wird.³²² Dieser Grundsatz beschlägt sämtliche Tatsachen, welche die sachverständige Person aufgrund ihrer besonderen Sachkunde erhoben oder beurteilt hat (Befundtatsachen); hier ist das Gericht «ungeachtet der freien Beweiswürdigung (Art. 10 Abs. 2 StPO) – grundsätzlich gehalten, der Expertise zu folgen.»³²³ Das Gericht darf vom Gutachten nur abweichen, wenn triftige Gründe die Beweiskraft des Gutachtens erschüttern, wobei das Gericht sein Abweichen stichhaltig begründen muss.³²⁴

Die richterliche Beweiswürdigung ist beim Sachverständigenbeweis somit systemimmanent beschränkt. Konkret wird sich das Gericht bei seiner Überprüfung primär auf die leicht zugänglichen Aspekte fokussieren. So dürften etwa Logikfehler (Widersprüche im Gutachten), das Nichtbeantworten einer Gutachtensfrage, die Nichtbegründung von Schlussfolgerungen oder das gutachterliche Ab-

³²¹ HUBER, S. 68; TOEPEL, S. 170.

³²² BGE 143 IV 9, E. 3.4; vgl. auch BINDER, S. 190; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 442 ff.

³²³ So die etwas unpräzise Formulierung in BGer, 18. Dezember 2015, 6B_619/2015, E. 2.5.2. Bei Lichte betrachtet kann man aber kaum sagen, dass die Bindung «ungeachtet der freien Beweiswürdigung» erfolgt. Vielmehr ist die Bindung gerade notwendige Folge der rationalitätsorientierten Beweiswürdigung.

³²⁴ BGE 142 IV 49, E. 2.1.3 und E. 2.2; ARENS, S. 273; FONJALLAZ/GASSER, S. 160; VUILLE, N 8.

stellen auf falsche Sachverhaltsannahmen vom Gericht feststellbar sein.³²⁵ Selbiges gilt für formale Mängel eines Gutachtens (Gliederung, Sprache usw.), wobei darauf hinzuweisen ist, dass sich auch hinter formal einwandfreien Gutachten inhaltlich unhaltbare Beurteilungen verstecken können.³²⁶

- 123 Gerade die zentralen inhaltlichen Aspekte eines Gutachtens führen das Gericht jedoch an die Grenzen seiner Kompetenz: Es gibt schlicht keinen Mechanismus, der es einem (nicht psychiatrisch geschulten) Richter erlauben würde, die psychiatrischen Stellungnahmen umfassend auf ihre Verlässlichkeit hin zu überprüfen.³²⁷ Dies gilt zum einen für die sachkundige Beurteilung des Sachverhalts: Selbst wenn das Gericht detailliert anamnестische Informationen des Exploranden studieren würde, könnte es diese Unmenge an Information mangels Fachwissen kaum in eine wissenschaftlich sinnvolle Aussage (Diagnose, Behandelbarkeit usw.) transformieren und damit die sachverständige Stellungnahme überprüfen.³²⁸ Zum anderen ist auch die Herstellung des Tatsachenfundaments des Gutachtens durch die gutachterlichen Erhebungen für das Gericht nur sehr limitiert überprüfbar. Auch hier wirkt die Grenze des Fachwissens: Ob die (auch) explorationsgestützte gutachterliche Beschreibung des Exploranden im psychischen Befund oder die Vergabe von Punktwerten in einem Diagnose- oder Prognoseinstrument (PCL-R, HCR-20 usw.) vertretbar ist, wird das Gericht mangels Fachwissen nur in engen Grenzen überprüfen können.³²⁹ Die Überprüfbarkeit wird darüber hinaus durch die Tatsache erschwert, dass das Gericht im geltenden System des Sachverständigenbeweises keinerlei unmittelbare Einsicht in die für die sachverständige Beurteilung mitentscheidende Exploration besitzt, sondern den Explorationssachverhalt nur anhand der sachverständigen Angaben (Gutachten, Aussage des Sachverständigen vor Gericht) sowie allfällig abwei-

³²⁵ Stellvertretend für diese Mängelgruppe: BGer, 12. Dezember 2018, 6B_257/2018, 6B_270/2018, E. 7.4.2; zur Feststellbarkeit solcher Mängel durch das Gericht auch WOHLERS, ZStrR 2018, S. 446 f.

³²⁶ GRAF, Qualitätskriterien, 101, der in diesem Zusammenhang anmerkt, dass in der Praxis oft das Prinzip «form follows function» zur Anwendung gelange; die Auffassung, wonach formelle Qualität nicht inhaltliche Qualität bedeutet, ist nicht aus der Luft gegriffen wie etwa die Untersuchung zur Qualität von Schuldfähigkeitsgutachten von PRUETER-SCHWARTE/KUNERT, S. 127 ff. und KONRAD, R & P 2010, S. 30 ff. illustrieren.

³²⁷ DONATSCH, fp 2019, S. 138; GRAF, Qualitätskriterien, S. 100; HUBER, S. 235 ff.; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 446 f.

³²⁸ APPAZOV, S. 165; ähnlich ALBRECHT, NStZ 1983, S. 490 f.

³²⁹ So BGer, 19. Juni 2018, 6B_582/2017, E. 2.2.6 im Kontext der Risikobeurteilung: «...mangels eigener Sachkunde vermag der Rechtsanwender eine allenfalls unsachgemässe Punktvergabe kaum zu erkennen.»; HABERMAYER, Verwahrte, S. 199 f. zeigt anhand eines Verfahrens plastisch auf, dass eine richterliche Intervention in die Anwendung solcher Instrumente mangels Fachwissen geeignet ist, schiefzugehen.

chender Aussagen des Exploranden feststellen kann.³³⁰ Bei diesen intransparenten Ausgangsbedingungen ist das Gericht regelmässig darauf angewiesen, der gutachterlichen Beschreibung des Exploranden durch den Sachverständigen zu glauben; dies gilt i.d.R. selbst dann, wenn der Explorand angibt, dass die Exploration tatsächlich anders verlaufen sei, da dessen Schilderungen gegenüber dem nominal neutralen Sachverständigen regelmässig die geringere Beweiskraft zugemessen wird.³³¹

Der beschriebene Kontrollverlust des Gerichts ist in gewissem Masse die unvermeidbare Folge des Sachverständigenbeizugs.³³² Der Sachverständige wird ja genau deshalb mandatiert, weil es den Strafbehörden am notwendigen Wissen zur Sachverhaltsaufklärung fehlt.³³³ Folgerichtig kann das für die Beweismittel zur Sachverständigenbeweises zuständige Gericht nicht gehalten sein, das Beweismittel des Sachverständigenbeweises vollständig auf seine inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen, denn sonst müsste das Gericht ja dieselben Kenntnisse wie die sachverständige Person aufweisen, womit der Anlass zum Beizug eines Sachverständigen wieder wegfallen würde.³³⁴ 124

Inhaltlich bleibt daher nur eine gerichtliche Plausibilitätsprüfung möglich.³³⁵ 125 Damit werden sich bestenfalls deutliche bzw. offensichtliche inhaltliche Mängel herausfiltern lassen.³³⁶ Ansonsten dürften Gerichte aber kaum von gutachterlichen Stellungnahmen abweichen, da dieser Schritt stichhaltig zu begründen wäre, was eine hohe Messlatte darstellt.³³⁷ Dies gilt umso mehr, als dass die Begründungshürden für den gegenteiligen Fall – das Gericht findet das Gutach-

³³⁰ Vgl. N 176 ff.; mit derselben Beobachtung auch HUBER, S. 239.

³³¹ Dazu eingehend N 205 ff.

³³² APPAZOV, S. 165; ARENS, S. 272 f.; BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 36; DONATSCH, fp 2019, S. 138; TOEPEL, S. 350.

³³³ KassGer-ZH, 18. September 2006, AC050083, E. III.7.6.c; ANTOGNINI, N 24.

³³⁴ KassGer-ZH, 18. September 2006, AC050083, E. III.7.6.c; ARENS, S. 273; ANTOGNINI, N 24 f.; BINDER, S. 218 f.; ERB, S. 889; TOEPEL, S. 350; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 434.

³³⁵ BRUNNER, Verlässlichkeit, S. 305; BOEHME-NESSLER, S. 224 ff.; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 340; ERB, S. 890; HABERMEYER, Verwahrte, S. 199; HEER, Grundlage, S. 201; HUBER, S. 236; SCHMID, Diss., S. 536; CR CPP-VUILLE, Art. 182 N 8.

³³⁶ So auch das BGer, 12. Dezember 2018, 6B_257/2018, 6B_270/2018, E. 7.4.2 mit folgender Fallgruppe: «...sonstwie an Mängeln krankt, die derart offensichtlich und auch ohne spezielles Fachwissen erkennbar sind, dass sie das Gericht nicht hätte übersehen dürfen»; TOEPEL, S. 350; Wohlers, ZStrR 2018, S. 447 ff.

³³⁷ ARENS, S. 273; BARTON, Sachverständige, S. 62; BOVEY, S. 109 f.; CHAMPOD/VUILLE, S. 31 f; HABERMEYER, Verwahrte, S. 199; HEER, Grundlage, S. 200 f.; OBERHOLZER, Begutachtung, S. 54.

ten überzeugend – nicht besonders hoch angesetzt werden.³³⁸ Diese Überprüfungslimitationen versiegen auch dann nicht vollständig, wenn sich das Gericht – wie im Schrifttum zurecht gefordert³³⁹ – in zumutbarem Rahmen psychiatrisches und psychologisches Fachwissen aneignet.³⁴⁰ Es bleibt selbst dann ein nicht zu verkennendes Wissensgefälle zwischen Gericht und PSY-Sachverständigem.³⁴¹ Vor dem Hintergrund dieser Ausgangsvariablen wäre es wider die Realität, sich im Verhältnis zwischen Gericht und Sachverständigem auf die freie Beweiswürdigung in Reinform zu berufen.³⁴² Der «Gehilfe des Gerichts» ist in Tat und Wahrheit ein *iudex facti*, der die richterliche Beweiswürdigung über weite Strecken vorwegnimmt.³⁴³

3. Dimension der Rechtsanwendung

- 126 Die voranstehenden Auswirkungen des PSY-Sachverständigen auf die Ebene der Sachverhaltsermittlung und Beweiswürdigung bei der Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbegutachtung sind bei näherer Betrachtung wenig überraschend. Sie stellen die logische Folge des Sachverständigenbeizugs dar. Wenn es den Strafbehörden an den notwendigen Fachkenntnissen fehlt, den Sachverhalt zu erheben und zu beurteilen, und deswegen eine sachverständige Person beigezogen wird (Art. 182 StPO), wird die Herrschaft über die Sachverhaltsermittlung und -würdigung systemimmanent partiell aus der Hand gegeben. Genau umgekehrt fällt die Erwartungshaltung auf der Ebene der Rechtsanwendung aus. Hier gäbe es *prima vista* keinen Grund, den Sachverständigen als Einflussfaktor zu betrachten. Es wird sich indes zeigen, dass auch dieses Leitbild auf der Faktenebene Relativierungen erfährt.

³³⁸ DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 343; kritisch dazu ANTOGNINI, N 44.

³³⁹ ARENS, S. 276; DETTER, S. 61; EGG, S. 262; EICKER, S. 80; HEER, FS Wiprächtiger, S. 183 f.; WOHLERS, ZStR 2018, S. 459.

³⁴⁰ JACOBS/GUERRA, S. 950 f.; treffend die Formulierung von ALBRECHT, NStZ 1983, S. 490 f.: «Die Bestrebungen des BGH, die Selbständigkeit richterlicher Entscheidungen gegenüber Gutachtern zu betonen, überfordern den Tatrichter nicht selten.»

³⁴¹ HEER, FS Wiprächtiger, S. 185.

³⁴² BOVEY, S. 110 und 112 f.; HEER, Grundlage, S. 201; WOHLERS, ZStR 2018, S. 460.

³⁴³ ARENS, S. 275; BOVEY, S. 96; BINDER, S. 148 und 212; BERNHEIM, S. 60; BRUNNER, Verlässlichkeit, S. 305; DIPPEL, FS Müller, S. 144; DONATSCH, fp 2019, S. 138; FONJALLAZ/GASSER, S. 159 f.; HABERMEYER, Verwahrte, S. 199; HEER, Grundlage, S. 200; KRAUSS, ZStW 1973, S. 334 f.; PICHINI, S. 155 f.; WOHLERS, ZStR 2018, S. 448 f.; differenzierend ERB, S. 888; a.M. DETTER, S. 61.

A) Leitbild: *iura novit curia*

Grundsätzlich weisen der Sachverständigenbeweis und die Rechtsanwendung 127 keine Schnittmenge auf. Es gilt der Grundsatz «*iura novit curia*»: Der Richter kennt das Recht und wendet dieses von Amtes wegen an.³⁴⁴ Dieser juristische Fundamentalsatz spiegelt sich in Art. 350 Abs. 1 StPO: «Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden». Daraus folgt für den vorliegenden Kontext, dass ein Sachverständigenbeweis – den Sonderfall ausländischen Rechts vorbehalten – nur zu Sachverhalts-, nicht aber zu Rechtsfragen eingeholt werden darf.³⁴⁵ Ebenso gilt, dass sich Sachverständige in ihrem Gutachten nur zu Tat-, und nicht zu Rechtsfragen zu äussern haben.³⁴⁶

B) Fakt: Teileinfluss des PSY-Gutachtens

So klar die Kompetenzenverteilung zwischen Sachverständigem und Gericht auf 128 theoretischer Ebene ist, so schwierig ist sie in der Praxis einzuhalten.³⁴⁷ Das voranstehende Leitbild (*iura novit curia*) wird dadurch relativiert, dass Tat- und Rechtsfragen Überschneidungen aufweisen: Psychiatrische und juristische Fragestellungen lassen sich kaum sauber trennen.³⁴⁸ Zwar lässt sich der Auftrag des PSY-Sachverständigen so formulieren, dass ihm «die zentrale Aufgabe zukommt, die psychische Verfassung des Betroffenen als wesentliche tatsächliche Entscheidungsgrundlage abzuklären» und deren massnahmenrechtlichen bzw.

³⁴⁴ Donatsch/Schmid-DONATSCH, § 109 N 24; DONATSCH, Kriminalistik 1995, S. 514; HUBER, S. 9; vgl. dazu auch EGMR, Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, nos. 11082/06 and 13772/05, § 722, 25 July 2013.

³⁴⁵ BGE 142 IV 14, nicht publizierte E. 4.2; BGer, 4. Dezember 2014, 6B_612/2014, E. 1.4; BÜHLER, S. 573 f.; BINDER, S. 190; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, S. 166; DONATSCH, Kriminalistik 1995, S. 514; EGE., Diss., S. 324; JEANNERET/KUHN, N 13001; SCHMID/JOSITSCH, PraKomm, Art. 182 N 2; PIQUEREZ/MACALUSO, N 1110; CR CPP-VUILLE, Art. 182 N 8.

³⁴⁶ BGer, 28. Januar 2015, 6B_648/2014, E. 5.2: «Zudem ist daran zu erinnern, dass dem Gutachter nicht...dessen rechtliche Würdigung oblag.»; BOVEY, S. 97; DIPPEL, Diss., S. 139; DONATSCH, Kriminalistik 1995, S. 514; HEER, Grundlage, S. 205; HUBER, S. 179.

³⁴⁷ HABERMEYER, Verwahrte, S. 192 weist zurecht darauf hin, dass sich die Aufgabebereiche zwischen Psychiatrie und Recht verschränkt haben; Kröber et al.-I-RÖSSNER, S. 419.

³⁴⁸ BGer, 28. September 2017, 6B_319/2017, E. 1.1; BGer, 17. Juli 2015, 6B_1028/2014, E. 3.5; BGer, 22. Januar 2018, 6B_1348/2017, E. 1.3.3; BGer, 13. März 2018, 6B_1243/2017, E. 1.1; BGer, 23. November 2018, 6B_240/2018, E 2.3; ANTOGNINI, N 39; BOEHME-NESSLER, S. 195 f.; BOVEY, S. 97; BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 36; BÜHLER, S. 574; DONATSCH, Kriminalistik 1995, S. 514; EICKER, S. 82; SCHMID, Diss., S. 452.

schuldbezogenen Auswirkungen abzuschätzen.³⁴⁹ Kommt der Sachverständige dieser Aufgabe nach, kann er jedoch kaum sinnvoll normative Abstinenz üben, da er seine Beurteilung auf juristische Begrifflichkeiten hin vornimmt.³⁵⁰ Bei Schuldfähigkeits- und Massnahmengutachten tritt damit jenes Kriterium hervor, dass der EGMR bei der Konkretisierung der Relevanz des Sachverständigen berücksichtigt: Die vom Gericht zu beantwortende Frage überschneidet sich mit jener des Sachverständigen, womit dem Gutachten grösste Bedeutung für das gerichtliche Urteil zukommt.³⁵¹ Diese These gilt es sowohl für das Schuldfähigkeits- (a) als auch das Massnahmenindikationsgutachten (b) zu untermauern.

a) *Schuldfähigkeitsgutachten*

129 Auf normativer Ebene scheint die Differenzierung zwischen Tat- und Rechtsfrage im Kontext der Schuldfähigkeit klar: «Der Zustand, in welchem sich der Beschwerdeführer zur Zeit der Tat befand, ist eine Tatfrage. Rechtsfragen sind hingegen, ob die Vorinstanz von zutreffenden Begriffen der Schuldunfähigkeit und der verminderten Schuldfähigkeit ausging und ob sie diese richtig anwandte.»³⁵² In der Praxis zeigt sich jedoch, dass diese Beurteilungsebenen viel enger miteinander verwoben sind, als es die bundesgerichtliche Linienziehung vermuten lässt.³⁵³ So lauten die an den Sachverständigen gerichteten Fragen des KSBS/SGFP-Fragenkatalogs³⁵⁴ wie folgt:

- 1. Zur Frage nach einer psychischen Störung
 - Hat die psychiatrische Untersuchung ergeben, dass die beschuldigte Person zur Zeit der Tat(en) an einer psychischen Störung gelitten hat? Wenn ja, an welcher und welchen Ausmasses?
- 2. Zur Frage der Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 1 und 2 StGB)

³⁴⁹ BGer, 18. Dezember 2015, 6B_619/2015, E. 2.5.1; BGer, 22. Oktober 2015, 6B_708/2015, E. 3.3; BGer, 17. Juli 2015, 6B_1028/2014, E. 3.5; BGer, 23. November 2018, 6B_240/2018, E. 2.3.

³⁵⁰ TOEPEL, S. 132; DUBS, S. 341; vgl. auch BGer, 9. April 2018, 6B_1343/2017, E. 2.6: «Die Gutachter sind für ihre Prognose auf die juristische Auslegung oder Konkretisierung des Gesetzes angewiesen.»

³⁵¹ Zu diesem Kriterium im Prüfungsmodell des EGMR: N 101.

³⁵² BGE 107 IV 3 E. 1a; BGer, 26. November 2009, 6B_725/2009, E. 2; BGE 141 IV 34, nicht publizierte E. 2.2; DIPPEL; Diss., S. 142; SCHMID, Diss., S. 446.

³⁵³ Dazu auch NOLL, S. 73 f.

³⁵⁴ Der KSBS/SGFP-Fragenkatalog wird momentan überarbeitet (Stand: 30. Januar 2018). Da der Entwurf noch nicht publiziert wurde bzw. die finale Fassung der Fragen nicht vorliegt, können sie hier noch nicht zitiert werden. Soweit dem Autor bereits Einsicht in den Entwurf gewährt wurde, kann gesagt werden, dass sich an den nachfolgenden Ausführungen bzgl. Überschneidung von Tat- und Rechtsfragen nichts Wesentliches ändert.

- 2.1. War die beschuldigte Person zur Zeit der Tat(en) wegen dieser psychischen Störung nicht fähig zur Einsicht in das Unrecht der Tat(en) oder zum Handeln gemäss dieser Einsicht (Art. 19 Abs. 1 StGB)?
- 2.2. War die beschuldigte Person zur Zeit der Tat(en) wegen dieser psychischen Störung nur teilweise fähig – zur Einsicht in das Unrecht der Tat(en) oder – zum Handeln gemäss dieser Einsicht (Art. 19 Abs. 2 StGB)? Wenn ja, in welchem Grad (leicht, mittel, schwer) schätzen Sie die Verminderung der Schuldfähigkeit ein?

Während das Stellen einer Diagnose und deren Beschreibung bzgl. Ausmass (Frage 1) noch eindeutig als Tatfrage eingestuft werden kann, sind die Übergänge zwischen Tat- und Rechtsfrage auf der Ebene der Fragen zur Schuldfähigkeit (Frage 2.1 und 2.2) fließend.³⁵⁵ Zwar findet sich trotz dieser Ausgangslage die bundesgerichtliche Forderung, dass sich der Gutachter zur Rechtsfrage der Schuldunfähigkeit sowie der verminderten Schuldfähigkeit nicht zu äussern habe.³⁵⁶ Ein Blick auf die Faktenebene relativiert dieses Dogma aber erheblich: Die bundesgerichtliche Forderung zur normativen Abstinenz des Sachverständigen steht bereits im Widerspruch zur eigenen (!) Praxis, wonach sich der Sachverständige auch darüber zu äussern hat, ob die Schuldfähigkeit leicht, mittel oder schwer beeinträchtigt ist (dazu die Frage 2.2, Unterfrage 2 des voranstehend abgedruckten Fragenkatalogs).³⁵⁷ Doch selbst, wenn die sachverständige Person sich terminologisch jeglicher Stellungnahmen zur Schuldfähigkeit enthält: Bei der Bewertung bzw. Quantifizierung der tatzeitaktuellen Einschränkungen der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit (welche nach herrschender forensisch-psychiatrischer Lehre vorgenommen werden kann³⁵⁸) sind die sachverständige Tatsachenbeurteilung und die anschliessende normative Bewertung der Schuldfähigkeit (Rechtsfrage) durch das Gericht sehr eng verschränkt.³⁵⁹ Will der PSY-Sachverständige die Frage nach der Auswirkung einer Störung auf die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit adäquat beantworten, muss er die juristische

³⁵⁵ DIPPEL, Diss., S. 140 ff.; NOLL, 73 f.

³⁵⁶ BGer, 18. Oktober 2017, 6B_853/2016, E. 3.4; BGE 141 IV 34, nicht publizierte E. 2.2.; BGer, 23. August 2017, 6B_202/2017, E. 2.2.1.

³⁵⁷ BGE 106 IV 241, E. 1b; BGE 119 IV 120, E. 1a; BGer, 15. November 2006, 6S.383/2006, E. 2.1; kritisch dazu KIESEWETTER, ZStrR 2010, S. 329; PITTELOUD, N 417.

³⁵⁸ HABERMEYER/SASS, S. 11 f., welche darauf hinweisen, dass nach herrschender Ansicht durchaus eine fachlich begründete Aussage über das Ausmass der störungsbedingten Einschränkungen der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit gemacht werden kann, indem man die psychopathologischen Merkmale des Probanden im Tatzeitpunkt mit anderen Symptomkonstellationen definierter Krankheitsbilder vergleicht; KIESEWETTER, ZStrR 2010, 320 und 329; KONRAD/RASCH, S. 226 und 230; NOLL, 74; SASS/HABERMEYER, S. 160; eine Mindermeinung ist die sog. agnostische Position (keine fachbegründete Aussage über Steuerungsfähigkeit möglich), wie sie z.B. von EISENBERG, S. 305 aufgegriffen wird.

³⁵⁹ SASS/HABERMEYER, S. 160.

Konkretisierung dieser Begriffe beiziehen, deren höchstrichterliche Auslegung auch für die rechtsanwendenden Instanzen einschlägig ist.³⁶⁰ Eine klare Differenzierung zwischen Rechts- und Tatfrage kann vor diesem Hintergrund nicht mit letzter Konsequenz durchgehalten werden.³⁶¹ Folglich ist auch die Trennlinie zwischen gutachterlicher und richterlicher Kompetenz unscharf.³⁶²

- 131 Die juristischen Tangenten der gutachterlichen Beurteilung ändern nichts an der Exklusivzuständigkeit des Gerichts zur Rechtsanwendung.³⁶³ Entsprechend wird im forensisch-psychiatrischen Schrifttum zurecht betont, dass eine gutachterlich festgestellte Einbusse der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit sowie deren Quantifizierung nicht direkt auf den Rechtsbegriff der Schuldfähigkeit übertragen werden könne.³⁶⁴ Es ist dem Gericht daher beispielsweise unbenommen, in Auslegung von Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 StGB eine verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen, auch wenn die sachverständige Person bei ihrer Beurteilung von einer aufgehobenen Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit ausgeht.³⁶⁵
- 132 Trotz dieser gerichtlichen Autonomie lässt sich eine Suggestivwirkung der gutachterlichen Stellungnahme bzw. eine gewisse Weichenstellung für die Rechtsanwendung kaum in Abrede stellen.³⁶⁶ Im deutschen Rechtsraum konnte dargelegt werden, dass die Gerichte je nach Studie der gutachterlichen Empfehlung im Rahmen der Schuldfähigkeit zu 96%³⁶⁷, 95.1%³⁶⁸, 94.5%³⁶⁹, 93.7%³⁷⁰, 80 bzw. 95% (schriftliche v. mündliche Gutachtenserstattung)³⁷¹ sowie 91.9%³⁷² Folge leisten. In der Schweiz ermittelten FREI/GRAF/DITTMANN in 81.5% der von ihnen analysierten Verfahren (Gesamtzahl: 81) eine vollständige und im-

³⁶⁰ DUBS, S. 341; HABERMEYER/SACHS, N 4; KIESEWETTER, ZStrR 2010, 318, der auf die Pflicht des Sachverständigen hinweist, den juristischen Schuldbegriff zu rezipieren.

³⁶¹ DUBS, S. 341.

³⁶² NOLL, S. 73 f.

³⁶³ BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 34 HABERMEYER/SASS, S. 11; KONRAD/RASCH, S. 230; WOHLERS, Fragestellung, S. 113.

³⁶⁴ SACHS/HABERMEYER, S. 259.

³⁶⁵ BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 35; EGE, S. 339; SCHMID, Diss., S. 446.

³⁶⁶ KONRAD/RASCH, S. 230 «Es ist nicht zu übersehen, dass durch eine vom Sachverständigen quasi-wissenschaftlich ausgesprochene Empfehlung die Weiche in die eine oder andere Richtung gestellt wird»; EGG, S. 210; TOEPEL, S. 134.

³⁶⁷ HÖRNER/LIEBAU/FOERSTER, S. 398 f.

³⁶⁸ FEGERT ET AL., S. 84.

³⁶⁹ VERREL, S. 340.

³⁷⁰ SCHNOOR, S. 257.

³⁷¹ SCHMID/SCHOLZ, S. 421.

³⁷² SCHÖTTLE, S. 228.

merhin bei 13.6% eine mässige³⁷³ Übereinstimmung zwischen gutachterlicher Empfehlung und gerichtlichem Urteil.³⁷⁴ Die Studie von HACHTEL ET AL. ergab unterschiedliche Übereinstimmungsquoten: Einer in 63 Fällen gutachterlich festgestellten Minderung der Einsichtsfähigkeit folgte das Gericht nur zu 25.4%.³⁷⁵ Markant höher fielen die Werte bei der Beurteilung der praxisrelevanten Steuerungsfähigkeit aus. Hier folgte das Gericht den gutachterlichen Empfehlungen im Falle der verminderten Steuerungsfähigkeit (die in 261 Gutachten angenommen wurde) zu 72.4% (= 189 Fälle).³⁷⁶ Auch bei der kategorialen Einstufung der Beeinträchtigung (keine, leichte, mittlere oder schwere Verminderung bzw. aufgehobene Schuldfähigkeit) folgte das Gericht ganz überwiegend den gutachterlichen Empfehlungen.³⁷⁷ In einer Gesamtbetrachtung dieser Erhebungen lässt sich die Aussage formulieren, dass die gutachterliche Einschätzung der störungsbasierten Beeinträchtigung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit geeignet ist, die Rechtsfindung zur Schuldfrage mitzuprägen.³⁷⁸

b) Massnahmengutachten

Ähnlich verwoben sind Tat- und Rechtsfragen bei der Beurteilung der Massnahmenindikation. Zwar kann auch hier formell differenziert werden. So hat sich das Gutachten zu den Rechtsfragen der Verhältnismässigkeit³⁷⁹, der Gefährlichkeit³⁸⁰, der rechtlichen Relevanz einer psychischen Störung³⁸¹ oder zu den

133

³⁷³ Nach FREI/GRAF/DITTMANN, S. 139 bedeutet «mässig» einen Unterschied von einer Stufe wie z.B. eine leichte Beeinträchtigung der (altrechtlich) Zurechnungsfähigkeit aus psychiatrischer Sicht und eine mittlere aus richterlicher Sicht.

³⁷⁴ FREI/GRAF/DITTMANN, S. 138 f.

³⁷⁵ HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 4 f.

³⁷⁶ HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 4 f.

³⁷⁷ HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 5 «bei einer leichten Minderung der Zurechnungsfähigkeit im Gutachten in 73.6% der Fälle (n = 89), bei einer leichten bis mittleren Minderung der Zurechnungsfähigkeit im Gutachten in 77.6% (n = 38), bei einer mittleren Minderung in 69.8% (n = 44), bei einer mittel bis hohen Minderung in 61.5% (n = 8) und bei einer schweren Minderung in 71.4% (n = 10) Art. 11 aStGB angewandt und somit den Empfehlungen der Gutachter Folge geleistet.» Nur bei der aufgehobenen Schuldfähigkeit folgte das Gericht den gutachterlichen Empfehlungen nicht.

³⁷⁸ KONRAD/RASCH, S. 230; SCHÖTTLE, S. 256 mit dem treffenden Hinweis, dass die Rechtsrealität die Vorstellung einer Alleinentscheidungskompetenz des Richters stark relativiert; TOEPEL, S. 134.

³⁷⁹ BGer, 23. Januar 2018, 6B_28/2017, E. 3.3.3; HUBER, S. 100.

³⁸⁰ BGer, 17. November 2011, 6B_232/2011, E. 3.1.3; ebenso die qualifizierte Gefährlichkeit nach Art. 59 Abs. 3 StGB, vgl. BGer, 13. März 2018, 6B_1243/2017, E. 1.1; BGer, 28. September 2017, 6B_319/2017, E. 1.1; FONJALLAZ/GASSER, S. 146; vgl. auch HUBER, S. 99.

juristischen Voraussetzungen für den Strafaufschub zugunsten einer ambulanten Massnahme (Art. 63 Abs. 2 StGB)³⁸² auszuschweigen. Auf Tatsachenebene wird vom Sachverständigen aber verlangt, sich «über sämtliche tatsächliche Voraussetzungen der Massnahmen...äussern. Es muss sich zur Notwendigkeit und den Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters, Art und Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten und zu den Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme äussern (Art. 56 Abs. 3 StGB)».³⁸³ Dabei sind gemäss KSBS/SGFP-Fragenkatalog³⁸⁴ folgende Themenfelder zu erarbeiten:

- 1. Zur Frage nach einer psychischen Störung
 - Hat die psychiatrische Untersuchung ergeben, dass die beschuldigte Person zur Zeit der Tat(en) an einer psychischen Störung gelitten hat? Wenn ja, an welcher und welchen Ausmasses?
- (2. Fragen zur Schuldfähigkeit)
- 3. Zur Rückfallgefahr
 - 3.1. Besteht bei der beschuldigten Person die Gefahr, erneut Straftaten zu begehen?
 - 3.2. Welche Straftaten sind mit welcher Wahrscheinlichkeit zu erwarten?
 - 3.3. Sofern ein Delikt gemäss Art. 64 in Betracht kommt: Besteht die Gefahr erneuter solcher Straftaten auf Grund einer anhaltenden oder lang dauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, oder besteht die Gefahr auf Grund von Persönlichkeitsmerkmalen der beschuldigten Person, der Tatumstände oder seiner gesamten Lebensumstände?
- 4. Zu einer Massnahme (Art. 59-61 und 63 StGB)

³⁸¹ BGer, 14. Dezember 2018, 6B_1163/2018, E. 2.4.2: «Die Doktrin geht davon aus, dass der psychiatrische Sachverständige über einen ausreichenden Erfahrungshintergrund verfügt, um über Krankheitswert und Auswirkung einer psychischen Störung oder einer Persönlichkeitsstörung zu befinden, sodass die Gerichte in die Lage versetzt sind, über die rechtliche Relevanz der Störung zu entscheiden...Juristischer Natur ist die Frage der rechtlichen Relevanz der medizinischen Diagnose. Die Beurteilung, ob eine vom Sachverständigen diagnostizierte psychische Störung als schwer im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB zu qualifizieren ist, obliegt daher dem Gericht...»; BGer, 23. Januar 2018, 6B_28/2017, E. 3.4.

³⁸² BGer, 26. Mai 2016, 6B_57/2016, E. 1.5.

³⁸³ BGE 134 IV 315, E. 4.3.1; BGer, 23. Januar 2018, 6B_28/2017, E. 3.3.3 und 3.4; BGer, 17. November 2011, 6B_232/2011, E. 3.1.3; BGer, 12. Dezember 2018, 6B_257/2018, 6B_270/2018, E. 7.4.2, BGer, 6. Mai 2014, 6B_829/2013, E. 4.1; HEER, LA Niggli, S. 109: «Der psychiatrische Befund sowie die Indikation und die Art einer Behandlung, wie sie sich aus medizinischer Sicht ergeben, sind Probleme, die zweifelsfrei in die Zuständigkeit des Sachverständigen fallen.»; vgl. auch KSBS/SGFP-Fragenkatalog, S. 1 f.

³⁸⁴ Wie bereits bei der Schuldfähigkeit gilt es zu betonen, dass der Fragenkatalog momentan überarbeitet wird. Da noch keine finale Fassung vorliegt, kann der Inhalt dieses Katalogs noch nicht zitiert werden. Der dem Autor vorgelegte Entwurf (Stand: 30. Januar 2018) geht in Richtung einer grösseren Ausdifferenzierung der jeweiligen Fragen. Auch mit ihm wird sich jedoch – nach der hier vertretenen Sicht – wenig bis nichts an der Überschneidung zwischen Tat- und Rechtsfragen ändern.

- 4.1. Besteht die für die Tatzeit festgestellte psychische Störung weiterhin? Stand(en) die vorgeworfene(n) Tat(en) damit in Zusammenhang?
- 4.2. Gibt es für die festgestellte psychische Störung eine Behandlung? Lässt sich durch diese der Gefahr neuerlicher Straftaten begegnen? Wenn ja, wie sollte eine solche Behandlung aussehen?
- 4.3. Ist die beschuldigte Person bereit, sich dieser Behandlung zu unterziehen? Könnte allenfalls auch die gegen den Willen der beschuldigten Person angeordnete Behandlung erfolgsversprechend durchgeführt werden?
- 4.4. Ist die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme im Sinne von Art. 59-60 StGB, einer ambulanten Behandlung im Sinne von Art. 63 StGB oder mehrerer Massnahmen im Sinne von Art. 56a StGB zweckmässig? Ist nur eine stationäre Behandlung geeignet, der Gefahr weiterer Straftaten zu begegnen oder genügt auch eine ambulante Behandlung? Welche Möglichkeiten der praktischen Durchführbarkeit der Massnahme gibt es?
- 4.5. Kann der Art der Behandlung auch bei gleichzeitigem oder vorherigem Strafvollzug Rechnung getragen werden?
- 4.6. Sofern die beschuldigte Person zur Zeit der Tat(en) noch nicht 25 Jahre alt war:
 - 4.6.1 Ist die beschuldigte Person in ihrer Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört?
 - 4.6.2 Besteht ein Zusammenhang zwischen Tat und Störung der Persönlichkeitsentwicklung?
 - 4.6.3 Kann die Massnahme für junge Erwachsene im Sinne von Art. 61 StGB die Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten vermindern? Ist die beschuldigte Person zu einem Aufenthalt in einer solchen Anstalt bereit? Ist diese Massnahme gegen den Willen der beschuldigten Person erfolgreich durchführbar? Bedarf es zusätzlich einer Massnahme nach Art. 59-60 und 63 StGB?

Wie bereits bei der Schuldfähigkeit beinhaltet die gutachterliche Antwort auf diese Fragen Aspekte, welche klar dem Bereich der Tatfragen zugeordnet werden können. Beispiele dafür sind die Diagnose einer psychischen Störung (Frage 1. und 4.1, Unterfrage 1, Frage 4.6.1), der Zusammenhang mit der Anlasstat (Frage 4.1, Unterfrage 2 sowie Frage 4.6.2), die Risikobeurteilung i.S. einer Konkretisierung der Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls und der zu erwartenden Delikte (Frage 3) sowie die Behandelbarkeit bzw. Erfolgsaussicht einer therapeutischen Massnahme (Fragen 4.2, 4.3, 4.5 sowie 4.6.3). Trotzdem kann auch bei der massnahmenrechtlichen Beurteilung die Grenzziehung zwischen Tat- und Rechtsfrage nicht stringent durchgehalten werden.³⁸⁵ 134

Der PSY-Sachverständige hat sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung «über die möglichen Wirkungen der verschiedenen Sanktionen vergleichend auszulassen...und dazu Stellung zu nehmen, ob und inwiefern andere sichernde 135

³⁸⁵ Dazu auch SCHMID, Diss., S. 548: «Bei den Fragen, die der Gutachter nach seinem gesetzlichen Auftrag zu beantworten hat, überschneiden sich medizinische und juristische Kompetenzen in schwer zu entwirrender Weise.»

Massnahmen auszuschliessen sind».³⁸⁶ Weiter hat sich der Sachverständige festzulegen, welche Massnahme seiner Meinung nach im konkreten Fall am geeignetsten ist.³⁸⁷ Diese Praxis spiegelt sich im Fragenkatalog: Die sachverständige Person wird explizit nach der Zweckmässigkeit einer Massnahme und den jeweiligen Alternativen gefragt (Frage 4.4 und 4.6.3). Kommt die sachverständige Person dieser Forderung nach und spricht sie sich in einer Gesamtabwägung (Indikation, Prognose, vergleichende Auslassung zu Sanktionen etc.) für eine konkrete Massnahme aus, spiegelt dieses Vorgehen über weite Strecken das, was das Gericht in der Rechtsanwendung (insb. bei der Verhältnismässigkeitsprüfung) abzuwägen hat.³⁸⁸ Diese Tatsache ändert wiederum nichts daran, dass es Sache des Gerichts ist, zu entscheiden, ob und welche strafrechtliche Massnahme in einem konkreten Verfahren angeordnet wird, was die juristische Relevanz einer psychischen Störung ist und welches Restrisiko einer Gesellschaft zugemutet werden kann. Der PSY-Sachverständige ist «bloss» Ratgeber und Entscheidungshelfer, dessen Empfehlungen das Gericht nicht binden.³⁸⁹ Es gibt daher durchaus Fälle, in welchen Gerichte von den gutachterlichen Empfehlungen abweichen.³⁹⁰ Trotzdem lässt sich die faktische Relevanz der gutachterlichen Empfehlungen für die richterliche Rechtsfindung nicht negieren.³⁹¹ Auch im Kontext der Massnahmenindikation zeigt sich, dass eine scharfe Trennung

³⁸⁶ BGer, 2. August 2018, 6B_56/2018, E. 2.1; BGer, 23. Januar 2018, 6B_28/2017, E. 3.4; vgl. auch BGer, 17. November 2011, 6B_232/2011, E. 3.1.3; KSBS/SGFP-Fragenkatalog, S. 1 f.

³⁸⁷ BGer, 5. Juli 2018, 6B_39/2018, E. 1.1.2; BGer, 10. Februar 2017, 6B_371/2016, E. 1.1.4.

³⁸⁸ GRAF, Qualitätskriterien, 95 (bezieht sich primär auf Frage 4.4 des Fragenkatalogs); GRAF, «Justice - Justiz - Giustizia» 4/2015, N 21 ff.; implizit auch SCHMID, Diss., S. 548.

³⁸⁹ BGer, 5. Juli 2018, 6B_39/2018, E. 1.1.2; BGer, 22. Januar 2018, 6B_1348/2017, E. 1.1.3: «L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise»; BGer, 23. Januar 2018, 6B_28/2017, E. 3.4 (zur juristischen Relevanz der festgestellten Störung); BGer, 23. Januar 2019, 6B_1167/2018, E. 4.1; DUBS, S. 342; HABERMEYER/SACHS, N 21; SCHMID, Diss., S. 556 f.

³⁹⁰ Als Beispiel das Verfahren BGer, 18. Januar 2018, 6B_1287/2017, E. 1.3.3, in welchem das Bundesgericht trotz geringer Erfolgsaussichten die Anordnung einer stationären Massnahme durch die Vorinstanz schützte, obwohl der Sachverständige sich für eine ambulante Behandlung nach Art. 63 StGB ausgesprochen hatte.

³⁹¹ EGG, S. 154: «Ich bin daher nicht sehr optimistisch, dass die rechtlich und praktisch gebotene Trennung zwischen kriminalprognostischer Stellungnahme und richterlichen Entscheidung überall konsequent eingehalten wird...»; FONJALLAZ/GASSER, S. 146.

zwischen psychiatrischen und richterlichen Kompetenzbereichen unrealistisch ist.³⁹²

Die Suggestivwirkung der sachverständigen Massnahmenempfehlung bzw. die Weichenstellung für die Rechtsanwendung findet wie bereits bei der Schuldfähigkeit empirische Bestätigung. Im deutschen Rechtsraum konnten sehr hohe Übernahmequoten erhoben werden. In einer Studie von ENGELHARDT folgte das Gericht in den von ihr analysierten Urteilen den gutachterlichen Ausführungen zur Diagnose (97%), der Prognose (96%), der Unterbringung nach §63 f. StGB-DE (100%) sowie der Behandlungsprognose (99%) in abgekürzten Urteilen fast durchgängig.³⁹³ Diese Übereinstimmungsquoten sanken auch bei den nicht abgekürzten Urteilen nur unwesentlich, nämlich auf 93% für die Diagnose und 93% für die Prognose. Bezüglich der Behandlungsprognose (99%) sowie der Unterbringung gemäss §63 f. StGB-DE (100%) blieben die Übereinstimmungsraten konstant hoch.³⁹⁴ In der Studie von FEGERT ET AL. folgte das Gericht der gutachterlichen Empfehlung der Anwendung von §63 StGB-DE (Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus; ähnlich wie Art. 59 StGB) in 68% der Fälle (n=25). Für die empfohlene Einweisung in eine Entziehungsanstalt nach §64 StGB-DE sank dieser Wert auf 33% der Fälle (2 von 6).³⁹⁵ 136

In der Schweiz ermittelten FREI/GRAF/DITTMANN für 81 Verfahren, dass das gerichtliche Urteil mit der gutachterlichen Massnahmenempfehlung zu 87.9% vollständig, zu 7.2% mässig und zu 3.6 % mittel übereinstimmte und zu 1.3% (1 Fall) ambivalent ausfiel.³⁹⁶ Die Basler Gutachten-Kohortenstudie von HACHTEL ET AL. zeigt tiefere, aber immer noch nennenswerte Übereinstimmungsquoten: Der gutachterlichen Einschätzung einer fehlenden Massnahmenindikation wurde zu 92.5% gefolgt.³⁹⁷ Der gutachterlichen Empfehlung einer ambulanten Mass- 137

³⁹² DUBS, S. 342.

³⁹³ ENGELHARDT, S. 187. Mit dem Terminus «abgekürztes Urteil» ist das Vorgehen nach § 261 Abs. 4 StPO-DE gemeint (vgl. ENGELHARDT, S. 168).

³⁹⁴ ENGELHARDT, S. 187.

³⁹⁵ FEGERT ET AL., S. 86 f.

³⁹⁶ FREI/GRAF/DITTMANN, S. 140: «Mäßige Übereinstimmung bedeutet z.B.: Keine Empfehlung aus forensisch-psychiatrischer Sicht für eine ambulanten Massnahme i. S. des Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. vs. der richterlichen Anordnung zu einer solchen. In vier der sechs als «mäßige» Übereinstimmung eingestuftten Fälle war dies der Fall. Mittlere Übereinstimmung bedeutete die Anordnung einer stationären Massnahme entgegen der gutachterlichen Empfehlung für eine ambulante Massnahme, beide i. S. des Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. Ambivalent bedeutete die richterliche Anordnung einer stationären Massnahme bei einem 22-jährigen, da das Gericht der Ansicht war, die auf 4 Jahre limitierte Zeit beim vom Gutachter empfohlenen An. 100^{bis} StGB werde der Schwere der Störung und des Deliktes (ermordete Taxifahrerin) nicht gerecht.»

³⁹⁷ HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 5.

nahme nach Art. 43 aStGB («Massnahme an geistig Abnormen») folgte das Gericht in 38.9% der Fälle.³⁹⁸ Bei ambulanten Massnahmen nach Art. 44 aStGB («Behandlung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen») stieg die Übernahmequote auf 45.1%.³⁹⁹ Wurde eine stationäre Massnahme nach Art. 43 aStGB empfohlen, folgte das Gericht in 30.4% der Fälle dem Gutachten.⁴⁰⁰ Bei einer Verwahrung gelangte das Gericht in 41.6% der Fälle zur selben Einschätzung wie der Sachverständige.⁴⁰¹ Für die stationäre Massnahme nach Art. 44 aStGB betrug die Übereinstimmungsquote 40.4%.⁴⁰² Die gutachterliche Empfehlung zur Einweisung in die Arbeitserziehungsanstalt nach Art. 100bis aStGB wurde vom Gericht in 28.6% der Fälle übernommen.⁴⁰³

138 Inwiefern sich die vergleichsweise tieferen Übernahmequoten der Basler Kohorten-Studie unter geltendem Recht (die Studie betraf Verfahren unter dem Geltungsbereich des aStGB) replizieren lassen würden, ist unklar.⁴⁰⁴ Es wäre vorstellbar, dass eine aktuelle Untersuchung unter dem revidierten Massnahmenrecht angesichts stetig steigender Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung einen stärkeren gerichtlichen «Gehorsam» offenbaren würde, als dies in der Basler Gutachten-Kohortenstudie der Fall war.⁴⁰⁵ Es wäre aber auch denkbar, dass die tieferen Übernahmequoten Ausdruck eines gestiegenen richterlichen Selbstbewusstseins darstellen oder dass sonstige Überlegungen (Vollzugseinrichtung,

³⁹⁸ HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 5. Das Gericht sprach sich in den übrigen Fällen für Alternativen aus: «55.7% erhielten keine Massnahme, während bei 3.1% stattdessen Art. 44 aStGB (Behandlung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen) zur Anordnung einer ambulanten Massnahme angewendet wurde».

³⁹⁹ HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 5. In den verbleibenden Fällen wurde entweder von einer Massnahme abgesehen (38.7%) oder eine stationäre Massnahme angeordnet (6.4%).

⁴⁰⁰ HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 5. Wenn das Gericht dem Gutachten nicht folgte wurde «in der Mehrzahl ... entweder keine Massnahme (52.9%) oder eine ambulante Massnahme nach Art. 43 aStGB (13.7%) angeordnet».

⁴⁰¹ HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 5 in den anderen Konstellationen wurde einmal (8.3%) eine stationäre Massnahme beschlossen und in sechs Fällen (50%) keine Massnahme angeordnet.

⁴⁰² HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 5. In den übrigen Fällen wurde zu 38.5% von einer Massnahme abgesehen. In 9.6% der Fälle wurde eine ambulante Massnahme nach Art. 44 aStGB angeordnet. In 5.7% wurde eine stationäre Behandlung nach Art. 43 aStGB ausgesprochen.

⁴⁰³ HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 5. Bei 57.1% wurde keine Massnahme verhängt. In den übrigen Fällen erachtete das Gericht «die Indikation zu je einer ambulanten und einer stationären Massnahme nach Art. 43 aStGB als gegeben».

⁴⁰⁴ Vgl. auch HUBER, S. 238 mit dem Hinweis, dass nicht untersucht worden sei, warum und unter welchen Umständen die Gerichte von den gutachterlichen Empfehlungen abwichen.

⁴⁰⁵ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, Fn. 10.

Verhältnismässigkeit, Kosten) dafür verantwortlich zeichnen.⁴⁰⁶ Letztlich handelt es sich bei sämtlichen Varianten um unbewiesene Annahmen. Für die vorliegende Betrachtung schadet dies nicht. Denn selbst bei Berücksichtigung der vergleichsweise tieferen Übernahmequoten in der Basler-Kohortenstudie gelangt man bei einer Gesamtbetrachtung der empirischen Ausgangslage zur Feststellung: Die gutachterliche Massnahmenempfehlung hat einen nennenswerten Einfluss auf die richterliche Rechtsfindung.

c) *Normative Abstinenz als unzulängliches Remedium*

Die voranstehenden Ausführungen illustrieren die Relativität des Dogmas «iura novit curia». Wiewohl die Rechtsfindung eine gerichtliche Aufgabe ist, muss rechtstatsächlich von einem arbeitsteiligen Dialogmodell zwischen Gericht und PSY-Sachverständigem gesprochen werden. Zwar bleibt unbestritten: «In welchem Ausmaß sich der Richter der Mitwirkung des Sachverständigen bei der normativen Entscheidung bedient bzw. welche Kompetenz er ihm zuweist, steht in seinem Ermessen».⁴⁰⁷ Die voranstehenden Ausführungen zeigen jedoch, dass die gutachterlichen Empfehlungen zu den Rechtsfragen im Schuldfähigkeits- und Massnahmenkontext durchaus Einfluss auf die richterliche Rechtsanwendung entfalten.⁴⁰⁸ 139

In der Literatur wird zur Behebung dieses Zustands teilweise die strikte normative Abstinenz des Sachverständigen gefordert. Der Sachverständige soll sich beispielsweise jeglicher Stellungnahme zum Rechtsbegriff der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit enthalten, um die damit einhergehende Gefahr der richterlichen Verantwortungsdelegation zu bereinigen.⁴⁰⁹ Allerdings: Das Resultat der normativen Abstinenz wäre eine rein terminologische Änderung seiner Aussagen, obwohl materiell alles beim Alten bliebe. Die gutachterlichen Erwägungen wären nun nicht mehr auf die Rechtsbegriffe der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit als Komponenten der Schuldfähigkeit ausgerichtet.⁴¹⁰ Das aber nach wie vor bestehende juristische Interesse an einer fachkundigen Einschätzung der Störungsauswirkungen im Tatzeitpunkt und die Kategorienbildung (Was hebt die Einsichts-/Steuerungsfähigkeit auf? Was reduziert sie und in welchem Masse? Was lässt die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit unberührt?) wäre nun lediglich in ein anderes Referenzsystem gepackt und 140

⁴⁰⁶ FONJALLAZ/GASSER, S. 161; vgl. auch die Diskussion der Studienergebnisse durch HACHTEL ET AL., SZK 2014, S. 7 f.

⁴⁰⁷ KONRAD, Tagungsthema, S. 9.

⁴⁰⁸ Vgl. N 128 ff.

⁴⁰⁹ EGE, S. 335 f.; SCHMID, Diss., S. 448 ff.; diese Thematik wird im Übrigen über die Landesgrenzen hinaus kontrovers diskutiert. Für die USA: NEIL, S. 329 m.w.N.; Für Deutschland: TOEPEL, S. 132 m.w.N.

⁴¹⁰ BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 34.

diese Ausführungen wären wiederum geeignet, die richterliche Schuldfähigkeitsbeurteilung zu tangieren.⁴¹¹ Man hätte sich – etwas überspitzt formuliert – einmal im Kreis gedreht und die gutachterliche Einschätzung in ein neues terminologisches Gewand gekleidet, ohne dass sich in der Sache etwas geändert hätte. Gleichzeitig hätte man aufgrund des Sprachwandels die Gefahr von beidseitigen Fehlinterpretationen erhöht. Das Primat der normativen Abstinenz muss daher zurückgewiesen werden. Sinnvoller für eine sachgerechte Kompetenzaufteilung dürfte das Instrument des Dialogs zwischen Gericht und Sachverständigem sein.⁴¹²

- 141 Dieses Argument gilt auf der Ebene der Massnahmenindikation in derselben Schärfe. Die gutachterlichen Ausführungen zur (Un)wirksamkeit spezifischer Sanktionen, deren Wirksamkeitsvergleich usw. beinhalten geradezu notwendigerweise Überlegungen, wie sie der richterlichen Rechtsanwendung – insb. der Verhältnismässigkeitsprüfung – eigen sind. Auch hier liesse sich theoretisch auf die explizite Massnahmenempfehlung seitens des Sachverständigen verzichten. Die Empfehlung ginge nun aber implizit aus der erforderlichen vergleichenden Wirksamkeitsprognose der jeweiligen Massnahmen hervor und gerade auf letztere könnte kaum verzichtet werden, will man den Nutzen des Sachverständigenbeweises für die Beurteilung der Massnahmenindikation nicht untergraben. Auch für die Massnahmenindikation zeigt sich somit, dass die normative Abstinenz des Sachverständigen ein untaugliches Remedium zur Sicherstellung der richterlichen Rechtsanwendungskompetenz darstellt. Man zwingt den PSY-Sachverständigen, so zu tun, «als ob er die Rechtslage und den Bedeutungsgehalt der Rechtsbegriffe kaum kennen würde, obschon er den Sachverhalt mit Blick auf genau diese Begriffe abzuklären hat.»⁴¹³ Eine solch trennende Sicht von sachverständiger und richterlicher Kompetenz verkennt die enge faktische Zusammenarbeit zwischen PSY-Sachverständigem und Gericht und erschwert die Integration der psychiatrischen Befunde in die juristische Entscheidungsfindung.⁴¹⁴

⁴¹¹ Dieser Punkt wird sogar von SCHMID, Diss., S. 450 f. eingeräumt, der die normative Abstinenz des Sachverständigen fordert (S. 449 ff.).

⁴¹² BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 34; HABERMAYER/SASS, S. 10; KIESEWETTER, ZStrR 2010, 329; NOLL, S. 74; Kröber et al.-I-RÖSSNER, S. 405; SASS/HABERMAYER, S. 160; wohl auch TOEPEL, S. 135; PK StGB-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 7 ff.

⁴¹³ So die treffende Formulierung von DONATSCH, Kriminalistik 1995, S. 516, welche sich allerdings auf den Sachverständigenbeweis im Allgemeinen bezieht.

⁴¹⁴ BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 34; DUBS, S. 341; SCHREIBER, S. 1017.

II. Neutralität des Sachverständigen

Die voranstehenden Ausführungen haben offenbart, dass der PSY-Sachverständige herausragende Relevanz für die gerichtliche Entscheidungsfindung einnimmt. Der Sachverständigenbeweis eröffnet damit ein Spannungsfeld zur richterlichen Unabhängigkeit, da sich die genuin richterliche Aufgabe der Entscheidungsfindung partiell auf den demokratisch nicht legitimierten Sachverständigen verlagert.⁴¹⁵ In diesem Zusammenhang wird von manchen Autoren formuliert, dass sich Gerichte «bei der Überprüfung der Qualität eines Gutachtens eigentlich auf die Überprüfung der Qualifikation und Integrität der Person eines Sachverständigen beschränken müssen».⁴¹⁶ Diese Haltung ist zwar etwas zu pointiert, da ein Gutachten – wie aufgezeigt – durchaus durch das Gericht zu überprüfen ist, wobei selbst inhaltliche Aspekte mit einem Plausibilitätsmassstab zu analysieren sind.⁴¹⁷ In limitiertem Masse trifft das voranstehende Zitat aber durchaus zu: Da Überprüfungslimitationen bestehen, ist das Gericht immer in gewissem Masse gezwungen, dem Sachverständigen zu vertrauen. Dieses Vertrauen ist aber nur dann gerechtfertigt, «wenn der Sachverständige sein Wissen und seine Kenntnisse in möglichst neutraler Weise vermittelt».⁴¹⁸ Ein wesentlicher Pfeiler der Verfahrensfairness im Rahmen des Sachverständigenbeweises ist folgerichtig die Neutralität des Sachverständigen.⁴¹⁹

1. Leitbild: Unabhängigkeit und Unparteilichkeit

Sowohl das Verfassungsrecht als auch die Strafprozessordnung orientieren sich an der vom EGMR aufgestellten Forderung nach ausreichender Sachverständigenneutralität. Zwar gilt das richterliche Neutralitätserfordernis qua Art. 30 BV für Sachverständige nicht, da sie keine formelle Richterposition innehaben; es werden aber analoge Anforderungen aus Art. 29 Abs. 1 BV abgeleitet.⁴²⁰ Diese

⁴¹⁵ ARENS, S. 261 und 274; BERNHARD, Jusletter 13. Februar 2012, N 11; BINDER, S.153 ff.; ERB, S. 884; HEER, Grundlage, S. 200; zu diesem Spannungsfeld auch EGMR, Sara Lind Eggertsdóttir v. Iceland, no. 31930/04, §54, 5 July 2007.

⁴¹⁶ GRAF, Qualitätskriterien, S. 101; ähnlich KAUFMANN, S. 114 f.: «...steht bei der Würdigung des sachverständigen Beweises nicht die Glaubwürdigkeit der sachverständigen Person bzw. die Glaubhaftigkeit des Gutachtens im Vordergrund. Vielmehr hat sich das Gericht seiner Unparteilichkeit, seines Fachwissen sowie der Schlüssigkeit bzw. Richtigkeit seiner Befunde zu überzeugen.»

⁴¹⁷ Vgl. N 116 ff.

⁴¹⁸ DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 344 f.

⁴¹⁹ Vgl. N 102.

⁴²⁰ BGer, 27. Dezember 2018, 6B_1101/2018, E. 1.1; BGer, 12. Juli 2018, 6B_616/2018, E. 2.2; BGer, 19. Juli 2017, 6B_22/2017, E. 1.2; BGer, 30. Juni 2015, 1B_82/2015, E. 2; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 87; DONATSCH, Jus-

sehen sich gesetzlich in Art. 183 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 56 lit StPO reflektiert. Neben qualifizierten Statusverhältnissen (lit. c-e) muss jene sachverständige Person in Ausstand treten, welche ein persönliches Interesse am Verfahrensausgang hat (lit. a), die vorbefasst ist (lit. b) oder die «aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte» (lit. f).

- 144 Allgemein spielt keine Rolle, ob die konkrete sachverständige Person tatsächlich subjektiv befangen ist. Für die Annahme eines Ausstandsgrunds ist einzig von Bedeutung, dass «bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen».⁴²¹ Liegt eine solche Sachlage vor und meldet die sachverständige Person den Ausstand begründenden Sachverhalt nicht selbst der Behörde (Art. 57 StPO), können die Parteien ein Ausstandsgesuch stellen (Art. 58 StPO). Die durch das Verfassungs- und Gesetzesrecht realisierte ausstandrechtliche Gleichsetzung⁴²² des Sachverständigen mit dem Richter soll gewährleisten, dass der Wissenstransfer vom Sachverständigen an die Strafbehörden möglichst frei von unsachlichen Wertungen erfolgt.⁴²³ Mit diesen Rahmenbedingungen realisiert das geltende Recht normativ die vom EGMR für die Gewährleistung eines fairen Verfahrens als relevant betonte Neutralität der sachverständigen Person.

letter 14.Mai 2007, N 20; DONATSCH, FS Castelberg, S. 38; JEANNERET/KUHN, N 13007; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 444.

⁴²¹ BGer, 30. Juni 2015, 1B_82/2015, E. 2; BGer, 27. Dezember 2018, 6B_1101/2018, E. 1.1.

⁴²² Zwar findet sich in der bundesgerichtlichen Praxis zuweilen die Äusserung, dass Ausstandsgesuche gegenüber Sachverständigen nicht leichthin gutzuheissen sind, da dies eine Verkomplizierung und Verlängerung des Verfahrens nach sich ziehe (BGer, 6. Juni 2006, 1P.787/2005, E. 3.1.1). Es müsse der unterschiedlichen Funktion des Richters sowie des Sachverständigen Rechnung getragen werden und eine unbesehene Übertragung des Ausstandspraxis verbiete sich (BGer, 6. Juni 2006, 1P.787/2005, E. 3.1.1; BGer, 30. November 2006, 1P.485/2006, E. 2.2.2; BGer, 21. Februar 2007, 1P.586/2006, E. 3.2; BGer, 29. Mai 2007, 1B_22/2007, E. 3.3). Diese Praxis wird in der Lehre zurecht kritisiert, vgl. ZK StPO-DONATSCH, Art. 183 N 11: «unverständlich»; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 346: «höchst problematisch», BSK StPO-I-HEER, Art. 183 N 20: «rechtstaatlich problematisch». Materiell dürfte es sich aber nur um eine scheinbare Ungleichbehandlung handeln. So stellte das Bundesgericht in einem Verfahren klar, dass wegen den genannten Erwägungen nicht ein Ausstandsgesuch abgelehnt werden darf, wenn effektiv ein Anschein der Befangenheit besteht, vgl. BGer, 26. Juli 2010, 4A_256/2010, E. 3.

⁴²³ DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 345.

2. Fakt: systembedingte Neutralitätszweifel

Das voranstehende Leitbild des neutralen Sachverständigen erfährt auf Fakten- 145
ebene gewisse Einschränkungen. Nachfolgend sollen indes nicht jene Aus-
standsgründe betrachtet werden, welche im Einzelfall eines Verfahrens auftreten
können, wie dies etwa bei Freundschaft, Feindschaft usw. der Fall sein kann.
Vielmehr soll die Aufmerksamkeit den systemischen Bedingungen (die im Re-
gelfall in jedem Strafverfahren vorliegen) gelten, welche geeignet sind, die
Neutralität des Sachverständigen zu tangieren.⁴²⁴ Dabei sind drei Aspekte zu
bedenken. Durch seine Tätigkeit vermengt der Sachverständige erstens partiell
die faktische Ermittler- und Richterfunktion (A.). Zweitens wird er im Regelfall
von der Strafverfolgungsbehörde – einer späteren Partei des gerichtlichen Ver-
fahrens (vgl. Art. 104 Abs. 1 lit. c StPO) – mandatiert (B.). Drittens ist der poli-
tisch-mediale Druck auf den Sachverständigen zu bedenken (C.).

A) Vermengung von faktischer Ermittler- und Richterfunktion

Eine erste Neutralitätsproblematik erwächst aus der Tatsache, dass der PSY- 146
Sachverständige zwei grundsätzlich zu trennende Aufgabenbereiche in seiner
Person vereint. Nach der Rechtsprechung des EGMR können berechtigte Zwei-
fel an der Unparteilichkeit des Gerichts entstehen, wenn die Rollen der ermit-
telnden Staatsanwaltschaft mit der Rolle des Richters vermengt werden, d.h.
wenn eine Personalunion beider Funktionen entsteht («where there is some con-
fusion between the functions of prosecutor and judge»)⁴²⁵ Die Ratio dieser
Rechtsprechung – welche auch vom Bundesgericht in seine Auslegung von Art.
30 BV aufgenommen wurde und in Art. 9 StPO (Anklageprinzip) reflektiert
wird – besteht in der Prämisse der Vorbefassung.⁴²⁶ Wer ein Verfahren anstösst,
«weil er aufgrund der Ermittlung vom Vorliegen eines strafbaren Verhaltens
überzeugt ist, wird danach mit grosser Wahrscheinlichkeit auch zu einem
Schuldspruch gelangen», weshalb ein Verfahren umso fairer ist, desto klarer
eine Sphärentrennung zwischen Untersuchungs- und Richterkompetenz verwirk-

⁴²⁴ Zur mangelnden Beachtung struktureller Neutralitätsdefizite in der Lehre: HUBER, S. 149.

⁴²⁵ EGMR, *Kamenos v. Cyprus*, no. 147/07, § 104, 31 October 2017; EGMR, *Ozerov v. Russia*, no. 64962/01, § 50, 18 May 2010; EGMR, *Kyprianou v. Cyprus* [GC], no. 73797/01, § 126, ECHR 2005-XIII; die daraus folgende Bundesgerichtspraxis: BGE 131 I 113, E. 3.5; BGE 121 I 208, E. 4; BGE 117 Ia 157, E. 2b.

⁴²⁶ Stellvertretend: BGer, 5. April 2018, 1B_491/2017, E. 3.6.

licht ist.⁴²⁷ Entsprechend ist auch die Personalunion von Fachrichter und Sachverständigem nach der Praxis des EGMR unzulässig.⁴²⁸

147 Zwar bildet das Konzept des gerichtlich beauftragten Sachverständigen (der nicht gleichzeitig als Richter bestellt ist) nach Sicht des EGMR keine Konventionsverletzung qua Vorbefassung, da dieser das Gericht «nur» mit seinem Fachwissen bei der Entscheidungsfindung unterstützt, ohne dass er richterliche Funktionen einnimmt.⁴²⁹ Allerdings ist diese Betrachtung auf der Faktenebene nur bedingt zutreffend. Nominal fusst der PSY-Sachverständige seine Beurteilung zwar zu einem Teil auf den Ermittlungsergebnissen der Strafbehörden, steht unter der Leitung der Verfahrensleitung und das Gericht ist zuständig zur Beweiswürdigung und Rechtsanwendung.⁴³⁰ In der Realität kann die strafbehördliche Leitungs- und Überprüfungsfunktion aber nicht stringent aufrecht erhalten werden.⁴³¹ Anerkennt man die zuvor herausgearbeiteten Einflüsse des Sachverständigen von der Ermittlung bis zur Beurteilung der ihm unterbreiteten Fragen zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindiktion, gestaltet sich die gutachterliche Beurteilung als ein eigentliches Sonderverfahren im Strafprozess, in dem der PSY-Sachverständige als faktischer (Teil)ermittler und (Teil)richter über die ihm vorliegenden Fragestellungen zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindiktion amtiert.

148 In diesem «Sachverständigen-Sonderverfahren» stellt die Begutachtungsindikation (Art. 20 StGB; Art. 56 Abs. 3 StGB) für den Sachverständigen das Äquivalent zum Tatverdacht für die Strafverfolgungsbehörden dar. Gestützt darauf wird der Sachverständige durch die Mandatierung seitens Strafbehörden im Strafverfahren aktiv (Art. 184 Abs. 1 StPO). Dabei basieren seine Ersthypothesen zwar auf den strafbehördlichen Informationen. Diese vermögen aber nur selten für die Beurteilung zu genügen. Folglich muss er für seinen Gutachtensauftrag in einem ersten Schritt in die Rolle des Ermittlers schlüpfen. In diesem Zusammenhang wird der PSY-Sachverständige gestützt auf Art. 185 Abs. 4 StPO auch die Exploration mit der beschuldigten Person vornehmen. Damit findet unbestritten eine vom PSY-Sachverständigen gesteuerte, strafbehördenvertretende Sachverhaltsermittlung statt.⁴³² Diese ist umso bedeutender, als das Explorationsgespräch für seine Beurteilung als essentielles Untersuchungsmittel bezeichnet

⁴²⁷ ACKERMANN/VETTERLI, S. 196 und 199; vgl. auch BGE 131 I 113, E. 3.4, worin unter Verweis auf BGE 114 Ia 50, E. 3d zurecht ausgeführt wird, dass eine solche Aufgabenkumulation die Gefahr der Betriebsblindheit mit sich bringt.

⁴²⁸ EGMR, D.N. v. Switzerland [GC], no. 27154/95, § 50 ff., ECHR 2001-III; BGE 137 III 289, E. 4.4; BGer, 14. April 2010, 5A_250/2010, E. 2.4; BGer, 24. November 2011, 5A_787/2011, E. 3.4.

⁴²⁹ EGMR, D.N. v. Switzerland [GC], no. 27154/95, § 53, ECHR 2001-III.

⁴³⁰ Vgl. N 112, N 116 f. sowie N 127.

⁴³¹ HEER, Grundlage, S. 201.

⁴³² Vgl. N 113 f.

wird.⁴³³ Sind die Ermittlungen abgeschlossen, schlüpft der PSY-Sachverständige bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation partiell in das richterliche Gewand, da seine Feststellungen vom Gericht nur limitiert überprüft werden können und seine Empfehlungen auf der Rechtsebene geeignet sind, die richtliche Rechtsfindung zu beeinflussen.⁴³⁴ Eine problematische Vermengung von ermittelnder und beurteilender Instanz für die Beurteilung der Schuldfähigkeit sowie der Massnahmenindikation ist die Folge. Es gibt daher gute Gründe für die Argumentation, dass die partielle Sachverhaltserhebung des Sachverständigen sowie die faktische Kompetenz zu dessen Beurteilung eine partielle Personalunion darstellt, die zumindest in Reibung mit dem Ausstandsgrund der Vorbefassung gerät. Dieser Gesichtspunkt vermag aufgrund der geschilderten EGMR-Praxis zwar für sich genommen noch keine Konventionsverletzung qua Vorbefassung zu begründen. Er ist aber in der noch vorzunehmenden Gesamtwürdigung der Verfahrensfairness gebührend zu berücksichtigen.

B) Beauftragung durch die Strafverfolgungsbehörde

Ein zweites Neutralitätsdefizit ergibt sich mit Blick auf den Beauftragungsmodus des PSY-Sachverständigen. Gemäss Art. 184 Abs. 1 StPO wird der Sachverständige von der Verfahrensleitung mandatiert. Die beschuldigte Person hat kein Recht auf einen bestimmten Sachverständigen und kann ihr Recht auf Stellungnahme zur Person des Sachverständigen (Art. 184 Abs. 4 StPO) in aller Regel nur dazu nutzen, auf allfällige Ausstandsgründe hinzuweisen.⁴³⁵ Nun ist es so, dass im Zeitpunkt der Beauftragung regelmässig die Staatsanwaltschaft die Position der Verfahrensleitung und damit jene des Auftraggebers innehat.⁴³⁶ Dieser Umstand ist nach konstanter Rechtsprechung des EGMR geeignet, Zweifel an der Unparteilichkeit des Sachverständigen zu wecken, da die Staatsanwaltschaft

149

⁴³³ Vgl. N 9 f.

⁴³⁴ Vgl. N 118 ff.

⁴³⁵ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 87; HEER, FS Wiprächtiger, S. 196; ISENRING/MÜLLER, S. 1335; MEIER/BIGLER, S. 61; PIQUEREZ/MACALUSO, N 1113; OBERHOLZER, Grundzüge 2012, N 811; SCHMID/JOSITSCH, PraKomm, Art. 184 N 13; CR CPP-VUILLE, Art. 184 N 17.

⁴³⁶ Zur Mandatierung durch die Staatsanwaltschaft: BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 84; BERNHARD, Massnahmenrecht, 147; FONJALLAZ/GASSER, S. 99; SCHNOOR, S. 184 konnte für den deutschen Rechtsraum aufzeigen, dass in 92.1% der Fälle der PSY-Sachverständige im Ermittlungsverfahren (CH-Terminologie: Vorverfahren) beauftragt wird; vgl. auch BGE 144 I 253, nicht publizierte E. 1: «Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das Gesetz besonderes Gewicht darauf legt, dass schon im Vorverfahren für ein grundsätzlich gültiges (und gerichtlich verwertbares) psychiatrisches Gutachten zu sorgen ist.»

als Verfolger des staatlichen Strafanspruchs im Verfahren agiert.⁴³⁷ Hat sie die Kompetenz, den Sachverständigen zu bestimmen, besteht die Gefahr, dass sie mit der Wahl eines konkreten PSY-Sachverständigen versucht, das Ergebnis in gewisser Weise vorzuspüren.⁴³⁸ In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass sich Sachverständige potentiell (auch unbewusst) mit der beauftragenden Seite überidentifizieren können, was sich in der sachkundigen Beurteilung reflektieren kann (sog. *adversarial-allegiance*).⁴³⁹

- 150 Beide Befürchtungen sind nicht bloss theoretischer Natur. In mehreren Untersuchungen konnte dargelegt werden, dass für die Frage der Sachverständigenbeauftragung verfahrensstrategische Gedanken seitens der beauftragenden Behörde eine Rolle spielen können.⁴⁴⁰ Bezüglich der «*adversarial allegiance*» legen weitere Studien nahe, dass von den Strafverfolgungsbehörden beauftragte Sachverständige regelmässig negativere Risikobeurteilungen vornahmen (d.h. ein höheres Risiko feststellten) als jene der Verteidigung.⁴⁴¹ Ähnliche Tendenzen manifestierten sich bei Schuldfähigkeitsgutachten in der Untersuchung von SCHNOOR: Bei der staatsanwaltschaftlichen Beauftragung des Sachverständigen wurden signifikant mehr Personen vom Sachverständigen für voll schuldfähig (29.8%) oder voll schuldunfähig (23.8%) befunden, als wenn das Gericht die Beauftragung vornahm (8.3% voll schuldfähig, 12.5% voll schuldunfähig).⁴⁴²
- 151 Zwar kommt auch diesem Neutralitätsdefizit (Beauftragung durch die Staatsanwaltschaft) nach der Praxis des EGMR nicht direkt fairnessverletzende Wirkung zu.⁴⁴³ Wiederum gilt es aber festzuhalten, dass die Beauftragung durch die Staatsanwaltschaft ein Kriterium darstellt, das im Rahmen der Gesamtwürdi-

⁴³⁷ EGMR, *Krunoslava Zovko v. Croatia*, no. 56935/13, § 45, 23 May 2017; EGMR, *Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 26711/07 and 2 others, § 94, 12 May 2016; EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 122 f., 1 June 2017; EGMR, *Duško Ivanovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 10718/05, § 57, 24 April 2014;; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 85; BRUNNER, *Verlässlichkeit*, S. 306; KRAUSS, ZStW 1973, S. 331 f.

⁴³⁸ BARTON, StV 2003, S. 539; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 85; DETTER, S. 58; HUBER, S. 149; ISENING/MÜLLER, S. 1337; MEIER/BIGLER, S. 61.

⁴³⁹ BRUNNER, *Verlässlichkeit*, S. 306; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 85; DROR/MURRIE, S. 4; MURRIE/BOCCACCINI, S. 37 ff.

⁴⁴⁰ BARTON, *Sachverständige*, S. 24 ff.; JACOBS/GUERRA, S. 953 f.; PALARIC/MOULIN, S. 492 f.; SCHNOOR, S. 194, bei deren Erhebungen bekannte Antworttendenzen des Gutachters immerhin in fast einem Drittel der Fälle (27.4 %) eine Rolle für die Wahl des Sachverständigen spielten.

⁴⁴¹ DROR/MURRIE, S. 4; MURRIE/BOCCACCINI, S. 37 ff.

⁴⁴² SCHNOOR, S. 185.

⁴⁴³ EGMR, *J.M. and Others v. Austria*, nos. 61503/14 and 2 others, § 122 ff.; EGMR, *Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 26711/07 and 2 others, § 94, 12 May 2016; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 88.

gung zu berücksichtigen ist, denn gerade diese systemischen Neutralitätsdefizite lassen sich nicht oder nur erschwert zu einem klar zu konkretisierenden Ausgangsgrund fassen und bleiben so als potentiell fairnessrelevantes Defizit im Verfahren bestehen.

C) Politisch-medialer Druck

Eine weitere Angriffsfläche der Sachverständigentätigkeit eröffnet sich durch die Natur der unterbreiteten Beweisfragen. Mit der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation wird über zentralste strafrechtliche Fragen entschieden, welche die Weichen für das weitere Verfahren stellen.⁴⁴⁴ Diesen Gesichtspunkten wird auch seitens der Medien und der politischen Entscheidungsträger grosse Aufmerksamkeit geschenkt, was Druck auf die Arbeitstätigkeit des Sachverständigen erzeugt.⁴⁴⁵ Für die Schuldfähigkeit lassen sich diese Druckmomente durch die jüngeren Verfahren in Sachen Breivik (Anschlag auf Oslo und Utoya; Norwegen)⁴⁴⁶ oder Zschäppe (NSU-Morde; Deutschland)⁴⁴⁷ illustrieren. Für massnahmenrechtliche Beurteilungen dürften die Druckmomente noch akzentuierter ausfallen: Hier ist der Sachverständige faktisch (Mit)garant für die öffentliche Sicherheit.⁴⁴⁸ Als paradigmatisches Beispiel kann an das medial gespiegelte Unverständnis in weiten Teilen der Bevölkerung erinnert werden, als der Vierfach-Mörder von Rupperswil nicht mit der lebenslangen Verwahrung belegt wurde.⁴⁴⁹ Es ist somit kaum von der Hand zu weisen, dass die vox populi den Sachverständigen bei seiner Beurteilung tangiert.⁴⁵⁰ Konkret können sich dadurch implizite und sachgelöste Urteilsheuristiken wie in *dubio pro culpa* oder in *dubio pro securitate*⁴⁵¹ in die Beurteilung einschleichen.

Nach konstanter Rechtsprechung des EGMR besteht zwar nicht bereits dann eine Neutralitätsverletzung des Gerichts, wenn die urteilende Person aufgrund der Berichterstattung die innere Distanz zum Streitgegenstand verlieren könnte;

⁴⁴⁴ Vgl. N 23 f.

⁴⁴⁵ EGG, S. 252 ff.; HUBER, S. 148; vgl. sodann BERNHARD, *Anwaltsrevue* 2019, S. 164.

⁴⁴⁶ <https://www.n-tv.de/politik/Ist-Breivik-schuldfaehig-oder-geisteskrank-article6042986.html> (besucht am 6. Mai 2019).

⁴⁴⁷ <http://www.spiegel.de/panorama/justiz/beate-zschaepe-anwalt-will-im-nsu-prozess-schuldunfaehigkeit-feststellen-a-1141101.html> (besucht am 6. Mai 2019).

⁴⁴⁸ STIELS-GLENN, S. 131.

⁴⁴⁹ <https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/kritik-nach-urteil-soll-der-einfluss-von-psychiatern-eingeschraenkt-werden-132332168> (besucht am 6. Mai 2019); BERNHARD, *Anwaltsrevue* 2019, S. 163 ff.

⁴⁵⁰ EGG, S. 253; GUTHEIL, S. 261 ff.; STIELS-GLENN, S. 142; zu analogen Einflüssen von Medien auf Gerichte und Staatsanwaltschaften: KEPPLINGER/JOST/WOHLRABE, S. 1 ff.; WELTE, *Rz.* 26; GUIDON, S. 272 f.

⁴⁵¹ Zu diesem Prinzip: HEER, *AJP* 2017, S. 594; HEER, *Öffentlichkeit*, S. 141 ff.

erforderlich sind vielmehr konkrete objektive Anzeichen einer Beeinflussung der urteilenden Person(en) durch die Berichterstattung, was höchstens im Extremfall eigentlicher Hetzkampagnen der Fall sein dürfte.⁴⁵² Diese Leitlinien sind auch für den Sachverständigen einschlägig. Die geforderte Druckintensität dürfte in der Praxis selten so hoch sein, dass die Unabhängigkeit des Sachverständigen alleine deswegen als nicht vorhanden eingestuft wird. Nichtsdestotrotz ist es geboten, den in Begutachtungen zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation latent vorhandenen politisch-medialen Druck in die Gesamtwürdigung der Verfahrensfairness aufzunehmen.

3. Objektivität der sachverständigen Beurteilung

- 154 Die voranstehend erwähnten systemischen Neutralitätsdefizite des Sachverständigen wären unter fairnessrechtlichen Gesichtspunkten dann unproblematisch, wenn das Resultat der Begutachtung durch objektive Anknüpfungstatsachen weitgehend vorgespart wäre und somit unabhängig von der Person des Sachverständigen ausfiele. Die Rede ist von der Objektivität gutachterlicher Erkenntnisse. Zwar berücksichtigt der EGMR diesen Gesichtspunkt in seiner Praxis nicht explizit. Der hier vertretenen Ansicht nach besteht aber kein Zweifel daran, dass dem so sein muss. Die Kontrollbedürfnisse bezüglich der Auswahl des Sachverständigen sind umso grösser, je stärker das konkrete Ergebnis der Begutachtung von seiner Person abhängt.⁴⁵³ In diesen Fällen kommt der Person des Sachverständigen und dessen Auswahl im Verfahren entscheidende Bedeutung zu.⁴⁵⁴ Auch hier zeigt ein kurzer Blick auf den forensisch-psychiatrischen Sachver-

⁴⁵² Bezüglich der Neutralität des Gerichts, aber mit analoger Geltung im vorliegenden Kontext: EGMR, *Paulikas v. Lithuania*, no. 57435/09, § 57 ff., 24 January 2017; EGMR, *Fileva v. Bulgaria*, no. 3503/06, § 46 ff., 3 April 2012; EGMR, *Mustafa (Abu Hamza) v. the United Kingdom (dec.)*, no. 31411/07, § 39; BGE 116 IV 14, E. 7c; BGE 116 IV 31, E. 5a/aa; BGer, 25. Oktober 2017, 6B_800/2016, E. 1.3; BGer, 15. Mai 2019, 1B_178/2019, E. 5; BSK StPO-I-BOOG, Art. 56 N 60.

⁴⁵³ WOHLERS, ZStrR 2018, S. 452; diese Erkenntnis liegt auch Art. 184 Abs. 3 Satz 2 StPO zugrunde, wonach bei Routinegutachten (z.B. Laboruntersuchungen etc.) davon abgesehen werden kann, den Parteien vorgängig das Recht auf Stellungnahme zur Person des Sachverständigen zu gewähren. Dazu auch BGE 144 IV 69, E. 2.2: «Der Grund für die Ausnahmeregelung liegt darin, dass es bei den in Art. 184 Abs. 3 Satz 2 StPO genannten Gutachten um standardisierte Expertisen geht, welche aufgrund allgemein anerkannter Methoden in weitgehend technisch vorgegebener Weise erstellt werden...Die vorgängige Information macht vor allem dort Sinn, wo gutachterliche Erkenntnisse stark von Wertungen abhängen, die mit der konkreten Person eng verbunden sind, wie dies beispielsweise bei psychiatrischen Gutachten der Fall ist.»

⁴⁵⁴ DONATSCH, fp 2019, S. 140; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 444 und S. 448 ff (insb. S. 452 ff.).

ständigenbeweis ein Auseinanderdriften von normativem Leitbild und Faktenlage.

A) Leitbild: Objektivität

Auf normativer Ebene geht die Rechtsordnung davon aus, dass der im Rahmen von Art. 182 ff. StPO beauftragte PSY-Sachverständige den Sachverhalt nach seinen fachlichen Grundsätzen wertneutral ermittelt und beurteilt.⁴⁵⁵ Nach diesem Konzept fördert der Sachverständigenbeweis die «materielle Wahrheit» zu Tage.⁴⁵⁶ Das Leitbild der Objektivität ist verständlich, gilt doch der zur Neutralität verpflichtete Sachverständige gerade als Mittel zur verbesserten Sachverhaltsaufklärung, wo die Strafbehörden mangels Fachwissen an ihre Wissensgrenzen stossen (Art. 182 StPO). Die normative Richtigkeit dieser Objektivitätsprämisse darf aber nicht davon ablenken, dass sie über weite Strecken eine Fiktion darstellt.⁴⁵⁷ 155

B) Fakt: Ermessensspielräume bei der PSY-Begutachtung

Jedem Sachverständigenbeweis – selbst wenn der Sachverständige neutral und in der Absicht der bestmöglichen Wahrheitsermittlung arbeitet – ist bei der Sachverhaltsfeststellung und -beurteilung ein Mass an Wertung inhärent.⁴⁵⁸ Dabei gibt es freilich Unterschiede: Bei einer DNA-Analyse bestehen beispielsweise relativ kleine Wertungsspielräume und die Messergebnisse sind überwiegend stabil reproduzierbar.⁴⁵⁹ Wo aber aufgrund der grossen Komplexität des Beurteilungsgegenstands zeitlich stabile wissenschaftliche Erfahrungssätze fehlen, wo diese Wissenssätze durch eine gewisse Vagheit charakterisiert sind und konstanter Anpassung unterliegen und wo Störvariablen (forensisches Setting, Simulation, Aggravation etc.) auf die Sachverhaltserhebung einwirken, fallen die subjektiven Interpretationsspielräume des Sachverständigen grösser aus. 156

⁴⁵⁵ DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 346.

⁴⁵⁶ BARTON, Sachverständige, S. 32; BERNHARD/BINDER, S. 9 f.

⁴⁵⁷ DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 346; JEGER, N 10; KIESEWETTER, Kriminalistik 1995, S. 601; RICHNER, S. 22, der mit Blick auf die Rahmenbedingungen der Begutachtung festhält, dass psychiatrische Gutachten keine wahre Analyse einer Psyche sein können.

⁴⁵⁸ BERNHARD, Massnahmenrecht, 145; DONATSCH, 125 Jahre Kassationsgericht, S. 365; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 340; HEER, LA Niggli, S. 105; HEER, FS Wiprächtiger, S. 178; TONDORF/TONDORF, N 16; ZWIEHOFF, S. 222.

⁴⁵⁹ DETTER, S. 57; DONATSCH, 125 Jahre Kassationsgericht, S. 365; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1251; zur Reproduzierbarkeit bei physikalischen Abläufen auch AXMANN ET AL., S. 484.

Dies trifft bei psychiatrischen Gutachten durchaus zu.⁴⁶⁰ Das Resultat einer psychiatrischen Begutachtung ist mindestens partiell auch von der Person des Sachverständigen abhängig.⁴⁶¹

- 157 Bei den im Schuld- und Massnahmenkontext anfallenden Fragen sind unterschiedliche Einschätzungen desselben Exploranden durch unterschiedliche Sachverständige keine Seltenheit. Zwar darf man davon ausgehen, dass die Einführung standardisierter Befunderhebungs-, Diagnose- und Prognoseinstrumente Verbesserungen der Objektivität mit sich gebracht hat.⁴⁶² Diese Standardisierungen dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tatsachenfeststellung immer noch massgeblich von der Person des Sachverständigen beeinflusst wird.⁴⁶³ Dies lässt sich verschiedentlich illustrieren: Auf der Ebene der Befunderhebung fällt es z.B. systemimmanent schwer, komplexe Zustandsbilder wie «oberflächlicher Charme», «Verantwortungslosigkeit», «ängstlich», «gehemmt» usw. klar zu definieren, was dem Sachverständigen einen grossen Ermessensspielraum bei der Beurteilung einräumt.⁴⁶⁴ Selbst bei Anwendung operationalisierter Diagnosesysteme bestehen beim Ausgangspunkt sämtlicher Schuldfähigkeits- und Massnahmengutachten, der Diagnostik (Stichwort: psychische Störung), Interpretationsspielräume, und es wird zur Bescheidenheit bezüglich der Präsentation von Diagnoseresultaten (auch im forensischen Kontext) gemahnt.⁴⁶⁵ Ebenso eröffnet die Beurteilung, welchen Schweregrad eine

⁴⁶⁰ BARTON, Sachverständige, S. 32 ff.; ERB, S. 911 f.; DONATSCH, fp 2019, S. 137 f.; LAEMMEL, S. 246; TOEPEL, S. 201; ähnlich auch RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1251; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 340, MEIER/BIGLER, S. 61 f. und ZWIEHOFF, S. 222 betonen indes zurecht, dass die Subjektivitätsproblematik sämtliche Wissenschaftsdisziplinen (d.h. auch Physik etc.) betrifft; dazu auch PIES, S. 18 ff. sowie HAUG/TRABERT/SCHAUB, S. 259 f.

⁴⁶¹ BGE 144 IV 176, E. 4.2.3; BGer, 19. Juni 2018, 6B_582/2017, E. 2.2.3; DETTER, S. 57; FINZEN, S. 122 und 125; MEIER/BIGLER, S. 61; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1303; STIELS-GLENN, S. 132.

⁴⁶² Zur standardisierten Befunderhebung: AMDP, S. 15 und S. 28; HAUG/TRABERT/SCHAUB, S. 261; KRÖBER/FALLER/WULF, S. 343; NEDOPIL, FPPK 2012, S. 222 ff.; NEDOPIL/GRASSL, S. 144 f.; MOKROS, S. 292 zu den Vorteilen der standardisierten Befragung im Vergleich zur freien Exploration; zu operationalisierten Diagnosesystemen (ICD-10 und DSM-IV): Kröber et al.-II-HOFF/SASS, S. 22; HOFF, FPPK 2015, S. 263 f.; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 23; HOFF, Psychiatrie, S. 54 f.; zu Prognoseinstrumenten: DAHLE/LEHMANN, S. 44.

⁴⁶³ Ebenso kritisch zu den Standardisierungsvorteilen: FINZEN, S. 68; ZWIEHOFF, S. 224.

⁴⁶⁴ BGer, 19. Juni 2018, 6B_582/2017, E. 2.2.6; HEER, Anforderungen, S. 123; SCHÜLER-SPRINGORUM, S. 60; allgemein zur Beobachtungsvarianz im Rahmen der Befunderhebung bei gleichem Sachverhalt: FÄHNDRICH/STIEGLITZ, S. 14.

⁴⁶⁵ FINZEN, S. 43 ff.; GOWENSMITH ET AL., S. 693: «Diagnostic field reliability in medicine and mental health is generally mediocre, despite continuing advances in both fields.»; HOFF, Psychiatrie, S. 40 ff.; KONRAD/HUCHZERMEIER, R & P 2019, S. 86:

psychische Störung aufweist und wie sich diese Störung im Zeitpunkt der Tat auszuwirken vermochte, grosse subjektive Ermessensspielräume für die gutachterliche Beurteilung.⁴⁶⁶ Sodann ist auch die massnahmenrechtliche Beurteilung nicht frei von Wertungen. Für die Risikobeurteilung wird ein Teil der durch standardisierte Prognoseinstrumente gewonnenen Objektivität wieder durch die Tatsache reduziert, dass nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung immer eine konkrete Einzelfallanalyse stattzufinden hat, was notgedrungen die Reliabilität der Risikobeurteilung herabsetzt.⁴⁶⁷ Für die massnahmenrechtlich nicht minder wichtige Behandlungsprognose, wo ein allgemein anerkannter Beurteilungsstandard fehlt und sich die Beurteilung aus einem Konglomerat zahlreicher Einzelfaktoren zusammensetzt, kann selbiges erwartet werden.⁴⁶⁸

Sind aber bereits die Bestandteile auf Mikroebene des Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachtens partiell von der Person des Beurteilenden abhängig, darf es nicht überraschen, dass auf Makroebene zwei Sachverständige bei methodisch einwandfreier Begutachtung derselben Person zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen können.⁴⁶⁹ Dabei mögen die Abweichungen je nach Sachlage (Störungstypus, Informationsfülle etc.) unterschiedlich stark ausfal-

158

«... ICD-11 wie auch im DSM-5 angeführten Kriterien weiterhin oft unscharf sind und breiten Spielraum zur Interpretation lassen.»; MOKROS/HABERMEYER/KÜCHENHOFF, S. 556 ff.; spannend sodann die Studie von BACA-GARCIA ENRIQUE ET AL., S. 210 ff. zur zeitlichen Stabilität von Diagnosen; EGG, S. 215 ff.

⁴⁶⁶ BARTON, StV 2003, S. 538; BRUNNER ET AL., S. 229.

⁴⁶⁷ Zur Bundesgerichtspraxis: BGer, 9. April 2008, 6B_772/2007, E. 4.2 f.; BGer, 4. Dezember 2015, 6B_424/2015, E. 3.3; BGer, 9. März 2017, 6B_100/2017, E. 5.3; zu den niedrigeren Reliabilitätswerten solcher Einzelfallbeurteilungen bzw. den subjektiven Ermessensspielräumen DAHLE/LEHMANN, S. 40 ff.

⁴⁶⁸ Zur Kriterienliste und dem Fehlen einer best practise: KNECHT, N 7 ff.; HEER, Feigenblatt, S. 15 ff.

⁴⁶⁹ DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 342; ERB, S. 911 f.; TONDORF/TONDORF, N 17; interessant in diesem Zusammenhang auch die Studien von GOWENSMITH/MURRIE/BOCCACCINI, S. 41 f. (Beurteilerübereinstimmung bei der Schuldfähigkeit, wo ein einstimmiges Einverständnis der Sachverständigen nur in 55% der Fälle vorlag, in welcher die Schuldfähigkeit begutachtet wurde), KRÖBER/FALLER/WULF, S. 348 ff. und BRUNNER ET AL., S. 229 ff.; sehr pointiert sodann KONRAD/RASCH, S. 357: «Da es für die Richtigkeit der Schuldfähigkeitsbeurteilung kein Außenkriterium im wissenschaftlichen Sinne gibt, sondern letztlich die Übernahme oder Nichtübernahme des Gutachtenresultats durch das Gericht Maßstab für den Wert des Gutachtens ist, scheidet eine Überprüfung der wissenschaftlichen Qualifikation im Härtestest der Diskussion unter Fachwissenschaftlern aus. Unter Umständen entscheiden rhetorisches und schauspielerisches Geschick des Gutachters über die »Richtigkeit« seiner Darlegungen.»

len.⁴⁷⁰ Diese Tatsache ändert aber nichts an der Richtigkeit der Aussage, dass die Ergebnisse der psychiatrischen Begutachtung im Schuldfähigkeits- und Massnahmenkontext auch von der Person des Sachverständigen mitgeprägt sind.⁴⁷¹ Damit hängt das Begutachtungsergebnis in Teilen vom «Wahlglück» des Betroffenen bezüglich des konkreten Sachverständigen ab.⁴⁷²

- 159 Mit diesen Beobachtungen soll freilich nicht gesagt werden, dass der psychiatrische Sachverständigenbeweis von geringem Erkenntniswert ist. Vollkommene Objektivität zu erwarten wäre angesichts der Komplexität des Untersuchungsgegenstands schlicht unrealistisch.⁴⁷³ Trotzdem gilt es zu konstatieren, dass sich die systemischen Neutralitätsdefizite beim Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachten stärker auswirken können, da die gutachterliche Sachverhaltserhebung und -beurteilung Ermessensspielräume aufweist. Dieser Gesichtspunkt muss in die Gesamtwürdigung der Position und Rolle des Sachverständigen einfließen.

III. Fazit

- 160 Es wurde aufgezeigt, dass die gesetzlich konzipierte Rolle des Sachverständigen und die Rechtsrealität in einem dissonanten Verhältnis stehen.⁴⁷⁴ Nachfolgend sollen die Kernerkenntnisse des vorliegenden Paragraphen rekapituliert werden, um vor diesem Hintergrund die Implikationen auf das im nächsten Paragraphen zu ermittelnde Mass an effektiven Verteidigungsrechten zu ermitteln.

1. Leitbild

- 161 Das Leitbild des Sachverständigen beruht auf seiner Einstufung als unabhängiger und unparteilicher Gehilfe, der dem Gericht mit seiner besonderen Sachkunde bei der Beurteilung eines Sachverhalts zwecks Suche nach der («einen») materiellen Wahrheit behilflich ist, wobei er die formelle Beweiserhebungs- und -würdigungskompetenz und erst recht die Rechtsanwendungskompetenz des Gerichts unberührt lässt.⁴⁷⁵

⁴⁷⁰ ZWIEHOFF, S. 224; diese These sieht sich auch durch GOWENSMITH/MURRIE/BOCCACCINI, S. 42 bestätigt, wo die Beurteilerübereinstimmung bei psychotischen Störungen grösser ausfiel als bei nicht-psychotischen.

⁴⁷¹ ZWIEHOFF, S. 240.

⁴⁷² DROR/MURRIE, S. 5.

⁴⁷³ GOWENSMITH/MURRIE/BOCCACCINI, S. 43.

⁴⁷⁴ BOEHME-NESSLER, S. 200; SCHÖTTLE, S. 256; SCHREIBER, S. 1008.

⁴⁷⁵ Vgl. N 112; N 116; N 127; N 143; N 155.

2. Faktenlage

Das voranstehend geschilderte Leitbild wird durch die Faktenlage relativiert. 162 Der psychiatrische Sachverständige agiert partiell als faktischer Staatsanwalt und Richter in Weiss, womit eine substantielle Aufgabenverlagerung von der Strafbehörde auf den Sachverständigen einhergeht.⁴⁷⁶ In den treffenden Worten KRAUSS': «Der Richterschaft entpuppt sich ihr sachverständiger Gehilfe als der Wasserträger des Zauberlehrlings, der mit besonderen Fähigkeiten die Stellung seines Herrn mehr und mehr in Frage stellt».⁴⁷⁷ Ehrlicher wäre es, von einem institutionellen Nebeneinander von Strafbehörden und Sachverständigen und nicht von einem strikt hierarchischen Auftraggeber-Gehilfen-Verhältnis zu sprechen.⁴⁷⁸ Problematisch ist nicht nur die herausragende Relevanz des Sachverständigenbeweises für das gerichtliche Urteil, sondern auch die Tatsache, dass aufgrund der partiellen Vermengung von ermittelnder und richtender Funktion, der Beauftragung des Sachverständigen seitens der Staatsanwaltschaft sowie den politisch-medialen Druck die Neutralität des Sachverständigen tangiert ist.⁴⁷⁹ Letzteres ist umso problematischer, weil seine Erhebungen und Beurteilungen nicht einfach die objektive Wahrheit abbilden. Es bestehen Ermessensspielräume. Daraus folgt, dass das Resultat einer Begutachtung immer auch in gewissem Mass von der Person des Sachverständigen abhängt.⁴⁸⁰

3. Fairnessimplikationen

Aus den genannten Ausgangsvariablen auf Faktenebene lässt sich nicht in 163 abstracto auf eine Verletzung der Verfahrensfairness schliessen. Allerdings kann als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass der Sachverständigenbeweis beim Schuldfähigkeits- und Massnahmengutachten unter dem Gesichtspunkt der Waffengleichheit ein substanzielles prozessuales Ungleichgewicht in das Strafverfahren einbringt, das verfahrensrechtlich kompensiert werden muss. Die Verteidigungsrechte der beschuldigten Person müssen von einer solchen Qualität sein, dass sie die erwähnte Dysbalance wieder in ein prozessuales Gleichgewicht rücken. Anders gewendet: «Wo das Gericht mit einer eingehenden inhaltlichen Prüfung des Gutachtens überfordert ist, muss man dem Angeklagten eine effektive Möglichkeit an die Hand geben, eine solche auf anderem Wege zu erreichen.»⁴⁸¹

⁴⁷⁶ Vgl. 113 f.; N 118 ff.; N 128 ff.

⁴⁷⁷ KRAUSS, ZStW 1973, S. 334.

⁴⁷⁸ HEER, Grundlage, S. 201.

⁴⁷⁹ Vgl. N 145 ff.

⁴⁸⁰ Vgl. N 156 ff.

⁴⁸¹ ERB, S. 906.

§ 7 Konventionswidrige Unüberprüfbarkeit der Explorationsinhalte

164 Nach den in § 6 geschilderten Parametern wäre zu erwarten, dass die StPO sowie das Verfassungsrecht der beschuldigten Person Verteidigungsrechte von einer hohen Effektivität einräumen, welche die Position und Rolle des PSY-Sachverständigen im Verfahren zu kompensieren vermögen. Es muss der beschuldigten Person und der Verteidigung – um die konventionsrechtliche Terminologie zu bemühen – möglich sein, das Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachten des Sachverständigen effektiv auf die Probe zu stellen, damit das Verfahren mit Art. 6 EMRK vereinbar ist.⁴⁸² Nachfolgend wird begründet werden, weshalb das geltende Recht dieser strengen Anforderung nicht gerecht wird.

I. Ausgangsvariablen der Untersuchung

165 Bevor der juristische Status quo auf seine Vereinbarkeit mit der EMRK überprüft werden kann, sind die Ausgangsvariablen der Untersuchung zu bezeichnen. In einem ersten Schritt ist darzulegen, welche explorationsbezogenen Überprüfungsbedürfnisse die Verteidigung beim Gutachten zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation aufweist (1.). Sodann muss klargestellt werden, auf welchen verteidigungsrechtlichen Hypothesen die EMRK-Prüfung erfolgt (2.). Letzteres ist vor dem Hintergrund des Gesamtwürdigungsansatzes des EGMR zu erklären, nach welchem den konkreten juristischen Verteidigungsmöglichkeiten als auch dem Verteidigungsverhalten der beschuldigten Person im Einzelfall Rechnung zu tragen ist.⁴⁸³

1. Explorationsbezogene Überprüfungsbedürfnisse

166 Die beschuldigte Person und ihre Verteidigung weisen mit Blick auf das Explorationsgespräch unterschiedliche Überprüfungsbedürfnisse auf. Erstens soll sichergestellt sein, dass der rapportierte Explorationssachverhalt im Gutachten das historische Explorationsgeschehen akkurat repräsentiert (A.). Zweitens soll garantiert sein, dass die sachverständige Person den Explorationssachverhalt in zulässiger Weise erhoben hat, was sowohl die Einhaltung ihrer fachwissenschaftlichen Regeln (B.) als auch die Befolgung juristischer Beweiserhebungsregeln beinhaltet (C.).

⁴⁸² Vgl. N 99 ff.; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 92; ERB, S. 906.

⁴⁸³ Vgl. N 105.

A) Kongruenz zwischen historischem Explorationsgeschehen und Gutachtenssachverhalt

Ein erstes Überprüfungsbedürfnis der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung besteht darin, die Kongruenz zwischen gutachterlich rapportiertem und historischem Explorationssachverhalt sicherzustellen.⁴⁸⁴ Wie noch zu zeigen sein wird, ist die sachverständige Person verpflichtet, ihre in der Exploration gemachten Wahrnehmungen (Aussagen des Exploranden, beobachtetes Verhalten, Symptome usw.) schriftlich zu dokumentieren und – sofern relevant für die Fragestellung – in ihre gutachterliche Stellungnahme einfließen zu lassen.⁴⁸⁵ Die gutachterliche Schilderung der Exploration sollte dabei bestmöglich spiegeln, was sich in der Exploration tatsächlich ereignet hat. Dabei handelt es sich aber um keine Selbstverständlichkeit. Die sachverständige Dokumentation kann Fehler enthalten. So kommt es durchaus vor, dass der Explorand die gutachterliche Rapportierung des Explorationssachverhalts beanstandet oder dass diese sogar nachweislich fehlerhaft ist. Dies kann sich auf unterschiedlichen Ebenen auswirken: im Hinblick auf den psychischen Befund oder die Persönlichkeitsbeschreibung oder bezüglich der Frage, was die beschuldigte Person in der Exploration für Aussagen tätigte.⁴⁸⁶ Vor diesem Hintergrund ist das Bedürfnis der Verteidigung zu erklären, den gutachterlich rapportierten Explorationsinhalt auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen. 167

B) Konformität mit dem psychiatrischen Methodenstandard

Ein objektivierender Blick auf das Explorationsgeschehen (dazu voranstehend) ist für die beschuldigte Person und ihre Verteidigung auch darum von Interesse, weil damit geprüft werden kann, ob die sachverständige Person die Exploration methodenkonform durchgeführt hat, d.h. die Informationen in Übereinstimmung mit forensisch-psychiatrischen Fachstandards erhoben hat. Für das Explorationsgespräch bedeutet dies namentlich, wie bereits in der Einleitung geschildert, dass eine entspannte, angstfreie Atmosphäre in der Exploration zu kreieren ist (Aufbau einer Beziehung), der begutachteten Person empathisch zugehört werden muss, unnötige Störungen sowie Suggestivfragen zu vermeiden sind, eine verständliche Sprache zu gebrauchen ist, eigene emotionale Reaktionen zu registrieren sind, bei fremdsprachigen Probanden ein Übersetzer beizuziehen ist 168

⁴⁸⁴ BRUNNER, Aspekte, S. 197.

⁴⁸⁵ Vgl. N 178 ff.

⁴⁸⁶ ALIOTTA, Begutachtungen, S. 73; HAAG, S. 15; KUHN/BERNHARD, S. 7; SAMUELSSON, S. 25; illustrativ der folgende Sachverhalt aus dem Sozialversicherungsrecht: <https://www.srf.ch/news/schweiz/gutachten-fuer-versicherungen-gutachter-schreibt-falsches-arztzeugnis-rente-weg> (besucht am 31. Januar 2019).

usw.⁴⁸⁷ Diese Regeln haben zum Ziel, dem Sachverständigen eine möglichst akkurate Abbildung des Exploranden und seiner Psyche zu ermöglichen, und dienen insofern der Wahrheitssuche.⁴⁸⁸ Bei Nichteinhaltung dieser methodischen Leitlinien besteht die Gefahr einer verzerrten Exploration, welche kein realitätsnahes Bild des Exploranden zeichnet. Entsprechend gross ist das Bedürfnis der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung, die Einhaltung der forensisch-psychiatrischen Fachstandards sicherzustellen und allfällige Abweichungen beanstanden zu können.

C) Konformität mit juristischen Beweiserhebungsregeln

- 169 Das Überprüfungsbedürfnis der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung bezieht sich nicht nur auf die psychiatrischen Methodenvorgaben. Vielmehr sind dem Sachverständigen gewisse Verhaltensweisen in der Exploration unabhängig von seinen Fachregeln juristisch verboten. Die Verteidigung hat gerade auch hier das Bedürfnis, die Konformität der Exploration mit diesen juristischen Beweiserhebungsregeln zu kontrollieren, zumal es keine unzulässige Behauptung darstellen dürfte, dass sich Sachverständige nicht immer sämtlicher juristischer Vorgaben zur Beweiserhebung bewusst sein werden.⁴⁸⁹

a) *Verbotene Beweiserhebungsmethoden (Art. 140 StPO)*

- 170 Der sachverständigen Person ist es (wie den Strafbehörden auch) verboten, Beweise durch «Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen» zu erheben (Art. 140 StPO).⁴⁹⁰ Zwar dürften in der Praxis des Sachverständigenbeweises die Relevanz der Gewaltanwendung oder der Einsatz von Mitteln, welche die Denk- oder Willensfähigkeit beeinträchtigten, irrelevant sein.⁴⁹¹ Die sonstigen unerlaubten Beweiserhebungsmethoden könnten sich in einer Exploration aber durchaus manifestieren. So kann der Sachverständige (auch unabsichtlich!) etwa durch die Dauer und inhaltliche Ausgestaltung der Exploration das Zwangsmittel der Zermürbungstaktik⁴⁹² zur Anwendung gelangen lassen (z.B. überlang dauernde Exploration mit immer wiederkehrenden Fragen). Ebenso ist das Inaussichtstellen eines ungesetzlichen

⁴⁸⁷ Vgl. N 18 ff.

⁴⁸⁸ So explizit zur Beziehungsgestaltung: COLLINS/LINCOLN/FRANK, S. 75 f.

⁴⁸⁹ HELFENSTEIN, S. 187; BERNHARD, Jusletter 13. Februar 2012, N 41.

⁴⁹⁰ Zur Geltung von Art. 140 StPO für die sachverständige Person: EGE, S. 329; HEER, FS Wiprächtiger, S. 181; PIETH, S. 213; CR CPP-VUILLE, Art. 185 N 1; BGer, 10. Oktober 2017, 1B_141/2017, E. 5.8; für die analoge Konstellation im deutschen Recht: TOEPEL, S. 384.

⁴⁹¹ MEISTER, S. 422.

⁴⁹² HEER, FS Wiprächtiger, S. 181; ZK StPO-WOHLERS, Art. 140 N 3.

künftigen Übels bzw. eines ungesetzlichen Vorteils nicht geradezu unmöglich, da hier die Grenze zwischen zulässigen Hinweisen auf die Rechtslage und Drohung sowie zulässiger Belehrung über den Verfahrensablauf und illegaler Versprechung für Nichtjuristen nicht immer einfach zu erkennen sein dürfte.⁴⁹³ Selbiges gilt für das Hervorrufen einer wirklichkeitsabweichenden Vorstellung bei der beschuldigten Person (Täuschung: «Ihre Kooperation zahlt sich bei der Risikobeurteilung aus.»).⁴⁹⁴ Zwar soll hier nicht der Vorwurf formuliert werden, dass PSY-Sachverständige sich in der Praxis regelmässig und bewusst dieser Methoden bedienen. Es dürfte aber eine vertretbare Aussage darstellen, dass verbotene Beweiserhebungsmethoden seitens des Sachverständigen nicht ausgeschlossen werden können, zumal die Anwendbarkeit von Art. 140 StPO nach h.L. nicht zwingend ein absichtliches Handeln seitens des Sachverständigen voraussetzt, sondern auch Fahrlässigkeit (z.B. wenn der Sachverständige durch eine unabsichtlich falsche Rechtsauskunft bei der beschuldigten Person einen Irrtum hervorruft) genügen kann.⁴⁹⁵

b) *Verbot von Suggestivfragen*

Ungesetzliches Handeln seitens des Sachverständigen ist auch unterhalb der Stufe von Art. 140 StPO möglich. Dies lässt sich an der Thematik der Suggestivfragen illustrieren. Diese stellen nach juristischen Massstäben unzulässige Frageformen dar: Das Verbot ist nach geltender Rechtsprechung zwar «nur» als Ordnungsvorschrift ausgestaltet. Verstösse führen entsprechend nicht automatisch zur Unverwertbarkeit der erlangten Aussagen. Die Einflüsse einer suggestiven Befragung sind aber auf der Ebene der Beweiswürdigung zu berücksichtigen.⁴⁹⁶ Zwar gelten Suggestivfragen auch nach forensisch-psychiatrischer Me-

⁴⁹³ Zu den heiklen Abgrenzungen: BSK StPO-I-GLESS, Art. 140 N 37 ff; ZK StPO-WOHLERS, Art. 140 N 6 ff.

⁴⁹⁴ Täuschend ist in diesem Beispiel, das die Kooperation der beschuldigten Person sich sowohl positiv als auch negative auf die Risikobeurteilung auswirken kann.

⁴⁹⁵ So allgemein zur Fallgruppe der Täuschung: ZK StPO-WOHLERS, Art. 140 N 1 und 10: «Gleiches [gemeint: wie bei der absichtlichen Täuschung] muss aber auch dann gelten, wenn es sich um eine lediglich fahrlässig falsche Erklärung handelt: Das Beweismethodenverbot des Art. 140 begründet keine Prozessstrafe für bewusstes Fehlverhalten der Strafbehörden, sondern soll die Menschenwürde und Subjektstellung der zu vernehmenden Person wahren... Insoweit macht es aber keinen Unterschied, ob das Strafverfolgungsorgan vorsätzlich oder nur fahrlässig falsche Angaben macht.»; gl.M. BSK StPO-I-GLESS, Art. 140 N 48; PETERMANN, S. 1059; a.M. BRODBECK, S. 302.

⁴⁹⁶ EGMR, S.N. v. Sweden, no. 34209/96, § 53, ECHR 2002-V: Nach diesem Entscheid gilt es als Schutzfaktor, wenn das Gericht Suggestivfragen im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt. Diesen Ansatz verfolgt auch das Bundesgericht: BGer, 8. Mai 2014, 6B_1162/2013, E. 1.5; BGer, 24. August 2017,

thodik als grundsätzlich zu vermeidende Grösse.⁴⁹⁷ Trotzdem kann in einer Exploration nicht ausgeschlossen werden, dass die sachverständige Person auf dieses Mittel zurückgreift⁴⁹⁸, zumal im forensisch-psychiatrischen und -psychologischen Schrifttum⁴⁹⁹ nicht mit letzter Deutlichkeit von Suggestivfragen Abstand genommen wird.

c) *Manifestation von Ausstandsgründen*

172 Schliesslich ist in Erwägung zu ziehen, dass sich im Rahmen der unmittelbaren Interaktion zwischen beschuldigter Person und Sachverständigem (d.h. in der persönlichen Interaktion vor, während und nach dem Explorationsgespräch) Ausstandsgründe manifestieren können. So kann der PSY-Sachverständige etwa in der Exploration (in Verletzung der Unschuldsvermutung) explizit oder implizit kundtun, dass er von der erst noch zu erstellenden Tatschuld der beschuligten Person überzeugt ist oder dass er sich bezüglich der erst zu beurteilenden Fachfrage bereits eine endgültige Meinung gebildet hat. Auch kann er auf andere Weise (Gestik, Mimik, abfallende Bemerkungen, harscher Ton etc.) seine Befangenheit zum Ausdruck bringen.⁵⁰⁰ Hier besteht das verteidigungsrechtliche Bedürfnis darin, dass solche Neutralitätsdefizite des Sachverständigen erkennbar gemacht und in einem Ausstandsverfahren effektiv nachgewiesen werden können.

6B_1401/2016, E. 2.2; zur Thematik auch BERNHARD, Jusletter 13. Februar 2012, N 41.

⁴⁹⁷ Vgl. N 168.

⁴⁹⁸ HEER/COVACI, S. 443.

⁴⁹⁹ HAUG, S. 18: «In manchen Lehrbüchern wird fast dogmatisch darauf hingewiesen, dass Suggestivfragen unbedingt zu vermeiden seien. Dies ist aus Sicht des Autors nicht richtig. Suggestive Fragen können sinnvoll, in manchen Situationen sogar notwendig sein.»; sodann KIEGELAND, S. 187: «Ein Konzept anbieten oder Suggestivfragen stellen kann ein Gutachter immer dann, wenn er sehr genau weiss, dass er gerade genau dieses tut. Er ist dann in der Lage, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und die Antwort des Kunden entsprechend zu werten.»

⁵⁰⁰ Zu den Fallgruppen des Ausstands: ZK StPO-DONATSCH, Art. 183 N 16 f.; BSK StPO-I-HEER, Art. 183 N 29; siehe auch BRUNNER, Aspekte, S. 196, der von entsprechenden Erfahrungen seiner Klienten über ausstandsrelevantes Verhalten seitens des PSY-Sachverständigen im Explorationskontext berichtet; illustrativ das Beispiel in KassGer-ZH, 9. Juli 2009, AC080015, E. III.1.c.bb: In diesem Verfahren war umstritten, ob der Sachverständige zu Beginn der Exploration die folgende Aussage getätigt hatte: «Herr X., Sie sind gemeingefährlich.». Wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte die Äusserung den Ausstand des PSY-Sachverständigen bedeutet.

2. Grundannahmen bezüglich des Verteidigungsdispositivs

Nachdem die Überprüfungsbedürfnisse der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung bezüglich des Explorationsgesprächs geklärt sind, gilt es in einem zweiten Schritt zu definieren, mit welchen Verteidigungsrechten diese Überprüfungsbedürfnisse im Verfahren realisiert werden können. Das strafprozessuale Verteidigungsdispositiv der beschuldigten Person im Rahmen des Sachverständigenbeweises ist *prima vista* umfangreich ausgestattet und enthält viele Verteidigungsrechte, welche vom EGMR als fairnesssichernde Instrumente in seiner Praxis berücksichtigt werden.⁵⁰¹ Konkret können folgende Rechte vor oder nach der Begutachtung ausgeübt werden:

173

1. Die beschuldigte Person darf sich zur Person des Sachverständigen sowie zu den Gutachtensfragen äussern (Art. 184 Abs. 4 StPO).
2. Liegen Ausstandsgründe vor, kann der Ausstand des Sachverständigen verlangt werden (Art. 183 Abs. 3 i.V.m. Art. 56 ff. StPO).
3. Nach Erstellung und Einreichung des Gutachtens kann Einsicht in dieses genommen, Stellung dazu bezogen und es können Ergänzungsfragen gestellt werden (Art. 188 StPO).
4. Die beschuldigte Person hat das Recht, die mündliche Befragung des Sachverständigen zu beantragen.⁵⁰²
5. Weiter steht es der beschuldigten Person frei, das Gutachten des PSY-Sachverständigen mithilfe eines Privatgutachters (auch: Privatsachverständigen) zu überprüfen.⁵⁰³

⁵⁰¹ Vgl. N 103 f.

⁵⁰² Die h.L. geht davon aus, dass es sich dabei um ein Recht auf mündliche Befragung des Sachverständigen handelt: BERNHARD/BINDER, S. 9; JEANNERET/KUHN, N 13013; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, N 949 (sofern im Vorverfahren noch keine solche Befragung gewährt wurde); CR CPP-VUILLE, Art. 187 N 4; auch das Bundesgericht scheint in seiner jüngeren Rechtsprechung ein Recht auf mündliche Befragung des Sachverständigen anzunehmen: BGer, 9. März 2017, 6B_100/2017, E. 3.2 f. (anders noch BGer, 13. August 2014, 6B_84/2014, E. 3); ein Teil des Schrifttums will das Recht auf mündliche Befragung des Sachverständigen auf den Fall beschränken, in dem der Sachverständige ein Belastungszeuge i.S.v. Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK ist: BSK StPO-I-HEER, Art. 187 N 5 (in Reibung mit Art. 188 N 3, wo ein Anspruch auf mündliche Befragung stipuliert wird); ZK StPO-DONATSCH, Art. 188 N 8; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1334, wobei die Autoren sich darüber ausschweigen, wann diese Konstellation (Sachverständiger ist Belastungszeuge) vorliegt.

⁵⁰³ DONATSCH, 125 Jahre Kassationsgericht, S. 369; FONJALLAZ/GASSER, S. 119; ISENING/MÜLLER, S. 1335.

6. Schliesslich kann die beschuldigte Person bei Mängeln des Gutachtens (Art. 189 Abs. 1 lit. a-c StPO) die Ergänzung/Verbesserung des Gutachtens beantragen oder den Antrag auf ein Zweitgutachten stellen (Art. 189 Abs. 1 StPO).

- 174 Das Bundesgericht scheint davon auszugehen, dass mit diesen Mitteln «eine effiziente methodische und inhaltliche Kontrolle des psychiatrischen Gutachtens» möglich ist.⁵⁰⁴ Diese Prämisse wird nun unter konventionsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen sein. Dabei darf man es nicht nur bei einer abstrakten Analyse der theoretisch bestehenden Verteidigungsrechte belassen. Vielmehr gilt es, im Rahmen der Gesamtwürdigung (Einzelfallfokus) ein hypothetisches Verteidigungsverhalten anzunehmen: Für die nachfolgende Untersuchung besteht die Hypothese darin, dass die beschuldigte Person und ihre Verteidigung die voranstehenden Verteidigungsrechte im Kontext des Sachverständigenbeweises bestmöglich ausschöpfen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der EGMR bei seiner Fairnessanalyse das konkrete Verteidigungsverhalten der beschuldigten Person beachtet.⁵⁰⁵
- 175 Darüber fusst die vorliegende Untersuchung auf der Annahme, dass sich das Akteneinsichtsrecht der beschuldigten Person nicht nur auf das Gutachten, sondern auch die schriftlichen Arbeitsunterlagen der sachverständigen Person (z.B. Explorationsnotizen) erstreckt. Diese Annahme steht zwar im Widerspruch zur (zurecht kritisierten⁵⁰⁶) bundesgerichtlichen Praxis, dass kein unbedingter Anspruch auf Einsicht in die Arbeitsunterlagen der sachverständigen Person («vorbereitende Arbeitsunterlagen, wie Hilfsmittel für die Erstellung eines Gutachtens, etwa schriftliche Aufzeichnungen über Testergebnisse oder andere Befunde») besteht.⁵⁰⁷ Ein Beizug dieser Unterlagen drängt sich nach dieser Rechtsprechung nur auf, «wenn dies im Einzelfall zur Überprüfung des Sachverständigen-gutachtens in seinen Grundlagen und in seinen Schlussfolgerungen angezeigt

⁵⁰⁴ BGE 144 I 253, E. 3.8.

⁵⁰⁵ Vgl. N 105.

⁵⁰⁶ BSK StPO-I-HEER, Art. 185 N 35 sowie Art. 187 N 10.

⁵⁰⁷ BGer, 12. November 2003, 1P.544/2003, E. 5.3; OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 13, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.: «Ob der Gutachter selber die Explorationsgespräche aufzeichnen möchte, weil ihm dies eine Hilfe wäre (...), ist ihm überlassen und verleiht dem Beschwerdeführer nicht seinerseits einen Anspruch oder ein Einsichtsrecht in diese Aufzeichnungen.»; KassGer-ZH, 18.12.2009, AC080021, E. 1.7.1.c/cc; ZK StPO-DONATSCH, Art. 188 N 2; BSK StPO-I-HEER, Art. 187 N 10; JEANNERET/KUHN, N 13013; SCHMID, AJP 2010, S. 830; CR CPP-VUILLE, Art. 185 N 5; WIPRÄCHTIGER, S. 45; analog die sozialversicherungsrechtliche Praxis: BGer, 22. Mai 2014, 8C_37/2014, E. 2.1; BGer, 4. Juni 2014, 8C_659/2013, 3.2; BGer, 20. Dezember 2010, 9C_591/2010, E. 5.1.2; BGer, 21. Februar 2017, 9C_338/2016, E. 5.2; BGer, 9. November 2017, 8C_466/2017, E. 4.1.2.

erscheint».⁵⁰⁸ Trotzdem rechtfertigt es sich, für die nachfolgende Untersuchung davon auszugehen, dass die beschuldigte Person und ihre Verteidigung auch in schriftliche Arbeitsunterlagen des Sachverständigen Einsicht erhalten. Der Vorteil der so definierten Ausgangslage ist evident: Wenn selbst auf Basis dieses umfassenden Akteneinsichtsrechts ein faires Verfahren nicht gewährleistet werden kann, gilt selbiges a fortiori für weniger optimale Verfahrensumstände.

II. Sachverständiger als imperfekte Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt

Nach der Konkretisierung der Ausgangsvariablen gilt es zu klären, ob das bestehende Verteidigungsdispositiv eine effektive Überprüfung des Explorationsgesprächs (als Bestandteil des Gutachtens) erlaubt. Im 2. Teil dieser Arbeit wurde aufgezeigt, dass die beschuldigte Person die Teilnahme ihrer Verteidigung an der Exploration juristisch nicht erzwingen kann.⁵⁰⁹ Die Verteidigung ist damit nicht unmittelbare Zeugin der Exploration. Trotzdem müssen ihr Kenntnisse über diesen Untersuchungsschritt vermittelt werden, damit sie für die bzw. mit der beschuldigten Person effektiv Stellung zum Gutachten beziehen oder Ausstandsgründe geltend machen kann.⁵¹⁰ Für die Erledigung dieser Aufgabe stehen zwei Informationsquellen zur Verfügung: der PSY-Sachverständige und die beschuldigte Person. Sie sind die unmittelbaren Zeugen der Exploration. Nachfolgend wird sich zeigen, dass der PSY-Sachverständige in verschiedener Hinsicht nur eine imperfekte Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt baut und der Verteidigung damit keinen adäquaten Blick auf das Explorationsgeschehen eröffnet.

176

⁵⁰⁸ BGer, 12. November 2003, 1P.544/2003, E. 5.3 (in E. 5.4 wurde eine Beizugspflicht für die existierende Tonbandaufnahme der aussagepsychologischen Exploration verneint); BGer, 22. Mai 2014, 8C_37/2014, E. 2.1 (in E. 2.2 f. verneint für die Resultate des Uhren- und Mini-Mental-Status-Testes); BGer, 4. Juni 2014, 8C_659/2013, 3.2 (in E. 3.3 verneint für die Notizen des Sachverständigen); BGer, 20. Dezember 2010, 9C_591/2010, E. 5.1.2 (in E. 5.1.3 verneint für die Notizen der Exploration); BGer, 21. Februar 2017, 9C_338/2016, E. 5.2 (verneint für ein Teलगutachten, das in das Gesamtgutachten einfluss); BGer, 9. November 2017, 8C_466/2017, E. 4.1.2 (in E. 4.1.2 ff. verneint für Rohdaten eines Tests); WIPRÄCHTIGER, S. 45.

⁵⁰⁹ Vgl. N 43 ff.

⁵¹⁰ SANER, S. 133 f.

1. Informationsbrücken

177 Die sachverständige Person kann in zweierlei Hinsicht Angaben zum Explorationssachverhalt machen. Erstens erhalten die beschuldigte Person und ihre Verteidigung Einsicht in das vom PSY-Sachverständigen erstellte Gutachten sowie in die schriftlichen Arbeitsunterlagen, wo die Explorationsinhalte dokumentiert sind (A.). Zweitens kann die sachverständige Person nach Erstellung und Einreichung des Gutachtens von der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung zum Explorationssachverhalt befragt werden (B.).

A) Akteneinsicht

a) *Allgemeine Dokumentationspflicht*

178 Ein erstes Mittel der Verteidigung zur Erschliessung des Explorationsinhalts stellt das Akteneinsichtsrecht der beschuldigten Person dar. Damit dieses Recht eine Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt ermöglichen kann, müssen von der sachverständigen Person zuerst Akten erstellt werden. Wie BGE 115 Ia 97 treffend beschreibt: «Das Akteneinsichtsrecht verblasst in seiner Substanz, wo die zur Einsicht offenstehenden Unterlagen lückenhaft sind.»⁵¹¹ Entsprechend gilt für die Strafbehörden eine allgemeine Dokumentationspflicht, gemäss welcher sämtliche verfahrensrelevanten Vorgänge schriftlich festzuhalten sind.⁵¹² Nur wenn dieser Pflicht nachkommen wird, sind die berechtigte Partei sowie die Gerichte in der Lage, das fragliche Beweismittel auf inhaltliche und formelle Mängel zu überprüfen bzw. sind die Parteien befähigt, sich wirksam und sachbezogen zu verteidigen, womit ein wichtiger Beitrag an ein faires Verfahren gewährleistet wird.⁵¹³ Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass auch die sachverständige Person zu einer «umfassenden Dokumentierung der eigenen Erhebungen unter genauer Angabe der entsprechenden Vorkehren sowie der Quellen verpflichtet» ist.⁵¹⁴

⁵¹¹ BGE 115 Ia 97, E. 4c; BINDER, S. 184.

⁵¹² BGE 115 Ia 97, E. 4c; BGer, 14. Februar 2013, 6B_307/2012, E. 3.1; BGer, 19. Februar 2018, 6B_307/2017, E. 1.3.1; BGer, 12. November 2012, 6B_719/2011, E. 4.5; BGer, 18. April 2019, 6B_98/2018, E. 2.3.2.

⁵¹³ BGer, 8. Mai 2006, 1P.399/2005, E. 3.1; BGer, 19. Februar 2018, 6B_307/2017, E. 1.3.1; BGer, 14. Februar 2013, 6B_307/2012, E. 3.1; BGer, 12. November 2012, 6B_719/2011, E. 4.5; BGer, 18. April 2019, 6B_98/2018, E. 2.3.2; BGE 129 I 85, E. 4.1.

⁵¹⁴ BGE 141 IV 34, nicht publizierte E. 4.2; ähnlich auch BGer, 4. Dezember 2015, 6B_424/2015, E. 3.5 mit der Ausführung, der Sachverständige habe «im Gutachten daher darzulegen, von welcher Begriffsbestimmung er bezüglich eines Merkmals ausgeht, an welchen Sachverhalt er im zu beurteilenden Einzelfall diesbezüglich konkret anknüpft und weshalb er das zu beurteilende Item wie bewertet.» sowie die

b) Konkretisierung für das Explorationsgespräch

So klar die Geltung der allgemeinen Dokumentationspflicht für die sachverständige Person im Grundsatz ist, so diffus ist die konkret erforderliche Dokumentations-schärfe für die materiellen⁵¹⁵ Explorationsinhalte ausgestaltet. Nach einer im Schrifttum pointiert kritisierten⁵¹⁶ Gerichtspraxis gilt, dass die Protokollierungsvorschriften der StPO nur auf Strafbehörden, nicht aber auf die Tätigkeit der sachverständigen Person Anwendung finden. Es besteht keine Pflicht der sachverständigen Person, den Explorationssachverhalt nach Art. 76 ff. StPO zu protokollieren oder auf Tonband oder Video aufzuzeichnen.⁵¹⁷ Die Überprüfung des Gutachtensinhalts könne durch die gesetzlichen Gehörsrechte (insb. Art. 188 f. StPO) ausreichend gewährleistet werden.⁵¹⁸ Damit ist geklärt, was nicht erforderlich ist. Zu beantworten bleibt die Frage, welchen konkreten Gehalt die verfassungsrechtliche Dokumentationspflicht des Sachverständigen für das Explorationsgespräch aufweist.⁵¹⁹ Band- oder Videoaufnahmen dürfen vom Sach-

179

Bestätigung dieser Praxis in BGer, 19. Juni 2018, 6B_582/2017, E. 2.2.3; zur Geltung der Dokumentationspflicht für den Sachverständigen auch OGer-ZH, 1. November 2016, SB 160254, E. 3.3.6; FONJALLAZ/GASSER, S. 124; BSK StPO-I-HEER, Art. 185 N 31; HEER, FS Wiprächtiger, S. 193; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1329; SCHMID, AJP 2010, S. 830.

⁵¹⁵ Mit «materiell» ist gemeint, was in der Exploration gesagt wurde oder wie sich die Teilnehmer verhielten. Relativ klar fällt die Interpretation der Dokumentationspflicht für die formellen Explorationsinhalte wie die Belehrung (SCHMID, AJP 2010, S. 830), die Angabe der Explorationsdauer (vgl. KassGer-ZH, 7. Februar 2006, AC050057, E. 3.7.c.) oder der Beizug von Hilfspersonen (vgl. Art. 187 Abs. 1 StPO sowie BGE 144 IV 176, E. 4.5.2) aus. Weiterführend: OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II.11, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.; BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 537 ff.; BOETTICHER ET AL., NStZ 2005, S. 58 ff.; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 1 ff.

⁵¹⁶ BINDER, S. 238; BSK StPO-I-HEER, Art. 185 N 31; BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64b; HEER, FS Wiprächtiger, S. 193 «Bei der Exploration sind alle Angaben des Exploranden festzuhalten, eine Beschränkung auf Teile davon ist unzulässig.»; BERNHARD/BINDER, S. 12 f.; SANER, S. 137 f.

⁵¹⁷ BGer, 24. September 2018, 6B_276/2018, E. 1.4.2; BGE 144 I 253, E. 3.7; OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II.9 und 10a, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.; OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II.4.1; OGer-BE, 30. März 2011, SK-10 387, E. 3f.; OGer-ZH, 18. November 2014, SB140071, E. II.1 ; unter kantonalem Verfahrensrecht: KassGer-ZH, 18. September 2006, AC050083, E. III.3.3d; KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/cc: «Im Bereich der Schuldfähigkeitsbeurteilungen werden Tonbandmitschnitte von Explorationsgesprächen als verzichtbar erachtet.»; SCHMID, AJP 2010, S. 830; HEER/COVACI, S. 442.

⁵¹⁸ OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 12, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.

⁵¹⁹ Angesichts der unklaren Vorgaben seitens der Rechtsprechung wird es kaum überraschen, dass die Dokumentationsqualität in der Praxis oft als unzureichend bezeichnet wird, vgl. HEER/COVACI, S. 442 f.

verständigen zwar verwendet werden. Sie haben aber noch keinen generellen Eingang in die Praxis erhalten; es gilt das Primat der schriftlichen Dokumentation.⁵²⁰ Auf dieser Annahme (Schriftlichkeit der Dokumentation) fusst auch die vorliegende Untersuchung. Bei der konkreten Ausgestaltung der Schriftdokumentation ist zu differenzieren, ob es sich um die Angaben des Probanden (aa) oder Fremdbeurteilungsebenen (bb) handelt.

aa) *Angaben des Exploranden*

- 180 Eine erste Informationsquelle stellen die Angaben der begutachteten beschuldigten Person in der Exploration dar, wie sie im Rahmen der Anamnese, des psychischen Befunds, der Tatschilderung sowie der Erläuterung allfälliger Zukunftsszenarien anfallen.⁵²¹ Dabei gilt der Grundsatz, dass aus dem Gutachten deutlich werden muss, «welche Angaben des Beschuldigten als Anknüpfungstatsachen zu Grunde gelegt wurden».⁵²² Die konkrete Dokumentationsschärfe wird aus dieser Vorgabe jedoch noch nicht ersichtlich. Klar ist nach der Gerichtspraxis einzig: Die Aussagen des Exploranden sind weder im Gutachten noch in dessen Anhang vollständig zu protokollieren.⁵²³ Ansonsten gilt es, relativ ausführlich mitzuschreiben.⁵²⁴ Angaben des Exploranden, welche von erkennbar grosser Bedeutung für das Gutachten sind, sollen möglichst wortgetreu (als Zitat) dokumentiert werden.⁵²⁵ Weitere Angaben können hingegen stich-

⁵²⁰ MAIER/MÖLLER, S. 193 f.; aufgenommen in KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/cc; OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 11, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17: «Sehr selten bitten Probanden um eine Bandaufnahme des Untersuchungsgesprächs. Ihr Wunsch sollte unter Einschaltung des Auftraggebers und unter Berücksichtigung des persönlichen Stils des Sachverständigen geklärt werden. Eine generelle Ablehnung ist ebenso wenig sachgerecht wie eine generelle Forderung nach einem solchen Vorgehen.»; Kröber et al.-II-KRÖBER, S. 167.

⁵²¹ Vgl. N 12 ff.

⁵²² BOETTICHER ET AL., NStZ 2005, S. 58; BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 539; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 4 ff.

⁵²³ BGer, 30. März 2010, 6B_92/2010, E. 3.3; OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II.4.1.

⁵²⁴ KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/cc; MAIER/MÖLLER, S. 194; MOKROS ET AL., S. 22.

⁵²⁵ KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/cc mit Verweis auf MAIER/MÖLLER, S. 194; OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 11, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff. ««Im schriftlich zu erstattenden Gutachten wird der Gutachter die für die Beantwortung der ihm gestellten Fragen wesentlichen Aussagen des Beschwerdeführers in den Explorationsgesprächen – so dieser denn mitwirkt – zur Begründung seiner psychiatrischen Schlussfolgerungen aufführen. Damit wird der strafprozessualen Dokumentationspflicht insoweit genügt»»; extensiv sodann teilweise die sozialversicherungsrechtliche Praxis in BGer, 4. August 2016, 9C.410/2016, E. 2.2.1, wonach Aussagen der explorierten Person im Gutachten soweit möglich

wortartig notiert werden.⁵²⁶ Was aus diesen Leitlinien hervorgeht, ist das Folgende: Die sachverständige Person fertigt eine inhaltszentrierte (d.h. auf die gutachtensrelevanten Aspekte fokussierte) Niederschrift an, bei deren Ausgestaltung ihr ein grosses Ermessen zukommt.⁵²⁷

bb) *Fremdbeurteilungsebenen*

Neben den Angaben der Probanden sind auch jene Explorationsinhalte zu dokumentieren, welche der Sachverständige durch die Beobachtung des Exploranden erschliesst, wie es namentlich beim psychischen Befund oder der Beschreibung der Persönlichkeit des Exploranden der Fall ist.⁵²⁸ Der Sachverständige hat auch solche Wahrnehmungen bezüglich des Exploranden zu dokumentieren, wobei auch hier Ermessensspielräume bestehen.⁵²⁹ Methodisch stehen dem Sachverständigen zwei Möglichkeiten (welche kombiniert eingesetzt werden können) zur Verfügung. Erstens kann er den Befund oder die Persönlichkeit des Exploranden frei beschreiben.⁵³⁰ Zweitens werden in der Praxis regelmässig standardisierte Dokumentationssysteme angewendet. Neben standardisierten Diagnose- und Prognoseinstrumenten⁵³¹ ist für die Befunderhebung das AMDP-System von hoher Praxisrelevanz⁵³². Bei letzterem können auf vorgefertigten

wortgetreu oder in ihrem tatsächlich gemeinten Sinn wiederzugeben sind; weniger weitgehend hingegen BGer, 30. Januar 2012, 9C_784/2011, E. 2.2, gemäss welchem ein Protokoll oder eine «ausführliche Notiz» als ausreichend beurteilt wurde; vgl. auch KIEGELAND, S. 247; TONDORF/TONDORF, N 351.

⁵²⁶ HAUG, S. 136; FÄHNDRICH /STIEGLITZ, S. 52, welche in diesem Zusammenhang sogar dazu raten, während dem Gespräch möglichst nicht mitzuschreiben und höchstens Stichworte als Gedächtnisstütze zu verwenden; aus juristischer Sicht sodann ALIOTTA, Diss., S. 405; SCHMID, AJP 2010, S. 830; BGer, 30. Januar 2012, 9C_784/2011, E. 2.2.

⁵²⁷ Kröber et al.-II-KRÖBER, S. 167; TONDORF/TONDORF, N 351; zum Ermessenselement auch NEDOPIL, FPPK 2012, S. 222; FASTENMEIER, S. 85; KIEGELAND, S. 248; Kröber et al.-III-KRÖBER, S. 104; ZOEHNER ET AL., S. 225; HAUG, S. 136: «Es gibt keine allgemein gültigen Regeln zu der Frage von Notizen während der Untersuchungen»; ähnliche Dokumentationsprinzipien gelten auch im internationalen Kontext (in casu: USA): AAPL TASK FORCE, S. 2 «...most forensic psychiatrists take copious notes during the interviews and/or dictate notes shortly after the interviews so as to preserve impressions and data»; illustrativ zur Dokumentationsdichte die Beispielgutachten von NEDOPIL/KRUPINSKI, S. 1 ff.

⁵²⁸ Dazu auch N 14.

⁵²⁹ OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 6 f.; BOETTICHER ET AL., NStZ 2005, S. 59; BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 541; illustrativ zur Dokumentationsdichte die Beispielgutachten von NEDOPIL/KRUPINSKI, S. 1 ff.

⁵³⁰ HAUG, S. 137; implizit auch OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 4 ff.

⁵³¹ NEDOPIL, FPPK 2012, S. 223.

⁵³² OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 6 f.; HAUG, S. 137; AEBI ET AL., S. 1470; KONRAD/RASCH, S. 338; FINZEN, S. 67; BESSLER, SZK 2/2007 S. 30; MÜLLER/NEDOPIL, S.

Dokumentationsbögen die im Rahmen der Exploration erkannten psychopathologischen Merkmale des Exploranden (z.B. «deprimiert», «ängstlich» oder «antriebsarm») erfasst und quantifiziert werden («nicht vorhanden», «leicht», «mittel ausgeprägt», «schwer», «keine Aussage»)⁵³³

B) Befragung des PSY-Sachverständigen

182 Neben der Akteneinsicht haben die beschuldigte Person und ihre Verteidigung nach Erstellung des Gutachtens das Recht, die mündliche Befragung des Sachverständigen zu beantragen. Im Rahmen dieser Einvernahme kann auch der Explorationsinhalt thematisiert werden. Mit dieser Möglichkeit – soweit die Idee der Gerichtspraxis – wird es der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung ermöglicht, allfällige Unklarheiten der schriftlichen Explorationsdokumentation zu thematisieren und allenfalls aufzuklären.⁵³⁴

2. Imperfektion der Informationsbrücken

183 Sowohl die schriftliche Dokumentation des PSY-Sachverständigen als auch seine Antworten im Rahmen einer allfälligen Einvernahme sind imperfekte Informationsbrücken zum Explorationssachverhalt. Der Grund für diese These liegt darin, dass es sich bei der gutachterlichen Rapportierung des Explorations-sachverhalts immer um die Wiedergabe der subjektiven Wahrnehmung des Sachverständigen von der Exploration handelt. Ist dies aber der Fall, können allgemeine Verzerrungseffekte (A.), unbewusste Filterungs- und bewusste Selektionseffekte (B.), die lückenhafte Erfassung des eigenen Explorationsverhal-

113; FONJALLAZ/GASSER, S. 133 inkl. Fn. 101; GRAF, Fremdanamnese, S. 59; FÄHNDRICH /STIEGLITZ, S. 14; Es wird keineswegs ignoriert, dass andere Möglichkeiten der Befunddokumentation als das Vorgehen nach AMDP bestehen wie z.B. das von Nedopil entwickelte, auf das AMDP aufbauende Forensisch-psychiatrische Dokumentationssystem (FPDS): dazu NEDOPIL/GRASSL, S. 139 ff.; NEDOPIL, FPPK 2012, S. 222; Venzlaff et al.-SCHREIBER/ ROSENAU, S. 109; BESSLER, SZK 2007 S. 30; darüber hinaus werden Explorationsinhalte auch im Rahmen der Anwendung von standardisierten Diagnose- und Prognoseinstrumente dokumentiert. Dazu NEDOPIL, FPPK 2012, S. 223.

⁵³³ Dazu der Musterdokumentationsbogen in AMDP, S. 175 ff.; Diese Standardliste kann mit fakultativen Reservemerkmale sowie einigen Zusatzmerkmalen ergänzt werden (AMDP, S. 120 ff.).

⁵³⁴ OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 13, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.: «Soweit der Gutachter aufgeführte Aussagen des Beschwerdeführers nicht wörtlich wiedergibt, sondern als zusammenfassenden Sinn von Aussagen des Beschwerdeführers, kann er, wenn sich der Beschwerdeführer dabei missverstanden fühlt, dazu befragt werden, und ist dies auf diese Weise nachvollziehbar. Das gilt auch für die Stimmung der Explorationsgespräche, soweit diese für das Gutachten relevant ist.»; HABERMEYER/SACHS, N 8; LAEMMEL, S. 253; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 458 f.

tens (C.) sowie die Vergessenskurve (D.) dazu beitragen, dass das Explorationsgeschehen nicht adäquat abgebildet wird.⁵³⁵

A) Verzerrungseffekte

In den Augen mancher Verfahrensbeteiligter mag die gutachterliche Beschreibung der zu begutachtenden Person bzw. des Explorationssachverhalts als objektive Grösse erscheinen.⁵³⁶ Dies ist nur allzu verständlich: Der mit dem Sachverständigenbeweis verbundene Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und das Neutralitätserfordernis wecken berechnete Objektivitätserwartungen.⁵³⁷ Es besteht kein Zweifel daran, dass die gutachterliche Schilderung der Explorationsinhalte die grösstmögliche Objektivität zum Ziel haben sollte und dass der überwiegende Teil der Sachverständigen nach dieser Maxime arbeiten wird.⁵³⁸ Nachfolgend soll folglich nicht das dunkle Bild des vorsätzlich falschbegutachtenden Sachverständigen als Massstab genommen werden. Ein solches Vorgehen wäre polemisch und würde die Realität der Begutachtungspraxis nur zu einem winzigen Teil repräsentieren.⁵³⁹ Allerdings darf trotz der Annahme eines neutralen, auf Objektivität bedachten Sachverständigen nicht der Schluss gezogen werden, dass die sachverständige Schriftdokumentation oder die Aussage des Sachverständigen im Rahmen der Befragung den Exploranden und dessen Persönlichkeit objektiv wiedergeben.⁵⁴⁰ Vielmehr handelt es sich bei der gutachterlichen Dokumentation um die subjektive Wahrnehmung des PSY-Sachverständigen vom Exploranden und von der Exploration.⁵⁴¹

⁵³⁵ Im Kern handelt es sich bei den nachfolgend beschriebenen Fallgruppen um Problemfelder, welche im Rahmen der aussagepsychologischen Forschung bekannt sind (eingehend dazu BERLINGER, S. 1 ff.). Die sachverständige Person muss den Explorationssachverhalt wahrnehmen, speichern und in ihrem Gutachten oder im Rahmen der Aussage vor Gericht reproduzieren. Dabei kann es auf sämtlichen Ebenen zu unbewussten oder bewussten Falschaussagen kommen (vgl. allgemein auch BAUMER/LUDEWIG/TAVOR, S. 1419). Nachfolgend sollen nicht all diese Aspekte aufgegriffen werden. Vielmehr wird der Fokus auf einige zentrale Gesichtspunkte gelegt, welche zu einer verzerrten oder lückenhaften Sachverhaltsschilderung seitens des beitragen können.

⁵³⁶ STIELS-GLENN, S. 137 f.

⁵³⁷ Vgl. N 155.

⁵³⁸ FONJALLAZ/GASSER, S. 133.

⁵³⁹ In der Sache auch HEER/COVACI, S. 443.

⁵⁴⁰ Vgl. dazu auch N 156 ff.

⁵⁴¹ STIELS-GLENN, S. 133; TONDORF/TONDORF, N 16 und 351; allgemein zur zur Tatsache, dass die Rapportierung eines historischen Sachverhalts nie objektive Tatsachen, sondern subjektive Wahrnehmungen bzw. Interpretationen davon beinhalten BERNHARD, SO/2014, S. 16; HUNKELER, N 25 f.; MELUNOVIC, S. 600: «Das Erzählte ist somit a priori keine Kopie des Erlebten. Es ist bereits ein Surrogat.»

a) *Zerrspiegel der Persönlichkeit*

- 185 Der PSY-Sachverständige nimmt den Explorationssachverhalt durch den Zerrspiegel seiner Persönlichkeit wahr, wobei seine eigene Biographie (Sozialisierung, Ausbildung, Karriere), die Persönlichkeit im Untersuchungszeitpunkt (inkl. Normen und Werte), die Lebenssituation (Hunger, Gesundheit, Stress) oder sonstige Explorationsvariablen (Berücksichtigung von Aggravation/Simulation, Schweigerecht, Sympathie und Antipathie mit dem Exploranden) nolens volens auf den Wahrnehmungs- und Interpretationsprozess des Sachverständigen einwirken.⁵⁴² Als Folge kann es in der Interaktion mit dem Exploranden zu verzerrten Wahrnehmungen seitens des PSY-Sachverständigen kommen, welche anerkanntermassen potentielle Fehlerquellen eines Gutachtens sind.⁵⁴³
- 186 Diese Verzerrungseffekte bezüglich des Exploranden können sich über sämtliche Erhebungsdimensionen in der Exploration manifestieren; sie sind zuweilen sogar auf die sachverständige Person selbst und die von ihr ausgesendeten Signale rückführbar.⁵⁴⁴ Diese Effekte können sich auf die Explorationsdokumentation auswirken. So kann der Aussageinhalt des Exploranden vom Sachverständigen ganz oder teilweise falsch verstanden werden.⁵⁴⁵ Sodann gibt die Schriftdokumentation diverse Kontextvariablen (Verhaspelungen, Mundart, Sprechpausen, Tempo, Lautstärke) nicht oder nur ungenau wider; es findet regelmässig eine durch den Sachverständigen erfolgende Glättung oder Filterung der tatsächlichen Befragungsinhalte statt.⁵⁴⁶
- 187 Noch akzentuierter gestaltet sich die hier beschriebene Problematik bei der Beschreibung des Exploranden. Ob eine Person z.B. «aggressiv» ist, einen «oberflächlichen Charme» hat oder sonstige Persönlichkeitsmerkmale aufweist, öffnet sich im Rahmen der sachverständigen Einschätzung weiten Bewertungsspielräumen. Es ist folglich nicht undenkbar, dass die gutachterliche Verhaltensbeschreibung (z.B. «sexualisiertes Verhalten») aufgrund der erwähnten Verzer-

⁵⁴² FONJALLAZ/GASSER, S. 105; GRAF, Fremdanamnese, S. 62 f.; KIEGELAND, S. 92; KONRAD/RASCH, S. 338; LAEMMEL, S. 250 f.; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1251a; SAIMEH, S. 60 f.; STIELS-GLENN, S. 133 f.; WAGNER/KRANICH, S. 6 ff.; WESTHOFF/KLUCK, S. 67 und 122 ff.; US Court of Appeals, District of Columbia Circuit, United States v. Byers, 740 F2d 1104, Dissent Bazelon, N 222.

⁵⁴³ GRAF, Fremdanamnese, S. 62; KIEGELAND, S. 178; LAEMMEL, S. 250 f.; WESTHOFF/KLUCK, S. 67; eine umfassende Architektur der potentiellen Verzerrungsfaktoren findet sich bei ZAPF/DROR, S. 1 ff.; US Court of Appeals, District of Columbia Circuit, United States v. Byers, 740 F2d 1104, Dissent Bazelon, N 222.

⁵⁴⁴ Illustrativ dazu KIEGELAND, S. 180 ff. und S. 186 ff.; WAGNER/KRANICH, S. 6 f.

⁵⁴⁵ CECI/BRUCK, S. 10 f.; KIEGELAND, S. 98 ff.

⁵⁴⁶ PRÜFER, S. 99; so auch die Überlegungen zum Schriftprotokoll bei Einvernahmen: CAPUS, BJM 2012, S. 175 f.; CAPUS, «Justice - Justiz - Giustizia» 2014/3, N 16; KAUFMANN, S. 118 ff.; WEDER, S. 549.

rungseffekte an der Realität bzw. am konkreten Exploranden vorbeigeht.⁵⁴⁷ Dieser Umstand wird zuweilen mit der pointierten Aussage beschrieben, dass man aus der gutachterlichen Beschreibung des Exploranden mehr über den Gutachter als den konkreten Exploranden erfahre.⁵⁴⁸

b) *Selbstreflexion als imperfektes Korrektiv*

Dem PSY-Sachverständigen sind die referierten Verzerrungseffekte zwar bewusst und sie werden ihn nicht am grundsätzlichen Wert der Exploration als Erkenntnismittel zweifeln lassen.⁵⁴⁹ Als Korrektiv wird er bei methodisch einwandfreiem Vorgehen versuchen, sich ständig kritisch zu hinterfragen (Selbstreflexion).⁵⁵⁰ Er muss «die emotionale Wechselwirkung zwischen dem Exploranden und sich selbst, die Motivation des Exploranden sowie die Aspekte der Abwehr, Übertragung und Gegenübertragung reflektieren»⁵⁵¹, um zu vermeiden, dass diese unbedacht Eingang in die Beurteilung finden.⁵⁵² Vernachlässigt er diese Aufgabe, besteht die Gefahr, die Objektivität seines Gutachtens aufs Spiel zu setzen, da so seine (unreflektierte) emotionale Reaktion ins Gutachten einfließt.⁵⁵³ Anders gewendet: Mangelnde Selbstreflexion kann zu kommunikativen Störsignalen zwischen den Gesprächsbeteiligten führen, welche dann vom Sachverständigen nur allzu schnell dem Exploranden zugeschrieben werden, was wiederum zur gutachterlichen Einschätzung des Exploranden als «aggressiv», «wortkarg» usw. führen kann, ohne dass diese Einschätzung für Aussen-

188

⁵⁴⁷ SAIMEH, S. 61.

⁵⁴⁸ KONRAD/RASCH, S. 338; ähnlich KRÖBER, FPPK 2015-B, S. 102.

⁵⁴⁹ WAGNER/KRANICH, S. 8: «Durch die zuvor dargestellten Fehlerquellen ist die Methode der psychologischen Exploration nicht etwa in ihrem Bedeutungsgehalt für die zu stellende Verhaltensprognose abgewertet, vielmehr erfordert diese Form des qualifizierten und zielgerichteten Dialogs einen professionellen Umgang mit diesen unerwünschten Einflussfaktoren.»

⁵⁵⁰ BROWN, S. 91; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; DEITMARING, S. 108; FONJALLAZ/GASSER, S. 132 f. inkl. Fn. 100; KIEGELAND, S. 180; LAEMMEL, S. 250; LITTMANN, S. 91; STIELS-GLENN, S. 134; allgemein zur hilfreichen Funktion der Selbstreflexion im Kommunikationsprozess: HUNKELER, N 80.

⁵⁵¹ BGE 137 V 210, E. 6.1.2.

⁵⁵² EBNER ET AL., S. 450 f.; Venzlaff et al.-FOERSTER/DRESSING, S. 6 und 18; LAEMMEL, S. 250 f.; MARELLI, S. 81 f.; MÜLLER/NEDOPIL, S. 411.

⁵⁵³ BGE 137 V 210, E. 6.1.2 in dem das Bundesgericht zurecht ausführt, das sein Gutachten ohne entsprechende Berücksichtigung nicht lege artis erstellt ist; Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 6 und 18; FELTHOUS/SASS, S. 136.

stehende (die weder an der Exploration teilnehmen noch diese auf Video zur Kenntnis nehmen können) überprüfbar wäre.⁵⁵⁴

- 189 Die Möglichkeiten der gutachterlichen Selbstkontrolle dürfen indes – anders als im Schrifttum zuweilen angedeutet⁵⁵⁵ – nicht zu optimistisch bewertet werden. Objektivität soll vom Sachverständigen zwar als *Maxime* angesehen werden, ist aber selbst bei bestem Bemühen nur unvollständig zu erreichen.⁵⁵⁶ Es ist bereits unklar, ob der konkrete Sachverständige in der Lage ist, allfällige Verzerrungseffekte bei sich auszumachen. In mehreren Studien konnte aufgezeigt werden, dass Sachverständige ihren Berufskollegen mehr kognitive Verzerrungen zuschreiben als sich selbst (so. *blind spot bias*).⁵⁵⁷ Selbst wenn man eine selbstreflexive Haltung des konkreten Sachverständigen supponiert, ist damit keine Garantie für die Objektivität seiner Explorationsschilderung geschaffen. Diverse Untersuchungen legen nahe, dass Introspektion (trotz der Beliebtheit des Mittels) eine ineffektive Strategie zu sein scheint, um Verzerrungseffekten entgegenzuwirken.⁵⁵⁸ Entsprechend kann Selbstreflexion nur beschränkt als Korrektiv in die Diskussion eingeführt werden.⁵⁵⁹ Elementar ist ohnehin die folgende Erkenntnis: Selbst wenn man die Effektivität der Selbstreflexion als Korrektiv annehmen würde, müsste von der Verteidigung überprüft werden können, dass die sachverständige Person dieses Mittel angewendet hat. Genau hier bestehen verteidigungsrechtliche Grenzen: Die gutachterliche Selbstkontrolle ist ein subjektiver Prozess, dessen fachgerechte Anwendung durch den Sachverständigen von Seiten der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung nur dann überprüft werden kann, wenn eine objektive Sicht auf den Explorationssachverhalt existiert. Genau diese objektive Sicht auf den Explorationssachverhalt kann die sachverständige Dokumentation, welche die subjektive Wahrnehmung des Sachverständigen spiegelt, jedoch nicht bieten.

⁵⁵⁴ STIELS-GLENN, S. 138 f.; FONJALLAZ/GASSER, S. 105 ff. führen in diesem Zusammenhang zurecht die positiven Effekte von Super- und Intervision im Begutachtungskontext auf.

⁵⁵⁵ FONJALLAZ/GASSER, S. 132 f. inkl. Fn. 100; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1251a.

⁵⁵⁶ TONDORF/TONDORF, N 16; ZAPF/DROR, S. 2: «...unbiased and impartial examinations (forensic science) and evaluations (forensic mental health) are aspirational in nature and that, because examiners/evaluators are human, it is impossible to eliminate all bias.»

⁵⁵⁷ NEAL/BRODSKY, S. 69 f.; PRONIN/KUGLER, S. 575; ZAPF ET AL., S. 7; ZAPALLA ET AL., S. 45 ff.

⁵⁵⁸ NEAL/BRODSKY, S. 72 f.; PRONIN/KUGLER, S. 576; ZAPALLA ET AL., S. 45 ff.

⁵⁵⁹ Der Vollständigkeit ist anzufügen, dass in der Literatur auch erfolgsversprechendere Debiasing-Strategien diskutiert werden (dazu weiterführend NEAL/BRODSKY, S. 69 m.w.N.).

B) Informationsfilterung und -selektion

Neben den voranstehend erwähnten Verzerrungseffekten (oder damit verbunden) können unbewusste Filterungs- und bewusste Selektionsprozesse seitens des Sachverständigen auf die Explorationsschilderung einwirken. Die gutachterliche Dokumentation erweist sich wegen diesen Gesichtspunkten immer nur als ein unbewusst bzw. bewusst skizzierter Ausschnitt des Explorationssachverhalts.⁵⁶⁰

a) Informationsverlust durch unbewusste Filterung

Der PSY-Sachverständige sieht sich in der Exploration mit einer Fülle komplexer, gleichzeitig auszuführender Aufgaben konfrontiert. Er hat mit zahlreichen Fragen Informationen vom Exploranden zu erheben, soll gleichzeitig dessen Verhalten beobachten, muss die Exploration steuern, hat sich seiner emotionalen Reaktion auf den Exploranden bewusst zu werden (Selbstreflexion) und ist überdies verpflichtet, die wesentlichen Explorationsinhalte handschriftlich zu dokumentieren. Dabei kann der vom Exploranden ausgehende, konstante und voluminöse Informationsfluss nie umfassend vom Sachverständigen aufgenommen und dokumentiert werden: Es sind schlicht zu viele parallele Tätigkeiten für den Sachverständigen, welcher zwangsläufig den Explorationssachverhalt unbewusst filtert, woraus die Gefahr des unbewussten Informationsverlusts erwächst.⁵⁶¹

Dabei können bereits die voranstehend referierten Verzerrungseffekte eine Rolle spielen.⁵⁶² Es ist in einem gewissen Ausmass zu erwarten, dass der Sachverständige in erster Linie das speichert, «was in das Raster persönlicher Vorerfahrungen, Meinungen und möglicherweise auch Vorurteile passt».⁵⁶³ Das verteidigungsrechtliche Problem liegt nun darin, dass von der Verteidigung nur äusserst limitiert überprüft werden kann, ob solche Filterungsprozesse zum Auslassen

⁵⁶⁰ Treffend KIEGELAND, S. 103: «...wird deutlich, dass die Explorationsmitschrift – und sei sie noch so genau – stets nur eine Teilmenge der übermittelten Informationen enthalten kann...»; WAGNER/KRANICH, S. 7 f.; zur gleich gelagerten Problematik bei Einvernahmeprotokollen auch CAPUS, «Justice - Justiz - Giustizia» 2014/3, N 15 mit ausführlicher Berücksichtigung diverser Studien.

⁵⁶¹ BROWN, S. 89; HAYS, S. 571; ZOEHNER ET AL., S. 225 f.; dieser Aspekt mag in jenen Fällen weniger ausgeprägt sein, wo Hilfskräfte des Sachverständigen in der Exploration anwesend sind und Notizen für den PSY-Sachverständigen anfertigen; interessant auch PICHINI, S. 163 f., der darauf hinweist, dass im Gutachten diverse Faktoren eines Explorationsgeschehens nicht oder unzureichend ersichtlich sind (z.B. Suggestionseinflüsse usw.).

⁵⁶² Vgl. N 184 ff.

⁵⁶³ KONRAD/RASCH, S. 338; ähnlich auch ALIOTTA, Diss., S. 397; CECI/BRUCK, S. 10 ff.

von u.U. relevanten Explorationsinformationen geführt haben. Der Grund dafür ist simpel: Der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung liegt nur das Resultat des Filterungsprozesses (die Notizen, das Gutachten, die Aussage des Sachverständigen) vor. Die Vergleichsgrundlage für die Überprüfung – ein authentisches Bild der Exploration – fehlt jedoch.⁵⁶⁴

b) Informationsverlust durch bewusste Selektion

193 Selbst wenn die sachverständige Person in der Lage wäre, sämtliche Informationen zu registrieren, findet ein potenziell über mehrere Stunden andauerndes Explorationsgespräch nie vollständigen Eingang ins Gutachten. Vielmehr wird vom Sachverständigen nach seinem fachlichen Ermessen bestimmt, welche Informationen für das Gutachten erheblich sind.⁵⁶⁵ Dieser Selektionsprozess ist sinnvoll und soll an dieser Stelle nicht prinzipiell in Frage gestellt werden. Es wäre kaum zielführend, wenn der PSY-Sachverständige sämtliche Explorationsereignisse schildern würde, selbst wenn sie für die Beurteilung der Fragestellung nicht relevant sind. Trotzdem birgt dieses Vorgehen das Problem der Überprüfbarkeit mit sich: Ob aus dem Explorationssachverhalt alles für die Gutachtensfragen Relevante berücksichtigt wurde, lässt sich aus der gutachterlichen Schilderung (den Notizen, dem Gutachten, der mündlichen Aussage) nicht erkennen, da die Dokumentation nur das Resultat des Selektionsprozesses darstellt. Es fehlt der Verteidigung der notwendige Blick auf die «Rohdaten» der Exploration, um ihre Überprüfung effektiv vornehmen zu können.⁵⁶⁶

C) Dokumentationsfokus auf den Exploranden

194 Sodann ist zu bedenken, dass die sachverständige Person ihre Dokumentation vor allem auf die vom Exploranden erhobenen Informationen fokussieren wird. Das Verhalten des Sachverständigen in der Exploration findet hingegen bestenfalls marginalen Niederschlag in der Dokumentation des Sachverständigen. Unter Umständen werden sich anhand der Dokumentation (Explorationsnotizen, Verwendung von standardisierten oder halbstandardisierten Interviews usw.) noch ein Teil des Explorationsablaufs und Fragmente der sachverständigen Gedanken während der Exploration rekonstruieren lassen. Ob aber die sachverständige Person bei ihren Erhebungen korrekt vorgegangen ist (psychiatrisch-methodisch einwandfreies Vorgehen, Nichtanwendung verbotener Beweiserhebungsmethoden etc.), lässt sich ihrer Dokumentation kaum oder gar nicht entnehmen. Der Grund dafür ist simpel: Wenn sich die sachverständige Person allfälliger methodisch-juristischer Fehler nicht bewusst ist, was hier als Regelfall

⁵⁶⁴ ZOEHNER ET AL., S. 226.

⁵⁶⁵ MAIER/MÖLLER, S. 194.

⁵⁶⁶ ZOEHNER ET AL., S. 226.

angenommen wird, hat sie gar nicht die Möglichkeit, den diesbezüglichen Protokollierungsbedarf festzustellen. Noch klarer ist der (Ausnahme)fall bei (eventual-)vorsätzlichen Regelverstössen seitens des Sachverständigen: Hier wird die sachverständige Person schlicht kein Interesse daran haben, ihr regelwidriges Verhalten zu dokumentieren.

D) Vergessenskurve

Schliesslich ist auf einen Aspekt einzugehen, welcher im Nachgang der Gutachtererstellung von Bedeutung ist. Wenn der Sachverständige in diesem Stadium zum Explorationssachverhalt befragt wird, muss er eine Erinnerungsleistung vollbringen. Neben den bereits geschilderten Verzerrungseffekten ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass sich die sachverständige Person in vielen Fällen nicht mehr oder nicht mehr präzise an das Explorationsgeschehen erinnern wird.⁵⁶⁷ Dabei handelt es sich nicht um eine theoretische Befürchtung. Es konnte in mehreren Experimenten aufgezeigt werden, dass Menschen (auch spezialisierte Befrager) bereits nach verhältnismässig kurzer Zeit grosse Schwierigkeiten haben, einen Gesprächsinhalt akkurat wiederzugeben und dass sich bei diesen Schilderungen durchaus substantielle Fehler (Vergessen von einzelnen Informationen, Einfügen von nicht geschehenen Tatsachen usw.) einschleichen.⁵⁶⁸

3. Zwischenfazit

Der PSY-Sachverständige muss zwar keine formelle Protokollierung des Explorationsinhalts nach Art. 76 ff. StPO vornehmen. Zur Dokumentation seiner Erhebungen ist er aber durch den allgemeinen Dokumentationsgrundsatz verpflichtet. Nach forensisch-psychiatrischen Standards findet dabei i.d.R. eine vom gutachterlichen Ermessen gesteuerte, inhaltszentrierte Aufzeichnung der Explorationsinhalte in Schriftform statt. Dabei werden zentrale Angaben des Probanden wörtlich, andere Aussagen stichwortartig festgehalten. Die Schilderung des Befunds sowie der Persönlichkeit des Exploranden erfolgt durch einen freien Bericht und/oder mittels standardisierter Methoden (z.B. AMDP-System). Wird der Sachverständige überdies von der beschuldigten Person nach Erstellung des Gutachtens befragt, kann er nachträglich Angaben zum Explorationsgeschehen machen.⁵⁶⁹

⁵⁶⁷ Zur Vergessenskurve: BAUMER/LUDEWIG/TAVOR, S. 1419.

⁵⁶⁸ Illustrativ dazu: CECI/BRUCK, S. 10 ff.

⁵⁶⁹ Vgl. für den gesamten Abschnitt N 179 ff.

197 Die gutachterliche Schriftdokumentation sowie die allfällige mündliche Aussage werden vom Sachverständigen zwar im Regelfall mit dem Anspruch auf Objektivität verfasst bzw. abgegeben. Dennoch kann sich aus ihnen ein unvollständiges Bild der Exploration ergeben. Für die Verteidigung ist nicht effektiv überprüfbar, ob die gutachterliche Beschreibung der beschuldigten Person und deren Aussagen durch den Sachverständigen zutreffen oder ob sie das Resultat einer verfälschten Wahrnehmung seitens des Sachverständigen darstellen. Ebenso ist für die Verteidigung nicht zu erschliessen, ob alles Relevante aus der Exploration rapportiert wurde oder ob Filterungs- und Selektionsprozesse seitens des Sachverständigen zum Weglassen von potenziell relevanten Informationen geführt haben. Sodann ist zu berücksichtigen, dass die Dokumentation des Sachverständigen sich primär auf den Exploranden und weniger auf das Verhalten des Sachverständigen (Frageinhalt, Ablauf, Verhalten etc.) beziehen wird, wodurch die Verteidigung nicht erschliessen kann, ob die sachverständige Person den erhobenen Sachverhalt methodisch-juristisch korrekt erhoben hat. Schliesslich ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die sachverständige Person, wenn sie nach Erstellung des Gutachtens mündlich zur Exploration befragt wird, den Sachverhalt wohl nur noch in Teilen korrekt wiedergeben kann.⁵⁷⁰ Die Schriftdokumentation sowie die mündliche Aussage seitens des Sachverständigen bieten der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung damit nur eine imperfekte Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt.⁵⁷¹

III. Beschuldigter als imperfekte Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt

198 Aus den vorangehenden Ausführungen geht hervor, dass die schriftliche Dokumentation sowie die Befragung des Sachverständigen der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung nur eine imperfekte Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt bauen.⁵⁷² Diese Lücke könnte theoretisch durch die beschuldigte Person geschlossen werden, da diese ebenfalls am Explorationsgespräch anwesend ist und die Verteidigung bezüglich des Explorationsgeschehens in Kenntnis setzen kann. Es wird sich aber zeigen, dass die beschuldigte Person diese Funktion nur unzureichend erfüllen kann.⁵⁷³

⁵⁷⁰ Vgl. für den gesamten Abschnitt N 183 ff.

⁵⁷¹ Dasselbe Fazit bei ZOEHNER ET AL., S. 226: «Letztendlich ist bei der derzeitigen Praxis der handschriftlichen Dokumentation kaum nachzuweisen, wer was genau während der Exploration gesagt oder gefragt hat, und genau dies lässt viel Raum für Spekulationen.»

⁵⁷² Vgl. N 176 ff.

⁵⁷³ GOCKER, S. 634.

1. Analoge Herausforderungen wie beim Sachverständigen

Wie bereits beim Sachverständigen erläutert, bestehen auf unterschiedlicher Ebene Limitationen, welche eine akkurate Sachverhaltsschilderung beeinträchtigen oder verunmöglichen können. Auf das Gesagte kann insofern verwiesen werden.⁵⁷⁴ An dieser Stelle sei bloss an das Folgende erinnert: Auch die beschuldigte Person nimmt den Sachverhalt durch den Zerrspiegel ihrer Persönlichkeit wahr und filtert unbewusst bzw. selektiert bewusst Explorationsinformationen. Sodann wird sie – wie auch die sachverständige Person – regelmässig Teile der Exploration vergessen.⁵⁷⁵ Bereits wegen dieser Effekte ist die beschuldigte Person nur eine imperfekte Brücke zum Explorationssachverhalt. 199

2. Katalysatoren für eine mangelhafte Explorationsrekonstruktion

Über die voranstehend erwähnten Defizite hinaus gibt es Grund zur Annahme, dass die beschuldigte Person in besonderer Weise ungeeignet ist, ihrer Verteidigung sachgerechte Angaben zum Explorationsgeschehen zu machen. Dafür sind im Kern die drei nachfolgenden Katalysatoren verantwortlich: die mangelnde Beobachterstellung (A.), die besondere Verletzlichkeit der beschuldigten Person (B.) sowie der Mangel an psychiatrischem und juristischem Fachwissen (C.). 200

A) Mangelnde Beobachterstellung

Substantielle Bestandteile der psychiatrischen Begutachtung bestehen in der Fremdbeurteilung; auch und gerade im Kontext der Befunderhebung oder der Persönlichkeitsbeschreibung.⁵⁷⁶ Die Verteidigung muss auch über die solchen Beurteilungen zugrundeliegenden Explorationsinhalte Kenntnisse erlangen, um Verteidigungsdefizite für die beschuldigte Person zu vermeiden.⁵⁷⁷ Doch gerade in diesem Zusammenhang eignet sich die beschuldigte Person nur sehr bedingt als Informationsquelle. Der Grund für dieses Verteidigungsdefizit ist klar: Fremdbeurteilungen setzen eine Aussenperspektive voraus. Genau an dieser fehlt es der beschuldigten Person; sie und ihre Psyche werden ja gerade vom Sachverständigen begutachtet. Die beschuldigte Person ist (wie alle Menschen) nicht fähig, ein objektives Bild von sich selbst zu zeichnen und sich selbst so zu sehen, wie Dritte dies tun. Selbst bei guter Selbstwahrnehmung unterliegt das 201

⁵⁷⁴ Vgl. N 183 ff.

⁵⁷⁵ GOCKER, S. 635; WAGNER/KRANICH, S. 6.

⁵⁷⁶ Vgl. N 14.

⁵⁷⁷ PICHINI, S. 163 f.

Selbstbild Verzerrungen.⁵⁷⁸ Entsprechend kann sich die beschuldigte Person subjektiv als sachlich und nur in begründeten Ausnahmefällen kritisch erleben, während sie für Dritte wenig empathisch und renitent wirkt. Mangels Aussensperspektive kann die beschuldigte Person daher nur bedingt sachgerechte Einwendungen gegen die gutachterliche Fremdbeurteilung formulieren und auch die Verteidigung kann die gutachterliche Schilderung höchstens aufgrund ihres persönlichen Eindrucks des Mandanten überprüfen.

B) Besondere Verletzlichkeit der Exploranden

202 Die Rekonstruktion des Explorationsgeschehens wird sodann durch die Tatsache verstärkt, dass im Kontext der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation regelmässige Personen mit erhöhter Verletzlichkeit begutachtet werden. Bereits der allgemeine Umstand des Exploriertwerdens bringt einen signifikanten Stressfaktor mit sich, welcher die Wahrnehmungs- und Speicherungsfähigkeit der beschuldigten Person herabsetzen dürfte.⁵⁷⁹ Sodann indizieren soziodemografische Daten die Annahme einer erhöhten Verletzlichkeit der Exploranden: Menschen im Massnahmenvollzug weisen, von der basalen Schulbildung abgesehen, überwiegend keinen Berufsabschluss und keine berufliche Einbindungen auf.⁵⁸⁰ Sodann ist zu bedenken, dass die Vermutung qualifizierter psychischer Abweichungen die Begutachtungsindikation für die Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation begründet. Entsprechend plausibel ist der Schluss, dass die psychischen Kapazitäten bei einer Mehrzahl der Exploranden suboptimal ausfallen.⁵⁸¹ Oft wird störungsbedingt die Selbst- und Aussenwahrnehmung verzerrt sein.⁵⁸² Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich Exploranden mit schweren Psychosen oder pathologisch ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmalen kaum im gutachterlichen Beschrieb wiedererkennen.⁵⁸³ Regelmässig werden solche Menschen störungsbasierte Schwierigkeiten haben, den Explorationssachverhalt einigermassen sachgerecht zu rekonstruieren und an ihre Verteidigung zu kom-

⁵⁷⁸ GRAF, Fremdanamnese, S. 60 und S. 62 f.; SAIMEH, S. 59.

⁵⁷⁹ GOCKER, S. 634 f.

⁵⁸⁰ WEBER ET AL., S. 34 f. konnten aufzeigen, dass z.B. 65.8% der untersuchten (männlichen) Probanden (48 Personen) keinen Berufsabschluss haben und dass 49.3% (37 Personen) arbeitslos und 10.7% (8 Personen) eine Invalidenrente bezog. Für weibliche Massnahmenpatienten konnten KRAMMER/WEBER/LIEBRENTZ, S. 36 ff. ähnliche Tendenzen aufzeigen; für den deutschen Rechtsraum auch Kammeier/Pollähne-MARSCHNER, E 23.

⁵⁸¹ LANDE, S. 54; näheres zu den im Massnahmenvollzug nach Art. 59 StGB vertretenen Störungsbildern bei WEBER ET AL., S. 36 f.; KRAMMER/WEBER/LIEBRENTZ, S. 36 ff.

⁵⁸² GRAF, Fremdanamnese, S. 60 und S. 62 f.

⁵⁸³ SAIMEH, S. 59; MOKROS, S. 286.

munizieren.⁵⁸⁴ Bestreiten sie gegenüber ihrer Verteidigung die gutachterliche Darstellung des vom Sachverständigen rapportierten Geschehens, kann sich die Verteidigung nie sicher sein, ob es sich dabei um eine gerechtfertigte Intervention ihres Mandanten handelt oder ob sich in dieser Opposition das Störungsbild manifestiert, welches zur Begutachtung Anlass gegeben hat.

C) Fehlendes psychiatrisches und juristisches Fachwissen

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die begutachtete beschuldigte Person in aller Regel weder juristisches noch psychiatrisches Fachwissen hat. Entsprechend wird sie überwiegend gar nicht erkennen, ob ein spezifisches Verhalten des PSY-Sachverständigen in der Exploration mit der psychiatrischen Methodik oder juristischen Beweiserhebungsvorschriften vereinbar war oder nicht.⁵⁸⁵ Bestenfalls wird es der beschuldigten Person möglich sein, Extremfälle von unzulässiger Fragestellungen (z.B. eine explizite Drohung für den Fall der Nichtmitwirkung) oder einzelne Ausstandsgründe (z.B. wenn der PSY-Sachverständige beim nicht geständigen Täter sagt: «Herr X., seien wir ehrlich, Sie waren es!») zu erkennen. Abgesehen von diesen eher theoretischen Fällen wird sie aber schlicht nicht abschätzen können, ob ein vom Sachverständigen gewählter Explorationsablauf noch mit dessen fachlichen Standards oder juristischen Vorgaben vereinbar ist. Entsprechend wird die beschuldigte Person solche Mängel oft gar nicht registrieren, womit die Verteidigung nie Kenntnis solcher Verfehlungen erlangt. 203

3. Zwischenfazit

Die beschuldigte Person ist nicht in der Lage, den Explorationssachverhalt sinnvoll zu rekonstruieren. Ihre Schilderungen unterliegen subjektiven Färbungen, wie sie bereits beim Sachverständigen geschildert wurden. Hinzu kommen drei Katalysatoren. Es fehlt der begutachteten beschuldigten Person an der notwendigen Aussenperspektive, um die Fremdbeurteilungen des Sachverständigen auf ihre Rechtfertigung zu hinterfragen. Sodann ist daran zu denken, dass gerade bei Schuld- und Massnahmengutachten in aller Regel besonders verletzte Menschen exploriert werden, was eine realitätsnahe Explorationsrapportierung seitens der beschuldigten Person zusätzlich erschwert. Schliesslich wird die beschuldigte Person allfällige juristische oder psychiatrische Fehlritte des Sachverständigen mangels Fachwissen regelmässig nicht bemerken und entsprechend auch nicht an die Verteidigung kommunizieren. Mit diesen Vorbedingungen 204

⁵⁸⁴ BERNHARD/BINDER, S. 13, welche auf die psychisch labile Situation des Exploranden hinweisen; MELTON ET AL., S. 78; US Court of Appeals, District of Columbia Circuit, United States v. Byers, 740 F2d 1104, Dissent Bazelon, N 224.

⁵⁸⁵ GOCKER, S. 634.

kann die Eingangsthese bestätigt werden, dass auch die beschuldigte Person ihrer Verteidigung nur eine imperfekte Informationsbrücke zum Explorations-sachverhalt baut.⁵⁸⁶

IV. Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten der Sachverständigenschilderung

205 Die imperfekten Informationsbrücken verunmöglichen es der Verteidigung der beschuldigten Person, die Überprüfungsbedürfnisse⁵⁸⁷ bezüglich des Explorations-sachverhalts zu realisieren. Doch selbst wenn die begutachtete beschuldigte Person in starker Abweichung von der Realität als Person fingiert würde, welche sich perfekt an den Gutachtenssachverhalt erinnert (Rapportierung der eigenen Aussagen), kraft vollkommener Selbstreflexion ihre Wirkung auf Dritte abschätzen kann (Hinterfragung von Fremdbeurteilungsebenen), sämtliche unzulässigen Verhaltensweisen des Sachverständigen (Verletzung der psychiatrischen Methodik, Ausstand, Beweiserhebungsmethoden) erkennt und allfällige Abweichungen davon ihrer Verteidigung kommuniziert, wäre noch nicht viel gewonnen. Zwar wäre die Verteidigung nun in der Position, gegen den gutachterlich rapportierten Sachverhalt Einwendungen zu erheben. Diese Einwendungen (mangelhaft rapportierter Gutachtenssachverhalt, Ausstandsgrund, unzulässige Beweiserhebungsmethode usw.) wären indes zu beweisen. In dieser Konstellation sehen sich die beschuldigte Person und ihre Verteidigung jedoch mit einem Beweisproblem konfrontiert.⁵⁸⁸ Mangels objektiver Dokumentation (z.B. Audio/Video) muss die beurteilende Instanz in diesen Fällen den strittigen Gutachtenssachverhalt mittels einer Aussagewürdigung erschliessen.⁵⁸⁹

206 Bei dieser Aussagewürdigung besteht zwar formell keine Richtigkeitsvermutung zugunsten der Angaben der sachverständigen Person. Dies wäre eine mit der freien Beweiswürdigung nicht zu vereinbarende Beweisregel. Massgeblich für die Sachverhaltsfeststellung ist alleine die Glaubhaftigkeit der jeweiligen Aussage.⁵⁹⁰ Trotzdem lässt sich ein Glaubhaftigkeits-Bias⁵⁹¹ zugunsten des PSY-Sachverständigen kaum in Abrede stellen. Die Gründe dafür liegen auf der

⁵⁸⁶ Für den gesamten Abschnitt N 198 ff.

⁵⁸⁷ Vgl. N 166.

⁵⁸⁸ Vgl. im sozialversicherungsrechtlichen Kontext: EVGer, 14. November 2007, I 1094/06, E. 3.1.2; BGer, 4. August 2016, 9C.410/2016, E. 2.2.2.

⁵⁸⁹ BGer, 4. August 2016, 9C.410/2016, E. 2.2.2.

⁵⁹⁰ BGE 133 I 33, E. 4.3.

⁵⁹¹ Unter «Glaubhaftigkeits-Bias» wird im vorliegenden Rahmen die systematische Tendenz der beweiswürdigenden Gerichte verstanden, den Ausführungen des Sachverständigen zu glauben und diese zum Urteilssachverhalt zu erheben.

Hand. Die sachverständige Person agiert als nominal neutrale (Art. 183 Abs. 3 StPO) und fachkundige Instanz im Verfahren und äussert sich unter der Strafandrohung nach Art. 307 StGB (vgl. Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO) zu ihren Erhebungen sowie ihrer fachkundigen Beurteilung. Auf der Gegenseite steht die beschuldigte Person als psychiatrischer und juristischer Laie, welche im strafrechtlichen Rahmen ein (relatives) Recht auf Lüge⁵⁹² besitzt, u.U. psychische Auffälligkeiten aufweist und mit Selbstentlastungsmotivation im Verfahren agiert. Bei diesen Ausgangsbedingungen überrascht es nicht, dass Gerichte regelmässig den Angaben der sachverständigen Person Glauben schenken.⁵⁹³

Dieses Glaubhaftigkeits-Bias spiegelt sich in der Gerichtspraxis, was an zwei Beispielen zu illustrieren ist: Der Beschwerdeführer hatte im ersten Verfahren den Ausstand des ihn beurteilenden Sachverständigen verlangt. Nach Darstellung des Beschwerdeführers hatte die PSY-Sachverständige ihm gegenüber im Explorationsgespräch geäussert, «ob er und sein Anwalt wirklich denken würden, dass er freikomme, und dass er, wenn er weiter auf seiner Unschuld bestehe, ein 100-Jahre-Massnahmekandidat wäre», was mit hoher Sicherheit einen Ausstandsgrund (Art. 56 lit. f StPO) begründet hätte, wenn die Aussage von der sachverständigen Person so getätigt worden wäre. Die PSY-Sachverständige entgegnete auf Nachfrage des Gerichts, dass «das fragliche Gespräch ihrer Erinnerung nach anders verlaufen sei als vom Beschwerdeführer geschildert» und führte die Relevanz des Deliktsverständnisses des Beschuldigten für die Prognose aus. Es sei im Explorationsgespräch darum gegangen, «dem Beschwerdeführer diesen Umstand deutlich zu machen, was offensichtlich zu Missverständnis-

207

⁵⁹² «Relativ», da in den Grenzen von Art. 303 ff. StGB. Ob aus dem Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht der beschuldigten Person nach Art. 113 StPO ein eigentliches Recht auf Lüge fliesst, ist im Einzelnen umstritten. Da aber insofern Einigkeit herrscht, dass an das einfache Lügen keine Sanktionen geknüpft werden dürfen und die beschuldigte Person nicht zur wahrheitsgemässen Aussage verpflichtet werden kann, dürfte sich selbiges kaum in Abrede stellen lassen. Zur Diskussion: ZK StPO-LIEBER, Art. 113 N 29 m.w.N. Überzeugend für die Existenz eines Lügerechts THOMMEN, *sui-generis* 2018, 314 ff.; auch BRODBECK, S. 302 geht von einem Lügerecht aus; vgl. sodann die Praxis des Bundesgerichts: BGer, 8. August 2016, 6B_157/2016, E. 2.4.2; BGE 103 IV 8, E. 4b).

⁵⁹³ HAAG, S. 15; KUHN/BERNHARD, S. 7 (Bernhard: «Man kann sich vorstellen, wem das Gericht glaubt: Dem Herrn Doktor oder dem Klienten.»); MELTON ET AL., S. 78 «...nor is such a person's testimony alone likely to fare well against the testimony of a mental health professional»; SAMUELSSON, S. 25; OLG-Hamm, 3. Februar 2015, 14 UF 135/14, N 3; der Glaubhaftigkeitsbias manifestiert sich sodann in folgender Annahme von KAUFMANN, S. 114 f.: «...steht bei der Würdigung des sachverständigen Beweises nicht die Glaubwürdigkeit der sachverständigen Person bzw. die Glaubhaftigkeit des Gutachtens im Vordergrund. Vielmehr hat sich das Gericht von seiner Unparteilichkeit, seinem Fachwissen sowie der Schlüssigkeit bzw. Richtigkeit seiner Befunde zu überzeugen.»

sen geführt habe».⁵⁹⁴ Das Bundesgericht stellte sich auf dieser Basis auf den Standpunkt, der Wortlaut des Explorationsgesprächs stehe nicht fest und lasse sich nicht mehr eruieren. Auf die Beanstandungen des Beschwerdeführers müsse nicht näher eingegangen werden. Es handle sich bei den Behauptungen des Begutachteten um unbewiesene und nicht beweisbare Darlegungen. Die PSY-Sachverständige habe bei ihrer Begutachtung mit der Arbeitshypothese des Schuldspruchs agieren müssen. Sie habe dabei die Möglichkeit des Freispruchs durchaus in die Erwägung und Schlussfolgerungen einbezogen. Abgesehen von den Äusserungen des Beschwerdeführers, auf die nicht abgestellt werden könne, gäbe es keinerlei Anhaltspunkte, wonach die PSY-Sachverständige im Rahmen der Begutachtung/Aufklärung den Boden der Arbeitshypothese «Schuldspruch» verlassen und sich damit dem Vorwurf der Befangenheit geöffnet hätte.⁵⁹⁵

208 Noch pointierter manifestierte sich das Glaubhaftigkeits-Bias in einem Verfahren vor dem OGer-ZH in der folgenden Erwägung: «Ein im Sachverständigenverzeichnis eingetragener und unter Hinweis auf die Straffolgen von Art. 307 StGB ordentlich ermahnter Gutachter (Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO) bietet grundsätzlich Gewähr für ein unabhängiges sorgfältiges Gutachten. Damit kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein solcher Gutachter die wesentlichen Aussagen des Exploranden in den Explorationsgesprächen im Gutachten richtig wiedergibt (unwesentliche Aussagen sind nicht aufzuführen; die Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Aussagen für die psychiatrische Beantwortung der gestellten Fragen ist eigentliche Aufgabe des Gutachters). Allfällige diesbezügliche Diskrepanzen, Unklarheiten oder Missverständnisse zwischen seinem Verständnis und demjenigen des Exploranden sind im Rahmen einer allfälligen Ergänzung oder Verbesserung des Gutachtens (Art. 189 StPO) oder in einer allfälligen Zeugenbefragung des Gutachters zu klären. Ein vorgängiges grundsätzliches Misstrauen in die Fähigkeit oder Unbefangenheit des Gutachters, das deshalb eine gesetzlich nicht vorgesehene (prophylaktische) Video- oder Tonaufnahme der Explorationsgespräche erforderte, ist damit nicht angebracht».⁵⁹⁶ Vor dem Hintergrund dieser Gerichtspraxis wird der Beweisnotstand der beschuldigten Person erkennbar.⁵⁹⁷ Es fehlt an effektiven Mitteln, allfällige Fehlleistungen des PSY-Sachverständigen zu beweisen.⁵⁹⁸

⁵⁹⁴ BGer, 20. Februar 2018, 6B_1408/2016, E. 2.1.1.

⁵⁹⁵ BGer, 20. Februar 2018, 6B_1408/2016, E. 2.1.2.

⁵⁹⁶ OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 12, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.

⁵⁹⁷ Für das Sozialversicherungsrecht: ALIOTTA, Diss., S. 403; BÖHME, N 727 f.

⁵⁹⁸ Für das Sozialversicherungsrecht: RIEMER-KAFKA, S. 175.

V. **Kompensationsmechanismen: mangelnde Effektivität**

Durch die Akteneinsicht sowie die Befragung des Sachverständigen kann das Recht auf Stellungnahme zum Gutachten sowie zur Person des Sachverständigen bezüglich des Explorationsgesprächs nicht mit der gebotenen Effektivität ausgeübt werden. Verantwortlich dafür sind die imperfekten Informationsbrücken (sachverständige und beschuldigte Person) sowie das Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten des Sachverständigen. Allerdings darf nicht bereits daraus auf eine Konventionsverletzung geschlossen werden. Vielmehr ist im Lichte des Gesamtwürdigungsansatzes des EGMR zu prüfen, ob die Transparenzdefizite bezüglich der Exploration durch das Verteidigungsmittel des Privatgutachtens (1.) oder sonstige strafbehördliche Schutzmechanismen (2.) kompensiert werden können. 209

1. **Beizug von Privatsachverständigen**

In einem ersten Schritt ist der Frage nachzugehen, ob die beschuldigte Person und ihre Verteidigung die voranstehend geschilderten Überprüfungsdefizite durch die Einbindung eines Privatsachverständigen (auch: Privatgutachter) kompensieren können. Allgemein dürfte sich die Einbindung eines Privatsachverständigen regelmässig aufdrängen, da sich die beschuldigte Person und ihre Verteidigung ansonsten (mangels Fachwissens) nur limitiert zur Qualität des amtlichen Gutachtens äussern können.⁵⁹⁹ Es wird sich jedoch zeigen, dass dieses Verteidigungsinstrument für den vorliegenden Kontext weder sachlich (A.) noch mit Blick auf den Beweiswert (B.) geeignet ist, eine kompensierende Wirkung im Verfahren zu entfalten. 210

A) **Mangelnde Kompensationseignung von Privatgutachten**

Bei der Formulierung des Auftrags an einen Privatsachverständigen stehen der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung zwei (theoretisch auch kombinierbare) Gestaltungsvarianten zur Verfügung: Einerseits kann ein methodenkritisches Privatgutachten in Auftrag geben werden, andererseits kann der Privatsachverständige mit einer «Vollbegutachtung» der beschuldigten Person (inkl. Exploration usw.) betraut werden. 211

⁵⁹⁹ BERNHARD, Massnahmenrecht, 149 f.; GRAF, Qualitätskriterien, S. 102; WOHLERS, ZStrR 2018, S. 458.

a) *Methodenkritisches Privatgutachten*

212 Bei einem methodenkritischen Privatgutachten erfolgt keine eigenständige Untersuchung der beschuldigten Person durch den Privatsachverständigen, sondern es findet lediglich eine Beurteilung statt, ob der amtliche Sachverständige (Art. 182 ff. StPO) bei der Erstellung seines Gutachtens in Übereinstimmung mit den Regeln seines Fachs vorgegangen ist.⁶⁰⁰ Der grundsätzliche Wert dieses Instruments für die beschuldigte Person und ihre Verteidigung soll nicht bestritten werden.⁶⁰¹ Für die vorliegende Frage gilt es jedoch zu konstatieren, dass die Möglichkeiten des methodenkritischen Gutachtens durch die Intransparenz des Explorationssachverhalts begrenzt sind: Ob der amtliche Sachverständige den Sachverhalt in der Exploration methodenkonform erhoben (Atmosphäre, Sprachstil, Fragetechnik usw.) und alles Wesentliche registriert hat, kann der Privatsachverständige nicht beurteilen, da er bei der Exploration nicht zugegen war. Er ist denselben Hindernissen ausgesetzt wie die explorationsabwesende Verteidigung: Für die Beurteilung stehen nur die sachverständige Schilderung im Gutachten, allfällige gutachterliche Arbeitsunterlagen (Notizen etc.) und die Angaben der beschuldigten Person zur Verfügung. Beide dieser Quellen sind wie mehrfach betont imperfekte Informationsbrücken zum Explorationsgeschehen. Ist der Explorationssachverhalt aber nicht ausreichend transparent, kann das methodenkritische Gutachten nicht seine volle Wirksamkeit entfalten. Ihm fehlt dadurch die verteidigungsrechtliche Kompensationseignung mit Blick auf die Überprüfbarkeit des Explorationssachverhalts.

b) *«Vollbegutachtung» durch den Privatsachverständigen*

213 Der Privatsachverständige kann anstelle einer reinen Methodenkritik damit betraut werden, die beschuldigte Person zu begutachten. Durch die privatgutachterliche Beurteilung – so die Theorie – könnte ein prozessuales Gegengewicht zum Explorationssachverhalt des amtlichen Sachverständigen in das Verfahren eingeführt werden. Bei genauer Betrachtung ist dieses Vorgehen aber nur bedingt geeignet, Kompensationswirkung zu entfalten. Es muss bedacht werden, dass ein vom Privatsachverständigen erhobener Explorationssachverhalt bestenfalls limitiert als Indiz dafür gelten kann, dass der dem amtlichen Gutachten zugrunde gelegte Explorationssachverhalt mangelhaft erhoben wurde. Finden zwei Explorationsgespräche zu unterschiedlichen Zeitpunkten von zwei Sachverständigen statt, ist es aufgrund der unterschiedlichen Gesprächsdynamiken nicht nur denkbar, sondern wahrscheinlich, dass zwischen den beiden Sachverständigen gewisse Inkongruenzen bezüglich des Explorationssachverhalts entstehen. Würde die Erhebung der Privatsachverständigen von jener des amtlichen

⁶⁰⁰ HABERMEYER, Privatgutachten, S. 72 f.

⁶⁰¹ Zum verteidigungsrechtlichen Wert auch EGG, S. 89; HABERMEYER, Privatgutachten, S. 72 ff.

Sachverständigen abweichen, wäre damit noch nicht gesagt, dass der amtliche Sachverständige das Explorationsgeschehen mangelhaft rapportiert hat. Zusätzlich könnte eine Vollbegutachtung nichts dazu aussagen, ob der amtliche PSY-Sachverständige mit methodisch und juristisch zulässigen Mitteln zu seinem Explorationssachverhalt gekommen ist. Vor diesem Hintergrund fehlt es auch einer Vollbegutachtung durch den Privatsachverständigen an der notwendigen Kompensationswirkung. Eine effektive Überprüfung des amtlichen Sachverständigenbeweises wird durch sie nicht ermöglicht.

B) Beweiswert des Privatgutachtens

Neben der mangelnden sachlichen Kompensationseignung des Privatgutachtens ist zu beachten, dass dieses Instrument bereits beweisrechtlich kein adäquates Gegengewicht zum Sachverständigenbeweis nach Art. 182 ff. StPO bildet.⁶⁰² Das Privatgutachten hat nach konstanter Rechtsprechung nicht den Stellenwert eines Beweismittels wie der Sachverständigenbeweis nach Art. 182 ff. StPO, sondern ist blosser Bestandteil der Parteivorbringen und vom Gericht zurückhaltend zu würdigen.⁶⁰³ Grund für diese Gerichtspraxis ist die Annahme, dass der Privatsachverständige durch den Modus seiner Beauftragung (Partei als Auftraggeber und Zahler, Intransparenz der Abrede, keine Belehrung nach Art. 307 StGB etc.) von Beginn weg den Anschein der Befangenheit mit sich bringt.⁶⁰⁴ Besteht aber auf beweisrechtlicher Ebene dieses Ungleichgewicht der gutachterlichen Stellungnahmen, kann von einer adäquaten Kompensation der Intransparenz des amtlichen Gutachtens erst recht nicht die Rede sein.

2. Strafbehördliche Massnahmen

Eine Kompensation der verteidigungsrechtlichen Defizite könnte schliesslich dadurch erfolgen, dass die Verfahrensleitung (allenfalls auf Antrag der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung) das Gutachten des Sachverständigen und den Explorationssachverhalt kritisch überprüft und bei entsprechender Indikation Ergänzungen und Verbesserungen einholt oder einen weiteren Sachverständigen mandatiert (vgl. Art. 189 StPO).⁶⁰⁵ Mit Blick auf die Überprüfbarkeit des gutachterlich rapportierten Explorationssachverhalts hat die Verfahrensleitung aber die selben Einschränkungen wie die Verteidigung: Auch sie kann den Explorationssachverhalt nur indirekt erschliessen. Dabei bilden beide Informationsquellen (sachverständige Person, beschuldigte Person) imperfekte Informationsbrücken, wobei im Zweifelsfall den Ausführungen des Sachverständigen

⁶⁰² Zur Berücksichtigung dieses Kriteriums durch den EGMR: N 104.

⁶⁰³ BGE 141 IV 369, E. 6.2.

⁶⁰⁴ BGE 141 IV 369, E. 6.2.

⁶⁰⁵ OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 13, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.

geglaubt wird (Glaubhaftigkeits-Bias).⁶⁰⁶ Vor diesem Hintergrund ist das Verfahren nach Art. 189 StPO ungeeignet, die mangelnde Effektivität der Verteidigungsrechte zu kompensieren.

VI. Fazit: Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 i.V.m. Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK

- 216 Mit den Ausführungen der § 6 und 7 sind sämtliche Faktoren für die Gesamtwürdigung der Verfahrensfairness umrissen. Ausgangspunkt der Analyse bildete die Betrachtung der prozessualen Position und Rolle des Sachverständigen. Bei der Begutachtung der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation agiert der PSY-Sachverständige faktisch als partieller Staatsanwalt und Richter in Weiss. Dabei ist seine Neutralität systembedingt tangiert (Vermengung von faktischer Ermittlungs- und Richterfunktion, Mandatierung durch die Staatsanwaltschaft, medialer Druck), was deshalb von besonderer Bedeutung ist, weil Stellungnahmen im Kontext der Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbegutachtung immer ein gewisses Mass an Wertung beinhalten, wodurch das Ergebnis der Begutachtung partiell auch von der Person des Sachverständigen abhängt.⁶⁰⁷
- 217 Angesichts der so beschaffenen Position und Rolle des Sachverständigen sind höchste Anforderungen an die Verteidigungsrechte zu stellen. Diesem Gebot vermag der Status quo nicht zu genügen. Zwar geht das Bundesgericht davon aus, dass die Verteidigung weder den fachlich korrekten Ablauf unmittelbar zu kontrollieren noch die Exploration mit eigenen Fragen zu ergänzen habe, und hält dafür, dass mit den gesetzlichen Mitteln eine effektive Kontrolle des Gutachtens möglich sei.⁶⁰⁸ Diese Auffassung konnte jedoch widerlegt werden. Ausgangspunkt dieser These bildet die Tatsache, dass die gutachterliche Rapportierung des Explorationssachverhalts nur eine imperfekte Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt schlägt, da die sachverständigen Wahrnehmungen und Schilderungen Verzerrungs-, Filterungs- und Selektionseffekten unterliegen und das eigene Verhalten während der Exploration überwiegend nicht dokumentieren. Die gutachterliche Darstellung der Exploration in den Arbeitsunterlagen des Sachverständigen, im Gutachten oder anlässlich der mündlichen Befragung ist unter diesen Bedingungen nicht auf ihre inhaltliche Richtigkeit überprüfbar. Selbiges gilt für die Frage, ob die sachverständige Person bei ihrer Erhebung methodisch-juristisch korrekt vorgegangen ist.⁶⁰⁹

⁶⁰⁶ Vgl. N 160 ff.

⁶⁰⁷ Vgl. N 162.

⁶⁰⁸ BGE 144 I 253, E. 3.8.

⁶⁰⁹ Vgl. N 176 ff.

Diese Intransparenz kann durch die beschuldigte Person nicht behoben werden. Sie unterliegt denselben Verzerrungs-, Filterungs- und Selektionseffekten wie die sachverständige Person. Diese werden zusätzlich durch drei Katalysatoren verstärkt: Erstens fehlt der beschuldigten Person die Beobachterstellung (sie selbst wird ja gerade begutachtet), womit sie die gutachterliche Beschreibung ihrer Person nur schlecht überprüfen kann. Zweitens ist die begutachtete beschuldigte Person regelmässig besonders verletzlich: Der Explorationsstress, ihre generellen Kapazitäten und v.a. auch die regelmässig vorliegenden psychischen Auffälligkeiten machen es ihr schwer, den Explorationssachverhalt adäquat zu rekonstruieren. Schliesslich wird sie allfällige psychiatrische oder juristische Fehler des Sachverständigen bei der Erhebung mangels Fachwissen oft nicht registrieren und entsprechend auch nicht an ihre Verteidigung kommunizieren können.⁶¹⁰ 218

Mit den ihr zur Verfügung stehenden Informationsquellen kann die Verteidigung den gutachterlich rapportierten Explorationssachverhalt nicht umfassend überprüfen. Sie ist vielmehr, wie es in der Literatur pointiert ausgedrückt wird, auf eine Art Kaffeesatzlesen angewiesen.⁶¹¹ Diese Transparenzdefizite können von der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung auch durch die Einbindung eines Privatsachverständigen nicht kompensiert werden. Ein methodenkritisches Gutachten kann nur dort Methodenkritik anbringen, wo die Informationsgrundlage transparent ist, und gerade daran fehlt es im Explorationsgespräch. Die Begutachtung der beschuldigten Person durch den Privatsachverständigen ist als Kompensationsfaktor ebenfalls ungeeignet, weil sie keine Aussage darüber zu tätigen vermag, ob der vom amtlichen Sachverständigen rapportierte Explorationssachverhalt zutrifft und methodisch sowie juristisch korrekt erhoben wurde. Zusätzlich ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass den Äusserungen des Privatsachverständigen geringerer Beweiswert beigemessen wird als dem amtlichen Sachverständigen.⁶¹² Das verteidigungsrechtliche Defizit (Intransparenz der Exploration) kann auch durch strafbehördliche Massnahmen nicht kompensiert werden. Der Verfahrensleitung fehlt es – wie der Verteidigung auch – an einer authentischen Sicht auf das Explorationsgeschehen. Somit ist es ihr nicht möglich, zu beurteilen, ob der Explorationssachverhalt akkurat rapportiert wurde und ob die sachverständige Person bei ihren Erhebungen methodisch-juristisch korrekt vorgegangen ist.⁶¹³ 219

Aufgrund der referierten Transparenzdefizite kann die gutachterliche Rapportierung des Explorationssachverhalts nicht wirkungsvoll überprüft werden. Vielmehr scheint die Annahme zu dominieren, dass die sachverständige Person als 220

⁶¹⁰ Vgl. N 198 ff.

⁶¹¹ BERNHARD/BINDER, S. 13.

⁶¹² Vgl. N 210 ff.

⁶¹³ Vgl. N 215.

neutrale Instanz den Sachverhalt objektiv berichtet. Es lässt sich ein Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten des Sachverständigen erkennen, das in die Gesamtwürdigung einzubeziehen ist. Wenn seitens der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung Einwendungen gegen die gutachterliche Explorationsschilderung vorgebracht werden, bestehen kaum reale Erfolgsaussichten, dass sich diese in der Beweiswürdigung des Gerichts durchsetzen. Vielmehr wird bei anderslautender Sachverhaltsdarstellung des PSY-Sachverständigen das Gericht dieser Darstellung in aller Regel folgen, weil letzterer im Verfahren als neutrale Instanz agiert, während die beschuldigte Person oft an psychischen Defiziten leidet, keine Fachkenntnisse hat, lügen darf und offensichtliche Selbstentlastungsmotive aufweist.⁶¹⁴

- 221 Unter den erwähnten Bedingungen ist die konventionsrechtlich gebotene effektive Überprüfungsmöglichkeit bezüglich der Exploration als elementarer Bestandteil des Gutachtens zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation nicht gegeben. Ist die Verteidigung der beschuldigten Person (wie alle anderen Verfahrensbeteiligten auch) eines authentischen Blicks auf die Exploration beraubt, können sie und die beschuldigte Person diesen Untersuchungsvorgang nur unzureichend auf seine methodisch-juristische Korrektheit hin überprüfen.⁶¹⁵ Ein von These und Gegenthese geprägtes kontradiktorisches Verfahren ist damit nicht garantiert.⁶¹⁶ Der juristische Status quo begründet eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 (i.v.m. Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK⁶¹⁷).

§ 8 Ermittlung konventionskompatibler Lösungsmodelle

- 222 In § 7 wurde festgestellt, dass der juristische Status quo den konventionsrechtlichen Mindestanforderungen nicht entspricht. Nun gilt es zu prüfen, auf welche Weise die Ausgestaltung des Strafverfahrens modifiziert werden könnte, um die Konventionskonformität wiederherzustellen. Sollten dabei mehrere Lösungsmodelle «fairnessgeeignet» sein, ist es dem Gesetzgeber unbenommen, eine mit dem nationalen Modell harmonisierende Regelung zu implementieren.⁶¹⁸

⁶¹⁴ Vgl. N 205 ff.

⁶¹⁵ Dazu auch BERNHARD/BINDER, S. 13.

⁶¹⁶ So auch BRUNNER, Verlässlichkeit, S. 305.

⁶¹⁷ Zur Frage der dogmatischen Verortung des Prüfungsmodells des EGMR: N 97 f.

⁶¹⁸ BGE 142 II 305, E. 6.3.

I. Optimierung der Position und Rolle des Sachverständigen

Eine erste Möglichkeit zur Ausbalancierung des konventionswidrigen Ungleichgewichts könnte darin bestehen, die Position und Rolle des Sachverständigen zu optimieren. Die damit verbundene Fairnessimplikation ist am besten anhand einer Waage illustriert: Mit der prozessualen Optimierung der Position und Rolle (entweder via Schwächung des Relevanzkriteriums oder Verbesserung des Neutralitätskriteriums)⁶¹⁹ könnte die erforderliche Balance mit den Verteidigungsrechten der beschuldigten Person hergestellt und die Waffengleichheit des Verfahrens gesichert werden. Es wird sich zeigen, dass die diskutierten Lösungen für sich genommen zwar durchaus positive Wirkungen entfalten, aber dass ihre Umsetzung gleichwohl eine inakzeptable Dysbalance zulasten der Verteidigungsrechte übriglässt. 223

1. Neutralitätssicherung bei der Auftragsvergabe

Die Neutralität des Sachverständigen ist u.a. gewissen Zweifeln ausgesetzt, weil der PSY-Sachverständige im Regelfall durch die Staatsanwaltschaft mandatiert wird, welche im gerichtlichen Verfahren als Partei agiert.⁶²⁰ In der Literatur findet sich entsprechend die Forderung, dass nicht der fallführende Staatsanwalt die Mandatierung des PSY-Sachverständigen vornimmt, sondern eine neutrale Stelle wie beispielsweise ein Gericht oder die nicht im Fall involvierte Oberstaatsanwaltschaft.⁶²¹ Ein Beitrag an die Waffengleichheit wäre damit geleistet.⁶²² Implizit steckt hinter diesem Lösungsansatz der bereits angesprochene Gedanke, dass durch die optimierte Neutralität des Sachverständigen Gewähr für eine möglichst grosse Objektivität seiner Tätigkeit (und damit auch seiner Reportierung des Explorationsgeschehens) besteht.⁶²³ 224

⁶¹⁹ Vgl. N 100 ff.

⁶²⁰ Vgl. N 149 ff.

⁶²¹ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 89 ff.; BERNHARD, Massnahmenrecht, 148; DETTER, S. 61; DONATSCH, fp 2019, S. 140; MEIER/BIGLER, S. 61; kritisch zum Status Quo der Sachverständigenbestimmung durch die Staatsanwaltschaft auch WOHLERS, ZStrR 2018, S. 457.

⁶²² BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 86; zu den Vorteilen auch STRIDBECK ET AL., S. 254.

⁶²³ Vgl. N 142.

A) Fragmentarische Sicherung der Neutralität

225 Trotz der nominalen Vorteile darf die fairnessrelevante Wirkung dieses Lösungsansatzes nicht überschätzt werden.⁶²⁴ Zu Beginn ist festzuhalten, dass die Beauftragungskompetenz nur eines der drei systembedingten Neutralitätsdefizite des Sachverständigen zu beheben vermag: Mit diesem Ansatz könnten die Gefahr der strategischen Sachverständigenwahl seitens der Staatsanwaltschaft sowie das Phänomen der *adversarial allegiance* reduziert werden.⁶²⁵ Die Vermengung von faktischer Ermittler- und Richterfunktion und der latente politisch-mediale Druck blieben jedoch im Verfahren bestehen.⁶²⁶ Sodann ist zu bedenken, dass auch ein Gericht der Versuchung ausgesetzt sein kann, durch die Wahl des Sachverständigen das Verfahren in gewisse Bahnen zu lenken, und dass auch in einem solchen Setting die sachverständige Person versucht sein könnte, ihre Stellungnahme auftraggebergerecht zu verfassen.⁶²⁷ Der Gefahr einer bewussten Selektion durch das Gericht liesse sich zwar mit einer Beauftragung nach einem Losverfahren (Zufallsprinzip) begegnen.⁶²⁸ Diese Lösung könnte aber im Einzelfall wiederum zu sachfremden Resultaten führen, da es durchaus legitime Gründe geben kann, einen spezifischen Sachverständigen zu beauftragen.⁶²⁹

B) Anhaltende Intransparenz der Exploration

226 Für die Antwort auf die Frage, ob mit der Modifikation der Beauftragungszuständigkeit ein faires Verfahren herbeigeführt werden könnte, ist jedoch der folgende Punkt entscheidend: Mit diesem Lösungsansatz können die Transparenzdefizite bezüglich des gutachterlich rapportierten Explorationssachverhalts in keiner Weise behoben werden. Der Sachverständigenbeweis wäre nach wie vor das entscheidende Beweismittel für die Fragen der Schuldfähigkeit und Massnahmenanordnung, und ein zentraler Baustein davon (Exploration) könnte von der Verteidigung nicht umfassend überprüft werden. Diese Erkenntnis liesse sich auch nicht mit dem Argument beiseiteschieben, die nun verbesserte Neutralität des Sachverständigen leiste Gewähr für eine objektive Explorationsrapportierung seitens des Sachverständigen. Selbst wenn nämlich dieser Sachverständige mit grösster Neutralität bei seinen Erhebungen vorgeht, könnten ihm unbe-

⁶²⁴ ERB, S. 914.

⁶²⁵ Vgl. N 149.

⁶²⁶ Vgl. N 146 ff. und N 152.

⁶²⁷ ERB, S. 895 f. und S. 914; LAEMMEL, S. 246: «Und längst wissen die Richter, welche Gutachter zackigen Gemütes sind, wer ihnen beim Wegsperrern von Tätern hilft oder wer so schwammige Arbeiten abliefert, dass man sich darin wie in einem Selbstbedienungsladen nach Gutdünken bedienen kann.»

⁶²⁸ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 90 f.

⁶²⁹ ERB, S. 914.

wusste methodische oder juristische Fehlritte unterlaufen, und gerade diese könnten von der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung mangels Transparenz des Explorationssachverhalts nur unzureichend überprüft und im Verfahren geltend gemacht werden. Damit erweist sich die Optimierung der Beauftragungskompetenz durch eine neutrale Instanz zwar als begrüssenswerter Schritt hin zu einem fairen Verfahren. Die konventionsrechtliche Kernforderung – effektive Überprüfbarkeit des Gutachtens – wird damit aber nicht erfüllt.

2. Doppelbegutachtung

Die herausragende Relevanz des Sachverständigenbeweises ist mitunter darin begründet, dass im Regelfall nur ein einziges Gutachten im Verfahren vorliegt. Eine Lösung könnte nun darin bestehen, dass der Beweiswert des Privatgutachtens entgegen der heutigen Gerichtspraxis⁶³⁰ erhöht und es wie der Sachverständigenbeweis nach Art. 182 ff. StPO als Beweismittel anerkannt wird.⁶³¹ Alternativ könnte eine Begutachtung durch zwei amtliche Sachverständige erfolgen.⁶³² Das Gericht könnte anschliessend in freier Beweiswürdigung jenem Gutachten folgen, das es für überzeugender erachtet.⁶³³ Mit dieser Erhöhung der Anzahl Sachverständigenbeweise könnte – so die Theorie – die fairnessrechtliche Waage (Waffengleichheit) ausbalanciert werden. Bei näherer Betrachtung überzeugt aber auch dieser Ansatz nicht. Bereits faktisch wäre zu berücksichtigen, dass durch eine Doppelbegutachtung das Verfahren weiter aufgebläht würde (zeitlicher und finanzieller Zusatzaufwand).⁶³⁴ Ebenso könnte es für die Verteidigung (bei einer Aufwertung des Privatgutachtens) schwierig sein, Privatsachverständige zu mandatieren, da solche nicht in unendlicher Zahl zur Verfügung stehen und nicht alle davon für die Verteidigung Gutachten erstellen.⁶³⁵ Entscheidend ist jedoch die Feststellung, dass der Doppelbegutachtungsansatz sachlich ungeeignet ist, die Verteidigungsdefizite beim Sachverständigenbeweis zu beheben.

227

⁶³⁰ Vgl. N 214.

⁶³¹ MARQUES LOPES, N 42 ff.; MEIER/BIGLER, S. 60 f.

⁶³² BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 95 f.; BERNHARD, Jusletter 13. Februar 2012, N 48; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, S. 348; MARQUES LOPES, N 45; kritisch zu dieser Option auch WOHLERS, ZStrR 2018, S. 458.

⁶³³ MARQUES LOPES, N 42 ff.

⁶³⁴ DETTER, S. 61; ERB, S. 901; GRAF, Qualitätskriterien, 101; MARQUES LOPES, N 43 und 47; NOLL/BERNHARD, S. 8 (Votum Noll).

⁶³⁵ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 94; HABERMEYER, Parteigutachten, S. 67; ISENRING/MÜLLER, S. 1339; allgemein zum Mangel geeigneter Experten: MARQUES LOPES, N 43.

A) Neutralitätszweifel am «Sachverständigen der Verteidigung»

228 Gegen die beweisrechtliche Aufwertung des Privatsachverständigen oder (bei zwei amtlichen Gutachten) die Einführung eines von der Verteidigung gewählten amtlichen Sachverständigen sprechen systembedingte Gründe. Bei diesem Modell würde der Sachverständige der Verteidigung beim Gericht – selbst wenn mit Blick auf die formelle Egalität zwischen den Sachverständigenbeweisen besteht – wohl nur limitiert Gehör finden, da beim Sachverständigen der Verteidigung immer noch der Anschein der Befangenheit mitschwingt.⁶³⁶ Entsprechend würde wohl überwiegend den Darstellungen des Sachverständigen gefolgt, der von der Verfahrensleitung bestimmt wurde. Doch selbst wenn dies nicht der Fall wäre und sich die Gerichte sachlich mit beiden Sachverständigenbeweisen auseinandersetzen würde, wäre für die Verfahrensfairness nur wenig gewonnen (dazu sogleich).

B) Anhaltende Intransparenz der Exploration

229 Die fairnessrechtliche Untauglichkeit des vorliegend referierten Lösungsmodells manifestiert sich im Kern darin, dass das Vorliegen zweier Gutachten das zentrale Manko – die limitierte Überprüfbarkeit des durch den amtlichen Sachverständigen erhobenen Explorationssachverhalts – nicht beheben würde. An der Qualität der Gutachten würde sich mit der blossen Erhöhung der Anzahl Gutachten nichts ändern.⁶³⁷ Die beschuldigte Person, ihre Verteidigung und auch das Gericht könnten nach wie vor nicht effektiv überprüfen, ob die Rapportierung des Explorationssachverhalts durch den jeweiligen amtlichen Sachverständigen akkurat erfolgte und ob die Exploration methodisch-juristisch korrekt durchgeführt wurde.⁶³⁸ Aus diesen Gründen ist der Ansatz der Doppelbegutachtung für die Gewährleistung eines fairen Verfahrens ungeeignet.

II. Teilnahmerecht der Verteidigung

230 Die Behebung des konventionswidrigen Status quo kann nach den voranstehenden Ausführungen nicht (alleine) in der Optimierung der Position und Rolle des Sachverständigen gesucht werden. Vielmehr muss die Lösung in der Behebung der Intransparenz des Explorationssachverhalts bestehen. Zu diesem Zweck könnte der Verteidigung ein Teilnahmerecht am Explorationsgespräch ihrer

⁶³⁶ DETTER, S. 61; FELTHOUS/SASS, S. 137 f.; SCHREIBER, S. 1020; TOEPEL, S. 292.

⁶³⁷ DONATSCHE, 125 Jahre Kassationsgericht, S. 375; DETTER, S. 61.

⁶³⁸ Dazu bereits derselbe Schluss bei N 213.

Mandantin eingeräumt werden.⁶³⁹ Durch die Teilnahme an der Exploration würde die Verteidigung – so die Theorie – einen unmittelbaren Eindruck der Exploration erlangen und wäre damit in die Lage versetzt, mit der beschuldigten Person zusammen effektiv Stellung zum Gutachten bzw. dem Bestandteil des Explorationsgesprächs zu nehmen.⁶⁴⁰ Auf den ersten Blick wäre das Teilnahme-recht der Verteidigung ein taugliches Instrument zur Gewährleistung einer effektiven Überprüfung des Gutachtens. Allerdings erhellt eine nähere Betrachtung, dass diese Annahme bestenfalls partiell aufrechterhalten werden kann.

1. Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten des Sachverständigen

Die Verteidigung hätte durch ihre Teilnahme an der Exploration zwar volle Kenntnis des Explorationssachverhalts. Wäre das Explorationsgeschehen umstritten, bestünde die Möglichkeit, die Verteidigung als Zeugin zum Explorationsgeschehen einzuvernehmen.⁶⁴¹ In der Sache blieben aber Verteidigungsdefizite bestehen: Das urteilende Gericht hätte nach wie vor keine andere Möglichkeit, als den Explorationssachverhalt bei divergierenden Schilderungen mittels einer Aussagewürdigung festzustellen, da es selbst (das Gericht) nicht unmittelbar bei der Exploration anwesend ist. Zwar wären die Karten nun neu gemischt, denn anders als die beschuldigte Person wäre die Verteidigung als Zeugin an die Wahrheitspflicht nach Art. 307 StGB gebunden. Damit stünden sich – anders als im Status quo – zwei Personalbeweise (Aussage des Sachverständigen und jene der Verteidigung) gegenüber, welche beide der Wahrheitspflicht nach Art. 307 StGB unterliegen. Damit wäre die Position der beschuldigten Person im Rahmen der Beweiswürdigung nominal verbessert. 231

Trotz dieser theoretischen Besserstellung wäre die Wirksamkeit eines Teilnahmerechts wohl limitiert. Das Gericht – will man seine Mitglieder nicht an der Exploration teilnehmen lassen (dazu später) – wäre bei strittigem Explorationssachverhalt immer noch darauf angewiesen, eine Aussagewürdigung zu vollziehen. Bei dieser gibt es Grund zur Annahme, dass das Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten des PSY-Sachverständigen partiell weiterbesteht und der Aussage des Sachverständigen erhöhte Glaubhaftigkeit zugemessen würde. Diese Annahme fusst sowohl auf der Betrachtung der systemischen Position der Verteidigung im Strafprozess (A.) als auch der Natur der Exploration als fachspezifisches Untersuchungsmittel (B.). 232

⁶³⁹ Stellvertretend: BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 97; MARQUES LOPES, N 48.

⁶⁴⁰ SANER, S. 133 f.; PICHINI, S. 163.

⁶⁴¹ Allgemein die Möglichkeit der Vernehmung der Verteidigung als Zeugin: CAVEGN, S. 62 ff.; zu dieser Konstellation bzgl. der Exploration im deutschen Recht: OLG-Hamm, 3. Februar 2015, 14 UF 135/14, N 3 ff.

A) Systematische Position der Verteidigung

233 Das Gericht wird sich bei der Würdigung eines umstrittenen Explorations Sachverhalts bewusst sein, dass die Verteidigung die Interessen der beschuldigten Person in den Schranken des Rechts bestmöglich zu wahren hat (Art. 128 StPO). Zwar darf die Verteidigung bei ihrer Aussage als Zeugin zum Explorationsgeschehen nicht lügen (Art. 307 StGB). Gleichzeitig ist (wie bereits mehrfach dargelegt) zu berücksichtigen, dass die Sachverhaltsfeststellung im Rahmen einer psychiatrischen Begutachtung nicht nach einem simplen «schwarz-weiss-System» funktioniert, sondern dass bei der psychiatrischen Sachverhaltserhebung (z.B. Persönlichkeitsbeschreibung, psychischer Befund etc.) Interpretationsspielräume bestehen.⁶⁴² Ist dies jedoch der Fall, wäre die Verteidigung im Rahmen von Art. 128 StPO verpflichtet, die für die beschuldigte Person optimale Wahrheitsinterpretation zu vertreten. Sodann wäre zu bedenken, dass auch die Verteidigung bei ihren Wahrnehmungen Verzerrungseffekten unterliegen und Explorationsinhalte vergessen kann. Bei dieser Ausgangslage scheint die Annahme berechtigt, dass das Gericht bei Streit um den Explorationsinhalt überwiegend der Darstellung des PSY-Sachverständigen Glauben schenken würde, da dieser einer Neutralitätspflicht unterliegt, während die Verteidigung systembedingt beschuldigtenorientierte Interessenwahrung⁶⁴³ zu betreiben hat. Bereits vor diesem Hintergrund wäre ein Teilnahmerecht der Verteidigung an der Exploration von limitiertem Nutzen.

B) Fehlendes Fachwissen der Verteidigung

234 Die systematische Neigung der Beweiswürdigung zugunsten der Sachverständigendarstellung ist auch durch die Wissensasymmetrie zwischen dem Sachverständigen und der Verteidigung begründet. Die in der Exploration stattfindenden Erhebungen sind fachspezifischer Natur und erfordern besondere Sachkunde.⁶⁴⁴ Diese fehlen der Verteidigung (als juristisch ausgebildete Person) im Regelfall. Dadurch wäre der Nutzen ihrer Teilnahme eingeschränkt, da sie ihr Augenmerk primär auf juristische Gesichtspunkte richten und methodische Verfehlungen des Sachverständigen nur limitiert registrieren würde.⁶⁴⁵ Auch aus diesem Grund

⁶⁴² Vgl. N 156 ff.

⁶⁴³ NOWROUSIAN, S. 105: «Darin unterscheiden sie [gemeint: die Verteidiger] sich fundamental von Staatsanwaltschaft und Gericht. Diese haben sowohl Entlastendes wie Belastendes zu berücksichtigen und sie haben auf Täter wie Opfer zu schauen – und daher eine Aufgabe, die auf den Rechtsstaat in beiden Aspekten bezogen ist. Hüter des Rechtsstaats ist daher die Justiz. Verteidiger sind die Hüter von Beschuldigtenrechten – nicht weniger, aber auch nicht mehr.»

⁶⁴⁴ Stellvertretend: AMDP, S. 14 ff.

⁶⁴⁵ Der Gesichtspunkt des mangelnden Fachwissens wird auch in der Gerichtspraxis und Literatur aufgegriffen, wenn davon ausgegangen wird, dass die Teilnahme der

würde ein beweiswürdigendes Gericht wohl oft dazu schreiten, den Darstellungen des Sachverständigen zu glauben.

Diese Wissensasymmetrie in der Exploration könnte zwar behoben werden, indem man neben der Verteidigung auch dem Privatgutachter der beschuldigten Person ein Teilnahmerecht am Explorationsgespräch einräumt.⁶⁴⁶ Die Verteidigung könnte dann die Überprüfung der genuin juristischen Aspekte, der Privatgutachter die Überprüfung der psychiatrischen Gesichtspunkte vornehmen. Mit dieser (aufwändigen⁶⁴⁷) Lösung liesse sich das mangelnde Fachwissen der Verteidigung kompensieren. Doch selbst damit wäre nur ein imperfektes Lösungsmodell geschaffen: An der gerichtlichen Wahrnehmung, dass auch der Privatsachverständige im Lager der beschuldigten Person steht⁶⁴⁸, würde sich nichts ändern. Im Zweifelsfall würde sich vor Gericht regelmässig die Darstellung des amtlichen Sachverständigen durchsetzen. Wird man sich dieser Defizite bewusst, muss der Teilnahmerechtsansatz als imperfektes Lösungsmodell zurückgewiesen werden.

2. Reflexwirkungen eines Teilnahmerechts

Der Sicherstellung der Überprüfbarkeit des Explorationssachverhalts mit einem Teilnahmerecht stehen weitere Bedenken entgegen. Es sind nämlich nicht nur die beschuldigte Person und ihre Verteidigung, welche ein berechtigtes Interesse an der effektiven Überprüfbarkeit eines Schuld- und/oder Massnahmengutachtens haben. Vielmehr hätten auch die Staatsanwaltschaft, das Gericht und allenfalls gar Privatk Kläger⁶⁴⁹ Überprüfungsinteressen. Auch ihnen müsste unter dem Gesichtspunkt der prozessualen Gleichbehandlung ein gleich effektiver Einblick

Verteidigung an der Exploration wäre mangels Fachwissen kaum von Nutzen: OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II. 4.1; OGer-AG, 16. Januar 2014, SBK.2013.373, E. 2.3.2.3; BSK StPO-II-HAENNI, Art. 251 N 28. Die Annahme des fehlenden Nutzens der Verteidigung mangels Fachwissens ist indes verkürzt, denn die Verteidigung könnte ihr Augenmerk auf die Einhaltung der juristischen Rahmenbedingungen der Begutachtung richten. Nur bei der Frage, ob ein Vorgehen des Sachverständigen mit der psychiatrischen Methodik vereinbar wäre, käme sie (teilweise) an ihre Grenzen (vgl. dazu auch SMITH, S. 441 f.).

⁶⁴⁶ GOCKER, S. 636; SIMON, S. 18; SMITH, S. 441; Merke: es könnte in der Sache nur um ein zusätzliches Teilnahmerecht des Privatsachverständigen zur Verteidigung gehen, denn dem Privatsachverständigen würde seinerseits das juristische Wissen fehlen, um unzulässige Beweiserhebungsmethoden festzustellen.

⁶⁴⁷ Koordination eines Explorationstermins zwischen mehreren Personen, Kosten für die anwesende Verteidigung und den Privatsachverständigen, usw.

⁶⁴⁸ Vgl. N 214.

⁶⁴⁹ Zur potentiellen Legitimation des Privatk lagers HEER, FS Wiprächtiger, S. 201 f.

in das Explorationsgeschehen vermittelt werden.⁶⁵⁰ Sodann darf auch der Sachverständige nicht vergessen werden, welcher sich bei einer Teilnahme der Verteidigung zwei «Gegnern» gegenübersehen und ein Interesse daran hätte, nicht mit ungerechtfertigten Beanstandungen konfrontiert zu werden.

237 Zur Befriedigung dieser Bedürfnisse stünden unterschiedliche Lösungsansätze zur Verfügung. Man könnte dem PSY-Sachverständigen erlauben, einen neutralen Beobachter ans Explorationsgespräch mitzunehmen.⁶⁵¹ Dieser Ansatz erweist sich jedoch aus zwei Gründen als wenig zielführend: Erstens scheint es fraglich, ob die berechtigten Parteien (z.B.: Staatsanwaltschaft, Privatklägerschaft) unter diesen Bedingungen tatsächlich eine gleich effektive Einsicht in die Exploration erhalten würden wie die unmittelbar anwesende Verteidigung. Zweitens bliebe es bei dieser Lösung dabei, dass das Gericht bei strittigem Explorationssachverhalt immer noch auf die Aussagewürdigung der explorationsanwesenden Parteien angewiesen wäre. Und in dieser Beweiswürdigung liegt angesichts der Ausgangslage (neutraler Sachverständiger und neutraler Beobachter v. beschuldigte Person und Verteidigung) der Schluss nahe, dass das Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten des PSY-Sachverständigen sowie des neutralen Beobachters weiterbestehen würde. Die Position der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung wäre damit nach wie vor in gewissem Masse beschränkt.

238 Zur Behebung der vorerwähnten Defizite könnte man dazu übergehen, den Strafbehörden (Staatsanwaltschaft, Gericht) und einer allfällig legitimierten Privatklägerschaft ebenfalls ein Teilnahmerecht an der Exploration einzuräumen. Diese Lösung hätte indes genau jene Implikationen, welche das Bundesgericht in seiner Verfassungspraxis befürchtet. Abgesehen von den hohen Sach- und Koordinationskosten eines solchen Vorgehens wäre zu berücksichtigen, dass bei der unmittelbaren Teilnahme all dieser Personen die Persönlichkeitsrechte des Exploranden unverhältnismässig strapaziert wären (man stelle sich eine Sexualanamnese mit einem Raum voller Personen vor) und der Informationsertrag wohl überschaubar ausfiele.⁶⁵² Neben den voranstehend erwähnten Effektivitätsgrenzen muss ein Teilnahmerecht auch vor dem Hintergrund der geschilderten Reflexwirkungen als ungeeigneter Lösungsansatz bezeichnet werden, zumal sich die Überprüfungsbedürfnisse sämtlicher Parteien durch eine

⁶⁵⁰ Zu dieser Überlegung bereits BGE 99 Ia 42, E. 3b zum Teilnahmerecht der Parteien an einem sachverständigen Augenschein: «Von einem Verstoß gegen Art. 4 BV könnte nur dann die Rede sein, wenn der Experte bei seinem Augenschein von Vertretern der gegnerischen Partei begleitet gewesen wäre.»; so auch GUYAZ, S. 141 im zivilprozessualen Kontext: «...il est incontestable que la présence d'un seul conseil, à tout le moins en procédure civile, violerait gravement le principe d'égalité des parties».

⁶⁵¹ HAUSOTTER, S. 28; LSG Rheinland-Pfalz, 20. Juli 2006, L 5 KR 39/05; ähnlich auch SIMON, S. 17 (Präsenz eines neutralen Gerichtsmitarbeiters).

⁶⁵² Vgl. N 56 f.

Aufwertung des Dokumentationsstandards besser verwirklichen lassen (dazu nachfolgend III.)

3. Inkompatibilität mit psychiatrischer Methodik

Schliesslich spricht gegen ein Teilnahmerecht der Verteidigung, dass dieses Lösungsmodell in die Methodenfreiheit des Sachverständigen eingreifen würde. Wie bereits im Themenaufriß dieser Arbeit erörtert wurde, besteht der psychiatrische Methodenstandard darin, dass Drittpersonen wie z.B. die Verteidigung grundsätzlich nicht zum Explorationsgespräch zuzulassen sind, weil dadurch eine Störung der Exploration befürchtet wird.⁶⁵³ Selbiges gilt auch für die Teilnahme weiterer Personen (Strafbehörden, Parteien etc.).⁶⁵⁴ Diese psychiatrischen Überlegungen würden wohl selbst dann gelten, wenn die teilnehmenden Personen – wie zuweilen in der Literatur diskutiert⁶⁵⁵ – nicht physisch im Explorationsraum präsent sind, sondern die Explorationsinhalte in einem anderen Raum mittels audiovisueller Übertragung zur Kenntnis nehmen.

Auch der Bruch mit der Methodenfreiheit spricht folglich gegen die Installation eines Teilnahmerechts der Verteidigung. Allerdings ist eine Relativierung anzubringen: Es ist zu bedenken, als dass die bundesgerichtlich eingeräumte Methodenfreiheit nur solange Schutz genießt, wie die gutachterlichen «Schlussfolgerungen transparent sowie für die Verfahrensbeteiligten nachvollziehbar» sind.⁶⁵⁶ Und genau an dieser Transparenz fehlt es. Ebenso wird der 4. Teil der vorliegenden Arbeit zeigen, dass der psychiatrische Methodenstandard keinen zwingenden Grund zur Einschränkung des Teilnahmerechts der Verteidigung zu bilden vermag.⁶⁵⁷ Entsprechend wird im vorliegenden Teil der mit einem Teilnahmerecht verbundene Methodeneingriff nicht als Kernargument für die Verwerfung eines Teilnahmerechts der Verteidigung beigezogen. Vielmehr sprechen die bereits aufgeführten Defizite (Glaubhaftigkeits-Bias, mangelndes Fachwissen, Reflexwirkungen) gegen die Implementierung eines Teilnahmerechts der Verteidigung zur Gewährleistung der Überprüfbarkeit des Sachverständigenbeweises. Dennoch darf der Aspekt der Methodenverletzung bei der

⁶⁵³ Vgl. N 19 ff.

⁶⁵⁴ GUYAZ, S. 141.

⁶⁵⁵ BERNHARD/BINDER, S. 13; HEER, Feigenblatt, S. 30; BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64a; SMITH, S. 450; SIMON, S. 17.

⁶⁵⁶ BGE 128 I 81, E. 2; BGer, 17. November 2011, 6B_232/2011, E. 2.3; BGer, 14. Dezember 2015, 6B_304/2015, E. 2.4; BGer, 25. Februar 2016, 6B_1237/2015, E. 1.1.3; BGer, 19. Juni 2018, 6B_582/2017, E. 2.2.3; BGer, 24. Oktober 2018, 6B_1006/2017, E. 2.3.3; zur Orientierung am aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand im Rahmen der Schuldfähigkeitsbegutachtung und Risikobeurteilung auch BOETTICHER ET AL., NSTZ 2006, S. 539; BOETTICHER ET AL., NSTZ 2005, S. 58.

⁶⁵⁷ Vgl. N 344 ff.

Diskussion möglicher Lösungsmodelle eingeführt werden, weil die nachfolgend favorisierte Lösungsvariante (Aufwertung des Dokumentationsstandards) keinen direkten Bruch mit der Methodenfreiheit des psychiatrischen Sachverständigen beinhaltet.

III. Aufwertung des Dokumentationsstandards

241 Ein Teilnahmerecht der Verteidigung ist nach den voranstehenden Ausführungen bestenfalls ein bedingt konventionskompatibles Lösungsmodell zur Sicherstellung der effektiven Überprüfbarkeit des Sachverständigenbeweises mit Blick auf die Exploration. Nachfolgend wird sich zeigen, dass die Aufwertung des Dokumentationsstandards den konventionsrechtlichen Erfordernissen besser entspricht.

1. Beweisrechtliche Bestandteile der Exploration

242 Für die Bestimmung des massgeblichen Dokumentationsstandards muss zuerst die beweisrechtliche Natur des Explorationsgesprächs erschlossen werden. Massgeblich ist dabei die Frage, welche Beweissubstrate mit der Exploration ermittelt werden und welches Dokumentationsmedium geeignet ist, diesen Prozess abzubilden. Nur wenn dies gewährleistet ist, kann die beschuldigte Person und ihre Verteidigung das fragliche Beweismittel (bzw. seine Erhebung) auf inhaltliche und formelle Mängel überprüfen und sich wirksam und sachbezogen verteidigen.⁶⁵⁸ Für die Wahl des Dokumentationsansatzes ist zu berücksichtigen, dass die Exploration sowohl eine Einvernahme- (A.) als auch eine Augenscheinkomponente (B.) enthält.

A) Einvernahmekomponente

243 Der Begriff der Einvernahme wird in der StPO nicht konkretisiert.⁶⁵⁹ Nach gängiger Interpretation wird darunter die Befragung einer Person zu Protokoll⁶⁶⁰ oder zumindest jene Befragung verstanden, deren Inhalt auf irgendeine Weise aktenkundig⁶⁶¹ wird.⁶⁶² Zwar wird in der psychiatrischen Literatur mit Nach-

⁶⁵⁸ BGer, 19. Februar 2018, 6B_307/2017, E. 1.3.1; BGer, 14. Februar 2013, 6B_307/2012, E. 3.1; BGer, 12. November 2012, 6B_719/2011, E. 4.5; BGE 129 I 85, E. 4.1.

⁶⁵⁹ ZK StPO-GODENZI, Art. 143 N 1; EGLIN, S. 75.

⁶⁶⁰ DONATSCH/CAVEGN, fp 2009, S. 105; EGLIN, S. 75; BSK StPO-I-HÄRING, Art. 143 N 2; PITTELOUD, N 354; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, N 1174; SCHMID, FS Trechsel, S. 757.

⁶⁶¹ DONATSCH/CAVEGN, fp 2009, S. 105; tendenziell auch SCHLEGEL, S. 149.

druck betont, dass die Exploration keine Einvernahme, sondern die Abklärung einer psychiatrischen Fragestellung darstelle.⁶⁶³ Dem Sachverständigen gehe es vorrangig – anders als in der strafbehördlichen Einvernahme – um die gutachterliche Erfassung der psychischen Symptomatik, während es in der Einvernahme vor allem auf das gesprochene Wort ankomme.⁶⁶⁴

Diese Position stimmt aber nur teilweise. Zwar trifft es zu, dass in der Exploration vom Sachverständigen das Untersuchungsmittel der Beobachtung benutzt wird, um das Verhalten der Exploranden, allfällige Störungssymptome usw. festzustellen (zu dieser Augenscheinkomponente nachfolgend B.). Gleichzeitig lässt sich nicht abstreiten, dass für die gutachterliche Beurteilung auch die Aussagen des Exploranden (bzw. deren Inhalt) von Bedeutung sind: Wie im Themenaufriss dargelegt wurde, befragt der Sachverständige den Exploranden im Rahmen der Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbegutachtung ausführlich zu seiner Biographie, seinem subjektiven Erleben, den konkreten Tatvorwürfen im Verfahren sowie seinen Zukunftsplänen.⁶⁶⁵ Dabei wird der Sachverständige zwar unbestritten ein Augenmerk darauf richten, wie der Explorand etwas sagt (Augenscheinkomponente; dazu B.) Gleichzeitig ist für die sachverständige Beurteilung ebenso von Bedeutung, was die beschuldigte Person inhaltlich sagt. Dies kann anhand des folgenden Beispiels illustriert werden: Ob die von der beschuldigten Person berichteten psychotischen Phasen oder Vorstrafen in der Vergangenheit tatsächlich vorlagen, hat offensichtlich eine konkrete Relevanz für die sachverständige Beurteilung (Diagnose, Risikobeurteilung etc.). Entsprechend besteht ein Bestandteil der gutachterlichen Tätigkeit auch darin, sich bezüglich des Realitätsgehalts der Angaben seitens des Exploranden zu vergewissern.⁶⁶⁶ Wäre der Aussageinhalt tatsächlich bedeutungslos, müsste die

⁶⁶² Noch extensiver ZK StPO-GODENZI, Art. 143 N 8, welche mit Blick auf den prozessualen Schutzgedanken die Protokollierung/Aktenkundigkeit nicht für massgeblich hält. Vielmehr formuliert sie folgenden Einvernahmebegriff: «Die Strafbehörden müssen zur Abklärung konkreter Verdachtsmomente unter Offenlegung ihrer amtlichen Funktion von einer Person, der die Verfahrensrolle einer beschuldigten Person, eines Zeugen oder einer Auskunftsperson zugewiesen werden muss, Auskünfte mit Bezug auf den Verfahrensgegenstand eines Strafverfahrens verlangen.»

⁶⁶³ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; FOERSTER/FOERSTER, S. 1016; HABERMEYER/SACHS, N 7; Hässler/Kinze/Nedopil-KINZE, S. 41 f.; KIESEWETTER, Kriminalistik 1995, S. 602; Kröber et al.-II-KRÖBER, S. 167; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 192.

⁶⁶⁴ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; HABERMEYER/SACHS, N 7; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 192 f.

⁶⁶⁵ Vgl. N 12 ff.

⁶⁶⁶ KIEGELAND, S. 167 ff.; Kröber et al.-III-KRÖBER, S. 97: «...soll der Sachverständige unter Offenbarung eigenen Wissens gezielt nachfragen,...mit anderen Darstellungen der Realität oder anderen früheren Einlassungen konfrontieren, Korrekturen ermöglichen.»; WAGNER/KRANICH, S. 9: «Eine Besonderheit stellt die Verfahrens-

sachverständige Person dies nicht tun. Auch darum ist der Sachverständige im Sinne des allgemeinen Dokumentationsgrundsatzes verpflichtet, die für seine Beurteilung wesentlichen Aussagen des Exploranden zu dokumentieren.⁶⁶⁷

- 245 Vor dem Hintergrund des Gesagten lässt sich die materielle Einvernahme Komponente der Exploration nicht übersehen. Die durch die sachverständige Befragung erhobenen Angaben des Beschuldigten fliessen über den Sachverständigenbeweis in den Strafprozess ein, werden vom Gericht verwertet⁶⁶⁸, gewürdigt und bilden (sofern die Angaben des Beschuldigten als glaubhaft taxiert werden) einen Teil des gerichtlichen Urteilssachverhalts. Damit kommt der sachverständigen Befragung im Resultat die beweisrechtliche Bedeutung einer strafbehördlichen Einvernahme zu.

B) Augenscheinkomponente

- 246 Die Exploration beschränkt sich jedoch nicht auf die Erhebung von Aussageinhalten seitens der beschuldigten Person, sondern besteht in einem wesentlichen Teil auch aus der sachverständigen Beobachtung der Exploranden. Dies weckt Assoziationen zum Augenschein. Der Augenschein nach Art. 193 StPO beinhaltet nach gängiger Formulierung die «sinnliche Wahrnehmung urteilsrelevanter bzw. beweiserheblicher Sachverhalte»⁶⁶⁹, womit beispielsweise deren Existenz, Lage/Standort, oder (bei Tatrekonstruktionen) die dort stattfindenden Vorgänge gemeint sind.⁶⁷⁰ Für den vorliegenden Kontext ist zu beachten, dass auch der Mensch ein Augenscheinsobjekt sein kann.⁶⁷¹ Nun ist zwar die Exploration seitens des Sachverständigen formellrechtlich betrachtet kein Augenschein i.S.v. Art. 193 StPO, sondern eine einfache Erhebung im Rahmen des Sachverständigenrechts (Art. 185 Abs. 4 StPO), da für die fraglichen Wahrnehmungen einschlägiges Fachwissen notwendig ist.⁶⁷² Trotzdem kann nicht in Abrede gestellt werden, dass der Sachverständige in dieser Exploration Informationen durch seine sinnliche Wahrnehmung (visuell, auditiv etc.) erhebt, indem er den Exploranden und sein Verhalten eingehend beobachtet, damit Informationen für den

weise mit unrealistischen Angaben dar. Hierbei gebietet es ein transparenter und fairer Umgang mit dem Klienten, durch Rückmeldungen widerzuspiegeln, wie man seine Äußerungen bewertet. Dadurch erhält der Betroffene die Chance, seine Aussagen zu korrigieren. Der Psychologe ermuntert den Betroffenen zur Korrektur, Ergänzung und Präzisierung der Angaben.»

⁶⁶⁷ Vgl. N 178 ff.

⁶⁶⁸ Vgl. N 310 ff.

⁶⁶⁹ OGer-ZH, 5. November 1997, E. II. 3.b, in: ZR 98/1999 S. 174 ff.

⁶⁷⁰ BSK StPO-I-BÜRGISSER, Art. 193 N 1 f.; ZK StPO-DONATSCH, Art. 193 N 1; NÄPFLI, S. 18 f.

⁶⁷¹ ZK StPO-DONATSCH, Art. 193 N 22.

⁶⁷² ZK StPO-DONATSCH, Art. 193 N 22.

psychischen Befund und die Persönlichkeitsbeschreibung erhebt und diese zur weiteren Verwendung in seinem Gutachten dokumentiert.⁶⁷³ Damit weist die Exploration den materiellen Charakter eines Augenscheins auf.⁶⁷⁴

2. Implikation auf Wahl des Dokumentationsansatzes

Nach den voranstehenden Erwägungen beinhaltet das Explorationsgespräch 247 sowohl eine Einvernahme- als auch eine Augenscheinkomponente. Der Dokumentationsstandard hat diesen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen, d.h. ihm muss die Eignung zukommen, die durch die Einvernahme und den Augenschein erhobenen Informationen adäquat abzubilden. Nur dann ermöglicht die Dokumentation den berechtigten Parteien die effektive Ausübung des Akteneinsichtsrechts und des Rechts auf Stellungnahme.⁶⁷⁵ Die nachfolgende Darstellung wird zeigen, dass nur ein Lösungsansatz diesen Forderungen gerecht wird.

A) Ausscheiden ungeeigneter Dokumentationsansätze

a) Defizite einer Protokollierungspflicht

Nach einer im Schrifttum vertretenen Meinung sollte die sachverständige Person 248 im Minimum verpflichtet werden, das Explorationsgespräch zu protokollieren.⁶⁷⁶ Mit der analogen Anwendung der Vorschriften über Einvernahmeprotokolle (Art. 78 StPO) wäre die sachverständige Person zur laufenden Protokollierung in der Sprache des Exploranden verpflichtet (Abs. 1 und 2), müsste wichtige Fragen und Antworten wörtlich protokollieren (Abs. 3), könnte dem Exploranden gestatten, Antworten selbst zu diktieren (Abs. 4) und hätte dem Exploranden das Protokoll nach Abschluss der Exploration zur Kenntnisnahme, Visierung und Unterzeichnung vorzulegen (Abs. 5). Für die Augenscheinkomponente der Exploration müsste darüber hinaus ein Augenscheinprotokoll erstellt wer-

⁶⁷³ Vgl. N 14 und N 181.

⁶⁷⁴ TOEPEL, S. 116: «... oder ein Angeklagter bestimmte Symptome einer Geisteskrankheit zeigt. Der Sachverständige nimmt hier an Stelle des Gerichts einen Augenschein ein, wozu eine besondere Sachkunde erforderlich ist.»; ansatzweise sodann in der Praxis des Bundesgerichts in BGE 132 V 443, E. 3.6: «Augenschein an der Person»; BGE 122 II 464: «...recourant, qui est en quelque sorte lui-même l'objet de l'expertise.»; damit spricht das Bundesgericht nichts anderes an, als hier vertreten wird: die Exploration ist auch ein (sachverständiger) Augenschein am Exploranden.

⁶⁷⁵ Vgl. N 178.

⁶⁷⁶ BERNHARD/BINDER, S. 12 f.; HEER, Anforderungen, 125 f.

den.⁶⁷⁷ Praktisch betrachtet ist dieses Lösungsmodell aber aus verschiedenen Gründen ungeeignet, ein faires Verfahren zu garantieren.

aa) *Inadäquate Dokumentation der Exploration*

- 249 Das bedeutendste Defizit des Protokollierungsansatzes besteht darin, dass das Schriftprotokoll seiner Natur nach ungeeignet ist, den Explorationssachverhalt adäquat abzubilden. Die dafür relevanten Gründe wurden bereits in § 7 erörtert und bildeten die Grundlage für das Fazit, dass die sachverständige Schriftdokumentation nur eine imperfekte Informationsbrücke zum Explorationssachverhalt schlägt, da sie mit zahlreichen Verzerrungen sowohl bzgl. der Einvernahme- als auch der Augenscheinkomponente einhergeht (Auslassen von wichtigen Aussagen des Exploranden, verzerrte Darstellung von Aussagen, sprachliche Glättung usw.), Informationen bewusst oder unbewusst gefiltert werden und sich der Dokumentationsfokus auf den Exploranden und nicht das (ebenso überprüfungsbedürftige) Verhalten des Sachverständigen bezieht. Diese Ausführungen gelten ohne Vorbehalte auch im vorliegenden Kontext.⁶⁷⁸ Selbst bei Geltung der massgeblichen Protokollierungsvorschriften käme dem verantwortlichen Sachverständigen ein grosser Ermessensspielraum bei der konkreten Ausgestaltung des Protokolls zu⁶⁷⁹, womit die Gefahr einer lückenhaften Explorationsabbildung nicht gebannt wäre.

bb) *Kapazitätsgrenzen der beschuldigten Person*

- 250 Der Protokollierungsansatz geht neben der mangelnden Dokumentationseignung auch mit einer Überforderung der beschuldigten Person einher. Bestenfalls wäre die beschuldigte Person in der Lage, von ihr nicht gemachte Angaben im Protokoll zu beanstanden oder Aussagen zu präzisieren. Allerdings wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass es der beschuldigten Person i.d.R. an psychiatrischem und juristischem Fachwissen fehlt, dass sie keine Beobachterstellung bezüglich ihrer eigenen Person hat, dass ihre Wahrnehmungen durch psychische Störungen verfälscht sein können und sie deswegen kaum in der Lage ist, das Explorationsgeschehen zu rekonstruieren und methodisch-juristische Fehlverhalten des Sachverständigen zu registrieren und zu beanstanden.⁶⁸⁰ Sie könnte daher die sachverständige Sachverhaltsdarstellung der Exploration nur limitiert

⁶⁷⁷ Zum allgemeinen Erfordernis des Augenscheinprotokolls: BGE 142 I 86, E. 2.2.

⁶⁷⁸ Vgl. N 176 ff.

⁶⁷⁹ Zum grossen Ermessensspielraum bei strafbehördlichen Protokollen: CAPUS, «Justice - Justiz - Giustizia» 2014/3, N 4.

⁶⁸⁰ Vgl. N 198 ff.

überprüfen.⁶⁸¹ In vielen Fällen dürfte die Annahme näher liegen, dass die beschuldigte Person das Protokoll vorbehaltlos unterzeichnet.⁶⁸²

Tendenziell wäre die verfahrensrechtliche Stellung der beschuldigten Person durch den Protokollierungsansatz sogar verschlechtert, denn mit dem Vorgang des Lesens und Unterzeichnens durch die einvernommene Person geht die beweisrechtliche Folge einher, dass das Protokoll «als wahrheitsgetreue Repräsentationen der Einvernahme aufgefasst» wird, wodurch ein späterer Widerruf der protokollierten Aussage erschwert wird (sog. Bindungsfunktion des Protokolls).⁶⁸³ Auf die Exploration übertragen bedeutet dies, dass die beschuldigte Person mit ihrer Unterschrift u.U. einen Explorationssachverhalt «absegnet», der (a) nicht dem Geschehenen entspricht und/oder der (b) durch unzulässige Mittel erhoben wurde, was ihr aufgrund der diversen Defizite (Erinnerung, Fachwissen etc.) nicht einsehbar war. Mit der vorbehaltlosen Unterschrift der beschuldigten Person wäre es noch schwieriger, wirksame Einwendungen gegen die sachverständige Explorationsdokumentation zu erheben. Doch selbst bei einer äusserst wachsam beschuldigten Person wäre zu bedenken, dass der protokollierte Explorationsinhalt verwertbar bliebe, wenn sich die beschuldigte Person der Unterzeichnung des Protokolls verweigert (vgl. Art. 78 Abs. 5 StPO).⁶⁸⁴ In dieser Konstellation würde sich wieder die bereits erwähnte Situation einstellen, dass das Gericht regelmässig der gutachterlichen Sachverhaltsdarstellung Glauben schenkt (Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten des Sachverständigen).⁶⁸⁵ Auch vor diesem Hintergrund ist der Protokollierungsansatz als ungeeignet einzustufen.

⁶⁸¹ GEIGER, S. 51: «Zum einen sind die wenigsten in der Lage, festzustellen, ob der Inhalt der teilweise einstündigen Exploration vollständig erfasst wurde; zum andern kann ein nicht Sachkundiger schwerlich sofort erkennen, ob die – meist nur sinn-gemässe – Wiedergabe der eigenen Antworten exakt deren Wortlaut trifft.» In der Begutachtungspraxis wird zuweilen der beschuldigten Person nach der Exploration vom Sachverständigen der Inhalt der Explorationsdokumentation zur Stellungnahme informell zugesendet und ihr Gelegenheit gegeben, Einwendungen zu formulieren, wobei die sachverständige Person diese in geeigneter Form vermerkt (dazu GEIGER, S. 51). Auch bei diesem Vorgehen ist die beschuldigte Person indes nicht in der Lage, die sachverständige Sachverhaltsdarstellung effektiv zu überprüfen. Insofern gilt das hier Ausgeführte analog.

⁶⁸² Für die strafbehördliche Einvernahme, aber mit Geltung für die analoge Konstellation im Explorationsgespräch: MELUNOVIC, S. 602.

⁶⁸³ CAPUS/STOLL, S. 206 ff; CAPUS, «Justice - Justiz - Giustizia» 2014/3, N 14.

⁶⁸⁴ Dazu auch CAPUS, «Justice - Justiz - Giustizia» 2014/3, N 7.

⁶⁸⁵ Vgl. N 205 ff.

cc) *Störung der Exploration*

- 252 Gegen die Implementierung einer formellen Protokollierungspflicht spricht so-
dann die Tatsache, dass das konstante Mitschreiben des Sachverständigen ge-
eignet wäre, die Wahrheitssuche im Rahmen der Exploration zu stören, da sich
die sachverständige Person verstärkt der gesetzeskonformen Protokollierung
widmen müsste.⁶⁸⁶ Als Folge ist zu erwarten, dass die Spontanität des Gesprächs
sowie der Kontakt zum Exploranden in Teilen verloren gingen und dass die
bereits erwähnten Filtereffekte⁶⁸⁷ noch einmal verstärkt würden.⁶⁸⁸ Es ist wohl
auch vor diesem Hintergrund zu würdigen, dass in einigen psychiatrischen Stel-
lungnahmen formuliert wird, während des Interviews solle möglichst nicht mit-
geschrieben werden⁶⁸⁹ bzw. dass die Erstellung eines Verbalprotokolls im Rah-
men der Exploration nicht machbar und sachlich absurd⁶⁹⁰ sei.

dd) *Würdigung*

- 253 In einer Gesamtschau wäre eine Protokollierungspflicht kaum geeignet, zur
effektiven Überprüfung des Explorationsgeschehens durch die beschuldigte
Person und deren Verteidigung beizutragen. Ein Schriftprotokoll wäre lücken-
haft, und zwar sowohl bezüglich der rapportierten Aussageinhalte (Einvernahme-
komponente) als auch bezüglich der sachverständigen Beschreibung des
psychischen Befunds und der Persönlichkeit des Exploranden (Augenschein-
komponente). Sodann würde die Kontrolle des Protokolls die beschuldigte Per-
son in verschiedener Weise überfordern. Schliesslich wäre (wenn sich der Sach-
verständige nicht von einer Hilfsperson, die Protokoll führt, begleiten lässt) eine
Protokollierungspflicht geeignet, die Sachverhaltserhebung in der Exploration
zu stören, da der Sachverständige stark mit der Niederschrift der Aussagen be-

⁶⁸⁶ Anmerkung: Dieser Kritikpunkt gilt für den Fall des Sachverständigen, der nicht
von einer Hilfsperson begleitet wird. Wäre letzteres der Fall, könnte die Hilfsperson
die Protokollierung übernehmen. Selbst dann wären aber gewisse Verzögerungen
zu erwarten, da der Sachverständige wohl bestrebt wäre, der Hilfsperson genug Zeit
für die sachgerechte Protokollierung zu lassen. Wenn er dies nicht tun würde, stiege
wiederum das Risiko, dass die Hilfsperson elementare Informationen zu protokol-
lieren vergisst.

⁶⁸⁷ Vgl. N 190 ff.

⁶⁸⁸ SANER, S. 138: «...erschwert die schriftliche Protokollierung dem Psychiater...die
sachgerechte Durchführung der Untersuchung, weil er sich gleichzeitig auf den Ex-
ploranden und auf das Schreiben des Protokolls konzentrieren muss.»; bezüglich
dem Verlust der Spontanität: HAUG, S. 136, FASTENMEIER, S. 85 f. und ZOEHNER ET
AL., S. 226; zum Kontaktverlust: TONDORF/TONDORF, N 351 und GEIGER, S. 51
(Störung durch fehlenden Blickkontakt bei handschriftlicher Dokumentation und
Klappern der Tastatur); ebenso kritisch zur Protokollierungspflicht: RICHNER, S. 22.

⁶⁸⁹ FÄHNDRICH/STIEGLITZ, S. 52.

⁶⁹⁰ RICHNER, S. 22.

fasst wäre. Freilich könnte nun eingewendet werden, dass diese Umstände (lückenhafte Erfassung der Erhebung, Störung des Gesprächsablaufs) auch bei einer strafbehördlichen Einvernahme vorliegen, welche nach geltendem Recht ebenfalls nur mittels Schriftprotokoll nach Art. 78 StPO zu dokumentieren ist. Dieses Argument ist aber in mehrfacher Weise instabil.

Erstens wird wegen der Lückenhaftigkeit der Schriftdokumentation bereits bei der strafbehördlichen Einvernahme mit guten Gründen gefordert, die Einvernahme sei audiovisuell aufzuzeichnen, um eine umfassende nachträgliche Überprüfung zu gewährleisten.⁶⁹¹ Entsprechend ist das Argument, auch die Einvernahme werde nicht aufgezeichnet, wenig zielführend, wenn bereits dort die Defizite einer reinen Protokollierungspflicht geltend gemacht werden. Zweitens vernachlässigt der Seitenblick auf die strafbehördliche Einvernahme die Tatsache, dass die Exploration neben der Einvernahme- auch eine Augenscheinkomponente beinhaltet. Gerade in diesem Zusammenhang drängt sich ein Blick auf Art. 193 StPO auf. Bei Augenscheinen werden Wahrnehmungen zwar auch in einem schriftlichen Augenscheinprotokoll festgehalten; diese Dokumentation wird aber wo notwendig und möglich mit Augenscheinsurrogaten (Bild, Video, Plänen usw.) ergänzt (Art. 193 Abs. 4 StPO).⁶⁹² Wenn man diesen Gedanken auf das Explorationsgespräch überträgt, müsste die Exploration als zeitlich gestreckter Kommunikations- und Interpretationsprozess neben der schriftlichen Dokumentation durch ein geeignetes Augenscheinsurrogat festgehalten werden.

Entscheidend für die mangelnde Stichhaltigkeit des Vergleichs zur strafbehördlichen Einvernahme der beschuldigten Person ist jedoch die Tatsache, dass die beschuldigte Person bei der strafbehördlichen Einvernahme von ihrer Verteidigung begleitet werden kann (Art. 159 StPO, Art. 147 StPO) und letztere bei der Abnahme des Protokolls strafprozessuale Verfehlungen der einvernehmenden Behörde oder abweichende Sachverhaltenswahrnehmungen aktenkundig machen kann. Diese schützende Anwesenheit der Verteidigung fehlt beim hier diskutierten Protokollierungsansatz im Rahmen der Exploration, da ein Teilnahmerecht der Verteidigung nach geltendem Recht nicht besteht. Summa summarum zeigt sich, dass der Protokollierungsansatz ungeeignet ist, eine effektive Überprüfbarkeit der Exploration durch die beschuldigte Person und ihre Verteidigung sicherzustellen.

⁶⁹¹ AMMANN, S. 570 ff.; MELUNOVIC, S. 596 ff.; NÄPFLI/RUCKSTUHL, S. 6 ff.; WEDER, S. 554 f.

⁶⁹² BSK StPO-I-BÜRGISSER, Art. 193 N 8; ZK StPO-DONATSCH, Art. 193 N 28 f; NÄPFLI, S. 19; BGE 142 I 86, E. 2.2 f.; BGE 130 II 473 E. 4.2; BGer, 8. Juni 2016, 1C_646/2015, E. 2.2.

b) *Defizite einer Tonband-Dokumentation*

256 Die voranstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass das Schriftprotokoll die Exploration nicht sachgerecht abzubilden vermag und dass sich – gerade auch mit Blick auf die Augenscheinkomponente der Exploration – die zusätzliche Dokumentation mit einem Augenscheinsurrogat (Art. 194 Abs. 4 StPO) aufdrängt. Ein solches Surrogat könnte die Tonbandaufnahme darstellen. Wenig überraschend finden sich in der Literatur Forderungen, die Exploration sei auf Tonband (bzw. heute wohl treffender: digitale Tonträger) aufzuzeichnen.⁶⁹³ Damit wäre unbestritten eine Verbesserung gegenüber dem Status quo geschaffen: Die Aussageinhalte des Exploranden sowie der auditiv wahrnehmbare Teil der sich allenfalls ereignenden methodischen oder juristischen Fehler des Sachverständigen wären bei einem solchen Vorgehen dokumentiert. Allerdings hätte auch die Tonaufnahme systembedingte Grenzen. Die Augenscheinkomponente der Exploration könnte nur auf auditiver Ebene dokumentiert werden. Sonstige Informationsebenen, die visuell wahrnehmbare Interaktion zwischen Sachverständigem (inkl. Gestik, Mimik usw.) und Exploranden, wären nicht abgebildet.⁶⁹⁴ Aus diesen Gründen wäre die Aufzeichnung auf Tonband als Dokumentationsmittel unvollkommen, zumal mit der nachfolgend geschilderten audiovisuellen Aufzeichnung ein Instrument zur Verfügung steht, welches dieses Defizit nicht aufweist.

B) **Audiovisuelle Aufzeichnung als sinnvoller Dokumentationsstandard**

257 Die quasi-unmittelbare Wahrnehmung der Exploration kann mit der audiovisuellen Aufnahme sichergestellt werden.⁶⁹⁵ Dabei scheint folgende Vorbemerkung zentral: Die audiovisuelle Aufzeichnung wäre lediglich ein Dokumentationszusatz und würde die schriftliche Dokumentation der wesentlichen Explorationsinhalte im Gutachten nicht ersetzen.⁶⁹⁶ Das Festhalten am grundsätzlichen Schriftlichkeitserfordernis ist in praktischer Hinsicht gerechtfertigt, denn es bewahrt alle Beteiligten davor, sich stundenlang Aufzeichnungen anzusehen bzw. anzuhören und erlaubt rasch den Überblick bezüglich des dokumentierten Verfahrensvorgangs.⁶⁹⁷ Mit der audiovisuellen Aufzeichnung wäre es aber möglich, die Schriftdokumentation des Sachverständigen im Bedarfsfall auf die Probe zu

⁶⁹³ ALIOTTA, Begutachtungen, S. 73; zu den Vorteilen einer Tonbandaufzeichnung sodann FASTENMEIER, S. 86; GEIGER, S. 51.

⁶⁹⁴ RICHNER, S. 22; GEIGER, S. 52.

⁶⁹⁵ BROWN, S. 90.

⁶⁹⁶ BGE 143 IV 408, E. 8.3; BGer, 18. April 2019, 6B_98/2018, E. 2.3.1; HEER/COVACI, S. 451; für die analoge Konstellation bei Einvernahmen: MELUNOVIC, S. 605; CAPUS/STOLL, S. 213 f.

⁶⁹⁷ BGE 143 IV 408, E. 8.3.

stellen. In den nachfolgenden Passagen wird sich zeigen, dass die mit einer audiovisuellen Aufzeichnung der Exploration verbundenen Vorteile die (befürchteten) Nachteile klar überwiegen.

a) *Vorteile der audiovisuellen Aufzeichnung*

aa) *Transparenz der Exploration*

Durch die audiovisuelle Aufzeichnung (ein im Strafprozess bereits etabliertes⁶⁹⁸ und damit mit unserer Rechtsordnung harmonisierendes Instrument) würde die Exploration transparent; sämtliche gutachterlichen Erhebungen wären der Überprüfbarkeit auf fachspezifische oder juristische Fehler zugänglich und zwar sowohl für die Verteidigung als auch die anderen Verfahrensbeteiligten (Strafverfolgungsbehörde, Gerichte, u.U. auch Privatklägerschaft).⁶⁹⁹ Uneinigkeiten bezüglich des Explorationssachverhalts oder methodisch-juristische Verfehlungen des Sachverständigen könnten ohne Weiteres aufgeklärt werden.⁷⁰⁰ 258

Damit würde nicht nur dem Exploranden die effektive Überprüfung des Gutachtens erlaubt, sondern auch dem PSY-Sachverständigen Schutz vor ungerechtfertigten Beanstandungen seitens des Exploranden geboten.⁷⁰¹ Die Transparenz der Exploration hätte zur Wirkung, dass die Position und Rolle des Sachverständigen optimiert würde. Erstens könnten durch die Aufzeichnung die Einhaltung von Ausstandsvorschriften besser überprüft werden, was sich positiv auf das Neutralitätskriterium auswirkt. Zweitens könnte das Gericht mit dieser Dokumentationsgrundlage die Schärfe seiner Plausibilitätsprüfung im Rahmen der 259

⁶⁹⁸ HEER, Anforderungen, S. 125 f. sowie HEER/COVACI, S. 450 weisen zurecht darauf hin, dass sich bei der Befragung von Opfern sexueller Übergriffe ein entsprechendes Verfahren (Aufzeichnung) längst eingeschleppt hat.

⁶⁹⁹ HEER, LA Niggli, S. 115; BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64b; HEER/COVACI, S. 450; SIEGEL/KINSCHERFF, S. 380; GUYAZ, S. 141; SANER, S. 138; SMITH, S. 442 f.; WESTHOFF/KLUCK, S. 95; SIMON, S. 16; MARTINEZ/GRAY, S. 180; NÄPFLI, S. 79; differenzierend MELTON ET AL., S. 79, der der Meinung ist, dass auch die audiovisuelle Aufzeichnung nicht alle Kontextvariablen der Exploration übermitteln kann; zu den Vorteilen der realitätsgetreuen Dokumentation bei der strafbehördlichen Einvernahme auch AMMANN, S. 574.

⁷⁰⁰ BÖHME, N 727; HEER, Anforderungen, 125 f.; HUBER, S. 273; NÄPFLI, S. 77 (für die audiovisuell aufgezeichnete polizeiliche Vernehmung, aber mit identischer Geltung für den vorliegenden Kontext); AAPL TASK FORCE, S. 2 f.

⁷⁰¹ HUBER, S. 273; siehe sodann IDHE-SCHOLL in seinem Interview mit dem SRF auf <https://www.srf.ch/news/schweiz/gutachten-fuer-versicherungen-gutachter-schreibt-falsches-arztzeugnis-rente-weg>; besucht am 6. Mai 2019). Für die strafbehördliche Einvernahme, aber mit identischer Geltung für den Explorationskontext: AMMANN, S. 574 f.; allgemein zum Problemkreis von Vorwürfen seitens des Exploranden CLAAS, S. 25.

Beweiswürdigung erhöhen, erhalte erhöhte Selbständigkeit in der Entscheidungsfindung und sähe sich schliesslich in seiner verfassungsrechtlichen Unabhängigkeit gestärkt.⁷⁰²

bb) *Methodenkompatibilität*

260 Das Dokumentationsmittel der audiovisuellen Aufzeichnung hat überdies den Vorteil, dass es mit der psychiatrischen Methodik kompatibel wäre. Zwar bestehen im Einzelnen durchaus aufzeichnungskritische Stimmen seitens forensischer Psychiater, auf die noch einzugehen sein wird.⁷⁰³ Diese ändern jedoch nichts an der Feststellung, dass die audiovisuelle Aufzeichnung ein anerkanntes Dokumentationsmittel der Psychiatrie darstellt. Dies zeigt sich nicht nur im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildungen.⁷⁰⁴ Auch im forensisch-psychiatrischen Kontext ist die audiovisuelle Aufzeichnung als Dokumentationsmedium anerkannt. Dabei sprechen sich nicht nur Einzelstimmen für eine Aufzeichnung aus.⁷⁰⁵ Vielmehr sehen auch die vom Bundesgericht bei seiner Rechtsfindung konsultierten⁷⁰⁶ Mindestanforderungen von BOETTICHER ET AL. für Schuldfähigkeits- und Prognosegutachten die Möglichkeit der Videodokumentation explizit vor.⁷⁰⁷ Dieselbe Dokumentationsform wird sodann bei etablierten Diagnoseinstrumenten wie der PCL-R (Psychopathy Checklist – Revised) als Option bezeichnet.⁷⁰⁸ Auch jenseits der Landesgrenzen ist die audiovisuelle Aufzeich-

⁷⁰² BINDER, S. 155; BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 93; SANER, S. 138.

⁷⁰³ Vgl. N 267 ff.

⁷⁰⁴ ELLGRING, S. 11 ff.; FÄHNDRICH /STIEGLITZ, S. 32 und 46; LINDEN, Videofeedback, S. 155; MARTINEZ/GRAY, S. 180; RACHLIN/SCHWARTZ, S. 1013; SIEGEL/KINSCHERFF, S. 381; differenzierend KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 193, der aufgezeichnete Gespräche von einer Begutachtungssituation sowie von «echten» Therapiegesprächen (gemeint: nicht aufgezeichnete Therapiegespräche) unterscheidet.

⁷⁰⁵ NOLL/BERNHARD, S. 8 (Votum Noll); HEER/COVACI, S. 450 mit Verweis auf ein Votum von Prof. Marc Graf; WESTHOFF/KLUCK, S. 95; so auch IDHE-SCHOLL in seinem Interview mit dem SRF (<https://www.srf.ch/news/schweiz/gutachten-fuer-versicherungen-gutachter-schreibt-falsches-arztzeugnis-rente-weg>; besucht am 6. Mai 2019).

⁷⁰⁶ Auch das Bundesgericht rekurriert auf diese Quellen: vgl. BGer, 3. Dezember 2015, 6B_265/2015, E. 6.3 (Bezug auf Mindestanforderungen für Prognosegutachten); BGE 140 IV 49, E. 2.4.1 (Bezug auf Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten).

⁷⁰⁷ Die Mindestanforderungen: BOETTICHER ET AL., NStZ 2005, S. 59 und BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 541; das diese Mindestanforderungen rezipierende Schrifttum: MÜLLER/NEDOPIL, S. 362 und 422; Venzlaff et al-DRESSING/FOERSTER, S. 66 und S. 424.

⁷⁰⁸ MOKROS ET AL., 22 führen für die Dokumentation der PCL-R aus, dass entweder ausführliche schriftliche Aufzeichnungen der Interviews angefertigt werden sollen oder, falls möglich, Audio- oder Videoaufnahmen erstellt werden sollen.

nung ein anerkanntes Dokumentationsmittel.⁷⁰⁹ In einer Gesamtschau scheint somit der Schluss gerechtfertigt, dass die audiovisuelle Aufzeichnung dem psychiatrischen Methodenstandard nicht zuwiderläuft.

cc) *Leistungsmöglichkeiten des Sachverständigen*

Die fortlaufende Aufzeichnung der Exploration hätte sodann zur Folge, dass der Sachverständige sich besser auf die Wahrheitssuche konzentrieren könnte. So stünde es dem PSY-Sachverständigen z.B. frei, die Niederschrift der Exploration sinhalte erst nachträglich und auf Basis des Videos zu erstellen oder allfällige Präzisierungen anzubringen.⁷¹⁰ Ebenso darf erwartet werden, dass der Gesprächsfluss verbessert würde, das Gespräch weniger lang ausfiele und sich der Sachverständige besser auf das Explorationsgeschehen fokussieren könnte.⁷¹¹ Bei grossen Zeitspannen zwischen einer allfälligen Exploration und der späteren Aussage des Sachverständigen vor Gericht könnte die audiovisuelle Dokumentation überdies zu einer wertvollen Gedächtnisauffrischung beigezogen werden und die Aussagequalität der sachverständigen Stellungnahme vor Gericht verbessern.⁷¹²

dd) *Ausbildungseffekte*

Längerfristig wäre durch die Existenz audiovisueller Aufzeichnungen auch eine Qualitätsverbesserung der psychiatrischen Explorationstechnik zu erwarten. Das Vorliegen einer authentischen Dokumentation könnte zur Erstellung von Case-Studies führen, welche in der forensischen Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden. Aus mangelhaften Beispielen könnten die notwendigen Lehren gezogen werden.⁷¹³

⁷⁰⁹ CRAMER/BRODSKY, S. 58; interessant auch SHEALY/PIRELLI/CRAMER, welche auf S. 565 darlegen, dass die audiovisuelle Aufzeichnung von 45.7% (n = 160) der Befragten Sachverständigen als eine akzeptable Praktik für die forensische Begutachtung bezeichnet wurde. Nur 19.4% stellten sich dagegen. 35 % waren der audiovisuellen Aufzeichnung gegenüber neutral eingestellt.

⁷¹⁰ BGE 143 IV 408, E. 8.3; AMMANN, S. 573.

⁷¹¹ AAPL TASK FORCE, S. 2; FASTENMEIER, S. 86 (bzgl. der analogen Konstellation bei der Tonbandaufzeichnung); für die analoge Ausgangslage bei polizeilichen Vernehmungen: AMMANN, S. 574; NÄPFLI, S. 78; US Court of Appeals, District of Columbia Circuit, United States v. Byers, 740 F2d 1104, Dissent Bazelon, N 171.

⁷¹² SIEGEL/KINSCHERFF, S. 374; AAPL TASK FORCE, S. 3; zum Nutzen einer Aufzeichnung auch WESTHOFF/KLUCK, S. 95.

⁷¹³ AAPL TASK FORCE, S. 14; AHRENS/LINDEN, S. 155; MARTINEZ/GRAY, S. 181; SIEGEL/KINSCHERFF, S. 374 sowie 381 f.; für die analoge Überlegung bei strafbehördlichen Einvernahmen AMMANN, S. 575; NÄPFLI, S. 79.

ee) *Verhinderung der Teilnahmerechtskumulation*

- 263 Mit der audiovisuellen Aufzeichnung würden überdies auch die vom Bundesgericht befürchtete Teilnahmerechtskumulation in der Exploration sowie die damit zusammenhängenden Nachteile verhindert.⁷¹⁴ Schützenswerte Informationsinteressen seitens der Strafbehörden oder von Privatklägern könnte kraft der objektiven Dokumentation Rechnung getragen werden. Ihre Teilnahme an der Exploration wäre nicht erforderlich, da sie die beschuldigte Person oder den Sachverständigen ohne Weiteres nachträglich, im Rahmen der Stellungnahme zum Gutachten oder anlässlich des gerichtlichen Verfahrens, zum Explorationsinhalt befragen könnten.

ff) *De-facto-Durchsetzbarkeit durch Exploranden*

- 264 Die audiovisuelle Aufzeichnung bietet sich auch vor einem profanen Hintergrund an. Explorationsgespräche mit Sachverständigen können – da nach geltender Praxis nicht unter Art. 179^{ter} StGB fallend – straflos heimlich vom Exploranden aufgezeichnet werden.⁷¹⁵ Ohne an dieser Stelle sämtliche Eventualitäten zu benennen, gibt es gute Gründe für die Annahme, dass eine entsprechende Aufnahme im Strafverfahren als Beweismittel zugelassen würde, wenn sich daraus die Mangelhaftigkeit eines Gutachtens ergeben würde.⁷¹⁶

gg) *Wegfallen unnötiger Rechtsmittelverfahren*

- 265 Die audiovisuelle Aufzeichnung könnte sodann ökonomische Vorteile bieten. Bei Streitigkeiten über den Explorationsinhalt bestünde eine Dokumentationsgrundlage, mit der sich die vorgebrachten Einwände konkret überprüfen lassen würden. Dadurch könnten langwierige Verfahren, in welchen über den genauen Explorationsinhalt gestritten wird, vermieden und einen Teil der noch zu erläuternden Kosten einer Aufzeichnung (Aufzeichnungsinfrastruktur, Sichtung der Aufzeichnung etc.) kompensiert werden.⁷¹⁷

⁷¹⁴ Dazu N 56.

⁷¹⁵ HAAG, S. 14; Nichtanhandnahmeverfügung der StA-Schwyz, 29. Juni 2017, SUB 2017 397 JJ, E. 1 ff.; BGE 108 IV 161; BGer, 7. März 2019, 6B_925/2018, E. 1.4 f.; OGer-ZH, 27. August 2014, SB130424, E. 2 (audiovisuelle Aufzeichnung einer Einvernahme); kritisch: YOUSSEF, FS Donatsch, S. 3 ff.; vgl. sodann GOLDSTEIN, The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law 1989, S. 367 ff.; KIEGELAND, S. 250; es bleibt anzumerken, dass die faktische Möglichkeit der heimlichen Aufzeichnung nur bei Explorationen besteht, bei denen die Explorandin in Freiheit begutachtet wird. In der Haft sind die technischen Aufzeichnungsgeräte für die Explorandin nicht (legal) verfügbar.

⁷¹⁶ HAAG, S. 15.

⁷¹⁷ SCHMID, plädoyer 6/2017, S. 23 (Stellungnahme von HAAG); für den analogen Kontext bei strafbehördlichen Einvernahmen: AMMANN, S. 574 f.; CAPUS/STOLL, S.

b) (Befürchtete) Nachteile der audiovisuellen Aufzeichnung

Gegen die Dokumentation der Exploration mittels audiovisueller Aufzeichnung werden auch kritische Argumente vorgebracht. Allerdings zeigt eine nähere Betrachtung, dass keiner dieser Kritikpunkte geeignet ist, die Vorteile einer Aufzeichnung aufzuwiegen.⁷¹⁸ 266

aa) Aufzeichnung als Störfaktor

Voranstehend wurde die audiovisuelle Aufzeichnung ein grundsätzlich methodenkonformes Dokumentationsmittel in der forensischen Psychiatrie bezeichnet. Allerdings ist offenzulegen, dass es keinen Fachkonsens bezüglich des Dokumentationsstandards gibt, sondern die Wahl des Dokumentationsmittels im Ermessen des Sachverständigen steht.⁷¹⁹ Entsprechend bestehen Stimmen, welche sich kritisch zu einer audiovisuellen Aufzeichnung äussern und darin einen Einschnitt in ihre Methodenfreiheit sehen. So wird von einem Teil der forensisch-psychiatrischen Sachverständigen vorgebracht, dass der Explorand während der Exploration zurückhaltend-gehemmt sein oder die Exploration sogar ganz verweigern könnte, wenn er sich bewusst wird, dass alle seine Äusserungen und sein Verhalten genau aufgezeichnet werden.⁷²⁰ Ähnliches wird für die sachverständige Person vorgebracht.⁷²¹ Die forensische Exploration benötige – so das Kernargument – eine Privatheitszone, um den Geisteszustand des Exploranden effektiv und akkurat erfassen zu können.⁷²² Die Begegnung von Psychiater und 267

213 f. (bzgl. Tonbandaufnahme: «Gleichzeitig dürfte bereits das Bestehen einer Audioaufnahme Anfechtungsversuchen vorbeugen, die im Wissen um die Überprüfungsmöglichkeit als chancenlos gelten müssen.»).

⁷¹⁸ In diesem Zusammenhang auch WESTHOFF/KLUCK, S. 95 mit der provokanten aber wohl nicht ganz unberechtigten These, dass die von Psychologen (was auch für Psychiater gilt) gezeigte Scheu, das Gespräch aufzuzeichnen, wohl auch darin beruht, dass die eigenen Fehler mit aller Deutlichkeit erkennbar werden.

⁷¹⁹ Zur identischen Ausgangslage in den USA auch MARTINEZ/GRAY, S. 180; AAPL TASK FORCE, S. 3 und 14 stipuliert keine generell-abstrakte Pflicht der Sachverständigen, eine Videoaufnahme der Exploration anzufertigen.

⁷²⁰ OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 11, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.; BÖHME, N 730; LANDE, S. 58; MELTON ET AL., S. 79; MARTINEZ/GRAY, S. 185; RICHNER, S. 22; RIEMER-KAFKA, S. 175; SMITH, S. 443; SIEGEL/KINSCHERFF, S. 381; ZOEHNER ET AL., S. 225 Fn. 8 berichten von solchen Stellungnahmen, wo die Gutachter folgende Erscheinungen befürchteten: «Störung des offenen Gesprächsklimas, Einschränkung der freien Redemöglichkeit für den Begutachteten, subjektive Haltung des Misstrauens seitens des Betroffenen gegenüber der Arbeit des Gutachters oder der Anschein einer verhörähnlichen Situation.»

⁷²¹ BÖHME, N 729 (Worte des Sachverständigen auf Goldwaage = Zurückhaltung im Rahmen der Gesprächsführung seitens des Sachverständigen).

⁷²² MARTINEZ/GRAY, S. 185.

Explorand würde denaturiert, «wenn dabei eine Kamera läuft und beide wissen, sie führen das Gespräch für unbekannte Dritte....»⁷²³

268

Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Präsenz von Aufzeichnungsgeräten das Begutachtungsergebnis tangiert. Bei neuropsychologischen Untersuchungen konnte im therapeutischen Kontext aufgezeigt werden, dass eine Aufzeichnung negative Effekte auf den Probanden entfalten kann.⁷²⁴ Trotzdem scheinen die Störungsbefürchtungen in einer Gesamtbetrachtung auf einem instabilen Tatsachenfundament zu stehen. Erstens ist die Übertragbarkeit der voranstehend erwähnten neuropsychologischen Untersuchungen auf den forensischen Kontext und das Instrument des Explorationsgesprächs nicht gesichert; es fehlt für das Explorationsgespräch an empirischen Grundlagen zur Frage, ob eine audiovisuelle Aufzeichnung störend wirken würde.⁷²⁵ Zweitens wird – was für die Gegenthese spricht – aus der Anwendererfahrung berichtet, dass die Exploranden nach anfänglicher Zurückhaltung wegen der Aufzeichnung die Existenz des Aufzeichnungsgeräts vergessen und sich «wie normal» gegenüber dem Befrager äussern.⁷²⁶ Ebenso wird sich der korrekt arbeitende Sachverständige kaum durch eine Aufzeichnung stören lassen.⁷²⁷ Drittens ist zu bedenken, dass wenn sich ein Explorand der Begutachtung verweigert, weil er um die Aufzeichnung weiss, dies die Ausübung des ihm zukommenden Schweige- und Mitwirkungsverweigerungsrechts (Art. 185 Abs. 5 StPO) ist: keine Störung der Exploration also, sondern die Wahrnehmung eines ihm zustehenden Rechts. Vor diesem Hintergrund fördert der Störungseinwand keine überzeugenden Vorbehalte gegenüber der audiovisuellen Aufzeichnung zu Tage.

⁷²³ KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 193.

⁷²⁴ GOLDSTEIN, *American Journal of Psychiatry* 1988, S. 1246; SHEALY/PIRELLI/CRAMER, S. 568; zu den neuropsychologischen Untersuchungen: CRAMER/BRODSKY, S. 52; CONSTANTINOU/ASHENDORF/MCCAFFREY, S. 410 ff.; CONSTANTINOU/ASHENDORF/MCCAFFREY, S. 46 f.; OTTO/KRAUS, S. 367.

⁷²⁵ CRAMER/BRODSKY, S. 52 ff.; GOLDSTEIN, *American Journal of Psychiatry* 1988, S. 1246; MARTINEZ/GRAY, S. 180 f.; AAPL TASK FORCE, S. 3.

⁷²⁶ BROWN, S. 90: «...the claimant and examiner typically forget the presence of an electronic third person in the room, and an independent record of the interview's conduct is permanently available.»; HEER/COVACI, S. 444; WESTHOFF/KLUCK, S. 67 fügen an, dass die meisten Probanden gegen eine Tonträgeraufzeichnung nach angemessener Erklärung nichts einzuwenden haben; für die analoge Erscheinung in der Einvernahme: NÄPFLI, S. 80; WEDER, S. 552 f.; AMMANN, S. 576; SIEGEL/KINSCHERFF, S. 381; KAUFMANN, S. 133.

⁷²⁷ BÖHME, N 732.

bb) *Interpretationsspielräume trotz Aufzeichnung*

Ein weiteres Argument gegen die audiovisuelle Aufzeichnung lautet, dass dieses Medium nicht geeignet sei, «die mit der Begutachtung zwangsläufig verbundenen unterschiedlichen Interpretations- und Deutungsmöglichkeiten aufzulösen». ⁷²⁸ Ähnlich motiviert ist der von anderen Autoren formulierte Einwand, dass eine strikt juristische Kontrolle nicht zum Konzept der psychiatrischen Exploration passe, da juristisches und psychiatrisches Denken auf unterschiedlichen Prämissen basierten. Entsprechend bringe die Aufzeichnung die Gefahr mit sich, dass die makroskopische gutachterliche Untersuchung einer mikroskopischen rechtlichen Analyse zugeführt und die gutachterliche Einschätzung oder der Explorationsstil in Frage gestellt werde, nicht weil sie falsch sind, sondern auf einer Verkennung der Differenzen zwischen Recht und Psychiatrie beruhen. ⁷²⁹

Diesen Stimmen ist zwar insofern zuzustimmen, als dass die Beurteilung von Menschen mit ihren unzählbaren Persönlichkeitsmerkmalen nie absolute Wahrheiten zu Tage zu fördern vermag. Wie bereits dargestellt wurde, stellt jede Begutachtung das Resultat einer Interpretationsleistung dar, und entsprechend ist es denkbar, dass zwei Personen beim selben Exploranden zu unterschiedlichen Auffassungen gelangen, ohne dass eine dieser Sichten zwingend falsch wäre. ⁷³⁰ Im Kontext einer Schuldfähigkeits- oder Massnahmenindikationsbegutachtung bedeutet Wahrheit folglich keinen Fixpunkt auf einer Skala, kein binäres «Richtig-Falsch» mit klarer Linie, sondern vielmehr einen Skalenbereich an vertretbaren Interpretationen. Bestehen aber solche Interpretationsspielräume, ist es unverständlich, deswegen auf eine audiovisuelle Aufzeichnung verzichten zu wollen. Die Lösung kann im Strafprozess nicht darin bestehen, angesichts der unvermeidbaren Interpretationsspielräume die Waffen zu strecken und die autoritative Beurteilung des PSY-Sachverständigen formell zur Wahrheit zu erheben. In einem auf Kontradiktion ausgerichteten Strafverfahren ist es im Gegensatz gerade wichtig, dass bestehende Unsicherheiten oder Beurteilungsspielräume «mit voller Wucht in des Strafverfahren hineingetragen werden» ⁷³¹, denn nur so ist allen Beteiligten (Parteien, Gericht, Staatsanwaltschaft) der schwankende Wahrheitsgrund bekannt, auf dem man sich bewegt.

⁷²⁸ HEER/HABERMEYER, N 8; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 193, welcher der Meinung ist, es sei «Irrtum zu glauben, ein Videoband enthalte den «objektiven» Ablauf und sei nachher von einem kompetenten Anderen «richtig» zu deuten.»; wohl auch MARTINEZ/GRAY, S. 181.

⁷²⁹ MARTINEZ/GRAY, S. 181; RACHLIN/SCHWARTZ, S. 1013; SIMON, S. 17.

⁷³⁰ Vgl. N 156 ff.

⁷³¹ So die treffende Formulierung von ERB, S. 912.

271 Gerade dies wird mit der audiovisuellen Aufzeichnung ermöglicht, da sie sämtlichen Beteiligten den Blick auf einen identischen Explorationssachverhalt erlaubt. Dadurch kann die sachverständige Interpretation des Explorationssachverhalts auf seine Vertretbarkeit hin überprüft und dann einer kontradiktorischen Wahrheitssuche im Sinne von Rede und Gegenrede zugänglich gemacht werden.

cc) *Sichtung der Aufzeichnungen*

272 Ein durchaus ernstzunehmendes Argument lautet, dass die Überprüfung der stundenlangen Aufnahmen einen Aufwand generieren würde, der in Anbetracht der bereits heute vorhandenen prozessualen Möglichkeiten unverhältnismässig wäre.⁷³² Damit einhergehend wird befürchtet, dass u.U. die gesamte Aufzeichnung der Exploration vor Gericht gesichtet werden müsste.⁷³³ Gerade auch im Zusammenhang mit den voranstehend erläuterten Interpretationsspielräumen werden unendliche Streitigkeiten über die gutachterliche Interpretation des Explorationssachverhalts befürchtet.⁷³⁴

273 Es soll an dieser Stelle nicht in Abrede gestellt werden, dass durchaus substantielle Zeitaufwände für die Sichtung der Aufzeichnungen seitens der Parteien entstehen würden.⁷³⁵ Ebenso scheint es plausibel, dass zusätzliche Streitigkeiten über gutachterliche Interpretationen durch die bessere Transparenz der Exploration erfolgen könnten. Dies ist aber ein Preis, der angesichts der entscheidenden Fragen bei einer Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbegutachtung angemessen ist und hingenommen werden muss. Immerhin wäre es nicht zwingend, dass die Explorationsaufzeichnungen vollständig vor Gericht abgespielt und von den Richtern angesehen werden müssten. Eine Überlegung zum Untersuchungsgrundsatz sowie dem Unmittelbarkeitsprinzip ergibt dies in klarer Weise. Art. 343 StPO statuiert ein bloss beschränktes Unmittelbarkeitsprinzip, d.h. nicht alle Beweise müssen vom Gericht unmittelbar in der Hauptverhandlung erhoben werden.⁷³⁶ Ausgehend davon kann nun für die Sichtung der audiovisuellen Aufzeichnung (welche einer unmittelbaren Beweisabnahme durchaus nahekommt) argumentiert werden, dass das Gericht die Aufzeichnungen nur dann einsehen muss, wenn der Explorationsinhalt umstritten ist, und diesbezüglich müssten die Strafverfolgungsbehörde oder die Parteien (insb. die beschuldigte Person und ihre Verteidigung) entsprechende Einwände formulieren.⁷³⁷ Bei

⁷³² OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 13, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.; ansatzweise auch MARTINEZ/GRAY, S. 181.

⁷³³ KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 192.

⁷³⁴ MARTINEZ/GRAY, S. 181.

⁷³⁵ MARTINEZ/GRAY, S. 181.

⁷³⁶ Eingehend dazu KAUFMANN, S. 1 ff.; RIKLIN, ZStW 2014, S. 173 ff.

⁷³⁷ Widerspricht die beschuldigte Person der Sachverhaltsdarstellung des Sachverständigen, stellt sich eine ähnliche Situation ein, wie sie das Bundesgericht im Rahmen

dieser Lesart wäre die Sichtung der Aufnahme nicht der prozessuale Regelfall, sondern käme nur dann zur Anwendung, wenn ein entsprechender Bedarf zur Überprüfung erkennbar wird.⁷³⁸

dd) *Persönlichkeitsschutz des Exploranden*

Ein weiteres Argument gegen eine Pflicht zur audiovisuellen Aufzeichnung der Exploration stellt sodann die Überlegung dar, dass mit dieser Dokumentationsform ein intensiver Eingriff in informationelle Selbstbestimmung der begutachteten Person erfolgt.⁷³⁹ Diese Position bedarf einiger Differenzierungen: Versteht man – wie vorliegend vertreten – die audiovisuelle Aufzeichnung als Verteidigungsrecht der beschuldigten Person im Rahmen von Art. 6 EMRK und nicht als gesetzlich vorgesehenen Eingriff gegen den Willen der beschuldigten Person, könnte die beschuldigte Person auf eine Aufzeichnung verzichten, sofern sie sich über die Konsequenzen eines solches Vorgehens im Klaren ist (sog. *knowing and intelligent waiver*).⁷⁴⁰ Tut sie dies nicht, sondern will sie eine Auf-

von Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen unter Art. 343 Abs. 3 StPO würdigt (vgl. dazu BGE 140 IV 196, E. 4.4.1 f.). Diese Erwägungen können auf die vorliegende Situation übertragen werden. Der Explorationsinhalt kann den Ausgang des Verfahrens beeinflussen (Fragen um Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation). Zusätzlich ist in der Exploration nicht nur von Bedeutung, was gesagt wurde (Inhalt; Einvernahmekomponente), sondern auch wie etwas gesagt wurde (Augenscheinkomponente). Im Fall der Bestreitung des Explorationssachverhalts wäre somit das Gericht in der Pflicht, die audiovisuelle Aufzeichnung anzusehen, was einer quasi-unmittelbaren Beweisaufnahme gleichkäme; interessant in diesem Zusammenhang auch BGer, 12 Juni 2015, 6B 420/2015, E. 3.3, wo das Bundesgericht die Anwendbarkeit von Art. 343 Abs. 3 StPO u.a. darum verneinte, weil die Verteidigung nicht konkret aufzeigte, warum das Protokoll die Befragung nicht korrekt wiedergebe (im konkreten Fall hatte sogar ein Tonband existiert, dass die Formulierung solcher Rügen ermöglicht hätte). Daraus folgt implizit, dass die Sichtung solcher Aufzeichnungen davon abhängt, ob stichhaltige Einwendungen formuliert werden.

⁷³⁸ Im Resultat auch MELUNOVIC, S. 605: «...zusätzlich zum Schriftprotokoll auf Video aufgenommen werden. Diesfalls hätte der Richter die Möglichkeit, bei Bedarf die Aufnahme der originären Aussage und die Befragungssituation zu überprüfen.»; ebenso CAPUS/STOLL, S. 213 f.: «Die Tonbandaufnahme soll lediglich als Sicherheitsnetz fungieren, das in seltenen Streit- und Zweifelsfällen zur Kontrolle des Protokolls genutzt werden kann»; vgl. in diesem Zusammenhang auch BGE 143 IV 408, E. 8.3 wonach die Aufzeichnung das Schriftprotokoll nicht ersetzt, sondern nur ergänzt, wobei dies wie folgt begründet wird: «Das Festhalten am Erfordernis des Schriftprotokolls bezweckt, die Strafbehörden und die Verfahrensbeteiligten davon zu entbinden, stundenlang Aufzeichnungen anzuhören.»

⁷³⁹ GEIGER, S. 53; FASTENMEIER, S. 87; ZOEHNER ET AL., S. 228 f., wobei sich diese Autoren auf den Fall beziehen, dass von Gesetzes wegen eine Aufzeichnungspflicht greift.

⁷⁴⁰ Vgl. dazu N 294.

zeichnung erstellen lassen, könnte aufgrund dieser Einwilligung das grundrechtliche Argument nicht mehr gegen die audiovisuelle Aufzeichnung vorgebracht werden.

- 275 Gegen den voranstehenden Gedanken liesse sich einwenden, dass auch die Strafbehörde und u.U. gar der Privatkläger legitime Interessen haben, einen unmittelbaren Blick auf das Explorationsgeschehen zu erhalten, weswegen sich eine audiovisuelle Aufzeichnung auch für deren Bedürfnisse aufdrängt. Doch auch dann (d.h. wenn eine Aufzeichnung auch gegen den Willen der beschuldigten Person erstellt werden dürfte), könnte das grundrechtliche Argument kaum als gewichtig genug beurteilt werden, um die Vorteile einer Aufzeichnung in Frage zu stellen, denn Fakt ist: Die sachverständige Person wäre mit ihrer Schriftdokumentation ohnehin verpflichtet, den Explorationsinhalt und die darin erhobenen persönlichkeitsbezogenen Daten des Exploranden im Gutachten zu nennen, womit diese Informationen wiederum anderen Personen (Strafverfolgungsbehörde, Gericht usw.) zur Kenntnis gelangen würden. Vor diesem Hintergrund muss der durch eine Aufzeichnung zusätzlich erfolgende Grundrechtseingriff (wenn er gegen den Willen des Explorierten erfolgt) als tendenziell geringfügig eingestuft werden.

ee) *Logistisch-kostentechnische Herausforderungen*

- 276 Ein weiteres Argument gegen eine Pflicht zur audiovisuellen Aufzeichnung betrifft die Herausforderungen der praktischen Umsetzung. So führte etwa das OGer-ZH aus, dass ein Aufzeichnungserfordernis zur Folge hätte, dass nur noch jene Sachverständige zur Begutachtung beigezogen werden könnten, «die Zugang zu einem professionell betriebenen Aufnahmestudio hätten».⁷⁴¹ In der Sache wird damit implizit das Kostenargument angerufen. Diese Haltung lässt sich indes mit Blick auf die heutigen technischen Möglichkeiten nicht aufrechterhalten. Es existieren auf dem Markt hochqualitative, preiswerte und portable Aufzeichnungsinstrumente, die vom Sachverständigen ohne nennenswerten Aufwand als Teil seiner Ausrüstung angeschafft werden können.⁷⁴² Ein professionelles Aufnahmestudio wäre klarerweise nicht notwendig. Zwar ist dem Obergericht, sofern es mit seinen Ausführungen implizit auf die Qualität der Aufzeichnung zielt, insofern beizupflichten, als dass bei einer Aufzeichnung Leitfäden zu erlassen wären, wie eine Aufnahme korrekt durchzuführen ist (Erfassung von Exploranden und Sachverständigem, Ausleuchtung, Kameraposition, Videoformate usw.). Diese praktische Herausforderung allein wäre aber kein sachlicher Grund, von der Erstellung einer audiovisuellen Aufzeichnung abzu-
sehen.

⁷⁴¹ OGer-ZH, 14. Juni 2018, E. II. 13, in: ZR 117/2018 Nr. 46 S. 188 ff.

⁷⁴² NÄPFLI, S. 78; SANER, S. 138; SIEGEL/KINSCHERFF, S. 380 f.; WEDER, S. 553.

ff) *Verbreitung der Aufzeichnungen*

Eine letzte Sorge betrifft sodann die unkontrollierte Verbreitung der Explorationsinhalte. Es könnten – so die Befürchtung aus psychiatrischer Sicht – das Aufzeichnungsmaterial den Medien zugespielt und anschliessend auf Internetportalen, in Fernsehsendungen oder Satireinhalten verwendet werden.⁷⁴³ Diese Bedenken sollen nicht ignoriert werden. Allerdings ist es durchaus interessant, festzustellen, dass sich der massgebliche Autor auf die datenschutzrechtlichen Interessen des Sachverständigen zu fokussieren scheint. Allerdings gilt es zu betonen: Es wäre primär die beschuldigte Person, die berechnete Schutzinteressen an der sicheren Aufbewahrung ihrer personenbezogenen Daten aufweist, und nicht die sachverständige Person, deren Tätigkeit im Rahmen der Begutachtung per se aktenkundig zu machen ist (Dokumentationsgrundsatz). Ohnehin liessen sich legitimen datenschutzrechtlichen Interessen (z.B. des Opfers, wenn es in der Exploration thematisiert wird) mit organisatorischen Mitteln (Einsichtnahme in die Aufzeichnung vor Ort bei der Strafbehörde etc.) in Grenzen halten. Vor diesem Hintergrund sind datenschutzrechtliche Bedenken kaum ein stichhaltiges Argument gegen die Implementierung einer audiovisuellen Aufzeichnung.

IV. Fazit

Die voranstehenden Ausführungen zeigen, dass eine rein auf die Position und Rolle des Sachverständigen ausgerichtete Gewichtsverschiebung die qua Waffengleichheit erforderliche Balance und damit die Verfahrensfairness nach Art. 6 Ziff. 1 i.V.m. Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK nicht herstellen kann. Zwar sind der Neutralitätszuwachs bei neutraler Vergabe der Gutachten und der Kontradiktionsgewinn bei Vorliegen zweier Gutachten durchaus positive Effekte. Ihr Wert ist aber nicht dergestalt, dass er die Überprüfbarkeitslimiten des PSY-Gutachtens aufzulösen vermag. Die Intransparenz des Sachverständigenbeweises mit Blick auf die Exploration wird durch sie nicht behoben.⁷⁴⁴

Die sachgerechte Lösung muss folglich am Transparenzgedanken ausgerichtet werden. Zwei Modelle wurden dafür näher betrachtet: Teilnahmerechte zum einen und eine Optimierung der Dokumentationsstandards zum anderen. Im Rahmen der Analyse konnte aufgezeigt werden, dass der Teilnahmerechtsansatz zwar eine Informationsbrücke zur Verteidigung zu schlagen vermag, aber diverse Gründe gegen seine Implementierung sprechen. Erstens würde auch mit der Präsenz der Verteidigung am Explorationsgespräch dem Gericht nur die Möglichkeit offenstehen, den Explorationsinhalt auf dem Weg der Aussagewürdi-

⁷⁴³ KRÖBER, FPPK 2015-B, S. 192.

⁷⁴⁴ Vgl. N 223 ff.

gung zu erschliessen, wobei aufgrund der systematischen Ausgangslage (neutraler Sachverständiger v. Verteidigung als Interessenwahrer) weiterhin ein Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten des Sachverständigen seinen Platz fände. Zudem müsste für die Überprüfbarkeit des psychiatrischen Vorgehens wohl auch ein Privatsachverständiger zur Exploration zugelassen werden. Zweitens ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Strafbehörden und u.U. gar eine Privatklägerschaft legitime Überprüfungsinteressen aufweisen. Diese könnten zwar durch die Anwesenheit eines weiteren neutralen Beobachters oder die Gewährleistung von weiteren Teilnahmerechten adressiert werden. Damit würde aber die Exploration zu einer schwer zu koordinierenden und kostenintensiven Gruppenveranstaltung werden, in der die Persönlichkeitsrechte des Exploranden über Gebühr strapaziert würden. Schliesslich spricht gegen diese Lösung, dass sich die rechtlich erzwingbare Teilnahme von Drittpersonen mit der Methodenfreiheit des Sachverständigen und dem einschlägigen Grundsatz des Vier-Augen-Gesprächs nicht verträgt. Diese Nachteile sprechen gegen die Implementierung eines Teilnahmerechts der Verteidigung.⁷⁴⁵

280 Wegen der Defizite des Teilnahmeansatzes wurde in der Folge die Aufwertung der Dokumentationsstandards als Lösungsmodell analysiert. Es zeigte sich, dass das Schriftprotokoll für sich genommen ein ungeeigneter Dokumentationsstandard ist. Nicht nur wird die Exploration darin lückenhaft abgebildet. Vielmehr wird durch dieses Vorgehen auch die beschuldigte Person (welche das Protokoll lesen, unterzeichnen und Beanstandungen anbringen müsste) überfordert. Ebenso ist eine erhöhte Protokollierungsdichte geeignet, die Exploration zu stören. Auf Basis dieser Erkenntnis wurde geprüft, ob sich diese Defizite durch das Erstellen einer audio- oder audiovisuellen Aufzeichnung beheben lassen würde.⁷⁴⁶ In dieser Analyse konnte herausgearbeitet werden, dass nur die audiovisuelle Aufzeichnung eine adäquate Dokumentation der Exploration erlaubt. Diese Dokumentationsart bietet nicht nur die fast vollständige Transparenz der Exploration und ist methodenkonform, sie verhindert auch die bei einem Teilnahmerechtsmodell unerwünschten Reflexwirkungen (weitere Teilnahmerechte von anderen Parteien), optimiert den Explorationsablauf (Aufmerksamkeit des Sachverständigen beim Exploranden), führt zu Ausbildungseffekten (Lernen aus schlechten Beispielen) und kann faktisch vom Exploranden jederzeit durch eine heimliche Aufzeichnung herbeigeführt werden. Damit erweist sie sich als ideale Lösung, um dem konventionswidrigen Status quo Abhilfe zu verschaffen.⁷⁴⁷

281 Die gegen eine Aufzeichnung vorgebrachten Argumente ändern nichts an dieser Feststellung. Es ist ungewiss, ob eine Aufnahme wirklich ein Störfaktor wäre, da praktische Erfahrungen zeigen, dass sich Aufgezeichnete nach einer kurzen Zeit

⁷⁴⁵ Vgl. N 230 ff.

⁷⁴⁶ Vgl. N 248 ff.

⁷⁴⁷ Vgl. N 257 ff.

an die Aufzeichnung gewöhnen und wie unter Normalbedingungen agieren. Selbst wenn sich ein Explorand im Wissen um die Aufzeichnung einer Mitwirkung in der Exploration verweigert, wäre darin lediglich die Ausübung eines ihm zustehenden Rechts (Art. 185 Abs. 5 StPO) zu sehen und keine Störung, welche Anlass dazu gibt, von einer Aufzeichnung abzusehen. Ebenso unbestritten ist, dass die Aufzeichnung der Exploration nicht alle Interpretationsspielräume zu beseitigen vermag, welche eine psychiatrische Begutachtung mit sich bringt. Allerdings wäre es gerade durch die Aufzeichnung möglich, diese Ermessensspielräume sichtbar zu machen und dem Gericht einen informierten Entscheid in einem kontradiktorischen Verfahren zu ermöglichen, anstatt dass es sich der autoritativen Beurteilung des Sachverständigen fügt. Potenziell zutreffend mag das Argument der Verfahrensverlängerung sein, das eng mit der Frage der Interpretationsspielräume zusammenhängt: Durch die Transparenz wären Bedingungen geschaffen, welche eine intensivere Debatte über die sachverständigen Erhebungen und Beurteilungen ermöglichen würden. Diese Verlängerungen wären aber der hier vertretenen Auffassung zur Sicherstellung eines fairen Verfahrens hinzunehmen. Schliesslich wurde aufgezeigt, dass auch logistisch-finanzielle oder datenschutzrechtliche Erwägungen zwar bei der praktischen Umsetzung einer Aufzeichnung zu bedenken sind, aber für sich genommen nicht genügen, eine audiovisuelle Aufzeichnung abzulehnen.⁷⁴⁸

In einer Gesamtabwägung überwiegen die Vorteile einer audiovisuellen Aufzeichnung. Durch sie wird die konventionsrechtlich geforderte effektive Überprüfbarkeit des Sachverständigenbeweises gewährleistet. Dies ist – wie in § 6 hinreichend erläutert – umso wichtiger, als dass dem PSY-Sachverständigen im Rahmen der Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbegutachtung eine herausragende Relevanz für die richterliche Entscheidungsfindung zukommt und seine Neutralität konstanten Druckmomenten ausgesetzt ist.⁷⁴⁹ Durch die hier vorgeschlagene Stärkung der Verteidigungsrechte kann diese prozessuale Dysbalance wieder ins Gleichgewicht gerückt und dem Grundsatz der Waffen-

282

⁷⁴⁸ Vgl. N 266 ff.

⁷⁴⁹ Vgl. N 110 ff.

4. Teil: Das Teilnahmepostulat im Lichte des Rechts auf Beizug der Verteidigung

§ 9 Prüfungsmodell des EGMR

Im Themenaufriß wurde dargelegt, dass sich das Postulat des Teilnahmerechts der Verteidigung nicht nur auf den Aspekt der effektiven Überprüfung des Gutachtens im Rahmen des Rechts auf Stellungnahme stützt, sondern auch aus der Beistands-, Kontroll- und Fürsorgefunktion der Verteidigung hergeleitet wird: Sei die Verteidigung am Explorationsgespräch nicht anwesend, könne sie die beschuldigte Person weder vor rechtswidrigem Verhalten seitens des Sachverständigen schützen noch eine effektive Wahrnehmung ihres Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrechts (Art. 185 Abs. 5 StPO; *nemo tenetur*) gewährleisten.⁷⁵⁰ Auch diesen Begründungsstrang für ein Teilnahmerecht der Verteidigung gilt es in den Kontext von Art. 6 EMRK zu stellen und auf seine Rechtfertigung hin zu überprüfen. 283

I. Verortung des Prüfungsmodells in Art. 6 EMRK

Die Suche nach dem konventionsrechtlichen Prüfungsmodell für den vorliegend zu begutachtenden Begründungsstrang führt zu Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK. Aus dieser Norm fließt nicht nur das Recht der beschuldigten Person, «sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen». Vielmehr gilt, dass der beschuldigten Person das Recht zukommt, sich in effektiver Weise von einem Anwalt verteidigen zu lassen («the right...to be effectively defended by a lawyer...»).⁷⁵¹ Die Leitfrage des 4. Teils lautet somit, ob Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK es erfordert, dass der Verteidigung der beschuldigten Person ein Teilnahmerecht am Explorationsgespräch des PSY-Sachverständigen mit seinem Mandanten im Kontext des Schuld- und/oder Massnahmengutachtens zukommt. Der EGMR hat diese Frage noch nie beantworten müssen. Es erweist sich daher als notwendig, die bestehenden konventionsrechtlichen Leitlinien zum Recht auf Verteidigerbeizug im Vorverfahren zu analysieren und ihre Übertragbarkeit auf den Untersuchungsgegenstand zu prüfen. 284

⁷⁵⁰ Vgl. N 28.

⁷⁵¹ EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 112, ECHR 2017.

II. Fairnessprüfungssequenzen des EGMR

1. Aktivierung und Inhalt des Beizugsrechts

285 Nach konstanter Rechtsprechung des EGMR gilt das Recht der beschuldigten Person auf effektive Verteidigung durch einen Anwalt als fundamentales Merkmal eines fairen Verfahrens.⁷⁵² Dieses Recht ist zwar in seiner ursprünglichen Konzeption auf das gerichtliche Verfahren ausgerichtet.⁷⁵³ Allerdings erkannte der EGMR bereits früh, dass eine auf das gerichtliche Verfahren beschränkte Anwendbarkeit dieses Rechts keinen effektiven Schutz zu gewährleisten vermag. Als Folge dieser Erkenntnis hat er den zeitlichen Anwendungsbereich ins Vorverfahren ausgedehnt.

A) Der «Anwalt der ersten Stunde»

286 Das Fundament für die vorliegend massgebliche konventionsrechtliche Gerichtspraxis stellt das Urteil in Sachen Salduz v. Turkey dar. In diesem Urteil hielt der EGMR erstmals fest, dass der beschuldigten Person der Zugang zu einem Anwalt in der Regel vom Zeitpunkt der ersten polizeilichen Einvernahme an zu gewähren ist.⁷⁵⁴ Dieses Urteil wurde später dahingehend präzisiert, dass das Recht auf Zugang zu einem Anwalt nicht vom formellen Element der Einvernahme abhängt, sondern bereits dann aktiviert wird, wenn eine Person in polizeilichen Gewahrsam genommen wird, unabhängig davon, ob Einvernahmen stattfinden oder nicht.⁷⁵⁵ Diese Leitlinien wurden durch die Rechtsprechung des EGMR zahlreich bestätigt und dürfen als Ausgangspunkt der Analyse nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK bezeichnet werden.⁷⁵⁶ In diesem Zusammenhang ist auch vom «Anwalt der ersten Stunde» die Rede.⁷⁵⁷

⁷⁵² EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 112, ECHR 2017; EGMR, *Dayanan v. Turkey*, no. 7377/03, § 130, 13 October 2009.

⁷⁵³ WU, S. 52.

⁷⁵⁴ EGMR, *Salduz v. Turkey* [GC], no. 36391/02, § 55, ECHR 2008.

⁷⁵⁵ EGMR, *A.T. v. Luxembourg*, no. 30460/13, § 64, 9 April 2015.

⁷⁵⁶ EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 116, ECHR 2017; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 256, ECHR 2016; EGMR, *A.T. v. Luxembourg*, no. 30460/13, § 63, 9 April 2015; EGMR, *Zachar and Čierny v. Slovakia*, nos. 29376/12 and 29384/12, § 59, 21 July 2015.

⁷⁵⁷ Stellvertretend: SCHLEGEL/WOHLERS, S. 307 Fn. 5.

B) Ratio der Schutzausweitung ins Vorverfahren

Die Ratio der zeitlichen Vorverlagerung des Rechts nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c 287 EMRK fusst auf der Anerkennung der Bedeutung des Vorverfahrens für die Fairness des Gesamtverfahrens. So betont der EGMR, dass die im Vorverfahren stattfindenden Beweiserhebungen oft determinieren, wie die Straftat vom Gericht gewürdigt wird, dass sich die beschuldigte Person zu Beginn des Strafverfahrens in einer vulnerablen Position befindet und sich ein prozessuales Gegengewicht in Form der Verteidigung aufdrängt, um die Waffengleichheit des Verfahrens zu sichern.⁷⁵⁸

Das Recht auf Beizug einer Verteidigung dient dem Schutz der beschuldigten Person und ihrer Rechte.⁷⁵⁹ Von grossem Interesse ist in diesem Zusammenhang das Recht zu schweigen und sich nicht selbst belasten zu müssen (*nemo tenetur*). Die Verteidigung stellt diesbezüglich sicher, dass die beschuldigte Person aufgeklärt und aus freiem Willen auf strafbehördliche Fragen antwortet; sie verkörpert damit einen Schutzfaktor für *nemo tenetur*, auf welchen der EGMR bei seiner Gesamtwürdigung grosses Gewicht legt.⁷⁶⁰ Eng damit verbunden schützt die Verteidigung vor Misshandlungen und unzulässigem Zwang des Beschuldigten durch die Polizei; ihre Präsenz wirkt als Präventivfaktor für entsprechende Verhaltensweisen der Strafbehörden.⁷⁶¹ Wenn ihre passive Präsenz alleine nicht genügt, kann sie durch Interventionen unzulässiges Behördenhandeln (z.B. unzulässiger Druckaufbau, falsche Protokollierung) aktiv unterbinden.⁷⁶² Durch ihre Tätigkeit in der Anfangsphase des Verfahrens kompensiert die Verteidigung die besondere Verletzlichkeit der beschuldigten Person (Stresssituation, Komplexität der Rechtslage) im Vorverfahren und sichert damit eine effektive Wahr-

⁷⁵⁸ EGMR, *Salduz v. Turkey* [GC], no. 36391/02, § 54, ECHR 2008; EGMR, *Artur Parkhomenko v. Ukraine*, no. 40464/05, § 73, 16 February 2017; EGMR, *Blokhin v. Russia* [GC], no. 47152/06, § 198, ECHR 2016; BILLING, S. 69; PITCHER, S. 32.

⁷⁵⁹ PIVATY, S. 60; WU, S. 51.

⁷⁶⁰ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 128, 9 November 2018; EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 74, 23 May 2019; EGMR, *Salduz v. Turkey* [GC], no. 36391/02, § 54, ECHR 2008; EGMR, *Blokhin v. Russia* [GC], no. 47152/06, § 198, ECHR 2016; EGMR, *Zachar and Čierny v. Slovakia*, nos. 29376/12 and 29384/12, § 59, 21 July 2015; CELIKSOY, S. 5; GINTER/SOO, S. 172; zu diesem Nexus zwischen *nemo tenetur* und dem Recht auf Verteidigerbeistand auch GOCKER, S. 621; PIVATY, S. 73 f.; LAMBERIGTS, S. 428; VERHOEVEN, S. 173.

⁷⁶¹ EGMR, *Blokhin v. Russia* [GC], no. 47152/06, § 198, ECHR 2016; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 112, ECHR 2017; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 255, ECHR 2016; CELIKSOY, S. 5; PAREIN/BURGENER, S. 549; PIVATY, S. 70 und 76; VERHOEVEN, S. 173.

⁷⁶² PIVATY, S. 76.

nehmung der Verteidigungsrechte ab.⁷⁶³ Es ist vor diesem Hintergrund zu würdigen, dass der EGMR regelmässig betont, dass die Vorverlagerung des Rechts auf Beizug einer Verteidigung die Ziele von Art. 6 EMRK im Allgemeinen und die Waffengleichheit im Besonderen schütze.⁷⁶⁴

C) Manifestationsformen des Verteidigerhandelns

289 Die Zielsetzung einer effektiven Verteidigung kann Verteidigungshandeln in verschiedenster Art und in unterschiedlichen Stadien des Strafverfahrens erfordern. Dies spiegelt sich auch in der Rechtsprechung des EGMR. Nach seiner Praxis hat die beschuldigte Person sowohl das Recht auf freien Verkehr mit der Verteidigung (a) als auch das Recht auf Anwesenheit der Verteidigung anlässlich der strafbehördlichen Einvernahme (b).

a) Freier Verkehr mit der Verteidigung

290 Effektive Verteidigung umfasst nach der Praxis des EGMR den gesamten Umfang juristischer Beistandsformen; es muss der Verteidigung somit ohne Restriktionen möglich sein, den Fall mit der beschuldigten Person zu besprechen, sie auf die Befragung vorzubereiten und ihr psychischen Beistand zu leisten.⁷⁶⁵ Der freie und vertrauliche Verkehr zwischen der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung (besonders vor der ersten Einvernahme) ist dabei von grösster Bedeutung für die Fairness des Verfahrens.⁷⁶⁶ Er eröffnet der Verteidigung die Möglichkeit, kritische Informationen mit der beschuldigten Person auszutauschen und letztere über die ihr zustehenden Rechte zu belehren.⁷⁶⁷ Dazu gehört

⁷⁶³ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 126 f., 9 November 2018; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 112, ECHR 2017; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 255, ECHR 2016; *Zachar and Čierny v. Slovakia*, nos. 29376/12 and 29384/12, § 59, 21 July 2015; EGMR, *Pishchalnikov v. Russia*, no. 7025/04, § 69, 24 September 2009; GINTER/SOO, S. 174; PIVATY, S. 78; WU, S. 51.

⁷⁶⁴ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 125, 9 November 2018; EGMR, *Blokhin v. Russia* [GC], no. 47152/06, § 198, ECHR 2016; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 112, ECHR 2017; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 255, ECHR 2016; CELIKSOY, S. 5.

⁷⁶⁵ EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 74, 23 May 2019; EGMR, *Dayanan v. Turkey*, no. 7377/03, § 32, 13 October 2009; EGMR, *A.T. v. Luxembourg*, no. 30460/13, § 63 f., 9 April 2015.

⁷⁶⁶ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 133, 9 November 2018; EGMR, *A.T. v. Luxembourg*, no. 30460/13, § 87, 9 April 2015; EGMR, *Farrugia v. Malta*, no. 63041/13, § 97, 4 June 2019.

⁷⁶⁷ EGMR, *A.T. v. Luxembourg*, no. 30460/13, § 86, 9 April 2015; vgl. auch RAMOS, S. 406.

insbesondere auch die Beratung darüber, ob bzw. in welchem Rahmen es sinnvoll ist, das Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht auszuüben.⁷⁶⁸

b) *Teilnahmerecht der Verteidigung*

Eine gewisse Zeit war unklar, ob sich aus den Salduz-Leitlinien⁷⁶⁹ auch ein Anspruch auf Teilnahme der Verteidigung an der Einvernahme der beschuldigten Person ergibt.⁷⁷⁰ Das Bundesgericht lehnte dies in seiner älteren Rechtsprechung ab.⁷⁷¹ Der EGMR hat aber in diversen Salduz nachfolgenden Urteilen keinen Zweifel daran gelassen, dass eine effektive Verteidigung unter Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK grundsätzlich auch das Teilnahmerecht der Verteidigung (-> physische Anwesenheit) an Einvernahmen enthält.⁷⁷² Dabei darf die Rolle der Verteidigung nicht auf passive Präsenz beschränkt werden.⁷⁷³ Vielmehr ist der Verteidigung eine aktive Position einzuräumen; sie ist berechtigt, zur Wahrung der Rechte ihres Klienten zu intervenieren.⁷⁷⁴ Dies bedeutet nicht nur das Rügen ungesetzlicher Verhaltensweisen seitens der Strafbehörden, sondern auch, dass die Verteidigung während der Einvernahme auch ihrer Beratungstätigkeit nachkommen darf, was insb. die bereits erwähnte Beratung über die Ausübung oder Nichtausübung des Schweigerechts umfasst.⁷⁷⁵

2. Nexus zu nemo tenetur

Wie bereits dargelegt wurde, besteht eine wesentliche Funktion der Verteidigung darin, der beschuldigten Person eine effektive Ausübung ihres Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrechts (*nemo tenetur se ipsum accusare*; kurz:

⁷⁶⁸ PIVATY, S. 74 und 86.

⁷⁶⁹ EGMR, *Salduz v. Turkey* [GC], no. 36391/02, ECHR 2008.

⁷⁷⁰ CELIKSOY, S. 5; GAEDE, S. 794 f.; GINTER/SOO, S. 171; RAMOS, S. 405; SCHLEGEL, fp 2010, S. 92.

⁷⁷¹ BGer, 26. November 2009, 6B_700/2009, E. 2.2.2.

⁷⁷² EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 134, 9 November 2018; EGMR, *Farrugia v. Malta*, no. 63041/13, § 97, 4 June 2019; EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 74, 23 May 2019; EGMR, *Brusco v. France*, no. 1466/07, § 45, 14 October 2010; EGMR, *Navone and Others v. Monaco*, nos. 62880/11 and 2 others, § 79, 24 October 2013; implizit auch *Karabil v. Turkey*, no. 5256/02, § 44, 16 June 2009; EGMR, *Šebalj v. Croatia*, no. 4429/09, § 257, 28 June 2011; EGMR, *Dimitar Mitev v. Bulgaria*, no. 34779/09, § 64, 8 March 2018; CELIKSOY, S. 5; GINTER/SOO, S. 172; RAMOS, S. 405.

⁷⁷³ EGMR, *Aras v. Turkey* (no. 2), no. 15065/07, § 40, 18 November 2014.

⁷⁷⁴ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 134, 9 November 2018; EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 74, 23 May 2019; EGMR, *Aras v. Turkey* (no. 2), no. 15065/07, § 40, 18 November 2014; PIVATY, S. 78 f.

⁷⁷⁵ Vgl. N 287 ff.; PIVATY, S. 79.

nemo tenetur) zu garantieren.⁷⁷⁶ Nemo tenetur (in der Praxis des EGMR «right to remain silent...and the privilege against self-incrimination» genannt) genießt in der Rechtsprechung des EGMR einen hohen Stellenwert und wird als essentieller Bestandteil eines fairen Verfahrens bezeichnet, dessen Funktionen in der Vermeidung von unzulässigem Zwang, von Justizirrtümern und allgemein der Verwirklichung der Ziele von Art. 6 EMRK liegen.⁷⁷⁷ Das Kernanliegen dieses Rechts – ohne auf sämtliche streitigen Einzelpunkte einzugehen⁷⁷⁸ – besteht nach der Rechtsprechung des EGMR darin, dass die Strafbehörden den Willen der beschuldigten Person zu schweigen akzeptieren bzw. dass sie keine Zwangsmittel anwenden, welche den Willen der beschuldigten Person überwinden.⁷⁷⁹

- 293 Nemo tenetur verbietet zwar das Erlangen inkriminierender Beweise von der beschuldigten Person nicht per se.⁷⁸⁰ Den Strafbehörden ist es aber verboten, die von nemo tenetur geschützten Informationen mittels unzulässigem Zwang (improper compulsion) zu erlangen.⁷⁸¹ Solcher besteht nach der Praxis des EGMR besonders dann, wenn der Beschuldigte unter Androhung von Sanktionen zur Aussage verpflichtet oder wegen Nichtmitwirkung sanktioniert wird, auf ihn physischer oder psychischer Druck ausgeübt wird oder wenn die Strafbehörden Täuschungen verwenden, um dem Beschuldigten Informationen zu entlocken.⁷⁸² Ebenso ist es unzulässig, aus dem Schweigen der beschuldigten Person negative Beweisschlüsse zu ziehen; ein Schuldspruch, der alleine oder entscheidend auf dem Schweigen des Beschuldigten fusst, ist mit nemo tenetur nicht vereinbar.⁷⁸³ Nemo tenetur steht damit in engem Zusammenhang mit der Unschuldsvermu-

⁷⁷⁶ Vgl. N 287 ff.

⁷⁷⁷ EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 266, ECHR 2016; EGMR, Turbylev v. Russia, no. 4722/09, § 84, 6 October 2015; EGMR, Oleg Kolesnik v. Ukraine, no. 17551/02, § 36, 19 November 2009.

⁷⁷⁸ Dazu die Ausführungen bei ASHWORTH, S. 767 ff.; JACKSON, S. 836 ff.; OTT, S. 74 ff.; REDMAYNE, S. 211 ff.; TRECHSEL, S. 341 ff.; WOHLERS, FS Küper, S. 698.

⁷⁷⁹ EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 266, ECHR 2016; EGMR, Turbylev v. Russia, no. 4722/09, § 84, 6 October 2015; BGE 142 IV 207, E. 8.3.1; BGE 140 II 384, E. 3.3.2.

⁷⁸⁰ EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 267, ECHR 2016.

⁷⁸¹ EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 266, ECHR 2016; EGMR, Turbylev v. Russia, no. 4722/09, § 84, 6 October 2015.

⁷⁸² EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 269, ECHR 2016.

⁷⁸³ EGMR, Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], nos. 26766/05 and 22228/06, § 138, ECHR 2011.

tung.⁷⁸⁴ Wenn der Staat die beschuldigte Person zur Mitwirkung verpflichten oder aus ihrem Nichtmitwirken negative Schlüsse ziehen dürfte, würde sich die Beweislast faktisch vom Staat auf den Beschuldigten verschieben.⁷⁸⁵ Es bleibt zu betonen, dass *nemo tenetur* kein absolutes Recht darstellt und nicht sämtliche Erscheinungsformen von Zwang in einer Konventionsverletzung münden.⁷⁸⁶ Die Schwelle ist dann überschritten, wenn der Wesensgehalt dieser Garantie zerstört wird, was anhand einer Gesamtwürdigung zu beurteilen ist.⁷⁸⁷ In dieser wird neben diversen Faktoren (Art und Schwere des Zwangs, prozessuale Schutzmechanismen usw.) vor allem der Frage Beachtung geschenkt, ob die so erlangten Aussagen im weiteren Verfahren verwendet wurden.⁷⁸⁸ Diese Aspekte bilden – dies sei an dieser Stelle bereits gesagt – Teil der Kriterienliste des EGMR, welche er bei der Gesamtwürdigung der Verfahrensfairness nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK berücksichtigt (dazu nachfolgend 5.).

3. Belehrungspflicht und Verzicht auf Verteidigungsrechte

Angesicht der fundamentalen Bedeutung des Rechts auf Verteidigerbeizug sowie *nemo tenetur* dürfte es kaum überraschen, dass der EGMR sicherstellen möchte, dass sich die beschuldigte Person dieser Rechte bewusst ist. Die beschuldigte Person ist darum von den Strafbehörden über ihr Recht auf Beizug eines Anwalts sowie das Recht, zu schweigen und die Mitwirkung zu verweigern (*nemo tenetur*), aufzuklären.⁷⁸⁹ Erfolgt dies, liegt das Schicksal dieser Ver-

294

⁷⁸⁴ EGMR, *Saunders v. the United Kingdom*, 17 December 1996, § 68, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; EGMR, *Allen v. the United Kingdom* [GC], no. 25424/09 [GC], § 93, 12 July 2013; EGMR, *Weh v. Austria*, no. 38544/97, § 46, 8 April 2004.

⁷⁸⁵ LAMBERIGTS, S. 426; TRECHSEL, S. 348.

⁷⁸⁶ EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 269, ECHR 2016; EGMR, *Weh v. Austria*, no. 38544/97, § 46, 8 April 2004; EGMR, *Quinn v. Ireland*, no. 36887/97, § 47, 21 December 2000; EGMR, *Heaney and McGuinness v. Ireland*, no. 34720/97, § 47, ECHR 2000-XII.

⁷⁸⁷ EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 269, ECHR 2016; EGMR, *O'Halloran and Francis v. the United Kingdom* [GC], nos. 15809/02 and 25624/02, § 53, ECHR 2007-III.

⁷⁸⁸ EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 269, ECHR 2016; EGMR, *O'Halloran and Francis v. the United Kingdom* [GC], nos. 15809/02 and 25624/02, § 55, ECHR 2007-III; PABEL/SCHMAHL, § 24 N 138.

⁷⁸⁹ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 129, 9 November 2018; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 118, ECHR 2017; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 272, ECHR 2016.

teidigungsrechte im Autonomiebereich der beschuldigten Person: Der EGMR anerkennt in konstanter Praxis, dass eine Person auf die durch Art. 6 EMRK eingeräumten Rechte durch ihren freien Willen verzichten kann, sei es ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten, in welchem Fall keine Verletzung der Verfahrensfairness vorliegt.⁷⁹⁰ Damit der Verzicht jedoch als rechtsgültig betrachtet wird, muss er in unzweifelhafter Weise manifestiert worden sein und durch Schutzmechanismen abgesichert werden, welche seiner Bedeutung in einem konkreten Verfahren (insb. Schwere des Tatvorwurfs/Strafandrohung) gerecht werden.⁷⁹¹ Es muss der verzichtenden Person möglich gewesen sein, die Konsequenzen ihres Verzichts zu überblicken, d.h. sie muss sich der rechtlichen Implikationen ihres Verhaltens bewusst sein und diese akzeptiert haben (sog. «knowing and intelligent waiver»)⁷⁹² und es dürfen der Verzichtannahme keine sonstigen wichtigen öffentlichen Interessen entgegenstehen.⁷⁹³

4. Zwingende Gründe für den Ausschluss der Verteidigung

295 Das Recht auf Beizug einer Verteidigung hat nach den voranstehenden Erörterungen unbestritten grosse Bedeutung für die Fairness des Strafverfahrens und ist im Regelfall zu gewähren. Trotzdem gilt das Recht auf Beizug einer Verteidigung nicht absolut. Liegen zwingende Gründe («compelling reasons») vor, darf der beschuldigten Person der Beizug des Anwalts verweigert werden.⁷⁹⁴ Sachlich hat der EGMR die in Frage kommenden Schutzinteressen bei diesen zwingenden Gründen aber sehr eng gefasst. Nur die Abwendung von unmittelbaren Gefahren für Leben, Freiheit oder körperliche Integrität vermögen unter geltender Rechtsprechung zwingende Gründe darzustellen; die nicht spezifische Angabe, dass durch die Zulassung des Anwalts Informationen nach aussen dringen könnten, oder der Umstand, dass ein Gesetz die Anwesenheit des Anwalts

⁷⁹⁰ EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 115, ECHR 2017.

⁷⁹¹ EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 115, ECHR 2017; EGMR, *Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine*, nos. 48016/06 and 7817/07, § 65 ff., 10 November 2016.

⁷⁹² EGMR, *Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine*, nos. 48016/06 and 7817/07, § 73, 10 November 2016; EGMR, *Dvorski v. Croatia* [GC], no. 25703/11, § 101, ECHR 2015.

⁷⁹³ EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 115, ECHR 2017; EGMR, *Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine*, nos. 48016/06 and 7817/07, § 70, 10 November 2016; EGMR, *Kovačević v. Croatia*, no. 34804/14, § 70, 12 April 2018.

⁷⁹⁴ EGMR, *Blokhin v. Russia* [GC], no. 47152/06, § 198, ECHR 2016; EGMR, *A.T. v. Luxembourg*, no. 30460/13, § 63, 9 April 2015; EGMR, *Zachar and Čierny v. Slovakia*, nos. 29376/12 and 29384/12, § 59, 21 July 2015.

generell-abstrakt ausschliesst, genügt hingegen nicht.⁷⁹⁵ Sodann müssen die zwingenden Ausschlussgründe gesetzlich klar umschrieben sowie zeitlich limitiert sein und ihr Vorliegen muss anhand einer umfassenden Einzelfallanalyse festgestellt werden (d.h. generell-abstrakte Ausschlüsse der Verteidigung sind unzulässig).⁷⁹⁶

5. Gesamtwürdigungsansatz

Zu beantworten bleibt die Frage, wie der EGMR vorgeht, wenn das Recht auf Verteidigerbeizug im Vorverfahren von einem Mitgliedsstaat der EMRK nicht oder nicht in vollem Umfang gewährleistet wird: Sei dies bei Vorliegen von zwingenden Gründen zum Ausschluss der Verteidigung oder in Absenz solcher Gründe. In beiden Konstellationen ist die Fairness des Verfahrens anhand einer Gesamtwürdigung zu prüfen.⁷⁹⁷ Allerdings unterscheiden sich die beiden Fallgruppen im Hinblick auf die Beweislast.

A) Beweislastverteilung im Rahmen der Gesamtwürdigung

Die Beweislastverteilung der Gesamtwürdigung bestimmt sich danach, ob zwingende Gründe für den Ausschluss der Verteidigung vorlagen. Wenn dies der Fall ist, prüft der EGMR in einer «normalen» Gesamtwürdigung, ob der verweigerte Zugang zur Verteidigung die Verteidigungsrechte nach Art. 6 EMRK in unangemessener Weise beeinträchtigte.⁷⁹⁸ Wenn keine zwingenden Gründe vorliegen, mündet dies zwar nicht automatisch in der Annahme einer Konventionsverletzung; es ist auch hier eine Gesamtwürdigung vorzunehmen.⁷⁹⁹ Allerdings

⁷⁹⁵ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 142, 9 November 2018; EGMR, *Farrugia v. Malta*, no. 63041/13, § 100, 4 June 2019; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 259, ECHR 2016; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 117, ECHR 2017; CELIKSOY, S. 7; WAHL, S. 324 f.

⁷⁹⁶ EGMR, *Zachar and Čierny v. Slovakia*, nos. 29376/12 and 29384/12, § 59, 21 July 2015; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 117, ECHR 2017; EGMR, *Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine*, nos. 48016/06 and 7817/07, § 59, 10 November 2016.

⁷⁹⁷ EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 113, ECHR 2017; EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 120 f., 9 November 2018.

⁷⁹⁸ EGMR, *Blokhin v. Russia* [GC], no. 47152/06, § 198, ECHR 2016; EGMR, *A.T. v. Luxembourg*, no. 30460/13, § 63, 9 April 2015; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 264, ECHR 2016.

⁷⁹⁹ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 144, 9 November 2018; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 262 f., ECHR 2016; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 118, ECHR 2017; kritisch zu dieser Entscheidungslinie: BURIC, S. 352; CELIKSOY, S. 16 f.;

verlagert sich hier die Beweislast auf den Mitgliedsstaat.⁸⁰⁰ In diesen Fällen wendet der EGMR einen besonders strengen Prüfungsmassstab («very strict scrutiny») an: Eine Fairnessverletzung wird solange vermutet, wie der Mitgliedsstaat nicht überzeugend darlegt, wieso ausnahmsweise in diesem Einzelfall trotzdem ein faires Verfahren stattfinden konnte.⁸⁰¹

B) Kriterien der Gesamtwürdigung

298

Zu beantworten bleibt, nach welchen inhaltlichen Kriterien der EGMR die Fairness eines Strafverfahrens bewertet. In diesem Zusammenhang gilt es vorab anzumerken, dass sich die Kriterienliste unabhängig von den referierten Fallgruppen (zwingende Gründe für Ausschluss der Verteidigung oder keine zwingenden Gründe) zusammensetzt. Sie fällt bei beiden Fallgruppen identisch aus und enthält namentlich folgende Gesichtspunkte⁸⁰²:

- a) Besondere Verletzlichkeit der Person wegen ihres Alters oder des psychischen Zustands.
- b) Nationalrechtliche Ausgestaltung des Vorverfahrens und insb. der Zulässigkeit von Beweisen im Gerichtsverfahren. Einhaltung dieser Normen. Wo ein Verwertungsverbot für die ohne Anwalt erlangten Aussagen Anwendung findet, ist es besonders unwahrscheinlich, dass das Gesamtverfahren unfair war.
- c) Möglichkeit der betroffenen Person, Einwendungen gegen die Nutzung des ohne Anwalt erlangten Beweismaterials zu machen und dabei die Authentizität dieses Materials in Frage zu stellen.
- d) Qualität der Beweise. Dabei ist zu prüfen, ob die Umstände der Beweiserlangung Zweifel auf die Beweiskraft des Beweismittels werfen, wobei zu berücksichtigen ist, ob und welche Form von Zwang existierte.

CAIANIELLO, S. 291 ff.; HOHL-CHIRAZI, LD Roth, S. 110 ff.; PAREIN/BURGENER, S. 548.

⁸⁰⁰ SOO, S. 335.

⁸⁰¹ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 145, 9 November 2018; EGMR, *Farrugia v. Malta*, no. 63041/13, § 108 und § 112 bzgl. Belehrung, 4 June 2019; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 265, ECHR 2016; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 118, ECHR 2017; EGMR, *Dimitar Mitev v. Bulgaria*, no. 34779/09, § 64, 8 March 2018; RAMOS, S. 415.

⁸⁰² EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 130 (bzgl. Belehrung) und § 150, 9 November 2018; EGMR, *Farrugia v. Malta*, no. 63041/13, § 104, 4 June 2019; EGMR, *Ibrahim and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 273 f. und 303, ECHR 2016; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 120, ECHR 2017.

- e) Sofern Beweise unrechtmässig erhoben wurden: Natur der Verletzung und ob dadurch eine andere Konventionsgarantie verletzt wird.
- f) Natur der Aussage sowie die Frage, ob die Aussage nachträglich unverzüglich zurückgezogen oder modifiziert wurde.
- g) Verwendung des Beweismittels und besonders, ob dieses einen integralen oder signifikanten Teil der Verurteilungsbasis bildete und wie stark das sonstige Beweismaterial ausfiel.
- h) Ob die Schuldbeurteilung durch professionelle Richter oder eine Laienjury stattfand und ob in letzterem Fall Instruktionen an die Jury erteilt wurden.
- i) Gewicht des öffentlichen Interesses an der Untersuchung und Bestrafung der konkret fraglichen Straftat.
- j) Sonstige prozessuale Schutzmechanismen des nationalen Rechts.
- k) Obwohl in der Liste des EGMR nicht genannt, aber in den massgeblichen Urteilen immer an anderer Stelle aufgegriffen: Stattfinden einer Belehrung über das Recht auf Beizug eines Anwalts sowie nemo teneatur. Wird sie unterlassen, führt dieses Verfehlen zwar nicht automatisch zur Annahme eines unfairen Verfahrens, aber es fliesst als gewichtiges Negativkriterium in die noch zu erläuternde Gesamtwürdigung ein.

In Anbetracht dieser Vielzahl an Kriterien beurteilt der EGMR (immer die Beweislast beachtend), ob ein Mitgliedsstaat ein faires Verfahren gewährleistete oder ob er sich eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK zu Schulden kommen liess. Damit ist das Prüfungsmodell des EGMR umrissen: Ausgehend von einem grundsätzlich zu gewährleistenden Recht auf Beizug der Verteidigung bei Festnahmen oder Einvernahmen im Vorverfahren wird geprüft, ob zwingende Gründe eine Einschränkung dieses Rechts nahelegen. Liegen keine zwingenden Gründe vor, trägt der Mitgliedstaat der EMRK die Beweislast und muss darlegen, warum trotz dieser Einschränkung ausnahmsweise ein faires Verfahren stattfinden konnte. Dabei beurteilt der EGMR die Verfahrensfairness anhand einer Gesamtwürdigung, wobei er den voranstehend erwähnten Kriterien besondere Beachtung schenkt.⁸⁰³

299

⁸⁰³ Anmerkung: Im vorliegenden Paragraphen geht es nur darum, das Prüfungsmodell des EGMR zu illustrieren. An dieser Stelle soll darum noch nicht auf die inhaltliche Qualität dieser Liste bzw. der relative Wert einzelnen Kriterien eingegangen werden. Dies wird in § 10 geschehen.

§ 10 Konventionswidriger Ausschluss der Verteidigung

300 Das Recht auf Verteidigerbeizug im Vorverfahren und das damit verbundene Recht auf freien Verkehr mit der Verteidigung sowie das Teilnahmerecht der Verteidigung an der strafbehördlichen Einvernahme bilden nach dem Gesagten wichtige Eckpfeiler eines fairen Verfahrens. Nachfolgend wird dargelegt werden, dass es sich aufgrund der Ähnlichkeit zwischen der Einvernahme im Vorverfahren und der psychiatrischen Exploration aufdrängt, die konventionsrechtlichen Leitlinien zur Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK auf das psychiatrische Explorationsgespräch zu übertragen. Diese Schlussfolgerung ist anhand der in § 9 erläuterten Prüfungssequenzen herzuleiten.⁸⁰⁴ Dafür wird in einem ersten Schritt die Annahme widerlegt, dass die Exploration keine Einvernahme ist (dazu nachfolgend I. und II.). Daraus folgt, dass die konventionsrechtlichen Leitlinien nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK auf das Explorationsgespräch übertragen werden müssen und somit das Recht auf Beizug einer Verteidigung grundsätzlich auch in der psychiatrischen Exploration zur Anwendung gelangt (II.). Da der psychiatrische Methodenstandard keinen zwingenden Grund für den Ausschluss der Verteidigung darstellt, trägt die Schweiz die Beweislast für ein faires Verfahren (III.). In der Gesamtwürdigung der Verfahrensfairness wird sich zeigen, dass die Schweiz diesen Nachweis nicht zu erbringen vermag, was in der Feststellung einer Verletzung von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK mündet (IV.)

I. Leitbild: Exploration ≠ Einvernahme

301 Ausgangspunkt der nachfolgenden Analyse bildet das Leitbild bezüglich der Rechtsnatur der Exploration. In forensisch-psychiatrischen Kreisen ist man sich einig, dass die gutachterliche Untersuchung keine Einvernahme, sondern die Abklärung einer psychiatrischen Fragestellung darstellt, deren Durchführung sich nach psychiatrischen Fachregeln zu richten hat.⁸⁰⁵ Zur Begründung wird angeführt, dass es dem Sachverständigen vorrangig – anders als in der Einver-

⁸⁰⁴ Vgl. N 285 ff.

⁸⁰⁵ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; FOERSTER/FOERSTER, S. 1016; HABERMEYER/SACHS, N 7; Hässler/Kinze/Nedopil-KINZE, S. 41 f.; KIESEWETTER, Kriminallistik 1995, S. 602; Kröber et al.-II-KRÖBER, S. 167; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 192.

nahme – um die Erfassung der psychischen Symptomatik gehe, während es in der Einvernahme vor allem auf das gesprochene Wort ankomme.⁸⁰⁶

Diese ausserjuristischen Stimmen spiegeln sich in der Rechtsprechung. Das Explorationsgespräch diene nicht der umfassenden Abklärung des Sachverhalts (wie die Einvernahme), sondern stelle ein besonderes Setting dar, «das der Feststellung psychischen Beschaffenheit sowie der Abklärung von geistigen und seelischen Eigenschaften einer Person» diene.⁸⁰⁷ Analoge Überlegungen spiegeln sich in der bundesgerichtlichen Praxis: Das Explorationsgespräch diene einem anderen Zweck als die Einvernahme. Es solle dem Experten ermöglichen, sich ein «möglichst unbeeinflusstes Bild über die laut Gutachtensauftrag zu prüfenden medizinisch-psychiatrischen Fachfragen zu verschaffen». Die sachverständige Person nehme ausschliesslich einfache (fachspezifische) Erhebungen vor, die in engem Zusammenhang mit dem Auftrag stünden. Die gutachterliche Befragung des Exploranden sei somit eng gutachtenorientiert.⁸⁰⁸ Summa summarum lautet das dogmatische Leitbild: Die Exploration ist keine Einvernahme.

302

II. Fakt: materielle Kongruenz zwischen Einvernahme und Exploration

Zwar kann nicht bestritten werden, dass die Exploration im Kontext des Schuld- und Massnahmengutachtens sowie die strafbehördliche Einvernahme der beschuldigten Person Unterschiede aufweisen. Während die Strafbehörde bei ihren Erhebungen eine umfassende Abklärung des rechtsrelevanten Sachverhalts anstrebt (Art. 6 Abs. 1 StPO; Art. 157 ff. StPO), fokussiert sich die sachverständige Person auf den Sachverhalt, welcher für die Beantwortung ihrer Gutachtensfragen von Bedeutung ist (Art. 185 Abs. 4 StPO). Diese Tatsache spiegelt sich auch im Zuständigkeitsmodell: Für Einvernahmen der beschuldigten Person sind die Strafbehörden zuständig (Art. 142 StPO; Art. 157 StPO), für die psychiatrische Exploration ist es die sachverständige Person im Rahmen der einfachen Erhebungen (Art. 185 Abs. 4 StPO). Formalrechtlich betrachtet sind strafbehördliche Einvernahme und psychiatrische Exploration damit nicht identisch. In diesem Rahmen – und nur in diesem – ist das Leitbild «Exploration ≠ Einvernahme» berechtigt. Sofern aus dieser Differenz allerdings Folgen für das verfahren-

303

⁸⁰⁶ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 18; HABERMEYER/SACHS, N 7; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 192 f.

⁸⁰⁷ KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/dd; OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH 110068, E. II.3 und 4.1; eine analoge Differenzierung nimmt der BGH im deutschen Recht vor: BGH, 8. August 2002, 3 StR 239/02, N 3.

⁸⁰⁸ BGE 144 I 253, E. 3.7.

rensrechtliche Schutzniveau abgeleitet werden, muss diese Schlussfolgerung als unberechtigt zurückgewiesen werden.

304 Die nachfolgende Analyse wird zeigen, dass die Exploration mindestens dieselben verteidigungsrechtlichen Herausforderungen wie eine Einvernahme mit sich bringt. Die dafür notwendige Argumentation fusst auf folgenden Pfeilern: Erstens steht die psychiatrische Exploration wie auch die strafbehördliche Einvernahme im Vorverfahren in einem latenten Spannungsverhältnis mit *nemo tenetur*, da mit ihr verwertbare Beweise von einer unter Druck stehenden beschuldigten Person erhältlich gemacht werden, was eine analoge Behandlung mit Blick auf das Recht auf Verteidigerbeizug nahelegt (1.) Diese These wird zusätzlich durch die Beobachtung gestützt, dass die beschuldigte Person wie auch bei einer Einvernahme ein Interesse hat, vor ungesetzlichem Verhalten des Sachverständigen geschützt zu werden (2.). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die Erhebungen der sachverständigen Person determinierende Wirkung für den weiteren Gang des Verfahrens aufweisen (3.) In einer Gesamtschau liegen damit in der Exploration weitgehend gleiche verteidigungsrechtliche Herausforderungen wie in einer Einvernahme vor, was nach denselben prozessualen Schutzmechanismen ruft; insbesondere dem Recht auf Beizug einer Verteidigung nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK (4.).

1. Tangenten der psychiatrischen Exploration mit *nemo tenetur*

305 In § 9 wurde erläutert, dass *nemo tenetur* einen hohen Stellenwert für die Verfahrensfairness besitzt und dass seine Wahrung eng mit dem Recht auf Beizug einer Verteidigung verbunden ist.⁸⁰⁹ Nachfolgend wird sich zeigen, dass dieser Leitsatz auch in der Exploration gilt. Es werden in der Exploration Informationen gesammelt, welche dem Schutzbereich von *nemo tenetur* unterstehen (A.). Folgerichtig hat die beschuldigte Person in der Exploration das Recht, die Mitwirkung zu verweigern, was sich in Art. 185 Abs. 5 StPO spiegelt (B.). Wirkt die beschuldigte Person trotzdem mit, können die so erhobenen Tatsachen umfassend verwertet werden (C). Daraus ergibt sich die Gefahr, dass sich die beschuldigte Person in der Exploration sowohl retrospektiv (Tat, Schuldfähigkeit, Strafzumessung) als auch prospektiv (Massnahmenindikation) selbst belastet (D.). Die Exploration stellt vor diesem Hintergrund die Arena potenzieller Selbstbelastungsgefahren dar.⁸¹⁰ Das Problem dieser Ausgangslage besteht darin, dass die beschuldigte Person in der Exploration psychischem Druck ausge-

⁸⁰⁹ Vgl. N 292 f.

⁸¹⁰ BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 40; EDITORS, 454: «...the pretrial mental examination can become a discovery tool for the prosecution, jeopardizing the accused's privilege against self-incrimination if adequate safeguards are not established.»

setzt ist, was auch aufgrund ihrer Verletzlichkeit von grosser Bedeutung ist (E.). Ebenso besteht die Gefahr, dass die beschuldigte Person ihre Mitwirkung in Verkenntung der prozessualen Rolle des Sachverständigen tätigt (F.). Mit diesen Bedingungen ist die Autonomie zur freien und bewussten Mitwirkung in der Exploration tangiert, welche durch nemo tenetur gewährleistet wird (G.).

A) Sachlicher Schutzbereich von nemo tenetur

a) Willensabhängigkeit des Beweismittels

Der Kerngedanke von nemo tenetur lautet, dass die Strafbehörden den Willen der beschuldigten Person zu schweigen akzeptieren bzw. dass sie keine Zwangsmittel anwenden, welche den Willen der beschuldigten Person überwinden.⁸¹¹ Elementar für den sachlichen Schutzbereich von nemo tenetur ist somit (ohne auf einzelne Besonderheiten der EGMR-Praxis näher einzugehen⁸¹²), ob das fragliche Beweismittel durch den Willen der beschuldigten Person zu Tage gefördert wird. Nach der sog. Saunders-Formel gilt: «The right not to incriminate oneself...does not extend to the use in criminal proceedings of material which may be obtained from the accused through the use of compulsory powers but which has an existence independent of the will of the suspect such as, inter alia, documents acquired pursuant to a warrant, breath, blood and urine samples and bodily tissue for the purpose of DNA testing.»⁸¹³ Es fallen somit insbesondere jene Beweismittel unter den Schutz von nemo tenetur, deren Existenz vom Willen der beschuldigten Person abhängt, was namentlich bei Aussagen der beschuldigten Person der Fall ist.⁸¹⁴ Für die Anwendbarkeit des sachlichen

306

⁸¹¹ EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 266, ECHR 2016; EGMR, Turbylev v. Russia, no. 4722/09, § 84, 6 October 2015; BGE 142 IV 207, E. 8.3.1; BGE 140 II 384, E. 3.3.2.

⁸¹² Ausführlich zur inkonsistenten EGMR-Praxis bezüglich des sachlichen Schutzbereichs von nemo tenetur: ASHWORTH, S. 758 ff.; OTT, S. 126 ff.; ROTH, ZStrR 2011, S. 312 ff.; WOHLERS, FS Küper, S. 696 ff.

⁸¹³ EGMR, Saunders v. the United Kingdom, 17 December 1996, § 69, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; EGMR, Quinn v. Ireland, no. 36887/97, § 40, 21 December 2000; EGMR, Heaney and McGuinness v. Ireland, no. 34720/97, § 40, ECHR 2000-XII; Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, § 102, ECHR 2006-IX; O'Halloran and Francis v. the United Kingdom [GC], nos. 15809/02 and 25624/02, § 47, ECHR 2007-III; EGMR, Aleksandr Zaichenko v. Russia, no. 39660/02, § 38, 18 February 2010; PABEL/SCHMAHL, § 24 N 138; BGer, 7. November 2018, 6B_598/2018, E. 3.6; BGE 140 II 384, E. 3.3.2; BGE 131 IV 36, E. 3.1; BGE 138 IV 47, E. 2.6.1.

⁸¹⁴ EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 266, ECHR 2016; EGMR, Turbylev v. Russia, no. 4722/09, § 84, 6 October 2015; BGE 142 IV 207, E. 8.3.1; BGE 140 II 384, E. 3.3.2; ausführlich sodann TRECHSEL, S. 341 ff.; OTT, S. 112 ff.; zur Ähnlichkeit der EGMR-Formel mit

Schutzbereichs spielt es keine Rolle, ob das von der beschuldigten Person erlangte Beweismaterial inhaltlich direkt selbstbelastend ist oder neutraler Natur zu sein scheint, da selbst *prima vista* neutrale Informationen im Laufe des Verfahrens von den Strafbehörden zur Widerlegung der Angaben der beschuldigten Person oder dem Nachweis von Widersprüchen verwendet werden können.⁸¹⁵

b) *Geschützte Explorationsinhalte*

307 Nimmt man für den Schutzbereich von *nemo tenetur* das Kriterium der Willensabhängigkeit als Massstab, bleibt zu erschliessen, welche von der beschuldigten Person im Rahmen der Exploration erlangten Beweissubstrate unter den Schutz von *nemo tenetur* fallen. Diese Frage wurde in den USA, wo der US Supreme Court einen ähnlichen Schutzbereich von *nemo tenetur* wie jenen des EGMR konturiert hat⁸¹⁶, bereits diskutiert. Nun könnte argumentiert werden, dass sämtliche vom Exploranden ausgehende Informationen blosser Ausdrücke des Körpers bzw. der Psyche sind, welche – da unabhängig vom Willen des Betroffenen existierend – nicht unter den Schutz von *nemo tenetur* fallen.⁸¹⁷ Diese Position ist aber kaum haltbar. Maximal wird vom unbewussten Teil des beobachtbaren Verhaltens des Exploranden (äusserliche Erscheinung, Art des Sprechens usw.) noch gesagt werden können, dass es unabhängig vom Willen der beschuldigten Person besteht. Allerdings sind bei näherem Hinsehen bereits hier die Grenzen schwammig, da fast jeder denkbare Verhaltensaspekt (Blinzeln, Gestik, Mimik) zumindest theoretisch durch die Kraft des Willens beeinflusst werden könnte.

308 Sofern aber Aussagen der beschuldigten Person im Explorationsgespräch betroffen sind, kann nicht abgestritten werden, dass diese Informationen nur durch den Willen des Betroffenen offenbart werden können und folglich den Schutz von *nemo tenetur* geniessen.⁸¹⁸ Gleich muss es sich bezüglich jener Informationen verhalten, welche die explorierte Person durch ihr Verhalten bewusst preisgibt,

der Differenzierung zwischen testimonial und non-testimonial evidence gemäss dem US-Supreme Court auch BERGER, S. 366.

⁸¹⁵ EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 268, ECHR 2016; EGMR, Saunders v. the United Kingdom, 17 December 1996, § 71, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; EGMR, Zaichenko v. Russia, no. 33720/05, § 54, 1 February 2007; BGE 109 Ia 166, C. 2b.

⁸¹⁶ BERGER, S. 366.

⁸¹⁷ Zu diesen Argumenten die Ausführungen bei ARONSON, S. 68 m.w.N. und GOCKER, S. 630 m.w.N.

⁸¹⁸ Zurecht: ARONSON, S. 68; GOCKER, S. 630 f.; MEISTER, S. 417 und 429 ff.; US Court of Appeals, District of Columbia Circuit, United States v. Byers, 740 F2d 1104, Dissent Bazelon, N 141: «The interview portion of the examination at issue in the instant case falls squarely at the testimonial end of the spectrum»; in der Sache auch TOEPEL, S. 359 f.

indem sie z.B. nickt, anstatt «ja» zu sagen usw. Der Sachverhalt liegt bei diesen Kommunikationsvorgängen anders als bei der Abnahme einer Blutprobe, wo die Existenz des Beweismaterials (Blut) nicht vom Willen des Betroffenen abhängt.⁸¹⁹ Summa summarum stehen mindestens sämtliche vom Willen gesteuerten Kommunikationsgehalte der beschuldigten Person im Explorationsgespräch – seien es mündliche Aussagen oder gleichwertiges konkludentes Verhalten – unter dem Schutz von *nemo tenetur*. Für die psychiatrische Exploration bedeutet dies: Die beschuldigte Person darf frei von unzulässigem Zwang darüber entscheiden, ob sie gegenüber dem Sachverständigen eine Information durch eine Aussage oder gleichwertiges Körperverhalten preisgeben will, womit sie in ihrer Stellung als autonomes Subjekt im Strafverfahren abgesichert wird.⁸²⁰

B) Gesetzliche Adressierung im Explorationskontext (Art. 185 Abs. 5 StPO)

Wie soeben⁸²¹ aufgezeigt wurde, stehen diverse vom Sachverständigen im Gespräch mit der beschuldigten Person erhobene Tatsachen unter dem Schutzbereich von *nemo tenetur*. Schon vor dem Erlass der StPO hatte die kantonale Gerichtspraxis folgerichtig erkannt, dass die beschuldigte Person durch die sachverständige Exploration nicht schlechter gestellt werden darf und entsprechend im selben Umfang auf ihre Rechte hingewiesen werden muss wie bei strafbehördlichen Einvernahmen.⁸²² Es dürfte mitunter diese Überlegung gewesen sein, welche den Gesetzgeber dazu bewog, dem Schutz von *nemo tenetur* im Kontext des Sachverständigenbeweises Rechnung zu tragen und wie bei strafbehördlichen Einvernahmen (Art. 158 Abs. 1 lit. b StPO) eine Belehrungspflicht (Art. 185 Abs. 5 StPO) vorzusehen.⁸²³ Die beschuldigte Person ist vom Sachver-

309

⁸¹⁹ GOCKER, S. 630.

⁸²⁰ OBERHOLZER, Begutachtung, S. 49 f.

⁸²¹ Vgl. N 307 ff.

⁸²² KassGer-ZH, 29. Januar 2003, E. 1d, in: ZR 102/2003, Nr. 30, S. 150 ff.; vgl. auch GRONER, S. 295.

⁸²³ Hierzu auch BGer, 19. September 2018, 6B_824/2018, E. 1.1 : «S'agissant du prévenu, la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP» sowie E. 1.2 «...l'art. 185 al. 5 CPP consacre, pour le prévenu, un droit de ne pas s'auto-incriminer, conformément à l'adage *nemo tenetur se ipsum accusare*.»; BGer, 18. Februar 2019, 1B_409/2018, E. 4.3: «Auch bei Erhebungen durch die sachverständige Person kann die beschuldigte Person ihre Mitwirkung oder Aussage verweigern (Art. 185 Abs. 5 StPO)»; ZK StPO-DONATSCH, Art. 185 N 38; PIETH, S. 212 und PIQUEREZ/MACALUSO, N 1119 hinterfragen, ob die sachverständige Person juristisch überhaupt in der Lage ist, eine solche Belehrung rechtskonform vorzunehmen; SCHMID, AJP 2010, S. 830 bezeichnet es vor diesem Hintergrund zurecht als wünschenswert, wenn die Verfahrensleitung der sachverständigen Person Merkblätter vermittelt, damit eine korrekte Belehrung stattfinden kann.

ständigen zu Beginn der sachverständigen Erhebung (in casu: Exploration) darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Mitwirkung oder Aussage verweigern darf.⁸²⁴ Diese Belehrung hat auch die Information zu enthalten, dass der Sachverständige gegenüber der Strafbehörde keiner Schweigepflicht untersteht und sämtliche Mitteilungen des Exploranden gegenüber dem Sachverständigen im Gutachten aufgeführt und später verwendet werden können.⁸²⁵ Dabei versteht sich von selbst, dass das Stattfinden dieser Belehrung zu dokumentieren ist.⁸²⁶

C) Verwertbarkeit der Explorationsinhalte

- 310 Ist der Nexus zwischen psychiatrischer Exploration und nemo tenetur geklärt, interessiert in einem weiteren Schritt, ob und in welchem Rahmen Angaben der beschuldigten Person verwertet werden dürfen, welche die sachverständige Person im Rahmen der Exploration erhoben hat. Für diese Frage gilt es die Leitlinien der kantonalen Rechtsprechung und h.L. zu konsultieren (a) und die ambivalente Bundesgerichtspraxis zur Kenntnis zu nehmen (b), bevor die geltende Rechtslage in einer Würdigung erschlossen werden kann (c).

a) Leitlinien der kantonalen Rechtsprechung und h.L.

- 311 Vor Erlass der geltenden StPO hatte sich zur Verwertbarkeit von Explorationsinhalten eine Rechtsprechungslinie etabliert. Danach galt: Befundtatsachen («Tatsachen, welche der Sachverständige zur Erfüllung des Auftrages und kraft seiner Sachkunde ermittelt») können ohne Weiteres verwertet werden.⁸²⁷ Anders gestaltete sich die Rechtslage bei sog. Zusatztatsachen, «die sich aus Anlass der Tätigkeit des Gutachters ergeben und für deren Ermittlung es nicht der gutachterlichen Sachkunde bedurft hätte, wie z.B. das Tatgeschehen betreffende Tatsachen».⁸²⁸ Die Verwertbarkeit solcher Angaben setzte voraus, dass die beschuldigte Person bezüglich ihres Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrechts (nemo tenetur) sowie der Tatsache, dass sämtliche Informationen in das

⁸²⁴ Die Belehrungspflicht gilt auch dann, wenn die beschuldigte Person zeitlich bereits zuvor anlässlich einer polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Einvernahme (im Rahmen von Art. 158 StPO) belehrt wurde: BGer, 19. September 2018, 6B_824/2018, E. 1.1.

⁸²⁵ KGer-VS, 24. Oktober 2014, TCV P3 14 153, E. 3.4.2; OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II.4.2; KassGer-ZH, 29. Januar 2003, E. 1d, in: ZR 102/2003, Nr. 30, S. 150 ff.; OGer-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 3; BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 31; MAIER/MÖLLER, S. 167; HELFENSTEIN, S. 97; LAEMMEL, S. 249; CR CPP-VUILLE, Art. 185 N 2; RIKLIN, Art. 185 N 10.

⁸²⁶ Stellvertretend: OGer-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 3.

⁸²⁷ KassGer-ZH, 29.01.2003, E. 1 b ff., in: ZR 102/2003, Nr. 30, S. 150 ff.; KassGer-ZH, 18.12.2009, AC080021, E. 1.7.1.c/aa.

⁸²⁸ KassGer-ZH, 18.12.2009, AC080021, E. 1.7.1.c/aa.

Gutachten einfließen und an die Strafbehörden gelangen können, belehrt wurde.⁸²⁹ Dieser Praxis – welche sich im Übrigen in der h.L. spiegelt – sind die kantonalen Gerichte unter dem Geltungsbereich der StPO treu geblieben: Hat eine rechtskonforme Belehrung nach Art. 185 Abs. 5 StPO stattgefunden, können auch Zusatztatsachen verwertet werden.⁸³⁰ Sofern Zusatztatsachen nicht schon im Gutachten erwähnt werden, können sie durch die Befragung des Sachverständigen als Zeugen in den Prozess eingebracht werden.⁸³¹

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der sachverständigen Person bei ihrer Aussage als Zeugin kein Zeugnisverweigerungsrecht (Art. 171 StPO i.V.m. Art. 321 StGB) zusteht, wenn eine Belehrung nach Art. 185 Abs. 5 StPO stattgefunden hat; vielmehr hat sie solche Tatsachen bei ihrer Zeugeneinvernahme zu offenbaren (Art. 307 StGB).⁸³² Dies (Offenbarungspflicht) gilt nach einer konservativeren Auffassung zumindest dann, wenn die fraglichen Tatsachen im Zusammenhang mit dem Begutachtungsauftrag stehen.⁸³³ Gerade an diesem Gutachtenszusammenhang dürfte es jedoch nur selten fehlen, wenn eine Begutachtung der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation in die Wege geleitet wird. Wenn man sich an die Ausführungen des Thementaufsatzes erinnert, wonach für den Sachverständigen beim Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachten sowohl das Vorleben, die Tat im aktuellen Verfahren als auch die Zukunft des Exploranden von Bedeutung ist⁸³⁴, wird man regelmässig zum Schluss gelangen müssen, dass die fraglichen Tatsachen einen potentiellen Gutachtenszusammenhang aufweisen.⁸³⁵ Damit ist klar: Das Berufsgeheimnis

⁸²⁹ KassGer-ZH, 29. Januar 2003, E. 1d, in: ZR 102/2003, Nr. 30, S. 150 ff.; KassGer-ZH, 7. Dezember 2004, E. 2.3.a, in: ZR 104/2005, Nr. 32, S. 133 ff.; KassGer-ZH, 23. Mai 2005, E. 7.1.e, in: ZR 104/2005, Nr. 74, 286 ff.; KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/aa.

⁸³⁰ KGer-VS, 24. Oktober 2014, TCV P3 14 153, E. 3.4.2; OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II.4.2; BSK StPO-I-HEER, Art. 185 N 32 (allerdings in Reibung mit Art. 187 N 4); BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 31; GRONER, S. 295; HELFENSTEIN, S. 97; LAEMMEL, S. 249; MAIER/MÖLLER, S. 167; OBERHOLZER, Grundzüge 2012, N 821; SCHMID, AJP 2010, 832; CR CPP-VUILLE, Art. 185 N 2 und 9; a.M. implizit BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 13 f.; DONATSCH, fp 2012, S. 237; wohl auch WOHLERS, Fremdanamnese, S. 84 ff.

⁸³¹ OGer-ZH, 11. Mai 2011, UH110068, E. II.4.2; KGer-VS, 24. Oktober 2014, TCV P3 14 153, E. 3.4.2; ZK StPO-DONATSCH, Art. 182 N 7; BSK StPO-I-HEER, Art. 187 N 12.

⁸³² BSK StGB-BOMMER, Art. 20 N 31; HELFENSTEIN, S. 97; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, § 64 N 15a; SCHMID, AJP 2010, S. 832.

⁸³³ Umkehrschluss aus FILI, S. 72 f.; BSK StPO-I-HEER, Art. 187 N 12; LUPU, S. 133; KELLER, S. 221 ff.; MAIER/MÖLLER, S. 222 f.

⁸³⁴ Vgl. N 13 ff.

⁸³⁵ Differenzierend: BSK StPO-I-HEER, Art. 187 N 12, welche zwar eingesteht, dass etwa ein Geständnis für die Schuldfähigkeitsbegutachtung von Bedeutung ist, aber

schützt die beschuldigte Person kaum davor, dass gegenüber dem Sachverständigen gemachte Angaben gegenüber den Strafbehörden im Rahmen einer Zeugeneinvernahme des Sachverständigen geheim gehalten werden können.

b) *Ambivalente Bundesgerichtspraxis*

- 313 Das Bundesgericht hat sich im Gegensatz zu den kantonalen Instanzen bisher nur unzureichend dazu geäußert, ob und in welchem Rahmen die vom Sachverständigen in der Exploration erhobenen Beweise im Strafverfahren verwertbar sind. In einem Versuch, eine Grenzziehung zwischen Exploration und Einvernahme zu vollziehen, führte das Bundesgericht immerhin aus, dass die sachverständige Person ausschliesslich fachspezifische Erhebungen vornehme, die in engem Zusammenhang mit dem Auftrag stehen. Die sachverständige Befragung der beschuldigten Person sei «eng gutachtenorientiert...Folglich dürfen die Strafbehörden Äusserungen des Beschuldigten bei einem psychiatrischen Explorationsgespräch diesem auch nicht wie Beweisaussagen zum inkriminierten Sachverhalt (im Verhör) vorhalten (Art. 157 StPO)». Eine klare Unterscheidung dränge sich auf, da beim psychiatrischen Explorationsgespräch die gesetzlichen Erfordernisse an ein justizkonformes Verhör des Beschuldigten (Justizperson, die zur Durchführung einer Einvernahme berechtigt ist, Teilnahmerechte der Verteidigung, Protokollierungsvorschriften nach Art. 78 StPO und Belehrung nach Art. 158 StPO) nicht erfüllt seien.⁸³⁶

c) *Würdigung*

- 314 Die bundesgerichtliche Praxis wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet.⁸³⁷ Wortwörtlich betrachtet beschränkt sich das bundesgerichtliche Verbot darauf, die Explorationsaussagen im Verhör bzw. der strafbehördlichen Einvernahme der beschuldigten Person zum inkriminierten Sachverhalt als Vorhalte zu verwenden. Unter Vorhalt wird jedoch nach Art. 143 Abs. 5 StPO jene Einvernahmetechnik verstanden, die dazu dient, die «die Vollständigkeit der Aussagen und

beispielsweise Tatsachen unter das Berufsgeheimnis fallen könnten, welche das Begutachtungsergebnis nicht direkt beeinflussen, aber z.B. für die rechtliche Tatqualifikation von Bedeutung sind; ähnlich auch HELFENSTEIN, S. 96 f. Allerdings scheinen diese Beispiele eher theoretischer Natur zu sein. Ob der Explorand bei ihm vorgeworfenen Raub (Art. 140 StGB) z.B. eine Schusswaffe bei sich trug (Art. 140 Ziff. 2 StGB) dürfte sowohl für die rechtliche Qualifikation als auch die sachverständige Beurteilung (insb. Risikobeurteilung) von Interesse sein. Überwiegend dürfte sich die Offenbarung von strafrechtsrelevanten Tatsachen durch das Berufsgeheimnis damit nicht verhindern lassen, zumal an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass in diesen Fällen eine Geheimnisentbindung im Rahmen von Art. 171 Abs. 2 lit. b StPO denkbar wäre.

⁸³⁶ BGE 144 I 253, E. 3.7.

⁸³⁷ Vgl. auch VETTERLI, S. 29; BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64a.

die Klärung von Widersprüchen» herbeizuführen.⁸³⁸ Bei Art. 143 Abs. 5 StPO handelt es sich aber nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung um eine Ordnungsvorschrift, deren Verletzung nicht die Unverwertbarkeit der Einvernahme nach sich zieht.⁸³⁹ Damit käme man im Explorationskontext zur wenig sinnvollen Rechtsfolge, dass die strafbehördliche Einvernahme verwertbar wäre, selbst wenn die Strafbehörde dieses Verbot missachtet und Explorationsaussagen zum inkriminierten Sachverhalt im Verhör vorgehalten wird. Ein anderes Resultat würde man nur erzielen, wenn das bundesgerichtliche «Vorhaltverbot» in der strafbehördlichen Einvernahme als Gültigkeitsvorschrift i.Sv. Art. 141 Abs. 2 StPO interpretiert wird. Doch auch dann würde sich die Frage stellen, inwiefern dieses Modell von verteidigungsrechtlichem Nutzen ist. Die Verfahrensleitung könnte nun einzig darauf verzichten, die Explorationsaussage in der Einvernahme als Vorhalt zu verwenden; das Gericht könnte sie aber bei der Beweiswürdigung trotzdem verwerten. Anders wäre der Sachverhalt einzig dann zu bewerten, wenn man den bundesgerichtlichen Entscheid dahingehend interpretiert, dass Explorationsaussagen ausserhalb des Gutachtens vom Gericht nicht verwertet werden dürfen.⁸⁴⁰ Abgesehen davon, dass sich mit diesem Lösungsansatz neue Problemfelder ergeben⁸⁴¹, ist zu konstatieren, dass das Bundesgericht in seinem Urteil mit keinem Wort von einem Verwertungsverbot spricht. Es kann ihm daher kaum eine solch gewichtige Rechtsfolge in den Mund gelegt werden.⁸⁴²

Betrachtet man die Systematik des Gesetzes, scheint die kantonalgerichtliche 315 und von der h.L. geteilte Auslegung naheliegender, dass bei einer Belehrung der beschuldigten Person nach Art. 185 Abs. 5 StPO die nachfolgend vom Sachverständigen erhobenen Tatsachen verwertet werden dürfen. Nur bei dieser Auslegung ist die Belehrungspflicht überhaupt sinnvoll. Allerdings drängen sich einige ergänzende Bemerkungen auf, sofern die Praxis und ein Teil der Lehre zwischen «frei» verwertbaren Befundtatsachen (vom Sachverständigen im Rahmen des Auftrags und mittels Fachkunde ermittelt) und nur mit Belehrung verwertbaren Zusatztatsachen (bei denen es zur Kenntnisnahme keiner Fachkunde bedarf) differenziert.⁸⁴³ Als Grund für diese Zweiteilung wird angeführt, dass sich eine beschuldigte Person eher bei Zusatztatsachen, die den Tathergang betreffen, der Gefahr von selbstbelastenden Aussagen aussetze, während Befundtatsachen

⁸³⁸ Zum Begriff des Vorhalts: HAAS/ILL, S. 18 ff.

⁸³⁹ BGE 141 IV 20, E. 3.3.

⁸⁴⁰ Mit dieser Interpretation der Bundesgerichtspraxis wohl: FINGERHUTH, fp 2018, S. 549 und HEER/COVACI, S. 446.

⁸⁴¹ Vgl. N 399 f.

⁸⁴² Zur ungeklärten Rechtslage auch: VETTERLI, S. 29.

⁸⁴³ Vgl. N 311 f.; der Gesetzestext der StPO kennt diese Differenzierung nicht: RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, N 1328.

«unmittelbar nicht die Tat oder den Tathergang, sondern die Person des Angeeschuldigten betreffen».⁸⁴⁴

- 316 Zwar anerkennt die Gerichtspraxis, dass die Abgrenzung heikel sein kann und die Grenzen zwischen Befund- und Zusatztatsachen fließend sind.⁸⁴⁵ Allerdings bleibt auch mit diesem Eingeständnis unbeantwortet, weshalb für die Erhebung von Befundtatsachen weniger strenge Standards als bei sonstigen strafbehördlichen Erhebungen gelten sollten.⁸⁴⁶ Dies wird umso klarer, wenn man sich der Tatsache bewusst wird, dass auch nicht-tatbezogene Angaben zur Person des Beschuldigten eine negative Auswirkung auf die Strafzumessung sowie die gutachterlichen Fragestellungen haben können (z.B. negativere Risikobeurteilung, fehlendes Vorliegen von psychischen Einschränkungen im Tatzeitpunkt bei der Schuldfähigkeit usw.). Bei diesen Informationen hat die beschuldigte Person ein genauso grosses Interesse, über ihr Recht informiert zu werden, nicht mitwirken zu müssen und schweigen zu dürfen (Art. 185 Abs. 5 StPO), denn der Schutzbereich von *nemo tenetur* fragt nicht danach, ob es sich um Angaben zur Tat oder zur Person handelt. Vielmehr gibt *nemo tenetur* im Strafprozess der beschuldigten Person generell die Freiheit, nur das kundzutun, was sie möchte (Willensabhängigkeit). Deshalb darf sie nicht nur zu Tat, sondern auch zu ihrer Person umfassend schweigen und muss nicht anderweitig mitwirken, wenn sie das nicht möchte.⁸⁴⁷
- 317 Ein treffendes Befund- und Zusatztatsachenverständnis lässt sich nach dem Gesagten einzig unter Rekurs auf den Schutzbereich von *nemo tenetur* erzielen. Danach gilt, dass sämtliche Aussagen des Exploranden sowie gleichwertige, willensabhängige kommunikative Inhalte als Zusatztatsachen gelten, da diese dem Schutz von *nemo tenetur* unterstehen.⁸⁴⁸ «Frei» (d.h. ohne Belehrung) verwertbare Befundtatsachen liegen hingegen nur dann vor, wenn die Information

⁸⁴⁴ KGer-VS, 24. Oktober 2014, TCV P3 14 153, E. 3.4.2; KassGer-ZH, 7. Dezember 2004, E. 2.3.a, in: ZR 104/2005, Nr. 32, S. 133 ff.; KassGer-ZH, 18.12.2009, AC080021, E. 1.7.1.c/aa.

⁸⁴⁵ KassGer-ZH, 29. Januar 2003, E. 1b ff., in: ZR 102/2003, Nr. 30, S. 150 ff.; KassGer-ZH, 7. Dezember 2004, E. 2.3.a, in: ZR 104/2005, Nr. 32, S. 133 ff.; BRUNNER, Aspekte, S. 195; BERNHARD/BRUNNER, Schuldinterlokut, S. 13 f.; KRAUSS, ZStW 1985, S. 100.

⁸⁴⁶ BRUNNER, Aspekte, S. 195.

⁸⁴⁷ Vgl. N 306 ff.

⁸⁴⁸ Vgl. N 307 f.; vgl. auch DONATSCH, fp 2012, S. 237; TOEPEL, S. 374, wonach zu den Befundtatsachen nie der Inhalt von Aussagen der untersuchten Person gehöre. Vielmehr zähle der Aussageninhalt stets zu den Umständen, die der Richter auch ohne besondere Sachkunde im Hinblick auf Wahrheit oder Unwahrheit zu beurteilen in der Lage wäre, wenn er die Wahrhaftigkeit, Objektivität und Sensitivität der Aussageperson unterstellen würde. Es handele sich beim Inhalt der wahren Aussage eines Untersuchten immer um Zusatztatsachen.

vom Sachverständigen in der Exploration unabhängig vom Willen der beschuldigten Person erhoben werden kann, wozu beispielsweise die beobachtbaren Aspekte des Explorandenverhaltens zu subsumieren sind, wobei selbst dann im Einzelnen Abgrenzungsprobleme verbleiben.⁸⁴⁹ Gerade auch vor dem Hintergrund dieser Abgrenzungsprobleme dürfte die Regelung nach Art. 185 Abs. 5 StPO ins Gesetz aufgenommen worden sein: Wird eine Belehrung vorgenommen, sollen die so erlangten Beweise im Verfahren verwertet werden dürfen. Anders lässt sich der gesetzgeberische Wille bzw. die ratio legis von Art. 185 Abs. 5 StPO kaum interpretieren.

D) Selbstbelastungsgefahren im Explorationskontext

Angesichts der vorangehenden Ausführungen zur Verwertbarkeit der Explorationssinhalte eröffnen sich für die beschuldigte Person als Explorandin analoge Selbstbelastungsgefahren wie im Rahmen der strafbehördlichen Einvernahme im Vorverfahren. Zwar strebt der PSY-Sachverständige mit seiner Exploration im Kontext des Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachtens nicht die umfassende Ermittlung des Sachverhalts an. Diese Aufgabe obliegt den Strafbehörden wie sich aus dem im 3. Teil betonten Ermittlungsverbot des Sachverständigen ergibt.⁸⁵⁰ Auf diese systematische Tatsache scheint sich auch das Bundesgericht zu stützen, wenn es formuliert, dass die sachverständige Person im Rahmen von Art. 185 Abs. 4 StPO nur fachspezifische Erhebungen durchführen dürfe, die mit dem Gutachten in engem Zusammenhang stehen, womit die gutachterliche Befragung des Exploranden (ungleich der Beweisaussage im Verhör; Art. 157 StPO) eng gutachtenorientiert ausfalle.⁸⁵¹ Ebenso wird in der Literatur betont, die sachverständige Befragung sei «auf die Erstellung des Gutachtens und der Beantwortung der Gutachterfragen, nicht aber auf die – den Strafbehörden vorbehaltene – Ermittlung des objektiven und subjektiven Tatbestands fokussiert.»⁸⁵²

Allerdings relativiert ein näherer Blick auf die Faktenlage diese Aussage. Bereits im Themenaufriß konnte aufgezeigt werden, dass diese «eng gutachtenorientierte Befragung» bei Schuldfähigkeits- und Massnahmengutachten faktisch eine umfassenden Durchleuchtung der beschuldigten Person, ihrer Biographie, der ihr vorgeworfenen Taten sowie ihrer Zukunftspläne umfasst.⁸⁵³ Wird man sich dieser Tatsache bewusst, könnte man sich kaum eine strafbehördliche Einvernahme vorstellen, welche tiefer in die Privatsphäre der beschuldigten

⁸⁴⁹ Vgl. N 307 f.

⁸⁵⁰ Vgl. N 112.

⁸⁵¹ BGE 144 I 253, E. 3.7.

⁸⁵² SCHMID, AJP 2010, S. 828 f.

⁸⁵³ Vgl. N 12 ff.

Person eingreift als das Explorationsgespräch des Sachverständigen.⁸⁵⁴ Solche Angaben werden vom Gutachter im Rahmen der Gutachtensrelevanz dokumentiert und im schriftlichen Gutachten (oder via Einvernahme des Sachverständigen) an die Strafbehörde kommuniziert.⁸⁵⁵ Dieser Umstand bringt es mit sich, dass sich die beschuldigte Person in der Exploration durch ihre Aussagen retrospektiv (a) und prospektiv (b) selbst belasten kann. Vor diesem Hintergrund lässt sich die bundesgerichtliche Differenzierung zwischen eng gutachtensorientierten Erhebungen (Art. 185 Abs. 4 StPO) und Beweisaussagen (Art. 157 StPO) nicht aufrechterhalten.⁸⁵⁶

a) *Retrospektive Selbstbelastungsgefahr*

- 320 Durch die sachverständige Befragung können Beweissubstrate generiert werden, welche neben den Begutachtungsfragen (Schuldfähigkeit, Massnahmenindikation) auch für den Tatnachweis oder die Strafzumessung relevant sind.⁸⁵⁷ Da sich diese Tatsachen auf historische Begebenheiten beziehen, soll diese Fallgruppe nachfolgend unter dem Titel «retrospektive Selbstbelastungsgefahr» diskutiert werden. Dabei lassen sich direkte (aa) und indirekte (bb) Selbstbelastungsmechanismen unterscheiden.

aa) *Direkte Selbstbelastung*

- 321 Eine direkte Selbstbelastung kann mehrere Formen annehmen. Es ist denkbar, dass sich die beschuldigte Person erstmals gegenüber dem Sachverständigen öffnet und ein (Teil)geständnis zur Tat ablegt, nachdem sie zuvor gegenüber den Strafbehörden schwieg oder die Tat bestritt.⁸⁵⁸ Sodann kommt es in der Praxis vor, dass sich der Explorand gegenüber dem Sachverständigen zu noch (strafbehördlich) unbekannten Straftaten äussert.⁸⁵⁹ Noch häufiger wird sich die beschuldigte Person ohne Geständniswillen (d.h. unbedacht) zur ermittelten Tat oder Aspekten davon äussern und dabei Tatsachen offenbaren, die sie gegenüber

⁸⁵⁴ ARONSON, S. 64; MEISTER, S. 413; WHITE, S. 962.

⁸⁵⁵ BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 13; BOETTICHER ET AL., NStZ 2005, S. 58 und BOETTICHER ET AL., NStZ 2006, S. 539: «... muß deutlich werden, ob und welche Angaben des Beschuldigten als Anknüpfungstatsachen zu Grunde gelegt wurden; insbesondere sind die gerichtlich noch zu überprüfenden Zusatzstatsachen besonders hervorzuheben»; OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 4 ff.; zur Relevanz der Tatangaben für das Gutachten: N 15; illustrativ zur Dokumentationsdichte bezüglich der Tatschilderungen seitens des Exploranden die Beispielgutachten von NEDOPIL/KRUPINSKI, S. 1 ff.; allgemein zur Dokumentationspflicht: N 178 ff.

⁸⁵⁶ Gl. M. HEER/COVACI, S. 445.

⁸⁵⁷ BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 38; HEER/COVACI, S. 445; wohl auch BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64a.

⁸⁵⁸ BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 13; BERNHARD, Massnahmenrecht, 148.

⁸⁵⁹ MEISTER, S. 419; SCHMID, AJP 2010, S. 832.

den Strafbehörden verschwiegen.⁸⁶⁰ Bei dieser Fallgruppe (in dieser Arbeit «selbstbelastende Tatsachenmosaik» genannt) ist es denkbar, dass die in der Exploration erlangte Zusatzinformation die Anklage eines schwerwiegenderen Tatbestands ermöglicht (z.B. eine bisher als vorsätzliche Tötung oder Totschlag vorgeworfene Tat kann nun als Mord angeklagt werden).⁸⁶¹ Sodann können die Äusserungen der beschuldigten Person zu ihrem Vorleben, der Tat usw. auch für die Strafzumessung Bedeutung erlangen.⁸⁶² Schliesslich soll nicht vergessen werden, dass sich die beschuldigte Person auch mit Blick auf die Schuldfähigkeit in einer Weise äussern kann, dass dies für sie negative Auswirkungen für die sachverständige Beurteilung der Schuldfähigkeit hat.

bb) *Indirekte Selbstbelastung*

Die Gefahr der Selbstbelastung über das Gutachten bleibt aber nicht auf die Fallgruppe der direkten Selbstbelastungen beschränkt, sondern findet durch die (auch) explorationsgestützte Persönlichkeitsbeschreibung der beschuldigten Person einen potenziellen Katalysator. Es besteht nämlich die Gefahr, dass die vom Sachverständigen beschriebene Persönlichkeitsdisposition-/störung vom Gericht als Indiz für den Tatnachweis verwendet wird.⁸⁶³ Dabei handelt es sich nicht um ein praxisfernes Problem. Sei es ein eingeschliffenes Verhaltensmuster⁸⁶⁴, eine persönlichkeitsimmanente latente Gewaltbereitschaft⁸⁶⁵ oder ein plausibler Deliktsmechanismus⁸⁶⁶: Sämtliche dieser (auch explorationsgestützten) Persönlichkeitsbeschreibungen wurden bereits von Gerichten als Indizien

⁸⁶⁰ BERNHARD, Massnahmenrecht, 148; LEYGRAF, S. 78; MEISTER, S. 419; SCHMID, AJP 2010, S. 832; TOEPEL, S. 375.

⁸⁶¹ Selbstverständlich kann auch das Umgekehrte geschehen, d.h. durch die Exploration können sich Tatsachen für die Unschuld oder privilegierte Tatbestände ergeben, vgl. DECKERS, S. 206 f.

⁸⁶² KassGer-ZH, 29. Januar 2003, E. 1e, in: ZR 102/2003, Nr. 30, S. 150 ff.: in diesem Verfahren hatte der Explorand gegenüber dem Gutachter erstmals geäussert, dass sein erster Gedanke nach der Schussabgabe «Habe ich das verdient?» gewesen sei, was vom Gericht in der Strafzumessung berücksichtigt wurde und berücksichtigt werden durfte; in OGer-GL, 27. März 2015, OG.2012.00033/34, E. IV.2.2.1.g stellte das OGer für das Vorleben des Täters im Rahmen der Strafzumessung «auf dessen eigenen Aussagen in der Untersuchung und in den psychiatrischen Explorationen» ab.

⁸⁶³ BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokt, S. 9 ff. sprechen in diesem Zusammenhang zurecht von einem Belastungs-Zirkelschluss; DIPPEL, Diss., S. 138; GRAF, Missbrauch, S. 147 f.; HADDENBROCK, S. 1303; LEYGRAF, S. 80 f.; MARNEROS, S. 359; TONDORF/TONDORF, N 282.

⁸⁶⁴ OGer-ZH, 31. Oktober 2016, SB160178, E. II.3.2.

⁸⁶⁵ OGer-ZH, 4. März 2016, SB140421, E. II.4.3.

⁸⁶⁶ Vgl. NZZ, Nr. 24, 30. Januar 2013, S. 15 (Urteil BezG-Horgen, 29. Januar 2013, DG120013); GRAF, Missbrauch, S. 148; OERTLE/HOLENSTEIN, S. 133.

für den Tatnachweis verwertet. Solche Beweisschlüsse werfen freilich mit Blick auf die Beweiseignung grosse Fragezeichen auf.⁸⁶⁷ Sie sind aber wie dargelegt existent und dürften sich – selbst wenn formell nicht darauf abgestellt werden dürfte – kaum aus der Psyche des urteilenden Gerichts bannen lassen.⁸⁶⁸ Da sich die gutachterliche Persönlichkeitsbeschreibung auch auf die Explorationsangaben der beschuldigten Person stützt, muss von einem indirekten Selbstbelastungsrisiko gesprochen werden.

b) *Prospektive Selbstbelastungsgefahr*

323 Neben der zuvor erläuterten Fallgruppe der retrospektiven Selbstbelastung kann sich ein Explorand durch seine Mitwirkung in der Exploration auch in prospektiver Sicht (Massnahmenindikation) selbst belasten. In diesem Kontext ist auf die graduelle Verlagerung vom Schuldstrafrecht hin zum Präventivstrafrecht hinzuweisen; anstelle der schuldangebundenen Strafsanktion treten mehr und mehr präventiv orientierte Massnahmen (Art. 56 ff. StGB).⁸⁶⁹ Grund und Ausmass von strafrechtlichen Massnahmen bestimmen sich dabei nicht alleine durch die Tat, sondern durch das Risiko- und Veränderungspotential, das der betroffenen Person bzw. deren Persönlichkeit attestiert wird.⁸⁷⁰ Und gerade in diesem Kontext kann sich die beschuldigte Person durch ihre Explorationsangaben prospektiv belasten, indem sie Informationen preisgibt, welche eine für sie negativere Risikobeurteilung und/oder Einstufung der Behandelbarkeit nach sich zieht, die wiederum potenziell zu eingriffsintensiven strafrechtlichen Massnahmen führt. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, im Rahmen der Exploration auch von einer prospektiven Selbstbelastungsgefahr auszugehen.

324 Die Terminologie der prospektiven Selbstbelastungsgefahr mag den Leser intuitiv irritieren, ist doch der Begriff der Selbstbelastung im allgemeinen Verständnis auf das Tatgeschehen und die Vergangenheit des Täters bezogen. Trotzdem ist der Terminus der prospektiven Selbstbelastung gerechtfertigt, wenn man den systematischen Kontext betrachtet. In den Ausführungen zu nemo tenetur wurde der enge konventionsrechtliche Zusammenhang der Aussage- und Mitwirkungsfreiheit zur Unschuldsvermutung betont: Wenn nemo tenetur nicht garantiert wäre, könnte durch die Pflicht zur Aussage oder Mitwirkung die kraft Un-

⁸⁶⁷ KRÖBER, FPPK 2015-B, S. 102; LEYGRAF, S. 81 und 84; STIELS-GLENN, S. 135.

⁸⁶⁸ LEYGRAF, S. 81 f.

⁸⁶⁹ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 77; BERNHARD, Massnahmenrecht, 152; FONJALLAZ/GASSER, S. 13; GRAF, Missbrauch, S. 141; GRAF, Fremdanamnese, S. 62; OBERHOLZER, ZStrR 2018, S. 95 ff. spricht in diesem Zusammenhang von einem «Interventionsrecht neuer Prägung»; SANER, S. 122; implizit auch BGer, 6. Juni 2017, 6B_300/2017, E. 6 «Das früher auf den Täter zentrierte Strafrecht nimmt heute den Opferschutz stärker in den Blick».

⁸⁷⁰ FONJALLAZ/GASSER, S. 147; GMÜR, S. 28; OBERHOLZER, ZStrR 2018, S. 98.

schuldsvormutung auf dem Staat lastende Beweislast (Art. 6 Ziff. 2 EMRK, Art. 32 Abs. 1 BV, Art. 10 Abs. 1 StPO) faktisch auf die beschuldigte Person verschoben werden.⁸⁷¹ Wenn aber der Staat im Strafverfahren die Beweislast trägt, betrifft dies nicht nur das Tatsachenfundament für einen Schuldspruch, sondern auch das gesamte Tatsachenfundament für die Beurteilung der Massnahmenindikation. Zwar gilt in dubio pro reo nach konstanter Bundesgerichtspraxis bei der Prognoseentscheidung nicht.⁸⁷² Allerdings darf nicht bezweifelt werden, dass in dubio pro reo für das Tatsachenfundament der Prognose Anwendung finden muss.⁸⁷³ Ist dies aber der Fall, ist die beschuldigte Person in keiner Weise verpflichtet, an der Herstellung des massnahmenbegründenden Sachverhalts mitzuwirken. Mit anderen Worten steht der beschuldigten Person kraft nemo tenetur der Entscheid offen, ob sie sich diesbezüglich dem Sachverständigen öffnen möchte oder nicht, denn wie bereits mehrfach betont gibt nemo tenetur der beschuldigten Person die Freiheit, willensabhängige Informationen preiszugeben oder zurückzuhalten.⁸⁷⁴ So auch beim massnahmenrelevanten Sachverhalt. Vor diesem Hintergrund ist auch die prospektive Selbstbelastungsgefahr in der Fairnessanalyse zu berücksichtigen.

E) Psychischer Druck auf den «freien» Kooperationsentscheid der beschuldigten Person

Voranstehend wurde nachgewiesen, dass sich die beschuldigte Person im Explo- 325
rationskontext analog zur Einvernahme sowohl retrospektiv als auch prospektiv selbst belasten kann. Dies wirft für sich genommen noch keine konventionsrechtlichen Friktionen auf, denn nemo tenetur verbietet ja nicht die Erlangung inkriminierender Informationen per se, sondern nur, wenn sie durch unzulässigen Zwang entstanden sind.⁸⁷⁵ Bei der strafbehördlichen Einvernahme im Vorverfahren bildet nun die Atmosphäre des latenten Kooperationszwangs einen zentralen Grund dafür, die Verteidigung zuzulassen; erst mit ihrer Teilnahme kann als gesichert gelten, dass die beschuldigte Person informiert mitwirkt oder

⁸⁷¹ Vgl. N 292 f.; vgl. sodann EGMR, Saunders v. the United Kingdom, 17 December 1996, §68, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; EGMR Heaney and McGuinness v. Ireland, no. 34720/97, § 40, ECHR 2000-XII; EGMR, Zaichenko v. Russia, no. 33720/05, § 38, 1 February 2007.

⁸⁷² BGer, 10. Oktober 2017, 6B_403/2017, E. 2.1; BGer, 23. August 2016, 6B_986/2015, E. 3.2; BGE 127 I 1, E. 2a; BGE 118 I 108, E. 2a.

⁸⁷³ KGer-BL, 20. Dezember 2016, 470 16 49, E. 2.4.1; HEER, Anforderungen, 117 f.; PAREIN, 367 ff.; POLLÄHNE, Basisraten, 239; POLLÄHNE, Risiko, 58; VOLCKART, Editorial.

⁸⁷⁴ Vgl. N 306 ff.

⁸⁷⁵ Vgl. N 293.

auf eben eine solche Mitwirkung verzichtet (*nemo tenetur*).⁸⁷⁶ Die nachfolgende Analyse wird zeigen, dass die Exploration in keinem minderen Masse als die Einvernahme Aspekte beinhaltet, welche substantiellen Druck auf den Kooperationsentscheid der beschuldigten Person mit sich bringen.⁸⁷⁷ Die Rahmenbedingungen der Exploration sind geeignet, in Konflikt mit der kraft *nemo tenetur* geschützten freien Entscheidung der beschuldigten Person für oder wider die Kooperation mit dem Sachverständigen zu geraten.

a) *Druckfaktoren auf den Kooperationsentscheid*

aa) *Informationsinteresse und Gesprächsführungstechnik des Sachverständigen*

- 326 Ein erstes Druckelement auf den Kooperationsentscheid des Exploranden ergibt sich aus der Tatsache, dass der PSY-Sachverständige im Rahmen seiner Begutachtung bestrebt ist, ein möglichst umfassendes Bild vom Exploranden und dessen Psyche zu zeichnen.⁸⁷⁸ Der Sachverständige hat entsprechend ein ausgeprägtes Interesse daran, dass die beschuldigte Person in der Exploration kooperiert.⁸⁷⁹ Sprechende Exploranden werden vom Sachverständigen lieber gesehen als schweigende, denn nur mit der Kooperation seines Gegenübers kann der Sachverständige seine Erkenntnis in der Exploration weiter ausbauen.⁸⁸⁰ Diese Rahmenbedingungen sind der beschuldigten Person bekannt. So hat das Bundesgericht im Kontext der Massnahmenindikation (Art. 56 ff. StGB) klargestellt, dass die beschuldigte Person seitens des PSY-Sachverständigen «über den Grund der Exploration und die Faktoren, welche die Massnahmeempfehlung beeinflussen» aufzuklären ist, was auch die «Orientierung über die Auswirkungen eines Geständnisses auf die gutachterliche Empfehlung» beinhaltet.⁸⁸¹ Analoges muss für das Schuldfähigkeitsgutachten gelten, d.h. auch hier muss die sachverständige Person den Exploranden darüber aufklären, welche Auswirkung die fehlende Kooperation in der Exploration für die Beurteilung zeitigt.

⁸⁷⁶ PIVATY, S. 73 spricht in diesem Zusammenhang von der «coercive atmosphere» der Einvernahme.

⁸⁷⁷ So auch ARONSON, S. 65 im US-amerikanischen Kontext.

⁸⁷⁸ Vgl. N 12 ff.

⁸⁷⁹ MARTINEZ/GRAY, S. 185 f.: «Quite the contrary, openness and full disclosure are desirable to assist the goal of truth seeking. Transparency and revelation are encouraged to assist the forensic evaluator in forming an accurate opinion of a narrow medico-legal consideration.»; KONRAD/RASCH, S. 313.

⁸⁸⁰ IGNOR, S. 93; siehe überdies die Ausführungen bei GERSTENFELD, S. 286.

⁸⁸¹ BGer, 20. Februar 2018, 6B_1408/2016, E. 2.1.2.

Diese vom Sachverständigen vorzunehmende Belehrung stellt zwar eine erlaubte Aufklärung über die prozessualen Folgen eines bestimmten Verhaltens dar.⁸⁸² 327
Trotzdem ergibt sich daraus ein psychisches Druckmoment auf den freien Kooperationsentscheid der beschuldigten Person. Sie dürfte sich der Abhängigkeit ihres strafrechtlichen Schicksals von der gutachterlichen Einschätzung sehr bewusst sein.⁸⁸³ Regelmässig wird sie wohl unabhängig von der tatsächlichen Verfahrenslage befürchten, Gegenwehr gegenüber dem Sachverständigen (d.h. keine Kooperation) könne ihr zum Nachteil gereichen.⁸⁸⁴ Dazu kommt, dass sie mangels Fachwissen und Anwesenheit der sie beratenden Verteidigung kaum abschätzen kann, ob in der konkreten Explorationssituation ihre Mitwirkung tatsächlich die bessere Option ist, oder ob Schweigen opportun wäre. Sie wird es daher ab initio schwer haben, sich gegen das Informationsinteresse zu wehren, zumal der PSY Sachverständige gesprächstechnisch hervorragend geschult ist, eine initiale Zurückhaltung des Exploranden zu überwinden⁸⁸⁵ bzw. weil sich seine Gesprächstechnik in der Sache kaum von den auf Gewinnung realitätsge-rechter Angaben ausgerichteten strafbehördlichen Vernehmungstaktiken unterscheidet (z.B. Arbeit mit Vorhalten, öffnende Gesprächsstechnik etc.)⁸⁸⁶.

⁸⁸² Zu dieser Fallgruppe: ZK StPO-WOHLERS, Art. 140 N 7.

⁸⁸³ MEISTER, S. 426; STIELS-GLENN, S. 137.

⁸⁸⁴ Zu den befürchteten Nachteilen auch STIELS-GLENN, S. 137 dabei ist auch denkbar, dass der Sachverständige unbewusst eine unbewusst «psychiatrische Strafzumessung» praktiziert und Nichtkooperation mit einer Negativbeurteilung und Kooperation mit einer Positivbeurteilung belohnt. Solche Mechanismen sind freilich kunstfehlerhaft, aber fast nicht aufzudecken. Siehe auch GERSTENFELD, S. 284 f.

⁸⁸⁵ ARONSON, S. 69; MÜLLER/NEDOPIL, S. 413: «Wird das Gespräch über weniger Belastendes, wie Lebenslauf oder Vorerkrankungen, an den Anfang gestellt, erhält der Proband die Gelegenheit, Untersuchungssituation und Gutachter ein wenig kennenzulernen und einzuschätzen. Der Untersucher signalisiert, dass er in erster Linie am Probanden und nicht an einer eventuellen Verurteilung interessiert ist...Bei einem solchen Vorgehen fällt es den meisten Probanden auch leichter, über den Anlass der Begutachtung zu sprechen und ihre subjektive Sicht darzulegen. Durch das Hintanstellen einer Tatexploration unterscheidet sich der Psychiater zudem von den Ermittlungsorganen.»

⁸⁸⁶ GERSTENFELD, S. 285; zum Fokus auf Gewinnung realitätsgerechter Angaben auch KIEGELAND, S. 167 ff.; Kröber et al.-III-KRÖBER, S. 97 «...soll der Sachverständige unter Offenbarung eigenen Wissens gezielt nachfragen,...mit anderen Darstellungen der Realität oder anderen früheren Einlassungen konfrontieren, Korrekturen ermöglichen.»; WAGNER/KRANICH, S. 9 «Eine Besonderheit stellt die Verfahrensweise mit unrealistischen Angaben dar. Hierbei gebietet es ein transparenter und fairer Umgang mit dem Klienten, durch Rückmeldungen widerzuspiegeln, wie man seine Äußerungen bewertet. Dadurch erhält der Betroffene die Chance, seine Aussagen zu korrigieren. Der Psychologe ermuntert den Betroffenen zur Korrektur, Ergänzung und Präzisierung der Angaben.»

bb) *Katalysatoren für allgemeinen Kooperationsdruck*

- 328 Die voranstehend erwähnten Pressionen auf den Kooperationsentscheid können weiter durch den allfällig vorhandenen Ermittlungseifer des Sachverständigen verstärkt werden. Zwar wird im forensisch-psychiatrischen Schrifttum betont, dass es zu vermeiden sei, in die Rolle eines Vernehmungsbeamten zu geraten; ein solches Verhalten wäre folglich als Kunstfehler zu werten.⁸⁸⁷ Trotzdem wird in der Verfahrensrealität von PSY-Sachverständigen berichtet, welche in Überschreitung ihrer Rolle einen Strafverfolgungseifer entwickeln und danach streben, die beschuldigte Person zu überführen.⁸⁸⁸ Dieser Eifer kann sich in einer entsprechenden Hartnäckigkeit, die Informationen in der Exploration zu Tage zu fördern, manifestieren.
- 329 Dieser Kooperationsdruck auf die beschuldigte Person kann auch durch medizinische Überlegungen seitens des Sachverständigen befördert werden. So existieren Voten, gemäss welchen es in begründeten Situationen sinnvoll sein soll, der beschuldigten Person zum Geständnis zu «verhelfen».⁸⁸⁹ Solche Extrempositionen bilden zwar Einzelstimmen in der forensischen Psychiatrie. Nichtsdestotrotz wird selbst bei namhaften Autoren eine systematische Kooperationsneigung erkennbar. So wird trotz grundsätzlicher Anerkennung von *nemo tenetur* dafür gehalten, dass Schweigen in der Exploration Silber, bedachtes Reden aber Gold sei.⁸⁹⁰ Es wird der sozial verantwortungsvolle Verteidiger herbeigewünscht, der seinem Mandanten dabei hilft, sich seiner sozialen Verantwortung (aus der Tat) und seiner Schuld zu stellen.⁸⁹¹ Andere halten dafür, dass die Abnahme eines Geständnisses zwar nicht Aufgabe des Sachverständigen sei, es für die beschuldigte Person aber eine Hilfe und Entlastung sein könne, sich dem Psychiater als neutrale und sachkundige Person zu öffnen und reinen Tisch zu machen.⁸⁹² Gerade in solchen Stellungnahmen zeigt sich, dass das ärztliche Rollenverständnis selbst bei grundsätzlicher Akzeptanz von Verfahrensrechten (*nemo tenetur*) durchschlägt und der Sachverständige tendenziell dazu neigt, dem Exploranden zu einer besseren Entwicklung seiner Persönlichkeit zu «verhelfen», d.h. ihm zur Kooperation zu raten.⁸⁹³

⁸⁸⁷ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 27; EGG, S. 245; GERSTENFELD, S. 285 und 287; HOFF, Psychiatrie, S. 165; MÜLLER/NEDOPIL, S. 414; KONRAD/RASCH, S. 328; KRÖBER, Angeklagte, S. 35; SCHMID, Diss., S. 500; TONDORF/TONDORF, N 282.

⁸⁸⁸ DIPPEL, Diss., S. 137; KONRAD/RASCH, S. 328; KRÖBER, FPPK 2015-A, 192 f.

⁸⁸⁹ MARNEROS, S. 359 ff.; ähnlich auch KIEGELAND, S. 141 im Kontext der verkehrsmedizinischen Begutachtung: «...sollte der Gutachten dem Kunden Hilfestellungen geben, das Schweigen zu brechen.»

⁸⁹⁰ KRÖBER, Angeklagte, S. 40 f.

⁸⁹¹ KRÖBER, FPPK 2015-B, S. 103.

⁸⁹² Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 27; MÜLLER/NEDOPIL, S. 414.

⁸⁹³ Idealtypisch hierzu: KRÖBER, FPPK 2015-B, S. 103 f.

Die geschilderten Aspekte sind darum so problematisch, weil gegen sie keine 330
effektive rechtliche Handhabe besteht. Der Sachverständige ist im Rahmen der
Exploration berechtigt (Art. 185 Abs. 4 StPO) und verpflichtet (Art. 307 StGB),
gutachtensrelevante fachspezifische Erhebungen zu tätigen und an die Strafbehör-
de zu berichten. Und zu den gutachtensrelevanten Informationen gehören
beim Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachten nun einmal das
Vorleben des Exploranden, seine Tat und die Zukunftsperspektiven.⁸⁹⁴ Ist dem
aber so, kann gegen Rollenüberschreitungen des Sachverständigen (wenn davon
strafprozessual überhaupt die Rede sein kann; er erledigt mit der Suche nach
solchen Informationen ja seinen Gutachtensauftrag) nicht effektiv vorgegangen
werden, denn seine Informationssammlung bewegt sich aufgrund des Gutach-
tenszusammenhangs in dem Rahmen, der ihm Art. 185 Abs. 4 StPO vorgibt.

b) Verletzlichkeit des Exploranden

Aus den vorangehenden Ausführungen geht hervor, dass bereits die Rahmenbedin- 331
gungen der Exploration sowie die Person des Sachverständigen substantiellen
Druck auf den Kooperationsentscheid des Exploranden ausüben.⁸⁹⁵ Dies wirkt in
einem nächsten Schritt die Frage auf, welche konkreten Widerstandskräfte die
beschuldigte Person entgegensetzen kann. In diesem Zusammenhang ist daran
zu erinnern, dass der EGMR die Vorverlagerung des Rechts auf Verteidigerbeizug
auf die Einvernahmen im Vorverfahren auch damit begründete, dass die
beschuldigte Person in diesem Verfahrensstadium besonders verletzlich ist
(Komplexität der Rechtslage, Stresssituation).⁸⁹⁶ Es wird sich zeigen, dass sich
diese besondere Verletzlichkeit der beschuldigten Person auch im Explorations-
kontext manifestiert.

aa) Allgemeine Verletzlichkeit

Die Exploration stellt für die beschuldigte Person ein hochkomplexes Gebilde 332
dar.⁸⁹⁷ Bereits für die gutachterlichen Fragen zur Schuldfähigkeit oder Mass-
nahmenindikation kann die beschuldigte Person als Laie nur schwer abschätzen,
welche Antworten wann opportun sind. Zusätzlich ist die beweisrechtliche Dop-
pelrelevanz dieses Erhebungsvorgangs zu bedenken: Zwar dient die Exploration
in erster Linie der Ermittlung der Beweisfragen der Schuldfähigkeit und/oder
Massnahmenindikation, sie kann aber auch auf den Tatnachweis oder die Straf-
zumessung rückwirken.⁸⁹⁸ In diesem Setting kann die Frage, ob und in welchem

⁸⁹⁴ Vgl. N 12 ff.

⁸⁹⁵ Vgl. N 325 ff.

⁸⁹⁶ Vgl. N 287 ff.

⁸⁹⁷ FOERSTER/FOERSTER, S. 1007 beschreiben die Exploration zurecht als emotional
und kognitiv höchst anspruchsvolle Situation.

⁸⁹⁸ Vgl. N 318 ff.

Rahmen eine Mitwirkung in der Exploration angebracht ist, von der beschuldigten Person kaum selbständig beantwortet werden.

- 333 Diese Faktoren und die durch sie bewirkte Komplexität der Rechtslage vermögen bereits eine Person zu überwältigen, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte ist. Im Kontext eines Schuldfähigkeits- oder Massnahmengutachtens sind die Ausgangsvariablen in aller Regel noch herausfordernder. Die beschuldigte Person steht in der Exploration unter grossem Druck. Auf dem Spiel steht beim Schuldfähigkeitsgutachten nicht weniger als der Verzicht (Schuldunfähigkeit; Art. 19 Abs. 1 StGB) auf eine Strafe oder deren substantielle Reduktion (verminderte Schuldfähigkeit; Art. 19 Abs. 2 StGB). Im massnahmenrechtlichen Kontext drohen potenziell schuldüberschreitende Sanktionen. Aufgrund der Ausführungen des 3. Teils ist klar, dass die gutachterliche Beurteilung der entscheidende Verfahrensschritt für diese Beweisfragen darstellt.⁸⁹⁹ Diese Ausgangslage bringt für den Exploranden beträchtliche Stressmomente mit sich, da ihm nur allzu bewusst ist, dass es in der Exploration um viel geht. Darüber hinaus wird sich der Explorand generell der Machtasymmetrie zwischen ihm und dem Gutachter bewusst und infolge des bisherigen Strafverfahrens psychisch angeschlagen sein.⁹⁰⁰ Ruft man sich diese Faktoren ins Bewusstsein, muss man daher von einer allgemeinen Verletzlichkeit der beschuldigten Person ausgegangen werden, welche keine geringere als bei den strafbehördlichen Einvernahmen im Vorverfahren ist.

bb) *Besondere Verletzlichkeit*

- 334 Bei einem Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachten dürfte die Verletzlichkeit der Exploranden noch einmal gesteigert ausfallen. Sowohl das Konzept der Schuldfähigkeit als auch das Massnahmenrecht nach Art. 56 ff. StGB knüpfen an psychische Sonderzustände an. Entsprechend wird sich die Regel formulieren lassen, wonach im Massnahmen- und Schuldkontext Personen exploriert werden, welche entweder psychisch gestört sind oder zumindest nicht optimale psychische Ressourcen aufweisen.⁹⁰¹ Gerade dieser Gruppe von Menschen wird es in aller Regel nur unzureichend möglich sein, sämtliche Konsequenzen des Begutachtungsvorgangs abzuschätzen und das Explorations- und Aussageverhalten entsprechend zu planen und zu steuern.⁹⁰² Damit muss eine

⁸⁹⁹ Vgl. N 162.

⁹⁰⁰ BERNHARD/BINDER, S. 13; zum allgemeinen Einfluss des Strafverfahrens als Stressfaktor auch BERNHARD, fp S0/2014, S. 8; BERNHARD, Jusletter 13. Februar 2012, N 40; zur Exploration als machtasymmetrisches Gespräch auch KIEGELAND, S. 83 und 93.

⁹⁰¹ GRAF, Missbrauch, S. 146; LANDE, S. 54; sodann N 202.

⁹⁰² GRAF, Missbrauch, S. 146.

zusätzliche, besondere Verletzlichkeit der beschuldigten Person im Explorationskontext festgestellt werden.

F) Potenzielle Verkennung der Sachverständigenrolle durch die beschuldigte Person (Täuschungselement)

Über die voranstehenden Aspekte hinaus weist die Exploration auch Charakteristiken auf, welche im Kontext dem Kreis der Täuschung zuzurechnen sind. Wie aufgezeigt wurde, kann sich auch daraus ein unzulässiger Zwang auf nemo tenetur ergeben.⁹⁰³ Das Täuschungselement ergibt sich aus der Tatsache, dass die Exploration in einem Spannungsverhältnis zwischen Erscheinungsbild und prozessualer Wirklichkeit steht. So findet das Gespräch mit dem Sachverständigen in Übereinstimmung mit medizinisch-psychiatrischen Massstäben statt (keine Anwesenheit von Dritten, empathisches Zuhören des Sachverständigen, Beziehungsaufbau usw.), was eine Vertraulichkeit des Gesprächs (Schweigepflicht) impliziert.⁹⁰⁴ Rechtlich ist jedoch klar, dass die sachverständige Person verpflichtet ist (Art. 307 StGB), die zur Kenntnis genommenen gutachtensrelevanten Tatsachen an die Strafbehörde zu kommunizieren.⁹⁰⁵ 335

Nun könnte man argumentieren, dass mit der Belehrung der beschuldigten Person über die Rolle des Sachverständigen und ihrer Offenbarungspflicht gegenüber den Strafbehörden (Art. 185 Abs. 5 StPO) dem Täuschungsverbot Genüge getan wird.⁹⁰⁶ Diese Argumentation scheint auf den ersten Blick schlüssig: Wenn die beschuldigte Person über die Rolle des Sachverständigen informiert ist, ist ihr Vertrauen in eine allfällige Vertraulichkeit des Gesprächs theoretisch zerstört. Allerdings drängt sich auf der Faktenebene eine differenzierte Betrachtung auf. Zwar ist den Strafbehörden und der sachverständigen Person bei einem 336

⁹⁰³ Vgl. N 293; BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 39.

⁹⁰⁴ BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 39; KRAUSS, ZStW 1985, S. 84 f.: «Er [gemeint: der Explorand] sieht seine Erwartungen zu einem guten Teil bestätigt. Die Untersuchung des Sachverständigen folgt tatsächlich weitgehend den Gesetzen ärztlicher Heilkunst. Vor allem versetzt sie ihn in einen Status, in dem er sich gegenüber ärztlicher Autorität als Leidender und Patient fühlen und geben darf. Dabei treten Mißtrauen und Verteidigungsbereitschaft gegenüber staatlicher Ausforschung zurück hinter das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Hilfsbereitschaft einer neutralen Instanz, von der man nicht glauben kann, daß sie sich als «Büttel der Polizei» erweisen könnte.»; auch HOFF, Psychiatrie, S. 165 f. räumt ein, dass durch die spezielle Situation (Wahrnehmung des Gutachters als Fachperson, Fachperson ist nicht unmittelbarer Bestandteil der Ermittlungsbehörde oder des Gerichts) ein Vertrauensverhältnis seitens des Exploranden gegenüber dem Sachverständigen entstehen kann.

⁹⁰⁵ OGER-ZH-FAKO, Leitfaden, S. 6; BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 13; HEER, Gutachten, S. 106; HOFF, Psychiatrie, S. 161; MAIER/MÖLLER, S. 167.

⁹⁰⁶ Zur Belehrungspflicht: N 309.

solchen Vorgehen in der Tat keine Täuschungsabsicht zu unterstellen. Gleichwohl können die systemischen Rahmenbedingungen der Exploration bei der beschuldigten Person trotz Belehrung täuschende Wirkung entfalten, was von fairnessrechtlicher Relevanz ist.

- 337 Konkret ist es (trotz Belehrung) möglich, dass die beschuldigte Person die verfahrensrechtliche Bedeutung der Exploration und die Rolle des Sachverständigen erkennt.⁹⁰⁷ In einer Studie konnte dargelegt werden, dass rund zwei Drittel der Exploranden konkrete Bedürfnisse äusserten, sich über ihre Sorgen und Probleme gegenüber dem Sachverständigen auszulassen und immerhin 60% versprachen sich von ihm therapeutische Hilfe.⁹⁰⁸ Es ist somit nur allzu schnell geschehen, dass die beschuldigte Person die prozessuale Rolle des Sachverständigen vergisst und davon ausgeht, ihr sitze der schweigegebundene Arzt und nicht der offenbarungsverpflichtete Sachverständige gegenüber, dem sie sich anvertrauen kann.⁹⁰⁹
- 338 Entsprechend überrascht es nicht, dass sich viele Begutachtete kooperativ verhalten und sich dem Gutachter ohne Vorbehalte anvertrauen.⁹¹⁰ Damit ist die Gefahr nicht fern, dass die beschuldigte Person in der Exploration weitergehende Angaben als gegenüber der Strafbehörde macht, selbst wenn sie vor dem Explorationsgespräch von der Verteidigung zum Schweigen bezüglich des Tatvorwurfs beraten wurde.⁹¹¹ Dass sich eine solche Gesprächsdynamik entwickeln kann, überrascht kaum. Die «prozessferne Atmosphäre der Exploration»⁹¹² fördert den Kooperationswillen des Exploranden. Der Sachverständige hat Zeit für die beschuldigte Person, interessiert sich nicht nur für die Tat, sondern für sie als Person und zeigt, dass sie «etwas von ihm verstanden» hat.⁹¹³ Dass die beschul-

⁹⁰⁷ BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 39; FOERSTER/FOERSTER, S. 1018; HOFF, Psychiatrie, S. 165 f.; KRAUSS, ZStW 1985, S. 84 f.

⁹⁰⁸ LITTMANN, S. 88.

⁹⁰⁹ FONJALLAZ/GASSER, S. 127; FINCKE, ZStW 1974, S. 657; FOERSTER/FOERSTER, S. 1018; HOFF, Psychiatrie, S. 160 f.; KRAUSS, ZStW 1985, S. 84 f.; NEDOPIL, NStZ 1999, S. 437; SCHMID, AJP 2010, S. 832; US Court of Appeals, District of Columbia Circuit, United States v. Byers, 740 F2d 1104, Dissent Bazelon, N 155.

⁹¹⁰ BROWN, S. 90; KONRAD/RASCH, S. 313.

⁹¹¹ BERNHARD, fp S0/2014, S. 18; HOFF, Psychiatrie, S. 161; MAIER/MÖLLER, S. 166; KRÖBER, Angeklagte, S. 37.

⁹¹² FINCKE, ZStW 1974, S. 657 f.

⁹¹³ KRÖBER, Angeklagte, S. 37; MÜLLER/NEDOPIL, S. 413: «Wird das Gespräch über weniger Belastendes, wie Lebenslauf oder Vorerkrankungen, an den Anfang gestellt, erhält der Proband die Gelegenheit, Untersuchungssituation und Gutachter ein wenig kennenzulernen und einzuschätzen. Der Untersucher signalisiert, dass er in erster Linie am Probanden und nicht an einer eventuellen Verurteilung interessiert ist...Bei einem solchen Vorgehen fällt es den meisten Probanden auch leichter, über den Anlass der Begutachtung zu sprechen und ihre subjektive Sicht darzulegen. Durch das Hintanstellen einer Tatexploration unterscheidet sich der Psychiater

digte Person unter diesen ärztlich-therapeutisch anmutenden Bedingungen latent gefährdet ist, die strafprozessuale Rolle des Sachverständigen zu vergessen, scheint daher nur allzu verständlich. Damit sind allerdings Bedingungen geschaffen, die geeignet sind, den freien (aufgeklärten) Kooperationsentscheid der beschuldigten Person zu untergraben.

2. Schutz vor ungesetzlichem Verhalten des Sachverständigen

Neben den Tangenten zu *nemo tenetur* ist zu bedenken, dass das konventionsrechtlich gebotene Recht auf Verteidigerbeizug anlässlich der strafbehördlichen Einvernahme auch auf die Überlegung gestützt wird, dass dadurch die beschuldigte Person vor ungesetzlichem Verhalten seitens der Strafbehörden geschützt werden kann; sei dies durch die präventiv wirkende passive Präsenz der Verteidigung, sei dies durch eine aktiv-schützende Intervention derselben.⁹¹⁴ Diese Erwägungen lassen sich vollständig auf die psychiatrische Exploration übertragen: Bereits im 3. Teil wurde aufgezeigt, dass sich in der Exploration Verhaltensweisen des Sachverständigen manifestieren können, welche im Widerspruch zu Art. 140 StPO oder dem Verbot der Suggestivbefragung stehen oder welche potenziell ausstandsbegründend sind.⁹¹⁵ Entsprechend drängt es sich auf, dieselben verfahrensrechtlichen Schutzmechanismen zu implementieren, wozu im Rahmen von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK auf das Recht auf Beizug einer Verteidigung gehört.

339

3. Determinierende Relevanz der gutachterlichen Erhebungen für das gerichtliche Verfahren

Zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die Vorverlagerung des Rechts auf Verteidigerbeizug vom EGMR auch darum vollzogen wird, weil er sich der entscheidenden Relevanz der Einvernahmen im Vorverfahren für das gerichtliche Verfahren bewusst ist.⁹¹⁶ Das Explorationsgespräch zwischen Sachverständigem und beschuldigter Person weist diese Eigenschaft in keinem minderen Masse auf. In der Exploration erhebt (Art. 185 Abs. 4 StPO) und beurteilt der PSY-Sachverständige die Beweisfragen der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation kraft seiner Sachkunde quasi-verbindlich für die übrigen Verfahrensbeteiligten und tangiert dabei selbst die Rechtsanwendung in nicht zu unterschätzen-

340

zudem von den Ermittlungsorganen.»; zur öffnenden Wirkung des empathischen Zuhörens auch BROWN, S. 90.

⁹¹⁴ Vgl. N 287 ff.

⁹¹⁵ Vgl. N 169 ff.

⁹¹⁶ Vgl. N 287.

dem Masse.⁹¹⁷ Dabei dürfen die von ihm erhobenen Informationen bei entsprechender Belehrung (Art. 185 Abs. 5 StPO) im Verfahren verwertet werden.⁹¹⁸ Gleichzeitig können die von ihm rapportierten Explorationsangaben der beschuldigten Person nur schwer angegriffen werden, da ein systemimmanentes Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten der Schilderungen des nominal neutralen Sachverständigen besteht.⁹¹⁹ Darüber hinaus beschränkt sich die beweisrechtliche Relevanz der Exploration nach geltender Praxis nicht auf die Gutachtensfragen der Schuldfähigkeit oder Massnahmenindikation, sondern kann auch für den Tatnachweis oder die Strafzumessung Bedeutung erlangen.⁹²⁰ Vor diesem Hintergrund lässt sich kaum bestreiten, dass die gutachterliche Erhebung in der Exploration determinierenden Charakter für das gerichtliche Verfahren aufweist.

4. Zwischenfazit

- 341 Aus den voranstehend referierten Erkenntnissen geht die materielle Kongruenz zwischen Einvernahme und Exploration hervor. Durch die Exploration werden von der beschuldigten Person zahlreiche Informationen erhoben, welche dem Schutz von *nemo tenetur* unterstehen; namentlich Aussagen der beschuldigten Person und gleichgelagerte, willensabhängige Kommunikationsinhalte. Diese können – sofern eine Belehrung nach Art. 185 Abs. 5 StPO stattgefunden hat – im Verfahren vom Gericht verwertet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die beschuldigte Person sich durch solche Angaben sowohl retrospektiv (Tat, Schuldfähigkeit, Strafzumessung) als auch prospektiv (Massnahmenindikation) selbst belasten kann und entsprechend ein grosses Interesse an einer optimalen Aussage- bzw. Mitwirkungsstrategie aufweist. Allerdings ist die beschuldigte Person nur unzureichend in der Lage, einen aufgeklärten und frei von psychischem Zwang erfolgenden Entscheid für oder wider die Kooperation mit dem Sachverständigen zu fällen. Sie sieht sich mit dem Informationsinteresse des Sachverständigen konfrontiert, der sie mit seiner Gesprächstechnik zu öffnen versteht. Die beschuldigte Person kann dem nur begrenzten Widerstand entgegensetzen: Angeschlagen vom Strafverfahren, ohne strafprozessuales Fachwissen (welche Mitwirkung ist opportun? Welche nicht?), gestresst von den drohenden Konsequenzen einer negativen Begutachtung und regelmässig unter der Last von psychopathologischen Symptomen sind ihre Defensivressourcen beschränkt. Diese Ausgangslage wird weiter dadurch verschärft, dass die Rolle des psychiatrischen Sachverständigen nicht einfach zu fassen ist. Damit besteht die Gefahr, dass die beschuldigte Person im Gespräch die Rolle des Sachverständi-

⁹¹⁷ Vgl. N 162.

⁹¹⁸ Vgl. N 310 ff.

⁹¹⁹ Vgl. N 205 ff.

⁹²⁰ Vgl. N 318 ff.

gen erkennt und weitergehende Angaben macht, als sie dies gegenüber den Strafbehörden getan hätte.⁹²¹

Bereits mit diesen Ausführungen ist die Kongruenzthese (Einvernahme = Exploration) ausreichend belegt. Hinzu kommt, dass die beschuldigte Person in der Exploration dieselben Schutzbedürfnisse hinsichtlich eines ungesetzlichen Verhaltens des Sachverständigen wie bei einer strafbehördlichen Einvernahme aufweist und solches Verhalten durch eine Intervention der Verteidigung unterbunden haben möchte.⁹²² Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die sachverständigen Erhebungen für das Sachurteil determinierende Bedeutung aufweisen. Dies stimmt unbestritten für die Fragen der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation. Aber selbst für die Frage des Tatnachweises und der Strafzumessung können die gutachterlichen Erhebungen Bedeutung entfalten.⁹²³ In einer Gesamtschau bestehen damit in einer Exploration mindestens dieselben verteidigungsrechtlichen Herausforderungen wie in einer strafbehördlichen Einvernahme im Vorverfahren. 342

Sind die Rahmenbedingungen zwischen Einvernahme im Vorverfahren und Exploration aber materiell kongruent, muss das eingangs erwähnte Leitbild (Exploration ist keine Einvernahme⁹²⁴) mit Blick auf die verfahrensrechtliche Realität verworfen werden. Vielmehr ist es gerechtfertigt, die Rechtsprechungslinie des EGMR zum Recht auf Beizug einer Verteidigung bei der Einvernahme im Vorverfahren auf das Explorationsgespräch des PSY-Sachverständigen zu übertragen.⁹²⁵ Das Recht auf Beizug einer Verteidigung ist daher mit all seinen Facetten – insbesondere auch dem Teilnahmerecht der Verteidigung – grundsätzlich auf das Explorationsgespräch des Sachverständigen anwendbar, um die Waffengleichheit im Explorationskontext herzustellen. 343

III. PSY-Methodenstandard als (potenzieller) Einschränkungsgrund

Im vorhergehenden Abschnitt wurde hergeleitet, dass ein grundsätzliches Recht der beschuldigten Person auf freien Verkehr mit der Verteidigung sowie ein Teilnahmerecht der Verteidigung an der Exploration besteht. In einem nächsten Schritt gilt es zu prüfen, ob zwingende Gründe bestehen, welche eine Einschränkung dieses Rechts legitimieren. 344

⁹²¹ Vgl. N 305 ff.

⁹²² Vgl. N 339.

⁹²³ Vgl. N 340.

⁹²⁴ Vgl. N 301 f.

⁹²⁵ Vgl. N 285 ff.

1. Methodenstandard: Drittpersonenausschluss

345 Bereits in der Einleitung dieser Arbeit wurde dargelegt, dass das Explorationsgespräch des PSY-Sachverständigen als ungestörtes Gespräch unter vier Augen konzipiert ist und die Anwesenheit von Drittpersonen als tendenziell kontraproduktiv bewertet wird. Zentral ist dabei die Annahme, dass die Drittpersonenanwesenheit den untersuchungsnotwendigen Beziehungsaufbau zwischen Exploranden und Sachverständigem (Vertrauensbeziehung) stört und dem Explorationsgespräch den Charakter einer Einvernahme aufdrückt. Entsprechend soll die Frage, ob eine Drittperson zur Exploration zugelassen wird, im Ermessen des Sachverständigen stehen. Wird eine Drittperson gleichwohl zugelassen, gilt als Minimalkonsens, dass diese bei der Exploration schweigen muss, d.h. nicht intervenieren darf. In der strafprozessualen Praxis erfolgt die Exploration im Lichte dieser Prinzipien überwiegend als Vier-Augen-Gespräch zwischen sachverständiger und beschuldigter Person. Wenn die Teilnahme der Verteidigung ausnahmsweise zugelassen wird, hat diese während der Begutachtung zu schweigen.⁹²⁶

346 Nun ist durch die Ausführungen des 2. Teils bekannt, dass diese psychiatrische Methodenvorgabe geschützt und nach schweizerischen Recht ein Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch in Abrede gestellt wird.⁹²⁷ Dies stellt nach den Erkenntnissen des vorangehenden Abschnitts eine Einschränkung des Rechts nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK dar. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine Eigenart des schweizerischen Rechts. Vielmehr zeigt ein Blick über die Landesgrenzen hinaus, dass der Schutz des psychiatrischen Methodenstandards im Rahmen der Exploration in diversen Rechtsordnungen zu finden ist und es dem Sachverständigen somit frei steht zu entscheiden, ob er Drittpersonen zulässt oder nicht.⁹²⁸ Der internationale Verbreitungsgrad dieses Einschränkungsg-

⁹²⁶ Für den gesamten Abschnitt: N 19 f.

⁹²⁷ Vgl. N 43 ff.

⁹²⁸ Deutschland: BGH, 8. August 2002, 3 StR 239/02, N 3 (dazu die Anmerkung von BARTON, StV 2003, S. 537 ff.); bestätigt in BGH, 12. September 2007, 1 StR 407/07, N 14; ebenso wird im Rahmen der laufenden Revisionsbestrebungen wohl kein Teilnahmerecht in die StPO-DE aufgenommen: BMJV, S. 15 und S. 33 ff.; kritisch dazu POLLÄHNE, Begutachtung, S. 42 ff. und SCHLOTHAUER, S. 65 f.; die Abwesenheit der Verteidigung in der Exploration ist auch der ausserstrafprozessuale Standard: OVG Lüneburg, 2. August 2016, 5 ME 103/16, N 13 f.; LSG Baden-Württemberg, 22. September 2016, L 7 R 2329/15, in: NZS 2016, S. 960; OVG Koblenz, Beschl. v. 11. 6. 2013 – 2 A 11071/12, in: NVwZ-RR 2013, S. 972 f.; OLG Köln, 30. Oktober 2009, 5 U 112/08, in: MedR 2010, S. 879; LSG Berlin-Brandenburg, 17. Februar 2010, L 31 R 1292/09 B, in: BeckRS 2010, 67412; LSG Niedersachsen-Bremen, 20. November 2009, L 2 R 516/09 B, E. 2; OLG Hamm, 4. Oktober 2010, 4 Ws 489, 490/06; Ausreisser in LSG Rheinland-Pfalz 23. Februar 2006, L 4 B 33/06 SB, N 7, in: NJW 2006, S. 1547 f.; und OLG-Hamm, 3. Februar

grunds ist aber für die Fairnessanalyse nicht von Bedeutung. Massgeblich ist einzig, ob die psychiatrische Methodik in konventionsrechtlicher Hinsicht einen zwingenden Grund zum Ausschluss der Verteidigung vom Explorationsgespräch darstellen könnte. Bei dieser Betrachtung darf es unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten einzig auf materielle Argumente und nicht den formellen Umstand eines hohen Verbreitungsgrads ankommen.

2. Legitimation des Einschränkungsgrunds

Der Ausschluss der Verteidigung muss sich im Rahmen der konventionsrechtlichen Prüfung zweierlei Massstäben stellen. Erstens muss der zwingende Grund sachlich haltbar sein, d.h. die öffentlichen Interessen müssen durch die in Frage stehende Einschränkung tatsächlich realisiert werden können (A.). Sodann muss ein sachlicher Grund von einem gewissen Gewicht sein, d.h. die öffentlichen Interessen müssen so stark ausfallen, dass sich eine Einschränkung des Rechts nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK rechtfertigt (B.). Nachfolgend wird sich zeigen, dass der psychiatrische Methodenstandard keinem dieser zwei Massstäbe genügt.

347

A) (In)stabilität der Prämisse: «Verteidigung als Störfaktor»

Der Methodenstandard der Psychiatrie fusst im Kern auf der Befürchtung, dass anwesende Drittpersonen den Ablauf der Exploration stören könnten. Zur Prüfung der Tragfähigkeit dieser These gilt es zwei Formen der Verteidigerteilnahme zu differenzieren: Die passive Präsenz der Verteidigung als Beobachterin der Exploration und ihre aktive Präsenz als Interessenwahrerin ihres Mandanten,

348

2015, 14 UF 135/14, N 3 ff.; Frankreich: Art. 164 Abs. 4 StPO-FRA gilt: «Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.» und die korrespondierende Rechtsprechung in Cour de Cassation, 9. April 1991, 91-80614, in: Bulletin criminel 1991 N° 169 S. 432; Cour de Cassation, 6. September 1993, 93-82861, in: Bulletin criminel 1993 N° 261 S. 661; AZIBERT, Art. 164 N 5; Italien: CSdCass, 11. Juli 2002, n. 35187, in: Cass. pen 2004, S. 593; USA: United States Supreme Court, 18. Mai 1981, Estelle v. Smith, 451 U.S. 474 (Fn 14) was im Schrifttum als obiter dictum gegen ein Teilnahmerecht der Verteidigung interpretiert wurde: MELTON ET AL., S. 78; SHEALY/PIRELLI/CRAMER, S. 561; SIEGEL/KINSCHERFF, S. 376; diese Auffassung wird überwiegend auch von unteren Instanzen geteilt, welche ein Teilnahmerecht der Verteidigung an der Exploration überwiegend verneinen, vgl. die zitierte Gerichtspraxis bei CRAMER/BRODSKY, S. 54 ff.; KALMBACH/LYONS, S. 271; PICHINI, S. 144 f; MELTON ET AL., S. 78; SIEGEL/KINSCHERFF, S. 376; SMITH, S. 449; US Court of Appeals, District of Columbia Circuit, United States v. Byers, 740 F2d 1104.

welche mit Interventionen (Rüge von Verfahrensverletzungen, Rat zum Schweigen) einhergeht. Während bei der ersten Fallgruppe zu analysieren ist, ob die Störungsbefürchtung überhaupt zutrifft, wird bei der zweiten Fallgruppe hinterfragt werden, ob die «Störung» qua Intervention der Verteidigung als legitimer Grund für einen Ausschluss der Verteidigung beigezogen werden kann.

a) Störwirkung bei passiver Präsenz der Verteidigung

349 In einem ersten Schritt gilt es zu prüfen, ob die passive Präsenz der Verteidigung (Beobachterstellung) als Störfaktor im Explorationsgeschehen einzustufen ist. Ganz allgemein ist in diesem Kontext die Frage aufzuwerfen, ob der forensisch-psychiatrische Fokus auf die Herstellung einer vertrauensvollen Explorationsatmosphäre systematisch gerechtfertigt werden kann. Das Explorationsgespräch erfolgt ohne Schweigepflicht des Sachverständigen und ist nicht therapeutischer, sondern strafprozessual-ermittelnder Natur.⁹²⁹ Entsprechend scheint es nicht konsistent, einen methodischen Standard, der im therapeutischen Kontext entwickelt wurde (Vier-Augen-Gespräch unter Schweigepflicht = Vertrauensverhältnis)⁹³⁰ unbesehen auf den forensischen Kontext zu übertragen, wenn dessen Bedingungen gerade anders liegen: Es existiert in der forensischen Exploration mangels Schweigepflicht des Sachverständigen schlicht kein Vertrauensverhältnis, das zu schützen wäre.⁹³¹

350 Doch selbst wenn man von diesem Gesichtspunkt absieht, gibt es gute Gründe, an der inhaltlichen Stabilität der Störungsthese zu zweifeln. Zwar soll nicht bestritten werden, dass die Anwesenheit einer Drittperson einen Einfluss auf das Explorationsgespräch hat. Dieser Einfluss kann allerdings sowohl positiv als auch negativ sein.⁹³² Die Annahme eines negativen Effekts ist dabei nicht so evident, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Bereits im psychiatrisch-psychologischen Schrifttum wurde verschiedentlich dazu aufgerufen, die Solidität des psychiatrischen Methodenstandards bzgl. Drittpersonenausschluss für das Explorationsgespräch näher zu untersuchen.⁹³³ Diese Aufrufe sind bis zum heutigen Tag fruchtlos geblieben. Es fehlen empirische Untersuchungen zur Frage, ob und auf welche Weise die Teilnahme der Verteidigung am Explorationsgespräch des Sachverständigen mit der beschuldigten Person die Explorationsqua-

⁹²⁹ KALMBACH/LYONS, S. 261.

⁹³⁰ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 17.

⁹³¹ AAPL TASK FORCE, S. 3: «Forensic evaluations, unlike therapeutic ones begin with adversarial tensions.»; HEER/COVACI, S. 444; GOLDSTEIN, American Journal of Psychiatry 1988, S. 1246; HEER, Feigenblatt, 29 f.; SANER, S. 132.

⁹³² OTTO/KRAUS, S. 364 und 367.

⁹³³ BROWN, S. 91; CRAMER/BRODSKY, S. 59; OTTO/KRAUS, S. 367; SHEALY/PIRELLI/CRAMER, S. 561.

lität beeinflussen würde.⁹³⁴ Zwar konnten für neuropsychologische Untersuchungen bei der Anwesenheit von Drittpersonen negative Effekte bezüglich der kognitiven Fähigkeiten festgestellt werden.⁹³⁵ Allerdings warnen sämtliche dieser Studien vor der unbesehenen Übertragung der Ergebnisse auf den forensischen Kontext bzw. das Explorationsgespräch.⁹³⁶ Es gilt daher zu konstatieren: Der Methodenstandard des Drittpersonenausschlusses im Explorationsgespräch ist nicht empirisch abgesichert, sondern stellt «nur» eine klinisch gestützte Aussage dar.⁹³⁷

Die Störungsthese ist jedoch instabil. Mit ihrer uneingeschränkten Geltung wäre beispielsweise die Praxis von Sachverständigen, von ihnen beigezogene Hilfspersonen (sei es im Rahmen der Ausbildung und/oder als Assistenz) an der Exploration teilnehmen zu lassen, nur schwer vereinbar, wenn man sich nicht in die Argumentation versteigen möchte, dass eine Hilfsperson aufgrund ihrer psychiatrisch-psychologischen Ausbildung besser als der Laie weiss, auf welche Art und Weise der passiven Präsenz man das Explorationsgeschehen nicht stört.⁹³⁸ Ebenso wäre nur schwer zu erklären, warum bei der aktiven Anwesenheit eines Übersetzers eine methodenkonforme Exploration noch erfolgen kann⁹³⁹, bei der passiven Anwesenheit der Verteidigung aber eine methodenwidrige Störung zu befürchten ist. Plausibler ist ohnehin die Annahme, dass bestehende Ängste bzw. das Misstrauen des Exploranden, alleine mit dem Sachverständigen zu Werke gehen zu müssen, durch die Anwesenheit seiner Verteidigung abgebaut werden und er bereit ist, sich weitergehend zu öffnen.⁹⁴⁰ Diese Annahme wird auch durch die Tatsache gestützt, dass die Teilnahme der Verteidigung am Explorationsgespräch in der Praxis von einigen Sachverständigen im Einzelfall

⁹³⁴ ARONSON, S. 91; BMJV, S. 34; GOLDSTEIN, American Journal of Psychiatry 1988, S. 1244; SHEALY/PIRELLI/CRAMER, S. 562.

⁹³⁵ CRAMER/BRODSKY, S. 52 ff.; HORWITZ/MCCAFFREY, S. 415; HOWE/MCCAFFREY, S. 518 ff.; MOREL, S. 638 f.; SHEALY/PIRELLI/CRAMER, S. 561.

⁹³⁶ CRAMER/BRODSKY, S. 54; zum Übertragbarkeitsproblem bereits GOLDSTEIN, American Journal of Psychiatry 1988, S. 1246.

⁹³⁷ Dabei ist zu berücksichtigen, dass Meinungen und Überzeugungen aus klinischer Erfahrung nach wissenschaftlichen Kriterien die tiefste Evidenz-Kategorie bilden: GRAF, «Justice - Justiz - Giustizia» 4/2015, N 8.

⁹³⁸ Siehe das Beispiel in BGE 144 IV 176, E. 4.4: «Untersuchungen des Beschwerdeführers von insgesamt 4,75 Stunden, bei welchen der rechtsunterzeichnende Sachverständige eine halbe Stunde ebenfalls [d.h. zusätzlich zur Hilfsperson] anwesend gewesen sei.»

⁹³⁹ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 19 f.

⁹⁴⁰ BROWN, S. 88 f.; CRAMER/BRODSKY, S. 54; EDITORS, S. 456; GOCKER, S. 637; HEER, FS Wiprächtiger, S. 202; MEISTER, S. 446; MELTON ET AL., S. 79; OTTO/KRAUS, S. 364; PICHINI, S. 164; RACHLIN/SCHWARTZ, S. 1013; SIMON, S. 11.

durchaus zugelassen wird⁹⁴¹ und von diesen Verfahren nicht zu vernehmen war, dass die Exploration unter diesen Bedingungen nicht mehr durchgeführt werden konnte. Wollte man diese Überlegungen zuspitzen, könnte man sagen, dass es nicht um eine objektive Störung geht, sondern darum, ob sich der individuelle Sachverständige bei der Anwesenheit der Verteidigung wohl fühlt oder nicht.⁹⁴² Vor diesem Hintergrund kann die Störungsthese beim passiv anwesenden Verteidiger kaum aufrechterhalten werden, zumal selbst beim Zutreffen der Störungsthese zu begründen wäre, warum der Sachverständige andere gewichtigere Störfaktoren (Simulation, Aggravation, Dissimulation usw.) seitens des Exploranden ohne weiteres in seiner Beurteilung berücksichtigen kann, aber selbiges für die nicht erwünschte passiv anwesende Drittperson nicht möglich ist.⁹⁴³

b) *Störwirkung bei aktiver Intervention der Verteidigung*

- 352 Anders liegen die Bedingungen, wenn die Verteidigung nicht nur passiv an der Exploration teilnimmt (Beobachterstellung), sondern aktiv im Explorationsgeschehen interveniert. Es wurde in den allgemeinen Ausführungen zu Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK aufgezeigt, dass konventionsrechtlich eine aktive Verteidigung gefordert wird, welche auch während der Einvernahme intervenieren darf und soll.⁹⁴⁴ Schlüpft die Verteidigung in der Exploration in diese aktive Rolle, d.h. rät sie der beschuldigten Person zum Schweigen, beantragt sie eine kurze Unterbrechung der Exploration zwecks Besprechung mit ihrem Mandanten oder rügt sie Gesetzesverletzungen des Sachverständigen, kann eine «Störung» der Exploration nicht in Abrede gestellt werden.

⁹⁴¹ BARTON, StV 2003, S. 539; KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 193; praktische Beispiele einer Verteidigerteilnahme in den Verfahren BGer, 18. Oktober 2010, 6B_590/2010, E. 6.3 sowie KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/dd.

⁹⁴² Interessant die Studie von SHEALY/PIRELLI/CRAMER, S. 656 und 567, in der aufgezeigt werden konnte, dass Psychologen mit langjähriger Erfahrung und/oder Personen, welche bereits Begutachtungen unter Anwesenheit von Dritten durchgeführt hatten, positivere Einstellungen zum Konzept der Drittpersonenanwesenheit aufwiesen und dabei insbesondere der Verteidigeranwesenheit und ihrer Funktion als fairnesssichernder Aspekt bejahender gegenüberstanden; in dieselbe Richtung auch BROWN, S. 89, welche darauf hinweist, dass unerfahrene Gutachter eher Ängste und Unbehagen gegenüber Begleitpersonen in der Exploration aufweisen.

⁹⁴³ Die Anwesenheit einer Drittperson scheint eine geringere Gefahr für die Validität forensisch-psychiatrischer Aussagen zu sein, als diese sonstigen Störfaktoren. Dazu auch OTTO/KRAUS, S. 368

⁹⁴⁴ Vgl. N 291.

Allerdings ist auch dieser Umstand keine legitime Basis, um der Verteidigung die Teilnahme in der Exploration zu verweigern.⁹⁴⁵ Dies lässt sich sowohl durch Rekurs auf die allgemeine Schutzfunktion der Verteidigung als auch den Schutzgehalt von *nemo tenetur* begründen. Erfolgen beispielsweise Gesetzesverletzungen seitens des PSY-Sachverständigen (Suggestivfragen, Art. 140 StPO usw.), muss die Verteidigung dies rügen können. Es wäre widersprüchlich, das Interventionsrecht der Verteidigung mit der Begründung zu verbieten, die Verteidigung störe damit den Explorationsablauf. Dies würde darauf hinauslaufen, dass die Rechtsordnung ungesetzliches Explorationsverhalten seitens des Sachverständigen schützt. Dass dies nicht zulässig sein kann, dürfte ohne weitere Ausführungen klar sein. 353

Sofern die «Störung» der Verteidigung darin besteht, dass sie der beschuldigten Person zum Schweigen rät oder eine Unterbrechung der Exploration zwecks Beratung über die weitere Aussagestrategie verlangt, ist die Ausgangslage nicht minder klar. Die beschuldigte Person darf sich kraft *nemo tenetur* ohnehin der Aussage bzw. Mitwirkung in der Exploration verweigern (Art. 185 Abs. 5 StPO). Sie ist auch im Rahmen der Begutachtung «autonomes Subjekt einer wechselseitigen Kommunikation im Strafverfahren und nicht einfach nur Objekt einseitiger Betrachtung und Wahrnehmung».⁹⁴⁶ Mit ihrer Beratungstätigkeit oder einer allfälligen Intervention (z.B. Erinnerung an Schweigerecht) in der Exploration sichert die Verteidigung somit nur ab, was die beschuldigte Person sowieso tun darf: zu schweigen, wenn es verfahrensrechtlich Sinn macht.⁹⁴⁷ Es handelt sich auch bei der aktiven Verteidigerteilnahme damit nicht um eine Störung, sondern um die effektive Wahrnehmung bzw. Absicherung eines bestehenden Verteidigungsrechts (*nemo tenetur*, Art. 185 Abs. 5 StPO). 354

Im diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die beschuldigte Person auch ohne die anwesende Verteidigung berechtigt ist, dem Sachverständigen die Erlangung jeglicher Angaben unmöglich zu machen und ihn auf die Erstellung eines Aktengutachtens zurückwerfen könnte, indem sie schweigt und anderweitig nicht mitwirkt (Art. 185 Abs. 5 StPO).⁹⁴⁸ Solche Aktengutachten sind nur ausnahmsweise zulässig und stellen alles andere als den Goldstandard der psychiatrischen Wahrheitssuche dar.⁹⁴⁹ Wenn die Erstellung eines Aktengutachtens nach psychiatrischen Fachstandards nicht möglich ist, darf gemäss bundesge- 355

⁹⁴⁵ Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Gedankengang von HUBER, S. 269 f.

⁹⁴⁶ OBERHOLZER, Begutachtung, S. 49 f.; zum Zusammenhang von *nemo tenetur* mit der Wahrung der Subjektstellung der beschuldigten Person auch WOHLERS, FS Küper, S. 704 f.

⁹⁴⁷ Zu dieser Thematik auch ALBRECHT, Funktion, N 2.38.

⁹⁴⁸ Stellvertretend für eine solche Konstellation: BGer, 12. Januar 2018, 1B_533/2017, E. 4.3.1.

⁹⁴⁹ BGE 127 I 54, E. 2 f; KRÖBER, FPPK 2013, S. 303; MAIER/MÖLLER, S. 139.

richtlicher Rechtsprechung bei Mitwirkungsverweigerung sogar ganz auf die Einholung eines Gutachtens verzichtet werden.⁹⁵⁰ Wenn aber die erlaubte Mitwirkungsverweigerung seitens der beschuldigten Person in der Exploration den Verzicht auf ein Gutachten oder (weniger weitgehend) ein vom Informationswert herabgesetztes Aktengutachten nach sich ziehen kann, wäre es denkbar inkonsequent, die Teilnahme der Verteidigung mit dem Argument zu verweigern, dass sie die Wahrheitssuche in der Exploration stören könnte. Die Teilnahme der Verteidigung wäre im Vergleich zum vollständig schweigenden Exploranden, dem Begutachtungsverzicht oder dem Aktengutachten gewiss das kleinere Übel für die sachverständige Wahrheitssuche.⁹⁵¹

B) Inkompatibilität des Ausschlusses der Verteidigung im Lichte der EMRK-Praxis zu den «zwingenden Gründen»

356 Nach den voranstehenden Ausführungen ist der psychiatrische Methodenstandard bereits sachlich ungeeignet, einen legitimen Grund zum Ausschluss der Verteidigung zu bilden. Hinzu kommt, dass der Schutz der Methodenfreiheit nicht in die Systematik der vom EGMR restriktiv formulierten zwingenden Gründe für den Ausschluss der Verteidigung passt. Einerseits fehlt es an formellen Erfordernissen: Nach geltender Praxis sind zwingende Gründe zum Ausschluss der Verteidigung gesetzlich vorzusehen und es darf nicht zu einem generell-abstrakten Ausschluss der Verteidigung kommen.⁹⁵² Bereits dieser Anforderung vermag der juristische Status quo nicht nachzukommen, denn weder besteht eine explizite gesetzliche Grundlage, welche den Ausschluss der Verteidigung von der Exploration konkretisieren würde, noch kann von der geltenden Gerichtspraxis gesagt werden, dass sie nicht faktisch generell-abstrakter Natur sei.⁹⁵³

357 Selbst wenn man darüber noch hinwegsehen möchte, wäre der Schutz der Methodenfreiheit nicht geeignet, einen zwingenden Grund zum Ausschluss der Verteidigung nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK darzustellen, denn nach geltender Praxis vermögen nur die Abwendung von unmittelbaren Gefahren für Leben, Freiheit oder körperliche Integrität einen zwingenden Grund darzustellen.⁹⁵⁴ Diese Schutzinteressen werden mit dem Ausschluss der Verteidigung von der

⁹⁵⁰ BGer, 8. November 2006, 6S.390/2006, E. 3.3; BGer, 16. Februar 2009, 6B_937/2008, E. 2.2.

⁹⁵¹ Ähnlich auch BECKERT, S. 225.

⁹⁵² Vgl. N 295.

⁹⁵³ Zwar anerkennt die Bundesgerichtspraxis in der Theorie die ausnahmsweise Möglichkeit der Teilnahme der Verteidigung (vgl. N 47). Jedoch hat es diese Ausnahme noch nie angewendet, womit dem Ausschluss der Verteidigung faktisch generell-abstrakter Charakter zukommt.

⁹⁵⁴ Vgl. N 295.

Exploration aber gerade nicht verfolgt. Es geht vielmehr darum, die Wahrscheinlichkeit für das Verfahren zu optimieren. Die Methodenfreiheit ist bei Lichte besehen nichts anderes als das Ermittlungsinteresse der Strafbehörden im wissenschaftlichen Gewand. Gerade solche reinen Ermittlungsinteressen werden aber vom EGMR nicht als legitime Grundlage des Ausschlusses der Verteidigung anerkannt.

3. Zwischenfazit

Der Methodenstandard der Psychiatrie und der damit einhergehende Ausschluss der Verteidigung scheint nach dem Gesagten eher die (behebare⁹⁵⁵) Angst vor dem Unbekannten bzw. ein generelles Misstrauen gegenüber der Verteidigerfunktion⁹⁵⁶ als ein zwingender Grund für den Ausschluss der Verteidigung zu sein. Es gibt keinen triftigen Grund, warum die sachverständige Person einen schützenswerteren Anspruch auf Ungestörtheit im Explorationsgespräch haben soll als die Strafbehörden bei ihren Einvernahmen.⁹⁵⁷ Allgemein scheint es widersprüchlich, bei einem Gespräch ohne Schweigepflicht von einem Vertrauensverhältnis zu sprechen, das mittels Drittpersonenausschluss zu schützen wäre. Sofern die passive Präsenz der Verteidigung als Störfaktor moniert wird, sprechen die besseren Gründe dafür, dass sich der ohne Verteidiger agierende Beschuldigte weniger extensiv in der Exploration öffnet als wenn die Verteidigung anwesend ist.⁹⁵⁸

⁹⁵⁵ Interessant die Studie von SHEALY/PIRELLI/CRAMER, S. 656 und 567, in der aufgezeigt werden konnte, dass Psychologen mit langjähriger Erfahrung und/oder Personen, welche bereits Begutachtungen unter Anwesenheit von Dritten durchgeführt hatten, positivere Einstellungen zum Konzept der Drittpersonenanwesenheit aufwiesen und dabei insbesondere der Verteidigeranwesenheit und ihrer Funktion als fairnesssichernder Aspekt bejahender gegenüberstanden; in dieselbe Richtung auch BROWN, S. 89, welche darauf hinweist, dass unerfahrene Gutachter eher Ängste und Unbehagen gegenüber Begleitpersonen in der Exploration aufweisen.

⁹⁵⁶ Ein paradigmatisches Beispiel für ein negatives Verteidigerbild in der forensischen Psychiatrie formuliert etwa KRÖBER, FPPK 2015-B, S. 99: «Statt der widersprüchlichen Verfassung eines jungen Mannes, der gerade eine Katastrophe inszeniert hat, sieht man neben dem vermeintlichen Monster die alerte Gestalt des behütet aufgewachsenen Anwalts, der mit geschmeidigen Worten eine den Gesetzesvorschriften angepasste Küchenpsychologie zelebriert. Der Angeklagte wird seiner lebensgeschichtlich entscheidenden Tat enteignet; sie wird in den trivialen Kontext anwaltlicher Erfolgsvorstellungen gespannt, in Besetzungsrügen und Befangenheitsanträgen juristisch banalisiert und entsorgt.»

⁹⁵⁷ In der Sache auch HUBER, S. 270.

⁹⁵⁸ Vgl. N 349 ff.

359 Die aktive Intervention der Verteidigung ist sodann nicht als «Stör»faktor einzu-
 stufen. Vielmehr bewirkt die Verteidigung mit ihren Interventionen schlicht die
 Unterbindung ungesetzlichen Verhaltens oder die Wahrnehmung eines Rechts
 (*nemo tenetur*), welches der beschuldigten Person in der Exploration ohnehin
 zusteht (d.h. die beschuldigte Person darf dieses Recht auch ohne Anwesenheit
 der Verteidigung ausüben).⁹⁵⁹ Bereits vor diesem Hintergrund vermochte der
 psychiatrische Methodenstandard die Legitimationsprüfung für eine Einschränkung
 des Verteidigerbeizugs nicht zu bestehen. Diese Feststellung verfestigte
 sich mit Blick auf die vom EGMR gezogenen Leitlinien zu den zwingenden
 Gründen. Nur die Abwehr von unmittelbaren Gefahren für Leib, Leben und der
 Freiheit von Dritten vermag temporäre Einschränkungen des Rechts auf Vertei-
 digerbeizug zu legitimieren. Gerade darum geht es beim Methodenstandard der
 Psychiatrie aber nicht. Vielmehr erweist sich letzterer als nichts anderes als das
 Ermittlungsinteresse der Strafbehörde, das im Rahmen der sachverständigen
 Erhebungen im Gewand der Wissenschaft erscheint. Vor dem Hintergrund die-
 ser Erwägungen wird klar, dass der Methodenstandard keinen zwingenden
 Grund zur Einschränkung der Verteidigungsrechte zu bilden vermag.

IV. Fairnessverletzung qua Gesamtwürdigung

360 Nachdem dargelegt wurde, dass der Methodenstandard der Psychiatrie keinen
 zwingenden Grund für die Einschränkung des Rechts auf Beizug einer Verteidi-
 gung darstellt, muss in einem nächsten Schritt zur Gesamtwürdigung der Ver-
 fahrensfairness geschritten werden. Dabei trägt die Schweiz vor dem EGMR die
 Beweislast, da sie keinen zwingenden Grund für den Ausschluss der Verteidi-
 gung vorbringen kann. Sie hat unter der Geltung eines besonders strengen Prü-
 fungsmassstabs darzulegen, warum ausnahmsweise trotz dieser Bedingungen ein
 faires Verfahren gewährleistet ist.⁹⁶⁰ In diesem Kontext ist zu bemerken, dass
 die Eruierung des massgeblichen Fairnessniveaus methodisch herausfordernd
 ist. Der Grund dafür ist darin zu suchen, dass die Gesamtwürdigung des EGMR
 auf den Einzelfall fokussiert und dabei eine umfangreiche Kriterienliste konsult-
 tiert.⁹⁶¹ Aus diesen Fairnesskriterien – an die hier stellvertretend für die gesamte
 nachfolgende Abwägung erinnert wird⁹⁶² – ergeben sich zahlreiche Fallkonstel-
 lationen. Diese Vielzahl an prozessualen Konstellationen soll die nachfolgende
 Gesamtwürdigung nicht umfassend abbilden. Der hier vertretenen Ansicht bie-
 ten bereits die Regelvariablen einer umstrittenen Begutachtung im Kontext der
 Schuldfähigkeits- und Massnahmenbegutachtung eine genügend solide Basis,

⁹⁵⁹ Vgl. N 352 ff.

⁹⁶⁰ Vgl. N 296.

⁹⁶¹ Vgl. N 297; WOHLERS, fp 2019, S. 213.

⁹⁶² Vgl. N 298.

um die Konventionswidrigkeit des Schweizer Modells in nachvollziehbarer Weise darzulegen.

1. Indikatoren für die Annahme eines unfairen Verfahrens

A) Nationalrechtliche Ausgestaltung des Beweisverfahrens

Eine Schlüsselrolle im Gesamtwürdigungsmodell des EGMR spielt die Frage, ob die ohne Anwalt erlangten Beweise im Verfahren verwertet wurden. Eine Fairnessverletzung ist dann besonders unwahrscheinlich, wenn auf solche Beweise nicht abgestellt wird.⁹⁶³ Umgekehrt liegt die Annahme einer Konventionsverletzung nahe, wenn ohne Verteidigung erlangte Beweise verwertet werden.⁹⁶⁴ Nun wurde bereits im voranstehenden Teil nachgewiesen, dass sämtliche Aussagen, welche die beschuldigte Person nach der Belehrung (Art. 185 Abs. 5 StPO) gegenüber dem Sachverständigen macht, im späteren Verfahren verwertet

⁹⁶³ Vgl. N 298.

⁹⁶⁴ EGMR, A.T. v. Luxembourg, no. 30460/13, § 72 ff., 9 April 2015 (zwar keine belastende Aussage in der umstrittenen Einvernahme und es existierten weitere Beweise, aber später rekurrierte Gericht auf die umstrittene Einvernahme, um widersprüchliche Aussageverhalten zu untermauern; Fairnessverletzung); EGMR, Zachar and Čierny v. Slovakia, nos. 29376/12 and 29384/12, § 76 ff., 21 July 2015 (Aussagen ohne Anwalt waren zwar nicht die alleinige Basis für Schuldspruch, sie beeinflussten die Gerichte aber partiell; Fairnessverletzung); EGMR, Šebalj v. Croatia, no. 4429/09, § 263 f., 28 June 2011 (Verurteilung zu grossem Teil auf Angaben ohne Anwalt gestützt; Fairnessverletzung); EGMR, Bozkaya v. Turkey, no. 46661/09, § 51, 5 September 2017 (Gericht stützte sich auf ohne Anwalt erlangte Angaben; Fairnessverletzung); EGMR, Dimitar Mitev v. Bulgaria, no. 34779/09, § 68 ff., 8 March 2018 (Ohne Anwalt erlangte Angaben hatten signifikanten Einfluss auf weiteres Verfahren; Fairnessverletzung); EGMR, Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine, nos. 48016/06 and 7817/07, § 71 ff., 10 November 2016 (die nationalen Gerichte stützten sich zwar nicht explizit auf die Aussagen, es konnte aber nicht ausgeschlossen werden, dass sie das spätere Aussageverhalten beeinflussten); EGMR, Zachar and Čierny v. Slovakia, nos. 29376/12 and 29384/12, § 77 ff., 21 July 2015 (Angaben ohne Anwalt beeinflussten die Entscheidungsfindung des Gerichts; Fairnessverletzung); CELIKSOY, S. 16 f.; RAMOS, S. 415; zu absolut wohl BURIC, S. 349 f. (immer Annahme einer Konventionsverletzung, wenn auf Aussagen abgestellt wird, die ohne Anwalt erlangt wurden); HOHL-CHIRAZI, LD Roth, S. 113 f., HOHL-CHIRAZI, Diss., S. 205; bgl. sodann BGER, 19. September 2018, 6B_824/2018, E. 1.2: «Or, le recourant ne prétend pas regretter d'avoir tenu un propos particulier aux experts ou d'avoir collaboré à l'expertise. Il n'explique pas davantage quelles déclarations faites aux experts auraient pu être retenues à sa charge, étant rappelé que sa condamnation s'est fondée sur les aveux complets qu'il a livrés au tribunal de première instance.»

werden dürfen; und zwar sowohl für die Beweisfragen der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation als auch für den Nachweis der Tat oder zur Begründung von strafzumessungsrelevanten Faktoren.⁹⁶⁵ Dieser Umstand wiegt im Rahmen der Gesamtwürdigung schwer zulasten der Schweiz.

B) Signifikanz des Beweismaterials für Urteilsbasis

362

Wird auf das in der Exploration ohne Verteidigung erlangte Beweismaterial abgestellt, könnte die Konventionskompatibilität allenfalls dann gewahrt werden, wenn die erlangten Aussagen keine oder nur vernachlässigbare Auswirkungen (weil anderes Beweismaterial vorlag) auf die Verurteilung der beschuldigten Person hatten.⁹⁶⁶ Dieses Kriterium steht überdies in engem Zusammenhang zur «Natur der Aussage». Mit letzterem Gesichtspunkt prüft der EGMR, ob eine ohne Anwalt erlangte Aussage Geständnischarakter hatte oder inkriminierender Natur war und die Verteidigungsposition substantiell beeinträchtigte.⁹⁶⁷ Ungeachtet der Variabilität des Einzelfalls können dazu folgende Gedanken formuliert werden. Was die Natur der Aussage angeht, ist zu bedenken, dass die psychiatrische Begutachtung so umfassend ist, dass es nur allzu schnell geschehen kann, dass Äusserungen der beschuldigten Person strafprozessuale Nachteile mit sich bringen (Schuldfähigkeitsfrage, Massnahmenindikation, Tatnachweis, Strafzumessung). Ohne Anwalt erlangte Angaben im Explorationsgespräch sind somit systembedingt geeignet, die Position des Exploranden negativ zu beeinträchtigen. Was die quantitative Signifikanz angeht (anderes Beweismaterial), könnte argumentiert werden, dass eine Begutachtung – trotz der Pressionen des Beschleunigungsgebots⁹⁶⁸ – erst in die Wege geleitet wird, wenn der Sachverhalt strafbehördlich ausreichend abgeklärt ist⁹⁶⁹ und dass die sachverständige Person ihre Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbegutachtung (welche an-

⁹⁶⁵ Vgl. N 310 ff.

⁹⁶⁶ Vgl. N 298; EGMR, *Simeonovi v. Bulgaria* [GC], no. 21980/04, § 136 ff, ECHR 2017 (ohne Anwalt erlangte Angaben flossen nicht in Urteil ein; entscheidende Bedeutung für Feststellung eines fairen Verfahrens); EGMR, *Farrugia v. Malta*, no. 63041/13, § 113, 4 June 2019; EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 93, 23 May 2019; EGMR, *Artur Parkhomenko v. Ukraine*, no. 40464/05, § 73, 16 February 2017 (ohne Anwalt erlangte Angaben spielten keine entscheidende Rolle; keine Fairnessverletzung); EGMR, *Kalēja v. Latvia*, no. 22059/08, § 67, 5 October 2017 (es lag zahlreiches anderes Beweismaterial für Urteil vor; keine Fairnessverletzung); RAMOS, S. 416.

⁹⁶⁷ EGMR, *Farrugia v. Malta*, no. 63041/13, § 118, 4 June 2019; EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 92 f., 23 May 2019.

⁹⁶⁸ ZK StPO-DONATSCH, Art. 184 N 6; BSK StPO-I-HEER, Art. 184 StPO N 27.

⁹⁶⁹ BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 40; BSK StPO-I-HEER, Art. 184 StPO N 27; ZK StPO-DONATSCH, Art. 184 N 6; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, N 934; sehr streng MAIER/MÖLLER, 124 (fordern den praktischen Abschluss der Ermittlungen); HADDENBROCK, S. 1303.

schliessend vom Gericht gewürdigt und zum Urteilssachverhalt erhoben wird) auch auf andere Beweise als den Explorationsinhalt stützt⁹⁷⁰. Davon ausgehend könnte abgeleitet werden, dass das in der Exploration erlangte Beweismaterial nur beschränkte beweisrechtliche Signifikanz hat, da im Regelfall einer Begutachtung (auch) andere Beweise (strafbehördlich erhobene und sonstige Beweishebungen des Sachverständigen) als die Explorationsinhalte vorliegen. In diesem Sinn könnten auch die Stellungnahmen im Schrifttum verstanden werden, gemäss welchen ein Teilnahmerecht der Verteidigung v.a. beim nicht geständigen Exploranden bzw. bei Gutachten, die geeignet sind, den Schuldpunkt zu beeinflussen, erforderlich ist.⁹⁷¹ Dieser Schluss beruht auf der impliziten Annahme, dass in der Exploration die Verteidigungsinteressen dann nicht mehr so stark tangiert sind, wenn durch das bereits gegenüber den Strafbehörden abgegebene Geständnis ein starker anderer Beweis vorliegt.⁹⁷²

Allerdings sprechen die besseren Gründe dafür, die Signifikanz der Explorationsangaben generell als Indikator für die Verletzung der Verfahrensfairness zu werten. Dies gilt für die Begutachtungsfragen in klarer Weise: Anerkennt man die Exploration als zentrales Beweisstück für den Sachverständigenbeweis, der wiederum determinierende Wirkung auf die Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbeurteilung durch das Gericht hat, lässt sich die Signifikanz der Explorationserhebungen kaum in Abrede stellen.⁹⁷³ Doch selbst über das Gutachten hinaus kann die beweisrechtliche Signifikanz der Exploration kaum in Abrede gestellt werden. Zwar soll nicht in Frage gestellt werden, dass besonders akzentuierte Verteidigungsinteressen vorliegen, wenn die Straftat bestritten wird und keine eindeutige Beweislage existiert. In diesem Fall dürfte sich ein Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch ihrer Mandantin alleine durch diese Ausgangslage aufdrängen.⁹⁷⁴ Doch selbst wenn weitere Personal- oder Sachbeweise vorliegen, kann nicht in Abrede gestellt werden, dass die beschuldigte Person durch Explorationsangaben zum Tatnachweis, zur rechtli-

⁹⁷⁰ Zu diesen anderen Informationsquellen der sachverständigen Person auch N 8.

⁹⁷¹ BERNHARD, iusNet 27. November 2018 (wobei der Vollständigkeit halber anzumerken ist, dass der Autor auch dann ein Teilnahmerecht befürwortet, «wenn aus anderen Gründen die Begutachtung den Schuldpunkt beeinflussen könnte, beispielsweise hinsichtlich der Beurteilung des subjektiven Tatbestandes oder der Qualifikation eines Tötungsdelikts und ähnliches»); ebenso HEER/COVACI, S. 450.

⁹⁷² Diese Überlegung findet sich ansatzweise auch in BGer, 19. September 2018, 6B_824/2018, E. 1.2: «Or, le recourant ne prétend pas regretter d'avoir tenu un propos particulier aux experts ou d'avoir collaboré à l'expertise. Il n'explique pas d'avantage quelles déclarations faites aux experts auraient pu être retenues à sa charge, étant rappelé que sa condamnation s'est fondée sur les aveux complets qu'il a livrés au tribunal de première instance.»

⁹⁷³ Zur Bedeutung der Exploration: N 10; zur Bedeutung des Sachverständigenbeweises für das gerichtliche Urteil: N 110 ff.

⁹⁷⁴ BERNHARD, iusNet 27. November 2018.

chen Qualifikation der Tat, zur Strafzumessung sowie zum Schuldfähigkeits- oder Massnahmenindikationssachverhalt weiter beitragen kann. Auch die Bestätigung des vorhandenen Beweismaterials in der Exploration weist eine beweisrechtliche Relevanz auf. Durch die Angaben des Exploranden lassen sich insbesondere Rückschlüsse auf die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen (z.B. Aussagekonstanz) ziehen. Beispielsweise ist zu berücksichtigen, dass ein Geständnis von den Strafbehörden auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen ist (Art. 160 StPO). Wenn die beschuldigte Person sich in der Exploration äussert, kann diese Angabe wiederum als Beleg für oder wider die Glaubhaftigkeit der in der Einvernahme erlangten Aussage beigezogen werden. Vor dem Hintergrund des Gesagten kann man zu keinem anderen Fazit kommen, als dass die ohne Verteidigung erfolgenden Erhebungen in der Exploration Signifikanz für die spätere Urteilsbasis aufweist.

C) Qualität der Beweise

364 Angesichts der Verwertbarkeit von Explorationsangaben in Abwesenheit der Verteidigung kommt der Qualität der vom PSY-Sachverständigen erlangten Beweise eine wichtige Bedeutung zu.⁹⁷⁵ In diesem Zusammenhang muss ein besonderes Augenmerk auf die Umstände der Beweiserlangung gelegt und geprüft werden, ob und welche Form von Zwang Anwendung fand (bzw. ob solches von der beschuldigten Person glaubhaft dargelegt wird).⁹⁷⁶ Gerade die Umstände der Beweiserlangung sind aber im Explorationskontext nicht optimal. Im 3. Teil wurde dargelegt, dass sich der Explorationssachverhalt nur mittels der gutachterlich erstellten Schriftdokumentation sowie den Aussagen der beschuldigten Person und des Sachverständigen rekonstruieren lässt, wobei aufgrund des systemimmanenten Glaubhaftigkeits-Bias regelmässig der Darstellung des Sachverständigen gefolgt wird.⁹⁷⁷ Ist dies aber der Fall, fehlt es an einem objektiven Blick auf die Exploration, der eine umfassende Prüfung der Legalität der sachverständigen Erhebungen gewährleisten würde. Vom EGMR als prozedurale Schutzmechanismen anerkannte Mittel wie etwa die audiovisuelle Aufzeichnung fehlen.⁹⁷⁸ Mit diesen Ausgangsvariablen ist die Qualitätsprüfung der in der Exploration erlangten Beweise nur unzureichend gewährleistet.

⁹⁷⁵ Vgl. N 298.

⁹⁷⁶ Dazu insb. EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 167, 9 November 2018; EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 86, 23 May 2019.

⁹⁷⁷ Vgl. N 176 ff.

⁹⁷⁸ EGMR, *Fefilov v. Russia*, no. 6587/07, § 62, 17 July 2018: «having spent several hours in police custody without the benefit of legal advice and without his arrest having been recorded could not but have amounted to a coercive environment»; EGMR, *Farrugia v. Malta*, no. 63041/13, § 117 (implizit), 4 June 2019; EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 99, 23 May 2019: «A key additional safeguard ...

Sofern darüber hinaus die glaubhafte Schilderung der beschuldigten Person bzgl. 365
Zwanganwendung gefordert wird, sei auf folgenden Aspekt hingewiesen: Sollte eine explizite Zwanganwendung (Drohung etc.) stattgefunden haben, würde diese wohl von der beschuldigten Person im Verfahren kundgetan, was aber wiederum aufgrund der mangelnden Transparenz nur ineffektiv zur Geltung gebracht werden könnte. Nicht minder zentral ist sodann die folgende Feststellung: Im Regelfall wird die sachverständige Person die beschuldigte Person in der Exploration nicht bewusst Zwang aussetzen. Gleichwohl gilt es zu konstatieren, dass die Exploration mit systemimmanenten Druckmomenten (Informationsinteresse des Sachverständigen, Verletzlichkeit des Exploranden) einhergeht und dass wegen der ambivalenten Rolle des Sachverständigen latent die Frage im Raum steht, ob die beschuldigte Person bei Kenntnis der verfahrensrechtlichen Implikationen sich aufgeklärt und freiwillig für eine Mitwirkung entscheidet, wodurch *nemo tenetur* tangiert wird.⁹⁷⁹ Gerade auch mit Blick auf diese Reibungsfläche drängt es sich auf, die Qualität der vom Sachverständigen erlangten Beweise in Frage zu stellen und zulasten der Fairness des Verfahrens zu berücksichtigen.

D) Besondere Verletzlichkeit der beschuldigten Person als Explorandin

In der Fairnessanalyse ist sodann zu betrachten, ob die beschuldigte Person wegen ihrer psychischen Verfassung oder ihres Alters besonderen Schutzes bedarf.⁹⁸⁰ In seiner Praxis betont der EGMR im Zusammenhang mit Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK die Wichtigkeit, Kindern aufgrund ihrer besonderen Verletzlichkeit den Zugang zu einer Verteidigung zu ermöglichen.⁹⁸¹ Eine von der Ratio identische Praxis findet sich im Rahmen von Art. 5 Ziff. 4 EMRK: Hier gilt, dass psychische Störungen nie die Essenz der einer Person zustehenden Verfahrensrechte auslöschen dürfen, sondern im Gegenteil spezielle verfahrensrechtliche Schutzmechanismen für jene Personen notwendig sind, welche wegen ihrer Störung nicht oder nicht vollständig für sich handeln können.⁹⁸² Ausgehend

was the fact that all the applicant's police interviews were recorded on video and those videos were available to the judges at all three levels of jurisdiction and the jury at trial. The Court considers that this was indeed an important safeguard as it doubtless acted to maintain pressure on the police to act in conformity with the law.»

⁹⁷⁹ Vgl. N 325 ff.

⁹⁸⁰ Vgl. N 298.

⁹⁸¹ EGMR, *Blokhin v. Russia* [GC], no. 47152/06, § 198 f, ECHR 2016.

⁹⁸² EGMR, *Winterwerp v. the Netherlands*, 24 October 1979, § 60, Series A no. 33; EGMR, *Megyeri v. Germany*, 12 May 1992, § 22, Series A no. 237-A; EGMR,

davon gilt der Grundsatz, dass wenn eine Person wegen Schuldunfähigkeit von Strafvorwurf freigesprochen, aber stattdessen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, sie in der Regel in den Genuss eines Rechtsbeistands kommen muss, wenn über die Verlängerung, vorübergehende Aufhebung («suspension») oder Beendigung des Freiheitsentzugs entschieden wird; dies dränge sich sowohl mit Blick auf die Schwere des Grundrechtseingriffs (Freiheitsentzug) als auch auf den psychischen Zustand des Betroffenen auf.⁹⁸³

367 Diese Leitlinien sind auf das Explorationsgespräch im Rahmen einer Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbegutachtung im Strafprozess anwendbar. Wenn eine Person unter besonderen geistigen Herausforderungen leidet, akzentuiert sich die Notwendigkeit des Verteidigerbeizugs. Dieser konventionsrechtliche Grundgedanke sieht sich nebenbei bemerkt in Art. 130 lit. c StPO gespiegelt. Danach ist die Anordnung einer notwendigen Verteidigung erforderlich, wenn die beschuldigte Person «wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist.» Für die Beurteilung von Art. 130 lit. c StPO (welche Norm in engem kontextuellen Zusammenhang zur Verhandlungsfähigkeit nach Art. 114 StPO steht⁹⁸⁴) ist massgeblich, ob die beschuldigte Person das Wesen des Strafverfahrens versteht, den Sachverhalt aus ihrer Sicht darstellen kann, Möglichkeiten ihrer Entlastung zu erkennen und Ergänzungsfragen/ und kritische Stellungnahmen abzugeben vermag, was insb. ausreichende sprachlich-kognitive Fähigkeiten erfordert.⁹⁸⁵ Diese Überlegungen müssen für die Exploration in demselben Masse gelten: Wenn es der beschuldigten Person an der elementaren Verteidigungsfähigkeit fehlt, muss die Verteidigung zur Exploration zugelassen werden, ansonsten die Verfahrensfairness nicht gewährleistet ist.

368 Zwar scheint die Gerichtspraxis in diesem Zusammenhang einen restriktiven Massstab anzulegen. In der bundesgerichtlichen Praxis genügte z.B. nicht, dass die beschuldigte Person «beschränkte intellektuelle Fähigkeiten bzw. Mühe [hatte], sich richtig auszudrücken», um ein Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch zu begründen.⁹⁸⁶ Ebenso scheint der EGMR in seiner

Magalhães Pereira v. Portugal, no. 44872/98, § 56, ECHR 2002-I; EGMR, N. v. Romania, no. 59152/08, § 186, 28 November 2017.

⁹⁸³ EGMR, Megyeri v. Germany, 12 May 1992, § 23, Series A no. 237-A; EGMR, Magalhães Pereira v. Portugal, no. 44872/98, § 57, ECHR 2002-I; EGMR, N. v. Romania, no. 59152/08, § 196, 28 November 2017.

⁹⁸⁴ BGer, 3. November 2014, 1B_279/2014, E. 2.1.1; BGer, 1. September 2016, 1B_285/2016, E. 2.1; BGer, 27. Oktober 2014, 1B_318/2014, E. 2.1.

⁹⁸⁵ Vgl. BGer, 15. März 2016, 1B_435/2017, E. 4.3; BGer, 3. November 2014, 1B_279/2014, E. 2.1.1 und 2.2; KGer-BL, 19. Juli 2016, 470 16 71, E. 2.3.1; ZK StPO-LIEBER, Art. 130 N 19; BSK StPO-RUCKSTUHL, Art. 130 N 30.

⁹⁸⁶ BGE 144 I 253, E. 3.8; zurecht kritisch: BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64a.

Praxis die besondere Verletzlichkeit in seiner Gesamtwürdigung nur zu berücksichtigen, wenn sie über die allgemeine Verletzlichkeit hinausgeht, welche eine strafbehördliche Einvernahme mit sich bringt.⁹⁸⁷ Diese restriktive Praxis hält einer näheren Prüfung nicht stand. Nimmt man die beschuldigte Person als Prozesssubjekt mit ihren Verteidigungsrechten ernst, sollte die Annahme einer fehlenden Verteidigungsfähigkeit bei psychischen Auffälligkeiten des Exploranden mit Folge der notwendigen Einbindung der Verteidigung grosszügig bejaht werden.⁹⁸⁸

Zwar kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass in der Praxis begutachtete 369 beschuldigte Personen durchaus unterschiedliche psychische Kapazitäten aufweisen: Denkbar ist das ganze Spektrum vom unter- bis zum überdurchschnittlich intelligenten Exploranden. Der erstgenannten Fallgruppe müsste nach der voranstehenden Erwägung zweifelsohne der Beizug der Verteidigung erlaubt werden, ansonsten das Verfahren unfair ausfällt. Doch auch bei normal- oder überdurchschnittlich intelligenten Exploranden gibt es gute Gründe dafür, die Absenz einer Verteidigung im Rahmen der Gesamtwürdigung als Indikator für eine Verletzung der Verfahrensfairness zu werten. Es ist nämlich verteidigungsrechtlich kaum haltbar zu argumentieren, dass ein über die allgemeine Verletzlichkeit hinausgehendes Mass an Verletzlichkeit zur Begründung des Verteidigerbeizugs notwendig ist, wenn bereits die allgemeine Verletzlichkeit der zu begutachtenden Person bei einer Exploration zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation so intensiv ausfällt, dass sie nur mit anwaltlichem Beistand kompensiert werden kann. Gerade diese Ausgangsvariablen liegen der hier vertretenen Auffassung nach vor: Der Explorand ist bei Schuldfähigkeits- und Massnahmengutachten im Regelfall ab initio durch die Rahmenbedingung angeschlagen (Einfluss des Strafverfahrens, Bedeutung der Exploration usw.), sieht sich mit dem Informationsinteresse des Sachverständigen konfrontiert und hat zudem regelmässig mit psychischen Defiziten zu kämpfen, womit seine Verteidigungsfähigkeit reduziert ist.⁹⁸⁹ Selbst wenn also im Einzelfall nicht geradezu eine Verletzlichkeit von einer solchen Intensität vorhanden ist, welche bereits für sich genommen die Anwesenheit der Verteidigung erfordert, dürfen auch gerin-

⁹⁸⁷ EGMR, *Beuze v. Belgium* [GC], no. 71409/10, § 168, 9 November 2018: «The Court notes that the above-mentioned assessment concluded that while the applicant had limited intellectual capacities, his reasoning was nevertheless within the norm. Moreover, the applicant has not pointed to any indication in the records of his interviews and examinations that he had difficulty expressing himself. In addition, no other particular circumstance can be noted which would indicate that the applicant was in a greater state of vulnerability than that in which persons interviewed by investigators would generally find themselves.»; EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 85, 23 May 2019.

⁹⁸⁸ BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64a; HEER/COVACI, S. 450.

⁹⁸⁹ Vgl. N 331 ff.

gere Ausprägungen der Verletzlichkeit im Rahmen der Gesamtwürdigung gewichtet werden, und zwar als Indikator für die Annahme eines unfairen Verfahrens.

E) Fehlen eines Verzichts auf Verteidigerbeizug

370 In § 9 wurde ausgeführt, dass die beschuldigte Person über ihr Recht auf Beizug einer Verteidigung zu belehren ist und auf informierter Basis autonom darüber entscheiden kann, ob sie dieses Recht wahrnimmt oder darauf verzichtet.⁹⁹⁰ Dieses schützende Instrument kann im schweizerischen Modell per se nicht zur Anwendung gelangen, da ein Teilnahmerecht der Verteidigung im Explorationsgespräch nach geltender Rechtsprechung und herrschender Lehre ja gerade in Abrede gestellt wird.⁹⁹¹ Entsprechend wird auch keine Rechtsbelehrung der beschuldigten Person vorgenommen, sie dürfe zum Explorationsgespräch eine Verteidigung beiziehen. Folglich ist die beschuldigte Person systembedingt nie mit der erforderlichen Rechtskenntnis ausgestattet, welche einen rechtswirksamen Verzicht auf das Teilnahmerecht der Verteidigung begründen würde. Auch dieser Gesichtspunkt ist als Indikator für die Annahme eines unfairen Verfahrens zu würdigen.

2. Indikatoren für die Annahme eines fairen Verfahrens

A) Belehrung über das Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht

371 Der PSY-Sachverständige hat die beschuldigte Person vor Beginn der Exploration darüber zu belehren, dass sie im Rahmen des Explorationsgesprächs die Mitwirkung verweigern darf, dass keine Schweigepflicht des Sachverständigen besteht und dass sämtliche Informationen gegenüber der Strafbehörde offenbart werden können (Art. 185 Abs. 5 StPO). Damit sollen nach einem Teil der Gerichtspraxis die Rechte der beschuldigten Person (insb. nemo tenetur) ausreichend gewahrt sein.⁹⁹² Zwar stimmt es, dass diese Belehrung eine notwendige

⁹⁹⁰ Vgl. N 294.

⁹⁹¹ Vgl. N 43 ff.

⁹⁹² KassGer-ZH, 18. Dezember 2009, AC080021, E. II.1.7.1.c/dd; KGer-VS, 24. Oktober 2014, TCV P3 14 153, E. 3.4.2; dies scheint auch in Kreisen der PSY-Sachverständigen so angenommen zu werden, vlg. HOFF, Psychiatrie, S. 160 f.; auch der EGMR misst der Belehrung Fairnessrelevanz zu: EGMR, Doyle v. Ireland, no. 51979/17, § 97, 23 May 2019.

Voraussetzung dafür ist, dass die beschuldigte Person ihre Rechte effektiv wahrnehmen kann. Aus ihrer Realisierung wird aber nicht auf ausreichenden verfahrensrechtlichen Schutz geschlossen werden dürfen.

Erstens ist zu bedenken, dass Rechtsbelehrungen bereits durch Verständnisschwierigkeiten seitens des Adressaten regelmässig in ihrer Effektivität herabgesetzt werden.⁹⁹³ Zweitens wird es der beschuldigten Person oft am notwendigen Wissen fehlen, wie sie sich angesichts einer spezifischen verfahrensrechtlichen Konstellation im Explorationsgespräch am besten verhalten soll, d.h. ob und in welchem Masse eine Kooperation mit dem Sachverständigen opportun ist.⁹⁹⁴ Drittens zu berücksichtigen, dass Exploranden im Laufe der Exploration tendenziell die prozessuale Rolle des Sachverständigen verkennen und Informationen preisgeben, die sie gegenüber den Strafbehörden verschwiegen hätten.⁹⁹⁵ Letzteres spiegelt sich auch in der forensisch-psychiatrischen Literatur, wo anerkannt wird, dass eine zu Beginn der Exploration vorgenommene Belehrung oft nicht ausreicht, da der Explorand latent gefährdet ist, in das Verständnis zu gleiten, dass ihm der therapeutisch gesinnte Arzt und nicht der forensisch tätige Sachverständige gegenübersteht.⁹⁹⁶ Bereits diese Gesichtspunkte zeigen, dass der faktische Schutzgehalt einer bloss zu Beginn der Exploration abgegebenen Rechtsbelehrung limitiert ist. 372

Nun könnte eine partielle Behebung dieses Defizits darin gesehen werden, dass die Belehrung seitens des Sachverständigen bei erkannten Selbstbelastungen der beschuldigten Person während der Exploration wiederholt, die Möglichkeit einer Besprechung mit der Verteidigung angeboten oder gar die Exploration abgebrochen wird.⁹⁹⁷ Diese Lösung ist aber in vielerlei Hinsicht unvollkommen. Ganz allgemein ist zu berücksichtigen, dass durch sie die Neutralität des Sachverständigen gefährdet werden kann (der Sachverständige als Wahrer der Verteidigungsrechte). Davon abgesehen ist der Schutzgehalt dieses Lösungsansatzes lückenhaft. Die Effektivität dieser Instrumente während der Exploration setzt voraus, dass der Sachverständige verteidigungsrechtlich ungünstige Stellungnahmen des Exploranden überhaupt erkennt. Dies dürfte ausserhalb klarer Fälle (z.B. Geständnis in der Exploration nach vorherigem Schweigen gegenüber der Strafbehörde) bereits eine nicht zu bewältigende Herausforderung bilden, da der Sachverständige kein umfassendes juristisches Wissen aufweist und daher kaum abschliessend beurteilen kann, bei welchem Verfahrensstand sich mit Blick auf 373

⁹⁹³ Zu dieser Thematik: CAPUS/STOLL/STUDER, S. 51.

⁹⁹⁴ Vgl. N 332 f.

⁹⁹⁵ Vgl. N 335 ff.

⁹⁹⁶ Vgl. N 335 ff.; Kröber et al.-I-SASS, S. 426 f.

⁹⁹⁷ Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 27; EGG, S. 247; KRÖBER, Angeklagte, S. 37; MÜLLER/NEDOPIL, S. 414 f.; SCHMID, Diss., S. 500; TONDORF/TONDORF, N 282; vgl. hierzu auch EGMR, Doyle v. Ireland, no. 51979/17, § 98, 23 May 2019.

den Tatnachweis oder die Sanktionsfolgen eine Kooperation oder Nichtmitwirkung aufdrängt. Ebenso könnte er nur beschränkt beurteilen, ob durch eine neu in der Exploration erlangte Tatsache u.U. ein anderer Straftatbestand erstellt werden könnte oder in welcher Weise die Kooperation sich auf die Strafzumessung auswirkt.

- 374 Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die schützenden Interventionen durch den Sachverständigen nicht durch das Recht vorgeschrieben sind, sondern eine Frage des Explorationsstils des Sachverständigen darstellen. Es hat sich noch kein Konsens in der forensischen Psychiatrie bilden können, wie bei potentiellen Selbstbelastungen seitens des Exploranden vorzugehen ist.⁹⁹⁸ Es ist daher ebenso gut möglich, dass der Sachverständige seine qualifizierte Gesprächsführungsmethodik dazu nutzt, den Sachverhalt weiter auszuleuchten.⁹⁹⁹ Die nach Beginn der Exploration wiederholten Belehrungen stellen damit das Produkt eines Zufalls (Person des Sachverständigen) dar. Ruft man sich die Summe dieser Kritikpunkte in Erinnerung, gilt es zu konstatieren, dass die Belehrung der beschuldigten Person zwar ein notwendiger, aber nie ein ausreichender verfahrensrechtlicher Schutzmechanismus zur Wahrung der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person darstellt.

B) Freier Verkehr mit der Verteidigung

- 375 Das Recht nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK ist im Kontext des Explorationsgesprächs nur eingeschränkt (kein Teilnahmerecht der Verteidigung in der Exploration), aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Die beschuldigte Person kann mit der Verteidigung vor der Exploration frei verkehren und dabei den kommenden Untersuchungsvorgang besprechen.¹⁰⁰⁰ Nach gewissen Meinungen bietet diese Vorbereitungsmöglichkeit ausreichenden verfahrensrechtlichen Schutz und macht ein Teilnahmerecht der Verteidigung im Explorationsgespräch überflüssig.¹⁰⁰¹ Wie beim voranstehenden Kriterium der Rechtsbelehrung wird kaum bestritten werden können, dass der freie Verkehr der Verteidigung mit ihrer Mandantin ein Bestandteil eines fairen Verfahrens ist. Nur in diesem Rahmen kann eine umfassende Information der beschuldigten Person stattfinden und eine situationsadäquate Verteidigungsstrategie entwickelt werden.¹⁰⁰² Die effektive

⁹⁹⁸ GRAF, Missbrauch, S. 146.

⁹⁹⁹ GRAF, Missbrauch, S. 146; MÜLLER/NEDOPIL, S. 414 (Entscheid im Einzelfall).

¹⁰⁰⁰ BERNHARD, fp S0/2014, S. 18; HANSJAKOB, S. 304; vgl. auch BGE 119 Ia 260, E. 3d, in dem das BGer die Tatsache berücksichtigte, dass der freie Verkehr mit der Verteidigung gewährleistet war.

¹⁰⁰¹ BARTON, StV 1983, S. 79; HANSJAKOB, S. 304.

¹⁰⁰² Zu diesen Dimensionen des Verteidigerhandelns auch ALBRECHT, Funktion, N 2.34 ff.

Nutzung des freien Verkehrs stellt daher einen wesentlichen Baustein effektiver Verteidigungsarbeit dar.¹⁰⁰³

Dieser Baustein alleine gewährleistet aber noch kein faires Verfahren. Die Gründe dafür sind simpel. Selbst beim geständigen Exploranden (und erst recht beim nichtgeständigen) dürfte sich in der Sache mindestens ein partielles Schweigen gegenüber dem Sachverständigen aufdrängen.¹⁰⁰⁴ Umgekehrt sitzt der Verteidigung die Angst im Nacken, bei einem zu extensiven Schweigen das Misstrauen des PSY-Sachverständigen zu wecken.¹⁰⁰⁵ Realiter dürfte daher oft ein partielles Kooperieren (z.B. Öffnung zur Lebensgeschichte, aber nicht zum Tatvorwurf usw.) sinnvoll sein. Die Einhaltung komplexer Verteidigungsstrategien dürfte der beschuldigten Person indes schwerfallen. Nur allzu schnell verblasst das zuvor im Verkehr mit der Verteidigung Besprochene im Bewusstsein der beschuldigten Person. Es überrascht daher kaum, dass die beschuldigte Person das zuvor mit der Verteidigung verabredete Schweigen gegenüber dem Sachverständigen ohne anwaltlichen Beistand in der Exploration selten durchhalten kann.¹⁰⁰⁶ Vielmehr wird sie regelmässig der natürlichen Versuchung erliegen, sich aktiv-verbal zu verteidigen.¹⁰⁰⁷ Doch genau hier hätte die Verteidigung das Begehren, das psychologisch verständliche Redebedürfnis des Exploranden auf jene Sachverhaltsfelder zu beschränken, welche aus Sicht der Verteidigung strategisch sinnvoll sind.¹⁰⁰⁸ Diese strategische Gebotenheit müsste die Verteidigung immer wieder aufs Neue anhand der Situationsvariablen im Explorationskontext überprüfen und mit ihren Interventionen steuern können. Doch genau dieser Steuerungsmöglichkeit wird die beschuldigte Person beraubt, da ihre Verteidigung abwesend ist. Es fehlen der Verteidigung die Mittel, Strategieabweichungen des Klienten korrigieren zu können (z.B. Rat zum Schweigen bzw. Belehrung über Konsequenzen der Mitwirkung¹⁰⁰⁹, allenfalls Unterbruch der Exploration zwecks Besprechung), sobald die Exploration begonnen hat. Wird man sich aber dieses Defizits bewusst, ergibt sich, dass der freie Verkehr vor der Exploration keine ausreichende Interessenwahrung im Explorationsgespräch sichert.¹⁰¹⁰

¹⁰⁰³ BERNHARD, fp S0/2014, S. 18.

¹⁰⁰⁴ BERNHARD, fp S0/2014, S. 18; vgl. auch ROTH, Strassenverkehr 2019, S. 58.

¹⁰⁰⁵ BERNHARD, fp S0/2014, S. 18.

¹⁰⁰⁶ BERNHARD, fp S0/2014, S. 18; vgl. auch KRAUSS, ZStW 1985, S. 94 «Auch der Proband wird in aller Regel die absolute Verweigerung des Dialogs mit dem Sachverständigen weder durchstehen können noch auch nur in Betracht ziehen wollen.»

¹⁰⁰⁷ BERNHARD, fp S0/2014, S. 19.

¹⁰⁰⁸ Für die analoge Problematik in der Einvernahme: WOHLERS, ZStrR 2012, S. 60 f.

¹⁰⁰⁹ Zu diesem Aspekt im Allgemeinen PAREIN/BURGENER, S. 549.

¹⁰¹⁰ Mit demselben Ergebnis: SANER, S. 134.

C) Öffentliches Interesse an Untersuchung/Bestrafung

377 Vom EGMR wird sodann regelmässig berücksichtigt, ob gewichtige öffentliche Interessen an der sachgerechten Untersuchung und allfälligen Sanktionierung der beschuldigten Personen bestehen, bejahendenfalls dies als Indikator zugunsten eines fairen Verfahrens gewertet wird.¹⁰¹¹ Dieses Kriterium kann an dieser Stelle kaum generell-abstrakt beurteilt werden, denn es können Anlasstaten unterschiedlichster Natur Grundlage einer Begutachtung bilden, womit das öffentliche Interesse je nach Schwere des Delikts unterschiedlich besetzt ist. Entscheidend ist aber, dass die besseren Gründe dafür sprechen, die Erwägung des öffentlichen Interesses nicht in die Fairnessbetrachtung einfließen zu lassen. Wie im Schrifttum zurecht kritisiert wird, verlieren strafprozessuale Garantien für die Strafbehörden an Abschreckungswirkung, wenn man sie einer Abwägung mit den öffentlichen Strafverfolgungsinteressen öffnet.¹⁰¹² Nicht minder wichtig ist sodann die Feststellung, dass mit steigender Schwere des Strafvorwurfs (und des damit verbundenen öffentlichen Interesses an Aufklärung und Sanktionierung) auch das Interesse des Beschuldigten an einem fairen Verfahren steigt: Erhöhen sich aber auf beiden Seiten der Waage die Gewichte, vermag das Kriterium des öffentlichen Interesses keinen sinnvollen Beitrag an eine Interessenabwägung zu leisten.¹⁰¹³ Es darf vor diesem Hintergrund nicht überraschen, dass der EGMR dieses Kriterium weniger als Kernbestandteil in seiner Fairnessanalyse berücksichtigt, sondern vielmehr dazu nutzt, ein bereits aufgrund anderer Faktoren bestehendes Resultat abzusichern.¹⁰¹⁴

D) Einwendungen gegen Beweismaterial & Aussagerückzug oder -modifikation

378 Die beschuldigte Person hat sodann in jedem Strafverfahren die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Nutzung des ohne Anwalt erlangten Beweismaterials

¹⁰¹¹ Vgl. N 298.

¹⁰¹² Stellvertretend: THOMMEN/SAMADI, S. 84.

¹⁰¹³ THOMMEN/SAMADI, S. 84.

¹⁰¹⁴ EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom, nos. 50541/08 and 3 others, § 293, 16 December 2014 (Terroranschläge; öffentliches Interesse gegeben; Fairnesswahrung); EGMR, Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine, nos. 48016/06 and 7817/07, § 79 ff., 10 November 2016 (Mordanklage; öffentliches Interesse gegeben; trotzdem wegen anderer Kriterien Fairnessverletzung); EGMR, Fefilov v. Russia, no. 6587/07, § 64, 17 July 2018 (Mordanklage; öffentliches Interesse stark; trotzdem wegen anderer Kriterien Fairnessverletzung); EGMR, Zherdev v. Ukraine, no. 34015/07, § 163, 27 April 2017 (Mordanklage; öffentliches Interesse stark; Fairnesswahrung wegen anderer Kriterien); EGMR, Farrugia v. Malta, no. 63041/13, § 114, 4 June 2019; EGMR, Doyle v. Ireland, no. 51979/17, § 96, 23 May 2019.

zu machen und dabei die Authentizität dieses Materials in Frage zu stellen. Ebenso kann sie nach der Exploration ihre Aussagen unverzüglich zurückziehen oder modifizieren. Diese Faktoren werden vom EGMR als potenziell fairnessindizierende Merkmale gewichtet.¹⁰¹⁵ Wiederum scheint klar, dass diese Faktoren einen eigenständigen, immer zu gewährenden Schutzaspekt eines fairen Verfahrens bilden, die Absenz der Verteidigung aber nicht kompensieren können.¹⁰¹⁶ Um effektive Einwendungen zu machen, müsste die beschuldigte Person und ihre Verteidigung diese adäquat beweisen können. Nun ist aber aufgrund der im 3. Teil geschilderten Intransparenz der Exploration bekannt, dass die beschuldigte Person mangels adäquater Dokumentation vor Beweisproblemen steht und sich regelmässig die Variante des Sachverständigen durchsetzt.¹⁰¹⁷ Damit bietet die Möglichkeit, Einwendungen gegen das gutachterlich rapportierte Tatsachengrundament zu formulieren, keinen ausreichenden verfahrensrechtlichen Schutz.

Selbiges muss für die Optionen des Aussagerückzugs oder -modifikation konstatiert werden. Greift die beschuldigte Person zu diesem Mittel, fallen die umstrittenen Aussagen nicht einfach dahin, sondern bleiben als Beweismittel verwertbar.¹⁰¹⁸ Das Gericht hat anschliessend in der Beweismittelwürdigung zu gewichten, welche Tatsachenschilderung glaubhafter ist.¹⁰¹⁹ Dabei wird das Gericht eher der Explorationsaussage als einem allfälligen Aussagerückzug oder einer Ausagemodifikation Glauben schenken, welche in den Augen des Gerichts durch strategische Erwägungen der Verteidigung «kontaminiert» wären.¹⁰²⁰ Die Verteidigungsstrategie der beschuldigten Person wird damit durch die ohne Anwalt erlangte Aussage unterminiert, da wohl befürchtet werden muss, dass eine spätere Abänderung als nicht glaubhaft eingestuft wird.¹⁰²¹ Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass auch dieser Faktor kaum etwas zugunsten der Fairnesswahrung beizutragen vermag.

¹⁰¹⁵ Vgl. N 298; jüngst EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 89 ff., 23 May 2019.

¹⁰¹⁶ CAIANIELLO, S. 294.

¹⁰¹⁷ Vgl. N 176 ff.

¹⁰¹⁸ Für die analoge Konstellation der Einvernahme: ZK StPO-GODENZI, Art. 160 N 5; OGer-ZH, 21. Januar 2015, SB140269, E. II.5.4; BGer, 29. Oktober 2012, 6B_362/2012, E. 9.5.2.

¹⁰¹⁹ Für die analoge Konstellation der Einvernahme: ZK StPO-GODENZI, Art. 160 N 5; OGer-ZH, 21. Januar 2015, SB140269, E. II.5.4; in der Sache auch BGer, 20. Januar 2004, 1P.261/2002, E. 4.4; BGer, 4. Februar 2015, 6B_907/2014, E. 4.3.

¹⁰²⁰ Vgl. auch HEER/COVACI, S. 446, welche zurecht bezweifeln, dass eine beschuldigte Person die in der Exploration gemachten Angaben später frei bestätigen oder widerrufen kann.

¹⁰²¹ EGMR, *Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine*, nos. 48016/06 and 7817/07, § 83, 10 November 2016: «It cannot be ruled out that, having given that statement without legal advice at an early stage of the proceedings, the first applicant might have found it prejudicial to change it at the trial. Accordingly, that early declaration may have undermined his defence in respect of that episode overall».

E) Würdigung durch professionelles Gericht

380

Als fairnesswahrendes Instrument könnte sodann die Tatsache angeführt werden, dass im schweizerischen Modell nicht eine Laienjury, sondern ein professionelles Gericht für die Beweiswürdigung bzw. die Beurteilung von Straftaten zuständig ist (Art. 10 Abs. 2 StPO; Art. 19 StPO). Dieses Kriterium wurde vom EGMR in seiner Fairnessbetrachtung noch nicht ausführlich erläutert und wird in der Praxis höchstens am Rande beigezogen, um ein Gesamtwürdigungsergebnis weiter abzustützen.¹⁰²² Klargestellt wurde in einer «Joint Partly Dissenting Opinion» immerhin, dass der Gesichtspunkt der Beweiswürdigung durch ein professionelles Gericht in Verbindung mit den vorangehend erwähnten Kriterien steht, ob eine Aussage prompt zurückgezogen oder modifiziert wurde und ob die beschuldigte Person Einwendungen gegen das Beweismaterial richten konnte.¹⁰²³ Dahinter steckt wohl die Annahme, dass ein professioneller Richter besser als eine Laienjury in der Lage ist, den Wert von Einwendungen oder Aussagezurückzügen/-modifikationen einzuschätzen und ihnen in der Beweiswürdigung das gebührende Gewicht zukommen zu lassen. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang aufgezeigt, dass die Möglichkeit, Einwendungen gegen das Beweismaterial zu erheben oder Aussagen zurückzuziehen oder zu modifizieren, keine effektiven Mittel darstellen, um eine in der Exploration ohne Anwalt erlangte Aussage effektiv in Frage zu stellen.¹⁰²⁴ Diese Feststellung dürfte bei einem Gericht in demselben Masse gelten. Damit muss die Würdigung der Beweise durch das Gericht als unzureichendes Remedium bezeichnet werden; ein faires Verfahren wird durch sein Vorliegen nicht gesichert.

3. Fazit: Verletzung von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK

381

Betrachtet man sämtliche Argumente für und wider die Verletzung der Verfahrensfairness, ist das Fazit klar: Die Regelbedingungen einer umstrittenen psychiatrischen Exploration im Rahmen von Art. 185 Abs. 4 StPO und der damit einhergehende Ausschluss der Verteidigung verletzen Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK. Das Begründungsgeflecht für diese Annahme fusst dabei auf folgenden Überlegungen: Mangels Anerkennung des grundsätzlichen Teilnahmerechts der Verteidigung in der Exploration in der Schweiz findet keine Belehrung über dieses Recht statt und es kann nicht von einem Verzicht der beschuldigten Person die

¹⁰²² EGMR, Zherdev v. Ukraine, no. 34015/07, § 163, 27 April 2017; EGMR, Artur Parkhomenko v. Ukraine, no. 40464/05, § 89, 16 February 2017; EGMR, Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine, nos. 48016/06 and 7817/07, § 79, 10 November 2016.

¹⁰²³ EGMR, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 30 f., 13 September 2016, (Joint Partly Dissenting Opinion of Judges Hejiyev, Yudkivska, Lemmens, Mahoney, Silvis and O'Leary).

¹⁰²⁴ Vgl. N 378 ff.

Rede sein. Kommt es zur Exploration, sind sämtliche ohne Verteidiger erlangten Explorationsaussagen im weiteren Verfahren verwertbar. Dabei bilden diese Angaben regelmässig einen signifikanten Teil des Tatsachenfundaments des Urteils; und zwar sowohl für die Gutachtensfragen als auch potenziell darüber hinaus (Tatnachweis, Strafzumessung). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Qualität der so erlangten Beweise ab initio mit Fragen versehen ist, da der Explorationsinhalt de lege lata hauptsächlich auf der Dokumentation des Sachverständigen und seinen mündlichen Aussagen vor Gericht beruht, wobei allfälligen Einwendungen der beschuldigten Person oder Aussagerückzügen oder -modifikationen in der Regel keinen Glauben geschenkt wird. Sodann ist zu bedenken, dass bei Schuldfähigkeits- und Massnahmenbegutachteten im Regelfall besonders vulnerable Personengruppen in einem herausfordernden verfahrensrechtlichen Kontext agieren. Diese Faktoren indizieren eine Konventionsverletzung.¹⁰²⁵

Diesen Eindruck vermögen die Indikatoren zugunsten der Annahme eines fairen Verfahrens nicht umzustossen. Zwar ist es unbestritten wichtig, dass eine Belehrung über das Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht stattfindet (Art. 185 Abs. 5 StPO), dass sich die beschuldigte Person vor der Exploration mit ihrer Verteidigung eine Verteidigungsstrategie zurechtlegen kann (freier Verkehr), dass sie nachträglich Einwendungen gegen die gutachterliche Rapportierung tätigen und ihre Aussagen modifizieren bzw. zurückziehen kann und dass ihre Aussagen von einem professionellen Gericht gewürdigt werden. Allerdings erweisen sich diese Faktoren eher als per se notwendige Pfeiler eines fairen Verfahrens, ohne dass sie die Abwesenheit der Verteidigung während der Exploration kompensieren könnten.¹⁰²⁶ Weder kann die Verteidigung gegen ungesetzliches Verhalten des Sachverständigen einschreiten, noch ist es ihr möglich, im Explorationskontext zu intervenieren, um eine optimale Ausschöpfung des Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrechts der beschuldigten Person (nemo tenetur) zu gewährleisten. Bei diesen Rahmenbedingungen kann nicht davon gesprochen werden, dass die Schweiz dem strengen Prüfungsmassstab gerecht geworden ist. Ein faires Verfahren konnte nicht nachgewiesen werden. Die Schweiz trägt die Folgen der Beweislast. Es ist eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK festzustellen. 382

¹⁰²⁵ Für den gesamten Abschnitt N 360 ff.

¹⁰²⁶ Vgl. N 371 ff.

§ 11 Ermittlung konventionskompatibler Lösungsmodelle

383 Nachdem in § 10 herausgearbeitet wurde, dass die schweizerische Rechtslage Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK verletzt, gilt es, die Suche nach einer konventionskompatiblen Lösung anzutreten. In diesem Rahmen sind sowohl teilnahme-rechtslose Lösungsansätze als auch ein Teilnahmerecht der Verteidigung zu analysieren. Die Auseinandersetzung mit diesen Modellen wird zeigen, dass einzig ein Teilnahmerecht der Verteidigung den Verteidigungsinteressen der beschuldigten Person in adäquater Weise Rechnung trägt.

I. Teilnahmerechtslose Lösungsansätze

1. Verbot der Befragung zum Tatsachverhalt

384 Eine verteidigungsrechtliche Optimierung des Status quo könnte darin bestehen, der sachverständigen Person zu verbieten, den Exploranden zum Tatsachverhalt zu befragen.¹⁰²⁷ Dieser Ansatz könnte durch eine restriktive Auslegung von Art. 185 Abs. 4 StPO realisiert werden. Die Intention ist klar: Durch das Verbot könnte die Gefahr, dass die Strafbehörde über die Exploration zu weiterem Beweismaterial für die zu ermittelnde Tat gelangt, reduziert werden, wobei es dem Sachverständigen mit den sonstigen Befragungsfeldern immer noch möglich wäre, ein Bild der Psyche der beschuldigten Person zu zeichnen.¹⁰²⁸ Bei näherem Hinsehen zeigt dieser Lösungsansatz aber Schwächen bezüglich seines Schutzgehalts (A.), seiner Methodenvereinbarkeit (B.) sowie seiner praktischen Handhabung (C.).

A) Fragmentarischer Schutzgehalt

385 Der zentrale Mangel des Verbots der Befragung zum Tatsachverhalt ist sein fragmentarischer Schutzcharakter. So wäre nemo tenetur nur unzureichend geschützt. Selbst bei Einhaltung des Verbots zur Befragung des Tatsachverhalts könnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Explorand spontan (ungefragt) zur Tat oder Aspekten davon zu äussern beginnt, ohne dass die abwesende Verteidigung dies unterbinden könnte. In diesem Fall wäre das Befragungsverbot vom Sachverständigen zwar eingehalten. Es verlöre aber seinen verteidigungsrechtlichen Gehalt.

¹⁰²⁷ FINCKE, S. 657; WHITE, S. 973 f.

¹⁰²⁸ WHITE, S. 973.

gungsrechtlichen Nutzen. Sodann existieren über den Tatsachverhalt hinaus weitere Sachverhaltskomplexe, bezüglich derer die beschuldigte Person das legitime Bedürfnis nach einer optimalen Aussagestrategie bzw. nach einer Beratung seitens der Verteidigung aufweist. So könnte die beschuldigte Person etwa unbekannte Taten offenbaren oder Informationen zu ihrer Person preisgeben, welche sich negativ auf die Strafzumessung auswirken. Weiter könnte sie Informationen preisgeben, welche für sie bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit negative Auswirkungen zeitigen. Ebenso wären prospektive Selbstbelastungsgefahren nicht gebannt, da die Tat bei massnahmenrechtlichen Fragestellungen nur einen Gesichtspunkt der gutachterlichen Beurteilung darstellt und sich Risikofaktoren aus anderen Befragungsbereichen ergeben können. Vor diesem Hintergrund bringt es der beschuldigten Person bestenfalls fragmentarischen Schutz, wenn sich das Befragungsverbot nur auf den Tatsachverhalt richtet. Sodann wäre zu bedenken, dass die beschuldigte Person bei ungesetzlichem Verhalten seitens des Sachverständigen nicht von schützenden Interventionen ihrer Verteidigung profitieren könnte. Damit erweist sich der verfahrensrechtliche Schutz dieses Instruments als lückenhaft.¹⁰²⁹

B) Einschnitt in Sachverständigenmethodik

Der Lösungsansatz des Befragungsverbots ist aber auch vor dem Hintergrund der psychiatrischen Explorationsmethodik suboptimal. Im Themenaufriß wurde ausführlich dargelegt, dass die Thematisierung der konkret vorgeworfenen Tat(en) einen zentralen Baustein jeder Exploration zur Frage der Schuldfähigkeit sowie Massnahmenindikation bildet.¹⁰³⁰ Anerkennt man den Wert von tatbezogenen Angaben des Exploranden, ist nicht abzustreiten, dass dem Sachverständigen durch das Befragungsverbot bezüglich des Tatsachverhalts eine wichtige Beurteilungsdimension im Explorationsgespräch für die Frage der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation genommen wird. Ein Befragungsverbot käme damit einem Einschnitt in die Methodenfreiheit des Sachverständigen gleich. Zwar ist dies alleine – wie in § 10 aufgezeigt¹⁰³¹ – nicht ausreichend, um diesen Lösungsansatz zu verwerfen, da die Sachverständigenmethodik nicht per se eine zu wahrende Grösse im Strafverfahren darstellt. Dennoch darf der Aspekt des Methodeneingriffs bei der Gesamtwürdigung aller Lösungsvarianten in die Beurteilung einfließen.

386

¹⁰²⁹ Kritisch auch FINCKE, S. 667 f.

¹⁰³⁰ Zur Relevanz des Tatsachverhalts für die gutachterliche Beurteilung, vgl. N 15.

¹⁰³¹ Vgl. N 344 ff.

C) Probleme der praktischen Umsetzung

- 387 Ein letzter Kritikpunkt des vorliegend diskutierten Lösungsansatzes ergibt sich aus seiner praktischen Handhabung. Es ist nämlich in vielen Konstellationen nur schwer zu beurteilen, was noch zum Tatsachverhalt gehört und was nicht.¹⁰³² Wäre etwa die Befragung zum Vorabend des behaupteten Tatsachverhalts noch eine Ermittlung zur Tat? Wie wäre es bei einem Verfahren wegen häuslicher Gewalt mit der Erfragung von Konfliktsituationen im Familienkreis in der Vergangenheit? Formell betreffen diese Fragen zwar nicht den Tatablauf im engeren Sinne (d.h. das tatbestandsmäßige und rechtswidrige Delikt), und doch liesse sich kaum abstreiten, dass sich aus ihnen tatrelevante Erkenntnisse ergeben können. Entsprechend gäbe es wohl öfters Streitigkeiten um die Zulässigkeit einzelner gutachterlicher Fragen, in denen zu klären wäre, ob gewisse Informationen noch zum Tatsachverhalt gehören oder nicht. Dabei wäre die Linienziehung im Einzelfall nicht einfach, womit ein Befragungsverbot auch vor diesem Hintergrund nicht als sinnvolle Lösung erscheint.

2. Audiovisuelle Aufzeichnung

- 388 Eine weitere verteidigungsrechtliche Optimierung des konventionswidrigen Status quo könnte darin bestehen, die Exploration audiovisuell aufzuzeichnen. Damit würde das Kriterium der Beweisqualität verbessert. Das Vorhandensein einer solchen Aufzeichnung wird folgerichtig auch vom EGMR als fairnessrelevantes Instrument im Rahmen von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK gewürdigt.¹⁰³³ Ebenso würdigt ein Teil der Lehre dieses Medium als Surrogat für ein Teilnahmerecht der Verteidigung.¹⁰³⁴

A) Optimierung der Transparenz

- 389 Eine solche Aufzeichnung hätte unbestritten Positiveffekte. Erstens liegt die Annahme nahe, dass das Faktum der Aufzeichnung bereits für sich genommen geeignet wäre, ungesetzliches Verhalten seitens des Sachverständigen zu verhindern (Präventiveffekt).¹⁰³⁵ Wenn solches Verhalten trotzdem stattfinden würde, bestünde zweitens eine authentische Dokumentation, um diese Mängel sei-

¹⁰³² FINCKE, S. 667; WHITE, S. 973 f.

¹⁰³³ EGMR, *Fefilov v. Russia*, no. 6587/07, § 62, 17 July 2018; EGMR, *Farrugia v. Malta*, no. 63041/13, § 117 (implizit), 4 June 2019; EGMR, *Doyle v. Ireland*, no. 51979/17, § 99, 23 May 2019; PIVATY, S. 76.

¹⁰³⁴ HEER/COVACI, S. 450.

¹⁰³⁵ Für die analoge Problematik bei der Einvernahme: PIVATY, S. 72; dazu auch US Court of Appeals, District of Columbia Circuit, *United States v. Byers*, 740 F2d 1104, Dissent Bazelon, N 170: «The very presence of a tape would help ensure that overreaching does not take place.»

tens der Verteidigung effektiv zu rügen.¹⁰³⁶ Diese Vorteile der audiovisuellen Aufzeichnung sind unbestritten und stellen der hier vertretenen Meinung – wie im 3. Teil dieser Arbeit begründet wurde – per se eine notwendige Bedingung dar, damit die konventionsrechtlich geforderte effektive Überprüfbarkeit des Gutachtens gemäss Art. 6 Ziff. 1 i.V.m. Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK gewährleistet werden kann.¹⁰³⁷ Allerdings vermag die audiovisuelle Aufzeichnung keinen ausreichenden verfahrensrechtlichen Schutz im Kontext von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK zu gewährleisten, wie aus den nachfolgenden Erwägungen hervorgeht.

B) Fragmentarischer Schutzgehalt

Zwar könnte der Explorationssachverhalt mit einer Aufzeichnung effektiv überprüft werden. Zentrale Verteidigungsinteressen blieben aber ungeschützt. Erstens könnten ungesetzliche Verhaltensweisen nur ex post gerügt werden, d.h. die beschuldigte Person könnte nicht während der Exploration von ihrer intervenierenden Verteidigung profitieren.¹⁰³⁸ Zweitens bliebe die Exploration als komplexe Selbstbelastungsarena bestehen, in der eine beschuldigte Person mit erhöhter Verletzlichkeit in einem Umfeld agiert, das in diverser Hinsicht Druckmomente auf nemo tenetur beinhaltet.¹⁰³⁹ Die in der Exploration aussen vorbleibende Verteidigung könnte im Rahmen der Exploration nicht intervenieren (Beratung über Schweigerecht, Unterbruch zwecks Besprechung etc.) und müsste sich nachfolgend auf der Aufzeichnung der Exploration ansehen, wie sich ihre Mandantin um Kopf und Kragen geredet hat.¹⁰⁴⁰ Gesamthaft betrachtet bildet die audiovisuelle Aufzeichnung daher einen willkommenen und unter dem Gesichtspunkt der Gutachtensüberprüfbarkeit notwendigen verfahrensrechtlichen Schutzfaktor. Er alleine ist aber nicht geeignet, um den verteidigungsrechtlichen Bedürfnissen – dem sofortigen Schutz vor ungesetzlichem Sachverständigenverhalten sowie nemo tenetur – Rechnung zu tragen.

3. Tatinterlokut

Eine weitere Option für die Adressierung der verteidigungsrechtlichen Herausforderungen könnte in der Zuteilung der Hauptverhandlung bestehen, wie sie Art. 342 StPO ermöglicht.¹⁰⁴¹ Der Fokus liegt dabei auf dem Tatinterlokut nach

¹⁰³⁶ HEER/COVACI, S. 450.

¹⁰³⁷ Vgl. N 278 ff.

¹⁰³⁸ PIVATY, S. 76: «Indeed, the added value of the lawyer's presence compared to other measures such as video-recording, is their ability to prevent or (re)act immediately to coercion or misconduct.»

¹⁰³⁹ Vgl. N 325 ff.

¹⁰⁴⁰ Vgl. dazu auch EGMR, Farrugia v. Malta, no. 63041/13, § 117, 4 June 2019.

¹⁰⁴¹ BRUNNER, Beratung, S. 139.

Art. 342 Abs. 1 lit. b StPO, bei dem «in einem ersten Verfahrensteil nur die Tatfrage und in einem zweiten die Schuldfrage sowie die Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden».¹⁰⁴²

A) Kein Tatnachweis qua Gutachten

392 Die Implementierung eines Tatinterlokuts hätte einen zentralen Positiveffekt: Die Frage des Tatnachweises wäre im Begutachtungszeitpunkt (bzw. dem Zeitpunkt, in dem das Gutachten in das Verfahren einfließt) bereits beantwortet. Daraus ergäbe sich der Vorteil, dass der Sachverständige seiner ungeliebten Rolle als «unwillkürlicher Indizienbeschaffer» entfliehen könnte, denn erfolgt die gutachterliche Ausleuchtung des Exploranden erst nach dem richterlich festgestellten Tatnachweis, kann diese nicht mehr zu seiner Überführung beitragen.¹⁰⁴³

B) Fragmentarischer Schutzgehalt

393 Trotz des voranstehenden Positiveffekts lassen sich diverse Schutzlücken ausmachen. Der verteidigungsrechtliche Schutzgehalt des Tatinterlokuts wäre auf den Tatnachweis beschränkt, d.h. die beschuldigte Person müsste nicht mehr befürchten, sich bezüglich der zu ermittelten Tat selbst zu überführen. Andere Risikofelder blieben aber bestehen. So könnte sich die beschuldigte Person etwa zu unbekannten Straftaten öffnen.¹⁰⁴⁴ Ebenso wäre es möglich, dass durch die Exploration Tatsachen bekannt werden, welche sich negativ auf die Strafzumessung oder die Beurteilung der Schuldfähigkeit auswirken. Bei massnahmenrechtlichen Fragen wäre überdies zu bedenken, dass die prospektive Selbstbelastungsgefahr unangetastet weiterbestünde.¹⁰⁴⁵ An diesen verteidigungsrechtlichen Herausforderungen würde das Tatinterlokut nichts ändern und gerade bei solchen Konstellationen hätte die beschuldigte Person ein Interesse, dass die anwesende Verteidigung sie bezüglich der optimalen Aussagestrategie beraten kann. Ebenso wäre mit einem Tatinterlokut kein Schutzmittel gegen ungesetzliche Verhaltensweisen des Sachverständigen während der Exploration geschaffen; d.h. die beschuldigte Person wäre diesen Verhaltensweisen ausgesetzt, ohne dass die Verteidigung intervenieren könnte. Damit muss der Schutzgehalt des Tatinterlokuts als unzureichend betrachtet werden.

¹⁰⁴² Zur Untauglichkeit des Schuldinterlokuts für die hier diskutierten Zwecke vgl. BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 19.

¹⁰⁴³ HADDENBROCK, S. 1303 ff.; BRUNNER, Beratung, S. 139; HABERMAYER/SACHS, N 6 (welche das Modell zu Unrecht als Schuldinterlokut bezeichnen); WHITE, S. 969.

¹⁰⁴⁴ Vgl. N 321.

¹⁰⁴⁵ Vgl. N 323.

C) Potenzielle Verfahrensverlängerung

Neben dem fragmentarischen Schutzgehalt ist zu bedenken, dass sich durch die Zweiteilung der Verhandlung wohl Verfahrensverzögerungen einstellen würden. In der Literatur wird dieses Argument zwar zuweilen bestritten und es wird vorgebracht, dass der Prozessstoff mit einer Interlokutlösung nicht erweitert werde.¹⁰⁴⁶ Dieses Argument vermag allenfalls für die isolierte Betrachtung der gerichtlichen Verhandlung Geltung zu beanspruchen.¹⁰⁴⁷ Jedoch kann nicht ignoriert werden, dass bei der Organisation zweier Verhandlungen administrative Mehraufwände anfallen.¹⁰⁴⁸ Was sodann die Phase zwischen den gerichtlichen Verfahrensteilen angeht, müsste für die Erstellung eines Gutachtens wohl eine Wartefrist in Kauf genommen werden.¹⁰⁴⁹ Anerkennt man diese Tatsache, muss das Tatinterlokut auch mit Blick auf die drohenden Verfahrensverzögerungen als unvollkommen bezeichnet werden.

4. Fiktion des fehlenden Beweiswerts von Explorationsangaben ausserhalb des Gutachtens

Eine implizit von SCHMID vertretene Position fusst sodann auf der Annahme, dass den im Gutachten genannten Angaben der vom Sachverständigen befragten Person «ausserhalb des Gutachtens, also etwa bezüglich des objektiven und subjektiven Tatbestands keinen Beweiswert» zukommt, soweit sie eine Person belasten könnten.¹⁰⁵⁰ Mit diesem Ansatz könnte vermieden werden, dass sich die beschuldigte Person bezüglich des Tatnachweises selbst belastet.

A) Fragmentarischer Schutzgehalt

Wie bereits beim Tatinterlokut begründet, weist die beschuldigte Person nicht nur auf den Tatnachweis bezogene Verteidigungsinteressen auf. Weder würde die Annahme des mangelnden Beweiswerts die beschuldigte Person vor ungesetzlichen Handlungen des Sachverständigen schützen, noch könnte die beschuldigte Person ihre Verteidigungsinteressen bezüglich der Sanktionsfrage (Schuldfähigkeit, Massnahmenindikation) mit einer optimalen Mitwirkungsstrategie wahren, da sie die (abwesende) Verteidigung diesbezüglich nicht während der Exploration beraten kann. Auf die beim Tatinterlokut gemachten Ausführungen ist insofern zu verweisen.¹⁰⁵¹

¹⁰⁴⁶ BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 23.

¹⁰⁴⁷ Darauf scheint LIEBER, S. 53 abzielen.

¹⁰⁴⁸ So die Konzession von BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 23.

¹⁰⁴⁹ WHITE, S. 975.

¹⁰⁵⁰ SCHMID, AJP 2010, S. 831.

¹⁰⁵¹ Vgl. N 393.

B) Instabilität der Beweiswertfiktion

397 Die mangelnde Tragfähigkeit des vorliegenden Modells ist sodann auch durch die Instabilität der Beweiswertfiktion begründet. So ist nicht sinnvoll zu beantworten, warum die Prämisse «kein Beweiswert der Angaben» nur mit Bezug auf die Beweisführung ausserhalb des Gutachtens gelten soll, aber dieselben Aussagen für das Gutachten von Bedeutung sein können. Wenn die Angaben einer vom Sachverständigen befragten Person tatsächlich ohne Beweiswert wären, dürften sie mangels Beweiswert auch innerhalb des Gutachtens nicht zur Beurteilung der Schuldfähigkeit oder Massnahmenindikation verwendet werden. Die These des fehlenden Beweiswerts ist somit nicht zu halten: Es kann nicht plausibel erklärt werden, warum die Schilderung der Angaben der beschuldigten Person im Gutachten und bei einer allfälligen Zeugenaussage des Sachverständigen vor Gericht, die unter der Strafdrohung nach Art. 307 StGB abgegeben wird, keinen Beweiswert haben soll. Auch darum muss der vorliegende Lösungsansatz als verteidigungsrechtlich untauglich zurückgewiesen werden.

5. Verwertungsverbote

398 Ein weiterer Lösungsansatz besteht darin, dass die von nemo tenetur geschützten Angaben des Exploranden mit einem Verwertungsverbot belegt werden. Diese Lösung beinhaltet prima vista durchaus fairnessrelevantes Potential, da vom EGMR der prozessualen Verwendung von Aussagen, die ohne Anwalt erlangt wurden, besondere Beachtung geschenkt wird.¹⁰⁵² Zwei Varianten sind zu diskutieren: ein Verwertungsverbot ausserhalb des Gutachtens (Variante I) und ein generelles Verwertungsverbot (Variante II).¹⁰⁵³

¹⁰⁵² Vgl. N 361.

¹⁰⁵³ Präzisierung: Die vorliegende Untersuchung geht mit der h.L. davon aus, dass Verwertungsverbote immer nur als Belastungsverbote zu interpretieren sind und eine Entlastung der beschuldigten Person durch Explorationsinhalte immer zulässig ist (vgl. BSK StPO-I-GLESS, Art. 141 N 116; ZK StPO-WOHLERS, Art. 141 N 12; THOMMEN/SEELMANN, fp 2016, S. 260 f.). Diese Annahme sieht sich durch die Rechtsprechung bestätigt: OGer-BE, 18. Juni 2012, BK 2012 62, E. 4.2; OGer-ZH, 24. April 2013, UH120368, E. 3.2.3.b; OGer-ZH, 3. Dezember 2015, SB150061, E. 3.6 f.; vor Erlass der StPO sodann BGer, 5. März 2001, 1A.303/2000, E. 2b; a.M. wohl DONATSCH/CAVEGN, ZStrR 2008, S. 166 f.

A) Verwertungsverbot ausserhalb des Gutachtens (Variante I)

Wie bereits ausgeführt wurde, könnte die bundesgerichtliche Rechtsprechung (zur Erinnerung: kein Vorhalt der Explorationsaussage im Verhör zum inkriminierten Sachverhalt) dahingehend interpretiert werden, dass sie ein Verwertungsverbot für die Angaben des Exploranden ausserhalb des Gutachtens stipuliert.¹⁰⁵⁴ Konkret bedeutet dies: Die Explorationsaussage dürfte für die Beurteilung der Schuldfähigkeit und für die Massnahmenindikation verwendet werden. Eine Verwertung derselben Explorationsaussagen für den Tatnachweis oder die Strafzumessung wäre hingegen unzulässig. 399

a) *Fragmentarischer Schutzgehalt*

Ein Verwertungsverbot von Explorationsinhalten ausserhalb des Gutachtens würde zwar die Gefahr adressieren, dass sich die beschuldigte Person durch die Explorationsaussage bezüglich der Tat oder der Strafzumessung belastet. Konkret könnte etwa ein in der Exploration abgegebenes Geständnis oder sonstige selbstbelastende Tatsachenmosaik nicht zum Nachweis der Tat oder für die Strafzumessung verwendet werden. Allerdings wurde bereits bei der Diskussion der Tatinterlokutlösung aufgezeigt, dass sich die Verteidigungsinteressen der beschuldigten Person in der Exploration nicht nur auf die Thematik des Tatnachweises oder der Strafzumessung beschränken. Vielmehr bestehen in keinem geringeren Masse legitime Verteidigungsinteressen, im Rahmen der zentralen Fragen zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation eine optimale Aussagestrategie durchzusetzen, da mit diesen Gutachtensthemen über das «Ob» oder »Wieviel« einer Strafe sowie allfällig schuldüberschreitende strafrechtliche Massnahmen entschieden wird. Vor diesem Hintergrund kann nicht sinnvoll erklärt werden, warum für die Feststellung des Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationssachverhalts weniger hohe verfahrensrechtliche Anforderungen (keine Verteidigeranwesenheit) gelten sollen als für den Tatnachweis und die Strafzumessung. Sodann ist zu bedenken, dass ein beschränktes Verwertungsverbot keinerlei Schutz vor ungesetzlichem Verhalten seitens des Sachverständigen während der Exploration bieten würde. Auf das beim Tatinterlokut Gesagte kann insofern verwiesen werden.¹⁰⁵⁵ Gesamthaft betrachtet muss der Schutzgehalt eines ausserhalb des Gutachtens anwendbaren Verwertungsverbots als fragmentarisch bezeichnet werden. 400

¹⁰⁵⁴ Vgl. N 313 ff.

¹⁰⁵⁵ Vgl. N 393.

b) *Systemwidrigkeit von Divergenzen zwischen Urteils- und Gutachtenssachverhalt*

401 Ein zweiter Kritikpunkt ergibt sich aus den praktischen Konsequenzen. Denkt man dieses Lösungsmodell konsequent zu Ende, würde es bedeuten, dass die sachverständige Person für die Beurteilung der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation auf einen anderen Sachverhalt abstellen darf als das Gericht.¹⁰⁵⁶ Beispielsweise wäre es möglich, dass das Gericht seine Verurteilung auf den Sachverhalt «ein Faustschlag ins Gesicht» fusst, während der Sachverständige bei seiner Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbeurteilung wegen anderer Aussagen der beschuldigten Person in der Exploration auf den Sachverhalt «zwei Faustschläge ins Gesicht und Tritte gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers») abstellt. Eine solche Spaltung des Urteils- und Gutachtenssachverhalts wäre jedoch systemwidrig.¹⁰⁵⁷ Könnte sich der Sachverständige tatsächlich «seinen» eigenen Sachverhalt (auch mit Blick auf die Tat) erarbeiten, ergäbe die strafbehördliche Pflicht, dem Sachverständigen bei der Beauftragung den relevanten (allenfalls umstrittenen) Sachverhalt vorzugeben¹⁰⁵⁸, nur beschränkt Sinn. Noch zentraler ist die folgende Erwägung zur Würdigung des Sachverständigenbeweises. Die Kompetenz zur Sachverhaltsfeststellung unterliegt der formellen Herrschaft des Gerichts.¹⁰⁵⁹ Nach Art. 189 Abs. 1 lit. a StPO ist ein Gutachten daher unvollständig, wenn der dem Gutachten zugrunde gelegte Sachverhalt vom gerichtlich festgestellten Sachverhalt abweicht.¹⁰⁶⁰ Und gerade mit dieser Vorgabe wäre ein beschränktes Verwertungsverbot nicht vereinbar, weil unter ihm Sachverhaltsdivergenzen zwischen gerichtlichem Urteil und Gutachtenssachverhalt möglich blieben.

¹⁰⁵⁶ FINGERHUTH, fp 2018, S. 549.

¹⁰⁵⁷ Kritisch auch FINGERHUTH, fp 2018, S. 549, der in diesem Zusammenhang von einem «leicht schizophrenen Szenario» spricht; ihm zustimmend HEER/COVACI, S. 446.

¹⁰⁵⁸ BGer, 20. Dezember 2017, 6B_989/2017, E. 3.3.9: «Ist der Sachverhalt unklar oder umstritten, hat die Behörde dem Sachverständigen klar zu machen, von welchen Tatsachen er auszugehen hat.»; AEBI ET AL., S. 1464; BSK StPO-I-HEER, Art. 184 N 31; ZK StPO-DONATSCH, Art. 184 N 42.

¹⁰⁵⁹ Vgl. N 116 f.

¹⁰⁶⁰ BGer, 1. November 2017, 6B_253/2017, E. 2.4; KassGer-ZH, 18. September 2006, AC050083, E. III.7.10.d; HELFENSTEIN, S. 238; BSK StPO-I-HEER, Art. 189 N 12 sowie Art. 184 N 17 «Es ist sicherzustellen, dass Gericht und Sachverständiger vom gleichen...Sachverhalt ausgehen.»; ZK StPO-DONATSCH, Art. 189 N 9.

B) Verwertungsverbot für von nemo tenetur geschützte Beweissubstrate (Variante II)

Den Limitationen der Variante I könnte man allenfalls entgehen, wenn die in der Exploration ohne Verteidigeranwesenheit erhobenen Zusatztatsachen (welche dem Schutz von nemo tenetur unterstehen) generell nicht verwertet werden dürfen.¹⁰⁶¹ Will man den Schutzgehalt nicht von vornherein entwerten, müsste es sich dabei um ein absolutes Verwertungsverbot handeln, das sich keiner Interessenabwägung (wie z.B. bei Art. 141 Abs. 2 StPO) öffnet.

a) Schutz von nemo tenetur

Zuerst soll auf den Positiveffekt dieses Lösungsmodells eingegangen werden: Nur die gutachterlichen Beobachtungen bezüglich des unbewussten Teils des Verhaltens der beschuldigten Person (d.h. die von nemo tenetur nicht geschützten Befundtatsachen, die unabhängig vom Willen der beschuldigten Person bestehen) dürften verwertet werden.¹⁰⁶² Die Verwertbarkeit von dem Gutachten zugrunde gelegten Zusatztatsachen würde hingegen voraussetzen, dass sie in einer strafbehördlichen Einvernahme justizförmig erhoben werden, wobei bei dieser die Anwesenheit der Verteidigung ohne Zweifel gewährleistet wäre (Art. 147 StPO). Durch die Einbettung einer solchen Verwertungsschranke würde die Exploration partiell ihres materiellen Einvernahmecharakters enthoben. Die Exploration hätte unter diesen Bedingungen einzig den Charakter eines durch besonderen Sachkunde vorgenommenen Augenscheins.¹⁰⁶³ Ruft man sich die Ausführung des EGMR vor Augen, dass die Annahme eines unfairen Verfahrens umso unwahrscheinlicher ist, wenn auf die ohne Anwalt erlangten Angaben nicht abgestellt wird¹⁰⁶⁴, wäre mit dieser Lösung ein grosser Schritt hin zur Wahrung der Verfahrensfairness gemacht.

b) Fragmentarischer Schutzgehalt

Trotz des unbestrittenen Positiveffekts ist das Instrument des Verwertungsverbots kein optimaler Lösungsansatz zur Gewährleistung eines fairen Verfahrens. Bereits allgemein ist zu bemerken, dass ein Verwertungsverbot in gewissem Widerspruch zur Gesetzessystematik stünde. Wenn Angaben der beschuldigten Person in der Exploration ohne die Teilnahme ihrer Verteidigung nicht verwertet werden dürften, gäbe es keinen Grund, den Sachverständigen zu verpflichten, eine Belehrung nach Art. 185 Abs. 5 StPO vorzunehmen. Wichtiger ist aber, dass mit einem Verwertungsverbot kein Schutz der beschuldigten Person wäh-

¹⁰⁶¹ Im Ansatz DONATSCH, fp 2012, S. 237 sowie DONATSCH, fp 2019, S. 140.

¹⁰⁶² Vgl. N 307 f.

¹⁰⁶³ Zu dieser Überlegung auch TOEPEL, S. 358 ff.

¹⁰⁶⁴ Vgl. N 298.

rend einer Exploration gewährleistet wäre (aa), dass die nicht verwertbaren Informationen womöglich als Ermittlungsansätze verwendet würden (bb) und dass die fraglichen Informationen trotz des Verwertungsverbots faktisch Einfluss in die Beweiswürdigung finden (cc).

aa) *Schutzdefizit während der Exploration*

405 Mit einem Verwertungsverbot wäre zwar nemo tenetur nominal weitgehend geschützt. Gleichzeitig gilt es zu bedenken, dass die beschuldigte Person auch ein Interesse daran hat, während der Exploration vor ungesetzlichem Verhalten seitens des Sachverständigen geschützt zu werden. So hätte die beschuldigte Person z.B. ein klar erkennbares Bedürfnis, dass die Verteidigung ein ausstandsbegründendes Verhalten im Rahmen der Exploration nicht nur registriert und im Ausstandsverfahren geltend macht, sondern dass sie dieses sofort während der fraglichen Verfahrenshandlung unterbindet. Gleich gestaltet sich die Sachlage mit Blick auf sonstige ungesetzliche Vorgehensweisen im Rahmen von Art. 140 StPO sowie des Verbots von Suggestivfragen. Die beschuldigte Person hätte hier ein durchaus legitimes Interesse daran, dass die Verteidigung solches Verhalten sofort unterbinden kann, und gerade dies könnte ein Verwertungsverbot nicht leisten.

bb) *Explorationsangaben als Ermittlungsansatz*

406 Neben dem voranstehend erwähnten Schutzdefizit wäre zu bedenken, dass die nicht verwertbaren Explorationsgehalte den Strafbehörden unter Umständen zusätzliche Ermittlungsansätze (z.B. Kenntnis neuer Beweismittel) eröffnen können.¹⁰⁶⁵ Diesem Problem könnte zwar begegnet werden, indem man das Verwertungsverbot mit Fernwirkung ausstattet, wie es z.B. Art. 141 Abs. 4 StPO vorsieht. Diese Ausgestaltung wäre aber bestenfalls dann effektiv, wenn neben den fraglichen Explorationsangaben weitere Beweise fehlen. Im Regelfall dürften jedoch andere Beweise vorliegen und gerade in diesem Fall wäre es wohl schwierig, den Schutzgehalt der Fernwirkung zum Tragen zu bringen, da die Fernwirkung nach Art. 141 Abs. 4 StPO nicht absolut gilt.¹⁰⁶⁶ Die Strafbehörde könnte bei dieser Sachlage mit Blick auf die sonstigen Beweise argumentieren, dass der relevante «Folgebeweis im Sinne eines hypothetischen Ermittlungsverlaufs zumindest mit einer grossen Wahrscheinlichkeit auch ohne den illegalen ersten Beweis erlangt worden wäre», womit der Folgebeweis verwertbar wäre.¹⁰⁶⁷ Dies wäre selbst dann der Fall, wenn es realiter die Explorationsaussage gewesen wäre, welche die Strafbehörde auf den Folgebeweis aufmerksam ge-

¹⁰⁶⁵ WHITE, S. 965.

¹⁰⁶⁶ BGE 138 IV 169, E. 3.3.2.

¹⁰⁶⁷ BGE 138 IV 169, E. 3.3.3.

macht hat. Auch vor diesem Hintergrund erweist sich der Schutzgehalt eines Verwertungsverbots als fragmentarisch.

cc) *Faktische Beeinflussung der Beweiswürdigung durch unverwertbare Angaben*

Sodann gilt es zu bedenken, dass unverwertbare Explorationsinhalte die Entscheidungsfindung faktisch kontaminieren können, selbst wenn das Gericht auf diese Tatsachen formell nicht abstellen darf.¹⁰⁶⁸ Zwar geht das Bundesgericht davon aus, dass vom Sachrichter erwartet werden kann, «dass er in der Lage ist, die unzulässigen Beweise von den zulässigen zu unterscheiden und sich bei der Würdigung ausschliesslich auf letztere zu stützen».¹⁰⁶⁹ Rechtstatsächlich kann aber kaum in Abrede gestellt werden, dass die richterliche Überzeugungsbildung durch bekannte, aber unverwertbare Tatsacheninhalte kontaminiert und bei der Entscheidungsfindung (bewusst oder unbewusst) informell doch auf solche Tatsachen abgestellt wird (auch als Rosa-Elefanten-Effekt¹⁰⁷⁰ bezeichnet).¹⁰⁷¹ Sofern andere Beweise bestünden, wäre die Gefahr evident, dass das Beweismaterial nun in seiner Beweiskraft als so hoch eingestuft wird, dass die fragliche Tatsache als in dubio pro reo erwiesen gilt, obwohl das relevante Mass an innerer Überzeugung des Richters tatsächlich durch die unverwertbaren Tatsachen mitgeprägt wurde.

Die analoge Gefahr bestünde im Übrigen auch für den Sachverständigen. Bestätigt der Explorand seine Explorationsangaben nicht anlässlich einer strafbehördlichen Beweisabnahme und sind die Explorationsangaben infolgedessen unverwertbar, hätte dies zur Folge, dass der Sachverständige seine Beurteilung an das neue Tatsachenfundament anpassen müsste (Art. 189 StPO). Dabei läge die Annahme nahe, dass der Sachverständige durch die (formell nicht verwertbaren) Aussagen der beschuldigten Person bei seiner erneuten Beurteilung tangiert wäre und nicht ohne Not von seiner vorherigen Beurteilung abrückt. Wie auch dem Richter läge es ihm wohl nahe, die bereits erreichten Schlussfolgerungen formell auf andere Beweise abzustützen, obwohl seine Beurteilung faktisch von den nicht verwertbaren Tatsachen mitgeprägt wird, womit das Verwertungsverbot seinen Schutzgehalt nur sehr limitiert entfalten könnte. Auch vor diesem

¹⁰⁶⁸ BERNHARD/STUDER, Schuldinterlokut, S. 16 f. im Kontext des Geständnisses, aber mit genereller Geltung: «Selbst wenn man eine solche Aussage als nicht direkt verwertbar ansähe, wäre sie trotzdem im Gutachten dokumentiert; zumindest unbewusst droht daher eine richterliche Beeinflussung.»

¹⁰⁶⁹ BGer, 30. März 2016, 1B_76/2016, E. 1.1.

¹⁰⁷⁰ BEYDOUN, S. 21 Fn. 70; GLESS, S. 346; TANNER, S. 169 Fn. 913.

¹⁰⁷¹ WOHLERS/BLÄSI, S. 169; GLESS, S. 346; BEYDOUN, S. 21 Fn. 70; TANNER, S. 169 Fn. 913; WHITE, S. 968 für das Jury-System.

Hintergrund ist der verteidigungsrechtliche Schutz eines Verwertungsverbots bestenfalls fragmentarisch.

c) *Methodeneingriff & Prozessökonomie*

- 409 Es wurde bereits mehrfach dargelegt, dass die sachverständige Person in der Exploration die beschuldigte Person in stundenlanger Arbeit befragt, dabei die Vergangenheit (Anamnese, Tatvorwurf), die Gegenwart (Psychostatus) als auch die Zukunft mit der beschuldigten Person bespricht und dadurch einen Teil des gutachtensrelevanten Sachverhalts erhebt.¹⁰⁷² Würde man nun von der Geltung eines Verwertungsverbots für Explorationsangaben ausgehen, wären die von nemo tenetur geschützten Angaben der beschuldigten Person latent der Gefahr der Unverwertbarkeit ausgesetzt. Anders gewendet: Wenn sich diese Angaben nicht im Rahmen einer strafbehördlichen Einvernahme bestätigen lassen würden (weil die beschuldigte Person schweigt oder andere Angaben macht), wären sie unverwertbar. Es müsste in diesem Fall durch die sachverständige Person eine neue Beurteilung, gestützt auf das strafbehördlich festgestellte Tatsachenfundament, stattfinden. Damit würde nicht nur ein Eingriff in die sachverständige Methodik erfolgen.¹⁰⁷³ Zusätzlich würden potenziell zahlreiche (bezahlte) Arbeitsstunden des Sachverständigen teilweise (mit Blick auf die Zusatztatsachen) beweisrechtlich nutzlos. Auch vor diesem Hintergrund ist ein Verwertungsverbot kritisch zu betrachten.¹⁰⁷⁴

C) **Exkurs: Untauglichkeit eines gerichtsbezogenen Verwertungsverbots**

- 410 Voranstehend wurde ausführlich begründet, warum die auf ein Verwertungsverbot orientierten Lösungsansätze keine umfassende Verwirklichung der Verteidigungsinteressen ermöglichen. In diesem Zusammenhang drängt es sich auf, einen weiteren Nebenaspekt zu beleuchten. So könnte man nämlich die bundesgerichtliche Praxis auch dahingehend interpretieren, dass die sachverständige Person sämtliche Angaben des Exploranden im Gutachten verwenden darf und erst das nachfolgend beweiswürdigende Gericht an das Verwertungsverbot gebunden ist.¹⁰⁷⁵ Eine solche Rechtsprechung hat das Bundesgericht im Kontext des Strafregisterrechts aufgestellt. Nach Art. 369 Abs. 7 StGB dürfen aus dem Strafregister entfernte Straftaten im Rahmen der gerichtlichen Strafzumessung

¹⁰⁷² Vgl. N 12 ff.

¹⁰⁷³ Vgl. etwa URBANIOK, S. 419 f., der die Geltung von Verwertungsverboten für die gutachterliche Risikobeurteilung kritisch würdigt.

¹⁰⁷⁴ Gl. M. wohl HEER/COVACI, S. 446.

¹⁰⁷⁵ Diese Lösung hätte nebenbei gesagt eine gewisse Ähnlichkeit zur bereits diskutierten Variante I des Verwertungsverbots (N 399 ff.). Insofern gelten die dort gemachten Kritikpunkte auch hier.

und Legalprognose nicht verwertet werden.¹⁰⁷⁶ Für den Sachverständigen gilt dieses Verwertungsverbot bei seiner Gutachtenserarbeitung jedoch nicht. Er darf aktenkundige Hinweise auf entfernte (d.h. unter Art. 369 StGB unverwertbare) Straftaten berücksichtigen. Es ist – so das Bundesgericht – insofern zwischen medizinischer Real- und gerichtlicher Legalprognose zu unterscheiden. «Um eine Umgehung des gerichtlichen Verwertungsverbots gemäss Art. 369 Abs. 7 StGB zu verhindern, muss in der Begutachtung jedoch offengelegt werden, inwiefern die frühere mit der neu zu beurteilenden Delinquenz in Zusammenhang steht (Konnexität) und wie stark sich diese weit zurückliegenden Taten noch auf das gutachterliche Realprognoseurteil auswirkt (Relevanz). So kann auch für die gerichtliche Beurteilung gewährleistet werden, dass allfällige Schlechtprognosen nur im Umfang der noch eingetragenen Vorverurteilungen berücksichtigt werden».¹⁰⁷⁷

Diese bundesgerichtliche Praxis wird im Schrifttum jedoch zurecht kritisiert. 411 Will der Gutachter dem bundesgerichtlichen Transparenzanspruch nachkommen, muss er im Rahmen des Konnexitäts- und Relevanznachweises zwei Beurteilungshypothesen aufstellen: Sachverhalt mit Berücksichtigung der unverwertbaren Vortat (Hypothese 1) und ohne Berücksichtigung der unverwertbaren Vortat (Hypothese 2). Nur so kann sichergestellt werden, dass sich das Gericht bei seiner Legalprognose nicht doch auf unverwertbare Sachverhalte abstützt. Bereits die Anwendung dieses Prinzips dürfte für den vorliegenden Kontext schwierig sein, weil es nicht um einen eng umrissenen Sachverhalt (Vortat oder Vortaten) geht, sondern die gesamten von nemo tenetur geschützten Beweissubstrate. Davon abgesehen kann nicht sinnvoll begründet werden, dem Gericht auf der Ebene der Realprognose zwei Optionen (eine mit Berücksichtigung der unverwertbaren Vortat, eine ohne) vorzuhalten, wenn ohnehin klar ist, dass sich das Gericht bei seiner Rechtsanwendung nur auf das verwertbare Tatsachenfundament stützen darf.¹⁰⁷⁸ Gegen diese Lösung spricht sodann, dass eine strikte Trennung zwischen gutachterlicher Real- und richterlicher Legalprognose kaum durchführbar ist, womit die Gefahr besteht, dass trotzdem unverwertbare Tatsachen ins Urteilsfundament einfließen.¹⁰⁷⁹ Vor dem Hintergrund dieser offen-

¹⁰⁷⁶ BGE 135 IV 87, E. 2.4; BGE 136 IV 1, E. 2.6.3.

¹⁰⁷⁷ BGE 135 IV 87, E. 2.5: «Wie bereits unter bisheriger Rechtsprechung ist ein Verwertungsverbot in Bezug auf Gutachten abzulehnen»; zuletzt ausdrücklich bestätigt in BGer, 16. Oktober 2017, 6B_281/2017, E. 2.4.1.

¹⁰⁷⁸ So auch FINGERHUTH, Anwaltspraxis, S. 371.

¹⁰⁷⁹ BOMMER/KAUFMANN, ZBJV 2014, S. 1029; FINGERHUTH, Anwaltspraxis, S. 371; BSK StGB-ARNOLD/GRUBER, Art. 369 N 10; mit einem ähnlichen Gedanken im Kontext der Fremdanamnese WOHLERS, Fremdanamnese, S. 84 f.: «Konsequenterweise muss man dann aber auch die Verwertung derartiger Erkenntnisse im Rahmen eines Gutachtens als unzulässig ansehen, weil dieses Gutachten ja zur Urteils-

sichtlichen Defizite eines gerichtsbezogenen Verwertungsverbots ist von einer Übertragung der Rechtsprechung nach Art. 369 Abs. 7 StGB auf den Untersuchungsgegenstand abzusehen.

II. Teilnahmerecht der Verteidigung

- 412 Die Fairness des Verfahrens könnte u.U. hergestellt werden, wenn der beschuldigten Person ein Teilnahmerecht im Rahmen der Exploration zugestanden wird. Damit würden die verteidigungsrechtlichen Bedürfnisse umfassend geschützt (A.). Doch auch bei diesem Vorgehen gibt es einige Bedenken, die zu prüfen sind (B).¹⁰⁸⁰

1. Globaler Schutz der Verteidigungsrechte

- 413 Die Verteidigung könnte mit ihren Interventionen während der Exploration ungesetzliches Verhalten seitens des Sachverständigen aktiv unterbinden. Ebenso könnte sie den Mandanten in der Exploration bezüglich der optimalen Mitwirkungs- bzw. Aussagestrategie (*nemo tenetur*) beraten.¹⁰⁸¹ Damit würde gesichert, dass die beschuldigte Person ihre Aussagen frei von Zwang und in Kenntnis der umfassenden Offenbarungspflicht des Sachverständigen tätigt.¹⁰⁸² Die anwesende Verteidigung böte der beschuldigten Person psychischen Beistand während einem entscheidenden Verfahrensschritt.¹⁰⁸³ Sodann könnte die Verteidigung die Sachverhaltsaufklärung durch Ergänzungsfragen befördern.¹⁰⁸⁴ Diese verfahrensrechtliche Ausgestaltung hätte nebenbei zur Folge, dass auch die nachfolgend mit dem Gutachten befassten Strafbehörden grundsätzlich davon ausgehen könnten, dass die Informationspreisgabe des Exploranden auf freiwill-

grundlage wird, womit sich dann die eigentlich einem Verwertungsverbot unterfallenden Erkenntnisse doch im Urteil niederschlagen würden.»

¹⁰⁸⁰ Bei den Gründen gegen ein Teilnahmerecht ist daran zu erinnern, dass der Eingriff in den Methodenstandard der Psychiatrie bereits als Einschränkungsgrund analysiert und verworfen wurde und vorliegend nicht erneut thematisiert wird. Vgl. N 347 ff.

¹⁰⁸¹ MARQUES LOPES, N 50; MEISTER, S. 446; im Kontext der Einvernahme auch PIVATY, S. 78 f.; weniger weitgehend HEER, FS Wiprächtiger, S. 201 und BSK StGB-HEER, Art. 56 N 64a, welche tendenziell von der Teilnahme der Verteidigung als passive Beobachterin ausgeht. Mit diesem Modell könnte die Verteidigung aber gerade ihre Schutzfunktion mit Blick auf *nemo tenetur* und auch darüber hinaus nicht entfalten.

¹⁰⁸² ARONSON, S. 91.

¹⁰⁸³ CLAAS, S. 26.

¹⁰⁸⁴ DRUSCHKE, S. 171; MARQUES LOPES, N 50.

liger und aufgeklärter Basis erfolgte (Absicherung von *nemo tenetur*).¹⁰⁸⁵ Der Verwertbarkeit von Angaben seitens der beschuldigten Person im Verfahren – und zwar sowohl für den Tatnachweis als auch für das Gutachten – stünde unter diesen Bedingungen keine Bedenken entgegen¹⁰⁸⁶, solange nicht ein ungesetzliches Verhalten seitens des Sachverständigen moniert wird. Es ergäbe sich ein globaler Schutz der Verteidigungsrechte durch die Teilnahme der Verteidigung in der Exploration.

2. Überwindbare Herausforderungen

A) Modifikation der Explorationsmodalitäten

Würde der Verteidigung ein Teilnahmerecht an der Exploration eingeräumt, hätte dies Auswirkungen auf die konkrete Durchführung der Exploration. Zwar wurde bereits vorangehend aufgezeigt, dass der psychiatrische Methodenstandard kein zwingender Grund ist, um den Ausschluss der Verteidigung zu legitimieren.¹⁰⁸⁷ Gleichwohl lässt sich kaum bestreiten, dass sich die sachverständige Person auf das neue Untersuchungssetting einzustellen hätte. Die dabei entstehenden Herausforderungen scheinen aber überwindbarer Natur zu sein. Ganz allgemein läge die Annahme nahe, dass sich initiale Schwierigkeiten der Verteidigereinbindung durch die Sensibilisierung und Weiterbildung von Sachverständigen¹⁰⁸⁸ und Strafverteidigern beheben lassen würden.

Methodisch sollte es dem Sachverständigen möglich sein, einen allfälligen Einfluss der Verteidigeranwesenheit in seiner Beurteilung zu berücksichtigen.¹⁰⁸⁹ Wäre dem nicht so, würde der psychiatrische Methodenstandard kaum die Freiheit des Sachverständigen enthalten, Dritte nach eigenem Ermessen zuzulassen.¹⁰⁹⁰ Konkret müsste die sachverständige Person dokumentieren, welche Angaben vom Exploranden und welche vom Verteidiger stammen und inwiefern die Drittpersonenanwesenheit die Exploration beeinflusste.¹⁰⁹¹ Dabei könnte der Dokumentationsaufwand des Sachverständigen in Grenzen gehalten werden,

¹⁰⁸⁵ ARONSON, S. 91.

¹⁰⁸⁶ HEER/COVACI, S. 446.

¹⁰⁸⁷ Vgl. N 344 ff.

¹⁰⁸⁸ HEER, FS Wiprächtiger, S. 200; kritischer hingegen die jüngere Auffassung bei HEER/COVACI, S. 444 (Überforderung der sachverständigen Person), aufgrund derer die Autoren anstelle der direkten Teilnahme der Verteidigung die audiovisuelle Übertragung in einen anderen Raum befürworten, wo legitimierte Dritte der Exploration folgen und im Rahmen ihrer Rechte mitwirken könnten.

¹⁰⁸⁹ OTTO/KRAUS, S. 368.

¹⁰⁹⁰ Vgl. N 20.

¹⁰⁹¹ Zu dieser Methodenvorgabe auch die sozialversicherungsrechtliche Praxis: BGE 140 V 260, E. 3.2.3; BROWN, S. 91; FRANCKE, S. 23.

wenn man der im 3. Teil vertretenen Position folgt, dass die Exploration audiovisuell aufgezeichnet wird. Neben diesem Aspekt hätte die sachverständige Person darauf zu achten, dass ihre Reaktion auf die Präsenz der Verteidigung nicht die Wahrnehmung des Exploranden tangiert (Selbstreflexion).¹⁰⁹² Doch auch diese Überlegung kann kaum als Grund gegen ein Teilnahmerecht der Verteidigung ins Feld geführt werden, da man dem Sachverständigen denselben Prozess (Selbstreflexion) ja auch dann zutraut, wenn er mit der beschuldigten Person alleine in der Exploration sitzt.¹⁰⁹³

B) Reflexwirkungen auf Teilnehmerzahl

- 416 Ein weiteres Argument gegen ein Teilnahmerecht der Verteidigung könnte lauten, dass durch diese Lösung weiteren Personen (z.B. Staatsanwaltschaft, Privatk Kläger) Teilnahmerechte eingeräumt werden müssten. Gerade diese Ratio wurde im 3. Teil u.a. dazu verwendet, ein Teilnahmerecht der Verteidigung als suboptimale Lösung zu bezeichnen.¹⁰⁹⁴ Wenn nun im 4. Teil für ein Teilnahmerecht der Verteidigung argumentiert wird, entsteht daraus kein Widerspruch. Dies ist wie folgt zu begründen: Das vorliegend hergeleitete Teilnahmerecht der Verteidigung wäre durch genuin beschuldigtenorientierte Gesichtspunkte (Schutz von nemo tenetur, Schutz vor ungesetzlichem Verhalten, psychischer Beistand) begründet.
- 417 Das Interesse der anderen Parteien wäre anders besetzt und würde sich auf die Herstellung der materiellen Wahrheit (Strafbehörden, Art. 6 StPO) bzw. das Recht auf Stellungnahme (Privatklägerschaft, Art. 6 EMRK) beziehen. Wird den Erkenntnissen des 3. Teils gefolgt und findet eine audiovisuelle Aufzeichnung der Exploration statt, könnte den legitimen Überprüfungsinteressen der Staatsanwaltschaft und des Gerichts sowie einer allfälligen Privatk lagerschaft gebührend Rechnung getragen werden; ihre Teilnahme wäre zur Sicherstellung ihrer prozessualen Interessen nicht notwendig, da sie ausreichende Kenntnis von der Exploration hätten und die beschuldigte Person oder den Sachverständigen ohne Weiteres nachträglich anlässlich einer Einvernahme befragen könnten.¹⁰⁹⁵ Dies

¹⁰⁹² BROWN, S. 91.

¹⁰⁹³ Vgl. N 188 f.

¹⁰⁹⁴ Vgl. N 236 ff.; BGE 132 V 443, E. 3.6.

¹⁰⁹⁵ Vgl. N 263; zutreffend sodann die allgemeine dogmatische Überlegung von VAN KAMPEN, S. 187, die zurecht betont, dass Waffengleichheit nicht Identität der Verfahrensrechte bedeutet, sondern dass jeder Partei jene Rechte zu gewähren sind, um ihre Rechtspositionen im Verfahren zu realisieren. Und gerade dies wäre der hier vertretenen Auffassung nach durch die audiovisuelle Aufzeichnung gewährleistet; a.M. wohl HEER/COVACI, S. 444 welche bei einem Teilnahmerecht der Verteidigung davon ausgehen, dass auch die Staatsanwaltschaft oder Privatk lagerschaft entsprechende Rechte haben müsste.

wäre für die beschuldigte Person anders, da deren Rechte (nemo tenetur, Schutz vor ungesetzlichem Verhalten) nur durch die unmittelbare Teilnahme der Verteidigung adäquat geschützt werden können.

Sodann kann auch die Annahme nicht gerechtfertigt werden, bei einer Teilnahme der Verteidigung an der Exploration ihrer Mandantin müsste eine die Begutachtung leitende Behörde eingesetzt werden.¹⁰⁹⁶ Diesem Einwand ist zu entgegenen, dass die sachverständige Person bereits im Status quo in der Exploration mit der beschuldigten Person kraft ihres Auftrags (Art. 184 StPO) faktisch verfahrensleitende Kompetenzen ausübt: So kann sie die beschuldigte Person zur Exploration aufbieten und die beschuldigte Person hat dem Folge zu leisten (Art. 185 Abs. 4 in fine). Sie belehrt die beschuldigte Person (Art. 185 Abs. 5 StPO) und führt mit ihr das Explorationsgespräch (Art. 185 Abs. 4 StPO). Wenn sie diese verfahrensleitende Funktion aber bereits mit der beschuldigten Person ausüben kann, sollte selbiges für ein Setting «beschuldigte Person inkl. Verteidigung» auch möglich sein, wenn man sich nicht in die Argumentation verstricken möchte, dass der Sachverständige seiner faktisch verfahrensleitenden Funktion in der Exploration nur solange nachkommen kann, wie ihm «nur» die beschuldigte Person als Laie gegenübersteht. Die Teilnahme einer begutachtungsleitenden Behörde wäre damit nicht notwendig. 418

C) Unzulässiges Verteidigerverhalten

Eine weitere Herausforderung der Verteidigerteilnahme im Explorationsgespräch könnte darin bestehen, dass die Verteidigung eine missbräuchliche Verteidigungsstrategie verwendet und damit die Erzielung eines brauchbaren Explorationsresultats verunmöglicht. Gerade in diesem Zusammenhang wird u.a. ein Neutralitätsverlust des Sachverständigen befürchtet.¹⁰⁹⁷ Auch diese Herausforderung scheint allerdings überwindbar zu sein. Folgt man der im 3. Teil vertretenen Meinung (audiovisuellen Aufzeichnung), wäre allfälliges Fehlverhalten der Verteidigung unverfälscht dokumentiert und könnte von der Verfahrensleitung mittels Ordnungsbusse sowie im Rahmen der standesrechtlichen Disziplinierungsmöglichkeiten geahndet werden.¹⁰⁹⁸ Wäre das Fehlverhalten dergestalt, dass die Exploration wiederholt werden müsste, könnten dem Verteidiger bei entsprechendem Verschulden kraft Art. 417 StPO die Kosten für die nutzlose Erstexploration auferlegt werden.¹⁰⁹⁹ Diese Sanktionsmittel dürften die Verteidigung davon abhalten, rechtswidriges Verhalten an den Tag zu legen. 419

¹⁰⁹⁶ Vgl. N 236 ff.; BGE 132 V 443, E. 3.6.

¹⁰⁹⁷ Vgl. N 19 und N 57.

¹⁰⁹⁸ BERNHARD/STUDER, ZStrR 2015, S. 93; SANER, S. 139.

¹⁰⁹⁹ SANER, S. 139.

420 Abgesehen davon dürfte die Gefahr rechtsmissbräuchlichen Verteidigerverhaltens in der Praxis limitiert sein, stellt es doch nicht die Aufgabe der Verteidigung dar, das Verfahren oder die Arbeit des Sachverständigen zu hindern, sondern an der Wahrheitssuche unter Wahrung der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person mitzuwirken.¹¹⁰⁰ In diesem Rahmen dürfte eine eigentliche Konfliktverteidigung kaum je im Interesse der beschuldigten Person sein, zumal dasselbe Resultat (Vernichtung von Explorationserkenntnissen) rechtmässig durch den konsequenten Rat zum Schweigen erreicht werden kann. In der Praxis wird es sich zum präventiven Abbau von Spannungen zwischen Sachverständigem und Verteidigung anbieten, dass vor der Exploration ein Gespräch geführt wird, in dem der Grobablauf der Exploration vorbesprochen wird.¹¹⁰¹

D) Kosten der Verteidigerteilnahme

421 Schliesslich könnte das Kostenargument gegen ein Teilnahmerecht der Verteidigung ins Feld geführt werden. Die Anwesenheit der Verteidigung am Explorationsgespräch wäre zu entschädigen, was zu einem Kostenanstieg führen würde. Gerade auch dieser Gesichtspunkt bildete in der Kommission des Nationalrats beim Erlass der StPO einen wesentlichen Aspekt, sich gegen die Implementierung eines gesetzlichen Teilnahmerechts der Verteidigung bei sachverständigen Erhebungen zu stellen, da ein Teilnahmerecht – so die Annahme – faktisch zu einer Teilnahmepflicht gedeihen würde, was mit massiven Kostenfolgen verbunden wäre.¹¹⁰² Allerdings ist dieser Gesichtspunkt zu differenzieren. Nimmt man den Stundensatz des Kantons Zürich für amtliche Mandate von CHF 220 als Referenzwert (§ 3 AnwGebV-ZH) und geht von einer Regelexplorationsdauer zwischen vier bis acht Stunden als grober Richtwert aus¹¹⁰³, betragen die Kosten für die Teilnahme der Verteidigung zwischen CHF 880 und CHF 1760 (exkl. Auslagen wie Reisespesen). Bei komplexeren Begutachtungen mit einer Explorationsdauer von z.B. 16 Stunden würden sich die Kosten der Verteidigerteilnahme auf CHF 3520 belaufen. Es ist zu bezweifeln, dass diese moderate Kostensteigerung ein taugliches Argument gegen die Teilnahme der Verteidigung bildet. Dieser Aufwand scheint angesichts des Gewinns an Rechtsstaatlichkeit im Rahmen der Exploration eine verkräftbare Summe zu sein. Anerkennt man sodann die Ergebnisse des 3. Teils und implementiert man die audiovisuelle Aufzeichnung als Dokumentationsstandard, wäre die Sichtung dieses Materials durch die Verteidigung sowieso als notwendiger Verteidigungsauf-

¹¹⁰⁰ MARQUES LOPES, N 50.

¹¹⁰¹ MEISTER, S. 446.

¹¹⁰² Protokoll RK-NR 22. Feb. 2007, S. 60.

¹¹⁰³ MAIER/MÖLLER, S. 163 gehen von einer Regeldauer von 4-8 Stunden aus, die im Einzelfall auch länger sein kann; vgl. zur Fallabhängigkeit auch Venzlaff et al.-DRESSING/FOERSTER, S. 16; KONRAD/RASCH, S. 312.

wand zu entschädigen. Würde die Verteidigung am Explorationsgespräch teilnehmen, würde dies unter kostentechnischen Gesichtspunkten somit nur in beschränktem Masse Zusatzaufwand bedeuten, da der Verteidigung wegen ihrer Anwesenheit die Kosten für die Sichtung der audiovisuellen Aufzeichnung nicht mehr zu erstatten wären (sie hat die Exploration ja unmittelbar wahrgenommen). Hinzu kommt, dass durch die Anwesenheit der Verteidigung wohl weniger Zeit für das Studium des Gutachtens und die Verfassung einer Stellungnahme (Art. 188 StPO) benötigt würde, womit ein Teil allfälliger Zusatzkosten kompensiert werden könnte.¹¹⁰⁴

III. Fazit

Betrachtet man die besprochenen Lösungsmodelle und ihre Vor- und Nachteile, scheiden das Verbot zur Befragung des Tatsachverhalts, das Tatinterlokt, die audiovisuelle Aufzeichnung sowie das ausserhalb des Gutachtens geltende Verwertungsverbot mangels ausreichendem Schutzgehalt sowie aufgrund der Schwierigkeiten ihrer praktischen Handhabung aus.¹¹⁰⁵ Ein auf sämtliche Zusatztatsachen gerichtetes Verwertungsverbot könnte zwar einen relativ grossen Schutz von nemo tenetur mit sich bringen. Bei näherer Betrachtung erweist sich aber auch dieser Ansatz als fragmentarisch: Weder wäre die beschuldigte Person unmittelbar vor ungesetzlichem Verhalten in der Exploration geschützt, noch könnte durchgehend vermieden werden, dass unverwertbare Explorationsangaben als Ermittlungsansatz für weitere Beweiserhebungen verwendet werden. Ebenso wenig wäre gewährleistet, dass unverwertbare Tatsachen faktisch die Beweiswürdigung des Gerichts bzw. die Beurteilung des Sachverständigen mitprägen.¹¹⁰⁶ 422

Im Gegensatz dazu sind die Nachteile des Teilnahmerechtsansatzes überwindbar. Der PSY-Sachverständige könnte den Einfluss der Verteidigerpräsenz in seinem Gutachten zum Ausdruck bringen. Vor rechtsmissbräuchlichem Verhalten seitens der Verteidigung wäre er insofern geschützt, als dass solches über Ordnungsbussen oder die Auferlegung der Untersuchungskosten nach Art. 417 StPO sanktioniert werden könnte. Sodann wäre die Kostensteigerung verkraftbar, wenn man der im 3. Teil vertretenen These folgt, dass die Exploration audiovisuell aufzuzeichnen wäre. Diese Aufzeichnung hätte überdies den positiven Nebeneffekt, dass sich auf die Einräumung weiterer Teilnahmerechte der Staatsanwaltschaft usw. verzichten liesse, da deren Rechte ohne Weiteres nachträglich 423

¹¹⁰⁴ BRUNNER, plädoyer 3/2005, S. 42.

¹¹⁰⁵ Vgl. N 384 ff.

¹¹⁰⁶ Vgl. N 398 ff.

(z.B. anlässlich einer Einvernahme) ausgeübt werden könnten.¹¹⁰⁷ Diesen Herausforderungen stünde der Vorteil gegenüber, dass die Verteidigungsrechte mit der Anwesenheit der Verteidigung umfassend geschützt wären und insbesondere nemo tenetur Nachachtung verschafft würde. Dadurch würde sich u.a. auch der Nebeneffekt einstellen, dass die Angaben der beschuldigten Person ohne Bedenken verwertet werden könnten, wenn die anwesende Verteidigung keine Rechtsverletzungen bei der Exploration moniert. Schliesslich hätte die beschuldigte Person einen psychischen Beistand zur Seite gestellt, welche die Sachverhaltsaufklärung durch allfällige Ergänzungsfragen verbessern könnte.¹¹⁰⁸ Betrachtet man diese Faktoren in einer Gesamtwürdigung, sticht das Teilnahmerecht der Verteidigung als Musterlösungsansatz hervor.

¹¹⁰⁷ Vgl. N 414 ff.

¹¹⁰⁸ Vgl. N 413 ff.

Schlussbilanz

I.

Vor Erlass der StPO äusserte sich Ständerat Franz Wicki zuversichtlich: «Es ist ein Gesetz für die Zukunft.»¹¹⁰⁹ Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand konnte diese Aussage widerlegt werden. Der juristische Status quo im Rahmen der psychiatrischen Begutachtung zur Schuldfähigkeit- und/oder Massnahmenindikation vermag die Mindestanforderungen der EMRK nicht zu erfüllen. Dabei gilt es, das Kredo des Vereinheitlichungsprozesses in Erinnerung zu rufen: «Bewährtes zu übernehmen, bedeutet nicht, sich Neuem zu verschliessen».¹¹¹⁰ Das neue Element bildet die Erkenntnis, dass ein faires Verfahren im Kontext des Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachtens sinnvollerweise nur mit einem Teilnahmerecht der Verteidigung anlässlich des audiovisuell aufgezeichneten Explorationsgesprächs des PSY-Sachverständigen mit der beschuldigten Person erfolgen kann. Den Weg zu dieser Schlussfolgerung gilt es in Kürze zu rekapitulieren. 424

II.

Ausgangspunkt der Untersuchung bildete die Analyse des juristischen Status quo. Bei dieser zeigte sich, dass sich das Bundesgericht im Rahmen der Verfassungspraxis (Art. 29 ff. BV) konstant gegen Teilnahmerechte an sachverständigen Erhebungen aussprach. Wegleitend für diese Praxis ist das Argument, dass das nachträgliche Recht auf Stellungnahme den Anforderungen an das rechtliche Gehör genügt. Sodann wird vom Bundesgericht hervorgehoben, dass Teilnahmerechte mit dem psychiatrischen Methodenstandard unvereinbar sind. Schliesslich existiert die Befürchtung, dass durch ein Teilnahmerecht des Rechtsbeistands an der Exploration über das Prinzip der Waffengleichheit weitere Teilnahmerechte von anderen Parteien notwendig werden.¹¹¹¹ Die Verfassung bietet somit im Status quo kein Fundament für ein Teilnahmerecht der Verteidigung. 425

III.

In einem nächsten Schritt gelang es aufzuzeigen, dass die StPO die verfassungsrechtliche Praxis spiegelt. Auch unter dem Geltungsbereich der StPO sollte die Verteidigung nach der Vorstellung des Gesetzgebers kein Teilnahmerecht am Explorationsgespräch haben. Dieses Auslegungsergebnis sieht sich durch die 426

¹¹⁰⁹ Amt. Bull 2006, S. 982.

¹¹¹⁰ Botschaft StPO S. 1087.

¹¹¹¹ Für den Absatz N 43 ff.

kantonalrechtliche und verfassungsrechtliche Ausgangslage, den klaren Wortlaut von Art. 147 Abs. 1 StPO und den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens (Verwerfen von Anträgen für ein Teilnahmerecht der Verteidigung) bestätigt. Es überrascht insofern nicht und ist korrekt, dass ein Grossteil der Lehre und sämtliche Gerichte die Anwendbarkeit von Art. 147 StPO auf sachverständige Erhebungen verneinen.¹¹¹² Die Frage war nun, ob sich aus der EMRK eine andere Erkenntnis ergibt.

IV.

427 Der 3. Teil dieser Arbeit analysierte, ob ein Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch ihrer Mandantin zur Gewährleistung der Überprüfbarkeit des Gutachtens von Bedeutung ist. Ausgangspunkt bildete die Erkenntnis, dass der psychiatrische Sachverständige im Rahmen des Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsgutachtens sowohl auf der Ebene der Sachverhaltsermittlung, der Beweiswürdigung sowie der Rechtsanwendung massgeblichen Einfluss auf die gerichtliche Entscheidung hat. Gleichzeitig konnten systemimmanente Neutralitätsdefizite ausgemacht werden, da der Sachverständige durch die Staatsanwaltschaft beauftragt wird, faktisch eine partielle Personalunion von ermittelnder und entscheidender Funktion verkörpert und dem politisch-medialen Druck ausgesetzt ist. Diese Neutralitätstangenten wurden als gewichtige Defizite eingestuft, weil die psychiatrische Begutachtung im Rahmen der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation Ermessensspielräume aufweist, wodurch der Person des Sachverständigen eine grosse Bedeutung zukommt.¹¹¹³

428 Wegen der so beschaffenen Position und Rolle des Sachverständigen wurde die Forderung gestellt, dass die Verteidigungsrechte von herausragender Effektivität sein müssen. Daran fehlt es im Kontext des Explorationsgesprächs: Es bestehen unüberwindbare Transparenzdefizite. Die gutachterliche Rapportierung des Explorationssachverhalts stellt keine objektive Schilderung, sondern das Resultat einer subjektiven Wahrnehmung dar, das zwangsläufig mit mehr oder minder intensiven Verzerrungen und Lücken einhergeht. Für die beschuldigte Person gilt dasselbe. Sie ist darüber hinaus in besonderer Weise nicht in der Lage, den Explorationssachverhalt adäquat zu rekonstruieren (mangelnde Beobachterstellung, besondere Verletzlichkeit, mangelndes Fachwissen). Selbst wenn sie ausnahmsweise in der Lage wäre, einen Einwand zu formulieren, sähe sie sich bei der notwendigen Aussagewürdigung seitens des Gerichts mit dem Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten der sachverständigen Person konfrontiert und könnte ihre Einwendungen nicht anderweitig beweisen. Diese Transparenzdefizite können weder durch die Einreichung eines (im Beweiswert herabgesetzten) Privatgutachtens noch durch strafbehördliche Interventionen (Art. 189 StPO) kompensiert

¹¹¹² Für den Abschnitt N 67 ff.

¹¹¹³ Für den Abschnitt N 110 ff.

werden. Vor diesem Hintergrund musste eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 i.V.m. Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK festgestellt werden.¹¹¹⁴

Bei der Suche nach konventionskompatiblen Lösungsmodellen ergab sich, dass die Optimierung der Position und Rolle des Sachverständigen (Beauftragung durch das Gericht, Doppelbegutachtung) kein ausreichendes Remedium ist, da damit die Transparenzdefizite des Gutachtens in keiner Weise behoben werden. Die Lösung musste damit zwischen einem Teilnahmerecht der Verteidigung oder der Aufwertung der Dokumentationsstandards gesucht werden. Ersterer Ansatz vermochte nicht zu überzeugen. Nicht nur bliebe bei streitigem Explorationssachverhalt ein partielles Glaubhaftigkeits-Bias zugunsten des Sachverständigen bestehen. Ebenso wäre zu berücksichtigen, dass auch die Staatsanwaltschaft und allfällige Privatk Kläger schützenswerte Überprüfungsinteressen bezüglich der Exploration aufweisen. Möchte man diesen genügen, müssten ihnen wohl ebenfalls Teilnahmerechte an der Exploration eingeräumt werden, was nicht nur aufwändig wäre, sondern die Exploration wohl auch inhaltlich vor hohe Hürden stellen würde. 429

Sinnvoll erschien daher die Aufwertung des Dokumentationsstandards. Wegen der Lückenhaftigkeit und der drohenden Überforderung des Exploranden wurde eine Protokollierungspflicht verworfen. Ebenso konnte die Tonbandaufnahme nicht überzeugen, da sie sämtlichen visuellen Aspekte der Exploration nicht einfängt. Nur die audiovisuelle Aufzeichnung vermag sämtliche Informationsebenen der psychiatrischen Exploration zu erfassen und gewährleistet damit die Transparenz, welche für eine effektive Überprüfung des Gutachtens erforderlich ist. Sie hat den Vorteil, mit der psychiatrischen Methodik vereinbar zu sein und geht mit zahlreichen weiteren Positiveffekten (Leistungsmöglichkeit des Sachverständigen während Exploration, Ausbildung etc.) einher. Die gegen diese Lösung hervorgebrachten Argumente (Aufzeichnung als Störfaktor, weiterbestehende Interpretationsspielräume, Verfahrensverlängerung, Persönlichkeitsschutz, logistische Argumente) konnten entweder widerlegt werden oder waren als Preis für die Gewährleistung eines fairen Verfahrens hinzunehmen. Vor diesem Hintergrund schloss der 3. Teil mit der Feststellung, dass eine effektive Überprüfbarkeit des Sachverständigenbeweises mit Blick auf die Exploration durch eine audiovisuelle Aufzeichnung realisiert werden sollte.¹¹¹⁵ 430

V.

Im 4. Teil war zu prüfen, ob sich ein Teilnahmerecht der Verteidigung an der Exploration aus Schutzinteressen der beschuldigten Person während der Exploration ergibt. Dafür war Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK näher zu betrachten. Kraft dieser Norm gilt bereits im Vorverfahren das Recht der beschuldigten Person, 431

¹¹¹⁴ Für den Abschnitt N 176 ff.

¹¹¹⁵ Für den Abschnitt N 222 ff.

die Verteidigung beizuziehen, was sowohl den freien Verkehr als auch ein Teilnahmerecht der Verteidigung an strafbehördlichen Einvernahmen umfasst. Nun war zu prüfen, ob sich diese Gerichtspraxis auf die psychiatrische Exploration übertragen lässt. Dafür galt es das Leitbild zu widerlegen, wonach die Exploration keine Einvernahme ist. Diese Aufgabe gelang in mehreren Schritten. Zuerst konnte dargelegt werden, dass in der Exploration – wie in der Einvernahme – willensabhängige Beweissubstrate (insb. Aussagen) von der beschuldigten Person erhältlich gemacht werden, welche unter dem Schutz von *nemo tenetur* stehen. Diese können, sofern eine rechtskonforme Belehrung des Exploranden erfolgt (Art. 185 Abs. 5 StPO), vom Gericht verwertet werden. Daraus ergab sich, dass sich die beschuldigte Person in der Exploration in vielfältiger Hinsicht retrospektive (Tatnachweis, Schuld, Strafzumessung) und prospektive (Massnahmenrecht) belasten kann.¹¹¹⁶

432 In einem weiteren Schritt wurde aufgezeigt, dass die Exploration in keiner geringeren Weise als die Einvernahme psychischen Druck auf den durch *nemo tenetur* garantierten freien Kooperationsentscheid bewirkt, da der Sachverständige mit seinem Informationsinteresse und der öffendenden Gesprächstechnik an die beschuldigte Person herantritt und es letzterer schwer fallen wird, sich diesem Informationsinteresse zu entziehen, zumal sie mangels Fachwissen nur selten weiss, wann welche (Nicht)kooperation angebracht ist. Sodann ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es der beschuldigten Person trotz der Belehrung nach Art. 185 Abs. 5 StPO oft schwer fallen wird, sich über das ganze Gespräch hinweg bewusst zu bleiben, dass ihr nicht der schweigepflichtige Arzt, sondern der offenbarungsverpflichtete Sachverständige gegenübersteht. Durch diese latente (unbeabsichtigte) Täuschungsdimension besteht die Gefahr, dass sich die beschuldigte Person weitergehend öffnet, als sie dies gegenüber den Strafbehörden getan hätte, wodurch der durch *nemo tenetur* geschützte freie (aufgeklärte) Kooperationsentscheid untergraben wird. Hinzu kommt, dass die beschuldigte Person aufgrund allgemeiner Rahmenbedingungen (Komplexität des Kooperationsentscheids, Abhängigkeit vom Sachverständigen, Bedeutung der Schuldfähigkeits- und Massnahmenfrage, Druck des Strafverfahrens) sowie der regelmässig vorliegenden psychopathologischen Symptome eine besondere Verletzlichkeit aufweist und dem Informationsinteresse des Sachverständigen nur wenig Widerstandskräfte entgegensetzen kann. Schliesslich gelang es, aufzuzeigen, dass die beschuldigte Person auch in der Exploration ein Bedürfnis hat, vor ungesetzlichem Verhalten des Sachverständigen geschützt zu werden und dass die Feststellungen des Sachverständigen durchaus determinierende Wirkungen für das gerichtliche Verfahren haben. Vor dem Hintergrund dieser Faktoren konnte der Schluss gezogen werden, dass zwischen Einvernahme und Exploration materielle Kongruenz vorherrscht. Es rechtfertigte sich somit, die

¹¹¹⁶ Für den Abschnitt N 300 ff.

konventionsrechtlichen Leitlinien zur Einvernahme im Vorverfahren und das damit verbundene Teilnahmerecht der Verteidigung auf den Explorationskontext zu übertragen.¹¹¹⁷

Auf Basis dieser Erkenntnis wurde geprüft, ob die Fachmethodik des psychiatrischen Sachverständigen (Ausschluss von Drittpersonen nach Ermessen des Sachverständigen) einen zwingenden Grund zum Ausschluss der Verteidigung bilden könnte. Es zeigte sich, dass dieser Ausschlussgrund zwar internationale Anerkennung findet, aber gleichwohl keine legitime Basis bildet, den Ausschluss der Verteidigung zu begründen. Die Störungsprämisse des passiv anwesenden Verteidigers ist instabil, da in der strafprozessualen Exploration gar kein Vertrauensverhältnis vorliegt, das schützenswerter Natur wäre, und weil erst noch zu begründen wäre, warum die Anwesenheit einer Hilfsperson oder eines Übersetzers bei der Begutachtung berücksichtigt werden kann, selbiges aber bei einem passiv-anwesenden Verteidiger nicht möglich sein soll. Ebenso konnte aufgezeigt werden, dass es wahrscheinlicher ist, dass sich die von der Verteidigung begleitete beschuldigte Person in der Exploration extensiver öffnet, als wenn sie alleine mit dem Sachverständigen in der Exploration sitzt. 433

Was sodann die aktive Intervention der Verteidigung angeht, konnte aufgezeigt werden, dass im verfahrensrechtlichen Gesamtkontext nicht von einer Störung gesprochen werden kann. Wenn die Verteidigung gegen ungesetzliches Verhalten des Sachverständigen interveniert, stellt dies keine Störung, sondern die Gewährleistung eines justizförmigen Verfahrens dar. Wenn die Verteidigung der beschuldigten Person zum Schweigen rät oder sich mit ihr besprechen will, wird damit kein Zusatzrecht implementiert, sondern nur die effektive Ausübung des bestehenden Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrechts abgesichert (nemo tenetur; Art. 185 Abs. 5 StPO). Vor diesem Hintergrund konnte die Störungsthese nicht aufrechterhalten werden. Neben der mangelnden inhaltlichen Legitimation zeigte sich, dass der EGMR nur schwerwiegende Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit als zwingende Gründe anerkennt, wobei Ausschlussgründe gesetzlich verankert sein müssen und nicht generell-abstrakter Natur sein dürfen. Der Ausschluss der Verteidigung in der Exploration vermochte auch diesen Anforderungen nicht zu genügen. Nicht nur erfolgt der Ausschluss nach geltendem Recht faktisch generell-abstrakt. Durch ihn werden auch keine unmittelbaren Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit abgewendet, sondern es wird lediglich eine Fachmethodik geschützt, welche sich als strafbehördliches Ermittlungsinteresse im wissenschaftlichen Kleid entpuppt. Das Vorliegen eines zwingenden Grunds zum Ausschluss der Verteidigung musste vor diesem Hintergrund zurückgewiesen werden.¹¹¹⁸ 434

¹¹¹⁷ Für den Abschnitt N 325 ff.

¹¹¹⁸ Für den Abschnitt N 344 ff.

- 435 Mangels zwingender Gründe für den Ausschluss der Verteidigung musste das schweizerische Verteidigungsdispositiv im Rahmen der Gesamtwürdigung einem besonders strengen Prüfungsmassstab genügen. Dem schweizerischen Verfahrensmodell oblag vor dem EGMR die Beweislast für den Nachweis eines fairen Verfahrens. Ein solcher Nachweis konnte nicht erbracht werden. Die Indikatoren für eine Fairnessverletzung (Verwertbarkeit der Explorationsinhalte, hohe Signifikanz des erlangten Beweismaterials, mangelnde Transparenz der Exploration, besondere Verletzlichkeit des Exploranden, kein Verzicht auf Anwalt) überwiegen die Indikatoren für eine Wahrung der Verfahrensfairness (Belehrung über *nemo tenetur*, freier Verkehr mit der Verteidigung vor Exploration, öffentliches Interesse an Aufklärung der Straftat, Möglichkeit von Einwendungen, Aussagerückzug oder -modifikation sowie die Würdigung durch ein professionelles Gericht). Weder kann die beschuldigte Person vor ungesetzlichem Verhalten des Sachverständigen durch die Verteidigung geschützt werden, noch kann eine effektive Aussagestrategie sichergestellt werden. Bei diesen Bedingungen konnte das Fazit gezogen werden, dass die geltende verfahrensrechtliche Ausgestaltung der Exploration unter Ausschluss der Verteidigung eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK darstellt.¹¹¹⁹
- 436 Nachfolgend wurde nach einer konventionskompatiblen Lösung gesucht. Es zeigte sich, dass ein Verbot der Befragung zum Tatsachverhalt, die audiovisuelle Aufzeichnung oder ein Tatinterlokut nur fragmentarischen Schutz bieten. Die Lösung musste zwischen einem Verwertungsverbot sowie dem Teilnahmerecht der Verteidigung an der Exploration gesucht werden. Nachdem ein ausserhalb des Gutachtens geltendes Verwertungsverbot aufgrund seines fragmentarischen Schutzgehalts sowie seiner Systemfremdheit verworfen werden musste, konnte selbiges für ein generelles Verwertungsverbot bezüglich der von *nemo tenetur* geschützten Beweissubstrate nicht leichthin getan werden. Eine nähere Betrachtung zeigte, dass mit einem Verwertungsverbot *nemo tenetur* zwar nominal gewahrt würde, aber dass die Schutzinteressen der beschuldigten Person während der Exploration unerfüllt blieben, die Exploration neue Ermittlungsansätze liefern könnte und die nicht verwertbaren Beweise geeignet wären, die Urteilsfindung faktisch mitzuprägen. Aus diesen Gründen musste auch das Lösungsmodell des Verwertungsverbots aufgrund seines fragmentarischen Schutzgehalts zurückgewiesen werden.¹¹²⁰
- 437 Das Teilnahmerecht der Verteidigung vermag demgegenüber einen globalen Schutz der Verteidigungsinteressen der beschuldigten Person während der Exploration (insb. auch *nemo tenetur*) zu bieten. Die damit verbundenen Herausforderungen sind überwindbar. So ist es der sachverständigen Person möglich, die Auswirkungen der Verteidigerpräsenz im Gutachten zu beschreiben. Die

¹¹¹⁹ Für den Abschnitt N 360 ff.

¹¹²⁰ Für den Abschnitt N 383 ff.

Gefahr von unzulässigem Verteidigerverhalten wäre angesichts des zulässigen Rats zum Schweigen überschaubar und, wenn es sich doch ereignet, sanktionierbar (Ordnungsbusse und Art. 417 StPO). Schliesslich würden sich die Zusatzkosten eines Teilnahmerechts wohl in verkraftbaren Dimensionen bewegen. Diese Herausforderungen der Umsetzung eines Teilnahmerechts vermögen die Vorteile nicht zu überwiegen. Mit der Teilnahme der Verteidigung am Explorationsgespräch fände ein notwendiges Gegengewicht seinen Platz, das die Waffengleichheit und das darauf fussende faire Verfahren gewährleistet sowie einen notwendigen Baustein zur Legitimation des Strafverfahrens bildet.¹¹²¹

VI.

Zusammenfassend gelangt die vorliegende Arbeit zu folgendem Fazit: Nimmt man die beschuldigte Person als Verfahrenssubjekt mit ihren Verteidigungsrechten ernst, muss ein faires Verfahren im Rahmen der Schuldfähigkeits- und Massnahmenindikationsbegutachtung eine audiovisuelle Aufzeichnung der Exploration und ein Teilnahmerecht der Verteidigung beinhalten. Diese Position wird zwar in Teilen der forensischen Psychiatrie zu Widerspruch führen. Die vorliegende Situation spiegelt gewissermassen die Ausgangslage vor der Einführung des Anwalts der ersten Stunde (Art. 159 StPO). Hätte man die damals aus Strafverfolgungskreisen geäusserten Stellungnahmen (Gefährdung der Wahrheitssuche durch den anwesenden Anwalt) zum Nennwert genommen, «hätte die Einführung des Anwalts der ersten Stunde den unmittelbaren Zusammenbruch der Strafverfolgung...bewirken müssen. Wir alle wissen, dass es so nicht gekommen ist.»¹¹²² Analoges dürfte im vorliegenden Kontext gelten, wenn die hier vertretenen Modifikationen (Teilnahmerecht der Verteidigung und audiovisuelle Aufzeichnung der Exploration) dereinst umgesetzt werden. Zwar ist es nachvollziehbar, dass für den psychiatrischen Sachverständigen die beschuldigte Person nicht nur ein Prozesssubjekt mit Verfahrensrechten, sondern auch – kraft strafbehördlichem Auftrag unvermeidlich – ein Forschungs- bzw. Beweisobjekt ist.¹¹²³ Bei dieser Ausgangslage besteht das natürliche Bestreben des Sachverständigen darin, die Untersuchungsbedingungen zu optimieren, um ein möglichst valides Untersuchungsergebnis zu erhalten. Entsprechend mögen dem Sachverständigen verfahrensrechtliche Eingriffe in seine Methodik als unzulässige Einmischung vorkommen.

Die hier vorgeschlagenen Modifikationen sollen aber weder als unsachliche Eingriffe in die Arbeitsmethodik der Psychiatrie noch als generelles Misstrauensvotum gegenüber psychiatrischen Sachverständigen verstanden werden. Zwar mag es sein (wie selbst forensisch-psychiatrische Sachverständige einräu-

¹¹²¹ Für den Abschnitt N 412 ff.

¹¹²² WOHLERS, fp 2019, 211.

¹¹²³ DIPPEL, Diss., S. 52.

men¹¹²⁴), dass in den Reihen forensisch tätiger Psychiaterinnen und Psychiater nicht nur Vorbilder tätig werden. Die überwiegende Mehrheit von psychiatrischen Sachverständigen wird ihre Arbeit jedoch mit grosser Sorgfalt für methodische und juristische Vorgaben sowie mit hoher Achtung für die Würde des begutachteten Individuums verrichten. Nur ändert diese Tatsache nichts daran, dass die beschuldigte Person als Subjekt des Strafverfahrens einen Anspruch darauf hat, dass ihre Bedürfnisse auf die effektive Überprüfbarkeit des Gutachtens sowie der Schutz ihrer Rechte während der Exploration gewahrt werden, und diese Rechte können (wie in der vorliegenden Arbeit ausführlich aufgezeigt) selbst dann exponiert sein, wenn der psychiatrische Sachverständige nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet.

- 440 Die hier vorgeschlagenen, konventionsrechtlich begründeten Änderungen sind daher keine verbotene Einmischung in die Begutachtungsmethodik der Psychiatrie, sondern die unvermeidbare Folge der Tatsache, dass der psychiatrische Sachverständige seine Arbeit auf dem Territorium des Strafprozesses verrichtet.¹¹²⁵ Nimmt sich der Sachverständige dieser Aufgabe an, hat er sich der von KONRAD/RASCH vertretenen Haltung zu verpflichten: «Ein...Psychiater, der als Sachverständiger vor Gericht Verpflichtungen annimmt, hat sich den dort geltenden Regeln anzupassen».¹¹²⁶ Und zu diesen Regeln gehören wie dargelegt die audiovisuelle Aufzeichnung der Exploration sowie ein Teilnahmerecht der Verteidigung.

¹¹²⁴ KRÖBER, FPPK 2015-A, S. 192 f.

¹¹²⁵ Vgl. zu diesem systematischen Aspekt auch OBERHOLZER, Praxis, S. 56.

¹¹²⁶ KONRAD/RASCH, S. 19.

Sachregister

Sämtliche Angaben verweisen auf die Randnoten im Manuskript.

A

Abstinenz, normative 128, 139 ff.

Abweichen (vom Gutachten) 121, 125, 135

Adversarial allegiance 149 f., 225

Akteneinsicht 44 f., 48, 104, 107, 173, 175, 177 ff., 209, 247

Aktengutachten 10, 355

AMDP 181, 196

Anamnese 13, 114, 180, 409

Angaben des Exploranden 180, 363

Anknüpfungstatsachen 8, 21, 112, 154, 180

Anwalt der ersten Stunde 286

Anwesenheit 19 f., 46, 51 f., 53 f., 56, 63, 74 f., 85, 255, 279, 289, 295, 337, 345, 350 f., 359, 369, 400, 402 f., 415, 421, 423, 433

Analysen, apparative 9

Analysen, labortechnische 9

Atmosphäre (auch: Gesprächsatmosphäre) 17 f., 168, 212, 325, 338, 349

Aufgabenverlagerung (s. Delegation)

Aufwärmphase 17

Aufzeichnung, audiovisuelle 239, 254, 256, 257 ff., 388 ff., 415, 417, 419, 421 ff.

Augenschein 46, 59, 246 ff., 253 f., 403

Augenscheinkomponente 242, 244, 246 ff., 253 f.

Augenscheinsurrogat 254, 256

Auslegung 32, 38 ff., 83 ff., 130 f., 146, 315, 384, 426

Aussage-

-inhalte 246, 253, 256

-modifikation 378 f., 381, 435, 439

-rückzug 378 f., 435

-strategie 28, 354, 385, 393, 400, 413, 435

-verweigerungsrecht 17, 28, 74, 77, 80, 292, 311, 324, 341, 371 ff., 382

-würdigung 205 f., 231 f., 237, 279

Ausschluss (von Drittpersonen oder der Verteidigung) 19 f., 36, 43 f., 46, 50, 53, 58 f., 61, 64, 295 ff., 300, 345 ff., 356 ff., 381, 414 f., 433 ff.

Ausstand, Ausstandsgrund, Ausstandsgründe 106, 143 ff., 148 f., 172 f., 176, 203, 205, 207, 259, 339, 405

B

Beauftragung (des Sachverständigen) 102, 105, 149 ff., 162, 214, 225 f., 401, 429,

Befangenheit, befangen (vgl. auch: Ausstand) 106, 144, 172, 207 f., 214, 228

Befragungsverbot (s. Verbot der Befragung zum Tatsachverhalt)

Befund, psychischer 14, 114, 123, 167, 180 f., 187, 233, 246, 253

Befundtatsachen 8, 121, 311,

315 ff., 403

Behandlungsbereitschaft, -fähigkeit, -motivierbarkeit 16

Behandlungsprognose 6, 136, 157

Belastungszeuge 97

Belehrung 17, 74, 80, 82, 170, 214, 294, 309, 311 ff., 315, 317, 327, 336 f., 340 f., 361, 370, 371 ff., 381 f., 404, 431 f., 435

Beobachterstellung 201, 218, 250, 349, 352, 428

Beschleunigungsgebot 362

Beweisantrag 104, 106

Beweis

-eignung 19, 322

-erhebung 3, 8, 15, 59, 67, 71, 78, 80, 82, 84 f., 88, 111 f., 161, 166, 169 ff., 287, 362, 422

-erhebungsmethoden 170, 194, 205

-erhebungsregeln 169

-führung 4 ff., 397

-kraft 121, 123, 228, 298, 407

-last 293, 296 ff., 300, 324, 360, 382, 435

-mittel 22 f., 101, 117, 124, 178, 214, 226 f., 242, 264, 306, 379, 406

-problem 205, 378

-regeln 3, 119, 206

-wert 214, 219, 227, 395 ff., 428

-würdigung 3, 8, 101, 104, 111, 116 ff., 126, 147, 171, 206, 220, 227, 231, 234, 237, 259, 314, 379, 380, 404, 407, 422, 427

Beziehungsaufbau (s. Vertrauensbeziehung) 19, 168, 335, 345,

Biologisch-psychologische Methode 5

Blackbox 27

C

Compelling reasons (s. zwingende Gründe)

D

Deliktdynamik 15

Deliktsmechanismus 15, 322

Diagnose(n) 21, 123, 130, 134, 136, 157, 244

Diagnoseinstrumente, 123, 153, 157, 181

Differentialdiagnose(n) 21

Dokumentationspflicht 178 ff.

Dokumentationsstandard 241 ff., 247, 257, 267, 279 f., 421, 429 f.

Dokumentationssysteme 181

Doppelbegutachtung 227, 229, 429

Druck, politisch-medialer 152 ff., 162, 225, 427

Druck, psychischer 293, 325 ff.

E

Einsicht (s. Akteneinsicht)

Einvernahmekomponente 243 ff., 253

Einwendungen 47, 201, 205, 220, 251, 298, 378 f., 380 ff., 428, 435.

Empfehlungen (des Sachverständigen) 132, 135, 139, 148

Ergänzungsfrage(n) 45 ff., 85, 173, 367, 413, 423

Erhebungen, einfache 8, 77 f., 114, 246, 302 f.

Ermessensspielräume 156 f., 159, 162, 181, 281, 427

Ermittlungsverbot des Sachverständigen 112 ff., 318

F

Fachliches Ermessen 11, 54, 85, 155, 193

Fachstandard(s) 168, 355,

Folgebeweis 406

Fragenkatalog 129 ff.

Freie(r) Verkehr 46, 289 f., 300, 344, 375 ff., 382, 431, 435

Fremdanamnese(n) 9, 21, 46, 52

Fürsorgefunktion 28, 89, 283

G

Gefährlichkeit 133

Gehilfe des Gerichts 116 f., 125

Gesamtwürdigung 36, 105 ff., 148, 151, 153, 159, 165, 174, 209, 216, 220, 288, 293, 296 ff., 360 ff., 386, 423, 435

Gesetzgeber 7, 24, 40 f., 68 ff., 82, 87, 90 ff., 114, 222, 309, 426

Gesprächsführungsmethodik 18, 374

Gesprächsführungstechnik 326

Geständnis 321, 326, 329, 362 f., 373, 400

Glaubhaftigkeits-Bias 205 ff., 215, 220, 231 f., 237, 240, 251, 279, 340, 364, 428 f.

Gültigkeitsvorschrift 314

H

HCR-20 123

I

In dubio pro reo 3, 324, 407

Informationsfilterung und -selektion 190

Informationsinteresse 326 f., 341,

365, 369, 432

Interesse, öffentliches 377

Interpretationsspielräume 156, 157, 233, 269, 270, 272, 281, 430

Intransparenz 212, 214, 218, 219, 226, 229 f., 278, 378

Iudex facti 117, 125

Iura novit curia 127 f., 139

K

Knowing and intelligent waiver (s. Verzicht)

Kompensation 105, 209 ff., 219

Konfliktverteidigung 420

Kongruenz 90, 94, 167, 303 ff., 341, 342, 432

Kontradiktorisch, Kontradiktion 25, 26, 56, 65, 221, 271, 281

Kooperation 170, 325 ff., 331, 338, 341, 372 f., 432

Kosten 138, 238, 265, 276, 419, 421, 423, 437

L

Lebenspartner (als Beistand) 52

Legalprognose 410 f. (siehe auch Risikobeurteilung)

M

Mandatierung (siehe auch Beauftragung) 148, 216, 224

Massnahme, ambulante 6, 133, 137

Massnahme, stationäre 6, 133, 137

Massnahme, therapeutische 6

Massnahmenindikation 7, 10, 15, 16, 21, 23, 33, 34 ff., 111, 113, 114,

116, 120, 126, 128, 133, 135, 137,
141, 147 f., 152 f., 158, 159, 164 f.,
202, 216 f., 221, 224, 270, 273,
282, 305, 312, 318, 323 f., 326,
330, 332, 334, 340 ff., 361 ff., 386,
396 ff., 424, 427, 438

Materielle Wahrheit 3, 4, 7, 21,
25, 37, 112, 119, 155, 161, 417

Methodenfreiheit 11, 44, 48 f., 54,
56, 64, 239, 240, 267, 279, 356 f.,
386

Methodenstandard 10, 30, 36,
138, 239, 240, 260, 300, 344 ff.,
350, 356, 358 ff., 412, 414 f., 425

Mitwirkungsrechte 81, 85

N

Nachtatverhalten 15

Nemo tenetur 28, 283, 288,
292 ff., 298, 304, 305 ff., 325 ff.,
335, 339, 341, 353 f., 359, 365,
371, 382, 385, 390, 398, 402 ff.,
411, 413, 416 f., 422 f., 431 f.,
434 ff.

Neutralität (des Sachverständigen)
18 f., 57, 65, 100, 102, 105 ff.,
142 ff., 162, 216, 224 ff., 259, 282,
373

Neutralitätsdefizite 105, 151, 154,
159, 172, 225, 427

Neutralitätskriterium 102 ff., 223,
259

Neutralitätssicherung 224

Neutralitätszweifel 106, 145, 228

O

Objektivität 106, 154 f., 157, 159,
184, 188 f., 197, 224

Ordnungsbusse 419, 423, 437

P

PCL-R 123, 260

Personalunion 146, 148, 427

Persönlichkeit 14, 50, 56, 65, 114,
133, 167, 181, 185, 187, 196, 199,
233, 201, 246, 253, 270, 322, 329

Persönlichkeitsrechte 56, 85, 238,
279

Plausibilität 22, 125, 142, 159

Position und Rolle (des Sachver-
ständigen) 99, 100, 102, 103, 105,
109, 110 ff., 159, 164, 216 f.,
223 ff., 230, 259, 278, 428, 429

Privatgutachten (methodenkriti-
sches und Vollbegutachtung) 107,
209, 211, 212, 214, 227, 428

Privatkläger 236 ff., 258, 263, 275

Privatsachverständige(r) 73, 104,
106, 107, 173, 210 ff., 219, 227 f.,
235, 279

Prognose 135, 136, 207, 324

Prognoseinstrumente 157, 181

**Protokollierung, Protokollier-
ungspflicht** 179 ff., 196, 248 ff.,
280, 288, 313, 430

**Prozessökonomie, prozessöko-
nomisch** 78, 409

Prozesssubjekt 25, 26, 368, 438

Psychiatrisch-normative Methode
5

Q

Qualität der Beweise 298, 364.

Quantifizierung 130 f.

R

Rapportierung 167, 183, 204, 205,
217, 220, 224, 226, 229, 382, 428

Ratio legis 90, 317

Realprognose 410 f.

Recht

- Recht auf Beizug einer Verteidigung 288, 294, 295, 298 f., 300, 304 f., 339, 343, 370

- Recht auf Einsicht (s. Akteneinsicht)

- Recht auf Stellungnahme (s. Stellungnahme)

- Recht zu schweigen und nicht mitwirken zu müssen (s. nemo tenetur; Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht)

Rechtsbeistand 46, 50 f., 56, 57, 59 f., 63 ff., 77, 85, 143, 366, 425

Rechtsmissbräuchlich 420, 423

Reflexwirkungen 44, 48, 56, 65, 236, 238, 240, 280, 416

Relevanz, Relevanz(kriterium) 10, 15, 101, 105, 111 ff., 114, 116, 118, 128, 133, 135, 142, 162, 170, 207, 223, 227, 244, 282, 319, 332, 336, 340, 363, 410 f.

Richter in Weiss 1, 23, 162, 216

Richterfunktion 146, 216, 225

Risikobeurteilung 6, 15, 134, 150, 157, 170, 244, 316, 323

Rückfallrisiko 6, 16

S

Sachverhaltsermittlung 112, 115 f., 126, 148, 427

Sachverhaltsfeststellung 22, 156, 206, 233, 401

Schuldunfähigkeit 23, 129, 130, 140, 333, 366

Schweigepflicht 17, 309, 335, 349, 358, 371, 432

Selbstbelastungsgefahr(en) 305, 318, 320, 323 f., 385, 393

Selbstbestimmung, informationelle 274

Selbstreflexion 14, 188, 191, 205, 415

Staatsanwalt in Weiss 22, 115, 162, 216

Steuerungsfähigkeit 5, 21, 130 f., 132, 140

Störfaktor 267, 281, 348 f., 351, 358, 430

Störung der Exploration 239, 252, 268

Strafzumessung 22, 305, 316, 320, 321, 332, 340, 341, 342, 361, 363, 373, 381, 385, 393, 399 f., 410, 431

Subjektstellung 62

Suggestivfrage(n) 18, 168, 171, 353, 405

Suggestivwirkung 132, 136

T

Tatfrage 129 f., 134, 391

Tatinterlokt 391 ff., 396, 400, 422, 436

Tatnachweis 320, 322, 332, 340, 342, 363, 373, 381, 392 ff., 413, 431

Tatqualifikation (s. Qualifikation der Tat)

Tatsachenmosaike, selbstbelastende 321, 400

Tatsachverhalt 15, 114, 384 ff., 400 f., 422, 436

Täuschung 170, 293, 335 ff., 432

Teildelegation 113, 118

Teilnahmerechtskumulation 154

Teilnehmerkreis 19, 46, 50, 54

Tonband 179, 256, 430

Transparenz 27, 258 f., 280 f., 365, 389, 430, 435,

Transparenzdefizite (siehe auch Intransparenz) 209, 219, 220, 226, 240, 428 f.

U

Übersetzer 20, 55, 64, 168, 351, 433

Unabhängigkeit 143, 153, 259

Unabhängigkeit 143, 153, 259

Untersuchung, testpsychologische 9

Untersuchungsgrundsatz 3, 21, 112, 273

Unverwertbarkeit, unverwertbar 171, 314, 407 f., 410 f., 422

V

Verbot der Befragung zum Tatsachverhalt 384 ff., 436

Verfahrensfairness 24, 35, 105, 107, 142, 148, 153, 163, 216, 228, 278, 293 f., 299, 300, 305, 360, 363, 365, 369, 381, 403, 435

Verhältnismässigkeit 105, 109, 133, 135, 138, 141

Verletzlichkeit 200, 202, 288, 298, 331 ff., 365 ff., 390, 428, 432, 435

Vernehmung (s. Einvernahme)

Vernehmungsbeamter 328

Vertrauensbasis 18, 64, 74

Vertrauensbeziehung 19, 345

Vertrauensverhältnis 53, 349, 358, 433

Verwahrung 6, 137, 152

Verwertbarkeit 310 ff., 318, 364, 403, 413, 435

Verwertungsverbot(e) 298, 314, 398 ff., 436

Verzerrungseffekte 184, 186 ff., 192, 195, 233

Verzicht (auf Verteidigungsrechte) 294 f., 370, 381, 435,

Vier-Augen-Gespräch 20, 279, 345, 349

Vorbefassung 146 ff.

Vorhalt(e) 313, 314, 327, 399

Vorleben 114, 312, 321, 330

Vorstrafen 13, 244

W

Waffengleichheit 26, 56, 57, 65, 103, 109, 163, 223, 224, 227, 278, 282, 287, 288, 343, 425, 437

Wahrheitsrekonstruktion 3, 18, 25, 112

Wahrheitssuche 4, 19, 25, 26, 30, 64, 119, 168, 252, 261, 271, 355, 357, 420

Weichenstellung 23, 132, 136, 152,

Willensabhängigkeit (des Beweismittels) 306, 307, 316 f., 324, 341, 431

Z

Zeugnisverweigerungsrechte 80, 312

Zwang 288, 292 f., 298, 306, 308, 325, 335, 341, 364 f., 413

Zwingende Gründe (für den Ausschluss der Verteidigung) 80, 295, 297 ff., 344, 356, 434